



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN

Manual para Ejercer el Derecho Corporativo

TOMO II

Derecho Mercantil · Derecho Corporativo (Corporate Law)

13 CAPÍTULOS · EDICIÓN FINAL, VOZ CONSOLIDADA

ELIAS ALEJO
Biblioteca Jurídica AJE
Agosto de 2026

ÍNDICE DEL TOMO II

PARTE III — DERECHO MERCANTIL

[Nivel III · Libro 5] Mercado de Valores (LMV)

[Nivel III · Libro 6] Concurso Mercantil

[Nivel III · Libro 7] Gobierno Corporativo

PARTE IV — DERECHO CORPORATIVO (CORPORATE LAW)

[Nivel IV · Libro 1] Fundamentos de Fusiones y Adquisiciones (M&A)

[Nivel IV · Libro 2] Due Diligence (Debida Diligencia)

[Nivel IV · Libro 3] Estructuras de la Operación: Fusiones, Escisiones y Adquisiciones

[Nivel IV · Libro 4] La Documentación de la Operación: Term Sheet, SPA, APA y SHA

[Nivel IV · Libro 5] Derecho Bancario y Financiamiento Corporativo

[Nivel IV · Libro 6] Contratos Estratégicos y Joint Ventures

[Nivel IV · Libro 7] Private Equity y Venture Capital

[Nivel IV · Libro 8] Gobierno Corporativo Avanzado, Compliance y ESG

[Nivel IV · Libro 9] Fiscal Corporativo y Planeación Fiscal de Operaciones

[Nivel IV · Libro 10] Competencia Económica y Control de Concentraciones



PARTE III

Derecho Mercantil

PARTE III

[Nivel III · Libro 5] Mercado de Valores (LMV)

☞ **Apóstrofe de vigencia — léela cada vez.** El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: «*¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente*» (textos oficiales en *.../.../fuentes-legales/*). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como «**Derogado**». Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

Cuando una empresa necesita capital a una escala que ningún banco le presta, acude al **público inversionista**: emite **valores** (acciones, deuda) que se negocian en la **bolsa**. El mercado de valores es el sistema que canaliza el ahorro de millones hacia las empresas, bajo una premisa: **información veraz y oportuna** para que el inversionista decida. Aquí la sociedad anónima alcanza su forma máxima —la **S.A.B.**—, nace la **IPO**, y el gobierno corporativo se vuelve obligatorio y reforzado. Es el escenario del financiamiento corporativo de élite y del M&A público.

Etiquetas: derecho mercantil · mercado de valores · emisoras (S.A.B.) · IPO · CNBV · gobierno corporativo bursátil **Prerrequisitos:** Sociedades (LGSM), Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC), Economía para juristas. **Estándar:** V3 (43 secciones + secciones transversales). ⌚ **Tiempo estimado de dominio:** 5–6 semanas (≈ 55–70 h de estudio activo). Lectura de reconocimiento: 10–12 h. *Estúdialo en bloques: estructura del mercado e intermediarios → emisoras y oferta pública (IPO) → instrumentos → gobierno corporativo bursátil y regulación.*

Aviso de método. Tratado, no repaso. Es la materia que conecta el derecho societario con las finanzas y el M&A público: la trabajamos con profundidad, ejemplos trabajados, "cómo razona un socio" y conexión con IPO, OPA, gobierno corporativo y financiamiento.

NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL (VISTA RÁPIDA)

Litigio	★★★☆☆
Corporate	★★★★★
M&A	★★★★★
Mercado de Valores	★★★★★
Venture Capital	★★★★☆
Private Equity	★★★★★
Gobierno Corporativo	★★★★★
Compliance	★★★★★
Derecho Bancario	★★★★☆
Empresa Familiar	★★★☆☆

Es el techo del financiamiento corporativo y la antesala del M&A público (OPAs), las IPO y el gobierno corporativo de clase mundial.

1. Introducción

Hay dos formas de financiar una empresa grande: el **crédito** (que ya estudiamos: bancos, LGTOC) y el **mercado de valores** (acudir al público inversionista). El mercado de valores resuelve un problema económico mayúsculo: **conectar a quienes tienen ahorro** (millones de inversionistas, fondos de pensiones, aseguradoras) **con quienes necesitan capital** (las empresas), a una escala que ningún intermediario individual podría. La empresa emite **valores** —**acciones** (capital) u **obligaciones/certificados** (deuda)— que se colocan entre el público y luego se negocian en la **bolsa**, dándoles **liquidez**.

La idea central de este libro: el mercado de valores funciona sobre una premisa innegociable —la **información**—. Como el inversionista no conoce la empresa, la ley exige **transparencia total** (*disclosure*): la emisora debe revelar su situación financiera, sus riesgos y los hechos relevantes, de forma veraz y oportuna; y se **prohíbe** usar información privilegiada (*insider trading*) y manipular el mercado. Por eso la sociedad que cotiza —la **S.A.B.**— está sujeta a un régimen **reforzado** de gobierno corporativo (consejo con independientes, comités, deberes fiduciarios agravados) y a la supervisión de la **CNBV**. Para el abogado corporativo, este es el escenario del financiamiento de élite, de la **IPO** (salida a bolsa) y del M&A

público (OPAs): el campo de los despachos y los socios de primer nivel.

2. Objetivos del libro

Al terminar, el lector será capaz de:

- **Entender la estructura del mercado de valores:** emisoras, inversionistas, **intermediarios** (casas de bolsa), bolsas (BMV, BIVA), **Indeval** (depósito y liquidación) y el regulador (CNBV).
- **Dominar el concepto de valor** y los principales **instrumentos**: acciones, **certificados bursátiles** (deuda), obligaciones, **FIBRAS** y **CKDs/CERPIs** (vehículos de inversión).
- **Manejar la oferta pública y la IPO**: requisitos de inscripción en el RNV, **prospecto de colocación**, *due diligence*, *underwriting* (colocación) y listado.
- **Comprender la S.A.B. y su gobierno corporativo reforzado**: consejo, **consejeros independientes**, comités de **auditoría** y de **prácticas societarias**, deberes de **diligencia y lealtad** agravados.
- **Aplicar el régimen de información y conducta**: *disclosure* de eventos relevantes, prohibición de **uso de información privilegiada** y de **manipulación de mercado**.
- **Conectar con el M&A público**: la **oferta pública de adquisición (OPA)**, las tomas de control y la protección de minoritarios.

3. Importancia profesional

El mercado de valores es el **techo del derecho corporativo y el financiamiento**:

1. **Es el financiamiento a gran escala.** Las IPO y las emisiones de deuda (certificados bursátiles) captan miles de millones; estructurarlas es trabajo de los despachos líderes.
2. **Es el escenario del M&A público.** Las **OPAs** (ofertas públicas de adquisición), las tomas de control de empresas listadas y las fusiones de públicas son operaciones de máxima complejidad y valor.

3. **Define el gobierno corporativo de élite.** El régimen de la S.A.B. (consejeros independientes, comités, deberes fiduciarios) es el estándar de gobierno que luego se exporta a las empresas privadas.
4. **Es el corazón del compliance financiero.** El *insider trading*, la manipulación de mercado y el *disclosure* son materia de altísimo riesgo regulatorio y penal.

4. Historia de la institución

- **Orígenes:** las primeras **bolsas** nacieron para negociar las acciones de las grandes compañías coloniales (Ámsterdam, s. XVII — la VOC, Libro 2 Nivel III) y la deuda pública. El mercado de valores creció con el capitalismo industrial (s. XIX), financiando ferrocarriles e industrias.
- **La gran lección regulatoria (1929):** el **crac de 1929** y la Gran Depresión revelaron los peligros del mercado sin regulación (fraudes, manipulación, falta de información). La respuesta de EE. UU. fue fundacional: la **Securities Act de 1933** (regula la **oferta**: disclosure, prospecto) y la **Securities Exchange Act de 1934** (regula el **mercado secundario** y crea la **SEC**). Estas leyes —basadas en el principio de **full disclosure**— son el ADN de toda la regulación bursátil mundial.
- **México:** la **Bolsa Mexicana de Valores** tiene raíces en el s. XIX; la regulación moderna se consolidó con la **Ley del Mercado de Valores de 1975** y, sobre todo, con la **LMV de 2005** (vigente, reformada), que modernizó las emisoras, creó la **S.A.B.** y la **S.A.P.I.** (Libro 2 Nivel III), reforzó el gobierno corporativo y endureció el régimen de información privilegiada. En 2014 surgió **BIVA** como segunda bolsa, rompiendo el monopolio de la BMV.

5. Evolución histórica

- **Del mercado libre al mercado regulado:** del *laissez faire* bursátil del s. XIX al régimen de *disclosure* y supervisión tras 1929 (SEC). La regulación es la condición de la **confianza**.

- **De la acción al portafolio de instrumentos:** del simple título accionario a una **gama** de valores (deuda corporativa, estructurados, derivados, vehículos de inversión: FIBRAS, CKDs, CERPIs).
- **De la BMV monopólica a la competencia (BIVA, 2018) y a la internacionalización** (SIC —Sistema Internacional de Cotizaciones—, *dual listings*, ADRs en EE. UU.).
- **De la desmaterialización a la digitalización:** los valores se manejan por **anotaciones en cuenta** (Indeval; Libro 3 Nivel III: desmaterialización del título), y emergen las *fintech*, el *crowdfunding* (Ley Fintech) y los activos digitales.
- **Del gobierno corporativo voluntario al obligatorio:** los **códigos de mejores prácticas** (voluntarios) se volvieron, en buena parte, **derecho positivo** para las S.A.B. (LMV): consejeros independientes, comités, deberes fiduciarios.

Idea de evolución clave: la historia del mercado de valores es la historia de la **confianza regulada**. Cada crisis (1929, 2008, fraudes corporativos como Enron) produjo más **información**, **más gobierno corporativo y más supervisión**. El derecho bursátil es, en esencia, **derecho de la información y de la confianza**.

6. Contexto económico

El mercado de valores cumple funciones económicas centrales (Libros 9 y 10, Nivel I):

- **Canalización del ahorro a la inversión:** conecta el ahorro disperso (incluidos los fondos de pensiones —Afores—) con las empresas que necesitan capital. Es un motor del **crecimiento**.
- **Asignación eficiente y formación de precios:** el precio de mercado de un valor refleja (idealmente) toda la información disponible (**hipótesis de mercados eficientes**, Libro 10) y guía la asignación de capital hacia las empresas más prometedoras.
- **Liquidez:** la bolsa permite **vender** la inversión rápidamente, lo que la hace atractiva.

- **Disciplina de mercado:** el precio de la acción y la amenaza de una **OPA hostil** disciplinan a los administradores (mercado por el control corporativo — resuelve el problema de agencia, Libro 9). La **asimetría de información** (Akerlof, Libro 9) es el problema central que la regulación de *disclosure* combate: sin información veraz, el mercado de "limones" colapsaría.

¿Y POR QUÉ LA REVELACIÓN TIENE QUE SER OBLIGATORIA?

Parece una pregunta ingenua y es el debate fundacional de esta materia. Si revelar información **reduce el costo de capital** del emisor —porque el inversionista exige menos prima cuando tiene menos incertidumbre— entonces el emisor tendría **incentivo propio** para revelar, sin que nadie lo obligue. Esa es la objeción de **Easterbrook y Fischel**, y es más fuerte de lo que parece.

La respuesta que hoy predomina la formuló **John Coffee**: hay **bienes públicos informativos**. Parte de la información que produce un emisor es útil para el mercado **en su conjunto** —para comparar, para valuar al sector, para asignar capital— y de esa utilidad el emisor no puede apropiarse. Como no puede cobrarla, la produce por debajo de lo socialmente óptimo. Ese es el fallo de mercado que justifica el mandato.

El otro pilar es la **hipótesis del mercado eficiente** (Fama): si los precios incorporan rápidamente la información pública, entonces obligar a revelar es la forma más eficiente de lograr precios correctos —no hace falta que un regulador juzgue el valor de la empresa, basta con que la información fluya—. Y su matización viene de las finanzas conductuales (**Shiller**): existen burbujas, los precios se desvían de los fundamentos, y por tanto la revelación es necesaria pero no suficiente.

Y una tesis provocadora que conviene conocer para poder rechazarla con argumentos. Henry Manne llegó a defender que el *insider trading* debería permitirse, porque incentivaría a producir información y esta se incorporaría al precio más rápido. Es una posición **minoritaria y rechazada**, y su rechazo se apoya en dos razones que un abogado debe poder articular: destruye la **confianza** en la integridad del mercado —que es su insumo básico—, y hace que el inversionista común descunte sistemáticamente su disposición a participar, encareciendo el capital para todos.

El caso fundacional. *SEC v. Texas Gulf Sulphur* (1968) es la piedra angular del régimen de información privilegiada y fijó el principio de ***disclose or abstain***: quien posee información relevante no pública **revela o se abstiene de operar**. No hay una tercera opción, y esa regla —con sus variantes— es hoy universal.

Y la crítica que la propia materia se hace: la revelación como ritual. El *disclosure* creció hasta la **sobrecarga informativa**: prospectos de cientos de páginas que nadie lee completos, donde el riesgo relevante queda sepultado entre advertencias genéricas. Es el mismo fenómeno que el Libro 4 del Nivel IV describe como carrera armamentista contractual, y produce la misma paradoja: **más páginas, menos protección real**. A Sarbanes-Oxley se le reprochó, en la misma línea, haber encarecido tanto cotizar que empujó a muchas empresas a permanecer privadas —contribuyendo al auge del capital privado del Libro 7 del Nivel IV—.

La lección de oficio, y es la que aplica a tu trabajo mañana: el riesgo real de un emisor casi nunca es haber omitido un dato exótico. Es la **revelación tardía o selectiva** —informar a unos antes que a otros— y la **responsabilidad por el prospecto**. En el episodio de la adquisición de Twitter, por ejemplo, el retraso en la presentación del aviso de participación relevante fue objeto de señalamiento por la autoridad estadounidense [△] **verificar**. Nadie se equivocó en una definición contable: se equivocaron en el calendario.

7. Contexto político

El mercado de valores es estratégico para el Estado: financia el desarrollo, gestiona el ahorro para el retiro (Afores) y es sensible a la **estabilidad financiera**. El Estado regula intensamente vía la **CNBV** (supervisión de emisoras, intermediarios y bolsas), el **Banco de México** (sistemas de pago, política monetaria) y la **SHCP**. La regulación busca **proteger al inversionista** y la **integridad del mercado** (contra el fraude, el *insider trading* y la manipulación), porque la confianza es un bien público: un solo escándalo puede contaminar todo el mercado. La tensión política: **fomentar el mercado** (menos carga regulatoria, más empresas listadas) vs. **protegerlo** (más regulación, más confianza). México tiene un mercado **relativamente pequeño** (pocas emisoras), lo que es, en sí, un tema de política económica.

8. Contexto social

El mercado de valores afecta a la sociedad más de lo que parece: el **ahorro para el retiro** de millones de trabajadores (vía Afores) está invertido en valores; las **crisis financieras** (2008) muestran cómo el mercado puede dañar a toda la economía; y la **democratización de la inversión** (apps de inversión, *fintech*) acerca el mercado a más personas, con oportunidades y riesgos. La **protección del inversionista** —especialmente el pequeño y el no sofisticado— es un objetivo social, igual que la **educación financiera**. Un mercado de valores sano y confiable es infraestructura social, no solo económica.

9. Contexto empresarial

Para la empresa, el mercado de valores es la **gran liga del financiamiento**:

- **Salir a bolsa (IPO)**: convertirse en **S.A.B.** y captar capital del público; da acceso a financiamiento, liquidez para los socios y prestigio, pero impone **transparencia**, **gobierno corporativo reforzado** y escrutinio permanente.

- **Emitir deuda (certificados bursátiles):** financiarse con el público sin diluir el capital (alternativa al crédito bancario, a menudo más barata para grandes emisores).
- **Vehículos de inversión: FIBRAS** (inmobiliario), **CKDs/CER-PIs** (capital privado/proyectos): vehículos bursátiles que canalizan inversión a sectores específicos.
- **El costo de ser pública:** *disclosure* continuo, gobierno corporativo, comités, auditoría, responsabilidad agravada de administradores. Muchas empresas (y familias) valoran la **privacidad** de no cotizar.
- **M&A público:** ser pública expone a **OPAs** (incluso hostiles); la empresa debe tener defensas y gobierno robusto.

El abogado corporativo de élite asesora **IPOs, emisiones de deuda, OPAs y el gobierno corporativo** de las emisoras: el trabajo más sofisticado y mejor remunerado del derecho de los negocios, y la antesala directa del M&A del Nivel IV.

10. Definiciones doctrinales

- **Mercado de valores (doctrina):** el conjunto de mecanismos, instituciones y normas a través de los cuales se emiten, colocan y negocian **valores** entre el público inversionista, bajo supervisión estatal, con el fin de canalizar el ahorro hacia la inversión productiva.
- **Valor (doctrina):** instrumento —típicamente desmaterializado— que representa un **derecho de crédito** (deuda), de **participación** (acciones) o de otra índole, **susceptible de oferta y negociación** en el mercado, y emitido en **serie o en masa**. Comparte naturaleza con el título de crédito (Libro 3) pero con vocación de **circulación masiva y estandarizada**.
- **Mercado primario vs. secundario:** en el **primario**, la emisora **coloca** los valores por primera vez y recibe el capital (IPO, emisión de deuda); en el **secundario**, los inversionistas los **negocian entre sí** en la bolsa (la emisora ya no recibe dinero, pero el secundario da **liquidez** y forma el **precio**).

- **Full disclosure (principio rector):** la idea —de raíz estadounidense (Securities Act 1933)— de que la protección del inversionista se logra **obligando a revelar** información veraz, suficiente y oportuna, para que **el inversionista decida**, no prohibiéndole invertir.

Lectura del Consejo: el mercado de valores no protege al inversionista diciéndole "esto es buena inversión"; lo protege **obligando a la emisora a decir la verdad** (*disclosure*) y **castigando** al que usa información privilegiada o manipula. La premisa es la **información**: quien lee bien un **prospecto** y entiende el régimen de *disclosure* domina la mitad de la materia.

11. Definiciones legales (LMV — verificar versión vigente)

- **Objeto de la LMV (art. 1 ☞):** regular la oferta pública de valores, su intermediación, las actividades de las personas y entidades del mercado, la organización de las bolsas y del depósito (Indeval), y la protección del público inversionista y la transparencia del mercado.
- **Valor (art. 2 ☞):** las acciones, obligaciones, bonos, certificados, **certificados bursátiles** y demás títulos y documentos que se emitan **en serie o en masa** y sean objeto de oferta pública o intermediación.
- **Oferta pública (art. 2 ☞):** el ofrecimiento, con o sí intermediación, que se haga **al público en general** o a ciertas clases de inversionistas, a través de medios masivos, para suscribir, enajenar o adquirir valores.
- **Emisora / S.A.B.:** sociedad anónima **bursátil**, cuyas acciones (o valores) están inscritas en el **Registro Nacional de Valores (RNV)** y cotizan; sujeta a gobierno corporativo reforzado (arts. 22 ☞ y ss.: consejo, comités, deberes de los consejeros y del director general).
- **S.A.P.I. y S.A.P.I.B.:** etapas previas/de transición hacia la S.A.B. (Libro 2 Nivel III).
- **Intermediarios (casas de bolsa) y bolsas:** régimen de las casas de bolsa, de las bolsas (BMV, BIVA) y del **Indeval** (depósito, administración y liquidación de valores).

- **Información privilegiada y manipulación (arts. 362 º y ss., y delitos arts. 376 º y ss.):** prohibición del **uso de información privilegiada** (*insider trading*) y de la **manipulación del mercado**, con sanciones administrativas y penales.
- **Oferta pública de adquisición (OPA) — arts. 92 º y ss.:** régimen de las ofertas para adquirir el control de emisoras y la protección de los accionistas minoritarios.

12. Definición sencilla

El **mercado de valores** es "la gran feria del dinero": donde las empresas que necesitan **mucho** capital lo piden al **público** (millones de inversionistas), entregándoles **valores** —pedacitos de la empresa (**acciones**) o promesas de pago (**deuda**)— que luego se **compran y venden en la bolsa**. Para que la gente confíe y entregue su dinero, la ley exige a las empresas **decir la verdad** (información), **prohíbe** hacer trampa con información secreta (*insider trading*) o manipular precios, y vigila todo a través de la **CNBV**. Salir a bolsa (**IPO**) convierte a la empresa en **S.A.B.**: consigue mucho capital, pero a cambio debe ser **transparente** y tener **buen gobierno**.

13. Conceptos fundamentales

- **Valor:** instrumento emitido en serie/masa, objeto de oferta pública (acciones, deuda, estructurados).
- **Mercado de capitales vs. de deuda:** **capitales** = acciones (participación); **deuda** = certificados bursátiles, obligaciones (crédito). **Mercado de dinero** = deuda de corto plazo.
- **Mercado primario vs. secundario:** colocación inicial (la emisora recibe el capital) vs. negociación posterior entre inversionistas (liquidez y precio).
- **Oferta pública vs. privada:** dirigida al **público en general** (regulada, con prospecto) vs. a **inversionistas calificados/institucionales** (menos carga, *private placement*).
- **IPO (Initial Public Offering / Oferta Pública Inicial):** la primera colocación de acciones de una empresa al público; "salir a bolsa".

- **Inscripción en el RNV (Registro Nacional de Valores) y listado en bolsa:** requisitos para que un valor pueda ofrecerse y negociarse.
- **Prospecto de colocación:** el documento **estrella** del *disclosure*: describe la emisora, su negocio, sus **factores de riesgo**, su situación financiera y los términos de la oferta. Su veracidad es responsabilidad de la emisora (y de quienes lo firman).
- **Underwriting (colocación):** el proceso por el que un **intermediario** (casa de bolsa/banco de inversión) coloca los valores entre los inversionistas; puede ser **en firme** (el intermediario compra y asume el riesgo) o **a mejores esfuerzos** (best efforts).
- **Intermediarios:** **casas de bolsa** (intermediación), **bancos de inversión** (estructuración), **bolsas** (BMV, BIVA) e **Indeval** (depósito, custodia y liquidación —desmaterialización—).
- **CNBV:** la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, regulador y supervisor del mercado (órgano de la administración, Libro 3 Nivel I).
- **Instrumentos clave:**
 - **Acciones** (capital): participación en la S.A.B.
 - **Certificados bursátiles (CEBURES):** deuda de la emisora (corto o largo plazo).
 - **Obligaciones:** deuda, a veces convertibles en acciones.
 - **FIBRAS:** fideicomisos de inversión en bienes raíces (rentas inmobiliarias bursatilizadas).
 - **CKDs / CERPIs:** certificados de capital de desarrollo / proyectos de inversión (vehículos para canalizar inversión —incluidas las Afores— a **private equity**, infraestructura y proyectos).
 - **S.A.B. (Sociedad Anónima Bursátil):** la emisora; con **gobierno corporativo reforzado:** consejo de administración con **consejeros independientes**, **comité de auditoría** y **comité de prácticas societarias**, y **director general** con deberes fiduciarios (**diligencia** y **lealtad**) agravados.

- **Disclosure / revelación de eventos relevantes:** obligación de informar al mercado, de forma veraz y oportuna, todo **hecho o evento relevante** que pueda influir en el precio del valor.
- **Información privilegiada (*insider information*):** información relevante, **no pública**, cuyo uso para operar valores está **prohibido** (*insider trading*); delito y falta administrativa.
- **Manipulación de mercado:** operaciones o información falsa para alterar artificialmente el precio o el volumen; prohibida.
- **OPA (Oferta Pública de Adquisición):** oferta dirigida a los accionistas de una emisora para **adquirir** sus acciones (típicamente para tomar el **control**); puede ser **voluntaria** u **obligatoria** (al rebasar ciertos umbrales de control), y **amistosa** u **hostil**.

14. Desarrollo absoluto

Lo organizamos en: (A) la estructura del mercado y sus participantes; (B) los instrumentos; (C) la oferta pública y la **IPO** (paso a paso); (D) la **S.A.B.** y su gobierno corporativo reforzado; (E) el régimen de **información y conducta** (disclosure, insider trading, manipulación); (F) el **M&A público**: la **OPA**.

14.A · LA ESTRUCTURA DEL MERCADO Y SUS PARTICIPANTES

- **Emisoras:** las empresas (S.A.B.) o entidades (gobierno, fideicomisos) que **emiten** valores.
- **Inversionistas:** desde el pequeño ahorrador hasta los **institucionales** (Afores, fondos, aseguradoras) e **inversionistas calificados** (con cierto patrimonio/sofisticación, sujetos a menos protección).
- **Intermediarios:** las **casas de bolsa** (ejecutan operaciones, asesoran, colocan) y los **bancos de inversión** (estructuran IPOs, emisiones, M&A).
- **Bolsas:** **BMV** y **BIVA** (mercados organizados donde se negocian los valores).

- **Indeval (S.D. Indeval):** la institución para el **depósito, custodia, administración y liquidación** de valores; hace posible la **desmaterialización** (los valores son anotaciones en cuenta, no papeles —conexión con el Libro 3—).
- **CNBV:** el **regulador y supervisor** (autoriza ofertas, inscribe en el RNV, supervisa, sanciona).
- **Banxico y SHCP:** política monetaria, sistemas de pago y rectoría financiera.

14.B · LOS INSTRUMENTOS (QUÉ SE EMITE Y NEGOCIA)

- **Capital — acciones:** representan participación en la S.A.B.; el inversionista es **socio** (con derechos del Libro 2 Nivel III, adaptados al entorno bursátil).
- **Deuda — certificados bursátiles (CEBURES) y obligaciones:** la emisora pide prestado al público; el inversionista es **acreedor** (cobra intereses). Alternativa al crédito bancario, a menudo más barata para grandes emisores.
- **Estructurados y vehículos de inversión:**
- **FIBRAS** (Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces): bursatilizan **rentas inmobiliarias**; el inversionista recibe la renta de un portafolio de inmuebles (análogo a los REITs).
- **CKDs / CERPIs** (Certificados de Capital de Desarrollo / de Proyectos de Inversión): vehículos para canalizar capital —incluidas las **Afores**— hacia **private equity**, infraestructura y proyectos de largo plazo. (Conexión directa con el Nivel IV: PE.)
- **Derivados:** futuros, opciones, swaps (cobertura y especulación; mercado especializado —MexDer—).

14.C · LA OFERTA PÚBLICA Y LA IPO (PASO A PASO)

La **IPO** (salida a bolsa) es una de las operaciones más complejas del derecho corporativo. Fases:

1. **Decisión y preparación:** la empresa decide salir a bolsa; se **reorganiza** (suele convertirse primero en **S.A.P.I.B.** y luego **S.A.B.**), adopta gobierno corporativo y limpia su estructura.

2. **Due diligence:** los intermediarios y abogados revisan **a fondo** la empresa (legal, financiera, fiscal) para sustentar el prospecto —la veracidad del *disclosure* depende de esto—.
3. **Prospecto de colocación:** se redacta el documento que describe la empresa, su negocio, sus **factores de riesgo** y la oferta. Es el corazón del *disclosure*.
4. **Inscripción en el RNV y autorización de la CNBV:** la CNBV revisa y autoriza la oferta; se gestiona el **listado** en la bolsa (BMV/BIVA).
5. **Underwriting (colocación):** los intermediarios colocan las acciones entre los inversionistas; *roadshow*, formación del libro (*book-building*) y fijación del **precio**.
6. **Listado y mercado secundario:** las acciones empiezan a cotizar; la empresa queda sujeta al *disclosure* continuo y al escrutinio del mercado.

Cómo razona un socio (IPO). *"Una IPO es 30% finanzas y 70% disclosure y gobierno corporativo. Mi trabajo es: (i) reorganizar a la empresa en una S.A.B. con gobierno impecable (consejo, independientes, comités); (ii) dirigir una due diligence brutal, porque el prospecto debe ser veraz —si oculta un riesgo material, hay responsabilidad civil y penal—; (iii) redactar los factores de riesgo con honestidad quirúrgica; y (iv) preparar a la empresa para vivir bajo el escrutinio permanente del mercado. El día del listado, la empresa cambia de naturaleza: pasa a ser pública, y eso es irreversible en su cultura."*

14.D · LA S.A.B. Y EL GOBIERNO CORPORATIVO REFORZADO

Ser pública impone un **gobierno corporativo robusto** (LMV, arts. 22 ♂ y ss.), mucho más exigente que el de la S.A. privada (Libro 2 Nivel III):

- **Consejo de administración** con un mínimo de **consejeros independientes** (al menos el 25%): la independencia busca proteger a los **minoritarios** y resolver el problema de agencia.
- **Comité de auditoría** (integrado por independientes): vigila la información financiera, el control interno y la auditoría externa.

- **Comité de prácticas societarias** (independientes): vigila operaciones con partes relacionadas, compensaciones y conflictos de interés.
- **Director general** con deberes y responsabilidad propios.
- **Deberes fiduciarios agravados**: deber de **diligencia** (actuar informadamente, de buena fe, en el interés social — protegido por la **regla de juicio de negocio/business judgment rule**) y deber de **lealtad** (evitar conflictos, no usar información ni oportunidades de la sociedad, no favorecerse en operaciones con partes relacionadas). Su incumplimiento genera **responsabilidad**.
- **Operaciones con partes relacionadas**: sujetas a revelación, aprobación reforzada y revisión del comité de prácticas societarias (zona de máximo riesgo de abuso).

14.E · EL RÉGIMEN DE INFORMACIÓN Y CONDUCTA (EL CORAZÓN DEL DERECHO BURSÁTIL)

- **Disclosure inicial y continuo**: el prospecto (inicial) y la **revelación de eventos relevantes** (continua): la emisora debe informar, veraz y oportunamente, todo hecho que pueda **influir en el precio** del valor (resultados, contratos relevantes, cambios de control, litigios, M&A).
- **Información privilegiada (*insider trading*)**: está **prohibido** operar valores (o recomendar hacerlo) usando información **relevante y no pública**. Es **delito** y falta administrativa. Ejemplo: un directivo que compra acciones sabiendo de una fusión no anunciada.
- **Manipulación de mercado**: operaciones simuladas, información falsa o esquemas para alterar artificialmente el precio o el volumen; **prohibida** y sancionada.
- **Deber de los intermediarios**: conocer al cliente, idoneidad de las recomendaciones, prevención de conflictos y de lavado de dinero. *Por qué es el corazón*: el mercado vive de la **confianza**, y la confianza vive de la **información veraz** y de la **igualdad** entre inversionistas (nadie con ventaja indebida). Por eso el *disclosure*, el *insider trading* y la mani-

pulación son las materias de **máximo riesgo** —civil, administrativo y penal— y el centro del **compliance** financiero.

14.F · EL M&A PÚBLICO: LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN (OPA)

Cuando se quiere **adquirir el control** de una emisora (sociedad pública), no se negocia solo con un vendedor: hay que dirigirse a **todos los accionistas** mediante una **OPA** (arts. 92 º y ss. LMV):

- **OPA voluntaria:** quien quiere comprar lanza una oferta a los accionistas.
- **OPA obligatoria (*forzosa*):** al pretender rebasar ciertos **umbrales de control** (típicamente el 30% o la toma de control), la ley **obliga** a lanzar una OPA por un porcentaje significativo (a menudo el 100% o un mínimo), para que **los minoritarios** puedan **salir** en las mismas condiciones que el adquirente (protección de minorías; *equal treatment*).
- **OPA amistosa vs. hostil:** con el acuerdo del consejo de la *target* (amistosa) o contra su voluntad (**hostil**, dirigida directamente a los accionistas).
- **Defensas y deberes del consejo:** ante una OPA hostil, el consejo de la *target* debe actuar en el **interés social** y de los accionistas (no atrincherarse para conservar su puesto); emite una **opinión** sobre la oferta (a veces con *fairness opinion*). (Las defensas anti-OPA y los estándares de revisión — Revlon, Unocal— se profundizan en el Nivel IV.)

Conexión con el Nivel IV: la OPA es el **M&A de empresas públicas**. Las tomas de control, las fusiones de emisoras y las defensas anti-adquisición son de las operaciones más sofisticadas y mediáticas, y se rigen por la LMV + el derecho societario + el de competencia. Aquí confluyen todos los libros previos.

15. Explicación intuitiva

Imagina que tu empresa es un restaurante muy exitoso y quieres abrir **cientos de sucursales**, pero necesitas una fortuna que ningún banco te presta. Solución: **vender pedacitos del restaurante al público**. Eso es **salir a bolsa (IPO)**: divides la empresa en **acciones** y las ofreces a miles de personas; a cambio

de su dinero, se vuelven **dueños de un pedacito** y pueden **revender** su pedacito a otros en un "mercado" (la **bolsa**).

Pero hay un problema: esas miles de personas **no conocen** tu restaurante. ¿Cómo confían? La ley resuelve con tres reglas de oro: **(1)** debes **decir toda la verdad** en un documento llamado **prospecto** (cómo va el negocio, cuánto ganas, qué riesgos hay); **(2)** está **prohibido hacer trampa** con información secreta (si sabes que vas a anunciar algo bueno y compras acciones antes, eso es **insider trading**, delito) o inflar el precio artificialmente; y **(3)** un **árbitro** (la **CNBV**) vigila todo. A cambio del dinero del público, tu restaurante deja de ser "tuyo y privado": se vuelve una **S.A.B.**, con un **consejo** que incluye **personas independientes**, **comités** que vigilan, y la obligación de **informar siempre** al mercado.

Y si alguien quiere **comprar todo tu restaurante** cuando ya es público, no puede negociar solo contigo: debe ofrecer comprar a **todos los dueños** en las mismas condiciones (eso es la **OPA**). Todo este libro trata de cómo funciona esa "feria del dinero" y cómo el derecho la mantiene **confiable** con información, vigilancia y buen gobierno.

16. Ejemplos simples

1. **IPO.** Una empresa de tecnología necesita \$5,000M para crecer. Se convierte en **S.A.B.** y **coloca acciones** entre el público (IPO): miles de inversionistas le entregan capital y reciben acciones que cotizarán en la bolsa.
2. **Certificado bursátil (deuda).** Una empresa, en vez de pedir un crédito bancario, emite **certificados bursátiles** por \$2,000M a 5 años: el público le presta y la empresa paga intereses, sin diluir su capital.
3. **Insider trading.** Un directivo se entera de que su empresa anunciará una fusión que disparará el precio; compra acciones **antes** del anuncio. Es **uso de información privilegiada**: delito y falta administrativa.
4. **Evento relevante.** Una emisora firma un contrato que duplicará sus ingresos: debe **revelarlo** al mercado como **evento relevante**, de forma veraz y oportuna.

5. **OPA.** Un inversionista quiere adquirir el control de una emisora; debe lanzar una **oferta pública de adquisición (OPA)** a **todos** los accionistas, no comprar solo a unos cuantos en secreto.

17. Ejemplos complejos

1. **IPO y responsabilidad por el prospecto.** Una empresa sale a bolsa; el **prospecto** omitió un **riesgo material** (una contingencia ambiental grave). Tras el listado, el riesgo se materializa y la acción se desploma. Los inversionistas demandan: la emisora y quienes firmaron el prospecto responden por la **información engañosa u omisa**. Lección: la **due diligence** y la veracidad del prospecto son responsabilidad seria (civil, administrativa y penal).
2. **OPA obligatoria y protección de minoritarios.** Un grupo adquiere sigilosamente acciones hasta rebasar el umbral de **control** sin lanzar OPA. La CNBV interviene: debió lanzar una **OPA forzosa** para que los minoritarios pudieran **salir** en las mismas condiciones (equal treatment). Lección: tomar el control de una pública **dispara** la obligación de OPA; eludirla es sancionable.
3. **OPA hostil y deberes del consejo.** Un postor lanza una OPA **hostil** (sin acuerdo del consejo de la *target*). El consejo debe actuar en el **interés de los accionistas** (no atrincherarse para conservar su puesto); emite su opinión y, en su caso, busca un **caballero blanco** (otro postor mejor). Lección: ante una OPA, los deberes fiduciarios del consejo se ponen a prueba (Nivel IV: Revlon/Unocal).
4. **Operación con parte relacionada.** El director general de una S.A.B. quiere que la empresa compre un inmueble a una sociedad de su propiedad. Es una **operación con parte relacionada**: debe revelarse, pasar por el **comité de prácticas societarias** y aprobarse sin su voto, a precio de mercado. Lección: las partes relacionadas son zona de máximo riesgo de conflicto de interés.

18. Casos reales (jurisprudencia, regulación y operaciones estilizadas)

- **Securities Act 1933 / Exchange Act 1934 (EE. UU.):** el modelo mundial de *full disclosure* y la creación de la SEC; base conceptual de la regulación bursátil (incluida la mexicana).
- **Sarbanes-Oxley (2002) y los escándalos Enron/WorldCom:** el fraude contable de Enron detonó una reforma global del **gobierno corporativo**, la **auditoría** y la **responsabilidad de directivos** (certificación de estados financieros). Influyó en el reforzamiento del gobierno corporativo en la LMV de 2005.
- **Insider trading (casos emblemáticos):** sanciones a directivos e inversionistas por operar con información privilegiada (en EE. UU., casos célebres; en México, sanciones de la CNBV).
- **OPAs en México (operaciones estilizadas):** tomas de control de emisoras vía OPA, con protección de minoritarios y revisión de la CNBV.

Nota de método (Manifiesto XI.5): verificar la vigencia y los datos de los casos y normas antes de invocarlos; se exponen por su valor formativo.

19. Casos empresariales

- **Decisión de salir a bolsa (IPO) o permanecer privada:** sopesar el acceso a capital y liquidez vs. el costo de la transparencia, el gobierno corporativo y el escrutinio. Muchas familias eligen seguir **privadas** (o usar **S.A.P.I.**) para conservar el control y la privacidad.
- **Financiamiento vía deuda bursátil:** una empresa grande emite **certificados bursátiles** para financiarse más barato que con crédito bancario.
- **FIBRA inmobiliaria:** una empresa con un portafolio de inmuebles los aporta a una **FIBRA** y bursatiliza sus rentas, captando capital y dando liquidez a los inversionistas.

- **Afores y CKDs:** los fondos de pensiones invierten parte de su portafolio en **CKDs/CERPIS**, canalizando ahorro al **private equity** y la infraestructura (conexión Nivel IV).

20. Casos corporativos (en transacciones)

- **IPO como salida (exit) de un fondo de PE/VC:** un fondo que invirtió en una empresa la **lleva a bolsa** para vender su participación con liquidez y a buen precio (uno de los *exits* clásicos del PE/VC — Nivel IV).
- **OPA como vía de adquisición:** comprar una empresa pública requiere una **OPA** (no un simple SPA); el régimen de la LMV se suma al societario y al de competencia.
- **Fusión de emisoras:** la fusión de dos sociedades públicas combina derecho societario (LGSM), bursátil (LMV: disclosure, OPA si hay cambio de control) y de competencia (COFECCE).
- **Dual track:** un fondo prepara **simultáneamente** una venta privada (M&A) y una **IPO**, y elige la que dé mejor valor (*dual-track process*).
- **Gobierno corporativo como valor en M&A:** una emisora con gobierno corporativo robusto es más valiosa y más fácil de adquirir/fusionar.

21. Casos internacionales

- **Dual listing / ADRs:** empresas mexicanas que cotizan también en EE. UU. (vía **ADRs** —American Depositary Receipts—) quedan sujetas a la **SEC** y a la regulación estadounidense (incluida Sarbanes-Oxley), además de la mexicana.
- **Regulación comparada:** la **SEC** (EE. UU.) es el referente; la **UE** armoniza vía reglamentos (Folleto/Prospectus, Abuso de Mercado —MAR—); el Reino Unido (FCA) y otros tienen reguladores potentes. Todos comparten el ADN del *disclosure* y la prohibición del *insider trading*.
- **Ofertas internacionales (Reg S / Rule 144A):** las emisiones que se colocan también fuera de México usan exenciones de la regulación estadounidense (Reg S para ofertas *offshore*,

Rule 144A para inversionistas institucionales calificados — QIBs—).

- **Estándares de gobierno corporativo (OCDE):** los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE influyen en la regulación de todos los mercados (consejos, independientes, derechos de accionistas, transparencia).

22. Derecho comparado

SISTEMA	RASGOS DEL MERCADO DE VALORES
México	LMV (2005): S.A.B., S.A.P.I.; CNBV como regulador; BMV y BIVA; Indeval; gobierno corporativo reforzado; OPA; mercado relativamente pequeño.
España	Ley del Mercado de Valores; CNMV como regulador; armonización con la UE (folleto, abuso de mercado).
Estados Unidos	El referente mundial: Securities Act 1933 + Exchange Act 1934; SEC ; full disclosure; Sarbanes-Oxley (2002), Dodd-Frank (2010); tender offers (Williams Act); enforcement potente.
Delaware	Sede de las grandes corporaciones; su corporate law y la jurisprudencia de la Court of Chancery rigen las defensas anti-OPA y los deberes fiduciarios (Revlon, Unocal — Nivel IV).
Unión Europea	Armonización: Reglamento de Folleto (disclosure en ofertas), Reglamento de Abuso de Mercado (MAR) (insider trading, manipulación), Directiva de OPAs (takeover bids), MiFID II (intermediarios).
UNI-DROIT	Convenio de Ginebra sobre valores intermediados (titularidad de valores desmaterializados en cadenas de custodia).
UNCITRAL	Trabajos sobre comercio electrónico y, conexamente, sobre valores y garantías.
CISG	No aplica (es compraventa de mercaderías).
Common Law	Tradición de <i>securities regulation</i> (EE. UU., Reino Unido —FCA—); fuerte <i>enforcement</i> y litigio (class actions en EE. UU.).
Civil Law	Regulación bursátil basada en leyes especiales y reguladores administrativos; convergencia hacia el modelo de disclosure y los estándares OCDE.

Convergencia clave: todos los mercados comparten el ADN de la **SEC**: *full disclosure*, prohibición de *insider trading* y manipulación, gobierno corporativo y un regulador fuerte. Para el abogado de M&A público y de IPOs, dominar el modelo estadounidense (SEC, Reg S/144A, Sarbanes-Oxley) es indispensable, porque muchas operaciones mexicanas tocan EE. UU. (ADRs, dual listings, fondos).

23. Derecho mexicano

- **LMV (2005, reformada):** objeto y valores (arts. 1-2 ☺); **S.A.P.I., S.A.P.I.B. y S.A.B.** (arts. 12 ☺ y ss.); gobierno corporativo de la S.A.B. (consejo, independientes, comités de auditoría y prácticas societarias, deberes de diligencia y lealtad, arts. 22-44 ☺); oferta pública e inscripción en el RNV; **OPA** (arts. 92-109 ☺); información privilegiada y manipulación (arts. 362-380 ☺); régimen de intermediarios, bolsas e Indeval; sanciones y delitos.
- **CNBV:** Ley de la CNBV; facultades de autorización, supervisión y sanción.
- **Ley Fintech (2018):** instituciones de financiamiento colectivo (*crowdfunding*) y de fondos de pago; activos virtuales (con Banxico).
- **Normas conexas:** LGSM (supletoria en lo societario), Ley de Concursos, competencia (COFECE en concentraciones de emisoras), Afores (régimen de inversión).
- **Bolsas:** BMV y BIVA; **MexDer** (derivados); **Indeval** (depósito/liquidación).

24. Jurisprudencia relevante

Verificar vigencia antes de citar. - **Responsabilidad por el prospecto:** criterios sobre la información veraz y la responsabilidad de la emisora y firmantes por omisiones o información engañosa.

- **Deberes fiduciarios de consejeros y director general (LMV):** alcance de los deberes de diligencia y lealtad y de la regla de juicio de negocio.
- **Operaciones con partes relacionadas:** estándares de revelación y aprobación.
- **OPA y protección de minoritarios:** criterios sobre la obligatoriedad de la OPA y el trato igualitario.
- **Sanciones por información privilegiada y manipulación:** resoluciones de la CNBV.

25. Criterios de la Suprema Corte / reguladores

- **Constitucionalidad de la regulación bursátil:** validez de las facultades de la CNBV y de las restricciones (disclosure, prohibiciones) frente a la libertad de comercio, por el interés público en la **integridad del mercado**.
- **Gobierno corporativo y protección de minoritarios:** criterios que refuerzan los derechos de los accionistas minoritarios en emisoras.
- **Resoluciones de la CNBV:** sanciones por insider trading, manipulación e incumplimiento de disclosure (jurisdicción administrativa especializada).

26. Doctrina nacional

- **Doctrina sobre la LMV de 2005:** análisis de la S.A.B., S.A.P.I. y el gobierno corporativo reforzado (autores y comentaristas de la reforma).
- **Roberto Mantilla Molina / Jorge Barrera Graf:** marco mercantil y societario base.
- **Doctrina de gobierno corporativo (Consejo Coordinador Empresarial, Código de Principios de Gobierno Corporativo):** estándares de mejores prácticas.
- **Literatura sobre mercado de capitales mexicano** (BMV/ BIVA, Afores, FIBRAS, CKDs).

27. Doctrina internacional

- **Louis Loss & Joel Seligman, *Securities Regulation*** (EE. UU.): la obra monumental de la materia.
- **Reinier Kraakman et al., *The Anatomy of Corporate Law*:** análisis funcional del gobierno corporativo y la protección de inversores (también relevante en el Libro 2 Nivel III).
- **John Armour et al., *Principles of Financial Regulation*:** marco moderno de regulación financiera.
- **Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE/G20:** estándar internacional.

- **Regulación de la SEC, MAR/Folleto (UE):** los marcos de referencia globales.

28. Opiniones críticas (postura del Consejo)

1. **El mercado de valores mexicano es pequeño y debe crecer.** Pocas emisoras cotizan; el Consejo considera que el reto de política pública es **atraer más empresas** (reduciendo cargas sin sacrificar la confianza) y profundizar la cultura de inversión y de gobierno corporativo.
2. **El gobierno corporativo de la S.A.B. es el estándar de excelencia.** El Consejo recomienda que las empresas privadas que aspiren a crecer o venderse **adopten anticipadamente** el modelo de la S.A.B. (consejo con independientes, comités, deberes fiduciarios): eleva su valor y las prepara para una IPO o un M&A.
3. **El *disclosure* y el control del *insider trading* son innegociables.** La confianza es el activo del mercado; el Consejo subraya que el **compliance** bursátil (eventos relevantes, listas de personas con información privilegiada, ventanas de operación) es de máxima prioridad y de altísimo riesgo penal.

29. Debate doctrinal

- **¿Disclosure (mandatory disclosure) o desregulación?** ¿Debe el Estado **obligar** a revelar (modelo SEC) o bastaría con la disciplina del mercado? El consenso, tras 1929 y 2008, es que el *disclosure* obligatorio es necesario; el debate es sobre su **alcance y costo**.
- **Shareholder vs. stakeholder en la emisora (ESG):** ¿debe la S.A.B. maximizar el valor del accionista o atender a todos los grupos de interés? El **ESG** y el *disclosure* de sostenibilidad son la frontera actual (Nivel IV).
- **Defensas anti-OPA: ¿protegen a los accionistas o atrincheran a los administradores?** El debate clásico del *takeover law* (Delaware): las *poison pills* y otras defensas pueden proteger a los accionistas de ofertas inadecuadas o servir a los directivos para conservar su puesto (Nivel IV).

- **Mercados eficientes vs. conductual:** ¿reflejan los precios toda la información (Fama) o hay burbujas e irracionalidad (Shiller)? Afecta cómo se concibe el *disclosure* y la protección del inversionista (Libro 10 Nivel I).
- **Regulación vs. innovación (fintech, cripto):** cómo regular el *crowdfunding*, los activos digitales y las nuevas plataformas sin asfixiar la innovación ni desproteger al inversionista.

30. Errores comunes

- **Omitir un riesgo material en el prospecto.** Genera **responsabilidad civil, administrativa y penal** de la emisora y los firmantes; el *disclosure* veraz es innegociable.
- **Operar con información privilegiada.** *Insider trading*: delito y falta administrativa; uno de los mayores riesgos personales de directivos y asesores.
- **No revelar un evento relevante a tiempo** (o filtrarlo selectivamente): viola el deber de *disclosure* e igualdad de los inversionistas.
- **Tomar el control de una emisora sin lanzar la OPA obligatoria:** sancionable; viola la protección de minoritarios.
- **Confundir oferta pública con privada:** colocar entre el público sin cumplir el régimen de oferta pública (RNV, prospecto, CNBV) es ilegal.
- **Operaciones con partes relacionadas sin el proceso debido** (revelación, comité, precio de mercado): zona de máximo riesgo de conflicto.
- **Subestimar el costo de ser pública:** *disclosure* continuo, gobierno corporativo y responsabilidad agravada.

31. Mitos frecuentes

- **"Salir a bolsa es solo conseguir dinero." Falso:** implica transparencia permanente, gobierno corporativo reforzado y escrutinio del mercado (cambio cultural irreversible).

- "*El insider trading es difícil de detectar, así que se puede.*" **Falso y peligroso:** los reguladores rastrean operaciones; es delito con consecuencias graves.
- "*La CNBV garantiza que la inversión es buena.*" **Falso:** la CNBV vigila el *disclosure* y la integridad del mercado, **no** la calidad de la inversión (que decide el inversionista informado).
- "*Comprar acciones en bolsa hasta tener el control no requiere nada especial.*" **Falso:** rebasar umbrales de control dispara la **OPA obligatoria**.
- "*Una S.A.B. y una S.A. privada se gobiernan igual.*" **No:** la S.A.B. tiene gobierno reforzado (independientes, comités, deberes agravados).

32. Preguntas difíciles

1. ¿Cómo equilibrar el **costo del disclosure** (que desincentiva salir a bolsa) con la **protección del inversionista**? ¿Por qué el mercado mexicano es tan pequeño?
2. ¿Las **defensas anti-OPA** (poison pills) protegen a los accionistas o atrincheran a los directivos? ¿Deberían permitirse en México?
3. ¿Debe el *disclosure* incluir obligatoriamente información **ESG** (sostenibilidad), y con qué estándar?
4. ¿Cómo regular el **crowdfunding** y los **activos digitales** (cripto) sin asfixiar la innovación ni desproteger al pequeño inversionista?
5. ¿La **dualidad de bolsas** (BMV/BIVA) y la competencia mejoran el mercado o lo fragmentan?

33. Casos de examen (con respuesta modelo)

P1. *¿Cuál es el principio rector de la regulación del mercado de valores?* **R.** El **full disclosure**: proteger al inversionista **obligando a revelar** información veraz, suficiente y oportuna (prospecto, eventos relevantes), no prohibiéndole invertir; complementado con la prohibición del *insider trading* y la manipulación.

P2. Distinga mercado primario y secundario. R. En el **primario**, la emisora **coloca** los valores y recibe el capital (IPO, emisión de deuda); en el **secundario**, los inversionistas los negocian entre sí en la bolsa (liquidez y formación de precio; la emisora ya no recibe dinero).

P3. ¿Qué es la S.A.B. y qué gobierno corporativo exige? R. Sociedad Anónima Bursátil (emisora); requiere consejo con **consejeros independientes** (mín. 25%), **comités de auditoría y de prácticas societarias**, y deberes de **diligencia y lealtad** agravados de consejeros y director general (LMV).

P4. ¿Qué es el insider trading y por qué se prohíbe? R. Operar valores usando información **relevante y no pública**; se prohíbe (delito y falta) porque rompe la **igualdad** entre inversionistas y destruye la **confianza** en el mercado.

P5. ¿Cuándo es obligatoria una OPA? R. Cuando se pretende adquirir el **control** de una emisora (rebasar los umbrales legales): la ley obliga a lanzar una **OPA** para que los minoritarios puedan **salir** en las mismas condiciones (trato igualitario).

34. Simulador (ejercicio tipo despacho)

Rol: asociado de mercados de capitales. **Cliente:** una empresa familiar exitosa (hoy S.A.P.I.) que quiere **salir a bolsa (IPO)** para financiar su expansión y dar liquidez a una rama de la familia que quiere salir.

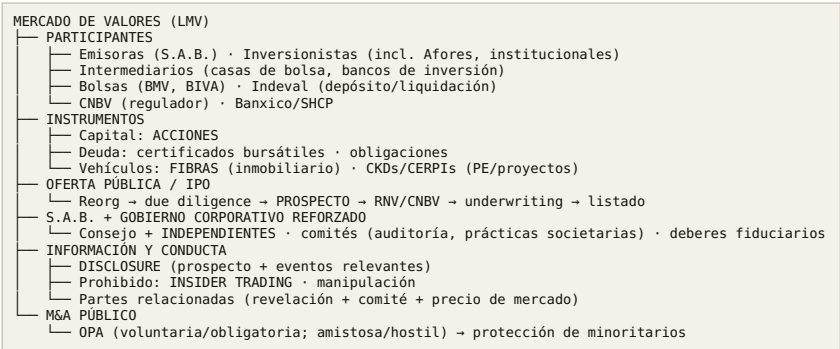
Tarea: elabora una **hoja de ruta de la IPO** que cubra: (1) la **reorganización** societaria y de gobierno (de S.A.P.I. a **S.A.P.I.B./S.A.B.**: consejo con **independientes**, comités de auditoría y prácticas societarias, deberes fiduciarios); (2) la **due diligence** y la preparación del **prospecto** (factores de riesgo, información financiera) y su responsabilidad; (3) la **inscripción en el RNV** y autorización de la **CNBV**, y el listado (BMV/BIVA); (4) el **underwriting** (en firme vs. mejores esfuerzos), roadshow y fijación de precio; (5) el régimen **post-IPO** (disclosure continuo, eventos relevantes, ventanas de operación, listas de personas con información privilegiada); (6) cómo la familia conserva control (acciones de voto, estructura) sin violar la protección de minoritarios. Concluye con los **3 riesgos** principales (responsabilidad por el prospecto, insider trading, pérdida de control) y su mitigación.

(Pista de evaluación: la mejor respuesta trata la IPO como un proyecto de gobierno corporativo + disclosure, no solo financiero; cuida la veracidad del prospecto, el régimen anti-insider; y diseña una estructura que equilibre el control familiar con la protección de minoritarios.)

35. Flashcards

- **¿Principio rector?** → Full disclosure (revelar la verdad para que el inversionista decida).
- **¿Mercado primario vs. secundario?** → Colocación inicial (emisora recibe capital) vs. negociación entre inversionistas (liquidez/precio).
- **¿Qué es una IPO?** → Oferta pública inicial: primera colocación de acciones al público (salir a bolsa).
- **¿Prospecto?** → Documento de disclosure (negocio, riesgos, finanzas, términos de la oferta).
- **¿Regulador en México?** → La CNBV.
- **¿S.A.B.?** → Sociedad Anónima Bursátil; gobierno corporativo reforzado (independientes, comités).
- **¿Insider trading?** → Operar con información relevante no pública (prohibido; delito).
- **¿Manipulación de mercado?** → Alterar artificialmente precio/volumen (prohibida).
- **¿Evento relevante?** → Hecho que puede influir en el precio; debe revelarse veraz y oportunamente.
- **¿OPA?** → Oferta pública de adquisición; obligatoria al tomar el control (protege minoritarios).
- **¿Certificado bursátil?** → Deuda de la emisora colocada en el mercado.
- **¿FIBRA / CKD?** → Vehículos bursátiles (inmobiliario / capital de desarrollo y proyectos).

36. Mapas mentales



37. Cuadros comparativos

Financiamiento: crédito vs. mercado de valores

	CRÉDITO (BANCA/ LGTOC)	MERCADO DE VALORES
De quién	De un banco/acreedor	Del público inversionista
Escala	Limitada	Muy grande
Costo de transpa- rencia	Menor	Alto (disclosure, gobierno)
Instrumento	Pagaré, contrato de crédito	Acciones, certificados bursátiles

Mercado primario vs. secundario

	PRIMARIO	SECUNDARIO
Qué ocurre	Colocación inicial (IPO/ emisión)	Negociación entre inver- sionistas
¿La emisora recibe dinero?	Sí	No
Función	Captar capital	Liquidez y formación de precio

S.A. privada vs. S.A.B.

	S.A. / S.A.P.I. (PRIVADA)	S.A.B. (PÚBLICA)
Acciones	No cotizan	Cotizan en bolsa
Gobierno corporativo	Flexible	Reforzado (independientes, comités)
Disclosure	Mínimo	Continuo (eventos relevantes)
Adquisición	SPA privado	OPA

38. Diagramas

Anatomía de una IPO:

Decisión → Reorganización (S.A.B. + gobierno) → DUE DILIGENCE → PROSPECTO
 → Inscripción RNV + autorización CNBV → Underwriting (roadshow, book-building, precio)
 → LISTADO (BMV/BIVA) → vida pública: DISCLOSURE continuo

OPA (toma de control de una emisora):

¿Quiero el CONTROL de una pública? → no puedo comprar solo a unos
 → debo lanzar OPA a TODOS los accionistas (trato igualitario)
 → ¿amistosa (con el consejo) u hostil? → consejo opina (interés de accionistas)

39. Mnemotecnias

- **Principio rector:** *"disclosure: que digan la verdad y el inversionista decida".*
- **Mercados:** *"primario = la empresa cobra; secundario = los inversionistas se lo pasan".*
- **S.A.B.:** *"pública = independientes + comités + disclosure + responsabilidad".*
- **Insider trading:** *"información secreta + operar = delito".*
- **OPA:** *"para el control de una pública, ofreces a TODOS por igual".*
- **Vehículos:** *"FIBRA = ladrillos (inmuebles); CKD = capital de proyectos/PE".*
- **CNBV:** *"vigila la verdad y la integridad, no la calidad de la inversión".*

40. Resumen ejecutivo

El **mercado de valores** es el sistema que canaliza el ahorro del **público** hacia las empresas que necesitan capital a gran escala, mediante la emisión y negociación de **valores** (acciones, deuda, estructurados). Funciona sobre un principio innegociable: el **full disclosure** —la protección del inversio-

nista se logra **obligando a revelar** información veraz y oportuna (prospecto, eventos relevantes), no prohibiéndole invertir —, complementado con la prohibición del **insider trading** y la **manipulación**, y la supervisión de la **CNBV**. La empresa que sale a bolsa (**IPO**) se convierte en **S.A.B.**, con **gobierno corporativo reforzado** (consejo con **independientes**, comités de auditoría y prácticas societarias, deberes fiduciarios agravados) y escrutinio permanente. Los instrumentos van de las **acciones** y los **certificados bursátiles** (deuda) a vehículos como **FI-BRAS** y **CKDs/CERPIs** (que canalizan el ahorro —incluidas las Afores— al inmobiliario y al private equity).

Para el abogado corporativo, este es el techo del financiamiento y la antesala del **M&A público**: la **IPO** (incluida como *exit* de fondos de PE/VC) y la **OPA** (oferta pública de adquisición, obligatoria al tomar el control, con protección de minoritarios) son operaciones de máxima complejidad y valor, donde confluyen el derecho societario (LGSM), el bursátil (LMV), el de competencia (COFECE) y las finanzas. El régimen de **disclosure** e **insider trading** es, además, el corazón del compliance financiero, de altísimo riesgo penal. Dominar este libro es entrar a la liga mayor del derecho de los negocios: el financiamiento de élite, el gobierno corporativo de clase mundial y el M&A de empresas públicas. Con él, casi cerramos el Nivel III y quedamos a un paso del Corporate Law (Nivel IV).

41. Checklist

IPO / oferta pública:

- [] ¿Reorganización a **S.A.B.** con gobierno corporativo (independientes, comités)?
- [] ¿**Due diligence** completa y **prospecto** veraz (factores de riesgo, finanzas)?
- [] ¿Inscripción en el **RNV** y autorización de la **CNBV**? ¿Listado (BMV/BIVA)?
- [] ¿**Underwriting** (en firme / mejores esfuerzos), roadshow, precio?

Vida como emisora (post-IPO):

- [] ¿**Disclosure** continuo de eventos relevantes (veraz y oportuno)?
- [] ¿Controles **anti-insider** (listas de personas con información, ventanas de operación)?
- [] ¿Régimen de **operaciones con partes relacionadas** (revelación, comité, precio de mercado)?
- [] ¿Funcionamiento de consejo y comités; deberes fiduciarios?

M&A público:

- [] ¿La adquisición requiere **OPA** (toma de control)? ¿Voluntaria u obligatoria?
- [] ¿Protección de minoritarios (trato igualitario)?
- [] ¿Deberes del consejo de la *target* (opinión, no atrincheraamiento)?
- [] ¿Autorizaciones de **competencia** (COFECE) y sectoriales?

42. Bibliografía comentada

- **Ley del Mercado de Valores (2005) y normativa de la CNBV.** El derecho positivo; estúdialo con el texto vigente y las disposiciones de carácter general.
- **Loss & Seligman, *Securities Regulation* (EE. UU.).** La obra monumental; entender el modelo SEC es entender el ADN de toda la regulación bursátil.
- **Kraakman et al., *The Anatomy of Corporate Law*.** Para el gobierno corporativo y la protección de inversores con visión funcional y comparada.
- **Armour et al., *Principles of Financial Regulation*.** Marco moderno de la regulación financiera.
- **Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE/G20 y el Código de Principios de Gobierno Corporativo (México).** Los estándares de mejores prácticas.
- **Doctrina sobre la LMV de 2005 (S.A.B., S.A.P.I., gobierno corporativo).** Para el detalle del régimen mexicano.
- **Fama, *Efficient Capital Markets (Journal of Finance, 1970)*.** La hipótesis del mercado eficiente, que es el supuesto

sobre el que se construyó todo el régimen de revelación. Hay que conocerla para entender por qué el sistema apuesta por informar en lugar de por autorizar.

- **Coffee, *Market Failure and the Economic Case for a Mandatory Disclosure System* (Virginia Law Review, 1984).** La respuesta que justifica el mandato: los bienes públicos informativos (§6). Es el artículo que hay que citar cuando alguien pregunte por qué no basta con la revelación voluntaria.
- **Easterbrook & Fischel**, su capítulo sobre *disclosure*, para el lado escéptico del debate; y **Shiller** para la crítica conductual a la eficiencia (burbujas).
- **Jurisprudencia fundacional:** *SEC v. Texas Gulf Sulphur* (1968), origen de la regla *disclose or abstain* en materia de información privilegiada.
- **Régimen europeo:** el **Reglamento de Abuso de Mercado (MAR)**, útil como contraste con el modelo estadounidense y con la LMV mexicana.

43. Ruta hacia el siguiente libro

Lo que acabas de aprender —el financiamiento a gran escala, la emisora pública, el gobierno corporativo reforzado y el M&A público (OPA)— será **indispensable para comprender** qué ocurre cuando una empresa **fracasa**: el **concurso mercantil**, el mecanismo para reestructurar o liquidar ordenadamente a las empresas insolventes, protegiendo a acreedores e inversionistas.

- **Siguiente libro:** [*Nivel III · Libro 6*] *Concurso Mercantil* — insolvencia, conciliación, quiebra, prelación de acreedores (donde se prueban las **garantías** del Libro 4 Nivel II) y reestructuración empresarial.
- **Conexión de largo alcance:** la **IPO**, la **OPA**, los **CKDs** y el gobierno corporativo reforzado reaparecen, con plena potencia, en el **Nivel IV** (M&A, PE, VC y Gobierno Corporativo). Vuelve a las secciones 14.C, 14.D y 14.F cuando llegues allí.

◆ ¿Por qué esto importa para un abogado corporativo?

Porque el mercado de valores es **el techo del financiamiento y el escenario del M&A público**, y porque su régimen de **gobierno corporativo** y **disclosure** define el estándar de excelencia de toda empresa seria. El abogado de élite asesora **IPOs** (que captan miles de millones y son el *exit* soñado de los fondos), **emisiones de deuda**, **OPAs** (las adquisiciones más complejas y mediáticas) y el **gobierno corporativo** de las emisoras. Además, el compliance bursátil —disclosure, control de insider trading, operaciones con partes relacionadas— es de los de **mayor riesgo penal** y, por tanto, de los mejor pagados. Dominar la LMV es requisito para los despachos y los puestos de *general counsel* de las grandes corporaciones.

◆ Cómo piensa un socio de un despacho internacional

*"Una IPO, para mí, es 70% gobierno corporativo y disclosure y 30% finanzas. Mi obsesión es la veracidad del prospecto: una omisión material es responsabilidad civil y penal, así que dirijo una due diligence implacable y redacto los factores de riesgo con honestidad quirúrgica. Preparo a la empresa para vivir como pública: consejo con independientes, comités, listas de personas con información privilegiada, ventanas de operación. En una OPA, pienso en los minoritarios (trato igualitario) y en los deberes del consejo de la target (que no se atrinchere). Y siempre tengo presente el peor riesgo: el **insider trading** y el disclosure selectivo, que pueden mandar a la cárcel a un cliente. En el mercado de valores, la confianza es el activo, y la información veraz es la moneda."*

◆ Errores que cuestan millones

1. **Prospecto con una omisión material.** Si la IPO oculta un riesgo relevante y este se materializa, la emisora y los firmantes responden ante miles de inversionistas (responsabilidad civil, multas y delito). *Prevención:* due diligence implacable y disclosure veraz de los factores de riesgo.
2. **Insider trading.** Operar (o filtrar) con información privilegiada destruye carreras y manda a la cárcel; además contamina la confianza en la empresa. *Prevención:* listas de

iniciados, ventanas de operación, capacitación y compliance estricto.

3. **Tomar el control sin lanzar la OPA obligatoria.** Eludir la OPA viola la protección de minoritarios; acarrea sanciones y la posible nulidad/ineficacia de la operación. *Prevención:* estructurar la toma de control conforme a la LMV.
4. **Disclosure selectivo o tardío de un evento relevante.** Informar a unos antes que a otros, o tarde, viola la igualdad de los inversionistas y se sanciona.
5. **Salir a bolsa sin gobierno corporativo sólido.** Una emisora con gobierno débil enfrenta escándalos, castigo del mercado y litigios; el gobierno corporativo es parte del valor.

Cierre del Libro. Has llegado al **techo del financiamiento corporativo**: la empresa pública, la IPO, el gobierno corporativo de clase mundial y el M&A público (OPA). Solo resta, para cerrar el Nivel III, estudiar qué pasa cuando una empresa **cae** —el **curso mercantil**— y consolidar el **gobierno corporativo**. Después, el **Nivel IV** reunirá todo en el corazón del objetivo: las **Fusiones y Adquisiciones**. Estás a un paso.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE III

[Nivel III · Libro 6] Concurso Mercantil

⦿ **Apóstrofe de vigencia** — **léela cada vez**. El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ⦿ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ⦿ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

Toda empresa puede fracasar. El **concurso mercantil** es el derecho de las empresas que ya no pueden pagar: el mecanismo ordenado para, primero, intentar **salvarlas** (reestructurarlas) y, si no es posible, **liquidarlas** repartiendo lo que queda entre los acreedores conforme a una **prelación** justa. Aquí se ponen a prueba todas las **garantías** que estudiamos (Libro 4 Nivel II): el día de la insolvencia se descubre quién tomó bien sus garantías y quién se quedó como simple quirografario. Es la "ley de Murphy" del derecho corporativo: hay que dominarla antes de que el cliente la necesite.

Etiquetas: derecho mercantil · insolvencia · concurso · quiebra · prelación de acreedores · reestructuración **Prerrequisitos:** Garantías (Nivel II), Obligaciones — Profundización, Sociedades (LGSM). **Estándar:** V3 (43 secciones + secciones transversales). ⌚ **Tiempo estimado de dominio:** 4 semanas (≈ 40–50 h de estudio activo). Lectura de reconocimiento: 8–9 h. *Estúdialo en bloques:* presupuestos y apertura → conciliación (reestructura) → quiebra y prelación → insolvencia transfronteriza.

Aviso de método. Tratado, no repaso. Profundizamos el procedimiento concursal y, sobre todo, la **prelación de acreedores** (donde se prueba el valor real de las garantías) y la **reestructuración**, con ejemplos trabajados, "cómo razona un socio" y conexión con financiamiento, *distressed M&A* y due diligence.

NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL (VISTA RÁPIDA)

Litigio	★★★★★
Corporate	★★★★☆
M&A	★★★★☆
Mercado de Valores	★★★☆☆
Venture Capital	★★★☆☆
Private Equity	★★★★★
Gobierno Corporativo	★★★★☆
Compliance	★★★★☆
Derecho Bancario	★★★★★
Empresa Familiar	★★★★☆

Es la prueba de fuego de las garantías y del financiamiento; central en banca, distressed M&A y reestructuración (un nicho de alto valor del private equity).

1. Introducción

Hasta ahora estudiamos la empresa que funciona: cómo se organiza (sociedades), cómo se financia (títulos, crédito, valores) y cómo contrata. Pero, ¿qué pasa cuando **deja de pagar**? Si cada acreedor pudiera cobrarse por su cuenta —embargando lo que alcance, el más rápido o el más fuerte—, habría un caos destructivo: se dismantelaría una empresa que quizá podía salvarse, y el reparto sería injusto. El **concurso mercantil** evita ese caos: es un procedimiento **colectivo y universal** que reúne a **todos** los acreedores y **todos** los bienes del deudor insolvente, suspende las ejecuciones individuales, y resuelve el problema de forma ordenada.

La idea central: el concurso persigue **dos finalidades**, en este orden. **Primero, conservar la empresa** (la **conciliación**: reestructurar la deuda mediante un convenio con los acreedores, para que la empresa siga operando —porque una empresa viva vale más y genera empleo—). **Segundo, si la conservación fracasa, liquidar ordenadamente** (la **quiebra**: vender los bienes y repartir el producto entre los acreedores según una **prelación** legal). Aquí se descubre la verdad sobre las garantías: el acreedor con garantía real bien constituida cobra **primero** sobre su bien; el quirografario, al final y a prorrata. Para el abogado corporativo, dominar el concurso es saber **proteger al acreedor antes de la crisis** (tomando bien las ga-

rantías) y **navegar la crisis** cuando llega (reestructurando o comprando activos en *distress*).

2. Objetivos del libro

Al terminar, el lector será capaz de:

- **Entender los presupuestos** del concurso (el **incumplimiento generalizado** de pagos) y cómo se **declara** (solicitud, demanda, sentencia de concurso).
- **Dominar las dos etapas:** la **conciliación** (reestructura vía convenio concursal) y la **quiebra** (liquidación), con el papel del **conciliador**, el **síndico**, el **visitador** y el IFECOM.
- **Manejar la prelación de acreedores:** el orden de pago (singularmente privilegiados, con garantía real, con privilegio especial, comunes) y dónde quedan las **garantías** (Libro 4 Nivel II).
- **Comprender los efectos** del concurso: suspensión de ejecuciones, **separación** de bienes, régimen de los **contratos pendientes**, y la **retroacción** (actos en fraude de acreedores).
- **Aplicar la reestructuración:** el **convenio concursal**, los **planes prepagados (*pre-packs*)** y las herramientas de *workout* extrajudicial.
- **Conectar** con el *distressed M&A* (comprar empresas/activos en concurso), el financiamiento (riesgo de crédito y recuperación) y la due diligence (contingencias de insolvencia).

3. Importancia profesional

El concurso es la **prueba de fuego** de buena parte de la práctica corporativa:

1. **Define la recuperación del acreedor.** En la insolvencia se materializa el valor de las **garantías**: quien tomó garantía real bien perfeccionada recupera; quien no, casi nada. El financiamiento se diseña pensando en este día.
2. **La reestructuración es un nicho de altísimo valor.** Salvar empresas viables (vía conciliación o *workout*) es trabajo de

despachos y fondos especializados (*distressed debt, special situations*).

3. **El *distressed M&A* es una oportunidad.** Comprar empresas o activos de compañías en concurso (a precios de crisis, "limpios" de pasivos) es una estrategia clásica del **private equity**.
4. **Es materia de due diligence y de riesgo.** Evaluar el riesgo de insolvencia de una contraparte, y la posibilidad de que actos previos sean **impugnados** (retroacción), es parte del análisis de todo *deal* y financiamiento.

4. Historia de la institución

- **Raíces:** la quiebra (*bancarrota*) tiene origen medieval en las ciudades comerciales italianas; el término "bancarrota" viene de *banca rotta* (romper el banco del comerciante que no pagaba). La insolvencia se asociaba a infamia y castigo (el deudor quebrado era tratado casi como delincuente).
- **Evolución:** del enfoque **punitivo y liquidatorio** (castigar al quebrado, liquidar y repartir) al enfoque **conservativo y re-habilitador** moderno (salvar la empresa viable, dar al deudor honesto una segunda oportunidad). El hito conceptual es la distinción entre la **empresa** (que puede ser viable y merece salvarse) y el **empresario** (que pudo fracasar).
- **Influencia estadounidense:** el **Chapter 11** del *US Bankruptcy Code* (reorganización con el deudor en posesión —*debtor in possession*—) es el modelo mundial del concurso **reorganizativo**; influyó decisivamente en las reformas latinoamericanas.
- **México:** de la **Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos (1943)** —liquidatoria y lenta— se pasó a la **Ley de Concursos Mercantiles (LCM) de 2000** (vigente, reformada en 2007 y 2014), que adoptó el modelo moderno: **dos etapas** (conciliación y quiebra), priorizando la **conservación** de la empresa, con un órgano especializado, el **IFECOM** (Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles), y especialistas (visitador, conciliador, síndico). La reforma de 2014

incorporó los **planes prepactados** y mejoró el financiamiento durante el concurso.

5. Evolución histórica

- **Del castigo a la rehabilitación:** la insolvencia dejó de ser un delito infamante para volverse un fenómeno económico que el derecho gestiona, distinguiendo al deudor **honesto pero desafortunado** del **fraudulento**.
- **De la liquidación a la reorganización:** la prioridad moderna es **salvar la empresa viable** (Chapter 11, conciliación), porque una empresa en marcha vale más (goodwill, empleo) que sus activos liquidados por separado.
- **Del concurso judicial puro a las soluciones híbridas:** auge de los **acuerdos extrajudiciales** (*workouts*) y los **planes prepactados** (*pre-packs*): negociar la reestructura **fue-
ra** del tribunal y solo "homologarla" judicialmente, ganando velocidad.
- **De lo nacional a lo transfronterizo:** las empresas multinacionales quiebran en varios países a la vez; surge el derecho de la **insolvencia transfronteriza** (Ley Modelo UN-CITRAL, incorporada a la LCM mexicana) para coordinar procedimientos.
- **Tendencia:** mayor énfasis en la **velocidad**, el **financiamiento durante el concurso** (para que la empresa siga operando) y los mecanismos preventivos (reestructurar **antes** de la insolvencia total).

Idea de evolución clave: el derecho concursal moderno cambió su pregunta: ya no es "¿cómo castigamos y liquidamos al quebrado?", sino "¿cómo salvamos la empresa viable y, si no, repartimos con justicia?". Esa migración —del castigo a la reorganización— es la clave para entender la LCM.

6. Contexto económico

El concurso cumple funciones económicas esenciales (Libros 9 y 10, Nivel I):

- **Reasignación eficiente de recursos:** saca de operación a las empresas **inviables** (liberando sus recursos para usos

más productivos) y **preserva** las viables (que valen más vivas).

- **Disciplina del crédito y certeza de la prelación:** un sistema concursal **predecible** (que respeta las garantías y la prelación) **reduce el costo del crédito:** los acreedores prestan más barato si saben que recuperarán en la insolvencia. Un concurso **impredecible** o que no respeta garantías **encarece** todo el crédito de un país.
- **Problema del "acreedor que corre" (*common pool*):** sin concurso, cada acreedor correría a embargar, desmantelando la empresa (tragedia de los comunes). El concurso resuelve este problema con el **principio colectivo** y la **suspensión** de ejecuciones individuales.
- **Valor de la empresa en marcha vs. liquidación:** la conservación se justifica económicamente porque la empresa **operando** (*going concern*) vale más que la suma de sus activos vendidos por separado (el goodwill, Libro 1 Nivel III).

LOS TRES MECANISMOS DEL CONCURSO, EXPLICADOS POR EL PROBLEMA QUE RESUELVEN

El derecho concursal parece un conjunto de tecnicismos hasta que se entiende que cada pieza resuelve un problema económico preciso. Tres, y valen para cualquier jurisdicción.

1 · La suspensión de ejecuciones (*automatic stay*): contra la **carrera destructiva**. Sin ella, cada acreedor tiene incentivo a ejecutar **primero** —el que llega antes cobra— y ese incentivo individualmente racional destruye valor colectivamente: se desmantela una empresa que valía más entera que en piezas. Es un problema clásico de acción colectiva, y **Thomas Jackson** lo formuló como el fundamento del sistema en *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*: el concurso es el mecanismo que **impide la carrera** y permite que los acreedores actúen como actuarían si pudieran coordinarse.

2 · La regla de prioridad absoluta: contra la destrucción del crédito futuro. El orden —acreedores antes que accionistas— no es una preferencia moral: es lo que hace posible el crédito **ex ante**. Si un acreedor supiera que podría cobrar des-

pués del accionista, no prestaría, o prestaría mucho más caro. La regla protege a quien presta hoy porque protege el orden de mañana. Su matiz debatido es la excepción de **new value**: permitir que el accionista-gestor conserve una porción si **aporta capital fresco** —útil cuando ese aporte salva la empresa, cuestionable cuando encubre una condonación disfrazada—.

3 · El financiamiento al deudor en posesión (*DIP financing*): contra el *debt overhang*. Una empresa insolvente necesita dinero para operar mientras se reestructura, y nadie presta a un insolvente que ya tiene acreedores por delante. La solución es dar a ese nuevo crédito una **superprioridad**. Es el mismo problema del *debt overhang* de Myers que estudias en Derecho Bancario, resuelto por vía concursal: cuando la deuda existente desincentiva la inversión buena, hay que ponerla en segundo lugar respecto del dinero nuevo.

Y el debate de fondo, que sigue abierto: ¿reorganizar o liquidar? La LCM y el Chapter 11 estadounidense tienen un sesgo **pro-reorganización** —preservar la empresa, el empleo, el valor del negocio en marcha—. La escuela de Chicago, con **Baird y Rasmussen** (*The End of Bankruptcy*), objetó con un argumento incómodo: muchas reorganizaciones mantienen vivas **empresas zombis** que deberían liquidarse, y hoy existe un mercado de M&A de empresas en dificultades capaz de reasignar esos activos mejor y más rápido que un procedimiento judicial.

Postura del Consejo: la crítica es válida como advertencia y excesiva como regla. La reorganización se justifica cuando el negocio **en marcha vale más que sus activos por separado** —es decir, cuando hay *goodwill* real que se destruiría al liquidar—, y no se justifica cuando solo preserva el control de quien ya demostró que no puede administrar. La pregunta operativa que hay que hacerle a cada expediente es esa, y es la misma del §6: **¿qué se pierde si esta empresa se desarma?** Si la respuesta es "poco", la reorganización solo está retrasando lo inevitable y consumiendo el patrimonio de los acreedores en el camino.

7. Contexto político

El concurso es una decisión de política económica de **equilibrio** entre intereses en conflicto: **acreedores** (quieren cobrar), **deudor/empresa** (quiere sobrevivir o liberarse), **trabajado-**

res (quieren sus empleos y salarios), **fisco** (quiere sus impuestos) y la **economía** (quiere preservar empresas viables y reasignar recursos). El Estado fija la **prelación** (quién cobra primero) con criterios políticos: protege a los **trabajadores** (créditos singularmente privilegiados) y al **fisco**, a veces por encima de las garantías privadas. La materia es **federal** (es comercio, art. 73-X ☺). La calidad del sistema concursal es un indicador clave del **clima de negocios** y del *country risk* (Doing Business del Banco Mundial mide "resolución de la insolvencia").

8. Contexto social

La insolvencia tiene un fuerte componente social: detrás de cada empresa en concurso hay **empleos, familias, proveedores** (muchos PyMEs) y **comunidades** que dependen de ella. Por eso el derecho moderno prioriza **salvar la empresa** (no por el empresario, sino por todos los que dependen de ella) y protege a los **trabajadores** con una prelación alta. La cultura del "fracaso" también importa: en algunos países (EE. UU.) el fracaso empresarial honesto se ve como aprendizaje y se da una **segunda oportunidad** ágil; en otros, el estigma de la quiebra desincentiva el emprendimiento. Un buen sistema concursal **destigmatiza** el fracaso honesto y castiga solo el fraude.

9. Contexto empresarial

Para la empresa y sus acreedores, el concurso es el **escenario del peor día**, y por eso se prepara **antes**:

- **Para el acreedor/banco:** el concurso es donde se cobra (o no) lo prestado; por eso el financiamiento se diseña con **garantías reales bien perfeccionadas** (Libro 4 Nivel II) que dan **prelación**, y se vigila el **riesgo de insolvencia** de los deudores.
- **Para la empresa en crisis:** el concurso (o el *workout* extrajudicial) es la vía para **reestructurar** la deuda y sobrevivir, o para una **liquidación ordenada**. La decisión de acogerse al concurso (y cuándo) es estratégica.

- **Para el inversionista (*distressed*):** comprar la deuda con descuento (*distressed debt*) o los activos/la empresa en concurso (*distressed M&A*) es una estrategia de **private equity** y *special situations*.
- **Para los administradores:** la cercanía de la insolvencia agrava sus **deberes** (no agravar el pasivo, no preferir indebidamente a ciertos acreedores —*zona de insolvencia*—); su incumplimiento genera responsabilidad.

El abogado corporativo asesora en las tres posiciones: **protege al acreedor** antes de la crisis, **reestructura** o **liquida** la empresa durante ella, y **estructura adquisiciones** de activos o deuda en *distress*. Es una especialidad técnica, intensa y de alto valor.

10. Definiciones doctrinales

- **Concurso mercantil (doctrina):** procedimiento **colectivo** y **universal** que, ante la **insolvencia** (incumplimiento generalizado de pagos) de un comerciante, reúne a todos sus acreedores y todos sus bienes para, primero, intentar **conservar** la empresa mediante un convenio (conciliación) y, en su defecto, **liquidarla** ordenadamente (quiebra) repartiendo el producto conforme a la **prelación** legal.
- **Insolvencia (concepto económico-jurídico):** incapacidad del deudor para hacer frente a sus obligaciones; en la LCM, se traduce en el **incumplimiento generalizado** de pagos (presupuesto objetivo del concurso).
- **Principios del concurso (doctrina):** **universalidad** (todos los bienes), **colectividad** (todos los acreedores), **par condicio creditorum** (igualdad de trato entre acreedores del mismo rango) y **conservación de la empresa** (preferencia por salvarla).
- **Debtor in possession (Chapter 11):** el modelo en que el deudor **conserva la administración** durante la reorganización (con vigilancia), en vez de ser desplazado por un síndico; influye en la conciliación moderna.

Lectura del Consejo: memoriza los cuatro principios —**universalidad, colectividad, *par condicio*, conservación**— y la **jerarquía de finalidades: primero conservar, luego liquidar**. De ahí se entiende todo el procedimiento: la conciliación (salvar) precede a la quiebra (liquidar), y la *par condicio* (igualdad) solo opera **dentro de cada rango** de la prelación —porque algunos acreedores (garantizados, laborales, fiscales) tienen **preferencia**—.

11. Definiciones legales (LCM — verificar versión vigente)

- **Finalidad — art. 1 º LCM:** el concurso mercantil es de **interés público** y tiene por objeto **conservar las empresas** y evitar que el incumplimiento generalizado ponga en riesgo su viabilidad y la de las demás con las que tenga relación.
- **Presupuesto (incumplimiento generalizado) — arts. 9-10 º:** el comerciante incurre en incumplimiento generalizado cuando **incumple sus obligaciones** de pago a **dos o más acreedores** y se cumplen ciertas condiciones (p. ej., que las obligaciones vencidas representen al menos el 35% de todas sus obligaciones, o que no tenga activos para cubrir al menos el 80% de sus obligaciones vencidas).
- **Etapas — art. 2 º y ss.:** el concurso consta de **dos etapas sucesivas**: la **conciliación** (finalidad: lograr la **conservación** mediante el **convenio**) y la **quiebra** (finalidad: la **venta** de la empresa o sus bienes para el pago a los acreedores).
- **Órganos:** el **juez** (de distrito), el **IFECOM** (designa y supervisa a los especialistas) y los **especialistas**: el **visitador** (verifica si procede el concurso), el **conciliador** (gestiona la reestructura y el convenio) y el **síndico** (administra y liquida en la quiebra).
- **Prelación de acreedores — arts. 217 º y ss.:** orden de pago: **singularmente privilegiados** (gastos de entierro y de enfermedad del comerciante persona física), **con garantía real** (prenda, hipoteca), **con privilegio especial** (los que tengan un privilegio especial conforme a leyes), y **comunes** (quirografarios, a prorrata). Los **créditos laborales** (sala-

rios e indemnizaciones del último año) y los **fiscales** tienen reglas de preferencia destacadas.

- **Retroacción y actos en fraude de acreedores — arts. 112 ¢ y ss.:** los actos del deudor en perjuicio de la masa, realizados en el **periodo de retroacción** (anterior a la sentencia de concurso), pueden ser declarados **ineficaces**.
- **Insolvencia transfronteriza — arts. 278 ¢ y ss.:** incorpora la **Ley Modelo UNCITRAL** sobre reconocimiento de procedimientos extranjeros y cooperación.

12. Definición sencilla

El **concurso mercantil** es lo que pasa cuando una empresa **ya no puede pagar** a sus deudas en general. En vez de dejar que cada acreedor llegue a llevarse lo que pueda (un caos que destruiría la empresa), un **juez** los reúne a **todos** y a **todos los bienes**, y se intenta, **primero, salvar la empresa** llegando a un **acuerdo** para reestructurar la deuda (la **conciliación**); si no se logra, se **vende todo** y se reparte el dinero entre los acreedores en un **orden** fijado por la ley (la **quiebra**): primero los trabajadores y ciertos privilegiados, luego los que tienen **garantía** (hipoteca, prenda) sobre un bien, y al final, lo que sobre, los acreedores **comunes** a prorrata. El día del concurso se ve **quién tomó bien sus garantías** y quién no.

13. Conceptos fundamentales

- **Incumplimiento generalizado:** el presupuesto del concurso (no pagar a dos o más acreedores, rebasando los umbrales del art. 10 ¢). No basta un solo impago.
- **Conciliación:** la **primera etapa**; busca **conservar** la empresa mediante un **convenio concursal** con los acreedores (reestructura: quitas, esperas, conversión). El deudor suele conservar la administración (con vigilancia del **conciliador**).
- **Convenio concursal:** el acuerdo entre el deudor y sus acreedores (reconocidos), aprobado por las **mayorías** legales, que reestructura la deuda y permite a la empresa seguir

- operando; una vez aprobado y homologado por el juez, **vincula** a todos (incluso a los disidentes —*cram down*—).
- **Quiebra:** la **segunda etapa** (si la conciliación fracasa o el deudor la pide); implica la **liquidación**: el **síndico** vende los bienes (idealmente la empresa **como unidad**, para conservar el goodwill) y paga conforme a la prelación.
 - **Masa concursal (activa y pasiva):** la **activa** = todos los bienes del deudor afectos al pago; la **pasiva** = todos los créditos reconocidos.
 - **Reconocimiento, graduación y prelación de créditos:** el procedimiento para **reconocer** qué créditos existen, **graduarlos** (clasificarlos por rango) y fijar el **orden de pago**. Es el corazón del concurso.
 - **Acreedores por rango (prelación):**
 - **Singularmente privilegiados** (gastos de entierro/enfermedad del comerciante persona física).
 - **Créditos laborales** (salarios e indemnizaciones del último año): **preferencia** destacada.
 - **Con garantía real** (prenda, hipoteca): cobran con **preferencia sobre el bien gravado** (aquí se materializa el Libro 4 Nivel II).
 - **Fiscales** (con reglas especiales de preferencia).
 - **Con privilegio especial.**
 - **Comunes (quirografarios):** cobran al final, **a prorrata**.
 - **Especialistas:** **visitador** (verifica si procede el concurso), **conciliador** (reestructura), **síndico** (liquida); designados y supervisados por el IFECOM.
 - **Periodo de retroacción y acciones de ineficacia:** lapso previo a la sentencia en que los actos del deudor en **fraude** de la masa (p. ej., constituir garantías o pagar a un acreedor preferido) pueden declararse **ineficaces** y revertirse.
 - **Suspensión de ejecuciones:** declarado el concurso, se **suspenden** los procedimientos de ejecución individuales contra el deudor (los acreedores deben cobrar **dentro** del concurso) —el principio colectivo en acción—.

- **Separación de bienes:** los bienes que están en poder del deudor pero **no son suyos** (en consignación, arrendados, en fideicomiso) pueden **separarse** de la masa.
- **Contratos pendientes:** régimen de los contratos en curso al declararse el concurso (cuáles continúan, cuáles pueden terminarse).
- **Plan prepackado (*pre-pack*):** convenio **negociado por anticipado** con los acreedores y luego presentado al juez para su homologación rápida (reforma 2014).
- **Workout extrajudicial:** reestructura negociada **fuera** del concurso (sin tribunal), por acuerdo directo con los acreedores; más rápida y flexible, pero requiere consenso.
- **Distressed M&A / distressed debt:** comprar **activos/empresas** en concurso o **deuda** con descuento, como estrategia de inversión (private equity, special situations).

14. Desarrollo absoluto

Lo organizamos en: (A) el presupuesto y la **apertura** del concurso; (B) los **efectos** de la declaración; (C) la **conciliación** (reestructura); (D) la **quiebra** (liquidación) y la **prelación**; (E) la **retroacción** y los actos en fraude; (F) la **reestructuración** moderna (*pre-packs, workouts*) y el **distressed M&A**.

14.A · EL PRESUPUESTO Y LA APERTURA DEL CONCURSO

Presupuesto objetivo: el incumplimiento generalizado. No basta un solo impago: la LCM exige (arts. 9-10 ☺) que el comerciante incumpla con **dos o más acreedores** y que se cumplan condiciones cuantitativas —en esencia, que las obligaciones **vencidas** representen al menos el **35%** de todas sus obligaciones, **o** que no tenga activos líquidos suficientes para cubrir al menos el **80%** de sus obligaciones vencidas—. La idea: un problema **generalizado y estructural** de pagos, no un incumplimiento aislado.

Cómo se abre:

- **Solicitud** (la presenta el **propio deudor**) o **demanda** (la presentan **acreedores** o el **Ministerio Público**).

- **Visita de verificación:** el **visitador** (designado por el IFE-COM) revisa la contabilidad y verifica si se actualiza el incumplimiento generalizado, y rinde dictamen.
- **Sentencia de concurso:** el **juez** declara el concurso (si procede). A partir de ella corren los efectos (suspensión de ejecuciones, designación del **conciliador**, etc.).
- **Concurso con plan pre pactado:** el deudor puede solicitar el concurso **acompañando ya un convenio** negociado con la mayoría de sus acreedores (reforma 2014), acelerando el proceso.

14.B · LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO

- **Suspensión de ejecuciones individuales:** los acreedores ya **no pueden** embargar ni ejecutar por su cuenta; deben cobrar **dentro** del concurso (principio colectivo). (Con matices para ciertos créditos garantizados y laborales.)
- **Reconocimiento, graduación y prelación de créditos:** se abre el procedimiento para **reconocer** los créditos, **graduarlos** por rango y fijar el **orden de pago**.
- **Administración:** en la **conciliación**, el deudor suele **conservar** la administración (con vigilancia del conciliador) — modelo *debtor in possession*—; en la **quiebra**, lo desplaza el **síndico**.
- **Contratos pendientes:** régimen especial: algunos continúan, otros pueden darse por terminados; se busca preservar los contratos **útiles** para la conservación de la empresa.
- **Separación de bienes:** los bienes en poder del deudor que **no son suyos** (consignación, arrendamiento, fideicomiso) pueden **separarse** de la masa por sus titulares.
- **Compensación:** opera con reglas especiales (la compensación de deudas recíprocas anteriores al concurso suele admitirse; la posterior, restringida).

14.C · LA CONCILIACIÓN (LA ETAPA DE SALVAR LA EMPRESA)

Es la **primera etapa** y la **prioritaria**. Su finalidad: **conservar** la empresa mediante un **convenio concursal** con los acreedores. Elementos:

- **El conciliador:** especialista que **media** entre el deudor y los acreedores, vigila la administración y promueve el convenio.
- **Plazo:** la conciliación tiene una **duración limitada** (con prórrogas máximas); si no se logra el convenio en el plazo, se pasa a la **quiebra**.
- **El convenio concursal:** reestructura la deuda (típicamente **quitas** —remisión parcial—, **esperas** —ampliación de plazos—, **conversión** de deuda en capital, nuevas garantías). Debe aprobarse por las **mayorías** legales de acreedores reconocidos.
- **Homologación y *cram down*:** aprobado por las mayorías y **homologado** por el juez, el convenio **vincula a todos** los acreedores reconocidos, **incluso a los disidentes** (mecanismo de *cram down*: la minoría disidente queda obligada por la voluntad mayoritaria, con protecciones). Esto evita que un acreedor minoritario "secuestre" la reestructura.
- **Financiamiento durante el concurso:** la empresa necesita **operar** mientras se reestructura; la LCM permite **créditos** durante el concurso con cierta **preferencia** para el nuevo financiador (incentiva a financiar la salvación —análogo al *DIP financing* del Chapter 11—).

14.D · LA QUIEBRA (LIQUIDACIÓN) Y LA PRELACIÓN DE ACREEDORES

Si la conciliación fracasa (o el deudor pide la quiebra), se **liquida**:

- **El síndico:** desplaza al deudor en la administración, **realiza** (vende) los bienes —idealmente la **empresa como unidad** (going concern), para conservar el goodwill y el empleo, en vez de venderla "en pedazos"— y **paga** conforme a la prelación.

- **La prelación de acreedores (el corazón del concurso, arts. 217 c y ss.):** el orden de pago es: 1. **Singularmente privilegiados** (gastos de entierro y de enfermedad del comerciante persona física): un rango menor en monto pero primero en orden. 2. **Acreedores con garantía real** (prenda, hipoteca): cobran con **preferencia sobre el producto del bien gravado. Aquí se materializa el valor de las garantías (Libro 4 Nivel II):** quien tomó y perfeccionó bien su garantía recupera; quien no, baja a quirografario. 3. **Créditos con privilegio especial** (los que la ley dota de un privilegio sobre ciertos bienes). 4. **Créditos comunes (quirografarios):** cobran **al final, a prorrata** (lo que sobre).
- **Créditos laborales (salarios e indemnizaciones del último año):** tienen una **preferencia destacada** (la ley los protege especialmente, incluso por encima de otros).
- **Créditos fiscales:** con reglas especiales de preferencia.
- **Gastos del concurso (de administración y los del procedimiento):** se pagan con prioridad (créditos contra la masa).

Cómo razona un socio (prelación y garantías). *"El concurso es el día de la verdad de las garantías. Por eso, cuando estructuro un financiamiento, no pienso en el día del pago normal, sino en el día de la quiebra: ¿mi garantía real está bien constituida, perfeccionada e inscrita? Si lo está, cobro antes que los comunes sobre ese bien. Si descuidé el perfeccionamiento, bajo a quirografario y cobro a prorrata —casi nada—. Y vigilo dos peligros: los créditos laborales y fiscales, que pueden tener preferencia, y la retroacción (que mi garantía no se haya tomado demasiado cerca de la insolvencia, o me la anulan)."*

14.E · LA RETROACCIÓN Y LOS ACTOS EN FRAUDE DE ACREEDORES

El deudor en crisis puede tener la tentación de **vaciar** la empresa o **favorecer** a ciertos acreedores antes de caer en concurso. Para evitarlo, la LCM establece un **periodo de retroacción** (anterior a la sentencia): los actos realizados en ese periodo **en perjuicio de la masa** (donaciones, ventas a bajo precio, **constitución de garantías** por deudas preexistentes, **pagos anticipados** o preferencias indebidas) pueden declararse **ineficaces** y revertirse. *Implicación crítica (Libro 4 Nivel II):* una

garantía tomada demasiado cerca de la insolvencia puede ser **impugnada** y anulada; por eso las garantías deben tomarse **a tiempo** (al otorgar el crédito), no cuando el deudor ya está hundiéndose.

14.F · REESTRUCTURACIÓN MODERNA Y DISTRESSED M&A

- **Plan prepackado (*pre-pack*):** negociar el convenio **antes** de entrar al concurso, con la mayoría de los acreedores, y presentarlo ya hecho al juez para una **homologación rápida**. Combina la flexibilidad del acuerdo privado con la fuerza vinculante (incluido el *cram down*) del concurso.
- **Workout extrajudicial:** reestructurar **fuera** del concurso, por acuerdo directo con los acreedores (sin tribunal). Más rápido y discreto, pero requiere **consenso** (un acreedor "díscolo" —*holdout*— puede bloquearlo, al no haber *cram down* judicial).
- **Distressed M&A:** comprar la **empresa** o sus **activos** en concurso —a menudo "**limpios**" de pasivos (la venta como unidad productiva, autorizada en el concurso, puede purgar ciertos gravámenes)— a precio de crisis. Es una estrategia clásica del **private equity** y de los fondos de *special situations* (Nivel IV).
- **Compra de deuda (*distressed debt*):** adquirir los créditos contra la empresa con **descuento**, para luego (i) cobrar en el concurso, (ii) influir en la reestructura, o (iii) **convertir deuda en capital** y quedarse con la empresa (*loan-to-own*).

15. Explicación intuitiva

Imagina que una empresa es un **barco que se hunde** y los acreedores son pasajeros que quieren salvarse. Sin reglas, cada uno correría a llevarse lo que pudiera —los botes salvavidas, las provisiones— y el barco se hundiría más rápido y de forma injusta (los más fuertes se salvarían, los demás se ahogarían). El **concurso mercantil** es el **capitán** que pone orden:

- **Primero, intenta salvar el barco** (la **conciliación**): reúne a todos y propone un **plan** (reestructurar la deuda: que los acreedores acepten cobrar menos —quita— o más tarde —

espera— para que el barco siga a flote y todos cobren algo). Si la mayoría acepta, **todos** se suben al plan (incluso los que decían que no: *cram down*).

- **Si el barco no se puede salvar** (la **quiebra**): se reparten ordenadamente los botes salvavidas según una **lista de prioridad**: primero los **trabajadores** (sus salarios) y ciertos privilegiados; luego los que tenían un **bote reservado a su nombre** (los acreedores con **garantía real** sobre un bien — hipoteca, prenda—); y al final, lo que quede, se reparte **a prorrata** entre los **comunes** (que casi siempre se ahogan).

Dos lecciones de oro: **(1)** vale más **salvar el barco** (la empresa viva genera más que sus restos); y **(2)** si quieres un **bote reservado** (garantía real), debes **reservarlo a tiempo y bien** (perfeccionarlo e inscribirlo cuando das el crédito), porque si lo reservas cuando el barco ya se hunde (periodo de **retroacción**), el capitán te lo **quita**. Todo este libro enseña a navegar ese naufragio —y a prepararse para él **antes** de que ocurra—.

16. Ejemplos simples

1. **Incumplimiento generalizado.** Una empresa deja de pagar a varios proveedores y al banco; sus obligaciones vencidas superan el 35% del total. Se actualiza el **presupuesto** del concurso.
2. **Conciliación exitosa.** En el concurso, el deudor y sus acreedores acuerdan una **quita del 30%** y una **espera de 3 años**; la mayoría aprueba el convenio, el juez lo **homologa** y la empresa **sobrevive** (todos cobran más que si se hubiera liquidado).
3. **Prelación.** En la quiebra, tras vender los bienes, se paga **primero** a los trabajadores (salarios del último año), luego al **banco hipotecario** (sobre el inmueble hipotecado), y al final, lo que sobra, a los **proveedores comunes** a prorrata.
4. **Garantía que sí sirve.** Un banco con **hipoteca inscrita** sobre la planta cobra con **preferencia** sobre el producto de su venta; un proveedor sin garantía cobra al final, casi nada.

5. **Suspensión de ejecuciones.** Declarado el concurso, un acreedor que iba a embargar **debe detenerse** y cobrar **dentro** del concurso (principio colectivo).

17. Ejemplos complejos

1. **Garantía anulada por retroacción.** Un banco, viendo a su cliente en problemas, le exige **constituir una hipoteca** por un crédito que ya existía sin garantía, poco antes del concurso. El conciliador/acreedores **impugnan** ese acto: constituir garantía por una deuda preexistente en el **periodo de retroacción** es un acto en **fraude de la masa**; la hipoteca se declara **ineficaz** y el banco baja a **quirografario**. Lección: las garantías se toman **al otorgar el crédito**, no cuando el deudor ya se hunde.
2. **Cram down (convenio que vincula a disidentes).** Un convenio de reestructura es aprobado por la mayoría de los acreedores, pero un fondo (que compró deuda con descuento) **vota en contra** para bloquearlo y exigir más. Aprobado por las mayorías legales y **homologado**, el convenio **vincula también al fondo disidente** (*cram down*). Lección: el concurso evita que un *holdout* secuestre la salvación de la empresa (a diferencia del *workout* extrajudicial, donde el disidente sí puede bloquear).
3. **Distressed M&A (compra de la empresa en concurso).** Un fondo de PE compra la **empresa como unidad** dentro del concurso, "limpia" de buena parte de sus pasivos (que quedan en la masa para pagarse con el precio), conservando la operación, la marca y los empleos. Lección: el concurso puede ser una **oportunidad** de adquisición a precio de crisis y con activos saneados.
4. **Conflicto laboral vs. garantía real.** El banco hipotecario y los trabajadores reclaman sobre el mismo patrimonio. Los **créditos laborales** (salarios del último año) tienen **preferencia destacada**; el banco cobra sobre el bien hipotecado pero **después** de la preferencia laboral aplicable. Lección: la prelación no es solo "garantía real primero"; los laborales y fiscales pueden anteponerse.

18. Casos reales (jurisprudencia y operaciones estilizadas)

- **Grandes concursos mexicanos (estilizados):** reestructuras de grandes corporativos (vía concurso o *workout*) han mostrado el uso de la conciliación, los planes prepactados y el financiamiento durante el concurso para preservar empresas viables y miles de empleos.
- **Chapter 11 (EE. UU.) como referente:** reorganizaciones célebres (aerolíneas, automotrices) bajo Chapter 11 ilustran el modelo *debtor in possession* y el *DIP financing* que inspiraron las reformas mexicanas.
- **Retroacción y actos en fraude:** criterios sobre la **ineficacia** de garantías y pagos preferentes realizados en el periodo de retroacción.
- **Preferencia laboral:** criterios que confirman la **preferencia** de los créditos laborales (salarios e indemnizaciones) en el concurso.

Nota de método (Manifiesto XI.5): verificar la vigencia y los datos de los casos y normas antes de **Vitro (2010-2013 △ verificar): el caso mexicano que enseñó insolvencia transfronteriza al mundo**. Un grupo mexicano reestructuró en México y buscó el reconocimiento de su plan en Estados Unidos. El punto de choque fueron las **garantías intragrupo** y el trato a los acreedores extranjeros: los tribunales estadounidenses se resistieron a reconocer un plan que, en su lectura, liberaba obligaciones de filiales garantes en términos que su propio derecho no habría permitido.

Aeroméxico y Oro Negro △ litigaron, cada uno a su manera, en la frontera entre la LCM y el Chapter 11.

Las tres lecciones prácticas, y son de las más valiosas del libro.

Primera: la insolvencia moderna es multijurisdiccional. El *forum shopping* —elegir dónde iniciar el procedimiento— es una decisión estratégica de primer orden, y el reconocimiento del procedimiento extranjero depende de la **cortesía internacional** (*comity*), que no es automática. La **Ley Modelo UNCITRAL** de insolvencia transfronteriza existe precisamente para ordenar esto, y México se inspira en ella.

Segunda: quien domina las dos sillas gana. El abogado que entiende la LCM y el Chapter 11 tiene una ventaja enorme sobre el que solo conoce una, porque las reestructuras grandes se negocian entre las dos y el resultado depende de anticipar qué reconocerá el otro tribunal.

Tercera, y es la más simple de todas: en un concurso, el acreedor con garantía real perfeccionada cobra; el quirografario espera. Toda la técnica de Garantías —la inscripción, la perfección, el registro— que parecía trámite en tiempos buenos, es exactamente lo que decide quién recupera su dinero en tiempos malos. Ese es el momento en que se cobra el trabajo bien hecho años antes.

invocarlos; se exponen por su valor formativo.

19. Casos empresariales

- **Reestructura para sobrevivir:** una empresa con un buen negocio pero **sobreendeudada** usa la conciliación (o un *workout*) para reducir y reprogramar su deuda y seguir operando.
- **Financiamiento de la operación durante el concurso:** la empresa obtiene crédito (con preferencia) para seguir produciendo mientras se reestructura, evitando que se "muera" en el proceso.
- **Protección preventiva del acreedor:** un banco diseña su crédito con **garantías reales perfeccionadas y oportunas** (no en la víspera de la crisis) para asegurar su prelación si el deudor cae en concurso.

20. Casos corporativos (en transacciones)

- **Distressed M&A:** comprar activos o la empresa en concurso, "limpios" de pasivos, a precio de crisis (estrategia de PE/special situations — Nivel IV).
- **Loan-to-own (distressed debt):** un fondo compra la **deuda** con descuento, vota en la reestructura, **convierte deuda en capital** y se queda con el control de la empresa.
- **Due diligence de riesgo concursal:** evaluar la salud financiera de la *target* y de sus contrapartes clave, y el riesgo de que actos previos (garantías, transmisiones) sean impugnables por retroacción.
- **Cláusulas de protección:** en contratos y financiamientos, prever el escenario de insolvencia de la contraparte (garantías, *set-off*, *ipso facto clauses* —con sus límites—, *change of control*).

21. Casos internacionales

- **Insolvencia transfronteriza (Ley Modelo UNCITRAL):** cuando una multinacional quiebra en varios países, se coordinan los procedimientos: se reconoce el procedimiento **principal** (donde el deudor tiene su centro de intereses principales —COMI—) y se coopera con los **secundarios**. México incorporó la Ley Modelo en la LCM.
- **Chapter 11 vs. concurso mexicano:** el Chapter 11 (EE. UU.) es el referente del concurso reorganizativo (*debtor in possession*, *DIP financing*, *cram down*); el concurso mexicano comparte su filosofía conservativa.
- **Reestructuras cross-border:** las grandes reestructuras de deuda internacional combinan procedimientos en varias jurisdicciones, acuerdos entre acreedores (*intercreditor*) y, a veces, *schemes of arrangement* (Reino Unido) o Chapter 11.
- **Forum shopping concursal:** las empresas a veces eligen la jurisdicción de reestructura más favorable (Reino Unido, EE. UU.) —fenómeno que la cooperación internacional busca ordenar—.

22. Derecho comparado

SISTEMA	RASGOS DEL DERECHO CONCURSAL
México	LCM (2000): dos etapas (conciliación → quiebra); IFECOM y especialistas; prioridad a la conservación ; insolvencia transfronteriza (Ley Modelo UNCITRAL); planes prepactados (2014).
España	Ley Concursal (texto refundido 2020): concurso único con fase común, convenio o liquidación; planes de reestructuración (Directiva UE 2019).
Estados Unidos	Bankruptcy Code: Chapter 11 (reorganización, <i>debtor in possession</i> , <i>DIP financing</i> , <i>cram down</i>) y Chapter 7 (liquidación); el modelo mundial del concurso reorganizativo.
Delaware/ Nueva York	Sedes preferidas de los grandes Chapter 11 (tribunales especializados, jurisprudencia rica); centro del <i>distressed</i> global.
Unión Europea	Directiva 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva y segunda oportunidad; Reglamento de Insolvencia (coordinación transfronteriza dentro de la UE).
UNIDROIT	Trabajos sobre ejecución y garantías relacionados con la insolvencia.
UNCITRAL	Ley Modelo sobre Insolvencia Transfronteriza (adoptada por México, EE. UU. —Chapter 15— y muchos países); guía legislativa sobre insolvencia.
CISG	No aplica.
Common Law	Chapter 11/7 (EE. UU.); en Reino Unido, <i>administration</i> , <i>CVA</i> y los <i>schemes of arrangement / restructuring plans</i> (muy usados en reestructuras internacionales).
Civil Law	Modelos de concurso con fases de convenio/liquidación; convergencia hacia la reestructuración preventiva (influencia de la Directiva UE y del Chapter 11).

Convergencia clave: el mundo converge hacia el modelo **reorganizativo** (salvar la empresa viable) inspirado en el **Chapter 11**, con mecanismos de ***cram down*** (vincular a disidentes) y **financiamiento durante el concurso**. La **Ley Modelo UNCITRAL** coordina las insolvencias transfronterizas. El abogado de reestructuración internacional debe dominar Chapter 11 y los *schemes/restructuring plans* ingleses, además del concurso local.

23. Derecho mexicano

- **Ley de Concursos Mercantiles (LCM, 2000; reformas 2007 y 2014):** finalidad y carácter de interés público (art. 1 ☞);

presupuesto de incumplimiento generalizado (arts. 9-10 ⅈ); etapas (conciliación y quiebra); órganos (juez, IFECOM, visitador, conciliador, síndico); reconocimiento, graduación y **prelación** de créditos (arts. 217 ⅈ y ss.); **retroacción** y actos en fraude (arts. 112 ⅈ y ss.); convenio concursal y *cram down*; financiamiento durante el concurso; insolvencia transfronteriza (arts. 278 ⅈ y ss., Ley Modelo UNCITRAL); planes prepactados.

- **Competencia:** jueces de distrito (materia federal — comercio, art. 73-X ⅈ).
- **Normas conexas:** LGSM (responsabilidad de administradores en la zona de insolvencia), leyes financieras (régimen especiales para bancos y entidades financieras, que tienen procedimientos propios), Ley de Instituciones de Crédito, fiscal (preferencia de créditos fiscales) y laboral (preferencia de créditos laborales).

24. Jurisprudencia relevante

Verificar vigencia antes de citar: - **Preferencia de créditos laborales:** confirmación de su lugar destacado en la prelación. - **Acciones de ineficacia (retroacción):** criterios sobre la impugnación de actos en fraude de la masa (garantías y pagos preferentes en el periodo de retroacción).

- **Suspensión de ejecuciones:** alcance de la suspensión y su relación con los acreedores garantizados.
- **Convenio concursal y vinculación de disidentes:** validez del *cram down* y sus límites (protección de los acreedores minoritarios disidentes).
- **Reconocimiento de procedimientos extranjeros:** aplicación de la insolvencia transfronteriza.

25. Criterios de la Suprema Corte / tribunales

- **Constitucionalidad de la LCM:** validez del régimen concursal y de la suspensión de ejecuciones frente al derecho de los acreedores (interés público en la conservación de empresas).

- **Equilibrio entre conservación y derechos de los acreedores garantizados:** criterios que buscan preservar la empresa sin vaciar las garantías.
- **Preferencias (laboral, fiscal, garantía real):** interpretación de la prelación y su jerarquía.

26. Doctrina nacional

- **Doctrina sobre la LCM de 2000** (autores que participaron en su redacción y comentaristas): clave por la novedad y tecnicismo del régimen.
- **Obras clásicas de quiebras** (bajo la antigua Ley de Quiebras de 1943) para el contraste histórico.
- **Literatura de reestructuración y *distressed*** (más reciente): planes prepactados, *workouts*, financiamiento concursal y *distressed M&A*.
- **Doctrina mercantil general** (Mantilla Molina, Barrera Graf) para el marco del comerciante y la empresa.

27. Doctrina internacional

- **US Bankruptcy Code y su doctrina (Chapter 11):** el modelo de referencia mundial; literatura abundante sobre reorganización, *DIP financing* y *cram down*.
- **UNCITRAL, Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia y Ley Modelo sobre Insolvencia Transfronteriza.**
- **Directiva UE 2019/1023** sobre reestructuración preventiva y segunda oportunidad.
- **Doctrina inglesa sobre *schemes of arrangement* y *restructuring plans*** (muy usados en reestructuras internacionales).

28. Opiniones críticas (postura del Consejo)

1. **El concurso mexicano sigue siendo lento y subutilizado.** Pese a la filosofía conservativa de la LCM, los tiempos y la incertidumbre llevan a muchas empresas a preferir **workouts extrajudiciales** o a colapsar sin reestructura orde-

nada; el Consejo aboga por una mayor **agilidad** y uso de los **planes prepagados**.

2. **La prelación debe respetar las garantías para no encarecer el crédito.** El Consejo subraya que un sistema que **respete** las garantías reales (y su prelación) **abarata** el crédito de todo el país; debilitarlas (por preferencias excesivas o impugnaciones laxas) tiene un costo macroeconómico.
3. **La retroacción es un arma de doble filo.** Necesaria contra el fraude, pero usada con laxitud genera **inseguridad** sobre las garantías; el Consejo recomienda tomar garantías **a tiempo** (al originar el crédito) y documentar su causa para resistir impugnaciones.

29. Debate doctrinal

- **¿Conservación o liquidación como prioridad?** El modelo moderno prioriza **salvar** la empresa viable, pero hay tensión: ¿hasta cuándo "mantener viva" una empresa inviable, a costa de los acreedores? El **test de viabilidad** es clave.
- **Prelación: ¿hasta dónde proteger a laborales y fiscales por encima de las garantías?** Proteger al trabajador es justo, pero una preferencia excesiva **erosiona** las garantías y encarece el crédito. El equilibrio es político y económico.
- **Cram down: ¿vincular a los disidentes es justo?** Necesario para evitar el *holdout* (que un minoritario secuestre la reestructura), pero debe proteger a los disidentes (que no reciban menos que en una liquidación —*best interest test*—).
- **Deberes de los administradores en la "zona de insolvencia":** cuando la empresa se acerca a la insolvencia, ¿deben los administradores velar por los **acreedores** (no agravar el pasivo) y no solo por los accionistas? Debate de gobierno corporativo y responsabilidad.
- **Insolvencia transfronteriza: ¿universalismo o territorialismo?** ¿Un solo procedimiento global (universalismo, COMI) o procedimientos locales coordinados (territorialismo)? La Ley Modelo UNCITRAL adopta un universalismo **modificado**.

30. Errores comunes

- **Tomar garantías tarde (en la víspera de la crisis).** Pueden ser **impugnadas** por retroacción y anuladas; la garantía debe tomarse **al originar** el crédito.
- **Confiar en cobrar por fuera tras el concurso.** Declarado el concurso, las **ejecuciones individuales se suspenden**; hay que cobrar **dentro**.
- **Subestimar las preferencias laboral y fiscal.** Pueden anteponerse a las garantías reales en la prelación.
- **Creer que el quirografario cobra parejo con el garantizado.** No: el garantizado cobra **antes** sobre su bien; el común, al final y a prorrata (casi nada).
- **Pensar que el concurso es solo liquidación.** La **prioridad** es la **conciliación** (reestructurar y salvar).
- **Bloquear una reestructura siendo minoría (en concurso).** El *cram down* vincula a los disidentes; el *holdout* solo funciona en *workouts* extrajudiciales.
- **Ignorar la insolvencia transfronteriza** en grupos multinacionales (COMI, reconocimiento).

31. Mitos frecuentes

- *"La quiebra es un castigo/delito."* **Falso (hoy):** el fracaso honesto se gestiona; solo el **fraude** se castiga.
- *"En el concurso, el más rápido en embargar gana."* **Falso:** se **suspenden** las ejecuciones; rige el principio **colectivo**.
- *"Tener una garantía garantiza cobrar todo."* **Matiz:** cobras con preferencia **sobre tu bien**, pero después de laborales/fiscales aplicables, y solo si la garantía fue **bien tomada y a tiempo**.
- *"El concurso siempre destruye la empresa."* **Falso:** la **conciliación** busca **salvarla** (y la venta como unidad conserva la operación).
- *"Comprar una empresa en concurso es comprar sus problemas."* **No necesariamente:** el *distressed M&A* puede adquirir activos/empresa **"limpios"** de pasivos.

32. Preguntas difíciles

1. ¿Hasta cuándo conviene **mantener viva** una empresa en concurso? ¿Cómo se mide su **viabilidad**?
2. ¿Es justo que los **créditos laborales y fiscales** se antepongan a las **garantías reales**? ¿Cuál es el costo macroeconómico de debilitar las garantías?
3. ¿El **cram down** (vincular a disidentes) respeta los derechos de los acreedores minoritarios? ¿Qué protecciones lo legitiman (*best interest test*)?
4. ¿Debería México facilitar más los **workouts** y los **planes prepactados** para ganar velocidad, reduciendo el papel del tribunal?
5. ¿Qué deberes tienen los **administradores** en la "zona de insolvencia": seguir maximizando para los accionistas o proteger a los acreedores?

33. Casos de examen (con respuesta modelo)

P1. *¿Cuál es el presupuesto del concurso mercantil?* **R.** El **incumplimiento generalizado** de pagos (a dos o más acreedores) que rebase los umbrales del art. 10 $\odot$ LCM (vencidas $\geq 35\%$ del total, o sin activos para cubrir el 80% de las vencidas). No basta un solo impago.

P2. *¿Cuáles son las dos etapas y sus finalidades?* **R.** La **conciación** (finalidad: **conservar** la empresa mediante convenio con los acreedores) y, en su defecto, la **quiebra** (finalidad: **liquidar** y pagar conforme a la prelación).

P3. *Explique la prelación de acreedores.* **R.** Orden de pago: singularmente privilegiados $\rightarrow$ (con preferencia destacada, **laborales** del último año) $\rightarrow$ **con garantía real** (sobre su bien) $\rightarrow$ **fiscales** $\rightarrow$ con privilegio especial $\rightarrow$ **comunes** (a prorrata). Los gastos del concurso se pagan con prioridad.

P4. *¿Qué es la retroacción y para qué sirve?* **R.** El periodo previo a la sentencia en que los actos del deudor **en fraude de la masa** (garantías por deudas previas, pagos preferentes, ventas a bajo precio) pueden declararse **ineficaces**, para proteger la igualdad de los acreedores.

P5. ¿Qué es el *cram down*? R. El mecanismo por el que el convenio concursal, aprobado por las **mayorías** legales y **homologado**, **vincula incluso a los acreedores disidentes**, evitando que una minoría bloquee la reestructura (con protección de que reciban al menos lo que obtendrían en liquidación).

34. Simulador (ejercicio tipo despacho)

Rol: asociado de reestructuración. **Cliente:** un **banco** acreedor de "Manufacturas del Bajío, S.A." por \$300M, **garantizado** con hipoteca (planta) y prenda (maquinaria), **bien inscritas hace 4 años**. La empresa entró en concurso; debe también \$80M a proveedores (quiérogafarios), \$40M de salarios e indemnizaciones del último año, y \$30M al SAT. El conciliador propone una reestructura (quita del 25%, espera de 4 años). Un fondo de *distressed* compró \$50M de deuda quiérogafaria y quiere bloquear el convenio.

Tarea: asesora al banco: (1) ¿en qué **rango de la prelación** cobra y qué tan protegidas están sus garantías (laborales y fiscales primero)?; (2) ¿le conviene **apoyar la conciliación** (quita/ espera) o empujar a la **quiebra** (liquidar y cobrar sobre sus bienes)? Compara la recuperación esperada en cada escenario; (3) ¿pueden anularse sus garantías por **retroacción** (se tomaron hace 4 años: ¿están a salvo)?; (4) ¿puede el fondo *distressed* **bloquear** el convenio o lo vincula el ***cram down***?; (5) propón la estrategia (votar el convenio, negociar mejores términos, ejecutar garantías). Concluye con la recomendación y su fundamento.

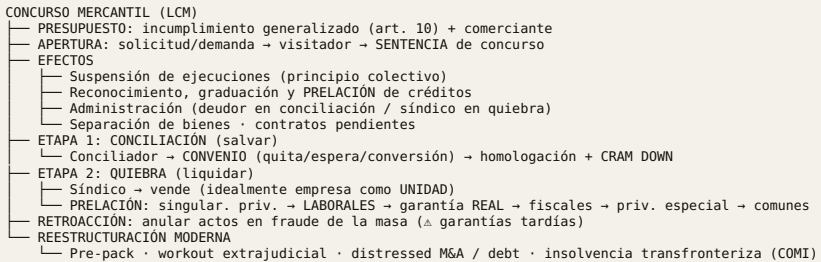
*(Pista de evaluación: la mejor respuesta ubica al banco como acreedor con garantía real (cobra sobre sus bienes, tras laborales/fiscales aplicables); nota que las garantías de hace 4 años están fuera del periodo de retroacción (a salvo); explica que el fondo disidente queda vinculado por el *cram down*; y compara recuperación en conciliación vs. quiebra para decidir el voto.)*

35. Flashcards

- **¿Presupuesto del concurso?** → Incumplimiento **generalizado** (umbrales del art. 10 ☺).
- **¿Dos etapas?** → Conciliación (salvar) → Quiebra (liquidar).
- **¿Finalidad prioritaria?** → **Conservar** la empresa.

- **¿Quién media en la conciliación / quién liquida?** → Conciador / síndico (designados por el IFECOM).
- **¿Prelación (orden)?** → Singularmente privilegiados → laborales → garantía real → fiscales → privilegio especial → comunes.
- **¿Dónde cobra el acreedor con garantía real?** → Con preferencia **sobre su bien** (tras laborales/ fiscales aplicables).
- **¿Qué es la retroacción?** → Anular actos en fraude de la masa previos a la sentencia.
- **¿Cram down?** → El convenio vincula a los disidentes.
- **¿Suspensión de ejecuciones?** → Declarado el concurso, se cobra **dentro** (principio colectivo).
- **¿Convenio concursal?** → Acuerdo de reestructura (quita/espera/conversión) homologado.
- **¿Distressed M&A?** → Comprar empresa/activos en concurso (a precio de crisis, "limpios").
- **¿COMI?** → Centro de intereses principales (insolvencia transfronteriza).

36. Mapas mentales



37. Cuadros comparativos

Conciliación vs. quiebra

	CONCILIACIÓN	QUIEBRA
Finalidad	Conservar (reestructurar)	Liquidar
Instrumento	Convenio concursal	Venta de bienes
Administración	Deudor (con vigilancia)	Síndico
Resultado	Empresa sobrevive	Empresa se liquida

Prelación (orden de pago)

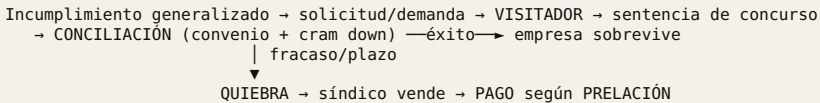
RANGO	ACREEDORES	COBRAN
1	Singularmente privilegiados	Primero (montos menores)
—	Laborales (último año)	Preferencia destacada
2	Con garantía real	Sobre el bien gravado
—	Fiscales	Preferencia especial
3	Con privilegio especial	Sobre ciertos bienes
4	Comunes (quirografarios)	Al final, a prorrata

Workout vs. concurso

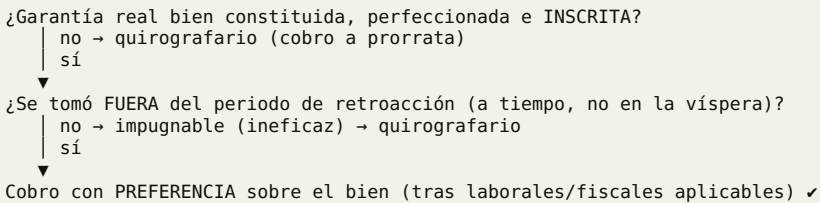
	WORKOUT (EXTRAJUDICIAL)	CONCURSO (JUDICIAL)
Tribunal	No	Sí
Velocidad	Rápido	Más lento
Vincula a disidentes	No (riesgo de <i>holdout</i>)	Sí (cram down)
Confidencialidad	Alta	Pública

38. Diagramas

Flujo del concurso:



¿Mi garantía sobrevive al concurso?



39. Mnemotecnias

- **Finalidades (en orden):** "primero *SALVAR* (conciliación), luego *LIQUIDAR* (quiebra)".
- **Prelación: "La-Ga-Fi-Co"** → Laborales, Garantía real, Fiscales, Comunes (con los singularmente privilegiados al frente).
- **Garantía:** "a tiempo y bien inscrita, o en el concurso no sirve" (retroacción).
- **Cram down:** "la mayoría arrastra al que dijo que no".

- **Colectivo:** *"declarado el concurso, nadie cobra por fuera".*
- **Conservación:** *"la empresa viva vale más que sus pedazos".*
- **Distressed:** *"comprar barato en la crisis, a veces limpio de pasivos".*

40. Resumen ejecutivo

El **concurso mercantil** es el derecho de la empresa insolvente: un procedimiento **colectivo** y **universal** (todos los acreedores, todos los bienes) que, ante el **incumplimiento generalizado** de pagos, persigue dos finalidades **en orden: primero conservar** la empresa viable —la **conciliación**, que reestructura la deuda mediante un **convenio** (quitas, esperas, conversión) vinculante incluso para los disidentes (**cram down**)— y, si fracasa, **liquidar** ordenadamente —la **quiebra**, donde el síndico vende los bienes (idealmente la empresa **como unidad**) y paga conforme a la **prelación**—. La prelación es el corazón de la materia: cobran primero los **singularmente privilegiados** y los **laborales** (preferencia destacada), luego los acreedores **con garantía real** (sobre su bien), los **fiscales** y los de privilegio especial, y al final los **comunes** a prorrata. La declaración de concurso **suspende** las ejecuciones individuales y abre la posibilidad de **anular** (retroacción) los actos en fraude de la masa —incluidas las **garantías tomadas tarde**—.

Para el abogado corporativo, este libro es la **prueba de fuego de las garantías** (Libro 4 Nivel II): el día de la insolvencia se descubre quién las tomó bien, a tiempo y perfeccionadas (y cobra) y quién quedó como quirografario (y no cobra). De ahí su doble enseñanza: **proteger al acreedor antes de la crisis** (garantías reales, oportunas y bien inscritas) y **navegar la crisis** cuando llega (reestructurar vía conciliación o *workout*, o aprovecharla vía **distressed M&A** y **distressed debt**). Es una especialidad técnica y de alto valor en banca, reestructuración y private equity, y la penúltima pieza del Nivel III antes del gobierno corporativo y del salto al Corporate Law.

41. Checklist

Para el acreedor (antes y durante la crisis):

- [] ¿Tomé **garantía real**, bien **perfeccionada e inscrita**, y a **tiempo** (fuera de retroacción)?
- [] ¿En qué **rango** de la prelación cobro? ¿Hay preferencias laborales/fiscales por delante?
- [] Declarado el concurso, ¿estoy cobrando **dentro** (no por ejecución individual)?
- [] ¿Me conviene **apoyar la conciliación** (reestructura) o empujar la **quiebra**? (comparar recuperación)
- [] ¿Puede el **cram down** vincularme, o puedo influir en el convenio?

Para la empresa en crisis:

- [] ¿Es viable? ¿Conviene **conciliación**, **workout** o **plan pre-pactado**?
- [] ¿Puedo obtener **financiamiento durante el concurso** para seguir operando?
- [] ¿Los administradores están cuidando sus **deberes en la zona de insolvencia** (no agravar el pasivo, no preferir indebidamente)?

Para el inversionista (distressed):

- [] ¿Conviene comprar **deuda** (distressed debt / loan-to-own) o **activos/empresa** (distressed M&A)?
- [] ¿La compra es "**limpia**" de pasivos? ¿Riesgo de impugnación?

42. Bibliografía comentada

- **Ley de Concursos Mercantiles (2000, reformas 2007 y 2014) y su doctrina.** El derecho positivo; estúdialo con el texto vigente y los comentarios a las reformas (planes pre-pactados, financiamiento).
- **US Bankruptcy Code — Chapter 11 (y su literatura).** El modelo mundial de la reorganización; indispensable para entender la filosofía conservativa y el *distressed* internacional.

- **UNCITRAL, *Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia y Ley Modelo sobre Insolvencia Transfronteriza*.** Para el marco internacional y la coordinación de grupos multinacionales.
- **Directiva UE 2019/1023** sobre reestructuración preventiva y segunda oportunidad.
- **Doctrina mexicana de reestructuración y *distressed*** (reciente): para los *workouts*, los *prepacks* y el *distressed M&A*.
- **Thomas Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law* (1986).** La obra que explica el concurso como solución a un problema de acción colectiva (§6). Si vas a leer un solo libro teórico de esta materia, es este.
- **Baird & Rasmussen, *The End of Bankruptcy* (Stanford Law Review, 2002).** La crítica de Chicago a la reorganización. Provocador y necesario: obliga a justificar por qué se salva una empresa en lugar de liquidarla.
- **Ley Modelo UNCITRAL sobre Insolvencia Transfronteriza.** El marco que ordena el reconocimiento entre jurisdicciones y en el que se inspira el régimen mexicano. Imprescindible si vas a trabajar en reestructuras de grupos con presencia internacional.
- **Los expedientes de *Vitro*, *Aeroméxico* y *Oro Negro* ⚠,** para ver la insolvencia transfronteriza mexicana en la práctica y no en la teoría.

43. Ruta hacia el siguiente libro

Lo que acabas de aprender —cómo se reestructura o liquida la empresa insolvente y cómo se reparte entre acreedores— será **indispensable para comprender** el último libro del Nivel III: el **gobierno corporativo**, que busca, entre otras cosas, **prevenir** la crisis mediante buenos consejos, control y deberes fiduciarios, y que es el puente directo al Corporate Law.

- **Siguiente libro:** [Nivel III · Libro 7] **Gobierno Corporativo (mercantil)** — consejo de administración, deberes de diligencia y lealtad, comités, protección de minorías y control; con-

solida lo visto en Sociedades (LGSM) y LMV y abre el Nivel IV.

- **Conexión de largo alcance:** el *distressed M&A*, el *distressed debt* y la reestructuración reaparecen, con plena potencia, en el **Nivel IV** (private equity, special situations) y en el **financiamiento de adquisiciones**. Vuelve a las secciones 14.D, 14.E y 14.F cuando llegues allí.

◆ ¿Por qué esto importa para un abogado corporativo?

Porque el concurso es **el día de la verdad de todo lo que el abogado estructuró antes**. El crédito, las garantías, los contratos, la estructura societaria: todo se pone a prueba cuando la empresa no puede pagar. El abogado que entiende la **prelación** y la **retroacción** diseña financiamientos que **sí cobran** en la insolvencia (garantías reales, oportunas y bien inscritas); el que no, deja a su cliente como quirografario. Además, la **reestructuración** (salvar empresas viables) y el **distressed M&A** (comprar en la crisis) son nichos de **altísimo valor** en banca y private equity. Y para el lado del deudor, saber cuándo y cómo acogerse al concurso (o reestructurar extrajudicialmente) puede salvar a la empresa y a los empleos. Es una de las materias que más distingue al abogado de negocios completo.

◆ Cómo piensa un socio de un despacho internacional

"Cuando estructuro un financiamiento, no pienso en el día del pago puntual, sino en el peor día: la quiebra del deudor. Me pregunto: ¿mi garantía real está bien tomada, perfeccionada e inscrita, y a tiempo (fuera del periodo de retroacción)? ¿En qué rango de la prelación caigo —después de laborales y fiscales—? Porque ese día se separa al acreedor que recupera del que mira cómo otros cobran. Cuando la crisis llega, decido rápido: ¿la empresa es viable (entonces reestructuro: conciliación, workout o pre-pack, usando el cram down para vencer a los holdouts) o no (entonces ejecuto y cobro sobre mi colateral)? Y como inversionista distressed, veo oportunidad: comprar deuda con descuento para hacer loan-to-own, o comprar la empresa en concurso limpia de pasivos. El concurso, bien entendido, es tanto un riesgo a blindar como una oportunidad a capturar."

◆ Errores que cuestan millones

1. **Tomar garantías en la víspera de la insolvencia.** Constituir una hipoteca o prenda por una deuda preexistente justo antes del concurso las expone a ser **anuladas por retroacción**: el acreedor pasa de garantizado a quirografario. Pérdida potencial: todo el colateral. *Prevención*: garantías **al originar** el crédito.
2. **Descuidar el perfeccionamiento/inscripción de la garantía.** Una garantía no inscrita puede ser inoponible y degradar al acreedor a común en el concurso. *Prevención*: perfeccionar e inscribir (Libro 4 Nivel II).
3. **Empujar a la liquidación una empresa viable.** Liquidar "en pedazos" una empresa que podía salvarse destruye el goodwill y reduce la recuperación de **todos** (incluido el propio acreedor). *Prevención*: evaluar la viabilidad y favorecer la **conciliación**/venta como unidad.
4. **Confiar en un *workout* con un acreedor díscolo.** Sin *cram down* judicial, un *holdout* puede **bloquear** la reestructura extrajudicial. *Prevención*: usar el concurso (o un *pre-pack*) cuando el consenso no es total.
5. **Ignorar la insolvencia transfronteriza.** En grupos multinacionales, no coordinar los procedimientos (COMI, reconocimiento) genera pérdidas y litigios paralelos.

Cierre del Libro. Has aprendido a navegar el **peor día** de la empresa —y a prepararte para él antes de que llegue—. Con esto dominas el ciclo completo del crédito: nace (obligaciones), circula (títulos), se garantiza (garantías) y, si todo falla, se resuelve en el **concurso**. Solo resta un libro para cerrar el Nivel III: el **gobierno corporativo**, que busca **prevenir** la crisis con buenos consejos y deberes fiduciarios, y que es la puerta directa al **Nivel IV: Corporate Law y M&A**. El objetivo está cada vez más cerca.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las

secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE III

[Nivel III · Libro 7] Gobierno Corporativo

☞ **Apóstrofe de vigencia — léela cada vez.** El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

¿Quién manda en una empresa, cómo decide y ante quién responde? El **gobierno corporativo** es el sistema de **poder, control y responsabilidad** dentro de la sociedad: cómo se reparte el poder entre accionistas, consejo y dirección; cómo se vigila a quienes administran dinero ajeno; y cómo se protege a los que no controlan (minoritarios) y a los terceros. Nació para resolver el **problema de agencia** (Libro 9, Nivel I): que los administradores sirvan al interés de la sociedad y de los accionistas, no al suyo propio. Es la materia que cierra el Nivel III y la **puerta directa al Corporate Law y al M&A**.

Etiquetas: derecho mercantil · gobierno corporativo · consejo de administración · deberes fiduciarios · control · minorías
Prerrequisitos: Sociedades (LGSM), Mercado de Valores (LMV), Historia del Pensamiento Jurídico y Económico (problema de agencia). **Estándar:** V3 (43 secciones + secciones transversales). ⌚ **Tiempo estimado de dominio:** 4 semanas (≈ 40–50 h de estudio activo). Lectura de reconocimiento: 8–9 h. *Estúdialo en bloques: el problema de agencia y los órganos → deberes fiduciarios → comités y control → minorías, partes relacionadas y ESG.*

Aviso de método. Tratado, no repaso. Consolida lo visto en Sociedades (LGSM) y LMV y lo eleva a sistema, con ejemplos trabajados, "cómo razona un socio/consejero" y conexión directa con M&A, private equity y compliance.

NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL (VISTA RÁPIDA)

Litigio	★★★☆☆
Corporate	★★★★★
M&A	★★★★★
Mercado de Valores	★★★★★
Venture Capital	★★★★★
Private Equity	★★★★★
Gobierno Corporativo	★★★★★
Compliance	★★★★★
Derecho Bancario	★★★★☆
Empresa Familiar	★★★★★

Es transversal a todo el derecho corporativo: define el poder y la responsabilidad en la empresa, y es central en M&A (deberes del consejo ante una venta), VC/PE (derechos de los inversionistas), emisoras (LMV) y compliance.

1. Introducción

Una sociedad anónima tiene un problema estructural: los **dueños** (accionistas) no son, normalmente, quienes la **administran** (los consejeros y directivos). Esa separación entre **propiedad** y **control** —genial para reunir capital (Libro 2, Nivel III)— crea un riesgo: que quienes administran **dinero ajeno** lo hagan en su propio beneficio (desviar recursos, pagarse de más, perpetuarse en el puesto, tomar riesgos imprudentes) en vez de servir al **interés de la sociedad**. Ese es el **problema de agencia** (Jensen-Meckling, Libro 9 Nivel I): el conflicto entre el **principal** (accionistas) y el **agente** (administradores).

El **gobierno corporativo** es el conjunto de **reglas, estructuras y prácticas** que resuelven ese problema: cómo se integra y funciona el **consejo de administración**, qué **deberes** (de diligencia y lealtad) tienen los administradores, qué **comités** vigilan, cómo se protege a los **minoritarios**, cómo se controlan las **operaciones con partes relacionadas** y cómo se rinde cuentas. La idea central: el gobierno corporativo alinea los incentivos para que **el poder se ejerza en interés de la socie-**

dad y de sus accionistas (y, en la visión moderna, de los *stakeholders*). Para el abogado corporativo, es la materia que organiza el poder dentro de la empresa —y, por eso, es central en cada M&A (los deberes del consejo al vender), en cada inversión de VC/PE (los derechos del inversionista) y en cada emisora (LMV).

2. Objetivos del libro

Al terminar, el lector será capaz de:

- **Entender el problema de agencia** y cómo el gobierno corporativo lo resuelve (alineación de incentivos, control, transparencia).
- **Dominar la estructura de poder:** la relación entre **asamblea, consejo de administración y dirección general**, y la integración del consejo (ejecutivos, patrimoniales, **independientes**).
- **Aplicar los deberes fiduciarios:** el deber de **diligencia/cuidado** (con la **regla de juicio de negocio**) y el deber de **lealtad** (conflictos de interés, oportunidades societarias, partes relacionadas), y la **responsabilidad** por su incumplimiento.
- **Manejar los comités** (auditoría, prácticas societarias) y los mecanismos de control (auditoría, vigilancia).
- **Proteger a las minorías** y controlar las **operaciones con partes relacionadas**.
- **Comprender el debate shareholder vs. stakeholder y el ESG**, y conectar el gobierno corporativo con el M&A (deberes del consejo ante una OPA/venta), el VC/PE y el **compliance**.

3. Importancia profesional

El gobierno corporativo es **transversal y de élite**:

1. **Define quién decide y quién responde.** En cada operación relevante (un M&A, una emisión, una operación con parte relacionada), la pregunta es: ¿quién tiene la facultad y qué deberes debe cumplir? El gobierno corporativo lo responde.

2. **Es central en M&A.** Cuando se vende una empresa, el **consejo** tiene deberes fiduciarios reforzados (maximizar el valor para los accionistas, procesos competitivos, *fairness opinions*); los estándares de Delaware (Revlon, Unocal) son derecho vivo del M&A (Nivel IV).
3. **Es el lenguaje del VC/PE.** Los derechos de los inversionistas (asientos en el consejo, vetos sobre *reserved matters*, información) son **diseño de gobierno corporativo** (Libro 2 Nivel III: S.A.P.I.).
4. **Es el corazón del compliance y de la responsabilidad de directivos.** Los deberes fiduciarios, los comités de auditoría y los programas de cumplimiento (incluida la responsabilidad penal de la persona moral, Libro 5 Nivel I) son gobierno corporativo en acción.

4. Historia de la institución

- **Origen del problema:** ya Adam Smith (1776) advirtió que los administradores de dinero ajeno (en las primeras sociedades anónimas) no lo cuidarían con la misma vigilancia que el propio. El problema nació con la **separación de propiedad y control** de la S.A.
- **Berle y Means (1932), *The Modern Corporation and Private Property*:** la obra fundacional; documentaron cómo en las grandes corporaciones el **control** pasó de los accionistas dispersos a los **administradores**, planteando el problema central del gobierno corporativo.
- **Teoría de la agencia (Jensen-Meckling, 1976):** formalizó el problema en clave económica (costos de agencia) y dio el marco para diseñar mecanismos de control (Libro 9, Nivel I).
- **Los grandes escándalos y las reformas:** los fraudes corporativos (**Enron**, WorldCom, 2001-2002) detonaron la **Sarbanes-Oxley** (2002, EE. UU.): independencia de auditores, comités de auditoría, certificación de estados financieros por los directivos, responsabilidad reforzada. La crisis de 2008 reforzó la atención al gobierno de los bancos y a la gestión de riesgos.

- **Códigos de mejores prácticas:** los **Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE** (1999, varias actualizaciones) y los códigos nacionales (en México, el **Código de Principios de Gobierno Corporativo** del Consejo Coordinador Empresarial) difundieron estándares; primero **voluntarios**, luego en buena parte **obligatorios** para emisoras.
- **México:** la **LMV de 2005** convirtió en **derecho positivo** el gobierno corporativo de las emisoras (consejeros independientes, comités de auditoría y de prácticas societarias, deberes de diligencia y lealtad codificados); la **LGS** rige el de las sociedades en general.

5. Evolución histórica

- **De la administración informal al consejo profesional:** del dueño-administrador al **consejo de administración** con consejeros **independientes** y **comités** especializados.
- **De la confianza a la regulación:** de confiar en la honradez de los administradores a **codificar deberes** (diligencia, lealtad), exigir **transparencia** y crear **controles** (auditoría, comités).
- **De lo voluntario a lo obligatorio:** los códigos de mejores prácticas (voluntarios) se volvieron **ley** para las emisoras (LMV, Sarbanes-Oxley).
- **Del shareholder al stakeholder (ESG):** del paradigma de **maximizar el valor del accionista** (Friedman) a una visión que incorpora a los **grupos de interés** (empleados, comunidad, ambiente) y la **sostenibilidad** (ESG): la frontera actual del gobierno corporativo (Nivel IV).
- **Del gobierno nacional al global:** estándares internacionales (OCDE), inversores institucionales globales que exigen buen gobierno, y la convergencia de prácticas.

Idea de evolución clave: el gobierno corporativo es la respuesta evolutiva al **problema de agencia** que nació con la sociedad anónima. Cada crisis (1929, Enron, 2008) produjo **más independencia, más transparencia y más responsabilidad**. Entender esa lógica —alinear al agente con el principal— explica cada regla de la materia.

6. Contexto económico

El gobierno corporativo es, en esencia, **economía de los incentivos** (Libro 9, Nivel I). El **problema de agencia** genera **costos** (de monitoreo, de garantía, la pérdida residual); el buen gobierno los **reduce**, alineando al administrador con el accionista mediante: (i) **control** (consejo, comités, auditoría); (ii) **incentivos** (compensación ligada al desempeño, acciones, opciones); (iii) **transparencia** (información que permite vigilar); y (iv) el **mercado** (la amenaza de una **OPA hostil** —el "mercado por el control corporativo"— disciplina a los malos administradores). Económicamente, el buen gobierno **crea valor**: las empresas bien gobernadas atraen más inversión, a menor costo de capital, y valen más (los inversionistas pagan una **prima** por buen gobierno). El mal gobierno destruye valor (fraudes, expropiación de minoritarios, mala gestión de riesgos).

7. Contexto político

El gobierno corporativo es objeto de regulación porque las grandes corporaciones concentran **poder económico** y su mala gestión tiene efectos sistémicos (crisis de 2008). El Estado regula vía la **LMV/CNBV** (gobierno de emisoras), la **LGS** (sociedades en general) y normas sectoriales (bancos, con gobierno reforzado). La tensión política: cuánto **imponer** por ley (independencia, comités, límites a la compensación) vs. dejar a la **autorregulación** (códigos voluntarios, decisión de los accionistas). El **ESG** y la **sostenibilidad** introducen una dimensión política nueva: ¿debe la empresa servir solo al accionista o también al interés público y al ambiente? Es uno de los grandes debates político-económicos actuales.

8. Contexto social

El gobierno corporativo tiene impacto social: las decisiones de las grandes empresas afectan a **empleados, consumidores, comunidades y al ambiente**. La visión **stakeholder** y el **ESG** responden a la demanda social de que las empresas sean **responsables** (no solo rentables). En México, la **empresa fami-**

liar —columna del tejido económico— enfrenta el reto de **profesionalizar su gobierno** (separar familia, propiedad y gestión; consejo con independientes; protocolo familiar; sucesión ordenada) para sobrevivir más allá de la primera generación. El buen gobierno corporativo es, socialmente, un mecanismo de **confianza**: protege el ahorro invertido (Afores, fondos), a los minoritarios y a los terceros que se relacionan con la empresa.

9. Contexto empresarial

Para la empresa, el gobierno corporativo es **cómo se organiza el poder y se toman las decisiones**:

- **Estructura de gobierno**: asamblea (dueños), **consejo de administración** (estrategia y vigilancia), **dirección general** (operación), **comités** (auditoría, prácticas societarias, riesgos), órgano de **vigilancia**.
- **Profesionalización**: especialmente en la **empresa familiar**, montar un gobierno corporativo serio (consejo con independientes, comités, reglas claras) eleva el valor y prepara para crecer, recibir inversión o vender.
- **Gestión de conflictos y partes relacionadas**: controlar que los administradores y socios de control **no abusen** (operaciones con partes relacionadas a precio de mercado, con revelación y aprobación).
- **Atracción de inversión**: los inversionistas (VC, PE, institucionales) **exigen** buen gobierno y derechos (asientos en el consejo, vetos, información) como condición para invertir.
- **Preparación para M&A e IPO**: un gobierno corporativo robusto es **valor** en una venta y requisito para salir a bolsa (LMV).

El abogado corporativo **diseña, opera y litiga** el gobierno corporativo: redacta estatutos y reglamentos de consejo, asesora a consejeros sobre sus deberes, estructura los derechos de los inversionistas, controla las operaciones con partes relacionadas y guía al consejo en los momentos críticos (un M&A, una crisis, una OPA). Es la materia que lo convierte en **asesor del consejo** —el rol de mayor responsabilidad y prestigio—.

10. Definiciones doctrinales

- **Gobierno corporativo (OCDE):** el **sistema** por el cual las sociedades son **dirigidas y controladas**; comprende el conjunto de relaciones entre la administración, el consejo, los accionistas y otros grupos de interés, y la estructura mediante la cual se fijan los objetivos, los medios para alcanzarlos y la forma de **vigilar** el desempeño.
- **Problema de agencia (Jensen-Meckling):** el conflicto de intereses entre el **principal** (accionistas) y el **agente** (administradores), que actúa por cuenta del primero pero puede perseguir su propio interés; genera **costos de agencia** (monitoreo, garantía, pérdida residual).
- **Deberes fiduciarios (doctrina anglosajona y LMV):** el **deber de diligencia/cuidado** (actuar informadamente, de buena fe y en el mejor interés de la sociedad) y el **deber de lealtad** (anteponer el interés social al propio: no usar información ni oportunidades de la sociedad, no competir, revelar y abstenerse en conflictos de interés).
- **Interés social (doctrina):** el "norte" de los administradores; tradicionalmente, el interés común de los **accionistas** (maximizar el valor de la sociedad); en la visión moderna (stakeholder/ESG), también el de los demás **grupos de interés** y la **sostenibilidad**.

Lectura del Consejo: todo el gobierno corporativo gira en torno a una idea: **quien administra dinero ajeno debe servir al interés de la sociedad, no al suyo**. De ahí derivan los dos deberes fiduciarios (diligencia y lealtad), los controles (consejo, comités, auditoría) y la protección de los que no controlan (minorías). Memoriza el binomio **diligencia (hacerlo bien) / lealtad (hacerlo honestamente, sin conflicto)**: es el corazón de la materia.

11. Definiciones legales (LGSM y LMV — verificar versión vigente)

- **Administración (LGSM, arts. 142 c y ss.):** la sociedad se administra por uno o varios mandatarios (administrador

único o **consejo de administración**); representan a la sociedad y ejecutan la voluntad social.

- **Responsabilidad de los administradores (LGSM, arts. 157-163 ☺)**: los administradores son **solidariamente responsables** frente a la sociedad por el cumplimiento de sus obligaciones; la **acción social de responsabilidad** puede ejercerla la sociedad (asamblea) o una **minoría del 25%** (art. 163 ☺).
- **Vigilancia (LGSM, arts. 164-171 ☺)**: el **comisario** fiscaliza la gestión.
- **Gobierno corporativo de la emisora (LMV, arts. 22 ☺ y ss.)**: para la S.A.B.:
- **Consejo de administración con consejeros independientes** (al menos el 25%).
- **Deberes de diligencia y lealtad** de consejeros y director general **codificados** (arts. 30-37 ☺), con la **regla de juicio de negocio** (no se les responsabiliza por decisiones de negocio tomadas informadamente y de buena fe, aunque resulten desfavorables).
- **Comités de auditoría y de prácticas societarias**, integrados por independientes.
- **Director general** con funciones y responsabilidad propias.
- Régimen de **operaciones con partes relacionadas** (revelación, aprobación reforzada).
- **S.A.P.I. (LMV)**: permite pactar gobierno corporativo a la medida (derechos de minoría reforzados, vetos, asientos en el consejo) — el vehículo del VC/PE (Libro 2 Nivel III).

12. Definición sencilla

El **gobierno corporativo** es "el sistema de **frenos y contrapesos** de una empresa": las reglas que deciden **quién manda** (la asamblea de dueños, el consejo, el director general), **cómo se vigila** a los que administran (comités, auditoría, consejeros **independientes**) y **qué deberes** tienen (hacerlo **bien** —diligencia— y **honestamente, sin conflictos** —lealtad—). Su objetivo es que quienes manejan el dinero de la empresa lo hagan **en interés de la empresa**, no en el suyo, y que los **accionistas**

pequeños (minorías) y los terceros estén protegidos. Una empresa con **buen gobierno** vale más, atrae inversión y resiste crisis; una con **mal gobierno** termina en fraudes, abusos o ruina.

13. Conceptos fundamentales

- **Separación de propiedad y control:** los accionistas (dueños) no administran; lo hacen el consejo y la dirección (origen del problema de agencia).
- **Problema de agencia y costos de agencia:** el conflicto principal-agente y el costo de controlarlo.
- **Órganos de gobierno:** **asamblea** (dueños; decide lo estructural), **consejo de administración** (estrategia y vigilancia de la gestión), **dirección general** (operación diaria), **comités** (auditoría, prácticas societarias, riesgos), **vigilancia** (comisario / auditoría).
- **Consejo de administración:** órgano colegiado de **estrategia y supervisión**; sus miembros (consejeros) tienen deberes fiduciarios.
- **Tipos de consejeros:** **ejecutivos/internos** (también dirigen), **patrimoniales** (representan a accionistas), e **independientes** (sin vínculos que comprometan su objetividad; protegen a las minorías y al interés social).
- **Consejero independiente:** clave del gobierno moderno; aporta **objetividad** y vigila a la administración y a los socios de control en beneficio de **todos** los accionistas.
- **Deber de diligencia (cuidado):** actuar **informadamente**, con la diligencia de un buen administrador; protegido por la **regla de juicio de negocio** (*business judgment rule*): no se responsabiliza por decisiones de negocio razonables, informadas y de buena fe, aunque salgan mal.
- **Deber de lealtad:** anteponer el **interés social** al propio: **no** aprovechar información u **oportunidades** de la sociedad, **no** competir, **revelar** los conflictos de interés y **abstenerse** de votar/decidir en ellos, y tratar las **operaciones con par-**

tes relacionadas a precio de mercado y con aprobación independiente.

- **Conflicto de interés:** cuando el interés personal del administrador choca con el de la sociedad; detonante del deber de lealtad.
- **Oportunidad societaria (*corporate opportunity*):** negocio que corresponde a la sociedad y que el administrador **no** puede tomar para sí.
- **Operaciones con partes relacionadas (OPR):** transacciones entre la sociedad y sus administradores, socios de control o sus parientes/empresas; zona de **máximo riesgo de abuso**; exigen **revelación, precio de mercado y aprobación** por independientes (comité de prácticas societarias en la S.A.B.).
- **Comité de auditoría:** vigila la información financiera, el control interno, el auditor externo y los riesgos (integrado por independientes).
- **Comité de prácticas societarias:** vigila las OPR, las compensaciones y los conflictos de interés.
- **Acción social de responsabilidad:** la vía para exigir a los administradores que **reparen** el daño causado a la sociedad por violar sus deberes (sociedad o minoría del 25%, LGSM art. 163 ☞).
- **Regla de juicio de negocio (*business judgment rule*):** protege a los administradores diligentes de ser segundo-advinados por los tribunales; presume que actuaron bien si decidieron informados, de buena fe y sin conflicto.
- **Protección de minorías:** derechos defensivos (Libro 2 Nivel III): convocar, designar consejero, información, impugnar, acción de responsabilidad; reforzados en la S.A.B. y la S.A.P.I.
- **Shareholder vs. stakeholder primacy:** ¿la empresa sirve solo a los accionistas (Friedman) o a todos los grupos de interés (ESG)?

- **ESG (Environmental, Social, Governance):** marco de sostenibilidad y responsabilidad que integra criterios ambientales, sociales y de gobierno (Nivel IV).
- **Compliance:** programas internos para asegurar el cumplimiento de la ley (anticorrupción, competencia, lavado, datos); conectado con la responsabilidad de la persona moral (Libro 5 Nivel I).

14. Desarrollo absoluto

Lo organizamos en: (A) la estructura de poder y los órganos; (B) el **consejo de administración** y sus consejeros; (C) los **deberes fiduciarios** (diligencia y lealtad) y la regla de juicio de negocio; (D) los **comités y el control**; (E) las **minorías** y las **operaciones con partes relacionadas**; (F) el debate **shareholder vs. stakeholder**, el ESG y el gobierno en M&A.

14.A · LA ESTRUCTURA DE PODER Y LOS ÓRGANOS

El gobierno corporativo organiza el poder en niveles, con **pesos y contrapesos**:

- **Asamblea de accionistas (los dueños):** decide lo **estructural** (estatutos, capital, fusión, nombramiento del consejo, dividendos). Es el órgano supremo, pero **no administra**.
- **Consejo de administración (la estrategia y la vigilancia):** fija la **estrategia**, **supervisa** a la dirección, aprueba las operaciones relevantes y vela por el interés social. Es el **núcleo** del gobierno corporativo.
- **Dirección general (la operación):** ejecuta la estrategia y dirige el día a día; rinde cuentas al consejo.
- **Comités (especialización):** auditoría, prácticas societarias, riesgos, etc.; preparan y vigilan para el consejo.
- **Vigilancia (comisario / auditoría externa):** fiscaliza la gestión y la información financiera.

La clave es la **separación de funciones**: la asamblea **nombra y controla** al consejo; el consejo **nombra, dirige y vigila** a la dirección; los comités y la auditoría **vigilan** a todos. Es la división de poderes (Libro 3, Nivel I) aplicada a la empresa.

14.B · EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y SUS CONSEJEROS

El **consejo** es el corazón del gobierno corporativo. Buen diseño:

- **Composición equilibrada:** consejeros **ejecutivos** (conocen la operación), **patrimoniales** (representan a accionistas) e **independientes** (objetividad; en la S.A.B., al menos el 25%).
- **El consejero independiente** es la pieza clave del gobierno moderno: sin vínculos que comprometan su juicio, vigila a la administración y a los socios de control **en beneficio de todos** los accionistas (especialmente las minorías).
- **Funcionamiento:** sesiones regulares, información suficiente y oportuna, actas, **comités** de apoyo; un buen consejo **de-libera** y **supervisa**, no solo ratifica.
- **Presidente del consejo vs. director general:** la tendencia (y mejor práctica) separa ambos roles (o nombra un consejero líder independiente) para evitar la concentración de poder.

14.C · LOS DEBERES FIDUCIARIOS: EL CORAZÓN DE LA RESPONSABILIDAD

Los administradores manejan **dinero ajeno**; por eso tienen **deberes fiduciarios** (LMV arts. 30-37 ⇄ para la S.A.B.; principios generales para toda sociedad):

1) Deber de diligencia (o de cuidado). Actuar **informadamente**, con la diligencia de un buen administrador, en el **mejor interés de la sociedad**: prepararse para las sesiones, exigir información, deliberar, vigilar. Su protección: la **regla de juicio de negocio** (*business judgment rule*): si el administrador decidió de manera **informada, de buena fe y sin conflicto de interés**, **no responde** por el resultado, aunque la decisión salga mal. (El derecho no castiga el riesgo empresarial razonable; castiga la **negligencia** y el **conflicto**.)

2) Deber de lealtad. Anteponer el **interés social** al propio. Implica:

- **No usar información** de la sociedad en beneficio propio (conexión con *insider trading*, Libro 5).

- **No tomar oportunidades societarias** (negocios que corresponden a la sociedad).
- **No competir** con la sociedad.
- **Revelar los conflictos de interés y abstenerse** de participar/votar en ellos.
- Tratar las **operaciones con partes relacionadas a precio de mercado**, con revelación y aprobación **independiente**.

Responsabilidad: la violación de estos deberes genera **responsabilidad** (deber de **reparar** el daño a la sociedad), exigible por la sociedad o por una **minoría del 25%** (acción social de responsabilidad, LGSM art. 163 ☞). En la S.A.B., el régimen es más detallado (LMV). El **deber de lealtad** es más estricto que el de diligencia: el conflicto de interés **no** está protegido por la regla de juicio de negocio.

Cómo razona un socio (asesor del consejo). *"Cuando asesoro a un consejo en una decisión importante —un M&A, una operación grande, una crisis—, mi trabajo es protegerlos cumpliendo el proceso: que estén informados (información completa, asesores, fairness opinion si hay venta), que actúen de buena fe y en el interés social, y que los conflictos se revelen y los conflictuados se abstengan. Si el proceso es impecable, la regla de juicio de negocio los protege aunque la decisión salga mal. El deber de diligencia se cumple con proceso; el de lealtad, con honestidad y transparencia. Mi peor pesadilla es un conflicto de interés no revelado: ahí no hay business judgment rule que valga."*

14.D · LOS COMITÉS Y EL CONTROL

El consejo no puede vigilarlo todo solo; se apoya en **comités** especializados (obligatorios en la S.A.B., recomendables en cualquier empresa seria):

- **Comité de auditoría** (independientes): vigila la **información financiera**, el **control interno**, la **gestión de riesgos** y al **auditor externo**. Es el guardián de la veracidad de las cuentas (lección de Enron).
- **Comité de prácticas societarias** (independientes): vigila las **operaciones con partes relacionadas**, las **compensaciones** de directivos y los **conflictos de interés**.

- **Auditoría externa e interna:** revisión independiente de las cuentas y de los controles.
- **Función de cumplimiento (*compliance*):** asegura el respeto a la ley (anticorrupción, competencia, lavado, datos) y previene la responsabilidad de la persona moral.

14.E · LAS MINORÍAS Y LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

El gobierno corporativo protege a quienes **no controlan** frente al abuso de la mayoría/control:

- **Derechos de minoría (Libro 2 Nivel III):** convocar asamblea, designar consejero, información, impugnar acuerdos, acción de responsabilidad; **reforzados** en la S.A.B. y pactables en la S.A.P.I.
- **Operaciones con partes relacionadas (OPR):** el mayor riesgo de **expropiación** de los minoritarios (que el socio de control "extraiga" valor vía operaciones a su favor). Control: **revelación, precio de mercado, aprobación** por consejeros/comité **independientes**, y abstención del conflictuado. La transparencia y la independencia son las defensas.
- **Túnel (*tunneling*):** el nombre que la doctrina da a la extracción indebida de valor por el socio de control (vía OPR abusivas, transferencias, etc.); el gobierno corporativo busca **cerrar el túnel**.

14.F · SHAREHOLDER VS. STAKEHOLDER, ESG Y EL GOBIERNO CORPORATIVO EN M&A

- **El gran debate (shareholder vs. stakeholder):** ¿debe el consejo maximizar el valor del **accionista** (Friedman, doctrina clásica de Delaware) o atender también a los **grupos de interés** —empleados, comunidad, ambiente— (stakeholder/ESG)? La tendencia moderna integra la **sostenibilidad** y el **largo plazo**, sin abandonar el deber hacia los accionistas (Nivel IV).
- **ESG:** los criterios ambientales, sociales y de gobierno se han vuelto exigencia de inversores, reguladores y sociedad; el consejo debe gestionarlos y, cada vez más, **revelarlos** (Nivel IV).

- **Gobierno corporativo en M&A (la conexión clave):** cuando se **vende** la empresa, el **consejo** tiene deberes fiduciarios **reforzados**:
- En una venta de control, debe **maximizar el valor para los accionistas** (estándar *Revlon* de Delaware: el consejo se vuelve "subastador"); proceso competitivo, *fairness opinion*.
- Ante una **OPA hostil**, puede defender a la empresa de ofertas inadecuadas (estándar *Unocal*: proporcionalidad de las defensas), pero **no** atrincherarse para conservar su puesto.
- Las **operaciones con partes relacionadas** y los conflictos (p. ej., un *management buyout*) exigen procesos especiales (comités independientes, *fairness opinions*) para resistir el escrutinio. (Los estándares de Delaware —*Revlon*, *Unocal*, business judgment rule— se profundizan en el **Nivel IV**.) *El gobierno corporativo es, por eso, el marco de deberes dentro del cual se hace todo M&A.*

15. Explicación intuitiva

Imagina la empresa como un **país**, y el gobierno corporativo como su **constitución y división de poderes** (Libro 3, Nivel I aplicado a la empresa):

- Los **accionistas** son el **pueblo** (los dueños del país); en la **asamblea** (las elecciones) eligen a sus representantes y deciden lo más importante.
- El **consejo de administración** es el **parlamento/gobierno**: fija el rumbo y **vigila** a quienes ejecutan.
- La **dirección general** es el **poder ejecutivo**: gobierna el día a día.
- Los **comités** y la **auditoría** son los **órganos de control** (como una contraloría): vigilan que nadie abuse.
- Los **consejeros independientes** son como **jueces imparciales**: no tienen interés propio en el juego, así que vigilan en beneficio de todos (sobre todo de los **minoritarios**, que son como las minorías políticas que hay que proteger del abuso de la mayoría).

¿Y los **deberes fiduciarios**? Son el **juramento del cargo**: quien administra debe hacerlo **bien** (diligencia: informarse, esforzarse) y **honestamente, sin corrupción** (lealtad: no robar, no usar el puesto para su provecho, no favorecer a sus amigos en contratos —partes relacionadas—). Y la **regla de juicio de negocio** es el reconocimiento de que **gobernar implica arriesgar**: si el administrador decidió bien informado y de buena fe, no se le castiga porque una apuesta razonable salga mal —solo se castiga la **negligencia** y la **deslealtad**—.

Cuando llega un momento crítico —**vender el país** (M&A), o defenderlo de una **invasión** (OPA hostil)—, los gobernantes tienen deberes **reforzados**: deben buscar el **mejor precio para el pueblo** (los accionistas), no su propio beneficio. Todo el gobierno corporativo es, en el fondo, **diseñar y hacer cumplir esa "constitución" de la empresa** para que el poder sirva a sus dueños y no se abuse de los débiles.

16. Ejemplos simples

1. **Regla de juicio de negocio.** Un consejo aprueba, bien informado y de buena fe, lanzar un producto que fracasa y causa pérdidas. ¿Responden los consejeros? **No**: la decisión fue **informada, de buena fe y sin conflicto** (regla de juicio de negocio); el derecho no castiga el riesgo empresarial razonable.
2. **Deber de lealtad (conflicto de interés).** Un consejero quiere que la empresa compre un inmueble **suyo**. Debe **revelar** el conflicto y **abstenerse** de votar; la operación pasa por consejeros **independientes** y a **precio de mercado**.
3. **Oportunidad societaria.** Un directivo se entera de un negocio que le interesaba a la empresa y lo toma **para sí**. Viola el deber de **lealtad** (se apropió de una **oportunidad societaria**).
4. **Consejero independiente.** Una S.A.B. integra a su consejo a independientes que vigilan las operaciones con partes relacionadas y protegen a los minoritarios.
5. **Acción de responsabilidad.** Unos administradores causan un daño a la sociedad por negligencia grave; una **minoría**

del 25% ejerce la **acción social de responsabilidad** para que **reparen**.

17. Ejemplos complejos

1. **Operación con parte relacionada y tunneling.** El socio de control hace que la empresa le compre insumos a **otra empresa suya**, a precios **inflados**, extrayendo valor en perjuicio de los minoritarios (*tunneling*). El comité de prácticas societarias y los independientes deben **bloquear** o ajustar la operación (precio de mercado, revelación, aprobación independiente). Si no lo hacen, hay responsabilidad y posible impugnación. Lección: las OPR son el principal canal de abuso; la independencia y la transparencia las controlan.
2. **Deberes del consejo en una venta (Revlon).** La empresa recibe ofertas de compra. El consejo debe **maximizar el valor para los accionistas** (no elegir al postor que le conserva el puesto a los directivos): proceso competitivo, *fairness opinion*, deliberación informada. Si el consejo favorece a un postor por interés propio, viola sus deberes. Lección: en una venta de control, el consejo se vuelve "subastador" en interés de los accionistas (Nivel IV).
3. **OPA hostil y defensas (Unocal).** Un postor lanza una OPA hostil. El consejo de la *target* cree que el precio es **inadecuado** y adopta defensas. Son válidas si son **proporcionales** a la amenaza y buscan proteger a los accionistas —**no** atrincherar a los directivos—. Lección: el consejo puede defender, pero dentro de sus deberes fiduciarios (Nivel IV).
4. **Empresa familiar sin gobierno.** Una empresa familiar exitosa no tiene consejo profesional ni reglas; al morir el fundador, los herederos entran en conflicto y la empresa se paraliza y pierde valor. Lección: profesionalizar el gobierno (consejo con independientes, protocolo familiar, sucesión) es supervivencia.

18. Casos reales (jurisprudencia, regulación y operaciones estilizadas)

- **Berle & Means / teoría de la agencia:** el marco conceptual que fundó la disciplina (separación propiedad-control).

- **Enron / WorldCom (2001-2002) → Sarbanes-Oxley:** el fraude contable que detonó la reforma global del gobierno corporativo (independencia de auditores, comités de auditoría, certificación de estados financieros, responsabilidad de directivos).
- **Jurisprudencia de Delaware (Revlon, Unocal, business judgment rule):** los estándares de los deberes fiduciarios y de las defensas anti-OPA; **derecho vivo del M&A** (se profundizan en Nivel IV).
- **México (LMV 2005):** codificación del gobierno corporativo de las emisoras (independientes, comités, deberes); sanciones de la CNBV por operaciones con partes relacionadas y conflictos.

Nota de método (Manifiesto XI.5): verificar la vigencia y los datos de los casos/normas; se exponen por su valor formativo y de criterio.

19. Casos empresariales

- **Profesionalización de la empresa familiar:** montar un **consejo** con consejeros independientes, comités, un **protocolo familiar** (reglas de la familia sobre la empresa) y un plan de **sucesión**; eleva el valor y la supervivencia.
- **Gestión de conflictos de interés:** políticas internas de conflictos, comité que aprueba las OPR, registro de partes relacionadas.
- **Compliance corporativo:** programa de cumplimiento (anti-corrupción, competencia, lavado, datos) que protege a la empresa y a los administradores (responsabilidad de la persona moral, Libro 5 Nivel I).

20. Casos corporativos (en transacciones)

- **Deberes del consejo en un M&A:** asesorar al consejo para que el proceso de venta cumpla sus deberes (información, *fairness opinion*, maximizar valor, manejar conflictos como un *management buyout*).
- **Derechos de gobierno del inversionista (VC/PE):** estructurar los asientos en el consejo, los **votos** sobre *reserved ma-*

tters, los derechos de información y los comités, vía estatutos (S.A.P.I.) y convenio entre accionistas (Libro 2 Nivel III).

- **Comité especial (*special committee*):** en operaciones con conflicto (compra por el socio de control, MBO), se forma un comité de **independientes** que negocia y aprueba, para "limpiar" el conflicto y resistir el escrutinio.
- **Due diligence de gobierno corporativo:** revisar la integración y funcionamiento del consejo, los comités, las OPR, los conflictos y los antecedentes de responsabilidad de administradores.

21. Casos internacionales

- **Delaware (el referente):** la Court of Chancery y su jurisprudencia (Revlon, Unocal, Caremark —deber de supervisión—, business judgment rule) definen los deberes fiduciarios y las defensas; estudio obligado del Nivel IV.
- **Sarbanes-Oxley (EE. UU., 2002) y Dodd-Frank (2010):** estándares de gobierno, auditoría y responsabilidad para emisoras.
- **Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE/G20:** el estándar internacional (derechos de accionistas, trato equitativo, papel del consejo, transparencia, stakeholders).
- **Códigos nacionales (UK Corporate Governance Code, etc.):** modelo "*comply or explain*" (cumplir o explicar por qué no): autorregulación con disciplina de mercado.
- **ESG y *stewardship*:** los grandes inversores institucionales globales (fondos de pensiones, gestoras) ejercen presión por buen gobierno y sostenibilidad (códigos de *stewardship*).

22. Derecho comparado

SISTEMA	RASGOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO
México	LGSM (sociedades en general) + LMV (S.A.B.: independientes $\geq 25\%$, comités de auditoría y prácticas societarias, deberes de diligencia y lealtad codificados, business judgment rule); Código de Principios de Gobierno Corporativo (CCE).
España	Ley de Sociedades de Capital + Código de Buen Gobierno (CNMV); deberes de diligencia y lealtad detallados; " <i>comply or explain</i> ".
Estados Unidos	<i>Corporate law</i> estatal + Sarbanes-Oxley/Dodd-Frank; deberes fiduciarios desarrollados por la jurisprudencia; SEC para emisoras.
Delaware	El referente mundial: business judgment rule, deberes de cuidado y lealtad , <i>Caremark</i> (supervisión), Revlon (venta de control) y Unocal (defensas anti-OPA); Court of Chancery.
Unión Europea	Directivas (derechos de accionistas, <i>say on pay</i> , informe de sostenibilidad —CSRD—); modelos de consejo monista (un solo consejo) y dualista (consejo de dirección + de vigilancia, Alemania).
UNI-DROIT/OCDE	Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE/G20: el estándar internacional (derechos y trato equitativo de accionistas, papel del consejo, transparencia, stakeholders, sostenibilidad).
UNCITRAL	Trabajos sobre gobierno de empresas (incl. MSME).
Common Law	Deberes fiduciarios de origen jurisprudencial (<i>duty of care</i> , <i>duty of loyalty</i> , <i>good faith</i>); fuerte litigio (class actions, <i>derivative suits</i>).
Civil Law	Deberes codificados; consejo monista o dualista; convergencia hacia los estándares OCDE y la independencia.

Convergencia clave: todos los sistemas reconocen los **deberes fiduciarios** (cuidado/diligencia y lealtad), la **independencia** en el consejo, los **comités** (auditoría) y la **protección de minorías**. **Delaware** es el laboratorio mundial de los estándares (Revlon, Unocal, business judgment rule), que el abogado de M&A debe dominar (Nivel IV). La diferencia estructural relevante es el modelo de consejo **monista** (México, EE. UU., España) vs. **dualista** (Alemania).

EL ERROR DE TRASPLANTE MÁS IMPORTANTE DE ESTA MATERIA

Aquí está, en nuestra opinión, la idea más valiosa de todo el libro, y conviene decirla sin rodeos porque casi nadie la formula así.

El gobierno corporativo que se enseña en el mundo fue diseñado para resolver un problema que México casi no tiene.

El modelo anglosajón —consejeros independientes, comités, *say-on-pay*, revelación— nació para la corporación de **capital disperso** que describieron Berle y Means: miles de accionistas pequeños y unos administradores que controlan sin arriesgar. El conflicto que resuelve es **accionistas frente a administradores**.

En México, como en la mayor parte de América Latina, Asia y Europa continental, la estructura típica es otra: **capital concentrado**. Hay un accionista o una familia de control que **sí** vigila a los administradores —no necesita mecanismos para hacerlo, tiene el mando—. El conflicto real, entonces, no es accionistas contra administradores: es **accionista de control frente a accionistas minoritarios**.

Y de ahí la consecuencia práctica, que es la razón de ser de este apartado: trasplantar el aparato del capital disperso a una empresa de capital concentrado **resuelve el conflicto equivocado**. Un consejero "independiente" designado por el propio controlador no protege a la minoría del controlador: es independiente del *management* —que ya obedece al controlador— y no de quien manda.

Los mecanismos que de verdad importan en este entorno son otros, y son los que debes negociar: **derechos de veto** sobre decisiones estructurales, **derecho a información**, **asiento en el consejo**, supervisión de **operaciones con partes relacionadas**, **voto acumulativo** y —sobre todo— **mecanismos de salida con fórmula de valuación** (ver el Libro 4 del Nivel IV).

Esta lectura tiene respaldo académico serio y vale conocerlo: el programa de investigación de **La Porta, López-de-Silanes, Shleifer y Vishny** (*Law and Finance*, 1998) documentó que la **protección jurídica de la minoría** correlaciona con la

profundidad de los mercados de capital y con la dispersión de la propiedad. Y **Mark Roe** (*Political Determinants of Corporate Governance*) añadió la explicación política: las estructuras de propiedad no son solo producto del derecho, sino de decisiones políticas históricas sobre el papel del trabajo y del capital —lo que explica la **cogestión** alemana (*Mitbestimmung*) mejor que cualquier análisis puramente jurídico—.

Y el instrumento comparado que más útil resulta: el llamado *marco MFW*, derivado de *Kahn v. M&F Worldwide* (Del. 2014). Su aportación es un **camino seguro** para las operaciones con el accionista de control: si la operación se condiciona desde el inicio a la aprobación de un **comité independiente con poder real de negociar y de decir no**, y además al **voto favorable de la mayoría de la minoría**, la operación se juzga con la deferencia del juicio de negocios en lugar de con el escrutinio más severo. Es decir: **el derecho premia el procedimiento que protege a la minoría**.

México no tiene ese marco. Pero su lógica es importable a un acuerdo de accionistas o a la estructura de aprobación de una operación con partes relacionadas — y hacerlo es una de las aportaciones más sofisticadas que un abogado corporativo mexicano puede ofrecer a un cliente minoritario o a un consejo que quiere blindar una decisión.

Y de aquí se sigue la crítica que cierra el apartado: el riesgo del *box-ticking*. Si el aparato importado resuelve el conflicto equivocado, cumplirlo formalmente produce **independencia de casilla**: consejeros que satisfacen el requisito legal y son designados por el propio controlador; comités que sesionan y no deciden, códigos que se adhieren y no se aplican. La forma se cumple y la función no. El tratamiento completo de esta crítica —con Bebchuk y Fried sobre remuneración, y la prueba de "cuándo fue la última vez que este consejo dijo no"— está en el Libro 8 del Nivel IV.

23. Derecho mexicano

- **LGSM (sociedades en general):** administración (142 y ss.), responsabilidad de administradores (157-163), acción social

de responsabilidad (163, minoría del 25%), vigilancia (164-171).

- **LMV (emisoras / S.A.B.):** consejo y **consejeros independientes** ($\geq 25\%$); **comités de auditoría y de prácticas societarias; deberes de diligencia y lealtad** codificados (arts. 30-37 $\curvearrowright$) con **business judgment rule**; régimen de **operaciones con partes relacionadas**; **S.A.P.I.** (gobierno pactable).
- **Código de Principios de Gobierno Corporativo (CCE):** mejores prácticas (recomendatorias) que difunden estándares (consejo, comités, transparencia).
- **Normas sectoriales:** bancos y entidades financieras con gobierno **reforzado** (CNBV); pronto, estándares de **sostenibilidad/ESG** (disclosure).
- **Responsabilidad penal de la persona moral (Libro 5 Nivel I):** fundamento de los **programas de compliance**.

24. Jurisprudencia relevante

Verificar vigencia antes de citar. - **Responsabilidad de administradores (LGSM):** alcance del deber y de la acción social de responsabilidad.

- **Deberes de diligencia y lealtad (LMV):** interpretación de su contenido y de la **business judgment rule**.
- **Operaciones con partes relacionadas:** estándares de revelación, precio de mercado y aprobación independiente.
- **Protección de minorías:** efectividad de sus derechos (convocar, designar, impugnar).
- **(Comparado) Delaware:** Revlon, Unocal, Caremark, Smith v. Van Gorkom (deber de informarse) — referencia obligada en M&A (Nivel IV).

25. Criterios de la Suprema Corte / reguladores

- **Protección de minorías y derecho de información:** la SCJN ha reforzado el acceso a la información y el control de los acuerdos sociales.

- **Responsabilidad de administradores y deberes fiduciarios:** desarrollo del deber de diligencia y lealtad (robusto en emisoras).
- **Operaciones con partes relacionadas:** sanciones de la CNBV y criterios sobre conflictos de interés.
- **Levantamiento del velo (Libro 5 Nivel I):** desestimación de la personalidad en fraude/abuso, con cautela.

26. Doctrina nacional

- **Doctrina sobre la LMV de 2005** (gobierno corporativo de la S.A.B., deberes fiduciarios): clave por su actualidad.
- **Código de Principios de Gobierno Corporativo (CCE) y literatura de mejores prácticas.**
- **Doctrina de empresa familiar** (protocolo familiar, consejo, sucesión): muy relevante en México.
- **Mantilla Molina / Barrera Graf:** marco societario base (órganos, responsabilidad).

27. Doctrina internacional

- **Berle & Means, *The Modern Corporation and Private Property*:** la obra fundacional.
- **Jensen & Meckling, "Theory of the Firm"** (teoría de la agencia).
- **Reinier Kraakman et al., *The Anatomy of Corporate Law*:** análisis funcional y comparado del gobierno corporativo (lectura **imprescindible**).
- **Stephen Bainbridge / Lucian Bebchuk:** debates sobre el poder del consejo vs. accionistas, y sobre la compensación.
- **Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE/G20.**

28. Opiniones críticas (postura del Consejo)

1. **El consejero independiente es el alma del buen gobierno —si es de verdad independiente.** El Consejo advierte contra los independientes "de membrete" (designados por el control, sin verdadera autonomía); la independencia **real** (no formal) es lo que protege a los minoritarios.

2. **Las operaciones con partes relacionadas son el principal canal de abuso (*tunneling*).** El Consejo subraya que su control —revelación, precio de mercado, aprobación independiente— es la prueba más exigente del gobierno corporativo, especialmente en empresas con un socio de control dominante (frecuentes en México).
3. **El gobierno corporativo crea valor; no es "burocracia".** El Consejo insiste en que las empresas privadas y familiares que adoptan buen gobierno **anticipadamente** (consejo con independientes, comités, deberes claros) **valen más**, atraen mejor inversión y se preparan para una IPO o un M&A.

29. Debate doctrinal

- **Shareholder vs. stakeholder primacy:** ¿el consejo debe maximizar el valor del **accionista** (Friedman, Delaware clásico) o atender a todos los **grupos de interés** (stakeholder/ESG)? El gran debate actual del gobierno corporativo.
- **Poder del consejo vs. de los accionistas:** ¿debe el consejo tener amplia autonomía (Bainbridge, *director primacy*) o deben los accionistas tener más voz (Bebchuk, *shareholder empowerment: say on pay*, nominación de consejeros)?
- **Compensación de directivos:** ¿alinea incentivos (acciones, opciones) o fomenta el cortoplacismo y la extracción de valor? Debate sobre el *say on pay* y los límites a la compensación.
- **Defensas anti-OPA:** ¿protegen a los accionistas de ofertas inadecuadas o atrincheran a los directivos? (Unocal, poison pills — Nivel IV).
- **Independencia real vs. formal:** ¿los criterios legales de "independencia" garantizan verdadera autonomía, o son sorteables por el socio de control?
- **ESG: ¿obligación fiduciaria o distracción?** ¿Integrar criterios ambientales y sociales es parte del deber del consejo (largo plazo, riesgo) o una desviación del interés de los accionistas?

30. Errores comunes

- **Confundir el deber de diligencia con el de lealtad.** La **diligencia** (hacerlo bien, informado) está protegida por la **business judgment rule**; la **lealtad** (sin conflicto) **no**: un conflicto no revelado no se salva con "fue una decisión de negocio".
- **Independientes "de membrete".** Nombrar como "independientes" a personas vinculadas al control: destruye el propósito y expone a la empresa.
- **Operaciones con partes relacionadas sin proceso.** Aprobarlas sin revelación, sin precio de mercado y sin independientes: principal canal de abuso (*tunneling*).
- **Consejo que solo ratifica.** Un consejo que no delibera ni se informa incumple el deber de diligencia (lección de *Smith v. Van Gorkom*).
- **No documentar el proceso de decisión.** En un M&A o decisión relevante, la falta de actas, información y *fairness opinion* debilita la protección del consejo.
- **Empresa familiar sin gobierno ni sucesión.** Receta para el conflicto y la destrucción de valor.
- **Ignorar los deberes reforzados del consejo en una venta** (Revlon) o ante una OPA (Unocal).

31. Mitos frecuentes

- *"Si la empresa va bien, el gobierno corporativo no importa."* **Falso:** el buen gobierno **previene** la crisis y **crea valor**; cuando la crisis llega, ya es tarde para instalarlo.
- *"Los consejeros responden por cualquier mala decisión."* **Falso:** la **business judgment rule** los protege si decidieron informados, de buena fe y sin conflicto.
- *"El gobierno corporativo es solo para empresas que cotizan."* **Falso:** crea valor en cualquier empresa (privada, familiar) y la prepara para crecer/vender.
- *"El consejero independiente es un adorno."* **Falso:** es la principal defensa de los minoritarios y del interés social.

- "Maximizar el valor del accionista significa ignorar todo lo demás." **Matiz:** la visión moderna (ESG, largo plazo) integra a los stakeholders sin abandonar el deber fiduciario.

32. Preguntas difíciles

1. ¿Debe el consejo maximizar el valor del **accionista** o atender a los **stakeholders** (ESG)? ¿Cambia eso sus deberes fiduciarios?
2. ¿Cómo lograr **independencia real** (no formal) de los consejeros cuando hay un socio de control dominante (caso típico mexicano)?
3. ¿Las **defensas anti-OPA** protegen a los accionistas o atrincheran a los directivos? ¿Deberían permitirse en México (Unocal)?
4. ¿La **compensación** ligada a acciones alinea incentivos o fomenta el cortoplacismo y la extracción de valor?
5. ¿Hasta dónde llega el deber de **supervisión** (*Caremark*) del consejo sobre el cumplimiento (compliance) y los riesgos?

33. Casos de examen (con respuesta modelo)

P1. *¿Qué problema resuelve el gobierno corporativo?* **R.** El **problema de agencia:** el conflicto entre el principal (accionistas) y el agente (administradores), alineando incentivos y controlando para que el poder se ejerza en **interés de la sociedad** y no del administrador.

P2. *Distinga el deber de diligencia y el de lealtad.* **R.** **Diligencia/cuidado:** actuar informadamente, de buena fe, como un buen administrador (protegido por la **business judgment rule**). **Lealtad:** anteponer el interés social al propio (no conflictos, no oportunidades societarias, no uso de información; OPR a precio de mercado). El conflicto de interés **no** está protegido por la business judgment rule.

P3. *¿Qué es la regla de juicio de negocio?* **R.** La presunción de que los administradores actuaron correctamente si decidieron **informados, de buena fe y sin conflicto**; los protege de ser responsabilizados por el **resultado** de decisiones de negocio razonables que salgan mal.

P4. *¿Por qué son importantes los consejeros independientes?*

R. Aportan **objetividad**; vigilan a la administración y al socio de control en beneficio de **todos** los accionistas (especialmente las minorías) y aprueban las operaciones con partes relacionadas.

P5. *¿Qué deberes tiene el consejo cuando se vende la empresa (control)?* **R.** Deberes **reforzados**: **maximizar el valor para los accionistas** (estándar Revlon), con proceso competitivo, información y *fairness opinion*, manejando los conflictos (no favorecer al postor que conserva el puesto a los directivos).

34. Simulador (ejercicio tipo despacho)

Rol: asesor del consejo de administración. **Cliente:** el consejo de "Grupo Industrial del Norte, S.A.B.", una emisora con un **socio de control** (familia, 55%) y minoritarios (incluidas Afores). Se presentan **dos asuntos** en la misma sesión: (1) el socio de control propone que la empresa **compre** una planta **propiedad de otra empresa de la familia** (operación con parte relacionada); (2) un fondo extranjero lanza una **oferta de compra (OPA)** por el control.

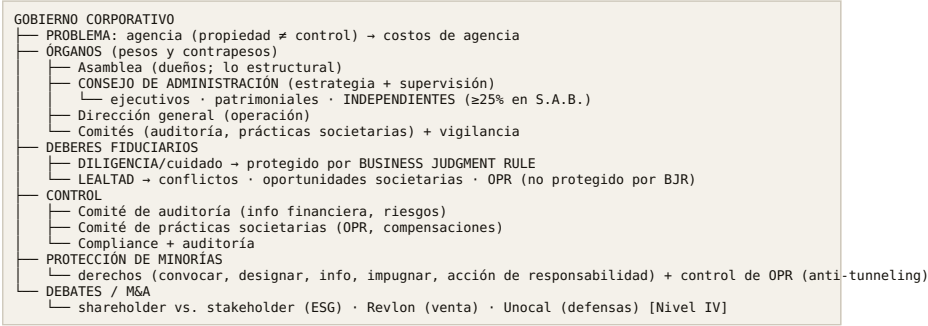
Tarea: asesora al consejo para que cumpla sus **deberes fiduciarios**: (1) para la **OPR**: ¿quién debe aprobarla (comité de **prácticas societarias**, independientes), con qué requisitos (**revelación, precio de mercado/avalúo, abstención** del conflictuado)? ¿Riesgo de *tunneling* y de daño a minoritarios?; (2) para la **OPA**: ¿qué deberes tiene el consejo (maximizar valor para los accionistas, **fairness opinion**, proceso, no atrincherarse)? ¿Puede defenderse si el precio es inadecuado (proporcionalidad — Unocal)?; (3) ¿cómo se protege a los **minoritarios** (incluida la OPA obligatoria por trato igualitario —LMV, Libro 5)?; (4) ¿cómo documentar el proceso para que la **business judgment rule** proteja al consejo? Concluye con las recomendaciones y los **3 riesgos** principales.

(Pista de evaluación: la mejor respuesta separa los dos asuntos; en la OPR, exige comité de independientes, precio de mercado y abstención del control; en la OPA, recuerda los deberes reforzados del consejo —maximizar valor, fairness opinion, no atrincherarse— y la protección de minoritarios; y subraya la documentación del proceso para activar la business judgment rule.)

35. Flashcards

- **¿Problema que resuelve el gobierno corporativo?** → El problema de agencia (principal vs. agente).
- **¿Dos deberes fiduciarios?** → Diligencia/cuidado y lealtad.
- **¿Business judgment rule?** → Protege decisiones informadas, de buena fe y sin conflicto.
- **¿El conflicto de interés está protegido por la BJR?** → No (es deber de lealtad).
- **¿Consejero independiente?** → Sin vínculos que comprometan su juicio; protege a minorías e interés social (S.A.B.: $\geq 25\%$).
- **¿Comité de auditoría?** → Vigila información financiera, control interno, auditor, riesgos.
- **¿Comité de prácticas societarias?** → Vigila OPR, compensaciones, conflictos.
- **¿Operación con parte relacionada (control)?** → Revelación + precio de mercado + aprobación independiente + abstención.
- **¿Tunneling?** → Extracción indebida de valor por el socio de control.
- **¿Acción social de responsabilidad?** → Exigir a administradores reparar el daño (sociedad o minoría 25%).
- **¿Revlon / Unocal?** → Deberes del consejo en venta de control / defensas anti-OPA (Nivel IV).
- **¿Shareholder vs. stakeholder?** → Maximizar valor del accionista vs. atender a todos los grupos (ESG).

36. Mapas mentales



37. Cuadros comparativos

Deber de diligencia vs. deber de lealtad

	DILIGENCIA/CUIDADO	LEALTAD
Qué exige	Decidir informado, con esfuerzo	Anteponer el interés social (sin conflicto)
Protección	Business judgment rule	No protegido por BJR
Violación típica	Negligencia, no informarse	Conflicto de interés, OPR abusiva, tunneling

Tipos de consejeros

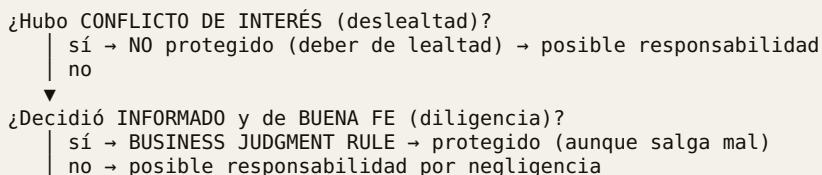
TIPO	QUIÉN	FUNCIÓN
Ejecutivo/interno	Dirige la empresa	Conocimiento operativo
Patrimonial	Representa accionistas	Voz de los dueños
Independiente	Sin vínculos	Objetividad; protege minorías/interés social

Shareholder vs. stakeholder

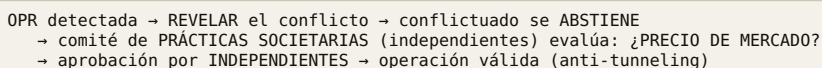
	SHAREHOLDER PRIMACY	STAKEHOLDER / ESG
Objetivo	Valor del accionista	Todos los grupos de interés + sostenibilidad
Representante	Friedman / Delaware clásico	Visión moderna / ESG
Horizonte	Puede ser cortoplacista	Largo plazo

38. Diagramas

¿Está protegido el administrador? (deberes y BJR):



Aprobación de una operación con parte relacionada (OPR):



39. Mnemotecnias

- **Problema central:** *"propiedad sin control = el agente puede traicionar al principal".*
- **Deberes:** *"Diligencia = hazlo BIEN; Lealtad = hazlo HONESTO (sin conflicto)".*
- **BJR:** *"informado + buena fe + sin conflicto = no respondes por el resultado".*
- **Independiente:** *"el que no tiene perro en la pelea vigila por todos".*
- **OPR:** *"revela, abstente, precio de mercado, aprueban los independientes".*
- **M&A:** *"al vender, el consejo subasta para los accionistas (Revlon); al defender, proporcional (Unocal)".*
- **Valor:** *"buen gobierno = más valor, menos costo de capital".*

40. Resumen ejecutivo

El **gobierno corporativo** es el sistema de **poder, control y responsabilidad** dentro de la empresa. Nació para resolver el **problema de agencia** (Berle-Means, Jensen-Meckling): que los administradores —que manejan **dinero ajeno**— sirvan al **interés de la sociedad** y de los accionistas, no al suyo. Su arquitectura: una **estructura de poder** con pesos y contrapesos (asamblea → consejo → dirección, vigilados por comités y auditoría), un **consejo de administración** con **consejeros in-**

dependientes, y dos **deberes fiduciarios** —el de **diligencia/cuidado** (decidir informado y de buena fe, protegido por la **regla de juicio de negocio**) y el de **lealtad** (sin conflictos, sin tomar oportunidades societarias, con las operaciones con partes relacionadas a precio de mercado y aprobadas por independientes)—. Protege a las **minorías** del abuso del control (*tunneling*) y se controla con **comités** (auditoría, prácticas societarias) y **compliance**.

Para el abogado corporativo, esta materia es transversal y de élite: define **quién decide y quién responde** en cada operación. Es central en **M&A** (los deberes reforzados del consejo al vender —Revlon— o al defenderse de una OPA —Unocal—), en **VC/PE** (los derechos de gobierno del inversionista, vía S.A.P.I.), en las **emisoras** (LMV) y en el **compliance**. El gobierno corporativo **crea valor**: las empresas bien gobernadas valen más, atraen mejor inversión y resisten crisis. Con este libro **cierra el Nivel III (Derecho Mercantil)**: el lector ya domina la empresa (sociedades), su financiamiento (títulos, crédito, valores), su crisis (concurso) y su poder (gobierno corporativo). Está listo para el **Nivel IV: Corporate Law y M&A**, el corazón del objetivo.

41. Checklist

Diseño del gobierno corporativo:

- [] ¿Consejo equilibrado con **independientes** (reales, no de membrete)?
- [] ¿**Comités** (auditoría, prácticas societarias, riesgos) y función de **compliance**?
- [] ¿Reglas claras (estatutos, reglamento del consejo) y separación de roles (presidente/director general)?
- [] ¿Derechos del inversionista/minoría (asientos, vetos, información) bien estructurados?

Cumplimiento de deberes fiduciarios (asesorar al consejo):

- [] **Diligencia**: ¿el consejo está **informado** (información, asesores, *fairness opinion*)?

- [] **Lealtad:** ¿se **revelaron** los conflictos y se **abstuvieron** los conflictuados?
- [] ¿Las **OPR** se aprueban con revelación, precio de mercado e independientes?
- [] ¿Se **documenta** el proceso (actas, información) para activar la business judgment rule?

En M&A / momentos críticos:

- [] ¿Deberes reforzados del consejo (maximizar valor — Revlon—; defensas proporcionales —Unocal—)?
- [] ¿Comité especial de independientes si hay conflicto (MBO, compra por el control)?
- [] ¿Protección de minoritarios (OPA obligatoria, trato igualitario —LMV)?

42. Bibliografía comentada

- **Kraakman, Hansmann et al., *The Anatomy of Corporate Law*. Lectura imprescindible:** análisis funcional y comparado del gobierno corporativo (agencia, protección de inversores, control).
- **Berle & Means, *The Modern Corporation and Private Property*; Jensen & Meckling, "Theory of the Firm".** Las fuentes del problema de agencia.
- **LMV (gobierno de la S.A.B.) y Código de Principios de Gobierno Corporativo (CCE).** El derecho positivo y las mejores prácticas mexicanas.
- **Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE/G20.** El estándar internacional.
- **Jurisprudencia de Delaware (Revlon, Unocal, Caremark, Smith v. Van Gorkom).** Los deberes fiduciarios y las defensas anti-OPA; estudio obligado para M&A (Nivel IV).
- **Bainbridge / Bebchuk.** Para los debates (poder del consejo vs. accionistas, compensación). De Bebchuk y Fried, *Pay Without Performance*: la tesis de que la remuneración no alinea incentivos sino que es **síntoma** del poder gerencial.
- **La Porta, López-de-Silanes, Shleifer & Vishny, *Law and Finance (Journal of Political Economy, 1998)*.** El estudio

que vinculó protección jurídica de la minoría con profundidad de los mercados. Es el sustento empírico del §22 y una de las investigaciones jurídico-económicas más citadas de la historia.

- **Mark Roe, *Political Determinants of Corporate Governance* (2003).** Por qué las estructuras de propiedad son también producto de la política y no solo del derecho. Explica la gestión alemana y, por contraste, la nuestra.
- ***Kahn v. M&F Worldwide* (Del. 2014),** para el marco de operaciones con accionista de control (comité independiente + voto de la mayoría de la minoría); y ***In re Caremark* (Del. Ch. 1996)** para el deber de vigilancia, que se desarrolla en el Libro 8 del Nivel IV.
- **Cadbury Report (1992) y Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE,** de donde proviene el estándar que adoptó el Código de Principios y Mejores Prácticas mexicano ☞.

43. Ruta hacia el siguiente libro / nivel

Lo que acabas de aprender —el poder, los deberes y el control dentro de la empresa— será **indispensable para comprender el Nivel IV: Corporate Law**, donde el gobierno corporativo se pone a prueba en las operaciones más complejas: las **Fusiones y Adquisiciones**.

- **Siguiente nivel: Nivel IV · Corporate Law — Fundamentos de M&A,** Due Diligence, estructuras (fusiones, escisiones, adquisiciones), documentación (Term Sheet, SPA, APA, SHA), **Private Equity y Venture Capital**, y gobierno corporativo avanzado, Compliance y ESG. **Es el corazón del objetivo.**
- **Conexión inmediata:** los **deberes fiduciarios del consejo** (Revlon, Unocal) y la protección de minorías se vuelven el marco de toda operación de M&A; los derechos de gobierno del inversionista son el lenguaje del VC/PE.

◆ ¿Por qué esto importa para un abogado corporativo?

Porque el gobierno corporativo define **quién decide y quién responde** en la empresa, y eso está en el centro de cada operación. En un **M&A**, el abogado asesora al **consejo** para que cumpla sus deberes fiduciarios reforzados (maximizar valor, fairness opinion, manejar conflictos como un MBO); en una inversión de **VC/PE**, **diseña** los derechos de gobierno del inversionista (asientos, vetos, información); en una **emisora**, opera el régimen de la LMV (independientes, comités, OPR); y en **compliance**, instala los controles que protegen a la empresa y a sus directivos. Además, el buen gobierno **crea valor**: una empresa bien gobernada vale más y se vende mejor. El abogado que domina el gobierno corporativo se convierte en **asesor del consejo** —el rol de mayor responsabilidad y prestigio del derecho de los negocios—.

◆ Cómo piensa un socio de un despacho internacional

"Cuando asesoro a un consejo en una decisión crítica —vender la empresa, una operación con el socio de control, una OPA—, mi obsesión es el proceso y los deberes fiduciarios. Para el deber de diligencia, me aseguro de que el consejo esté informado: información completa, asesores, fairness opinion; así la business judgment rule los protege aunque la decisión salga mal. Para el deber de lealtad, caza de conflictos: que se revelen y que los conflictuados se abstengan; en operaciones con el control (un MBO, una compra a una empresa de la familia), formo un comité especial de independientes que negocie de verdad. Y documento todo —actas, información, opiniones— porque, si algún día hay litigio, el proceso impecable es la mejor defensa. El gobierno corporativo es el marco de deberes dentro del cual se hace todo M&A: dominarlo es la diferencia entre un consejo protegido y uno demandado."

◆ Errores que cuestan millones

1. **Conflicto de interés no revelado.** La deslealtad **no** está protegida por la business judgment rule: una OPR abusiva o una oportunidad societaria tomada para sí generan responsabilidad y nulidad, y destruyen valor para los minoritarios

- (*tunneling*). *Prevención*: revelar, abstenerse, comité de independientes, precio de mercado.
2. **Consejo que decide sin informarse (Van Gorkom)**. Aprobar una venta o una operación relevante sin información ni asesores viola el deber de diligencia y pierde la protección de la business judgment rule. *Prevención*: información completa, *fairness opinion*, deliberación documentada.
 3. **Independientes "de membrete"**. Una independencia solo formal no protege a los minoritarios y expone a la empresa a impugnaciones y a la pérdida de confianza (y de valor). *Prevención*: independencia **real**.
 4. **Atrincherarse ante una OPA**. Usar defensas para conservar el puesto (no para proteger a los accionistas) viola los deberes fiduciarios (Unocal). *Prevención*: defensas **proporcionales** y en interés de los accionistas.
 5. **Empresa familiar sin gobierno ni sucesión**. La falta de consejo profesional, reglas y plan de sucesión lleva al conflicto y a la destrucción de valor al cambiar de generación. *Prevención*: profesionalizar el gobierno **antes** de la crisis.

Cierre del Libro y del Nivel III. Has completado el **Derecho Mercantil**: la teoría general y el comerciante, las **sociedades** (LGSM), los **títulos y operaciones de crédito** (LGTOC), los **contratos mercantiles**, el **mercado de valores** (LMV), el **concurso mercantil** y el **gobierno corporativo**. Dominas ya la empresa en su plenitud: cómo se organiza, financia, contrata, gobierna y —si falla— se reestructura o liquida. Eres, en formación, un **especialista en derecho mercantil**. Ahora cruzamos el umbral del verdadero objetivo: el **Nivel IV · Corporate Law**, donde todo lo aprendido converge en las **Fusiones y Adquisiciones**. El abogado corporativo de élite está cada vez más a tu alcance.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.



PARTE IV

Derecho Corporativo (Corporate Law)

PARTE IV

[Nivel IV · Libro 1] Fundamentos de Fusiones y Adquisiciones (M&A)

☞ **Apóstrofe de vigencia** — **léela cada vez**. El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: «*¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente*» (textos oficiales en *.../fuentes-legales/*). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como «**Derogado**». Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

Aquí empieza el **verdadero objetivo** de toda la biblioteca. Todo lo aprendido —Roma, obligaciones, contratos, sociedades, títulos, garantías, valores, gobierno corporativo— **converge** en una sola disciplina: comprar y vender empresas. Una operación de M&A es la **catedral** del derecho corporativo: en ella se ensambla cada institución que estudiaste. Este libro es el **plano maestro**: qué es una operación de M&A, por qué se hacen, cómo se estructuran, quiénes participan y cuáles son sus fases, de la idea al *closing* y más allá.

Etiquetas: corporate law · M&A · fusiones · adquisiciones · estructura · fases del deal **Prerrequisitos:** todo el Nivel III (especialmente Sociedades/LGSM y Gobierno Corporativo) + Contratos, Obligaciones, Garantías. **Estándar:** V3 (43 secciones + secciones transversales). ⌚ **Tiempo estimado de dominio:** 5–6 semanas (≈ 55–70 h de estudio activo). Lectura de reconocimiento: 10–12 h. *Estúdialo en bloques: racional y tipos → estructuras (share/asset/fusión) → fases del deal → actores y documentos → riesgos.*

Aviso de método. Tratado, no repaso. Este es el libro **insignia** del programa: lo trabajamos con la máxima profundidad, ejemplos trabajados, "cómo razona un socio de M&A" y conexión explícita con cada libro previo. A partir de aquí, todo es práctica de élite.

NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL (VISTA RÁPIDA)

Litigio	★★★☆☆
Corporate	★★★★★
M&A	★★★★★
Mercado de Valores	★★★★★
Venture Capital	★★★★★
Private Equity	★★★★★
Gobierno Corporativo	★★★★★
Compliance	★★★★☆
Derecho Bancario	★★★★☆
Empresa Familiar	★★★★★

Es la materia central del objetivo: la práctica mejor pagada y más sofisticada del derecho de los negocios, y la que integra todo lo aprendido.

1. Introducción

M&A (*Mergers & Acquisitions* — Fusiones y Adquisiciones) es el área del derecho corporativo dedicada a la **compraventa, fusión y reestructuración de empresas**. Cuando una empresa compra a otra, dos compañías se fusionan, un fondo adquiere un negocio, o una familia vende su empresa, hay una operación de M&A. Es, sin exageración, la **disciplina cumbre** del derecho de los negocios: combina derecho societario, contractual, de garantías, fiscal, laboral, de competencia, de valores y de gobierno corporativo, con finanzas, negociación y estrategia.

La idea central de este libro: una operación de M&A no es "un contrato", es un **proceso** complejo, por fases, que transforma la **propiedad y el control** de una empresa. Tiene una **lógica económica** (¿por qué se compra?: sinergias, crecimiento, acceso a mercados/tecnología, consolidación), una **estructura jurídica** (¿cómo se compra?: acciones —*share deal*—, activos —*asset deal*—, o fusión), un **calendario** (de la idea a la firma —*signing*— y al cierre —*closing*— y al *post-closing*) y un **reparto de riesgos** (quién responde si algo sale mal: *reps & warranties*, indemnización, *escrow*). El abogado de M&A es el **arquitecto y director de orquesta** de ese proceso. Este libro te da el plano maestro; los siguientes (Due Diligence, Estructu-

ras, Documentación, PE/VC, Gobierno avanzado) detallan cada pieza.

2. Objetivos del libro

Al terminar, el lector será capaz de:

- **Entender el racional** de una operación de M&A: por qué las empresas compran, se fusionan o se venden (sinergias, crecimiento, consolidación, *exit*).
- **Distinguir las estructuras** fundamentales: **share deal** (compra de acciones), **asset deal** (compra de activos) y **fusión** (merger), con sus ventajas, desventajas y consecuencias (pasivos, fiscal, consentimientos).
- **Dominar las fases** de una operación: originación, **NDA**, *teaser*/IM, **carta de intención/Term Sheet (LOI)**, **due diligence**, negociación y redacción del contrato, **signing**, condiciones, **closing** y **post-closing** (integración, *earn-out*, indemnización).
- **Identificar a los actores**: comprador, vendedor, asesores legales (de cada lado), banqueros de inversión, asesores financieros y fiscales, autoridades (COFECE, CNBV, sectoriales).
- **Comprender la lógica de asignación de riesgos**: cómo se reparte entre comprador y vendedor lo conocido y lo desconocido (precio, *reps & warranties*, condiciones, indemnización).
- **Conectar** cada pieza del M&A con su institución madre (todos los libros previos) y prepararse para los siguientes libros del Nivel IV.

3. Importancia profesional

El M&A es la **cima** de la práctica corporativa:

1. **Es la práctica más sofisticada y mejor pagada.** Las operaciones de M&A mueven miles de millones, involucran a los mejores despachos del mundo y exigen el dominio integral del derecho de los negocios. Ser socio de M&A es el destino que esta biblioteca persigue.

2. **Integra todo.** Una operación de M&A pone a prueba **cada** libro: sociedades (qué se compra), contratos (el SPA), garantías (el financiamiento), gobierno corporativo (los deberes del consejo), valores (si hay emisoras/OPA), concurso (*distressed M&A*), fiscal, laboral y competencia.
3. **Es el motor del private equity y el venture capital.** Los fondos **viven** del M&A: compran empresas (*entry*), las desarrollan y las venden o sacan a bolsa (*exit*). (Libros 5 del Nivel IV.)
4. **Define carreras.** El abogado que domina M&A es el más demandado por los despachos de élite y por las áreas de *general counsel* de las grandes corporaciones.

4. Historia de la institución

- **Las primeras grandes fusiones (s. XIX-XX, EE. UU.):** las **olas de fusiones** transformaron la economía. La **primera ola** (1895-1905) creó los grandes monopolios (Standard Oil, US Steel), detonando el **derecho antimonopolio** (Sherman Act, 1890). Las olas posteriores (años 60 —conglomerados—; 80 —*leveraged buyouts, hostile takeovers, junk bonds*—; 90 —megafusiones, globalización—; 2000s —*private equity*—; 2010s+ —tecnología—) moldearon el M&A moderno.
- **El nacimiento de la técnica:** el **derecho de Delaware** (su Court of Chancery) desarrolló la jurisprudencia de los deberes fiduciarios en el M&A (Revlon, Unocal, Van Gorkom —Libro 7 Nivel III), y la práctica de los despachos de Wall Street estandarizó la **documentación** (el SPA moderno, las *reps & warranties*, la indemnización, las condiciones).
- **Los raiders y el M&A hostil (años 80):** la era de las **adquisiciones hostiles** (Carl Icahn, T. Boone Pickens), los **LBOs** (la compra de RJR Nabisco, narrada en *Barbarians at the Gate*) y las **defensas anti-OPA** (*poison pills*), que definieron buena parte del derecho del *takeover*.
- **México:** el M&A creció con la **apertura económica** (TLCAN/T-MEC), las **privatizaciones** (años 90) y la llegada de fondos de PE y multinacionales. Los grandes despachos mexicanos (Creel, Galicia, Mijares, Ritch, Santamarina, Basham) y las

oficinas locales de los internacionales (Baker McKenzie, White & Case, etc.) desarrollaron una práctica de M&A de **clase mundial**, aplicando la técnica anglosajona sobre el derecho mexicano (LGSM, LMV, competencia).

5. Evolución histórica

- **De la fusión "doméstica" al M&A global:** de las consolidaciones nacionales a las operaciones **cross-border** que combinan varias jurisdicciones, monedas y reguladores.
- **De la negociación artesanal a la documentación estandarizada:** el SPA moderno, con su estructura fija (definiciones, *reps & warranties*, *covenants*, condiciones, indemnización, *boilerplate*), es producto de décadas de práctica de los despachos de Wall Street y la City.
- **Del comprador estratégico al financiero:** junto al comprador **estratégico** (una empresa que compra a otra por sinergias) surgió el comprador **financiero** (el **fondo de PE**, que compra para desarrollar y vender), con su técnica propia (LBO, *earn-outs*, *management incentives*).
- **De los riesgos asumidos al riesgo asegurado:** la aparición del **R&W Insurance** (seguro de manifestaciones y garantías) transformó la asignación de riesgos, permitiendo *clean exits*.
- **Tendencias actuales:** ESG en el M&A (due diligence de sostenibilidad), tecnología y datos (*tech M&A*, due diligence de ciberseguridad y propiedad intelectual), *distressed M&A*, y el uso de IA en la due diligence.

Idea de evolución clave: el M&A evolucionó de un **arte negociado** a una **disciplina sistematizada** con estructuras, documentación y reparto de riesgos estandarizados a nivel global. Dominar esa sistematización —sin perder el juicio estratégico— es lo que define al abogado de M&A de élite.

6. Contexto económico

El M&A es **estrategia corporativa y finanzas en estado puro** (Libros 9 y 10, Nivel I; Nivel V). ¿Por qué se compran empresas? Por **creación de valor**:

- **Sinergias**: que la empresa combinada valga **más** que la suma de las dos por separado ($1+1>2$): sinergias de **ingresos** (vender más, *cross-selling*) y de **costos** (economías de escala, eliminar duplicidades).
- **Crecimiento inorgánico**: crecer comprando, más rápido que construyendo desde cero (*build vs. buy* — la lógica de Coase y los costos de transacción, Libro 9).
- **Acceso**: a mercados, tecnología, talento, marcas, clientes, licencias.
- **Consolidación y poder de mercado**: ganar escala y posición (con el límite de la **competencia económica**).
- **Razones financieras**: comprar barato para vender caro (PE), aprovechar apalancamiento (LBO), arbitraje, diversificación.
- **Exit (para el vendedor)**: un fundador o un fondo que **realiza** el valor creado (vende, o saca a bolsa —Libro 5 Nivel III). El **precio** se determina por **valuación** (múltiplos, DCF — Libro 10 Nivel I y Nivel V); y muchas fusiones **destruyen** valor (sinergias sobreestimadas, mala integración): por eso la estrategia y la due diligence son críticas.

La teoría que explica por qué esto existe. Detrás de todo lo anterior hay una idea económica precisa, y conviene tenerla nombrada: el **mercado por el control corporativo** (Manne, 1965). Los activos productivos deben migrar hacia quien los administra mejor; y la adquisición —amistosa u hostil— es el mecanismo que reasigna el control cuando un equipo directivo destruye valor. Esa es la justificación económica del M&A y, al mismo tiempo, la razón por la que las defensas anti-OPA son polémicas: si bloquean la reasignación del control, protegen al directivo y no al accionista (§29).

Y el SPA, leído como instrumento económico. En clave de Coase, el contrato de compraventa de acciones es un **dispositivo para reducir costos de transacción** en un mundo de información asimétrica (Akerlof): el comprador no puede saber todo lo que el vendedor sabe. Cada cláusula que estudiarás en el Libro 4 de este nivel es, vista así, una **asignación de riesgo al que mejor lo soporta o mejor lo conoce**: las *reps & warranties* trasladan el riesgo de información al que la tiene; el *escrow* resuelve la cobrabilidad; el *earn-out* reparte la incertidumbre sobre el futuro; y la cláusula de *specific performance* elimina la opción del comprador de incumplir pagando daños —la opción que Holmes describía como el corazón del contrato en el *common law*—. **Ningún término de un SPA es neutral: cada uno es un incentivo diseñado.**

7. Contexto político

El M&A se desarrolla bajo el escrutinio del **poder público** (Libro 3, Nivel I):

- **Competencia económica (lo más relevante):** las concentraciones que superan umbrales requieren autorización de la COFECE (o el IFT en telecom/radiodifusión) para evitar daño a la competencia. Puede **autorizarse, condicionarse** (desinversiones, *remedies*) o **bloquearse**.
- **Inversión extranjera y seguridad nacional:** límites a la inversión extranjera en sectores reservados/restringidos (Libro 3 Nivel I); en otros países, *foreign investment screening* (CFIUS en EE. UU.).
- **Regulación sectorial:** energía (CRE), banca/valores (CNBV), seguros (CNSF), telecom (IFT): muchas operaciones requieren autorizaciones sectoriales.
- **Protección de minoritarios y mercado (OPA):** si hay emisoras, la LMV y la OPA (Libro 5 Nivel III). La dimensión política define el **calendario** (las autorizaciones tardan), las **condiciones de cierre** y, a veces, la **viabilidad** de la operación.

8. Contexto social

El M&A tiene impacto social profundo: las fusiones y adquisiciones afectan a **empleados** (sinergias de costos suelen significar **recortes**), a **comunidades** (cierre o crecimiento de plantas), a **consumidores** (más o menos competencia y precios) y a la **economía** (reasignación de recursos hacia usos más productivos —o concentración de poder—). El debate social: el M&A puede **crear valor** (empresas más eficientes, mejor gestionadas) o **destruirlo** (recortes, pérdida de competencia, endeudamiento excesivo en los LBO). El abogado de M&A opera en ese campo: estructura operaciones que crean valor legítimo y debe atender las dimensiones laboral, social y de competencia (y, cada vez más, el **ESG**).

9. Contexto empresarial

Para la empresa, el M&A es una de las **decisiones estratégicas más importantes** de su vida:

- **Para el comprador:** crecer, consolidar, acceder a capacidades; una mala adquisición (pagar de más, integrar mal, heredar pasivos ocultos) puede destruir años de valor.
- **Para el vendedor:** **realizar** el valor creado (un fundador que vende su empresa; un fondo que hace su *exit*; una corporación que se desprende de una división —*carve-out*—).
- **Para el fondo (PE/VC):** el M&A **es** su negocio: comprar (*entry*), desarrollar y vender (*exit*).
- **Para la empresa familiar:** la venta (o la sucesión) es un momento decisivo, cargado de dimensión patrimonial y emocional; el abogado debe combinar técnica de M&A con planeación patrimonial.

El abogado corporativo **lidera o integra el equipo** que ejecuta la operación: define la estructura, dirige la due diligence, negocia y redacta el contrato, coordina a los demás asesores (financieros, fiscales) y a las autoridades, y conduce el *signing* y el *closing*. Es el rol más completo, exigente y prestigioso del derecho de los negocios —y el destino de esta biblioteca—.

10. Definiciones doctrinales

- **M&A (doctrina y práctica):** conjunto de operaciones por las que se transfiere la **propiedad o el control** de una empresa (o de sus activos), incluyendo **adquisiciones** (compra de acciones o activos), **fusiones** (combinación de dos sociedades en una) y reestructuraciones afines (escisiones, *carve-outs*, *joint ventures*).
- **Adquisición (acquisition):** operación por la que un comprador obtiene el **control** de una empresa comprando sus **acciones** (*share deal*) o sus **activos** (*asset deal*).
- **Fusión (merger):** operación societaria (Libro 2 Nivel III) por la que dos o más sociedades se **combinan** en una sola: por **incorporación** (una absorbe a otra, que desaparece) o por **integración** (ambas desaparecen y nace una nueva), con **transmisión universal** del patrimonio.
- **Comprador estratégico vs. financiero:** el **estratégico** es una empresa que compra por **sinergias** (integrar el negocio); el **financiero** es un **fondo** (PE/VC) que compra para **desarrollar y vender** (busca rendimiento, no integración).
- **Sinergia (doctrina financiera):** el valor adicional que genera la combinación ($1+1>2$); justifica pagar una **prima** sobre el valor *stand-alone* de la *target*.

Lectura del Consejo: retén la **gran trifurcación estructural** — **share deal / asset deal / fusión**— porque de ella se deduce casi todo (qué se transfiere, qué pasivos se heredan, qué consentimientos y autorizaciones se necesitan, el tratamiento fiscal). Y distingue al comprador **estratégico** del **financiero**: piensan, negocian y estructuran distinto. Esas dos clasificaciones son la brújula del M&A.

11. Definiciones legales (verificar versión vigente)

El M&A **no** tiene una "ley de M&A" única: es una **práctica** que se construye sobre múltiples cuerpos legales (de ahí que integre todo):

- **Fusión y escisión: LGSM**, arts. 222-228 bis & (Libro 2 Nivel III): requisitos, asamblea extraordinaria, **derecho de oposición de acreedores**, efectos.

- **Compraventa de acciones:** **LGS** (transmisión por endoso + libro de registro, art. 128 C) + **Código Civil/Código de Comercio** (compraventa, saneamiento — Libros 2 Nivel II y 4 Nivel III).
- **Compraventa de activos:** Código de Comercio/Civil; transmisión de cada activo y **cesión** de contratos (con consentimientos — Libro 8 Nivel I).
- **Concentraciones (competencia):** **Ley Federal de Competencia Económica** (notificación y autorización de concentraciones que superen umbrales; COFECE/IFT).
- **Emisoras y OPA:** **Ley del Mercado de Valores** (Libro 5 Nivel III): oferta pública de adquisición, deberes del consejo, protección de minoritarios.
- **Inversión extranjera:** **Ley de Inversión Extranjera** (sectores reservados/restringidos).
- **Sectoriales:** leyes de energía, banca, seguros, telecom (autorizaciones).
- **Fiscal y laboral:** Código Fiscal, Ley del ISR (efectos de la operación), Ley Federal del Trabajo (sustitución patronal en *asset deals*).
- **El contrato (SPA/APA/SHA):** se rige por la **autonomía de la voluntad** (Libro 8 Nivel I) y, si es cross-border, a menudo por **ley extranjera** (NY, inglesa) elegida por las partes.

12. Definición sencilla

Una operación de **M&A** es **comprar, vender o fusionar empresas**. Hay tres formas básicas:

- **Comprar las acciones** (*share deal*): te quedas con la **empresa entera** (con todo lo bueno y lo malo: sus activos y sus deudas).
- **Comprar solo los activos** (*asset deal*): te llevas las **partes que quieres** (la fábrica, la marca, los contratos) y dejas atrás (idealmente) las deudas.
- **Fusionar** dos empresas en **una sola**.

Y no es "un contrato": es un **proceso por etapas** que va de la idea inicial a investigar la empresa (*due diligence*), negociar

y firmar el contrato (*signing*), cumplir condiciones (como permisos de las autoridades) y, finalmente, **cerrar** (*closing*: se paga el precio y se transfiere la empresa). El gran tema de fondo es **quién paga si algo sale mal** después: para eso están las **declaraciones y garantías** del vendedor (*reps & warranties*), la **indemnización** y el dinero retenido en **escrow**.

13. Conceptos fundamentales

- **Target (empresa objetivo)**: la empresa que se compra/adquiere.
- **Buyer/Bidder (comprador) y Seller (vendedor)**.
- **Share deal (compra de acciones)**: se adquieren las **acciones** de la *target*; el comprador **hereda la sociedad con todos sus activos y pasivos** (incluidos los ocultos). Más simple de ejecutar (una sola transferencia), pero más riesgoso en pasivos → más peso en *reps* e indemnización.
- **Asset deal (compra de activos)**: se adquieren **activos y pasivos seleccionados**; permite **dejar atrás** pasivos no deseados, pero exige transmitir **cada activo y ceder cada contrato** (con consentimientos y *change of control* — Libro 4 Nivel III), y puede activar **sustitución patronal** y costos fiscales.
- **Merger (fusión)**: combinación societaria (LGSM); transmisión universal del patrimonio.
- **Carve-out / spin-off**: separar una **división** o unidad de negocio para venderla (*carve-out*) o para distribuirla a los accionistas (*spin-off*, vía escisión — Libro 2 Nivel III).
- **NDA (acuerdo de confidencialidad)**: protege la información que el vendedor revela al comprador en las pláticas iniciales.
- **Teaser / Information Memorandum (IM)**: documentos con que el vendedor presenta la *target* a posibles compradores (en procesos competitivos/subastas).
- **LOI / Term Sheet / Carta de Intención (MOU)**: documento preliminar que fija los **términos básicos** (precio indicativo, estructura, exclusividad, calendario). **Mayormente NO vinculante**, salvo cláusulas específicas (confidencialidad, exclusividad/*no-shop*, ley aplicable) — Libro 8 Nivel I.

- **Due diligence:** la **investigación** a fondo de la *target* (legal, financiera, fiscal, laboral, etc.) antes de comprar (Libro 2 del Nivel IV).
- **SPA (Share Purchase Agreement):** el contrato de compraventa de **acciones** (el documento estrella del *share deal*). **APA (Asset Purchase Agreement):** el de compraventa de **activos**. **SHA (Shareholders Agreement):** convenio entre accionistas (gobierno post-cierre, en JV y PE/VC).
- **Reps & Warranties (declaraciones y garantías):** afirmaciones del vendedor sobre la *target* (su propiedad, finanzas, contratos, ausencia de pasivos ocultos); su falsedad activa la **indemnización** (raíz: saneamiento — Libro 2 Nivel II).
- **Covenants:** obligaciones de hacer/no hacer (p. ej., operar "en el curso ordinario" entre signing y closing).
- **Conditions precedent (condiciones suspensivas):** lo que debe cumplirse para cerrar (autorizaciones COFECE/CNBV, *no MAC*, veracidad de *reps*) — Libro 4 Nivel I (modalidades).
- **Signing vs. Closing:** la **firma** del contrato (signing) y el **cierre** (closing: se paga y se transfiere). Se separan cuando hay condiciones (autorizaciones); si no, son **simultáneos**.
- **Purchase price y ajustes:** precio, con ajustes por **deuda neta y capital de trabajo** (Libro 10 Nivel I); mecanismos **locked box vs. completion accounts**.
- **Earn-out:** parte del precio **diferida y condicionada** a resultados futuros de la *target* (obligación condicional — Libro 1 Nivel II).
- **Escrow / Holdback:** retención de parte del precio (en un fideicomiso/cuenta) para garantizar la **indemnización** (Libros 3 y 4 Nivel III; Libro 3 Nivel II).
- **MAC / MAE (Material Adverse Change/Effect):** cláusula que permite **no cerrar** si ocurre un cambio adverso relevante en la *target* entre signing y closing.
- **Indemnización (indemnity):** el régimen que define **qué daños** repara el vendedor, con **cap** (tope), **basket/de minimis** (umbral) y **survival** (plazo) — Libro 3 Nivel II.

- **R&W Insurance:** seguro que cubre el incumplimiento de las *reps*, permitiendo un *clean exit*.
- **Comprador estratégico vs. financiero (PE/VC):** ver sección 10.
- **Concentración (competencia):** la operación de M&A vista desde el derecho de competencia (notificación a COFECE/IFT).

14. Desarrollo absoluto

Lo organizamos en: (A) las **estructuras** (share/asset/fusión) y cómo elegir; (B) las **fases** del *deal* (de la idea al post-closing); (C) los **actores** y sus roles; (D) la **lógica de asignación de riesgos** (el alma del M&A); (E) las **autorizaciones y condiciones**.

14.A · LAS ESTRUCTURAS DEL M&A (SHARE DEAL, ASSET DEAL, FUSIÓN) Y CÓMO ELEGIR

1) Share deal (compra de acciones). El comprador adquiere las **acciones** de la *target*; la sociedad **sigue siendo la misma** (con su RFC, sus permisos, sus contratos), solo cambia de dueño.

- **Ventajas:** simple de ejecutar (una transferencia de acciones —endoso + libro de registro, Libro 2 Nivel III—); los **contratos, permisos y licencias** de la *target* **continúan** (no hay que cederlos uno por uno), salvo cláusulas de *change of control*.
- **Desventajas:** el comprador **hereda TODOS los pasivos** de la sociedad, incluidos los **ocultos** (fiscales, laborales, ambientales, litigios). Por eso el *share deal* exige **due diligence profunda** y un robusto régimen de ***reps & warranties* + indemnización**.

2) Asset deal (compra de activos). El comprador adquiere **activos y pasivos seleccionados** (la fábrica, la marca, el inventario, ciertos contratos), dejando el resto (idealmente los pasivos no deseados) en la sociedad del vendedor.

- **Ventajas:** permite **escoger** lo que se compra y **aislar** pasivos no deseados; útil para comprar una **división** (carve-out).

- **Desventajas:** hay que **transmitir cada activo** (con su forma y registro — Libro 6 Nivel I) y **ceder cada contrato** (con **consentimiento** de la contraparte y cuidado del *change of control* — Libro 4 Nivel III); puede activar **sustitución patronal** (laboral) y mayores **costos fiscales** (IVA, ISR sobre la enajenación de activos). Más laborioso.

3) Fusión (merger). Las sociedades se **combinan** en una (Libro 2 Nivel III): transmisión universal del patrimonio, asamblea extraordinaria, **derecho de oposición de acreedores** (efectos a los 3 meses, salvo pago/garantía). Útil para integrar definitivamente dos empresas o para estructuras de adquisición (el vehículo NewCo se fusiona con la *target* —*merger sub*—).

Cómo razona un socio (elección de estructura). *"La primera gran decisión es share, asset o fusión, y la tomo cruzando cuatro ejes: (1) Pasivos: ¿hay riesgo de pasivos ocultos? → si sí, quizá asset deal para aislarlos, o share deal con reps fuertes y escrow. (2) Contratos y permisos: ¿la target tiene contratos/licencias clave no transferibles o con change of control? → si son difíciles de ceder, share deal (continúan en la sociedad). (3) Fiscal: ¿qué estructura es más eficiente (a menudo el share deal evita el IVA de la venta de activos; el asset deal puede dar 'step-up' de base)? — siempre con el asesor fiscal. (4) Regulatorio: ¿qué requiere menos autorizaciones? La estructura óptima equilibra estos cuatro ejes; rara vez hay una respuesta única."*

14.B · LAS FASES DE UNA OPERACIÓN DE M&A (DE LA IDEA AL POST-CLOSING)

Una operación es un **proceso** con etapas bien definidas:

- 1. Originación y estrategia:** la idea de comprar/vender; definición de objetivos; identificación de *targets*/compradores. (En ventas, a menudo un **proceso competitivo/subasta** dirigido por un banco de inversión.)
- 2. Primer contacto y NDA:** se firma el **acuerdo de confidencialidad** para intercambiar información.
- 3. Documentos de presentación:** el vendedor entrega *teaser* e **Information Memorandum (IM)**; ofertas indicativas no vinculantes.

4. **Carta de intención / Term Sheet (LOI):** se acuerdan los **términos básicos** (precio indicativo, estructura, exclusividad/*no-shop*, calendario). **Mayormente no vinculante**, salvo confidencialidad, exclusividad y ley aplicable (Libro 8 Nivel I).
5. **Due diligence:** el comprador **investiga** a fondo la *target* (data room): legal, financiera, fiscal, laboral, ambiental, regulatoria, contractual. Se identifican **riesgos** que se traducen en ajustes de precio, *reps*, indemnidades específicas o condiciones (Libro 2 del Nivel IV).
6. **Negociación y redacción del contrato (SPA/APA):** se negocia el precio (y sus ajustes), las ***reps & warranties***, los *covenants*, las **condiciones**, la **indemnización** (cap, basket, survival), el *escrow*, el MAC. Rondas de *mark-ups*.
7. **Signing (firma):** las partes firman el contrato. Si hay condiciones pendientes (autorizaciones), el cierre se difiere.
8. **Periodo entre signing y closing (*interim period*):** se cumplen las **condiciones** (autorizaciones COFECE/CNBV/sectoriales, consentimientos de terceros), y el vendedor opera "en el curso ordinario" (*interim covenants*); aplica el MAC.
9. **Closing (cierre):** se **cumplen las condiciones**, se **paga el precio** y se **transfiere** la empresa (entrega de acciones/activos, firma de documentos de cierre, *closing checklist*).
10. **Post-closing: integración** (del comprador estratégico), ajustes de precio (*completion accounts*), **earn-out**, reclamaciones de **indemnización** (*claims*) contra el *escrow* o el vendedor, y cumplimiento de obligaciones supervivientes (no competencia, transición).

Signing y closing simultáneos vs. diferidos: si **no** hay condiciones (autorizaciones), se firma y se cierra el **mismo día** (*sign and close*). Si hay condiciones, hay un **periodo intermedio** (días o meses) durante el cual la operación está "firmada pero no cerrada".

14.C · LOS ACTORES DE UNA OPERACIÓN DE M&A

- **Comprador y vendedor** (estratégico o financiero/fondo).
- **Abogados de M&A** (de cada lado): dirigen la due diligence, estructuran, negocian y redactan los contratos, coordinan

autorizaciones y conducen signing/closing. (El rol que esta biblioteca forma.)

- **Banqueros de inversión / asesores financieros:** valúan, buscan compradores/targets, dirigen el proceso competitivo, emiten *fairness opinions*.
- **Asesores fiscales:** diseñan la estructura **fiscalmente eficiente** (decisión central).
- **Asesores contables / financieros:** due diligence financiera, *quality of earnings*.
- **Consultores especializados:** ambiental, técnico, de seguros, de RRHH, de TI/ciberseguridad.
- **Autoridades:** COFECE/IFT (competencia), CNBV (valores/OPA), CNIE (inversión extranjera), reguladores sectoriales (CRE, CNSF), notarios y Registro Público.
- **El consejo de administración** (de comprador y vendedor): aprueba la operación cumpliendo sus **deberes fiduciarios** (Libro 7 Nivel III: Revlon, Unocal, business judgment rule).

14.D · LA LÓGICA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS (EL ALMA DEL M&A)

El **problema central** del M&A es la **información asimétrica** (Libro 9 Nivel I): el **vendedor conoce la target; el comprador, no**. Toda la maquinaria del SPA existe para **repartir el riesgo de lo conocido y lo desconocido**:

- **Due diligence:** reduce la asimetría (el comprador investiga).
- **Reps & warranties:** el vendedor **garantiza** ciertos hechos (propiedad, finanzas, ausencia de pasivos ocultos); si son falsos, hay **incumplimiento** (raíz: saneamiento, Libro 2 Nivel II).
- **Disclosure schedules:** el vendedor **revela** las excepciones a sus *reps* (lo revelado **no** genera responsabilidad — relación regla/excepción, Libro 12 Nivel I).
- **Indemnización (cap, basket, survival):** define **cuánto** y por **cuánto tiempo** responde el vendedor por la falsedad de las *reps* (Libro 3 Nivel II: responsabilidad contractualizada).

- **Escrow / holdback:** asegura el cobro de la indemnización (retención del precio).
- **Conditions precedent y MAC:** permiten **no cerrar** si algo cambia o no se cumple.
- **Ajustes de precio (deuda neta, capital de trabajo) y earn-out:** asignan el riesgo del **valor** y del **desempeño** (Libro 10 Nivel I).
- **R&W Insurance:** **transfiere** el riesgo de las *reps* a una aseguradora.

Cómo razona un socio (reparto de riesgo). *"Negociar un M&A es, en el fondo, negociar quién paga si algo sale mal. El vendedor quiere un clean exit (vender y olvidarse): reps acotadas, cap bajo, survival corto, non-reliance. El comprador quiere protección: reps amplias, cap alto, survival largo, escrow, indemnidades específicas para lo que vio en due diligence. Mi trabajo es mover esas palancas —cada una vale dinero— para proteger a mi cliente. El SPA es un mapa de riesgos repartidos, y cada cláusula es una decisión de quién carga qué."*

14.E · AUTORIZACIONES Y CONDICIONES (EL CALENDARIO DEL DEAL)

Las **condiciones de cierre** (Libro 4 Nivel I: condición suspensiva) marcan el **calendario**:

- **Competencia (COFECE/IFT):** las concentraciones que superen umbrales requieren **autorización previa** (no se puede cerrar antes —*gun jumping* prohibido—). Puede tardar y traer **condiciones** (desinversiones).
- **Inversión extranjera / sectoriales:** CNIE, CRE, CNBV, CNSF según el sector.
- **Consentimientos de terceros:** por *change of control* en contratos clave (Libro 4 Nivel III).
- **Aprobaciones corporativas:** asambleas/consejos de comprador y vendedor (Libros 2 y 7 Nivel III).
- **Veracidad de reps al cierre (*bring-down*) y no MAC.** El abogado **gestiona el calendario** de estas condiciones: muchas operaciones se firman y tardan **meses** en cerrar por las autorizaciones.

15. Explicación intuitiva

Imagina que comprar una empresa es como **comprar una casa enorme y compleja**, pero a una escala y con una complejidad infinitamente mayores:

- Primero decides **qué compras**: ¿la **casa entera con todo dentro** —incluidas las deudas escondidas— (*share deal*: compras la sociedad)? ¿O **solo los muebles y cuartos que quieres**, dejando atrás las deudas (*asset deal*: compras activos)? ¿O **juntas tu casa con otra** (fusión)?
- Antes de pagar, **revisas la casa a fondo** (*due diligence*): ¿tiene cimientos sólidos?, ¿hay goteras ocultas (pasivos)?, ¿los papeles están en regla (propiedad, permisos, contratos)?
- Acuerdas las condiciones en un **preacuerdo** (*term sheet*, mayormente no vinculante) y luego en el **contrato detallado** (*SPA*). En él, el **vendedor te jura** que la casa está como dice (*reps & warranties*) y, si te ocultó las goteras, te **indemniza** —pero solo hasta cierto monto (*cap*) y por cierto tiempo (*survival*)—; y dejas dinero **retenido** (*escrow*) por si aparecen problemas.
- **Firmas** (*signing*), esperas los **permisos** (las autoridades, como un crédito hipotecario que tarda) y, cuando todo está listo, **cierras** (*closing*): pagas y te entregan las llaves.
- Después (*post-closing*), te **mudas e integras** (si eres estratégico), ajustas cuentas y, si aparecen goteras ocultas, **reclamas** contra el escrow.

El gran tema de fondo —como en cualquier compra de algo que no conoces del todo— es **quién carga con las sorpresas desagradables**. Todo el arte del M&A es **investigar bien** (*due diligence*) y **repartir ese riesgo con inteligencia** (*reps*, indemnización, escrow, condiciones). El abogado de M&A es el **arquitecto y director de orquesta** de todo ese proceso.

16. Ejemplos simples

1. **Share deal**. Un grupo compra el **100% de las acciones** de una embotelladora. Adquiere la sociedad **completa**: sus activos, su marca, sus contratos... y también sus **deudas y con-**

tingencias (fiscales, laborales). Por eso exige *reps* fuertes y escrow.

2. **Asset deal.** Una empresa compra solo la **línea de producción y la marca** de un competidor en problemas, **sin** asumir sus deudas con bancos. Debe ceder los contratos clave (con consentimientos) y atender la sustitución patronal de los empleados que recibe.
3. **Fusión.** Dos bancos medianos **se fusionan** en uno: asamblea extraordinaria, autorización de la CNBV y la COFECE, derecho de oposición de acreedores; nace un banco más grande.
4. **Signing y closing diferidos.** Se firma el SPA en enero, pero el cierre se condiciona a la **autorización de COFECE**, que llega en mayo: se cierra en mayo (no antes —*gun jumping*).
5. **Earn-out.** El comprador paga \$800M al cierre y **\$200M más** si la *target* alcanza cierto EBITDA en 2 años: parte del precio queda **condicionada** al desempeño futuro.

17. Ejemplos complejos

1. **LBO con estructura de fusión (merger sub).** Un fondo de PE crea una **NewCo** que se **endeuda** (acquisition finance — Libros 3 y 4 Nivel II y III) para comprar la *target*, y luego **se fusiona** con ella, de modo que la deuda quede en la empresa adquirida. Analiza: la estructura (share deal vía NewCo + fusión), el *security package* (prenda sobre acciones, hipoteca, fideicomiso de flujos), el riesgo de **fraude de acreedores** (la *target* "paga su propia compra"), y las autorizaciones. (Se profundiza en el Libro 5 Nivel IV: PE.)
2. **Pasivo oculto descubierto post-closing (share deal).** Tras comprar la sociedad, aparece una **contingencia fiscal** no revelada. El comprador activa la **indemnización**: ¿la *rep* fiscal era amplia?, ¿estaba dentro del **survival**?, ¿supera el **basket** y está bajo el **cap**?, ¿se revisó en *disclosure*? Se cobra contra el **escrow**. Lección: el reparto de riesgo pactado decide de quién paga (Libros 3 Nivel II y 12 Nivel I).
3. **Subasta competitiva (dual track).** Una familia vende su empresa; el banquero corre una **subasta** con varios fondos y, **en paralelo, prepara una IPO** (*dual track*), para elegir la

opción de mayor valor. El consejo debe cumplir sus **deberes fiduciarios** (maximizar valor — Revlon, Libro 7 Nivel III). Lección: el proceso competitivo maximiza el precio y disciplina los deberes del consejo.

4. **Operación frustrada por competencia (remedies).** Dos líderes pactan fusionarse; la COFECE determina que crearía poder de mercado y exige **desinversiones** (*remedies*) como condición. Las partes negocian si aceptan los remedios o abandonan (*walk away*). Lección: la competencia define la viabilidad y puede reconfigurar el *deal* (Libros 3 y 9 Nivel I).

18. Casos reales (operaciones estilizadas y referentes)

- **RJR Nabisco (1989, *Barbarians at the Gate*):** el LBO más famoso de la historia; ilustra la dinámica de los *leveraged buyouts*, las subastas, los deberes del consejo y el apalancamiento extremo de los años 80.
- **Megafusiones que destruyeron valor (AOL–Time Warner, Daimler–Chrysler):** ejemplos clásicos de **sinergias sobreestimadas** y **mala integración**: recuerdan que muchas fusiones **destruyen** valor.
- **Jurisprudencia de Delaware (Revlon, Unocal, Van Gorkom):** define los deberes del consejo en una venta/OPA (Libro 7 Nivel III); derecho vivo del M&A.
- **M&A en México (estilizado):** consolidaciones en banca, telecom, alimentos y retail; operaciones cross-border con fondos globales; el papel de la COFECE en concentraciones relevantes.
- **Disney–Fox (2019, ~71,300 mdd  verificar):** guerra de ofertas entre Disney y Comcast por los activos de Fox. Es la lección maestra sobre **proceso competitivo**: cuando hay subasta, el deber del consejo de maximizar precio (*Revlon*) deja de ser una abstracción y se vuelve el motor de la operación.
- **Microsoft–Activision (2023, ~69,000 mdd ):** mostró que en las grandes operaciones el riesgo que puede matar el *deal* hoy **no es financiero, es regulatorio** —CMA británica, FTC,

Comisión Europea—, y que el calendario de autorizaciones es la variable crítica del cronograma (§14.E).

- **Musk–Twitter (2022, ~44,000 mdd ▲)**: el intento de abandonar la operación después de firmar y el litigio en Delaware que lo forzó a cerrar. **Es el caso que hay que tener en la cabeza al redactar una MAC y una cláusula de *specific performance***: demostró que, bien redactadas, no dejan salida —y que ahí es donde se decide si el comprador puede arrepentirse—.

Nota de método (Manifiesto XI.5): los casos se exponen por su valor formativo; verificar datos y jurisprudencia vigente antes de invocarlos. **Las cifras de una operación se discuten durante años**: las marcas ▲ están puestas a propósito.

19. Casos empresariales

- **Crecimiento por adquisición (*buy-and-build*)**: una empresa (o un fondo) adquiere varios competidores pequeños para **consolidar** un sector fragmentado y ganar escala.
- **Carve-out**: una corporación **vende una división** no estratégica para enfocarse en su negocio central (y monetizar).
- **Venta de empresa familiar**: los fundadores **venden** a un estratégico o a un fondo; el abogado combina técnica de M&A con **planeación patrimonial** y manejo de la dimensión familiar/emocional.
- **Joint venture (equity JV)**: dos empresas crean una **sociedad conjunta** (S.A.P.I.) para un proyecto, con SHA que regula gobierno, aportaciones, *deadlock* y salida (Libros 2 y 4 Nivel III).

20. Casos corporativos (la conexión integral)

Una operación de M&A **ensambla todos los libros**:

- **Sociedades (LGSM)**: qué se compra (acciones), cómo se transfieren (endoso + libro), las vicisitudes (fusión, escisión).
- **Contratos (Niveles I y III)**: el SPA es un contrato (compra-venta); los contratos de la *target* y sus *change of control*.
- **Obligaciones y Responsabilidad (Nivel II)**: el régimen de indemnización (daños, cap, basket).

- **Garantías (Nivel II) y Títulos/Operaciones de crédito (Nivel III):** el *acquisition finance* y el *security package* (prenda sobre acciones, fideicomiso de flujos).
- **Mercado de valores (LMV):** si hay emisoras → **OPA** y disclosure.
- **Concurso:** el *distressed M&A* (comprar en crisis).
- **Gobierno corporativo:** los **deberes del consejo** (Revlon, Unocal) al aprobar la operación.
- **Competencia, fiscal, laboral:** las autorizaciones y los efectos. *Por eso este es el libro insignia: aquí converge toda la biblioteca.*

21. Casos internacionales

- **M&A cross-border:** operaciones que combinan **varias jurisdicciones** (la *target* en México, el comprador extranjero, financiamiento en NY, garantías en varios países): se coordinan equipos locales, ley aplicable (a menudo **NY/inglesa** para el SPA), foros y autorizaciones múltiples (incluido *foreign investment screening* —CFIUS en EE. UU.—).
- **Documentación anglosajona como estándar global:** el SPA cross-border sigue la **técnica anglosajona** (definiciones, reps & warranties, indemnity, conditions, boilerplate); el abogado debe redactar y negociar en **inglés jurídico**.
- **R&W Insurance internacional:** mercado maduro en EE. UU./Europa, creciente en México; permite *clean exits* y facilita los procesos competitivos.
- **Competencia multijurisdiccional:** las grandes concentraciones requieren autorización en **varios países** (COFECE, DOJ/FTC en EE. UU., Comisión Europea), con calendarios y *remedies* coordinados.
- **Arbitraje internacional:** las disputas post-closing (indemnización, MAC) se resuelven a menudo en **arbitraje** (CCI, LCIA), no en tribunales estatales.

22. Derecho comparado

SISTEMA	RASGOS DEL M&A
México	Estructuras share/asset/fusión (LGSM); SPA con técnica anglosajona sobre derecho mexicano; concentraciones ante COFECE/IFT ; OPA (LMV); inversión extranjera; mercado liderado por despachos de élite.
España / UE	Directiva de OPAs (<i>takeover bids</i>); control de concentraciones (Comisión Europea + autoridades nacionales); <i>due diligence</i> y SPA de estilo europeo-anglosajón.
Estados Unidos	El referente y el motor del M&A global: SPA/Merger Agreement estandarizados; Delaware (deberes fiduciarios, Revlon/Unocal); control antitrust (DOJ/FTC, Hart-Scott-Rodino); SEC y tender offers (Williams Act); R&W Insurance maduro.
Delaware	La capital del M&A: su <i>corporate law</i> y la Court of Chancery definen los estándares de los deberes del consejo, las defensas anti-OPA y la <i>appraisal</i> (derecho de los disidentes a valoración).
Reino Unido	El modelo opuesto al de Delaware, y por eso el más ins-tractivo: el <i>Takeover Code</i> y su regla de no-frustración trasladan la decisión a los accionistas —el consejo no puede desplegar defensas sin voto de la junta—, y un Takeover Panel resuelve con rapidez extrajudicial.
UNI-DROIT/OCDE	Principios de gobierno corporativo (deberes del consejo en M&A); soft law sobre adquisiciones.
UNCITRAL	Marco de comercio internacional y arbitraje (disputas post-closing).
CISG	No aplica a la compra de acciones/empresa; sí a la compraventa de bienes/activos en algunos casos.
Common Law	Documentación extensa y autosuficiente; <i>reps & warranties</i> , <i>indemnities</i> , <i>MAC</i> , <i>disclosure schedules</i> ; fuerte litigio post-closing (Delaware).
Civil Law	Adopta la técnica anglosajona del SPA sobre el derecho local (fusión/escisión societaria, saneamiento como raíz de las reps); convergencia global de la práctica.

Convergencia clave: el M&A es la práctica **más globalizada** del derecho. La **documentación anglosajona** (SPA con reps & warranties, indemnity, conditions, MAC) es el **estándar mundial**, se aplique sobre derecho mexicano, español o el que sea. **Delaware** es el laboratorio de los deberes fiduciarios y las defensas. Por eso el abogado de M&A debe dominar **inglés jurídico** y la técnica anglosajona, además del derecho local. (Los estándares de Delaware se profundizan en el Libro 3 y 6 del Nivel IV.)

Las dos soluciones al mismo problema, y qué debería aprender México. Delaware y el Reino Unido enfrentaron la misma pregunta —¿quién decide si la empresa se vende: el consejo o los accionistas?— y la resolvieron al revés. Delaware la dejó en el consejo y **disciplinó su conducta** con deberes fiduciarios afinados caso por caso (*Van Gorkom*: informarse; *Revlon*: maximizar precio en un cambio de control; *Unocal*: defensas proporcionales), lo que da previsibilidad a cambio de litigio. El Reino Unido se la quitó al consejo: con la **regla de no-frustración**, quien decide es la junta, y un panel especializado resuelve en días lo que en Delaware tarda años de *discovery*.

México no tiene ninguno de los dos: carece del cuerpo jurisprudencial denso de Delaware y de un *Takeover Panel*, y su régimen de OPA (LMV ☞) es más formalista que sustantivo. **La lección comparada, dicha como postura del Consejo:** un mercado de control eficiente necesita **o** deberes fiduciarios densos y exigibles, **o** una autoridad ágil que decida rápido. Tener las dos cosas a medias es la peor combinación, porque el minoritario no tiene ni jurisprudencia que invocar ni foro que resuelva a tiempo.

23. Derecho mexicano

El M&A en México **integra** múltiples cuerpos (no hay "ley de M&A"):

- **LGSM:** transmisión de acciones (128), fusión y escisión (222-228 bis), responsabilidad de administradores (157-163), S.A.P.I. (vía LMV).
- **LMV: OPA** (92-109), gobierno corporativo de emisoras, disclosure (Libro 5 Nivel III).
- **Ley Federal de Competencia Económica:** notificación y autorización de **concentraciones** (umbrales, COFECE/IFT, *gun jumping*, *remedies*).
- **Ley de Inversión Extranjera:** sectores reservados/restringidos y registro (RNIE).
- **Sectoriales:** energía (CRE), banca/valores (CNBV), seguros (CNSF), telecom (IFT).

- **Fiscal (CFF, LISR):** efectos de la enajenación de acciones/activos, fusión/escisión (régimen de neutralidad fiscal si se cumplen requisitos).
- **Laboral (LFT): sustitución patronal** en asset deals.
- **Civil/Mercantil:** la compraventa, el saneamiento, las garantías, los contratos y su cesión.
- **El SPA:** autonomía de la voluntad (art. 78 ⚡ C. Com.; Libro 8 Nivel I); a menudo regido por ley extranjera en operaciones cross-border.

24. Jurisprudencia relevante

Verificar vigencia antes de citar. - **Deberes fiduciarios del consejo (LMV / comparado Delaware):** Revlon (venta de control), Unocal (defensas), Van Gorkom (deber de informarse) — referencia del M&A (Libro 7 Nivel III).

Cómo se convierte una sentencia de 1985 en tres documentos de tu escritorio. Esto es lo que distingue leer jurisprudencia de usarla. *Smith v. Van Gorkom* (Del. 1985) declaró responsables a consejeros que aprobaron una venta **sin informarse suficientemente**: dos horas de junta, sin valuación, sin leer el acuerdo. La consecuencia práctica no fue doctrinal, fue **operativa**, y sigue viva en cada operación que documentas:

- **El *fairness opinion*** del banco de inversión: existe, en buena medida, para acreditar que el consejo se informó sobre el precio.
- **El acta detallada del consejo**, con las alternativas consideradas, la información recibida y las razones: es el registro del proceso, no del resultado. Es la misma lógica del sesgo retrospectivo del módulo 01 de la Columna VI.
- **La cláusula de *fiduciary out***: permite al consejo atender una oferta superior sin incumplir el contrato, precisamente porque *Revlon* le exige maximizar precio.

Cuando levantes el acta de un consejo que aprueba una adquisición (Laboratorio 08), estás ejecutando *Van Gorkom* aunque no lo cites. - **Concentraciones (COFECE) y *gun jumping***: resoluciones que sancionan cerrar antes de la autorización o no notificar.

- **Indemnización y reps & warranties**: criterios sobre interpretación de las *reps*, materialidad, *disclosure* y causalidad del daño (Libros 3 Nivel II y 8 Nivel I).
- **Fusión y derecho de oposición de acreedores**: criterios sobre los efectos y la protección de acreedores (LGSM 224-225).
- **OPA y protección de minoritarios**: criterios sobre la obligatoriedad de la OPA y el trato igualitario (LMV).

25. Criterios de la Suprema Corte / reguladores

- **Competencia económica:** la SCJN y los tribunales especializados han delineado el alcance del control de concentraciones y las facultades de la COFECE.
- **Protección de minoritarios:** criterios que refuerzan los derechos en emisoras (OPA, disclosure).
- **Deberes de administradores:** desarrollo del deber de diligencia y lealtad (robusto en emisoras).
- **(Comparado) Delaware:** la jurisprudencia de la Court of Chancery es el referente mundial de los deberes del consejo en M&A.

26. Doctrina nacional

- **Doctrina mexicana de M&A y derecho corporativo** (artículos y obras de los grandes despachos y académicos): práctica de fusiones, adquisiciones, due diligence y documentación en México.
- **Doctrina de competencia económica** (concentraciones): clave por su rol en la viabilidad del *deal*.
- **Doctrina societaria y bursátil** (LGSM, LMV — Libros 2 y 5 Nivel III): el sustrato del M&A.
- **Literatura de empresa familiar y planeación patrimonial:** para las ventas de empresas familiares.

27. Doctrina internacional

- **"The Art of M&A"** (Reed, Lajoux et al.): manual clásico y completo de la práctica de M&A.
- **Lou Kling & Eileen Nugent, *Negotiated Acquisitions of Companies, Subsidiaries and Divisions*:** la "biblia" de la práctica transaccional estadounidense.
- **Reinier Kraakman et al., *The Anatomy of Corporate Law*:** marco funcional del derecho corporativo y el M&A.
- **Jurisprudencia y doctrina de Delaware** (deberes fiduciarios, defensas).

- ***Barbarians at the Gate* (Burrough & Helyar):** lectura narrativa imprescindible para entender la dinámica humana y financiera de los grandes *deals*.
- **Gilson & Black, *The Law and Finance of Corporate Acquisitions*:** el puente entre el derecho y las finanzas del M&A. Es la obra que hay que leer cuando ya dominas la documentación y quieres entender **por qué** cada término existe.
- **Depamphilis, *Mergers, Acquisitions and Other Restructuring Activities*:** el manual de nivel intermedio, con el aparato financiero y de proceso.
- **Wachtell, Lipton, *Takeover Law and Practice*** (memorándum anual): el estado del arte de la práctica estadounidense, actualizado cada año. Léelo para saber qué está cambiando.
- **Los artículos fundacionales**, si quieres ir a la fuente: Manne (1965) sobre el mercado por el control corporativo; Roll (1986) sobre la hipótesis de la *hubris*; Jensen sobre costos de agencia; Bradley, Desai y Kim sobre sinergias.

28. Opiniones críticas (postura del Consejo)

1. **La estructura (share/asset/fusión) es la primera y más estratégica decisión.** El Consejo insiste en analizarla cruzando **pasivos, contratos, fiscal y regulatorio** desde el inicio: una estructura mal elegida arrastra problemas todo el *deal*.
2. **El M&A es 50% derecho y 50% gestión de proceso y personas.** El Consejo subraya que el abogado de M&A no solo redacta: **dirige un proceso** (calendario, due diligence, coordinación de asesores y autoridades, negociación), y eso —no solo el conocimiento— es lo que se aprende en el oficio.
3. **Muchas fusiones destruyen valor.** El Consejo recuerda que las **sinergias se sobreestiman** y la **integración** suele fallar; el buen abogado aporta **escepticismo informado** (due diligence rigurosa, asignación de riesgo realista), no solo entusiasmo por cerrar.

29. Debate doctrinal

- **Share deal vs. asset deal:** ¿prevalece la simplicidad (share) o el aislamiento de pasivos (asset)? El debate se decide caso a caso (pasivos, contratos, fiscal, regulatorio).
- **¿El M&A crea o destruye valor?** Es el debate central de la disciplina y tiene tres posiciones con nombre propio, que conviene poder citar:
 1. **La hipótesis de las sinergias** (Bradley, Desai y Kim): el comprador paga una prima porque el conjunto vale legítimamente más que las partes. La prima es el precio de un valor real.
 2. **La hipótesis de agencia, o del "imperio"** (Jensen): muchas adquisiciones benefician al tamaño, la relevancia y la remuneración del equipo directivo, **no al accionista** que las paga. Es un problema de agencia, no de estrategia.
 3. **La hipótesis de la hubris** (Roll, 1986): los directivos sobreestiman su propia capacidad de extraer valor y por eso pagan de más. En una subasta, el que gana suele ser el que más se equivocó al alza — la *maldición del ganador*.

La evidencia es incómoda y bastante consistente: el accionista del *target* casi siempre gana (captura la prima); el **comprador** con frecuencia pierde. La síntesis que hoy predomina: el M&A crea valor **agregado**, pero se reparte de forma desigual y todo depende de la **disciplina de precio**. La implicación para ti es directa y define tu utilidad profesional: **el abogado aporta escepticismo informado, no entusiasmo por cerrar** (§28) — y tiene que hacerlo sabiendo que su propio incentivo suele estar del lado del cierre (Columna VI, módulo 01).

La pregunta de criterio que deja abierta este debate, y que deberías poder contestar en una entrevista: *si la mayoría de las adquisiciones destruye valor para el comprador, ¿por qué siguen ocurriendo?* Las tres hipótesis dan tres respuestas distintas, y las tres son parcialmente ciertas.

- **¿Disciplina o cortoplacismo?** El gran intercambio entre **Bebchuk y Lipton** sobre el activismo accionario: ¿las adqui-

siciones y los inversionistas activistas **disciplinan** a un *management* acomodado, o lo obligan a sacrificar inversión de largo plazo para sostener el precio de la acción? No hay consenso, y no es una discusión académica: es la conversación real que vas a tener con un consejo bajo presión. Un abogado que solo conoce un lado del argumento asesora mal.

- **Deberes del consejo: shareholder vs. stakeholder en una venta.** ¿Debe el consejo buscar solo el mejor precio para los accionistas (Revlon) o también atender a empleados/comunidad/ESG?
- **Defensas anti-OPA:** ¿protegen a los accionistas o atrincheran a los directivos? (Unocal, poison pills — Libro 6 Nivel IV).
- **R&W Insurance:** ¿mejora la asignación de riesgo (clean exits) o desincentiva la due diligence rigurosa del comprador?
- **Control de concentraciones:** ¿hasta dónde debe la autoridad bloquear/condicionar fusiones eficientes por proteger la competencia? (eficiencia vs. poder de mercado — Libro 9 Nivel I).

30. Errores comunes

- **Elegir mal la estructura** (share/asset/fusión) sin analizar pasivos, contratos, fiscal y regulatorio: arrastra problemas todo el *deal*.
- **Due diligence deficiente.** No detectar pasivos ocultos, contratos con *change of control* o problemas de titularidad lleva a pagar de más o heredar bombas (especialmente en *share deals*).
- **Reps & indemnización mal calibradas.** Cap demasiado bajo, survival corto o exclusiones amplias dejan al comprador sin protección; lo contrario impide el *clean exit* del vendedor.
- **Cerrar antes de las autorizaciones (*gun jumping*).** Consumar una concentración antes de la autorización de COFECE es **sancionable**.

- **Ignorar el *change of control*** en contratos clave: la contraparte puede terminarlos tras el *deal*.
- **Sobreestimar las sinergias** y descuidar la **integración** (post-closing): la causa #1 de fusiones que destruyen valor.
- **No documentar el proceso del consejo** (deberes fiduciaros): expone a los administradores (Revlon/Van Gorkom).

31. Mitos frecuentes

- "*M&A es solo redactar un contrato.*" **Falso:** es **dirigir un proceso** complejo por fases (estrategia, due diligence, negociación, autorizaciones, signing, closing, integración).
- "*El share deal siempre es mejor (o el asset deal).*" **Falso:** depende del caso (pasivos, contratos, fiscal, regulatorio).
- "*Con el SPA firmado, el deal está hecho.*" **Falso:** entre signing y closing hay que cumplir **condiciones** (autorizaciones); puede no cerrarse (MAC, falta de aprobación).
- "*Las reps & warranties son relleno.*" **Falso:** son el **mecanismo de reparto de riesgo**; deciden quién paga los pasivos ocultos.
- "*Toda fusión crea valor.*" **Falso:** muchas lo **destruyen** (sinergias sobreestimadas, mala integración).

32. Preguntas difíciles

1. ¿Cuándo conviene **share deal**, **asset deal** o **fusión**? ¿Cómo se decide cruzando pasivos, contratos, fiscal y regulatorio?
2. ¿Cómo se **reparte el riesgo** de lo desconocido entre comprador y vendedor, y qué palancas mueve cada uno (reps, cap, basket, survival, escrow, R&W insurance)?
3. ¿Qué deberes tiene el **consejo** del vendedor en una subasta (Revlon) y del comprador al aprobar la compra?
4. ¿Cómo se gestiona el **calendario** cuando hay autorizaciones de competencia que tardan meses (interim covenants, MAC, *gun jumping*)?
5. ¿Por qué tantas fusiones **destruyen valor** y qué puede hacer el abogado para mitigarlo (due diligence, asignación realista de riesgo)?

33. Casos de examen (con respuesta modelo)

P1. *¿Qué es M&A y cuáles son sus estructuras básicas?* **R.** El conjunto de operaciones que transfieren la **propiedad o el control** de una empresa: **share deal** (compra de acciones —se hereda la sociedad con sus pasivos—), **asset deal** (compra de activos seleccionados —se aíslan pasivos pero hay que ceder cada activo/contrato—) y **fusión** (combinación societaria).

P2. *Distinga share deal y asset deal.* **R.** En el **share deal** se compran las **acciones** (el comprador hereda **todos** los activos y pasivos, incluidos ocultos; más simple); en el **asset deal** se compran **activos/pasivos seleccionados** (se aíslan pasivos no deseados, pero hay que **transmitir cada activo y ceder cada contrato** con consentimientos, con efectos fiscales y laborales).

P3. *¿Cuáles son las fases de una operación de M&A?* **R.** Origenación → NDA → IM/ofertas → **LOI/ Term Sheet** → **due diligence** → negociación y redacción del SPA → **signing** → cumplimiento de condiciones (autorizaciones) → **closing** → **post-closing** (integración, ajustes, earn-out, indemnización).

P4. *¿Cómo se reparte el riesgo entre comprador y vendedor?* **R.** Con la **due diligence** (reduce asimetría), las **reps & warranties** (el vendedor garantiza hechos), las **disclosure schedules** (revelan excepciones), la **indemnización** (cap, basket, survival), el **escrow** y las **condiciones/MAC**; opcionalmente, **R&W Insurance**.

P5. *¿Por qué se separan signing y closing?* **R.** Porque suelen existir **condiciones** (autorizaciones de COFECE/CNBV/sectoriales, consentimientos, veracidad de reps al cierre); el cierre se difiere hasta cumplirlas. Si no hay condiciones, signing y closing son **simultáneos**.

34. Simulador (ejercicio tipo despacho)

Rol: asociado de M&A en un despacho de élite. **Ciente:** un **fondo de private equity** que quiere adquirir "Alimentos Selectos, S.A." (empresa familiar, líder regional, 1,200 empleados, una planta, marcas valiosas, contratos de distribución clave, y rumores de una **contingencia ambiental**). El fondo financiará parte con **deuda**. La familia vendedora quiere un *clean exit*.

Tarea: elabora una **nota estratégica del deal** que cubra: (1) **estructura** (¿share deal vía NewCo + fusión para el LBO?, ¿asset deal para aislar el pasivo ambiental?) y su justificación (pasivos, contratos, fiscal, regulatorio); (2) **plan de due diligence** (focos: ambiental, laboral, fiscal, contratos con *change of control*, titularidad de marcas); (3) **reparto de riesgo** en el SPA (reps & warranties, **indemnidad específica** por lo ambiental, cap/basket/survival, **escrow**, y posible **R&W Insurance** para el clean exit que pide la familia); (4) **financiamiento** y *security package* (Libros 3 y 4 Nivel II/III); (5) **autorizaciones** (¿COFECE?, sectoriales, inversión extranjera); (6) **calendario** (signing → condiciones → closing) y **deberes del consejo** del vendedor. Concluye con los **3 riesgos** principales y cómo mitigarlos.

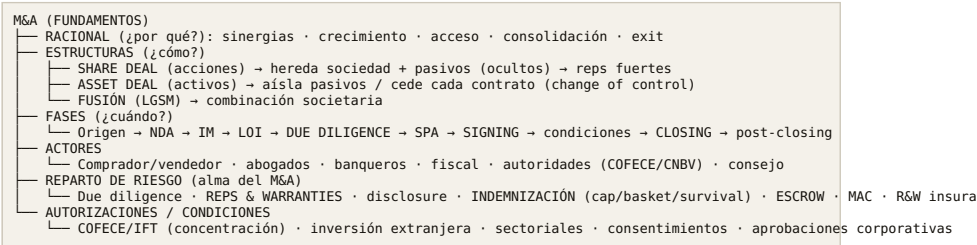
(Pista de evaluación: la mejor respuesta conecta cada pieza con su libro —estructura/LGSM, financiamiento/garantías, reps/responsabilidad, competencia/Libro 3 Nivel I—; resuelve la tensión entre el clean exit de la familia (R&W insurance) y la protección del fondo (indemnidad específica ambiental); y trata el M&A como un proceso dirigido, no como un contrato suelto.)

35. Flashcards

- **¿Qué es M&A?** → Comprar, vender o fusionar empresas (transferir propiedad/control).
- **¿Tres estructuras?** → Share deal (acciones), asset deal (activos), fusión.
- **¿Share deal: qué se hereda?** → La sociedad completa, con **todos** sus pasivos (incluidos ocultos).
- **¿Asset deal: ventaja/desventaja?** → Aísla pasivos / hay que ceder cada activo y contrato (consentimientos).
- **¿Comprador estratégico vs. financiero?** → Empresa (sinergias) vs. fondo PE/VC (desarrollar y vender).

- **¿LOI/Term Sheet vincula?** → Mayormente **no** (salvo confidencialidad, exclusividad, ley aplicable).
- **¿Signing vs. closing?** → Firma vs. cierre (pago + transferencia); se separan si hay condiciones.
- **¿Reps & warranties?** → Declaraciones del vendedor; su falsedad activa la **indemnización**.
- **¿Cap / basket / survival?** → Tope / umbral / plazo de la indemnización.
- **¿Escrow?** → Retención del precio para garantizar la indemnización.
- **¿MAC?** → Cláusula para no cerrar si hay cambio adverso relevante.
- **¿Gun jumping?** → Consumar una concentración antes de la autorización de COFECE (prohibido).

36. Mapas mentales



37. Cuadros comparativos

Share deal vs. asset deal vs. fusión

	SHARE DEAL	ASSET DEAL	FUSIÓN
Qué se transfiere	Acciones	Activos/pasivos selectos	Patrimonio universal
Pasivos ocultos	Se heredan	Se pueden aislar	Se asumen (combinación)
Contratos	Continúan (salvo change of control)	Hay que cederlos	Continúan (sucesión universal)
Complejidad	Baja (una transferencia)	Alta (activo por activo)	Media-alta (societaria)
Fiscal/laboral	Menos fricción	Más (IVA, sustitución patronal)	Régimen de fusión

Comprador estratégico vs. financiero

	ESTRATÉGICO	FINANCIERO (PE/VC)
Motivo	Sinergias, integración	Rendimiento (comprar-desarrollar-vender)
Horizonte	Permanente	Temporal (exit en años)
Financiamiento	Caja/acciones	Apalancamiento (LBO)

Signing vs. closing

	SIGNING	CLOSING
Qué ocurre	Se firma el SPA	Se paga y se transfiere
Condiciones	Aún pendientes	Cumplidas
Separación	Si hay autorizaciones	—

38. Diagramas

Línea de tiempo del deal:

ESTRATEGIA → NDA → IM/ofertas → LOI (no vinculante) → DUE DILIGENCE
 → negociación SPA → SIGNING → [condiciones: COFECE, consentimientos, no MAC] → CLOSING
 → POST-CLOSING (integración · ajuste de precio · earn-out · indemnización/claims)

Decisión de estructura:

¿Riesgo de pasivos ocultos alto? → asset deal (aislar) o share deal con reps+escrow
 ¿Contratos/permisos no transferibles o con change of control? → share deal (continúan)
 ¿Qué es más eficiente fiscalmente? → (con asesor fiscal)
 ¿Menos autorizaciones? → (regulatorio)
 → ESTRUCTURA ÓPTIMA = equilibrio de los cuatro ejes

39. Mnemotecnias

- **Estructuras:** *"compro la empresa entera (share), o sus pedazos (asset), o las junto (fusión)".*
- **Share deal:** *"compras la sociedad con TODO, lo bueno y lo oculto" → reps fuertes.*
- **Fases:** *"NDA-LOI-DD-SPA-Signing-Closing"* (de conocer a cerrar).
- **Riesgo:** *"due diligence investiga, reps reparten, escrow asegura".*
- **Signing ≠ Closing:** *"firmar no es cerrar; faltan los permisos".*
- **Gun jumping:** *"no cierres antes de COFECE".*
- **Valor:** *"las sinergias se prometen, la integración se sufre"* (cuidado con destruir valor).

40. Resumen ejecutivo

M&A (*Mergers & Acquisitions*) es el campo del derecho corporativo que estudia las operaciones por las cuales una empresa **cambia de dueño, se combina con otra o se reorganiza**. No es una rama autónoma del derecho: es un **punto de convergencia** donde se aplican, al mismo tiempo y bajo presión, el derecho de sociedades, de obligaciones y contratos, de competencia económica, fiscal, laboral y de mercado de valores. Su unidad la da una **lógica económica** —comprar el control de un negocio para crear valor (sinergias, crecimiento, acceso a mercados)— y una **lógica jurídica**: la **asignación racional del riesgo** entre comprador y vendedor.

El abogado de M&A trabaja sobre tres ejes. **Primero, la estructura**: decidir si la operación es un **share deal** (se compran las acciones y se adquiere la sociedad con todo su pasado, conocido u oculto), un **asset deal** (se compran activos seleccionados, aislando pasivos) o una **fusión** (combinación corporativa); la elección depende del equilibrio entre riesgo de pasivos, transferibilidad de contratos y permisos, eficiencia fiscal y autorizaciones necesarias. **Segundo, las fases**: de la estrategia al **NDA**, a la **LOI/term sheet** (mayormente no vinculante), a la **due diligence** (la investigación que revela qué se compra), a la negociación del **SPA**, al **signing** y, cumplidas las condiciones (COFEC, consentimientos, ausencia de un cambio adverso relevante o **MAC**), al **closing** y al **post-closing** (integración, ajustes de precio, *earn-outs*, reclamaciones). **Tercero, la asignación de riesgo**: la **due diligence** investiga, las **representations & warranties** distribuyen el riesgo de lo desconocido, las **indemnizaciones**, el **escrow** y los **MAC** lo aseguran y lo administran en el tiempo.

Para el lector, este libro **abre el Nivel IV** y, con él, el verdadero objetivo de toda la biblioteca. Todo lo aprendido converge aquí: las **sociedades** (lo que se compra), los **contratos** (el SPA es el contrato definitivo), el **gobierno corporativo** (los deberes del consejo al vender —Revlon— y al defenderse —Unocal—), el **mercado de valores** (OPAs), la **economía** (sinergias, valuación) y la **argumentación** (negociar y redactar

cláusulas). El M&A es el oficio donde el abogado corporativo de élite demuestra todo lo que sabe.

41. Checklist

Planeación y estructura de la operación:

- [] ¿Cuál es la **racionalidad económica** del deal (sinergias, crecimiento, exit)? ¿Es real o es una ilusión de sobreprecio?
- [] ¿**Share deal, asset deal o fusión**? ¿Se ponderaron los cuatro ejes (pasivos ocultos, transferibilidad de contratos/permisos, fiscal, autorizaciones)?
- [] ¿Quiénes son los **actores** (comprador, vendedor, target, asesores, financiadores, reguladores) y cuál es el rol del abogado?

Proceso y documentos:

- [] ¿Hay **NDA** firmado antes de revelar información sensible?
- [] ¿La **LOI/term sheet** distingue con claridad lo **vinculante** (exclusividad, confidencialidad, ley aplicable) de lo **no vinculante** (precio, estructura)?
- [] ¿Se planeó una **due diligence** proporcional al riesgo y al tamaño del deal?
- [] ¿El **SPA** contiene reps & warranties, covenants, condiciones, MAC, indemnización y mecanismos de precio (ajustes, *earn-out*, escrow) bien calibrados?

Cierre y riesgo:

- [] ¿Se identificaron las **condiciones al closing** (COFECE/competencia, consentimientos por *change of control*, autorizaciones sectoriales)? ¿Hay riesgo de **gun jumping**?
- [] ¿Cómo se asigna el riesgo del **período entre signing y closing** (covenants de operación ordinaria, MAC)?
- [] ¿Está prevista la **integración post-closing** (la fase donde se gana o se destruye el valor)?

42. Bibliografía comentada

- **Sebenius / Subramanian — negociación y deal-making (Harvard)**. Para entender el M&A como un proceso de **negociación y diseño de transacciones**, no solo de redacción de contratos.
- **American Bar Association, *Model Stock Purchase Agreement with Commentary***. Lectura **imprescindible** para quien quiera dominar el SPA: cláusula por cláusula, con comentario sobre por qué existe y cómo se negocia cada una.
- **Jurisprudencia de Delaware (Revlon, Unocal, Smith v. Van Gorkom, las MAC en *Akorn v. Fresenius*)**. El marco de los **deberes del consejo** en una venta y la interpretación de las cláusulas MAC; estudio obligado.
- **Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y guías de la COFECE**. El régimen mexicano de **concentraciones** (notificación, umbrales, gun jumping).
- **Doctrina mercantil mexicana (LGSM —fusión y escisión—; LMV —OPAs)**. El derecho positivo que da forma a las estructuras en México.
- **Manuales de M&A de despachos y *PLC/Practical Law***. Para los **estándares de mercado** de cada cláusula y los *precedents* que usa la práctica internacional.

43. Ruta hacia el siguiente libro

Ya tienes el **mapa completo del M&A**: por qué existe, cómo se estructura, sus fases, sus actores y su lógica de riesgo. Pero hay una fase de la que depende **todo** lo demás —el precio, las reps, las indemnizaciones, incluso la decisión de seguir o abandonar el deal—: la **investigación de lo que realmente se está comprando**.

- **Siguiente libro: *Libro 2 · Due Diligence*** — cómo se planea, organiza y ejecuta la **debida diligencia** (legal, fiscal, laboral, regulatoria, ambiental), cómo se construye y usa el **data room**, cómo se redacta el **DD report** y los *red flags*, y cómo los hallazgos se traducen en **cláusulas del SPA** (reps especí-

ficas, indemnizaciones especiales, ajustes de precio, condiciones al closing).

- **Conexión inmediata:** en este libro vimos que la **due diligence investiga y las reps reparten el riesgo**; el Libro 2 abre la caja negra de **cómo se investiga de verdad** y cómo cada hallazgo se convierte en protección contractual. Es la habilidad que distingue al abogado de M&A competente del excepcional.
-

◆ ¿Por qué esto importa para un abogado corporativo?

Porque el **M&A es la cumbre del derecho corporativo**: la operación donde se concentran el mayor valor, el mayor riesgo y la mayor visibilidad profesional. Cuando una empresa se compra, se vende o se fusiona, **todo el derecho privado se activa a la vez** —sociedades, contratos, competencia, fiscal, laboral, valores— y alguien tiene que orquestarlo bajo presión de tiempo y dinero: ese alguien es el abogado de M&A. Dominar esta materia significa entender no solo cláusulas, sino la **arquitectura completa de una transacción**: por qué se elige una estructura, cómo se asigna el riesgo de lo desconocido, qué puede hacer fracasar un cierre. Es el oficio mejor pagado y más estratégico de la profesión, y el rol desde el cual un abogado se convierte en **asesor de confianza** de empresarios, fondos y consejos. Quien domina el M&A domina el lenguaje en el que se toman las grandes decisiones empresariales.

◆ Cómo piensa un socio de un despacho internacional

"Cuando me llega un deal, antes de pensar en cláusulas pienso en riesgo y estructura. Primero: ¿qué está comprando realmente mi cliente —una sociedad con todo su pasado (share deal) o activos limpios (asset deal)? Esa sola decisión reordena la operación: en un share deal, la due diligence y las reps son mi muralla contra los pasivos ocultos; en un asset deal, negocio qué se queda fuera. Segundo, pienso en el calendario de riesgo: entre el signing y el closing pueden caerse las autorizaciones (COFECE), perderse contratos clave por change of control, o aparecer un cambio adverso relevante —por eso peleo la cláusula MAC palabra por palabra—. Tercero, asigno el riesgo de lo desconocido: la due diligence me dice lo que sé, las reps & warranties me cubren lo que no, y el escrow y las indemnizaciones me dan con qué cobrar si algo sale mal. Y nunca olvido que el deal no termina en el closing: el valor se gana o se pierde en la integración. Mi trabajo no es 'redactar el contrato'; es diseñar una transacción que proteja a mi cliente y se cierre."

◆ Errores que cuestan millones

1. **Confundir signing con closing y caer en *gun jumping*.** Empezar a operar la target o coordinar precios **antes** de la autorización de competencia es ilegal y se sanciona con multas enormes y hasta la nulidad. *Prevención:* respetar el calendario; nada de control antes del closing y de la COFECE.
2. **Due diligence superficial.** Lo que no se investiga, no se cubre con reps; un pasivo fiscal, laboral o ambiental oculto puede valer más que la empresa. *Prevención:* DD proporcional al riesgo y traducir cada *red flag* en una protección contractual (rep, indemnización especial, ajuste).
3. **Reps & warranties y MAC mal calibradas.** Reps demasiado generales o una MAC ambigua dejan al comprador sin defensa o atrapan al vendedor en una obligación infinita. *Prevención:* redactar con *materiality*, *knowledge qualifiers*, topes (*caps*) y plazos de supervivencia bien negociados.
4. **Ignorar los consentimientos por *change of control*.** Contratos clave, permisos o financiamientos que se cancelan al

cambiar el dueño pueden vaciar de valor a la target. *Prevención*: mapearlos en la DD y volverlos condición al closing.

5. **Pagar de más por sinergias imaginarias.** La mayoría de los deals que destruyen valor lo hacen por sobreprecio y por integración fallida, no por mala redacción. *Prevención*: disciplina en la valuación y un plan de integración **antes** de firmar.

Cierre del Libro 1 y apertura del Nivel IV. Has cruzado el umbral del verdadero objetivo: el **Corporate Law**. Ya tienes el mapa completo del **M&A** —por qué existe, sus estructuras (share, asset, fusión), sus fases (NDA, LOI, due diligence, SPA, signing, closing, post-closing), sus actores y, sobre todo, su **lógica de asignación de riesgo**—. Todo lo que aprendiste en los Niveles I a III converge aquí: sociedades, contratos, gobierno corporativo, valores y economía se vuelven las piezas de una sola partida. En el **Libro 2 · Due Diligence** abriremos la caja negra de la operación: cómo se investiga de verdad lo que se compra y cómo cada hallazgo se convierte en protección contractual. El abogado corporativo de élite ya no es una meta lejana: es el camino que estás recorriendo.

Libro 1 del Nivel IV. Voz consolidada (Edición Final): este capítulo ya no lleva apéndices al cierre. La doctrina (Manne, Bradley-Desai-Kim, Jensen, Roll), el análisis económico del contrato (Coase, Akerlof, Holmes), el derecho comparado (Delaware frente al Takeover Code británico), la traducción operativa de Van Gorkom y los casos Disney-Fox, Microsoft-Activision y Musk-Twitter viven ahora dentro del razonamiento, en las secciones 6, 18, 22, 24, 27 y 29. Ver el vacío C-1 de la Auditoría.

PARTE IV

[Nivel IV · Libro 2] Due Diligence (Debida Diligencia)

☞ **Apóstrofe de vigencia** — **léela cada vez**. El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: «*¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente*» (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como «**Derogado**». Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

Si el Libro 1 fue el **plano maestro** del M&A, este es el **arte de mirar antes de comprar**. La *due diligence* es la investigación sistemática mediante la cual el comprador descubre **qué está comprando realmente**: qué vale, qué riesgos esconde, qué contratos pueden caerse, qué pasivos ocultos pueden costar más que la empresa. Es la fase de la que depende **todo lo demás** —el precio, las *representations & warranties*, las indemnizaciones, las condiciones al *closing* y hasta la decisión de seguir o abandonar el deal—. Un abogado de M&A que no sabe hacer una *due diligence* rigurosa es como un cirujano que no sabe leer una radiografía.

Etiquetas: corporate law · M&A · due diligence · data room · red flags · gestión de riesgo · DD report **Prerrequisitos:** Libro 1 · Fundamentos de M&A + **todo el Nivel III** (especialmente Sociedades/LGSM, Contratos Mercantiles y Gobierno Corporativo) + Obligaciones y Responsabilidad Civil. **Estándar:** V3 (43 secciones + secciones transversales). ⌚ **Tiempo estimado de dominio:** 4–5 semanas (≈ 45–55 h de estudio activo). Lectura de reconocimiento: 8–10 h. *Estúdialo en bloques: qué es y por qué → tipos y áreas de la DD → proceso y data room → red flags y materialidad → del hallazgo a la cláusula (DD report → SPA).*

Aviso de método. Tratado, no repaso. Aquí aprenderás a **investigar como un abogado de transacciones**: no a "leer documentos", sino a **buscar el riesgo**, valorarlo y traducirlo en protección contractual. Cada sección conecta la due diligence con el SPA y con la asignación de riesgo que viste en el Libro 1.

NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL (VISTA RÁPIDA)

Litigio	★★★☆☆
Corporate	★★★★★
M&A	★★★★★
Mercado de Valores	★★★★☆
Venture Capital	★★★★★
Private Equity	★★★★★
Gobierno Corporativo	★★★★☆
Compliance	★★★★★
Derecho Bancario	★★★★☆
Empresa Familiar	★★★★☆

Es la habilidad operativa más demandada al abogado junior y de rango medio en M&A: el deal se gana o se pierde en la calidad de la due diligence. Dominarla temprano acelera la carrera más que casi cualquier otra cosa.

1. Introducción

Due diligence (literalmente, "diligencia debida") es la **investigación previa y sistemática** que realiza el comprador —con sus asesores legales, fiscales, financieros y técnicos— sobre la empresa que pretende adquirir (la *target*), antes de comprometerse de forma definitiva. Su propósito es responder, con evidencia, tres preguntas que el Libro 1 dejó planteadas: **¿qué estoy comprando realmente?**, **¿cuánto vale de verdad?** y **¿qué riesgos estoy asumiendo?**

La expresión viene del derecho anglosajón, donde "diligencia debida" es el **estándar de conducta** que se espera de una persona razonable y prudente antes de tomar una decisión de inversión. En el contexto del M&A, la due diligence es la **fase de investigación** que se sitúa entre la **LOI/term sheet** (el acuerdo preliminar) y el **SPA** (el contrato definitivo). Es el momento en que el comprador, que hasta entonces solo conocía la empresa "por fuera" (el *Information Memorandum*, lo que el vendedor quiso mostrar), abre la caja negra y exami-

na sus entrañas: sus contratos, sus litigios, sus pasivos fiscales y laborales, sus permisos, su propiedad intelectual, sus estados financieros.

La idea central de este libro: la due diligence **no es un trámite ni una formalidad**; es el **corazón analítico** de toda operación de M&A y la principal **herramienta de gestión de riesgo** del comprador. Todo lo que se descubre (o se deja de descubrir) tiene una consecuencia directa: baja el precio, exige una *representation* específica, obliga a una indemnización especial, se vuelve una condición al *closing*, o —en el peor caso— hace que el comprador se retire (*walk away*). Lo que **no se investiga**, normalmente **no se cubre**; y lo que no se cubre, lo paga el comprador. Por eso decimos que en M&A "la due diligence investiga y las reps reparten": esa frase, que enunciamos en el Libro 1, es la columna vertebral de este libro.

2. Objetivos del libro

Al terminar, el lector será capaz de:

- **Explicar** qué es la due diligence, por qué existe y qué función cumple dentro del proceso de M&A, conectándola con la lógica de asignación de riesgo del Libro 1.
- **Distincuir** los **tipos** de due diligence (legal, fiscal, financiera/contable, laboral, regulatoria, ambiental, técnica, de PI, de compliance) y saber **qué busca cada una**.
- **Diseñar** un **plan de due diligence** proporcional al tamaño y al riesgo del deal: alcance, equipo, calendario, *checklist* de solicitud de información.
- **Operar** un **data room** (físico o virtual), entender la dinámica de las **Q&A** y proteger la confidencialidad y el privilegio.
- **Identificar y jerarquizar** **red flags** (banderas rojas) aplicando el concepto de **materialidad**: distinguir lo que mata el deal, lo que baja el precio y lo que solo se documenta.
- **Redactar** un **DD report** útil: ejecutivo, claro, orientado a decisiones, con hallazgos, valoración del riesgo y recomendaciones.

- **Traducir** cada hallazgo en una **protección contractual** concreta en el SPA: *representation* específica, indemnización especial, ajuste de precio, *escrow*, condición al *closing* o exclusión del perímetro.
- **Pensar como un abogado de transacciones:** buscar el riesgo, no solo describir documentos.

3. Importancia profesional

Para el abogado corporativo, la due diligence es —junto con la redacción del SPA— la **competencia operativa central** del M&A, y la que **más temprano** se le exige. El abogado junior de un despacho de M&A pasa buena parte de sus primeros años **dentro de la due diligence:** revisando contratos en el data room, levantando *red flags*, redactando secciones del DD report. Hacerlo con rigor, criterio y velocidad es lo que distingue al asociado que asciende del que se estanca.

¿Por qué es tan importante? Porque la due diligence es el punto donde el abogado **agrega más valor medible:** cada riesgo que detecta y traduce en una protección contractual es dinero que le ahorra al cliente; cada riesgo que se le escapa es una pérdida potencial que el cliente sufrirá después del *closing*, cuando ya no haya remedio fácil. Un solo pasivo fiscal o ambiental no detectado puede valer más que toda la operación. Por eso los clientes —fondos de *private equity*, corporativos, family offices— evalúan a sus abogados, en gran medida, por la **calidad de su due diligence**.

Además, la due diligence es **transversal a todas las prácticas:** la misma habilidad se usa en una adquisición (comprador), en una venta (la *vendor due diligence* que prepara el vendedor), en un financiamiento (el banco hace su propia DD), en una inversión de *venture capital* o *private equity*, en una salida a bolsa (*IPO*) y en compliance (la DD de terceros y anticorrupción). Quien domina la due diligence tiene una herramienta que usará en **toda su carrera**, sea cual sea la operación.

4. Historia y origen

La due diligence, como práctica formalizada, nace en el **derecho del mercado de valores de Estados Unidos**, en particular con la **Securities Act de 1933**, promulgada tras el *crash* de 1929. Esa ley estableció que quienes participan en la colocación de valores (los *underwriters*, los bancos colocadores) podían **defenderse** de la responsabilidad por información falsa o incompleta en un prospecto si demostraban haber realizado una **investigación razonable** —una "diligencia debida"— sobre la empresa emisora. De ahí el nombre: la *due diligence defense*. La diligencia debida era, en origen, un **escudo de responsabilidad**: si investigaste con el cuidado de una persona prudente, no respondes aunque después aparezca un problema que no podías razonablemente conocer.

De ese contexto bursátil, la práctica migró al **mundo de las fusiones y adquisiciones** durante la segunda mitad del siglo XX, a medida que las operaciones se volvían más grandes, complejas y apalancadas (especialmente con el auge de los *leveraged buyouts* en los años 1980). Los compradores —y, sobre todo, los bancos que financiaban las compras— necesitaban un método riguroso para entender qué estaban comprando o financiando. Los grandes despachos de Wall Street y de la City de Londres desarrollaron metodologías, *checklists* y equipos especializados, y la due diligence se convirtió en una **fase estándar e ineludible** de cualquier transacción seria.

En **México**, la práctica se profesionalizó a partir de los años 1990 con la apertura económica, la llegada de la inversión extranjera, las grandes privatizaciones y la entrada de despachos internacionales y de los estándares de los fondos globales. Hoy, ninguna operación relevante de M&A en México se cierra sin una due diligence, y los despachos mexicanos de élite la ejecutan con estándares plenamente internacionales.

5. Evolución histórica

La due diligence ha evolucionado en tres grandes etapas que conviene tener presentes:

1) De escudo de responsabilidad a herramienta de inversión. En su origen (años 1930-1960), la due diligence era sobre todo una **defensa legal** en el contexto bursátil. Con el auge del M&A moderno, se transformó en una **herramienta de decisión y de negociación**: ya no se investiga solo para "cubrirse", sino para **valuar, negociar el precio y asignar el riesgo**.

2) Del cuarto de documentos físico al data room virtual. Durante décadas, la due diligence se hacía en un **cuarto físico** (el *data room*), normalmente en las oficinas del vendedor o de sus abogados, donde se apilaban cajas de documentos y los abogados del comprador acudían a revisarlos bajo vigilancia, sin poder fotocopiar lo sensible. La revolución digital (años 2000 en adelante) trajo los **Virtual Data Rooms (VDR)**: plataformas seguras en línea donde se cargan miles de documentos, con control de accesos, marcas de agua, registro de quién vio qué y módulos de **Q&A**. Esto aceleró y globalizó la práctica: hoy un equipo en Nueva York, Londres y Ciudad de México revisa el mismo data room simultáneamente.

3) De la revisión exhaustiva a la due diligence inteligente y asistida por tecnología. El volumen de información creció tanto que revisar "todo" se volvió imposible y antieconómico. La práctica moderna se orienta al **riesgo y a la materialidad**: se define un **umbral** (no se revisan contratos por debajo de cierto monto), se prioriza lo crítico y se usa **tecnología** —herramientas de revisión de contratos asistida por *machine learning*, que detectan cláusulas de *change of control*, de no competencia, de exclusividad, etc.—. El abogado moderno no compite con la máquina en velocidad de lectura; compite en **criterio**: saber qué buscar, qué significa lo que encuentra y cómo traducirlo en protección.

6. Contexto económico

Económicamente, la due diligence es un mecanismo para reducir la **asimetría de información**, el problema que el premio Nobel George Akerlof describió en su célebre análisis del "mercado de los limones" (*The Market for Lemons*, 1970): el vendedor **siempre sabe más** sobre la empresa que el comprador. Esa asimetría, si no se corrige, lleva a dos males: o el com-

prador paga de más (porque no ve los defectos) o se retrae de comprar (porque desconfía y descuenta en exceso). La due diligence es la inversión que el comprador hace para **igualar el terreno informativo** y poder valorar con realismo.

Vista así, la DD no es una revisión: es una tecnología de reducción de asimetría. Y no trabaja sola: forma un sistema con las *representations & warranties* y el *disclosure*, cuya función conjunta es **convertir información privada en información oponible** —es decir, en algo que genera consecuencias si resulta falso—. Ese es el mecanismo económico exacto por el que una operación puede cerrarse a un precio justo cuando las dos partes saben cosas distintas.

De ahí se deriva la regla operativa más útil de este libro, y conviene fijarla desde el principio: **todo hallazgo de la DD tiene tres destinos posibles y solo tres.**

NATURALEZA DEL RIESGO	SU DESTINO CONTRACTUAL
Cuantificable (sé cuánto vale)	Ajuste de precio
Contingente (puede o no ocurrir)	Indemnización específica y su respaldo (<i>escrow</i> , retención)
Inaceptable (no lo asumo)	Condición de cierre o derecho de retirada (<i>walk-right</i>)

Un hallazgo que no llega a ninguno de los tres es papel muerto: costó honorarios y no protege a nadie. Es la prueba a la que hay que someter cada renglón del reporte, y la razón por la que este libro insiste en que la DD se juzga por lo que **se traduce**, no por lo que se revisa (§28).

Y el mercado añadió una cuarta salida que no existía hace veinte años: el **seguro de manifestaciones y garantías** (*R&W insurance*), que traslada el riesgo a una aseguradora especializada. Es un ejemplo notable de cómo el mercado aprende a **precificar incertidumbre jurídica**: hoy es estándar en operaciones grandes en Estados Unidos y Europa y cada vez más frecuente en México [△], y su efecto práctico es permitir **salidas limpias** al vendedor —lo que desatora negociaciones que parecían muertas, como se ve en el ejercicio 12 del Laboratorio

—.

Tiene, además, una clara **lógica de costo-beneficio**. La due diligence cuesta dinero (honorarios de abogados, contadores, asesores; tiempo de los ejecutivos) y, sobre todo, **tiempo** —que en un deal es un recurso crítico—. Por eso su alcance debe ser **proporcional**: en una compra de cientos de millones se justifica una DD exhaustiva; en una adquisición pequeña, una DD focalizada en los riesgos clave. La pregunta económica siempre es: *¿el costo de investigar este riesgo adicional es menor que la pérdida esperada (probabilidad × impacto) si no lo investigo?* Ese cálculo —no la exhaustividad ciega— es lo que guía a un buen abogado de M&A.

Finalmente, la due diligence influye directamente en el **precio y en la estructura**. Los hallazgos se traducen en **descuentos** (el comprador baja su oferta), en **ajustes** (mecanismos de precio como el *locked box* o el *completion accounts*), en **retenciones** (*escrow*, *holdback*) y en la propia **elección de estructura** (un riesgo de pasivos ocultos alto empuja hacia un *asset deal* o hacia reps e indemnizaciones reforzadas, como vimos en el Libro 1).

7. Contexto político y regulatorio

La due diligence no ocurre en el vacío: opera dentro de un marco regulatorio que, en ciertas áreas, **la vuelve obligatoria o de altísimo riesgo omitirla**. Tres ejemplos centrales:

- **Competencia económica (COFECCE)**. Antes del *closing*, muchas operaciones requieren autorización de concentración. La DD debe evaluar si la operación es notificable y qué riesgo de competencia tiene (recuerda el *gun jumping* del Libro 1: no integrar antes de la autorización).
- **Anticorrupción y compliance (FCPA, UK Bribery Act, Ley General de Responsabilidades Administrativas)**. Si la *target* incurrió en corrupción, el comprador puede **heredar la responsabilidad** (sucesión de responsabilidad). Las autoridades de EE.UU. han sido explícitas: una due diligence anticorrupción rigurosa es esperada, y su ausencia agrava la sanción. Esta es una de las áreas donde "no investigar" es jurídicamente peligrosísimo.

- **Sectores regulados.** En banca, seguros, telecomunicaciones, energía, salud, etc., el cambio de control puede requerir autorización del regulador sectorial, y la DD debe mapear permisos, concesiones y licencias y verificar su **transferibilidad** y su vigencia.

A esto se suman las tendencias regulatorias recientes: el **escrutinio de inversión extranjera** en sectores estratégicos (presente en muchas jurisdicciones), la regulación de **protección de datos** (que vuelve la DD de privacidad cada vez más relevante) y los crecientes requerimientos **ESG**, que han dado lugar a una *due diligence* de sostenibilidad y derechos humanos en las cadenas de suministro.

8. Contexto social

Aunque la due diligence parezca un asunto puramente técnico-financiero, tiene una dimensión social y humana que el buen abogado no ignora. **Primero**, la DD toca a las **personas** de la empresa: la revisión laboral examina contratos, sindicatos, pasivos por despidos, planes de pensiones; los hallazgos pueden anticipar reestructuras y despidos *post-closing*, con impacto real en trabajadores y comunidades. Manejar esa información con sensibilidad y confidencialidad es parte del oficio.

Segundo, la due diligence se desarrolla en un clima de **tensión y desconfianza estructural**: el vendedor quiere mostrar lo mejor y minimizar lo malo; el comprador busca defectos. El abogado opera en esa tensión y debe equilibrar **rigor** (encontrar todo lo relevante) con **eficiencia diplomática** (no incendiar la relación con peticiones desmesuradas que descarrilen el deal). La habilidad social —saber qué preguntar, cómo y a quién— es tan importante como la técnica.

Tercero, en operaciones con dimensión social fuerte (empresas familiares, negocios con arraigo local, ESG), la DD revela información sensible sobre prácticas ambientales, condiciones laborales o relaciones con comunidades. El abogado moderno entiende que estos hallazgos no son solo "riesgos

legales", sino también **riesgos reputacionales** que pueden afectar el valor y la viabilidad del negocio adquirido.

9. Contexto empresarial

Desde la perspectiva de la empresa y del inversionista, la due diligence cumple funciones que van más allá de lo jurídico. Para el **comprador estratégico** (una empresa que adquiere a otra de su sector), la DD no solo busca riesgos: también **verifica las sinergias** que justifican el precio (¿son reales los ahorros de costos, las ventas cruzadas, el acceso a mercados?) y sirve para **planear la integración** post-closing (conocer los sistemas, los contratos, la plantilla). Para el **comprador financiero** (un fondo de *private equity*), la DD valida la **tesis de inversión**: la calidad de los flujos (la *Quality of Earnings*), la capacidad de la empresa para soportar el apalancamiento del LBO y las palancas de creación de valor para el exit.

La due diligence también moldea la **gobernanza del deal**: sus hallazgos suben a los comités de inversión y a los consejos, que deciden si aprobar, a qué precio y con qué condiciones. Un buen DD report es, en la práctica, **el documento sobre el que se toma la decisión de invertir millones**. De ahí que su redacción —ejecutiva, clara, jerarquizada por riesgo— sea una habilidad de primer orden.

Conviene también distinguir la **buy-side due diligence** (la que hace el comprador, el caso típico) de la **vendor due diligence o VDD** (la que el vendedor encarga sobre su propia empresa antes de venderla, para anticipar problemas, ordenar la casa y agilizar el proceso, entregando un reporte a los posibles compradores). La VDD es cada vez más común en procesos competitivos (subastas) porque acelera el deal y fortalece la posición negociadora del vendedor. Ambas usan la misma técnica; cambian el cliente y el objetivo.

10. Definiciones doctrinales

La doctrina especializada en M&A define la due diligence con matices que vale la pena conocer porque revelan distintas facetas de la institución:

- **Como proceso de investigación:** la due diligence es *"el proceso de investigación y análisis que un comprador potencial realiza sobre una empresa objetivo para evaluar sus activos, pasivos, riesgos y oportunidades antes de consumir una adquisición"*. Esta definición subraya su carácter **procesal y analítico**.
- **Como gestión de riesgo:** otros autores la definen como *"el ejercicio sistemático de identificación, valoración y asignación de los riesgos asociados a una transacción"*. Aquí el énfasis está en su función de **risk management**: no basta encontrar el riesgo, hay que valorarlo y decidir quién lo soporta.
- **Como estándar de conducta (origen anglosajón):** en su acepción original, *"diligencia debida"* es el **grado de cuidado** que una persona razonable y prudente emplearía en sus propios asuntos antes de tomar una decisión de inversión. Esta es la raíz del concepto: un **estándar de comportamiento diligente** cuya satisfacción genera consecuencias jurídicas (la *due diligence defense*).
- **Como puente entre la información y el contrato:** la doctrina transaccional moderna la describe como *"el mecanismo que traduce la realidad de la empresa en cláusulas del contrato de compraventa"*. Esta es, quizá, la definición más útil para el abogado: la DD es el **puente** entre lo que la empresa **es** y lo que el SPA **dice**.

Ninguna definición es completa por sí sola. La due diligence es, a la vez, **proceso** (cómo se hace), **función** (para qué sirve: gestionar riesgo) y **estándar** (con qué grado de cuidado). El abogado maduro las integra: investiga con rigor (proceso), para asignar el riesgo (función), con el cuidado de un profesional prudente (estándar).

11. Definiciones legales y marco normativo

A diferencia de otras instituciones de este programa, la *due diligence* **no está regulada por una ley específica que la defina y la imponga en términos generales** en el M&A privado mexicano. Es, fundamentalmente, una **práctica contractual y profesional** —un *uso* del comercio internacional adoptado en México—. Sin embargo, el ordenamiento jurídico la rodea y la conecta por varias vías:

- **Securities Act de 1933 (EE.UU.), §11 y §12:** la fuente histórica. Establece la *due diligence defense* para los participantes en una colocación de valores: la investigación razonable como eximente de responsabilidad por información defectuosa en el prospecto. Es derecho extranjero, pero su lógica permea toda la práctica global.
- **Deberes fiduciarios del administrador (deber de diligencia):** en México, la LGSM y la Ley del Mercado de Valores imponen a los administradores el deber de obrar con la **diligencia de un administrador prudente** y de manera **informada**. Un consejo que aprueba una adquisición relevante **sin** una *due diligence* adecuada puede estar incumpliendo su deber de diligencia (recuerda *Smith v. Van Gorkom* del libro de Gobierno Corporativo: decidir sin informarse rompe la *business judgment rule*). Aquí la DD deja de ser opcional: es parte del **proceso informado** que exige el deber fiduciario.
- **Régimen de competencia económica (LFCE):** impone la obligación de **notificar** concentraciones que superen ciertos umbrales y de no consumarlas antes de la autorización; la DD evalúa esta exposición.
- **Régimen anticorrupción y de prevención de lavado:** la FCPA, la UK Bribery Act y la Ley General de Responsabilidades Administrativas generan, en la práctica, una **exigencia de DD de compliance**: el comprador puede heredar responsabilidad, y la ausencia de investigación agrava la posición.

- **Obligaciones de información y buena fe (Código Civil/ Código de Comercio):** los deberes precontractuales de información y de buena fe en la negociación (que estudiaste en Obligaciones y Contratos) son el telón de fondo civil que da sustento al intercambio de información durante la DD y a la responsabilidad por dolo o reticencia del vendedor.

En síntesis: la due diligence no nace de un artículo que ordene "harás due diligence", sino de la **convergencia** del deber fiduciario de diligencia, del régimen de responsabilidad, de la buena fe contractual y de la práctica profesional internacional. Es derecho **vivo y consuetudinario** antes que codificado.

12. Definición sencilla

Imagina que vas a comprar una **casa usada**. Antes de firmar y pagar, harías —si eres prudente— varias cosas: contratarías a un **arquitecto** para que revise si hay grietas, humedad o problemas estructurales; pedirías al Registro Público que confirme que el vendedor es el **dueño real** y que la casa no tiene **hipotecas, embargos o deudas**; revisarías que no haya **adeudos** de predial, agua o mantenimiento; verificarías que los **permisos** de construcción estén en regla; y comprobarías que no haya un **inquilino** con derecho a quedarse. Toda esa investigación —mirar **antes** de comprar, para saber qué estás comprando y qué problemas escondidos puede tener— es la **due diligence**.

La due diligence en M&A es exactamente eso, pero sobre una **empresa** en lugar de una casa, y mil veces más compleja: en vez de revisar grietas y la escritura, revisas **contratos, litigios, impuestos, permisos, deudas laborales, propiedad intelectual y estados financieros**. La pregunta es la misma: *¿qué estoy comprando de verdad, cuánto vale y qué problemas trae escondidos?* Y la lógica también: lo que descubres te sirve para **bajar el precio, pedir garantías al vendedor, o retirarte si la casa está podrida por dentro**.

13. Conceptos fundamentales

Antes de entrar al desarrollo, fija estos **conceptos clave** que se usarán en todo el libro. Aprende cada término con su definición rigurosa; son el vocabulario del oficio.

- **Target (empresa objetivo):** la empresa que se pretende adquirir, sobre la cual recae la investigación.
- **Buy-side / Sell-side:** el lado del comprador / el lado del vendedor. La DD típica es *buy-side*; la *vendor due diligence* (VDD) es *sell-side*.
- **Data room (cuarto de datos):** el repositorio —hoy casi siempre virtual (VDR)— donde el vendedor pone a disposición del comprador la información y los documentos de la *target* para su revisión.
- **Due diligence request list (DDRL) / checklist:** la **lista de solicitud de información:** el documento donde el comprador pide, ordenadamente y por áreas, todos los documentos que necesita revisar.
- **Q&A (preguntas y respuestas):** el proceso, gestionado dentro del data room, mediante el cual el comprador formula preguntas sobre la información y el vendedor responde. Genera un **rastro documental** importante.
- **Red flag (bandera roja):** un hallazgo que representa un **riesgo relevante**. Se distinguen por gravedad: las que pueden **matar el deal** (*deal breakers*), las que **bajan el precio** o exigen protección, y las que solo se **documentan**.
- **Materialidad (materiality):** el **umbral de relevancia** a partir del cual un hallazgo importa. Es un concepto central: se fija un monto o un criterio (p. ej., "solo revisamos contratos de más de X" o "solo reportamos contingencias superiores a Y") para concentrar el esfuerzo en lo que de verdad mueve la aguja.
- **DD report (reporte de due diligence):** el documento donde el equipo plasma los **hallazgos**, su **valoración** y sus **recomendaciones**. Puede ser *full report* (exhaustivo) o *red flag*

report (solo los riesgos relevantes, el más usado en la práctica moderna).

- **Disclosure schedules (anexos de revelación):** los anexos del SPA donde el vendedor **revela excepciones** a sus *representations*. Son la otra cara de la DD: lo que el vendedor revela aquí, normalmente **deja de estar cubierto** por la garantía. La DD y los *disclosure schedules* dialogan constantemente.
- **Representations & warranties (declaraciones y garantías):** las afirmaciones que el vendedor hace sobre la *target* en el SPA (p. ej., "no hay litigios distintos de los revelados"). Son el principal vehículo para **asignar al vendedor** el riesgo de lo que la DD no pudo verificar del todo.
- **Indemnification (indemnización):** el mecanismo por el cual el vendedor se obliga a **compensar** al comprador si una *representation* resulta falsa o si se materializa un riesgo identificado. Suele venir con **topes (caps)**, **mínimos (baskets/de minimis)** y **plazos de supervivencia**.
- **Escrow / holdback:** la **retención** de una parte del precio (en una cuenta de garantía o por el propio comprador) para responder por eventuales indemnizaciones. Es la DD convertida en **garantía de cobro**.
- **Condition precedent (condición al closing):** un requisito que debe cumplirse **antes** del cierre (p. ej., obtener una autorización o subsanar un hallazgo de la DD).
- **Walk-away right (derecho a retirarse):** la facultad del comprador de **abandonar** la operación si la DD revela algo inaceptable o si no se cumplen las condiciones.
- **Quality of Earnings (QoE):** el análisis financiero que evalúa la **calidad y sostenibilidad** de las utilidades de la *target* (cuánto del resultado es recurrente y real). Es central en la DD financiera, sobre todo para fondos.

Con este vocabulario fijado, ya podemos entrar al **desarrollo absoluto** de la materia.

14. Desarrollo absoluto

Esta es la sección central del libro. La desarrollamos en cinco bloques: **(A)** las áreas o tipos de due diligence —qué se investiga y qué busca cada especialista—; **(B)** el proceso y sus fases —cómo se ejecuta de principio a fin—; **(C)** el data room y la dinámica de Q&A —dónde y cómo se revisa—; **(D)** los *red flags* y la materialidad —cómo se jerarquiza el riesgo—; y **(E)** del hallazgo a la cláusula —cómo cada riesgo se traduce en protección contractual—. Estúdialos en ese orden: primero qué se busca, luego cómo, después cómo se valora y, por último, qué se hace con lo encontrado.

14.A · LAS ÁREAS DE LA DUE DILIGENCE (QUÉ SE INVESTIGA Y QUÉ BUSCA CADA UNA)

La due diligence es **multidisciplinaria**: distintos especialistas revisan distintas dimensiones de la *target*, coordinados por el abogado de M&A (que suele actuar como director de orquesta del *workstream* legal y como punto de integración de los hallazgos). Estas son las áreas principales. Aprende, de cada una, **qué busca y cuáles son sus *red flags* típicos**.

1) Due diligence corporativa/societaria. Es la base. Verifica que la *target* **existe legalmente y es lo que dice ser**: acta constitutiva y estatutos vigentes; que las **acciones existen y están válidamente emitidas y pagadas**; el **libro de registro de accionistas** (¿quién es realmente dueño de qué?); las actas de asambleas y de consejo; los poderes vigentes; y, crucialmente, la **cadena de titularidad** (¿el vendedor es de verdad el dueño de las acciones que vende?). *Red flags típicos*: acciones mal emitidas, capital no pagado, conflictos entre socios, opciones o convertibles olvidados que diluyen, poderes revocados, falta de quórum en decisiones clave. **Sin propiedad clara de las acciones, no hay nada que comprar**: esta área es condición de todo lo demás.

2) Due diligence contractual. Revisa los **contratos materiales** de la empresa: con clientes, proveedores, distribuidores, arrendamientos, financiamientos, licencias. Busca tres cosas sobre todo: **(i)** cláusulas de **change of control** (que permiten a

la contraparte terminar o renegociar el contrato si la *target* cambia de dueño —el riesgo de que el activo se evapore justo al comprar—; (ii) cláusulas de **exclusividad, no competencia o *most favored nation*** que limiten el negocio; y (iii) **obligaciones onerosas, penas, garantías o plazos** problemáticos. *Red flags típicos*: contratos clave con *change of control*, dependencia de un solo cliente o proveedor, contratos vencidos o sin firmar, penalizaciones desproporcionadas.

3) Due diligence fiscal. Examina la **situación tributaria**: declaraciones, pago de impuestos, créditos fiscales, devoluciones, regímenes especiales, precios de transferencia (operaciones intragrupo), y **contingencias fiscales** (impuestos que la autoridad podría reclamar). Es de las áreas más delicadas porque los pasivos fiscales **pueden ser enormes y ocultos**, y porque la estructura de la operación (share vs. asset) tiene fuertes consecuencias fiscales. *Red flags típicos*: esquemas agresivos de elusión, deducciones cuestionables, precios de transferencia sin soporte, créditos fiscales inexistentes, omisiones que prescriben pronto, contingencias por operaciones simuladas (en México, el temido riesgo de **EFOS/EDOS** —empresas que facturan operaciones simuladas—).

4) Due diligence financiera y contable (incluye Quality of Earnings). Verifica que los **estados financieros reflejen la realidad** y analiza la **calidad de las utilidades** (QoE): cuánto del resultado es **recurrente y sostenible** frente a lo que es extraordinario o "maquillado". Revisa deuda (incluida la **deuda oculta** y los pasivos contingentes), capital de trabajo, la caja real, y la base sobre la que se calculará el precio. *Red flags típicos*: ingresos inflados o reconocidos antes de tiempo, gastos capitalizados indebidamente, deuda no revelada, dependencia de ingresos no recurrentes, capital de trabajo deteriorado.

5) Due diligence laboral y de seguridad social. Revisa la **relación con los trabajadores**: contratos, plantilla, sindicatos y contrato colectivo, prestaciones, planes de pensiones, pasivos por despidos, juicios laborales, y el cumplimiento de cuotas de seguridad social (IMSS, INFONAVIT) y de la normativa sobre **subcontratación** (en México, la reforma que prohibió la

subcontratación de personal, con fuertes contingencias para quien la usó mal). *Red flags típicos*: juicios laborales numerosos, pasivos por pensiones subvaluados, esquemas de *outsourcing* ilegales, sindicato hostil, pasivos por prima de antigüedad.

6) Due diligence regulatoria y de permisos. Verifica que la *target* tiene **todos los permisos, licencias, concesiones y autorizaciones** que su actividad requiere, que están **vigentes** y que son **transferibles** (o que sobreviven al cambio de control). En sectores regulados (banca, energía, telecom, salud), evalúa si la operación requiere **autorización del regulador**. *Red flags típicos*: operar sin permiso, permisos a punto de vencer o no transferibles, incumplimientos sancionables, concesiones con cláusulas de reversión.

7) Due diligence de competencia económica (antitrust). Evalúa si la operación es **notificable** a la COFECE (o a autoridades extranjeras si hay efectos transfronterizos), el **riesgo de que se objete** (por crear poder de mercado) y el calendario que ello impone. Conecta directamente con el *gun jumping* del Libro 1. *Red flags típicos*: alta concentración resultante, riesgo de condiciones o de bloqueo, operaciones previas no notificadas.

8) Due diligence ambiental. Especialmente relevante en industria, energía, minería, inmobiliario y manufactura. Revisa permisos ambientales, cumplimiento de la normativa, **pasivos por contaminación** (que pueden ser enormes y de largo plazo), estudios de impacto, y responsabilidad por sitios contaminados. *Red flags típicos*: suelos o aguas contaminados, falta de autorización de impacto ambiental, sanciones de la autoridad ambiental, pasivos de remediación.

9) Due diligence de propiedad intelectual (PI) y tecnología. Verifica la **titularidad y vigencia** de marcas, patentes, derechos de autor y nombres de dominio; que la PI **clave del negocio sea propiedad de la target** (y no de un fundador a título personal, error frecuente en *startups*); las licencias (especialmente de software, incluido el riesgo del *open source*); y litigios de infracción. *Red flags típicos*: PI registrada a nombre

equivocado, marcas no renovadas, licencias de software sin pagar, software propio que infringe *open source*, dependencia de PI de terceros.

10) Due diligence de tecnología, datos y ciberseguridad. Cada vez más central. Revisa los sistemas, la dependencia tecnológica, el cumplimiento de **protección de datos personales** (consentimientos, avisos de privacidad, transferencias), y el historial de **incidentes de ciberseguridad** (brechas de datos que generan pasivos y daño reputacional). *Red flags típicos:* brechas de datos no reportadas, incumplimiento de la normativa de privacidad, sistemas obsoletos, dependencia de un proveedor crítico.

11) Due diligence de compliance y anticorrupción. Revisa el **programa de cumplimiento** de la *target*, su exposición a **corrupción** (especialmente si hace negocios con el gobierno o en jurisdicciones de riesgo), prevención de lavado de dinero, sanciones internacionales, y conflictos de interés. Como vimos, aquí "no investigar" es peligrosísimo: el comprador puede **heredar la responsabilidad** por actos de corrupción de la *target*. *Red flags típicos:* pagos sospechosos a funcionarios o intermediarios, ausencia de programa de compliance, operaciones en países sancionados, banderas de lavado.

12) Due diligence de litigios y contingencias. Mapea **todos los juicios y procedimientos** en los que la *target* es parte (civiles, mercantiles, laborales, fiscales, administrativos, penales) y estima su **probabilidad e impacto**. Es transversal a varias áreas. *Red flags típicos:* litigios de alto monto, demandas colectivas, investigaciones de autoridades, contingencias mal provisionadas.

Cómo encaja todo: el abogado de M&A **coordina** estas áreas, integra los hallazgos en una **visión de riesgo única** y los traduce en decisiones de precio, estructura y contrato. No necesita ser experto fiscal o ambiental, pero **sí** debe saber qué busca cada área, **leer** sus reportes con criterio jurídico y **conectar** los puntos: un *red flag* fiscal puede exigir una indemnización especial; uno de *change of control*, una condición al clo-

sing; uno ambiental grave, un descuento, un *escrow* o el abandono del deal.

14.B • EL PROCESO DE DUE DILIGENCE (DE PRINCIPIO A FIN)

La due diligence no es leer documentos al azar: es un **proceso ordenado** con fases bien definidas. Domínalo como un protocolo; así sabrás siempre en qué punto estás y qué falta.

Fase 0 — Preparación y *scoping* (definir el alcance). Antes de pedir un solo documento, el equipo define el **alcance** (*scope*): ¿qué áreas se revisan?, ¿con qué profundidad?, ¿cuál es el **umbral de materialidad** (no revisar contratos por debajo de cierto monto)?, ¿cuál es el calendario y el presupuesto? El alcance se fija según el **tamaño y el riesgo** del deal y según la **tesis** del comprador (un estratégico mira sinergias e integración; un fondo mira QoE y capacidad de apalancamiento). *Error clásico del junior*: lanzarse a revisar sin un *scope* claro y ahogarse en documentos irrelevantes. **El alcance bien definido es la mitad del trabajo.**

Fase 1 — Solicitud de información (*request list* / DDRL). El comprador entrega al vendedor una **lista estructurada** de la información que necesita, organizada por áreas (corporativo, contractual, fiscal, laboral, etc.). Las *request lists* suelen partir de un *checklist* maestro del despacho que se **adapta** al deal concreto. La calidad de la lista marca el ritmo: pedir de más satura y enoja; pedir de menos deja huecos de riesgo. Es habitual hacer **rondas** (una lista inicial y solicitudes complementarias según lo que se va encontrando).

Fase 2 — Apertura y población del data room. El vendedor **carga** la información solicitada en el **Virtual Data Room (VDR)**, organizada en carpetas que normalmente espejan la *request list*. El comprador obtiene accesos (con distintos niveles según la sensibilidad). En procesos competitivos (subastas), el vendedor controla qué se revela y cuándo (a veces hay información ultrasensible —precios, clientes— que solo se abre en fases avanzadas o en un *clean room* para evitar problemas de competencia).

Fase 3 — Revisión y análisis. El equipo del comprador **revisa** sistemáticamente, área por área, registrando hallazgos. Aquí entran el criterio, la técnica y, hoy, la **tecnología** de revisión asistida (para detectar cláusulas tipo en grandes volúmenes de contratos). Cada revisor levanta los **red flags** de su área y los documenta con referencia precisa (qué documento, qué cláusula, qué riesgo, qué impacto estimado).

Fase 4 — Q&A (preguntas y respuestas). Cuando la información del data room es insuficiente, ambigua o genera dudas, el comprador formula **preguntas** a través del módulo de Q&A del VDR, y el vendedor responde. Este proceso: **(i)** llena los huecos de información; **(ii)** genera un **rastros documental** valioso (las respuestas del vendedor pueden ser, en sí mismas, una forma de revelación o de *representation* informal); y **(iii)** permite calibrar la **transparencia y cooperación** del vendedor (un vendedor evasivo es, en sí mismo, una bandera).

Fase 5 — Reporte (DD report). El equipo consolida los hallazgos en el **DD report** (típicamente un *red flag report*: solo lo relevante). Aquí la información cruda se convierte en **inteligencia para la decisión**: hallazgo → riesgo → impacto → recomendación. Lo veremos a fondo en la sección 14.E y en la sección 21.

Fase 6 — Traducción al contrato y a la negociación. Los hallazgos **alimentan** la negociación del precio y la redacción del SPA: reps específicas, indemnizaciones especiales, ajustes, *escrow*, condiciones al *closing*, exclusiones del perímetro. Esta es la fase donde la DD **paga**: un hallazgo que no se traduce en protección contractual es trabajo perdido.

Fase 7 — DD confirmatoria (entre *signing* y *closing*). Si hay separación entre firma y cierre (*gap*), suele hacerse una **due diligence confirmatoria** o de actualización (*bring-down*): verificar que nada relevante cambió, que las condiciones se cumplieron y que las reps siguen siendo ciertas a la fecha del *closing*. Conecta con los *covenants* de operación ordinaria y con la cláusula MAC del Libro 1.

Una idea rectora del proceso: la due diligence es **iterativa**, no lineal. Lo que se encuentra en una fase genera nuevas preguntas y nuevas solicitudes en la anterior. El buen abogado **navega** ese ciclo con orden, sin perder de vista ni el bosque (la tesis del deal y el riesgo agregado) ni los árboles (el hallazgo concreto en la cláusula concreta).

14.C · EL DATA ROOM Y LA DINÁMICA DE LA INFORMACIÓN

El **data room** es el escenario físico (hoy virtual) de la due diligence, y entender su dinámica es parte del oficio.

Del cuarto físico al VDR. Como vimos, antes era un cuarto con cajas de documentos vigilado; hoy es una **plataforma en línea segura** (Virtual Data Room). El VDR aporta ventajas decisivas: acceso simultáneo de equipos en varias ciudades, **control de permisos** por usuario y por carpeta, **marcas de agua** y bloqueo de descarga/impresión para lo sensible, y un **registro de auditoría** (*audit log*) que muestra quién vio qué y cuándo—dato relevante si después se discute qué fue revelado—.

Estructura del data room. Suele organizarse en carpetas que espejan las áreas de la DD: 1. Corporativo; 2. Contratos materiales; 3. Fiscal; 4. Financiero; 5. Laboral; 6. Permisos y regulatorio; 7. Propiedad intelectual; 8. Litigios; 9. Inmuebles; 10. Seguros; etc. Un data room **bien organizado** acelera la revisión; uno caótico (documentos sin nombrar, escaneos ilegibles, faltantes) es, en sí mismo, una **señal** sobre la calidad de la gestión de la *target*.

La dinámica de poder informativo. El vendedor **controla** qué pone en el data room y cómo lo presenta; el comprador busca lo que falta y lo que se esconde. Por eso el abogado del comprador debe leer no solo lo que **está**, sino detectar lo que **no está** (¿por qué no hay contrato con el principal cliente?, ¿por qué falta el dictamen fiscal de un año?). Las **ausencias** suelen decir tanto como los documentos.

Q&A: el arte de preguntar. El módulo de Q&A es una herramienta poderosa y delicada. Buenas prácticas: **(i)** preguntar de forma **precisa y referenciada** (a qué documento se refiere la pregunta); **(ii)** escalar la presión de forma gradual (primero

pedir el documento faltante, luego preguntar por su ausencia); **(iii)** documentar todo (las respuestas pueden tener valor probatorio o servir de base a una *representation*); y **(iv)** cuidar el **tono** (un Q&A agresivo o desmesurado puede deteriorar la relación y el deal). Recuerda: lo que el vendedor **responde** o **revela** en el Q&A puede luego limitar su responsabilidad (si reveló un problema, difícilmente podrá el comprador reclamar después por algo que **sabía**: es el principio anglosajón del *sandbagging*, que se negocia expresamente en el SPA).

Confidencialidad y privilegio. Todo el ejercicio se ampara en el NDA firmado al inicio (Libro 1). Además, el abogado debe cuidar el **secreto profesional** / **privilegio legal**: ciertos documentos (opiniones legales, análisis de litigios) son sensibles, y su manejo en el data room debe proteger el privilegio para que no se entienda renunciado. En operaciones transfronterizas, las reglas de privilegio varían por jurisdicción —un punto fino que distingue al abogado sofisticado—.

Información competitivamente sensible y clean teams. Cuando comprador y *target* son competidores, revelar precios, clientes o estrategias durante la DD puede violar la **ley de competencia** (intercambio de información sensible, *gun jumping* informativo). La solución profesional son los **clean teams**: equipos restringidos (a veces asesores externos) que revisan la información ultrasensible **sin** trasladarla a quienes toman decisiones comerciales hasta que la operación se autoriza y cierra. Es un matiz avanzado, pero crítico en deals entre competidores.

14.D · RED FLAGS Y MATERIALIDAD (CÓMO SE JERARQUIZA EL RIESGO)

Encontrar problemas es fácil; **toda** empresa los tiene. El arte de la due diligence no es hacer una lista infinita de defectos, sino **jerarquizar**: distinguir lo que importa de lo que no, y dentro de lo que importa, lo grave de lo manejable. Dos conceptos gobiernan esta jerarquía: la **materialidad** y la **clasificación de los red flags**.

La materialidad (*materiality*). Materialidad es el **umbral de relevancia**: el punto a partir del cual un hallazgo merece

atención, reporte o protección contractual. Sin un umbral, el equipo se ahoga y el DD report se vuelve inútil (mil hallazgos triviales esconden los cinco que de verdad importan). La materialidad se fija de dos formas: **cuantitativa** (un monto: "solo revisamos/reportamos contingencias superiores a X"; "solo contratos por encima de Y") y **cualitativa** (por naturaleza del riesgo: ciertos temas —corrupción, titularidad de las acciones, permisos esenciales, *change of control* en el contrato clave— importan **aunque** el monto sea bajo, porque ponen en riesgo el negocio mismo o generan responsabilidad penal/regulatoria). El abogado experto **calibra** la materialidad al inicio (en el *scoping*) y la ajusta sobre la marcha. Esta misma noción reaparecerá en el SPA: las reps suelen tener *materiality qualifiers* ("salvo por lo que no sea material...") que se negocian palabra por palabra.

La clasificación de los red flags. Un buen reporte clasifica cada hallazgo según su gravedad. Un esquema práctico de tres (o cuatro) niveles:

- ● **Deal breaker (mata el deal):** riesgo tan grave que, si no se resuelve, justifica **abandonar** la operación. Ejemplos: la *target* no es realmente dueña de su activo principal; un pasivo fiscal o ambiental que excede el valor de la empresa; corrupción sistémica con exposición penal; ausencia del permiso sin el cual el negocio no puede operar. Ante un *deal breaker*, las opciones son: resolverlo antes del *closing* (condición), reestructurar radicalmente, o retirarse.
- ● **Riesgo mayor (afecta precio/estructura/protección):** riesgo relevante pero **manejeable** mediante herramientas contractuales. Es el caso más frecuente y el corazón del trabajo. Ejemplos: una contingencia fiscal significativa pero acotada (→ indemnización especial + *escrow*); un contrato clave con *change of control* (→ consentimiento como condición al *closing*); un litigio relevante (→ rep específica + indemnización). Estos hallazgos **no matan el deal**: lo **reprecian** y lo **blindan**.
- ● **Riesgo menor / a documentar:** hallazgos de bajo impacto que se **registran** (para tenerlos mapeados, exigir su sub-

sanación o cubrirlos con reps generales), pero que no mueven el precio ni la estructura. Ejemplos: contratos menores vencidos pero renovables, formalidades societarias pendientes de bajo riesgo.

- **● Sin observaciones / conforme:** áreas revisadas donde no se encontró riesgo relevante. Reportarlo también es valioso: da **confianza** y delimita el alcance de lo revisado.

La matriz de riesgo (probabilidad × impacto). Para jerarquizar con rigor, el abogado piensa cada hallazgo en dos ejes: **probabilidad** de que el riesgo se materialice y **impacto** (cuánto costaría si ocurre). Lo de **alta probabilidad y alto impacto** es prioridad uno; lo de **baja probabilidad y bajo impacto**, se documenta y sigue. Esta matriz —heredada de la gestión de riesgo— es la herramienta mental que convierte una lista de defectos en una **estrategia de protección**.

Una advertencia de criterio. El junior tiende a reportar **todo** con el mismo tono alarmante (para "cubrirse"), lo que vuelve el reporte inútil y mina su credibilidad. El abogado maduro **jerarquiza y recomienda**: dice qué es grave, qué es manejable y qué es ruido, y **propone** la solución contractual. La diferencia entre "encontré 200 problemas" y "encontré 200 hallazgos, de los cuales 3 son críticos y así los resolvemos" es la diferencia entre un revisor de documentos y un **asesor de transacciones**.

14.E · DEL HALLAZGO A LA CLÁUSULA (LA DUE DILIGENCE SE CONVIERTE EN PROTECCIÓN)

Aquí está la **lección más importante de todo el libro**, la que separa a quien "hace due diligence" de quien **agrega valor**: cada hallazgo relevante debe **traducirse** en una protección contractual concreta. La due diligence que no se traduce en el SPA es trabajo desperdiciado. Estas son las **seis herramientas** de traducción y cuándo se usa cada una:

1) Ajuste de precio (descuento). Cuando el hallazgo revela que la empresa **vale menos** de lo pensado (deuda mayor, capital de trabajo deteriorado, ingresos no recurrentes, un pasivo cierto), la respuesta natural es **bajar el precio**. *Ejemplo:* la DD

financiera revela que el 30% de los ingresos provenían de un contrato que ya terminó → el comprador reduce su oferta o cambia el múltiplo de valuación.

2) Representation & warranty específica. Cuando el hallazgo revela un **área de riesgo** sobre la que el comprador quiere que el vendedor **garantice** un estado de cosas, se redacta una **rep específica**. *Ejemplo:* la DD detecta un historial de problemas de cumplimiento ambiental → se exige una rep robusta de que "la *target* cumple en todos los aspectos materiales con la normativa ambiental, salvo lo revelado en el *disclosure schedule X*". Si la rep resulta falsa, se activa la indemnización.

3) Indemnización especial (*special / specific indemnity*). Cuando el hallazgo revela un riesgo **concreto e identificado** (no una incertidumbre general), no basta una rep: se pacta una **indemnización específica** que cubre **ese** riesgo nominalmente, a menudo **fuera de los topes y mínimos** generales y **aunque el riesgo ya fuera conocido**. *Ejemplo:* la DD fiscal identifica una contingencia concreta por una deducción cuestionable de 2022 → indemnización especial del vendedor por "cualquier crédito fiscal derivado de la deducción X del ejercicio 2022", al 100% y sin tope. Esta es la herramienta estrella para los *red flags* mayores **conocidos**.

4) Retención del precio (*escrow / holdback*). Cuando el riesgo es relevante y se quiere asegurar el **cobro** de una eventual indemnización, se **retiene** parte del precio en una cuenta de garantía (*escrow*) por un plazo, liberándose si el riesgo no se materializa. *Ejemplo:* ante una contingencia fiscal o un litigio en curso, se deja el 10% del precio en *escrow* por 24 meses. Convierte la promesa de indemnizar en **dinero disponible**.

5) Condición al *closing* (*condition precedent*). Cuando el riesgo **puede y debe resolverse antes del cierre**, se vuelve **condición**: el comprador no está obligado a cerrar hasta que se subsane. *Ejemplo:* la DD detecta que el contrato con el cliente clave tiene *change of control* → se pacta como condición al *closing* obtener el **consentimiento** de ese cliente; o que se

obtenga la autorización de la COFECE; o que se regularice un permiso vencido.

6) Exclusión del perímetro o cambio de estructura. Cuando el riesgo está **localizado** en un activo, una subsidiaria o una línea de negocio, a veces la mejor solución es **dejarlo fuera** de la compra (reestructurar el perímetro) o **cambiar de estructura** (de *share deal* a *asset deal* para no heredar los pasivos ocultos, como vimos en el Libro 1). *Ejemplo:* la DD ambiental revela un sitio gravemente contaminado → se excluye ese inmueble de la operación, o se compra vía *asset deal* dejando el pasivo en el vendedor.

El cuadro mental que debes memorizar (lo retomaremos en la sección 37):

TIPO DE HALLAZGO	HERRAMIENTA TÍPICA
La empresa vale menos	Ajuste/descuento de precio
Área de riesgo a garantizar	Representation & warranty específica
Riesgo concreto conocido	Indemnización especial (sin tope, fuera de cesta)
Asegurar el cobro de la indemnización	<i>Escrow / holdback</i>
Riesgo subsanable antes de cerrar	Condición al <i>closing</i>
Riesgo localizado en un activo/pasivo	Exclusión del perímetro / cambio de estructura
Riesgo intolerable e irresoluble	<i>Walk away</i> (abandonar el deal)

Interioriza esta tabla: es el **puente** entre el Libro 2 (due diligence) y el Libro 4 (documentación: SPA). El abogado que, ante cada hallazgo, ya está pensando en cuál de estas herramientas aplicar, **piensa como un abogado de M&A**. Ese es exactamente el objetivo de este libro.

15. Explicación intuitiva

Piensa en la due diligence con tres metáforas que te ayudarán a retenerla y a explicarla.

La metáfora médica. Comprar una empresa sin due diligence es como **operar a un paciente sin estudios previos**. El *Information Memorandum* del vendedor es lo que el pacien-

te te cuenta de sus síntomas (subjetivo, incompleto, a veces engañoso). La due diligence son los **análisis de sangre, las radiografías y la resonancia**: la evidencia objetiva de lo que de verdad ocurre por dentro. Las **áreas** de la DD son las distintas especialidades (el cardiólogo mira el corazón = la DD financiera; el traumatólogo, los huesos = la DD de activos; etc.). Los **red flags** son los hallazgos clínicos, y la **materialidad** es saber distinguir un lunar inofensivo de un tumor. El **DD report** es el diagnóstico integrado, y las **cláusulas del SPA** son el tratamiento: a veces operas (cierras el deal con protecciones), a veces medicas (ajustes y condiciones), a veces decides **no operar** (walk away).

La metáfora del iceberg. Lo que el vendedor te muestra de inicio es la **punta del iceberg** —lo que flota a la vista, cuidadosamente presentado—. La due diligence es **bucear** para ver la masa sumergida: los pasivos ocultos, las contingencias, los contratos con trampa. La mayoría de los deals que destruyen valor no chocan con lo que se veía, sino con lo que estaba **bajo el agua** y no se buscó.

La metáfora del detective. El abogado de DD es un **detective**, no un archivista. No se limita a catalogar los documentos que le entregan; **interroga** la realidad: ¿por qué falta este contrato?, ¿por qué los ingresos saltaron justo el año de la venta?, ¿por qué hay un pago a un "consultor" sin contrato? Busca lo que **no cuadra**, sigue los hilos, y entiende que **las ausencias y las incongruencias** suelen ser las pistas más reveladoras. El buen detective tiene una teoría del caso (la tesis del riesgo) y busca evidencia que la confirme o la desmienta.

La intuición central que debes interiorizar: **la due diligence convierte la incertidumbre en riesgo manejable**. Antes de la DD, el comprador no sabe qué no sabe (incertidumbre pura). Después de una buena DD, sabe qué riesgos existen, cuánto pueden costar y cómo protegerse. No elimina el riesgo —eso es imposible—, pero lo vuelve **conocido, medido y asignado**. Y un riesgo conocido y asignado es, en el mundo de los negocios, un riesgo que se puede **precificar y soportar**.

16. Ejemplos simples

Ejemplo 1 — El cliente que era todo. Una empresa de servicios parece muy rentable. La DD financiera revela que **el 70% de sus ingresos** provienen de **un solo cliente**, y la DD contractual encuentra que ese contrato **vence en seis meses** y tiene cláusula de *change of control*. *Lección:* la empresa vale mucho menos de lo que aparenta; su valor depende de renovar (y de obtener el consentimiento de) un solo contrato. Herramientas: descuento de precio + condición al *closing* (obtener consentimiento y renovación)

- posible *earn-out* atado a la renovación.

Ejemplo 2 — El dueño que no era dueño. Un fundador vende su *startup*. La DD de PI descubre que la **marca y el software** —el activo central— están registrados a nombre del **fundador como persona física**, no de la sociedad que se vende. *Lección:* se compraría una cáscara sin su activo principal. Herramienta: condición al *closing* de **transferir la PI a la sociedad** antes de cerrar (y rep + indemnización por titularidad).

Ejemplo 3 — La deuda escondida. Los estados financieros muestran poca deuda, pero la DD encuentra **avales y garantías** que la empresa otorgó a favor de una compañía hermana. *Lección:* hay deuda **oculta** (contingente) que no aparecía en el balance. Herramienta: ajuste de precio (la deuda neta sube)

- rep específica + indemnización.

Ejemplo 4 — El permiso vencido. Una planta industrial opera con una licencia ambiental **vencida hace un año**. *Lección:* riesgo de clausura y sanciones. Herramienta: condición al *closing* de regularizar la licencia + rep de cumplimiento ambiental + indemnización por contingencias previas al cierre.

17. Ejemplos complejos

Ejemplo complejo 1 — La contingencia fiscal con efecto en cascada. Un grupo industrial mexicano va a ser adquirido por un fondo. La DD fiscal detecta que, durante tres ejercicios, la *target* dedujo pagos a una empresa proveedora que la autoridad podría considerar **operaciones simuladas (EFOS)**.

La contingencia es grande pero **incierta** (depende del criterio de la autoridad y de plazos de prescripción). Complejidad: no se puede solo "bajar el precio" porque el monto es incierto, ni ignorarlo porque podría ser enorme. *Solución integrada*: **(i)** indemnización especial del vendedor por esa contingencia concreta, **al 100% y sin tope**, **(ii)** respaldada por un **escrow** de monto suficiente por el plazo de prescripción, **(iii)** con un mecanismo de **control de la defensa** (¿quién dirige el litigio fiscal si la autoridad reclama, el comprador o el vendedor que indemniza?) y **(iv)** una rep fiscal robusta. Aquí ves cómo **varias herramientas se combinan** para un solo riesgo.

Ejemplo complejo 2 — El deal entre competidores con información sensible. Una empresa quiere comprar a un **competidor directo**. La DD requiere revisar **precios, márgenes y lista de clientes** de la *target* —información competitivamente sensible cuyo intercambio, antes de la autorización de competencia, podría constituir *gun jumping* informativo y violar la LFCE—. Complejidad: el comprador **necesita** la información para valorar, pero **no puede** verla libremente sin riesgo regulatorio. *Solución*: montar un **clean team** —asesores externos y un grupo restringido que **no** participa en decisiones comerciales— que revisa la información ultrasensible y entrega al comprador solo **conclusiones agregadas**, hasta que la COFECE autorice y el deal cierre. Ilustra cómo la DD debe respetar el marco de competencia del Libro 1.

Ejemplo complejo 3 — La PI heredada con open source contaminante. Una empresa de tecnología desarrolla software propietario que vende con licencia. La DD técnica descubre que el código incorpora componentes de **software libre (open source)** bajo licencias "copyleft" (tipo GPL) que **obligarían** a liberar el código propietario que las usa. Complejidad: el activo central (el software) podría estar **jurídicamente contaminado**, comprometiendo todo el modelo de negocio. *Solución*: análisis técnico-legal detallado del alcance, rep específica de PI y de cumplimiento de licencias, indemnización especial, y —según gravedad— condición al *closing* de **remediar** el código o, si es irremediable, reevaluación del precio o *walk away*.

18. Casos reales (operaciones estilizadas y referentes)

Nota de método (Manifiesto XI.5): los casos se presentan de forma estilizada, con fines didácticos. Verifica los detalles antes de citarlos profesionalmente.

HP – Autonomy (2011), el caso emblemático del fracaso de la DD. Hewlett-Packard compró la empresa de software Autonomy por más de 11,000 millones de dólares y, poco después, tuvo que reconocer una pérdida contable masiva (alrededor de 8,800 millones), alegando que las cuentas de Autonomy habían sido **infladas** antes de la venta. El caso —que derivó en litigios y procesos penales por años— se estudia en todo el mundo como el ejemplo de una **due diligence financiera insuficiente** (o de hallazgos ignorados por la prisa de cerrar). *Lección:* la **Quality of Earnings** importa más que cualquier otra cosa cuando se paga un múltiplo alto por una empresa de software; y ninguna presión por cerrar justifica saltarse la verificación de los ingresos.

Bayer – Monsanto (2018), el caso del riesgo que sí se vio y no se dimensionó. Es el complemento perfecto del anterior y enseña algo distinto. Bayer adquirió Monsanto sabiendo que existía litigio en torno al glifosato: **el hallazgo no se le escapó a nadie**. Lo que falló fue el **dimensionamiento**: la exposición terminó traducándose en miles de demandas y provisiones por decenas de miles de millones de dólares **△ verificar**, muy por encima de lo previsto al firmar.

La lección conjunta de los dos casos, y es la más importante del libro. HP–Autonomy enseña que **lo que la DD no ve, el comprador lo paga**. Bayer–Monsanto enseña algo más incómodo: **lo que la DD ve pero calcula mal, también lo paga**. Detectar un riesgo es la mitad del trabajo; la otra mitad es ponerle un número y un rango —y sobre eso, recuerda del módulo 01 de la Columna VI que tus rangos son sistemáticamente demasiado estrechos, y que conviene ensancharlos a propósito—.

Es también la razón por la que un litigio latente rara vez se resuelve con una indemnización genérica: requiere su propia cláusula, su propio tope y su propia fuente de pago.

Bank of America – Countrywide / Merrill Lynch (2008).

En plena crisis financiera, adquisiciones hechas con DD apresurada dejaron a Bank of America con **pasivos legales y regulatorios** enormes (heredados de las prácticas hipotecarias y de los activos tóxicos de las empresas adquiridas), que costaron decenas de miles de millones en años posteriores. *Lección:* en una compra se **heredan los pasivos** —legales, regulatorios, reputacionales—; la prisa y la euforia son enemigas de la due diligence.

Las MAC y la DD confirmatoria (caso Akorn v. Fresenius, Delaware, 2018). Fresenius había acordado comprar a la farmacéutica Akorn, pero durante el período entre firma y cierre descubrió **graves problemas de cumplimiento regulatorio** en Akorn (datos falseados ante la FDA). Un tribunal de Delaware permitió a Fresenius **abandonar** el deal invocando un *Material Adverse Effect* —el primer caso en que una corte de Delaware validó una salida por MAC—. *Lección:* la **due diligence confirmatoria** entre *signing* y *closing* y una **cláusula MAC** bien redactada (Libro 1) son la última línea de defensa cuando aparecen problemas graves después de firmar.

19. Casos empresariales

El fondo de Private Equity y la Quality of Earnings. Un fondo de PE evalúa comprar una cadena de restaurantes. Su DD financiera (QoE) descubre que buena parte de la "utilidad" provenía de **no haber invertido en mantenimiento** de los locales (lo que infla el resultado a corto plazo pero deteriora el negocio) y de **ingresos extraordinarios** por venta de inmuebles. La utilidad **recurrente y real** era mucho menor. *Decisión empresarial:* el fondo recalculó el múltiplo sobre el EBITDA **normalizado**, bajando su oferta sustancialmente, y condicionó el deal a un plan de inversión en mantenimiento. La DD **salvó** al fondo de pagar de más por utilidades ilusorias.

La empresa familiar y el orden de la casa (vendedor due diligence). Una familia decide vender su empresa manufacturera. Antes de salir al mercado, encarga una **vendedor due diligence** que revela problemas ocultos: formalidades societarias incompletas, un par de contingencias laborales y PI mal regis-

trada. *Decisión empresarial*: en lugar de esperar a que los compradores lo descubran (y descuenten el precio o desconfíen), la familia **regulariza** todo antes de vender, ordena la casa y entrega un VDD report limpio. Resultado: proceso más rápido, más compradores interesados y mejor precio. Ilustra el valor estratégico de la DD **del lado del vendedor**.

20. Casos corporativos (la conexión integral)

Este caso integra **todo** lo aprendido hasta ahora en el programa. *Corporación Alfa* (estratégico) quiere adquirir a *Beta, S.A.P.I.*, una empresa tecnológica con inversionistas de venture capital.

- **Del Nivel I (Obligaciones, Contratos)**: la DD contractual analiza los contratos materiales de Beta como **fuentes de obligaciones**, buscando cargas, condiciones y cláusulas de *change of control*.
- **Del Nivel II (Responsabilidad civil, Garantías)**: la DD de litigios estima la **responsabilidad civil** contingente de Beta; los hallazgos se traducen en **garantías** contractuales (reps, indemnización, escrow).
- **Del Nivel III (Sociedades/LGSM, Gobierno Corporativo, Valores)**: la DD corporativa revisa la estructura de **S.A.P.I.** de Beta, los **derechos de los inversionistas de VC** (asientos, vetos, preferencias de liquidación, *drag/tag along*) que afectan **cómo** se puede comprar; la DD de gobierno evalúa los **deberes del consejo** de Beta al vender (Revlon) y si hay conflictos.
- **Del Libro 1 de este nivel (Fundamentos de M&A)**: los hallazgos determinan la **estructura** (¿share o asset?), las **fases** (¿qué se vuelve condición al *closing*?) y la **asignación de riesgo** (reps, MAC, escrow).
- **De este Libro 2**: la DD **integra** todo en un DD report jerarquizado y lo traduce en el SPA.

Moraleja: la due diligence es el **punto donde converge toda tu formación jurídica**. No es una habilidad aislada: es la aplicación simultánea, bajo presión y con sentido práctico, de

todo el derecho privado que has estudiado. Por eso es tan formativa y tan valorada.

21. Casos internacionales

Cross-border due diligence (operaciones transfronterizas).

Cuando se compra una empresa con operaciones en varios países, la DD se vuelve **multijurisdiccional**: equipos locales en cada país revisan el cumplimiento bajo su propio derecho (laboral, fiscal, regulatorio, de competencia), coordinados por un despacho líder. Surgen retos finos: **diferencias de privilegio legal** (lo que es confidencial en un país puede no serlo en otro), **distintos umbrales de notificación de competencia** (una operación puede requerir autorización en la UE, EE.UU., Brasil y México a la vez), y **regímenes de protección de datos** divergentes (el GDPR europeo impone reglas estrictas a la transferencia de datos personales durante la DD).

FCPA y due diligence anticorrupción en adquisiciones. El Departamento de Justicia de EE.UU. ha sido explícito en su doctrina sobre **sucesión de responsabilidad**: cuando una empresa sujeta a la FCPA compra otra que incurrió en corrupción, puede **heredar** esa responsabilidad —pero una **due diligence anticorrupción rigurosa**, seguida de medidas correctivas, mitiga sustancialmente la exposición—. Esto ha vuelto la DD de compliance un **estándar global ineludible** en cualquier operación con nexo estadounidense o con operaciones en mercados de riesgo. *Lección*: en el M&A internacional, "no investigué la corrupción" no es una defensa; es un **agravante**.

El estándar de los fondos globales en México. Cuando un fondo de PE o un corporativo internacional adquiere en México, importa su **estándar de DD**: QoE exhaustiva, DD de compliance y anticorrupción, revisión laboral fina (incluido el régimen de subcontratación), y exigencias de ESG. El abogado mexicano de élite debe operar con **estándares plenamente internacionales**, hablar el lenguaje de los fondos y entender sus *checklists* y sus prioridades. Esa es, precisamente, la formación que persigue esta biblioteca.

22. Derecho comparado

La due diligence es una práctica **global**, pero el marco jurídico que la rodea —y, sobre todo, la regla sobre **quién soporta el riesgo de lo que no se reveló**— varía según la tradición jurídica. Esta es la tabla comparada que todo abogado de M&A debe tener en la cabeza:

JURISDICCIÓN / SISTEMA	CÓMO TRATA LA DUE DILIGENCE Y LA ASIGNACIÓN DE RIESGO INFORMATIVO
México (Civil Law)	DD como práctica contractual; el Código de Comercio y el Civil imponen buena fe y deberes de información precontractual; el riesgo se asigna por reps & warranties e indemnización en el SPA (importadas del common law). El dolo/reticencia del vendedor puede generar nulidad o responsabilidad.
EE.UU. (Common Law)	Origen de la práctica moderna. Predomina el principio de caveat emptor (el comprador se cuida) atenuado: lo que importa es lo pactado en el SPA (reps, indemnización, <i>sandbagging</i>). El sistema confía en la autonomía contractual y en una DD exhaustiva.
Delaware	El estándar de referencia mundial en M&A. Jurisprudencia riquísima sobre deberes del consejo (decidir informado: la DD como parte del deber de diligencia), interpretación de MAC y de reps. El <i>case law</i> de Delaware es la "lengua franca" del M&A.
España (Civil Law)	DD muy extendida (influencia anglosajona vía despachos internacionales); el Código Civil aporta el saneamiento por vicios ocultos y la responsabilidad por dolo; el riesgo se pacta en <i>manifestaciones y garantías</i> (las reps en español).
Reino Unido (Common Law)	<i>Caveat emptor</i> fuerte: el vendedor no tiene un deber general de revelar; el comprador se protege con warranties y con la disclosure del vendedor (los <i>disclosure letters</i>). La DD es esencial porque "lo que no preguntas/garantizas, lo pierdes".
Unión Europea	Sin un régimen único de DD privada, pero con fuerte impacto del derecho de competencia (control de concentraciones), protección de datos (GDPR) —que condiciona el manejo de datos en la DD— y, crecientemente, normas de due diligence en sostenibilidad y derechos humanos (cadenas de suministro).
UNIDROIT (Principios)	Aportan los deberes de buena fe y de información en la negociación y la doctrina de la responsabilidad precontractual (<i>culpa in contrahendo</i>), marco supletorio útil en contratos internacionales.
CISG (Compraventa internacional)	Regula la conformidad de las mercancías y los deberes de examen del comprador; aunque pensada para mercaderías, su lógica (examinar y notificar defectos) ilumina la racionalidad de la DD.
Civil Law vs. Common Law (síntesis)	El civil law tiende a proteger al comprador con deberes legales de información y saneamiento ; el common law confía en la autonomía contractual (reps, warranties, disclosure). En la práctica del M&A global, gana el modelo

JURISDICCIÓN / SISTEMA	CÓMO TRATA LA DUE DILIGENCE Y LA ASIGNACIÓN DE RIESGO INFORMATIVO
	common law: el SPA con reps e indemnización es el estándar aunque la ley aplicable sea civil.

La gran lección comparada: sin importar la jurisdicción, el M&A internacional se documenta con el **aparato contractual del common law** (reps & warranties, indemnización, disclosure schedules, sandbagging, MAC). Por eso un abogado mexicano de M&A debe dominar ese aparato **tanto** como su propio Código Civil: la operación se rige por derecho mexicano, pero **habla inglés contractual**.

23. Derecho mexicano

En México, la due diligence se asienta sobre varios pilares del ordenamiento, aunque ninguno la regule de forma autónoma:

- **Buena fe y deberes precontractuales (Código Civil Federal y locales; Código de Comercio).** La negociación debe conducirse de buena fe; el **dolo** (maquinaciones para engañar) y la **mala fe** (incluida la **reticencia** —callar lo que se debía decir—) vician el consentimiento y pueden generar **nulidad y responsabilidad por daños**. Este es el respaldo civil de la DD y de las reps: si el vendedor ocultó dolosamente un pasivo, el comprador tiene acción aun más allá del contrato.
- **Saneamiento por vicios ocultos y por evicción (CCF).** El régimen civil de la compraventa obliga al vendedor a responder por los **defectos ocultos** de la cosa y por la **evicción** (que un tercero prive al comprador de lo adquirido). En M&A, este régimen se **complementa y desplaza** contractualmente con reps e indemnización a la medida.
- **Deber de diligencia de los administradores (LGSM; LMV para emisoras).** Los administradores deben obrar como un **administrador prudente** y de manera **informada**. Aprobar una adquisición relevante sin DD adecuada puede comprometer su responsabilidad: la DD es parte del **proceso informado** que exige el deber fiduciario (conecta con Gobierno Corporativo y con *Van Gorkom*).

- **Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).** Régimen de **concentraciones**: notificación a la COFECE según umbrales, prohibición de consumir antes de la autorización (*gun jumping*), y reglas sobre el intercambio de información sensible entre competidores durante la DD (*clean teams*).
- **Régimen fiscal (CFF) y el riesgo EFOS/EDOS.** El **artículo 69-B**  **del Código Fiscal** y el régimen de operaciones simuladas hacen de la DD fiscal un área de altísima sensibilidad: comprar una empresa que facturó o dedujo operaciones simuladas puede heredar contingencias graves.
- **Materia laboral (LFT) y subcontratación.** La reforma que **prohibió la subcontratación de personal** (permitiendo solo servicios especializados registrados —REPSE) volvió crítica la DD laboral: esquemas de *outsourcing* mal estructurados generan pasivos y responsabilidad solidaria.
- **Protección de datos (LFPDPPP).** Condiciona el tratamiento y la transferencia de datos personales durante la DD y vuelve relevante la DD de privacidad.

En suma: el derecho mexicano **no impone** la due diligence con un mandato expreso, pero la **exige de hecho** por la convergencia del deber fiduciario, la buena fe, el saneamiento, y los regímenes de competencia, fiscal y laboral. Omitirla es, a la vez, una imprudencia de negocio y una posible **infracción de deberes**.

24. Jurisprudencia relevante

Nota de método: verifica la vigencia y los datos de identificación de los criterios antes de citarlos en un escrito profesional.

En México, no existe una línea jurisprudencial abundante y específica sobre "due diligence" como tal (por ser práctica contractual), pero sí criterios relevantes en las **instituciones que la sostienen**:

- **Sobre dolo, mala fe y reticencia en los contratos:** criterios que desarrollan cuándo el silencio o la ocultación de información relevante vicia el consentimiento y genera nulidad o responsabilidad —fundamento para reclamar cuando el vendedor ocultó pasivos que una DD habría detectado—.

- **Sobre el saneamiento por vicios ocultos:** criterios sobre el alcance de la responsabilidad del vendedor por defectos no aparentes y la carga de la prueba.
- **Sobre buena fe contractual y responsabilidad precontractual:** criterios que reconocen deberes de conducta en la etapa de negociación.
- **Sobre interpretación de los contratos conforme a la intención de las partes (CCF):** clave para interpretar reps, indemnizaciones y *disclosure schedules*.

En el ámbito **anglosajón** (de altísima influencia práctica), la "jurisprudencia" relevante es el *case law* de **Delaware**, que sí es abundante y determinante: la doctrina sobre **MAC** (*Akorn v. Fresenius*), sobre el **deber de informarse** del consejo (*Smith v. Van Gorkom*) y sobre la interpretación de reps y de *indemnification*. Para el abogado de M&A, este *case law* es **estudio obligado**, porque modela cómo se redactan e interpretan las cláusulas en todo el mundo.

25. Criterios de la Suprema Corte / reguladores

- **SCJN:** sus criterios sobre **buena fe, dolo y vicios del consentimiento** en materia contractual, y sobre **interpretación de los contratos**, son el telón de fondo que da fuerza a las reclamaciones derivadas de información ocultada en una operación.
- **COFEC:** sus **guías y resoluciones** sobre concentraciones definen umbrales de notificación, plazos, el tratamiento del **gun jumping** y el manejo de información sensible entre competidores durante la DD (relevante para diseñar *clean teams*).
- **SAT:** sus criterios y el régimen del **art. 69-B CFF** ☞ (operaciones simuladas) marcan el riesgo central de la DD fiscal en México.
- **CNBV (para emisoras):** en operaciones sobre empresas públicas, el régimen de la LMV (revelación, OPAs, información privilegiada) condiciona qué y cómo se revela en la DD.

26. Doctrina nacional

La doctrina mexicana sobre due diligence se ha desarrollado principalmente desde la **práctica de los despachos corporativos** y desde la doctrina mercantil y de competencia, más que desde tratados académicos clásicos. Las fuentes útiles son: la doctrina civil sobre **buena fe, vicios del consentimiento y saneamiento** (que da el marco de fondo), la doctrina mercantil y societaria (LGSM, gobierno corporativo) y la doctrina de **competencia económica** (concentraciones, gun jumping). El abogado mexicano completa esta base con la **literatura transaccional internacional**, que es donde la DD está más desarrollada técnicamente.

27. Doctrina internacional

La doctrina internacional sobre due diligence es vasta y eminentemente **práctica**:

- **Literatura transaccional de los grandes despachos y *Practical Law / PLC***: guías cláusula por cláusula, *checklists* de DD por área e industria, y *precedents* de mercado. Es el material de trabajo diario del abogado de M&A.
- **American Bar Association — *Model Stock Purchase Agreement* y materiales de DD**: referencia sobre cómo los hallazgos de la DD se reflejan en reps, indemnización y *disclosure schedules*.
- **Doctrina de negociación y *deal-making* (Harvard — Sebenius, Subramanian)**: entiende la DD como parte del **diseño de la transacción** y de la dinámica de información entre las partes.
- **Doctrina de compliance y anticorrupción (FCPA Resource Guide del DOJ/SEC)**: estándar sobre la DD anticorrupción en adquisiciones y la sucesión de responsabilidad.
- **Doctrina de valuación y finanzas (para la QoE)**: conecta la DD financiera con la valuación (anticipa el Nivel V).

28. Opiniones críticas (postura del Consejo Editorial)

Nuestra postura, como Consejo, sobre la due diligence:

Primero: la DD vale por lo que se traduce, no por lo que se revisa. Criticamos la cultura del "revisar todo" y del DD report de 400 páginas que nadie lee. Una DD excelente es **selectiva, jerarquizada y orientada a la decisión**. El mejor due diligence report cabe, en su parte ejecutiva, en pocas páginas: los *deal breakers*, los riesgos mayores y su traducción contractual. Lo demás es anexo.

Segundo: el riesgo de la DD defensiva. Advertimos contra el abogado que reporta todo con tono alarmante para "cubrirse". Esa práctica **destruye valor**: enturbia la decisión, dispara honorarios y mina la credibilidad del asesor. El cliente no paga por una lista de defectos; paga por **criterio**.

Tercero: la tecnología es palanca, no sustituto del juicio. La revisión asistida por IA acelera la detección de cláusulas tipo, pero la **valoración del riesgo** y su **traducción contractual** siguen siendo humanas. El abogado que solo "corre la herramienta" sin entender lo que encuentra no agrega valor; el que usa la herramienta para liberar tiempo y concentrarse en el criterio, **multiplica** su valor.

Cuarto: la DD es una habilidad de carrera, no una tarea de novatos. Aunque el junior la ejecuta, dominarla con criterio es lo que forma al socio. Quien aprende a **ver el riesgo y a traducirlo** temprano, acelera su carrera más que quien solo "redacta contratos".

Quinto, y es la crítica que más nos importa: la DD puede producir una falsa sensación de control. Se revisaron doce mil documentos, hay un reporte de cuatrocientas páginas, y aun así nadie vio el fraude (HP–Autonomy) ni midió bien la externalidad latente (Bayer–Monsanto). El volumen de la revisión se confunde con la calidad del juicio, y son cosas distintas.

Y hay una razón conductual detrás, no solo técnica. Una vez que el equipo decidió que la operación va, la información nueva deja de evaluarse y empieza a clasificarse: lo que confirma se examina con benevolencia y lo que contradice se examina con lupa hasta encontrarle un defecto. Es el **sesgo de confirmación**, agravado por el hecho de que **casi todos los que rodean la mesa —incluidos los abogados— tienen un incenti-**

vo económico en que la operación cierre. Nadie miente; todos son asimétricamente rigurosos.

La defensa no es la buena intención: es el proceso. Un *pre-mortem* antes de aprobar —"estamos a dieciocho meses del cierre y esto fue un desastre; cada uno escriba por qué"— rescata en veinte minutos los hallazgos incómodos que la fiebre de la operación había vuelto impolíticos. Está desarrollado en el módulo 01 de la Columna VI, junto con la pregunta que desactiva el costo hundido.

29. Debate doctrinal

- **¿*Caveat emptor* o deber de revelar? (common law vs. civil law).** El common law parte de que el comprador debe cuidarse (de ahí la DD exhaustiva); el civil law impone deberes de información y saneamiento al vendedor. *Postura del Consejo:* en el M&A moderno **gana la lógica contractual** —lo que importa es lo pactado (reps, disclosure)— pero el abogado mexicano debe recordar que su derecho ofrece **una red de seguridad adicional** (dolo, saneamiento) que el common law puro no tiene.
- **¿*Sandbagging* sí o no?** Debate clásico: si el comprador **sa-bía** (por la DD) que una rep era falsa y aun así cierra, ¿puede luego reclamar la indemnización (*pro-sandbagging*) o no (*anti-sandbagging*)? Se resuelve **expresamente** en el SPA. *Postura del Consejo:* el comprador prefiere cláusula *pro-sandbagging* (puede reclamar aunque supiera); el vendedor, lo contrario; quien tiene más poder de negociación impone su preferencia. Es un punto donde la DD y el contrato se cruzan de forma fascinante.
- **¿Hasta dónde llega la DD razonable? ¿Exhaustiva o basada en materialidad (*risk-based*)?** La escuela tradicional pedía revisarlo todo; la moderna —hoy dominante— sostiene que el alcance se decide con un análisis costo-beneficio: **el costo marginal de revisar debe justificarse por el riesgo evitado.** *Postura del Consejo:* la respuesta es la **proporcionalidad al riesgo** (la matriz probabilidad × impacto), no un estándar fijo. Y una nota de oficio: el *data room* virtual y la revisión asistida por herramientas han abaratado

tanto el rastreo que el cuello de botella se movió —ya no está en encontrar, está en **decidir qué importa**—.

Dónde desemboca todo esto en la práctica: la *issue list*. El producto final de una DD útil no es el reporte: es la lista de asuntos —jerarquizada— que se lleva a la mesa y **se negocia línea por línea** contra el SPA. Cada renglón carga su hallazgo, su cuantificación y su destino de los tres del §6. Ese documento es el puente real entre este libro y el Libro 4, y su negociación concreta se entrena en el ejercicio 12 del Laboratorio. - **DD vs. seguros de reps & warranties (*W&I insurance*).** Tendencia creciente: trasladar el riesgo de las reps a un **seguro** (*Warranty & Indemnity insurance*) en vez de a un *escrow*. *Debate:* ¿el seguro reduce el incentivo a hacer una DD rigurosa? *Postura del Consejo:* no debería —las aseguradoras **exigen** una DD sólida para emitir la póliza—; el seguro **complementa**, no sustituye, a la due diligence.

30. Errores comunes

- **Empezar sin un *scope* claro.** Revisar documentos sin haber definido alcance, materialidad y prioridades: el equipo se ahoga en lo irrelevante y se le escapa lo crítico. *Corrección:* define el *scope* y el umbral de materialidad **antes** de abrir el data room.
- **Confundir cantidad con calidad.** Un DD report enorme no es un buen DD report. *Corrección:* jerarquiza (deal breaker / mayor / menor) y orienta a la decisión.
- **No traducir los hallazgos al contrato.** El error más caro: detectar un riesgo y **no** convertirlo en rep, indemnización, ajuste o condición. *Corrección:* para cada *red flag* mayor, define ya la herramienta de protección (sección 14.E).
- **Olvidar el *change of control*.** No revisar si los contratos clave se caen al cambiar el dueño. *Corrección:* búscalo sistemáticamente y vuélvelo condición al *closing*.
- **DD de compliance superficial.** Subestimar el riesgo de corrupción heredada. *Corrección:* DD anticorrupción rigurosa, sobre todo con nexo FCPA o mercados de riesgo.

- **Ignorar las ausencias.** Revisar solo lo que está en el data room sin preguntarse qué falta y por qué. *Corrección:* lee también los **huecos**; úsalos en el Q&A.
- **Romper el privilegio o la confidencialidad.** Manejar mal documentos privilegiados o información sensible entre competidores. *Corrección:* cuida el privilegio y usa *clean teams* cuando haya riesgo de competencia.
- **Prisa por cerrar.** Saltarse o apresurar la DD por presión de tiempo (el error de HP-Autonomy). *Corrección:* ninguna prisa justifica no verificar lo crítico (titularidad, QoE, compliance).

31. Mitos frecuentes

- **"La due diligence garantiza que no habrá sorpresas."** Falso. La DD **reduce y administra** el riesgo; no lo elimina. Por eso existen las reps, la indemnización y el *escrow*: para lo que la DD no pudo ver.
- **"Hay que revisar absolutamente todo."** Falso. Revisar todo es imposible y antieconómico. La DD moderna es **selectiva y proporcional al riesgo** (materialidad).
- **"La DD es trabajo de juniors, sin importancia estratégica."** Falso. La ejecutan juniors, pero define **precio, estructura, contrato y la decisión misma** de comprar. Es de lo más estratégico del deal.
- **"Si está en el data room, está cubierto."** Falso. Lo que el vendedor **revela** (en el data room, en el Q&A, en los *disclosure schedules*) suele **dejar de estar garantizado**: el comprador "ya lo sabía". De ahí el debate del *sandbagging*.
- **"Con un seguro de reps & warranties no necesito DD."** Falso. Las aseguradoras **exigen** una DD sólida para emitir la póliza; el seguro complementa, no sustituye.
- **"La DD legal y la financiera son mundos separados."** Falso. Se cruzan constantemente: una deuda oculta (financiera) nace de un aval (legal); una contingencia fiscal (legal) altera la QoE (financiera).

32. Preguntas difíciles

1. **¿Por qué lo que el vendedor revela en la DD puede *reducir la protección del comprador***? Porque, bajo la lógica de las reps, el comprador se protege de lo **desconocido**; si el vendedor **reveló** un problema (en el *disclosure schedule*), el comprador lo **conocía** y, salvo cláusula *pro-sandbagging*, no podrá reclamar por él después. Revelar es, para el vendedor, una forma de **vacunarse** contra reclamaciones.
2. **¿Cuándo conviene un *asset deal* en vez de un *share deal* por razones de DD**? Cuando la DD revela un **riesgo alto de pasivos ocultos** (fiscales, ambientales, laborales) difíciles de acotar: el *asset deal* permite **dejar los pasivos** en el vendedor y comprar solo los activos limpios (Libro 1).
3. **¿Cómo investigar a un competidor sin violar la ley de competencia**? Con un **clean team**: un grupo restringido (a menudo asesores externos) que revisa la información competitivamente sensible y entrega solo conclusiones agregadas, hasta que la operación se autoriza y cierra. Evita el *gun jumping* informativo.
4. **Si la DD detecta corrupción en la *target*, ¿qué debe hacer el comprador**? Evaluar la gravedad y la exposición (FCPA/local), exigir remediación, estructurar protecciones (indemnización especial, posible *asset deal* para aislar), y —si es sistémica e irremediable— considerar el *walk away*. "No investigué" no es defensa; "investigué y remedie" sí mitiga.
5. **¿Una DD impecable exonera al consejo si el deal sale mal**? En buena medida sí: una DD adecuada es parte del **proceso informado** que activa la *business judgment rule* (Gobierno Corporativo). El consejo que decidió **informado** está protegido aunque el resultado sea malo; el que decidió **sin informarse** (Van Gorkom), no.

33. Casos de examen (con respuesta modelo)

Caso A. *Tu cliente quiere comprar una empresa de logística. La DD revela que su contrato más importante (40% de los ingresos) contiene una cláusula que permite al cliente terminarlo si la*

empresa cambia de control. ¿Qué recomiendas? **Respuesta modelo:** Es un *red flag* **mayor** (alto impacto sobre el valor). Herramientas combinadas: **(i)** condición al *closing* de obtener el **consentimiento** del cliente a la operación (o una renovación); **(ii)** si no se obtiene, derecho del comprador a **no cerrar** o a **ajustar el precio**; **(iii)** posible **earn-out** atado a la conservación del contrato; **(iv)** rep específica del vendedor sobre el estado del contrato. Razonar el porqué: el valor de la *target* depende de ese contrato, así que hay que **asegurar su continuidad antes de pagar**.

Caso B. *La DD fiscal identifica una contingencia concreta y conocida por una deducción cuestionable de un ejercicio anterior, de monto significativo pero incierto. ¿Cómo lo proteges en el SPA?* **Respuesta modelo:** Por ser un riesgo **concreto y conocido**, no basta la rep general: se pacta una **indemnización especial** por esa contingencia específica, **al 100%, fuera de los topes y mínimos generales, respaldada por un escrow** suficiente por el plazo de prescripción, y con una cláusula de **control de la defensa** del eventual litigio fiscal. Mencionar que un riesgo **conocido** se cubre con indemnización **específica**, no con la rep general (que cubre lo desconocido).

Caso C. *El comprador y la target son competidores directos. ¿Cómo organizas la DD de la información de precios y clientes?* **Respuesta modelo:** Mediante un **clean team**: grupo restringido o asesores externos que revisan la información sensible **sin** trasladarla a los equipos comerciales que toman decisiones, entregando solo conclusiones agregadas, hasta obtener la autorización de la COFECE y cerrar. Fundar en el riesgo de **gun jumping** informativo y la violación a la LFCE.

34. Simulador (ejercicio tipo despacho)

Instrucciones: eres asociado de M&A. Tu socia te asigna la coordinación de la DD legal en la compra de *Manufacturas del Norte, S.A.* (industrial, 600 empleados, una planta, exporta a EE.UU.). Trabaja el caso por pasos antes de leer la guía.

1. **Scoping:** define el alcance y las **áreas prioritarias** dado el perfil (industrial, exportadora, muchos empleados). ¿Qué materialidad propondrías?

2. **Request list:** redacta las **5 solicitudes más importantes** que pedirías primero y por qué.
3. **Hipótesis de riesgo:** anticipa los **3 red flags más probables** dado el perfil de la empresa.
4. **Q&A:** formula 3 preguntas precisas que harías si el data room **no** incluye los permisos ambientales.
5. **Traducción:** para cada *red flag* anticipado, indica la **herramienta de protección** (sección 14.E).

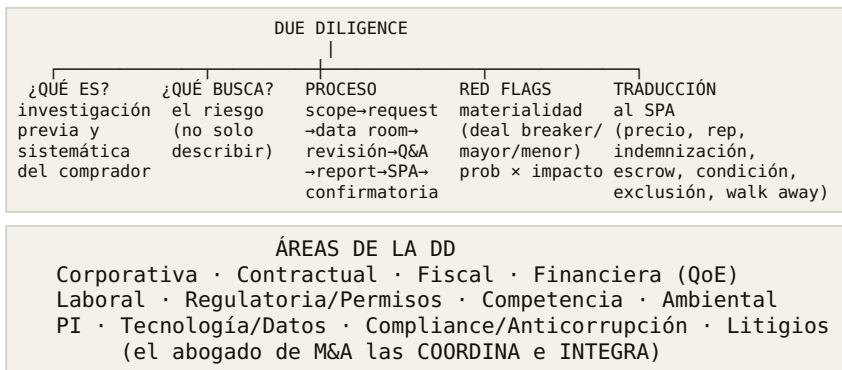
Guía de solución (resumen). (1) Prioriza **ambiental** (planta industrial), **laboral** (600 empleados, posible sindicato y pasivos), **fiscal** (exportadora: IVA, devoluciones, precios de transferencia), **regulatoria** (permisos de operación) y **contractual** (clientes de exportación con *change of control*). Materialidad: contratos > X y contingencias > Y, salvo temas cualitativos (permisos esenciales, ambiental, titularidad). (2) Acta constitutiva y libro de accionistas (titularidad); contratos materiales (clientes/proveedores); permisos ambientales y de operación; situación fiscal (declaraciones, devoluciones, precios de transferencia); pasivos laborales y contrato colectivo. (3) Pasivo ambiental de la planta; contingencia laboral/sindical o de subcontratación; contingencia fiscal por exportación/devoluciones. (4) "¿Cuenta la planta con autorización de impacto ambiental vigente? Favor de cargarla", "¿Existen procedimientos o sanciones de la autoridad ambiental en los últimos 5 años?", "¿Hay estudios de suelo/agua del sitio?". (5) Ambiental → condición al *closing* (regularizar) + rep + indemnización + posible *escrow*; laboral → rep + indemnización por contingencias previas al cierre; fiscal → indemnización especial + *escrow*.

35. Flashcards

- **¿Qué es la due diligence?** La investigación previa y sistemática del comprador sobre la *target* para saber qué compra, cuánto vale y qué riesgos asume.
- **¿Cuál es la lección central del libro?** "La DD investiga y las reps reparten": cada hallazgo relevante se traduce en una protección contractual.
- **¿Qué es la materialidad?** El umbral (cuantitativo y cualitativo) a partir del cual un hallazgo importa.

- **¿Tres niveles de red flag?** Deal breaker (mata el deal) / mayor (precio-estructura-protección) / menor (a documentar).
- **¿Qué es un data room (VDR)?** El repositorio virtual seguro donde el vendedor pone la información para su revisión.
- **¿Qué es la *Quality of Earnings*?** El análisis de cuán recurrentes y reales son las utilidades de la *target*.
- **¿Qué es un *clean team*?** Grupo restringido que revisa información sensible entre competidores sin trasladarla a las áreas comerciales, para evitar *gun jumping*.
- **¿Riesgo concreto y conocido se cubre con...?** Indemnización **especial** (no con la rep general).
- **¿Riesgo subsanable antes de cerrar se cubre con...?** Condición al *closing*.
- **¿Qué es el *sandbagging*?** Que el comprador reclame por una rep que sabía falsa; se pacta expresamente en el SPA.
- **¿Qué es la *vendor due diligence*?** La DD que encarga el **vendedor** sobre su propia empresa antes de venderla.
- **¿Origen del concepto?** La *due diligence defense* de la Securities Act de 1933 (EE.UU.).

36. Mapas mentales



37. Cuadros comparativos

Hallazgo → herramienta de protección (cuadro maestro)

TIPO DE HALLAZGO	HERRAMIENTA
La empresa vale menos	Ajuste/descuento de precio
Área de riesgo a garantizar	Rep & warranty específica
Riesgo concreto conocido	Indemnización especial (sin tope, fuera de cesta)
Asegurar el cobro	<i>Escrow / holdback</i>
Riesgo subsanable antes de cerrar	Condición al <i>closing</i>
Riesgo localizado en activo/pasivo	Exclusión del perímetro / <i>asset deal</i>
Riesgo intolerable e irresoluble	<i>Walk away</i>

Buy-side DD vs. Vendor DD (VDD)

	BUY-SIDE DD	VENDOR DD
Quién la encarga	El comprador	El vendedor
Objetivo	Detectar riesgos para protegerse	Ordenar la casa y agilizar la venta
Cuándo	Tras la LOI	Antes de salir al mercado
Uso del reporte	Negociar precio y SPA	Entregar a posibles compradores

Full report vs. Red flag report

	FULL REPORT	RED FLAG REPORT
Contenido	Exhaustivo, área por área	Solo riesgos relevantes
Extensión	Larga	Ejecutiva
Uso típico	Deals grandes/complejos	La mayoría de los deals modernos

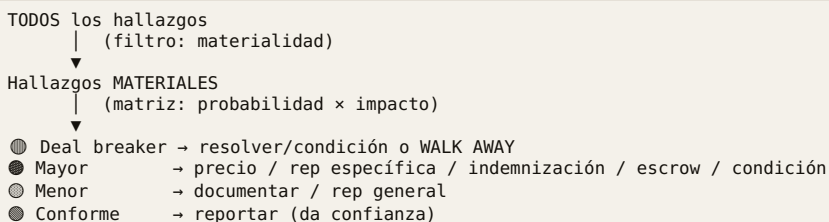
38. Diagramas

Ciclo de la due diligence:

SCOPING (alcance + materialidad)

- REQUEST LIST (solicitud de información)
- DATA ROOM (el vendedor carga; el comprador accede)
- REVISIÓN + Q&A (encontrar y aclarar el riesgo)
- DD REPORT (hallazgo → riesgo → impacto → recomendación)
- TRADUCCIÓN AL SPA (precio, reps, indemnización, escrow, condiciones)
- [signing] → DD CONFIRMATORIA / bring-down → [closing]

Embudo de jerarquización del riesgo:



39. Mnemotecnias

- **Las 3 preguntas de la DD:** "¿**QUÉ** compro, **CUÁNTO** vale, qué **RIESGOS** trae?"
- **El proceso (SRDRRT):** Scope · Request list · Data room · Revisión+Q&A · Report · Traducción al SPA.
- **La regla de oro:** "la DD investiga, las reps reparten, el escrow asegura, la condición exige, el walk away salva".
- **Materialidad:** "no todo importa; importa lo material" (cuánto + naturaleza).
- **Riesgo conocido vs. desconocido:** "lo desconocido → rep general; lo conocido → indemnización especial".
- **Competidores:** "entre competidores, clean team o gun jumping".
- **El gran error:** "hallazgo sin cláusula = trabajo perdido".

40. Resumen ejecutivo

La **due diligence** es la investigación previa y sistemática mediante la cual el comprador descubre **qué está comprando realmente**: cuánto vale la *target* y qué riesgos esconde. Nació como una **defensa de responsabilidad** en el derecho bursátil estadounidense (Securities Act de 1933) y se transformó en la **herramienta central de gestión de riesgo** del M&A moderno. Es multidisciplinaria —corporativa, contractual, fiscal, financiera (con la *Quality of Earnings*), laboral, regulatoria, de competencia, ambiental, de PI, de tecnología y datos, de compliance y de litigios— y la coordina el abogado de M&A, que **integra** los hallazgos en una visión de riesgo única.

Su proceso es ordenado e iterativo: definir el **alcance y la materialidad**, emitir la **request list**, poblar y revisar el **data**

room (hoy virtual, con su dinámica de **Q&A**), levantar y **jerarquizar los red flags** (deal breaker / mayor / menor, según una matriz de probabilidad × impacto), consolidarlos en un **DD report** ejecutivo y orientado a la decisión, y —la lección capital del libro— **traducir cada hallazgo en una protección contractual**: ajuste de precio, *representation* específica, indemnización especial, *escrow*, condición al *closing*, exclusión del perímetro o, en el extremo, el *walk away*. La due diligence que no se traduce al SPA es trabajo perdido.

Para el lector, este libro es la **competencia operativa** que más temprano se le exigirá y la que más acelera una carrera en M&A. Conecta hacia atrás con **todo** el programa (sociedades, contratos, responsabilidad, garantías, gobierno corporativo, competencia, fiscal, laboral) y hacia adelante con la **documentación** (Libro 4: el SPA y sus reps, indemnización y *disclosure schedules*) y con las **estructuras** (Libro 3: cómo un hallazgo empuja de *share* a *asset deal*). Dominar la due diligence es empezar a **pensar como un abogado de transacciones**: no describir documentos, sino **buscar el riesgo, valorarlo y asignarlo**.

41. Checklist

Antes de abrir el data room (scoping):

- [] ¿Está definido el **alcance** por áreas y la **materialidad** (cuantitativa y cualitativa)?
- [] ¿La DD es **proporcional** al tamaño y al riesgo del deal y a la **tesis** del comprador?
- [] ¿Hay **equipo, calendario y presupuesto** y una *request list* adaptada al deal?

Durante la revisión:

- [] **Titularidad**: ¿el vendedor es realmente dueño de las acciones/activos? ¿Las acciones están bien emitidas y pagadas?
- [] **Change of control**: ¿qué contratos clave se caen o renegocian al cambiar el dueño?

- [] **QoE:** ¿las utilidades son **recurrentes y reales**? ¿Hay deuda oculta o pasivos contingentes?
- [] **Fiscal/laboral/ambiental:** ¿contingencias materiales (EFOS, subcontratación, contaminación)?
- [] **Permisos:** ¿vigentes y **transferibles**? ¿La operación requiere autorización (COFECE/sectorial)?
- [] **Compliance:** ¿exposición a corrupción/lavado? (riesgo de responsabilidad heredada)
- [] ¿Leíste las **ausencias** y las aclaraste por **Q&A**? ¿Cuidaste **privilegio** y *clean teams*?

Al cerrar la DD:

- [] ¿El **DD report** está jerarquizado (deal breaker / mayor / menor) y orientado a la decisión?
- [] Para cada *red flag* mayor: ¿definiste la **herramienta** (precio, rep, indemnización, escrow, condición, exclusión)?
- [] ¿Previste la **DD confirmatoria** entre *signing* y *closing* (bring-down + MAC)?

42. Bibliografía comentada

- **American Bar Association, *Model Stock Purchase Agreement with Commentary*.** Imprescindible para ver cómo los hallazgos de la DD se convierten en reps, indemnización y *disclosure schedules*.
- **Securities Act de 1933 (EE.UU.), §11 — la *due diligence defense*.** La fuente histórica del concepto: la investigación razonable como eximente de responsabilidad.
- **FCPA Resource Guide (DOJ/SEC).** El estándar global sobre **DD anticorrupción** en adquisiciones y la sucesión de responsabilidad. Lectura obligada para compliance.
- **Jurisprudencia de Delaware (*Akorn v. Fresenius* —MAC—; *Smith v. Van Gorkom* —deber de informarse—).** Cómo la DD se conecta con el derecho del consejo y con la salida del deal.
- **Ley Federal de Competencia Económica y guías de la COFECE.** Concentraciones, *gun jumping* y manejo de información sensible (*clean teams*) durante la DD.

- **Código Fiscal de la Federación, art. 69-B** ☞ (operaciones simuladas). El núcleo del riesgo de la DD fiscal en México.
- **Doctrina civil sobre buena fe, dolo y saneamiento (CCF)**. La red de seguridad que el derecho mexicano añade a las protecciones contractuales.
- **Practical Law / PLC y manuales de DD de los grandes despachos**. Los *checklists* y *precedents* de mercado, herramienta de trabajo diario.

43. Ruta hacia el siguiente libro

Ya sabes **investigar lo que se compra y traducir el riesgo en protección**. El siguiente paso es entender en detalle las **arquitecturas jurídicas** mediante las cuales se ejecuta la transacción: cómo, exactamente, se compra y se combina una empresa.

- **Siguiente libro:** *Libro 3 · Estructuras: fusiones, escisiones y adquisiciones* — el desarrollo a fondo del *share deal*, el *asset deal*, la **fusión** (por absorción y por integración), la **escisión**, y las reestructuras; sus requisitos corporativos (LGSM), efectos, derechos de los acreedores y de las minorías, y consecuencias fiscales. Es el "cómo" jurídico de lo que en el Libro 1 viste como mapa.
- **Conexión inmediata:** en este Libro 2 aprendiste que un **hallazgo de la DD empuja la elección de estructura** (un riesgo alto de pasivos ocultos favorece el *asset deal*; la necesidad de continuidad de contratos y permisos favorece el *share deal* o la fusión). El Libro 3 te dará el dominio técnico de cada estructura para tomar —y ejecutar— esa decisión con maestría.

◆ ¿Por qué esto importa para un abogado corporativo?

Porque la due diligence es la **primera competencia real** que un despacho de M&A le exige a un abogado, y la que **más valor medible** aporta al cliente. Cada riesgo que el abogado detecta y traduce en protección contractual es dinero ahorrado; cada riesgo que se le escapa, una pérdida que el cliente

sufrirá después del *closing*, cuando ya no hay remedio fácil. Un solo pasivo fiscal o ambiental no detectado puede valer más que la empresa entera. Además, la DD es **transversal**: la misma habilidad se usa en una adquisición, una venta, un financiamiento, una inversión de VC/PE, una salida a bolsa y un programa de compliance. Quien domina la due diligence tiene una herramienta que usará toda su carrera y desarrolla, de paso, el músculo mental que define al gran abogado de transacciones: **ver el riesgo donde otros ven papeles**.

♦ Cómo piensa un socio de un despacho internacional

*"Cuando dirijo una due diligence, no busco 'revisar todo' —eso es imposible y nadie lo paga—. Busco el riesgo que mueve la aguja. Lo primero que pregunto a mi equipo es: '¿qué tres cosas, si están mal, hacen que mi cliente NO compre o pague mucho menos?' Eso ordena el trabajo. Vivo obsesionado con tres áreas: la titularidad (¿de verdad es dueño de lo que vende?), la calidad de las utilidades (¿estos números son reales y recurrentes, o están maquillados?) y el **change of control** (¿el activo se evapora justo cuando compramos?). Y exijo a cada asociado la misma disciplina: no quiero un reporte de 300 páginas con todo lo que encontraron; quiero tres niveles —lo que mata el deal, lo que repreciamos o blindamos, y lo que solo documentamos— y, para cada riesgo mayor, la cláusula que lo resuelve. Un hallazgo sin cláusula es trabajo perdido. La due diligence no termina cuando entiendo el riesgo; termina cuando lo traduje en una protección que mi cliente pueda cobrar."*

♦ Errores que cuestan millones

1. **DD financiera superficial (el síndrome HP-Autonomy).** Pagar un múltiplo alto sin verificar la *Quality of Earnings* y descubrir después que los ingresos estaban inflados. *Prevención:* QoE rigurosa; ninguna prisa por cerrar justifica no verificar los números.
2. **Ignorar el *change of control*. No detectar que los contratos o permisos clave se cancelan al cambiar el dueño, y comprar una empresa que se vacía de valor el día del *closing*. Prevención: mapearlos y volverlos condición al *closing* (consentimientos).**

3. **DD de compliance ausente.** No investigar la corrupción y **heredar** responsabilidad penal y regulatoria (FCPA). *Prevención:* DD anticorrupción rigurosa y remediación documentada; "no investigué" agrava la sanción.
4. **No traducir los hallazgos al contrato.** Detectar el riesgo y no convertirlo en rep, indemnización especial, *escrow* o condición: el comprador termina pagando un riesgo que **sí** se había visto. *Prevención:* para cada *red flag* mayor, define la herramienta de la sección 14.E.
5. **Intercambiar información sensible entre competidores sin *clean team*.** Revisar precios y clientes del competidor antes de la autorización y caer en *gun jumping* informativo (multas de competencia). *Prevención:* *clean teams* y conclusiones agregadas hasta el *closing*.

Cierre del Libro 2. Has aprendido a **mirar antes de comprar:** a investigar la empresa por dentro, jerarquizar el riesgo y —lo esencial— **traducir cada hallazgo en una protección contractual.** La due diligence es la bisagra entre conocer la realidad de la *target* y plasmarla en el contrato; conecta todo lo que estudiaste (sociedades, contratos, responsabilidad, gobierno, competencia, fiscal, laboral) en una sola habilidad práctica de élite. Con el mapa del M&A (Libro 1) y el arte de la due diligence (Libro 2) en tu poder, estás listo para dominar las **arquitecturas de la transacción.** Avanzamos al **Libro 3 · Estructuras: fusiones, escisiones y adquisiciones**, donde aprenderás, con precisión técnica, **cómo** se compra y se combina una empresa.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE IV

[Nivel IV · Libro 3] Estructuras de la Operación: Fusiones, Escisiones y Adquisiciones

☞ **Apóstrofe de vigencia** — **léela cada vez**. El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ./. /fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

El Libro 1 te dio el **mapa** del M&A y el Libro 2, el arte de **mirar antes de comprar**. Este libro responde la pregunta técnica de la que depende toda la ejecución: **¿con qué arquitectura jurídica se hace la operación?** Comprar acciones (*share deal*), comprar activos (*asset deal*), **fusionar** dos sociedades, **escindir** una empresa en varias, reorganizar un grupo: cada estructura tiene requisitos, efectos, protecciones de acreedores y minorías y consecuencias fiscales **distintas**. Elegir la estructura correcta — y ejecutarla con precisión— es lo que separa al abogado que "sabe de M&A" del que de verdad **arma transacciones**. Aquí construimos ese dominio técnico.

Etiquetas: corporate law · M&A · estructuras · share deal · asset deal · fusión · escisión · reestructuración · LGSM **Prerrequisitos:** Libro 1 · Fundamentos de M&A + Libro 2 · Due Diligence + **Nivel III** (sobre todo Sociedades/LGSM y Gobierno Corporativo) + Obligaciones y Garantías. **Estándar:** V3 (43 secciones + secciones transversales). ⌚ **Tiempo estimado de dominio:** 5–6 semanas (≈ 55–65 h de estudio activo). Lectura de reconocimiento: 10–12 h. *Estúdialo en bloques:* share vs. asset deal → fusión → escisión → reestructuras y holdings → criterios de elección (los cuatro ejes).

Aviso de método. Tratado, no repaso. Aquí aprenderás a **diseñar la arquitectura** de una transacción: no solo qué es una fusión, sino **cuándo** conviene, **cómo** se ejecuta paso a paso, a **quién** protege la ley (acreedores, minorías) y **qué consecuencias** fiscales y de continuidad tiene. Cada estructura se conecta con la due diligence (Libro 2) y con el contrato (Libro 4).

NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL (VISTA RÁPIDA)

Litigio	★★★☆☆
Corporate	★★★★★
M&A	★★★★★
Mercado de Valores	★★★★☆
Venture Capital	★★★★☆
Private Equity	★★★★★
Gobierno Corporativo	★★★★☆
Compliance	★★★☆☆
Derecho Bancario	★★★★☆
Empresa Familiar	★★★★★

Es el dominio técnico-societario que distingue al abogado corporativo: saber elegir y ejecutar la estructura óptima define el éxito (fiscal, de riesgo y de continuidad) de cada operación. Indispensable en M&A, PE y reorganización de grupos y empresas familiares.

1. Introducción

Toda operación de M&A debe **encarnar** en una estructura jurídica concreta. No existe "comprar una empresa" en abstracto: existe **comprar sus acciones, comprar sus activos, fusionarla** con otra, **escindirla**, o combinar varias de estas figuras en una reorganización. La estructura es el **vehículo jurídico** que transporta la operación de la intención al resultado, y la elección entre una y otra **no es un tecnicismo**: determina qué se adquiere, qué pasivos se heredan, qué autorizaciones se necesitan, cuántos impuestos se pagan, qué derechos tienen los acreedores y los socios minoritarios, y si los contratos y permisos de la empresa **continúan** o no.

En el Libro 1 conociste las tres grandes familias de estructura (*share deal*, *asset deal* y fusión) a vista de pájaro, como parte del mapa. En el Libro 2 viste que **un hallazgo de la due diligence puede empujar la elección de una**

estructura u otra (un riesgo alto de pasivos ocultos favorece el *asset deal*; la necesidad de conservar contratos y permisos favorece el *share deal* o la fusión). Ahora toca **bajar al detalle técnico**: entender cada estructura por dentro —sus requisitos en la **LGSM**, su proceso paso a paso, sus efectos jurídicos, sus protecciones y sus consecuencias fiscales— para poder **diseñar y ejecutar** la operación, no solo describirla.

La idea rectora del libro: **la estructura es una decisión de ingeniería jurídica que equilibra cuatro ejes** —riesgo (pasivos), continuidad (contratos y permisos), fiscalidad y autorizaciones—. No hay una estructura "mejor" en abstracto; hay una **óptima para cada operación**, que resulta de ponderar esos cuatro ejes a la luz de los hechos del caso y de los objetivos del cliente. El abogado que domina este equilibrio es quien de verdad **arma deals**.

2. Objetivos del libro

Al terminar, el lector será capaz de:

- **Distinguir con precisión** las grandes estructuras —*share deal*, *asset deal*, **fusión** (por absorción y por integración) y **escisión**— y explicar la lógica jurídica y económica de cada una.
- **Ejecutar** mentalmente, paso a paso, una **fusión** y una **escisión** conforme a la **LGSM**: acuerdos, formalidades, publicación, derecho de oposición de acreedores, efectos.
- **Comprender** el régimen de **protección de acreedores** (derecho de oposición, responsabilidad solidaria) y de **minorías** (derecho de separación, *appraisal rights*) en las reorganizaciones.
- **Analizar** la **transmisión** en cada estructura: qué se transfiere automáticamente (sucesión universal) y qué requiere consentimiento o cesión individual.
- **Identificar** las consecuencias **fiscales** básicas de cada estructura (sin sustituir al asesor fiscal) y por qué la fiscalidad suele decidir la estructura.

- **Aplicar los cuatro ejes de elección** (riesgo, continuidad, fiscalidad, autorizaciones) a un caso concreto para recomendar la estructura óptima.
- **Conectar** la estructura con la due diligence (Libro 2) y con la documentación (Libro 4): cómo los hallazgos empujan la estructura y cómo la estructura determina el contrato (SPA vs. APA vs. convenio de fusión).

3. Importancia profesional

La elección y ejecución de la estructura es **el núcleo técnico del trabajo del abogado corporativo** en una operación. Mientras que el financiero define el precio y el contador la fiscalidad, es el **abogado** quien diseña y ejecuta la **arquitectura jurídica** que hace posible (y eficiente) la transacción. Es un trabajo de **ingeniería**: combinar figuras societarias (fusiones, escisiones, aportaciones, constituciones de *holdings*) para llegar al resultado deseado con el menor riesgo, el menor costo fiscal y la mayor continuidad del negocio.

Esta competencia es la que más distingue al abogado **transaccional** del litigante o del generalista. Un abogado que solo "redacta contratos" puede documentar una compraventa de acciones; pero **diseñar** una operación compleja —digamos, reorganizar un grupo familiar para separar dos negocios, meter a un fondo en uno de ellos y dejar listo el otro para una venta futura, todo de forma fiscalmente eficiente— exige dominar las estructuras a fondo. Ese es el trabajo de alto valor (y altos honorarios) de los socios de M&A y de reorganización corporativa.

Además, las estructuras son **transversales**: la misma caja de herramientas (fusión, escisión, *asset deal*, *holding*) se usa en M&A, en *private equity* (armar el vehículo de adquisición, el *NewCo* del LBO), en reorganización de grupos, en planeación patrimonial de empresas familiares y en preparación para una venta o una salida a bolsa. Quien domina las estructuras tiene una habilidad que aplicará en **toda** su práctica corporativa.

4. Historia y origen

Las estructuras de reorganización empresarial nacen con la propia **sociedad de capitales** y se desarrollan al ritmo de la economía industrial. La **fusión** —la combinación de dos o más sociedades en una— es tan antigua como la necesidad de las empresas de **crecer por concentración** en lugar de solo por crecimiento orgánico. En el siglo XIX, con la expansión del ferrocarril, la banca y la industria pesada en Europa y Estados Unidos, las fusiones se volvieron el motor de la concentración empresarial (las grandes "olas de fusiones" estadounidenses de finales del XIX y principios del XX).

La **escisión** —la operación inversa: dividir una sociedad en dos o más— es una figura más **moderna**, desarrollada plenamente en el siglo XX a medida que los grandes grupos necesitaban **separar** negocios, desconcentrar, especializar o preparar la venta de una unidad. En muchos ordenamientos (México incluido), la escisión se reguló expresamente bastante después que la fusión.

La distinción entre **comprar acciones y comprar activos** (*share deal* vs. *asset deal*) se afina con la práctica transaccional moderna del siglo XX, especialmente en el mundo anglosajón, donde los compradores —y sus abogados— desarrollaron una conciencia fina sobre la diferencia de **riesgo y de fiscalidad** entre adquirir la "envoltura" (la sociedad, con todo su pasado) o solo su "contenido" (los activos seleccionados).

En México, la **Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) de 1934** reguló la **fusión** desde el principio; la **escisión** se incorporó expresamente a la LGSM mediante reforma en **1992**, reflejando la modernización del derecho societario mexicano y la creciente sofisticación de las reorganizaciones empresariales en el contexto de la apertura económica.

5. Evolución histórica

La evolución de las estructuras de M&A puede leerse en tres movimientos:

1) De la fusión simple a la ingeniería de reorganización.

Al principio, las operaciones eran relativamente directas: una empresa absorbía a otra. Con el tiempo, y sobre todo con el auge de los **grupos de sociedades** (holdings, subsidiarias, conglomerados), las reorganizaciones se volvieron **arquitecturas complejas**: cadenas de fusiones y escisiones, creación de *holdings*, aportaciones de activos a nuevas sociedades, etc. El abogado pasó de "documentar una fusión" a **diseñar reorganizaciones multinivel**.

2) **La irrupción de la lógica fiscal.** A medida que los sistemas tributarios se sofisticaron, la **fiscalidad** se convirtió en el principal **conductor** de la elección de estructura. Aparecieron los regímenes de **neutralidad fiscal** (fusiones y escisiones que, cumpliendo requisitos, no generan impuesto porque se consideran reorganizaciones y no enajenaciones gravadas) y, en paralelo, las reglas **antiabuso** para evitar que estas figuras se usen solo para eludir impuestos. Hoy, ninguna estructura se diseña sin el asesor fiscal al lado.

3) **La estructura como herramienta de gestión de riesgo y de deal-making.** Con la maduración del M&A, la estructura dejó de ser solo "cómo se transfiere la propiedad" para convertirse en una **herramienta estratégica**: aislar pasivos (asset deal), crear vehículos de adquisición apalancada (NewCo en los LBO de *private equity*), separar negocios para venderlos por partes, blindar activos, preparar salidas a bolsa. La estructura se integró con la **due diligence** (los hallazgos la moldean) y con la **negociación** (la estructura asigna riesgo tanto como las reps).

6. Contexto económico

Económicamente, las estructuras de M&A responden a la lógica de **maximizar el valor neto de la operación para las partes**, lo que implica minimizar tres "fugas" de valor: el **riesgo** (pasivos heredados), los **impuestos** (el costo fiscal de la

transacción) y los **costos de fricción** (autorizaciones, tiempo, pérdida de contratos y permisos).

- **Eje de riesgo:** el *asset deal* permite **dejar atrás** los pasivos ocultos (el comprador escoge qué activos lleva), mientras que el *share deal* y la fusión los **heredan** (se adquiere la sociedad con todo su pasado). Económicamente, el riesgo de pasivos ocultos tiene un **precio**: cuanto mayor sea, más valioso es aislarlo.
- **Eje fiscal:** la diferencia de impuestos entre estructuras puede ser **enorme** y, a menudo, decide la operación. Las fusiones y escisiones pueden gozar de **neutralidad fiscal** (no gravarse) si cumplen requisitos; un *asset deal* puede generar impuestos sobre la ganancia en la venta de cada activo y otros gravámenes (p. ej., sobre inmuebles). El valor de la operación cambia según quién soporta esos impuestos.
- **Eje de continuidad:** los contratos, permisos, concesiones y relaciones laborales tienen **valor económico**; perderlos (porque no se transfieren, o porque se activa un *change of control*) destruye valor. El *share deal* y la fusión preservan la continuidad (la sociedad sigue siendo la misma o sucede universalmente); el *asset deal* obliga a **re-contratar** o ceder, con riesgo de pérdida.

La estructura óptima es la que **maximiza el valor combinado** considerando estos tres ejes (más las autorizaciones), no la que minimiza una sola variable. Un abogado que solo piensa en aislar el riesgo puede recomendar un *asset deal* que dispare los impuestos y haga perder contratos clave: el equilibrio, no el extremo, es la respuesta económica correcta.

Por qué existen tantas figuras, dicho en una línea. La elección de estructura es un problema de **minimización de costos totales** en cuatro monedas simultáneas: fiscales, de transferencia (consentimientos de terceros y cláusulas de *change of control*), de asunción de pasivos y regulatorios. Y la razón de que coexistan la fusión, la escisión, el *share deal*, el *asset deal* y la aportación es que **ninguna domina en todos los escenarios**: cada figura internaliza uno de esos costos y ex-

ternaliza otro. No hay una estructura mejor; hay una estructura mejor **para este caso**.

Y por qué el derecho concede la neutralidad fiscal. Gravar una reorganización que no realiza valor económico real —que solo reordena la propiedad de los mismos activos— equivaldría a poner un **impuesto a la reasignación**: desincentivaría operaciones eficientes. En clave de Coase, el sistema procura no interferir con la migración de los activos hacia su uso más valioso. De ahí el límite natural del beneficio: cuando la operación **solo** persigue el efecto fiscal y no reordena nada económicamente real, la sustancia se vuelve el filtro. En México ese filtro tiene nombre y artículo:

Artículo 50.-A del Código Fiscal de la Federación ☞ ✓ (*cotejado verbatim contra el texto oficial en fuentes-legales/*):

"Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente."

Es la **razón de negocios** convertida en norma general antiabuso, y es la frontera que todo diseño de estructura debe poder cruzar con la cabeza en alto. Se desarrolla en Fiscal Corporativo.

7. Contexto político y regulatorio

Las estructuras de reorganización están condicionadas por varios marcos regulatorios que el abogado debe mapear desde el inicio:

- **Competencia económica (COFECCE).** Las concentraciones —incluidas fusiones y adquisiciones de control— que superen los umbrales deben **notificarse** y no consumarse antes de la autorización (*gun jumping*, Libro 1). La estructura puede afectar si la operación es o no notificable.
- **Régimen fiscal (LISR, CFF).** El Estado regula con detalle las fusiones y escisiones para otorgarles **neutralidad fiscal** solo si cumplen requisitos (permanencia de los socios, continuidad del negocio, avisos), y para **combatir el abuso** (reorganizaciones simuladas para eludir impuestos). La política fis-

cal es, quizá, el regulador más determinante de la estructura.

- **Sectores regulados y autorizaciones de cambio de control.** En banca, seguros, energía, telecom, transporte, etc., una fusión o un cambio de control puede requerir **autorización del regulador sectorial**, y ciertas concesiones tienen reglas especiales de transmisión o reversión.
- **Inversión extranjera.** La Ley de Inversión Extranjera limita o condiciona la participación foránea en ciertas actividades; la estructura debe respetar esos límites (a veces obliga a usar vehículos o fideicomisos específicos).
- **Mercado de valores (LMV).** Si la *target* es una emisora, la reorganización interactúa con el régimen de OPAs, revelación e información privilegiada.

8. Contexto social

Aunque las estructuras parezcan pura técnica societaria y fiscal, tienen efectos sociales reales. **Primero, sobre los trabajadores:** en una fusión, las relaciones laborales suelen **continuar** (la sociedad fusionante sucede a la fusionada, con sus obligaciones laborales); en un *asset deal*, la suerte de los trabajadores depende de si hay **sustitución patronal** o si se les recontrata, lo que genera ansiedad e incertidumbre. El abogado debe manejar estos efectos con cuidado técnico y humano.

Segundo, sobre los acreedores: las reorganizaciones pueden **alterar la garantía** de quienes prestaron a la sociedad (si una escisión se lleva los activos y deja las deudas en otra parte, el acreedor se perjudica). Por eso la ley los protege con el **derecho de oposición** y con la **responsabilidad solidaria**: un equilibrio social entre la libertad de reorganización de la empresa y la protección de quienes confiaron en ella.

Tercero, sobre los socios minoritarios: una fusión o escisión decidida por la mayoría puede **cambiar sustancialmente** la inversión del minoritario (lo mete en una sociedad distinta, con otro negocio y otro riesgo). El **derecho de separación** (poder salirse y que le paguen sus acciones) es la protección social del minoritario frente a decisiones estructurales que no com-

partió. Estas tensiones —empresa vs. acreedores, mayoría vs. minoría— son el trasfondo social de toda reorganización.

9. Contexto empresarial

Desde la óptica de la empresa, las estructuras son **herramientas para lograr objetivos de negocio** muy diversos:

- **Crecer por concentración (fusión).** Combinar dos empresas para ganar escala, sinergias, mercado o capacidades. Es la herramienta del crecimiento inorgánico.
- **Adquirir control (share deal) o activos selectos (asset deal).** Tomar una empresa entera, o solo la parte que interesa (una línea de negocio, una planta, una cartera), dejando el resto.
- **Separar y enfocar (escisión).** Dividir un negocio en partes para especializar, desconcentrar, resolver conflictos entre socios, o **preparar la venta** de una unidad sin vender el resto (la escisión como paso previo a una venta —*carve-out*—).
- **Organizar el grupo (holdings y reestructuras).** Crear una sociedad *holding* que controle a las operativas, separar activos valiosos (inmuebles, marcas) en sociedades distintas para protegerlos, ordenar la cadena de control de un grupo familiar o multinacional.
- **Construir el vehículo de adquisición (PE/LBO).** Los fondos de *private equity* crean una sociedad nueva (*NewCo*) que toma la deuda del LBO y adquiere o se fusiona con la *target* (la fusión apalancada).
- **Planear la sucesión patrimonial (empresa familiar).** Usar escisiones y *holdings* para repartir el patrimonio entre ramas familiares, blindar activos y ordenar la sucesión.

La elección de estructura es, por tanto, una decisión que el abogado toma **conversando con el negocio**: ¿qué quiere lograr el cliente, con qué riesgo tolera, con qué horizonte, con qué costo fiscal aceptable? La respuesta técnica (share, asset, fusión, escisión, o una combinación) sirve a un **objetivo empresarial** concreto. El gran abogado de estructuras traduce el

objetivo de negocio en la arquitectura jurídica que lo realiza de la forma más eficiente y segura.

10. Definiciones doctrinales

La doctrina societaria y transaccional define las figuras centrales así (apréndelas con rigor; son el vocabulario técnico del libro):

- **Adquisición (*acquisition*):** operación por la cual una persona o entidad **toma el control** de una empresa, sea comprando sus **acciones/partes sociales** (*share deal*) o sus **activos** (*asset deal*). La doctrina subraya que lo característico es la **transferencia de control**, no la combinación de patrimonios.
- **Share deal (compraventa de acciones):** adquisición en la que el comprador compra las **acciones o partes sociales** de la *target*, adquiriendo así la **sociedad completa** —su patrimonio, sus contratos, sus permisos y **todos sus pasivos, conocidos u ocultos**—. La sociedad sigue siendo la misma persona jurídica; solo cambian sus dueños.
- **Asset deal (compraventa de activos):** adquisición en la que el comprador compra **activos determinados** (y, en su caso, asume pasivos determinados) **seleccionados** del patrimonio de la *target*, dejando el resto (incluidos los pasivos no asumidos) en la sociedad vendedora. No se adquiere la sociedad, sino una parte (o la totalidad) de su **contenido**.
- **Fusión (*merger*):** operación por la cual **dos o más sociedades se integran en una sola**, transmitiéndose en bloque (**sucesión universal**) el patrimonio de la(s) sociedad(es) que desaparece(n) a la que subsiste o a una nueva, y pasando sus socios a ser socios de la sociedad resultante. La doctrina distingue la **fusión por absorción** (una subsiste y absorbe a la otra) de la **fusión por integración o pura** (todas desaparecen y nace una nueva).
- **Escisión (*spin-off / division*):** operación inversa a la fusión: una sociedad (**escidente**) **divide** la totalidad o parte de su patrimonio y lo transmite en bloque a una o varias sociedades nuevas o existentes (**escindidas o beneficia-**

rias). La doctrina distingue la **escisión total** (la escidente desaparece y reparte todo su patrimonio) de la **escisión parcial** (la escidente subsiste y solo segrega una parte).

- **Reestructuración / reorganización corporativa:** término amplio que designa cualquier **rediseño de la estructura jurídica** de una empresa o grupo (fusiones, escisiones, aportaciones, creación de holdings, etc.) para lograr objetivos de eficiencia, riesgo, fiscalidad o sucesión.
- **Sucesión universal vs. sucesión particular:** concepto doctrinal clave. En la **sucesión universal** (fusión, escisión) el patrimonio se transmite **en bloque, automáticamente**, sin necesidad de transferir cada bien o contrato uno por uno. En la **sucesión particular** (asset deal) cada activo y cada contrato debe transmitirse **individualmente**, con sus formalidades y, a veces, con el consentimiento de la contraparte.

11. Definiciones legales y marco normativo

El marco normativo mexicano de las estructuras se asienta, principalmente, en la **LGSM** (para fusión y escisión) y en el **derecho común de los contratos** (para las compraventas de acciones y de activos), complementado por la legislación fiscal:

- **Fusión — LGSM, artículos 222 ☞ a 226.** La ley regula: el **acuerdo de fusión** por cada sociedad (asamblea extraordinaria), su **inscripción** en el Registro Público de Comercio y **publicación**; la regla de que la fusión surte efectos **tres meses** después de la inscripción, salvo que se pague a los acreedores, se obtenga su consentimiento o se deposite el importe de las deudas (mecanismo de **protección de acreedores**); el **derecho de oposición** judicial de los acreedores durante ese plazo; y la **transmisión** del patrimonio a la sociedad fusionante. La fusión puede surtir efectos de inmediato si se cumplen las condiciones de pago/garantía a acreedores.
- **Escisión — LGSM, artículo 228 Bis ☞** (incorporado en 1992). Regula con detalle: el **acuerdo de escisión** (asamblea extraordinaria con mayoría reforzada), su contenido obligatorio (descripción de la forma de repartir activos, pasivos y

capital), su **publicación y resoluciones**, el **derecho de oposición** de acreedores (plazo de 45 días naturales desde la última publicación/inscripción), el **derecho de los socios** y la **responsabilidad solidaria** de las sociedades escindidas frente a los acreedores durante cierto periodo.

- **Compraventa de acciones (*share deal*):** se rige por el **Código de Comercio** y supletoriamente por el **Código Civil** (compraventa), más las reglas de la **LGSM** y de la **LMV** sobre transmisión de acciones (endoso e inscripción en el libro de registro de accionistas para las nominativas; régimen especial para acciones de S.A.B.). El contrato típico es el **SPA** (*Share Purchase Agreement*), que estudiarás a fondo en el Libro 4.
- **Compraventa de activos (*asset deal*):** se rige por las reglas de la **compraventa** y de la **cesión** de cada tipo de bien o derecho (inmuebles con sus formalidades registrales; cesión de contratos con consentimiento de la contraparte cuando se requiera; cesión de créditos con notificación al deudor; transmisión de PI con sus registros). El contrato típico es el **APA** (*Asset Purchase Agreement*).
- **Régimen fiscal — LISR y CFF.** Establece los **requisitos para la neutralidad fiscal** de fusiones y escisiones (que no se consideren enajenación gravada si cumplen condiciones de permanencia y continuidad, avisos y, en su caso, autorización), y las reglas **antiabuso**. El CFF regula los avisos y efectos fiscales de estas reorganizaciones.

Nota de método: la numeración y el contenido exacto de los artículos de la LGSM y de la legislación fiscal deben **verificarse en el texto vigente** antes de aplicarlos profesionalmente (Manifiesto XI.5). Aquí los citamos con fines didácticos para que ubiques **dónde vive** cada figura.

12. Definición sencilla

Imagina que las empresas son **edificios de Lego**.

- **Share deal (comprar acciones):** compras el **edificio completo, tal como está** —con todos sus cuartos, su instalación eléctrica, sus tuberías y también sus **fugas y grietas ocultas**

—. Te quedas con el edificio entero, lo bueno y lo malo, porque compraste la **escritura** del edificio (las acciones). El edificio no se movió: solo cambió de dueño.

- **Asset deal (comprar activos):** no compras el edificio; compras **solo las piezas que te interesan** —estas habitaciones sí, el sótano con humedad no—. Te llevas las piezas buenas y **dejas atrás** las grietas y los problemas. Pero como te llevas pieza por pieza, tienes que **desmontar y volver a montar** (transferir cada activo, pedir permiso para mudar ciertos contratos): más trabajo, pero más limpio.
- **Fusión (merger):** tomas **dos edificios y los unes en uno solo**. Las piezas de ambos se combinan en una sola construcción, y los dueños de los dos edificios pasan a ser **codueños** del edificio combinado. Uno de los edificios "desaparece" como tal (sus piezas pasan al otro) —eso es la **sucesión universal**: todo pasa en bloque, automáticamente—.
- **Escisión (spin-off):** tomas **un edificio grande y lo divides en dos** —separas el ala de oficinas del ala de bodegas, y cada una se vuelve un edificio independiente—. Sirve para separar negocios que estaban juntos, por ejemplo para vender uno y quedarte el otro.

La pregunta de siempre: *¿me conviene llevarme el edificio entero (con sus grietas), solo las piezas buenas, unir dos edificios, o partir uno en dos?* Eso es elegir la **estructura**.

13. Conceptos fundamentales

Fija estos conceptos; se usan en todo el libro y en la práctica diaria del M&A:

- **Share deal / Asset deal:** comprar la **sociedad** (acciones) vs. comprar su **contenido** (activos seleccionados). La diferencia clave: en el *share deal* se **heredan todos los pasivos**; en el *asset deal* se **eligen** activos y pasivos.
- **Fusión por absorción:** una sociedad (**fusionante**) subsiste y absorbe a otra(s) (**fusionada(s)**), que desaparece(n). Es la forma más común.

- **Fusión por integración (o pura):** todas las sociedades desaparecen y nace una **nueva** que recibe sus patrimonios.
- **Escisión total:** la **escidente desaparece** y reparte **todo** su patrimonio entre dos o más sociedades beneficiarias.
- **Escisión parcial:** la **escidente subsiste** y solo **segrega una parte** de su patrimonio a una o más beneficiarias.
- **Sucesión universal:** transmisión **en bloque y automática** del patrimonio (activos, pasivos, contratos) propia de la fusión y la escisión. No hay que transferir bien por bien.
- **Sucesión particular:** transmisión **individual** de cada activo/derecho, propia del *asset deal* (cada cosa con su formalidad y, a veces, consentimiento).
- **Derecho de oposición de los acreedores:** facultad de los acreedores de **oponerse judicialmente** a una fusión o escisión que perjudique su garantía, suspendiéndola hasta que se resuelva o se les pague/ garantice.
- **Responsabilidad solidaria:** en la escisión, las sociedades beneficiarias (y, en su caso, la escidente) **responden solidariamente** frente a los acreedores por las obligaciones, durante el plazo legal, para que la división del patrimonio no los perjudique.
- **Derecho de separación (*appraisal right*):** facultad del socio que **no estuvo de acuerdo** con una decisión estructural relevante (como ciertas fusiones o cambios fundamentales) de **separarse** de la sociedad y exigir el reembolso del valor de sus acciones.
- **Neutralidad fiscal:** régimen por el cual una fusión o escisión, si cumple requisitos, **no se considera enajenación gravada** (no genera impuesto inmediato), por tratarse de una reorganización y no de una venta. El gran atractivo fiscal de estas figuras.
- **Sustitución patronal:** en materia laboral, figura por la cual el nuevo titular de la empresa **sustituye** al anterior como patrón, conservando los derechos de los trabajadores. Relevante para la continuidad laboral en fusiones y *asset deals*.

- **Change of control:** cláusula (vista en el Libro 2) que permite a una contraparte terminar o renegociar un contrato si la empresa cambia de dueño. Determina la **continuidad** de los contratos según la estructura.
- **Carve-out:** segregación de una unidad o negocio de un grupo (típicamente vía escisión o *asset deal*) para venderlo o independizarlo. Operación frecuente y técnicamente exigente.
- **Holding (sociedad tenedora):** sociedad cuyo objeto principal es **poseer y controlar** las acciones de otras sociedades (operativas). Pieza central de la organización de grupos.
- **NewCo / vehículo de adquisición:** sociedad **creada específicamente** para realizar una adquisición (típica en los LBO de *private equity*: la NewCo toma la deuda y compra/se fusiona con la *target*).

Con este vocabulario fijado, entramos al **desarrollo absoluto**, donde diseccionamos cada estructura por dentro.

14. Desarrollo absoluto

Esta es la sección central. La desarrollamos en cinco bloques: **(A)** *share deal* vs. *asset deal* a fondo —la decisión más frecuente—; **(B)** la **fusión** —concepto, clases, proceso paso a paso y efectos—; **(C)** la **escisión** —concepto, clases, proceso y efectos—; **(D)** las **reestructuras y holdings** —cómo se combinan las figuras para reorganizar grupos—; y **(E)** los **criterios de elección** —los cuatro ejes que deciden la estructura óptima—. Estúdialos en orden: primero las dos formas básicas de adquirir, luego las dos grandes reorganizaciones societarias, después su combinación, y al final el método de decisión que lo integra todo.

14.A · SHARE DEAL VS. ASSET DEAL (LA DECISIÓN MÁS FRECUENTE DEL M&A)

La primera y más común disyuntiva estructural es: ¿el comprador adquiere las **acciones** de la sociedad (*share deal*) o sus **activos** (*asset deal*)? Aunque en ambos casos el comprador termina controlando un negocio, las consecuencias jurídicas

son **profundamente distintas**. Domina esta comparación: es la columna vertebral del trabajo transaccional.

Qué se adquiere y qué pasa con la persona jurídica.

- En el **share deal**, el objeto de la compra son las **acciones o partes sociales**. La **sociedad sigue siendo la misma persona jurídica** —el mismo RFC, los mismos contratos, los mismos permisos, las mismas cuentas bancarias—; lo único que cambia es **quién es su dueño**. El comprador "se pone los zapatos" del vendedor como accionista.
- En el **asset deal**, el objeto de la compra son **activos determinados** (una planta, maquinaria, inventario, marcas, una cartera de clientes, una línea de negocio). La sociedad vendedora **subsiste** y conserva lo que no vendió (incluidos, en principio, sus pasivos). El comprador adquiere **cosas**, no una sociedad.

El pasivo: la diferencia capital.

- **Share deal: se heredan TODOS los pasivos**, conocidos y ocultos, porque se compra la sociedad entera con su pasado. Una contingencia fiscal de hace tres años, un litigio que aún no estalla, una deuda contingente por un aval: todo "viene incluido". Por eso el *share deal* exige **due diligence exhaustiva** y un **blindaje contractual fuerte** (reps & warranties, indemnización, escrow) —la lección del Libro 2—.
- **Asset deal: se eligen los pasivos**. El comprador, en principio, adquiere **solo** los activos (y, en su caso, los pasivos que **expresamente** acepte asumir), dejando los demás en la sociedad vendedora. Esto permite **aislar el riesgo** de pasivos ocultos. **Pero hay excepciones importantes**: ciertos pasivos **siguen al activo o al negocio** por mandato de la ley, con independencia de lo pactado —en particular, **pasivos laborales** (sustitución patronal), **fiscales** (responsabilidad por adquisición de negociación en marcha) y **ambientales** (responsabilidad por el sitio contaminado)—. Es decir: el *asset deal* aísla **menos** de lo que el comprador ingenuo cree; el abogado debe conocer estas excepciones legales para no vender una falsa sensación de seguridad.

La transmisión: sucesión particular vs. continuidad.

- **Share deal:** como la sociedad no cambia, sus **contratos y permisos continúan automáticamente** (no hay que transferirlos uno por uno). **Excepción crítica:** las cláusulas de ***change of control***, que permiten a la contraparte terminar o renegociar el contrato precisamente porque cambió el dueño (Libro 2). Salvo esas cláusulas, la continuidad es la gran ventaja del *share deal*.
- **Asset deal:** cada activo y cada contrato debe transmitirse **individualmente (sucesión particular)**: los inmuebles con sus formalidades registrales, los créditos con notificación al deudor, los contratos con **consentimiento de la contraparte** cuando sea necesario, la PI con sus registros, los permisos —muchos de los cuales **no son transferibles** y obligan a tramitar nuevos—. Es más **trabajoso, lento y con riesgo de pérdida** (¿y si una contraparte clave no consiente la cesión?).

La fiscalidad: a menudo decide.

- **Share deal:** suele generar un **único hecho gravable** —la ganancia del vendedor por la venta de sus acciones—, con un tratamiento relativamente sencillo. El comprador, en cambio, **no actualiza** la base fiscal de los activos de la sociedad (los "hereda" con su valor fiscal histórico), lo que puede ser una desventaja a futuro.
- **Asset deal:** puede generar impuestos sobre la **ganancia en la venta de cada activo**, **IVA** sobre ciertos bienes, e impuestos locales sobre la transmisión de **inmuebles**; pero permite al comprador **actualizar la base** de los activos adquiridos (depreciar sobre el valor de compra), lo que puede ser ventajoso. El balance fiscal entre una y otra estructura es **caso por caso** y se decide con el asesor fiscal —pero es, muy a menudo, **el factor determinante**—.

Quién prefiere qué (la dinámica de negociación). Por regla general: el **vendedor** suele preferir el **share deal** (vende todo de un golpe, se desprende de los pasivos, suele tener mejor trato fiscal y no queda con una "cáscara" llena de

obligaciones); el **comprador** suele preferir el **asset deal** (elige qué lleva, aísla pasivos, actualiza base fiscal). La estructura final es resultado de esa **tensión negociadora**, mediada por la fiscalidad, el riesgo detectado en la due diligence y la importancia de la continuidad de contratos y permisos.

Cuadro síntesis (memorízalo):

CRITERIO	SHARE DEAL (ACCIONES)	ASSET DEAL (ACTIVOS)
Qué se compra	La sociedad entera	Activos seleccionados
Pasivos ocultos	Se heredan todos	Se eligen (con excepciones legales)
Continuidad de contratos/permisos	Automática (salvo <i>change of control</i>)	Cesión individual / nuevos permisos
Transmisión	No aplica (la sociedad es la misma)	Sucesión particular (bien por bien)
Complejidad de ejecución	Menor	Mayor (cesiones, consentimientos)
Fiscalidad	Un hecho gravable; sin <i>step-up</i> de base	Varios gravámenes; con <i>step-up</i> de base
Lo prefiere	El vendedor (típicamente)	El comprador (típicamente)
Pasivos que igual siguen al negocio	—	Laborales, fiscales, ambientales

Conexión con la due diligence (Libro 2): ahora ves con claridad por qué un **hallazgo** empuja la estructura. ¿La DD reveló pasivos ocultos grandes e inacotables? → empuja al **asset deal** (aislar). ¿La DD reveló que los contratos y permisos clave son intransferibles o tienen *change of control* hostil? → empuja al **share deal** o la fusión (continuidad). ¿La DD reveló un pasivo concreto y acotable? → puede quedarse en *share deal* con **indemnización especial** (no hace falta cambiar de estructura). El abogado de élite **conecta** el diagnóstico (DD) con la arquitectura (estructura) y con el blindaje (contrato).

14.B · LA FUSIÓN (CONCEPTO, CLASES, PROCESO PASO A PASO Y EFECTOS)

La **fusión** es la operación por la cual **dos o más sociedades se integran en una sola**. Es la herramienta clásica de la concen-

tración empresarial y una de las figuras más reguladas por la LGSM. Disecciónala así:

Las dos clases de fusión.

- **Fusión por absorción (o por incorporación):** una sociedad —la **fusionante**— **subsiste** y absorbe a una o varias —las **fusionadas**—, que **se extinguen** sin liquidarse. El patrimonio de las fusionadas pasa en bloque a la fusionante, y sus socios reciben acciones de la fusionante. Es la forma **más común** (p. ej., la matriz absorbe a su subsidiaria, o la empresa grande absorbe a la que compró).
- **Fusión por integración (pura o por combinación):** todas las sociedades participantes se **extinguen** y nace una **sociedad nueva** que recibe los patrimonios de todas. Se usa cuando se quiere una entidad nueva "de igual a igual" (p. ej., dos empresas de tamaño similar que se combinan creando una marca y entidad nuevas).

El rasgo jurídico esencial: la sucesión universal. En ambas clases opera la **transmisión en bloque y a título universal** del patrimonio: la sociedad que subsiste (o la nueva) adquiere **automáticamente** todos los activos, pasivos, contratos, permisos y relaciones de la(s) extinguida(s), **sin necesidad** de transferir cada bien o contrato individualmente. Esta es la **gran ventaja** de la fusión sobre el *asset deal*: la continuidad es máxima (con la salvedad, otra vez, de las cláusulas de *change of control* que algunos contratos puedan tener). La contracara: como todo pasa en bloque, también pasan **todos los pasivos** (igual que en el share deal).

El proceso de la fusión paso a paso (LGSM, arts. 222-226 c). Memoriza esta secuencia; es el esqueleto de la ejecución:

1. **Negociación y proyecto/convenio de fusión.** Las sociedades negocian las bases: quién absorbe a quién, la **relación de canje** (cuántas acciones de la fusionante recibe cada socio de la fusionada, según la valuación relativa), el tratamiento de los pasivos, la fecha de efectos. Se redacta el **convenio de fusión**.

2. **Acuerdo de cada sociedad en asamblea extraordinaria.** Cada sociedad participante debe **aprobar la fusión** en asamblea general extraordinaria de accionistas, conforme a sus estatutos y a la LGSM (la fusión modifica sustancialmente la sociedad, de ahí la asamblea extraordinaria).
3. **Inscripción en el Registro Público de Comercio y publicación.** Los acuerdos de fusión se **inscriben** en el RPC y se **publican** (con el último balance de cada sociedad y el sistema para extinguir el pasivo). La publicidad busca **proteger a los acreedores** (que se enteren y puedan reaccionar).
4. **Plazo de espera y derecho de oposición de los acreedores (la regla de los 3 meses).** Por regla general (art. 224-225 C), la fusión surte efectos **tres meses** después de la inscripción. Durante ese plazo, **cualquier acreedor** puede **oponerse judicialmente** a la fusión si considera que perjudica su garantía; la oposición **suspende** la fusión hasta que cause ejecutoria la sentencia que la declare infundada, o hasta que la sociedad pague o garantice el crédito.
5. **Efectos inmediatos (la excepción).** La fusión puede surtir efectos **de inmediato** (sin esperar los tres meses) si: se **pagan** todas las deudas de las sociedades que se fusionen, o se **deposita** su importe en una institución de crédito, o **consta el consentimiento de todos los acreedores**. En la práctica de grandes grupos con deudas manejables, esta vía acelera la operación.
6. **Extinción de las fusionadas y transmisión universal.** Cumplido el proceso, las sociedades fusionadas **se extinguen** (sin liquidación, porque su patrimonio no se reparte sino que pasa en bloque) y la fusionante (o la nueva sociedad) las **sucede universalmente**: adquiere su patrimonio y sus socios se integran a ella mediante el canje de acciones.

Efectos jurídicos de la fusión:

- **Patrimonial:** transmisión universal de activos y pasivos a la sociedad subsistente o nueva.

- **Societario:** extinción de las fusionadas; los socios de estas pasan a ser socios de la fusionante (canje de acciones según la relación de canje).
- **Frente a acreedores:** continúan siéndolo de la sociedad resultante, protegidos por el derecho de oposición y por la asunción de las deudas.
- **Laboral:** opera, en principio, la **sustitución patronal**: las relaciones laborales **continúan** con la sociedad resultante, conservándose los derechos de los trabajadores.
- **Fiscal:** puede gozar de **neutralidad fiscal** (no considerarse enajenación gravada) si cumple los requisitos de la LISR/CFF (permanencia, continuidad del negocio, avisos); de lo contrario, puede generar impuestos. **Siempre con el asesor fiscal.**

Conexión con M&A: la fusión se usa muchísimo como **paso de integración** tras una adquisición: el comprador primero **compra** la *target* (share deal) y luego la **fusiona** con su propia operación (o con una NewCo) para integrar patrimonios, simplificar la estructura y, a veces, lograr eficiencias fiscales (la célebre **fusión apalancada** de los LBO, donde la NewCo endeudada se fusiona con la *target* para que el flujo de la *target* sirva la deuda —tema del Libro 5—). También es la herramienta para las combinaciones "entre iguales" (*merger of equals*). Recuerda, además, los **deberes del consejo** al aprobar una fusión (Gobierno Corporativo: decidir informado, *fairness opinion*, manejar conflictos) y el **derecho de separación** de los socios disidentes.

14.C · LA ESCISIÓN (CONCEPTO, CLASES, PROCESO PASO A PASO Y EFECTOS)

La **escisión** es la operación **inversa** a la fusión: en lugar de combinar sociedades, **divide** una. Una sociedad (**escindente**) segrega la totalidad o parte de su patrimonio y lo transmite en bloque a una o más sociedades (**escindidas o beneficiarias**), nuevas o existentes. Es la herramienta de la **desconcentración**, la **especialización** y la **preparación de ventas** (*carve-outs*).

Las dos clases de escisión.

- **Escisión total:** la sociedad escidente **desaparece** (se extingue sin liquidarse) y **todo** su patrimonio se reparte en bloque entre **dos o más** sociedades beneficiarias. La empresa original deja de existir, transformada en varias.
- **Escisión parcial:** la escidente **subsiste** y solo **segrega una parte** de su patrimonio (típicamente una unidad de negocio, una planta, un conjunto de activos) que transmite a una o varias beneficiarias. La empresa original sigue viva, más "ligera".

El rasgo jurídico esencial: la sucesión universal parcial. Como en la fusión, en la escisión la transmisión del patrimonio segregado es **en bloque** (sucesión universal respecto del bloque transmitido): los activos, pasivos y contratos que integran la porción escindida pasan **automáticamente** a la beneficiaria, sin necesidad de cederlos individualmente. Esto distingue la escisión del *asset deal*: en la escisión, segregar un negocio **no** exige transferir activo por activo ni (en principio) pedir consentimiento contrato por contrato —lo que la hace una herramienta poderosísima para los *carve-outs*—.

El proceso de la escisión paso a paso (LGSM, art. 228 Bis c). Memoriza la secuencia:

1. **Proyecto de escisión.** Se diseña **cómo se divide** el patrimonio: qué activos, pasivos y capital van a cada beneficiaria, la forma del reparto, los estados financieros base, y las acciones que recibirán los socios en las beneficiarias. Este diseño es el corazón técnico de la escisión.
2. **Acuerdo en asamblea extraordinaria con mayoría reforzada.** La escisión debe aprobarse en asamblea general **extraordinaria**, con la **mayoría exigida para modificar el contrato social** (mayoría reforzada). La resolución debe contener los elementos que exige el art. 228 Bis c (la descripción de la forma en que se segregan activos, pasivos y capital; los estados financieros; la forma de reparto de las acciones; etc.).
3. **Protección de los socios.** Como regla, las acciones de las beneficiarias se reparten entre los **mismos socios** de la escin-

dente, en la **misma proporción** que tenían (escisión "proporcional"), salvo acuerdo distinto. El socio que **vota en contra** tiene **derecho de separación** (a salirse y que le reembolsen sus acciones), protección frente a una decisión estructural que no comparte.

4. **Publicación y resoluciones.** La resolución de escisión se **inscribe** en el RPC y se **publica** (con un extracto y el señalamiento de que el texto completo queda a disposición), para conocimiento de socios y acreedores.
5. **Derecho de oposición de los acreedores (plazo de 45 días).** Durante los **45 días naturales** siguientes a la última publicación/inscripción, **cualquier acreedor** con interés jurídico puede **oponerse judicialmente** a la escisión; la oposición **suspende** la escisión hasta que cause ejecutoria la sentencia que la declare infundada (o se pague/garantice el crédito). Es el equivalente al derecho de oposición de la fusión, calibrado para la escisión.
6. **Surtimiento de efectos y responsabilidad solidaria.** Transcurrido el plazo sin oposición (o resuelta esta), la escisión surte efectos. **Clave protectora:** durante el plazo legal, las sociedades beneficiarias (y, en la escisión parcial, la escidente) **responden solidariamente** frente a los acreedores por las obligaciones de la escidente, de modo que la división del patrimonio **no perjudique** a quienes prestaron antes de la escisión. Esta responsabilidad solidaria es el gran contrapeso a la libertad de repartir activos y pasivos.

Efectos jurídicos de la escisión:

- **Patrimonial:** transmisión en bloque del patrimonio segregado a la(s) beneficiaria(s).
- **Societario:** nacimiento de las beneficiarias (o aumento de capital de las existentes); en la escisión total, extinción de la escidente; reparto de acciones a los socios.
- **Frente a acreedores:** protegidos por el derecho de oposición y por la **responsabilidad solidaria**.
- **Laboral:** continuidad de las relaciones laborales con la sociedad a la que se asigne cada centro de trabajo (sustitución patronal).

- **Fiscal:** puede gozar de **neutralidad fiscal** si cumple los requisitos de la LISR/CFF (en particular, reglas de **permanencia accionaria** —que los socios mantengan cierta participación durante un periodo— y de continuidad); de lo contrario, puede gatillar impuestos. La fiscalidad de la escisión es delicada y exige **asesor fiscal** desde el diseño.

Usos en M&A y reorganización. La escisión es la herramienta estrella para:

- **Carve-outs:** separar una unidad de negocio para **venderla** (se escinde el negocio a una nueva sociedad cuyas acciones luego se venden) sin arrastrar el resto del grupo.
- **Resolver conflictos entre socios:** dividir la empresa para que cada grupo de socios se quede con una parte ("divorcio societario").
- **Especializar y desconcentrar:** separar negocios distintos que estaban en una misma sociedad para gestionarlos o financiarlos por separado.
- **Blindar activos:** segregar activos valiosos (inmuebles, marcas) en una sociedad distinta de la operativa, para protegerlos del riesgo del negocio.
- **Planeación patrimonial familiar:** repartir el patrimonio empresarial entre ramas de la familia.

Conexión con la due diligence y el contrato. Cuando la DD revela que solo interesa **una parte** de una empresa, o que hay un activo/negocio "contaminado" que conviene aislar, la **escisión** permite **separar** lo deseable de lo indeseable antes de la operación (a veces el vendedor escinde y luego vende solo la parte sana). Combinada con un *share deal* sobre la sociedad escindida, logra un resultado limpio y fiscalmente eficiente que un *asset deal* no siempre puede igualar.

14.D · REESTRUCTURAS Y HOLDINGS (LA COMBINACIÓN DE FIGURAS)

Las estructuras vistas no se usan solo de forma aislada: el verdadero arte del abogado corporativo está en **combinarlas** para lograr arquitecturas que resuelven problemas complejos.

Esto es la **reorganización corporativa**, y es trabajo de alto valor.

La sociedad holding (tenedora). Una *holding* es una sociedad cuyo objeto principal es **poseer y controlar las acciones** de otras sociedades (las operativas). La estructura típica de grupo es: una **holding** en la cúspide, que controla varias **subsidiarias operativas**, y a veces sociedades **patrimoniales** que aíslan activos valiosos (inmuebles, marcas, PI). ¿Para qué sirve?

- **Separar riesgo:** cada negocio en una sociedad distinta, de modo que el problema de uno no contamine a los demás (la quiebra de una subsidiaria no arrastra a las hermanas ni, en principio, a la holding más allá de su aportación).
- **Organizar el control:** la holding centraliza la propiedad y el gobierno del grupo; facilita la entrada de inversionistas en una subsidiaria sin tocar las demás.
- **Eficiencia fiscal:** la organización en grupo permite, dentro de los límites de la ley, ciertas eficiencias (régimen de dividendos entre sociedades del grupo, etc., siempre con asesor fiscal).
- **Blindaje de activos:** los activos valiosos viven en una sociedad patrimonial que los **arrienda** a la operativa, protegiéndolos del riesgo del negocio operativo.

Cómo se construye/reorganiza un grupo (las figuras combinadas). El abogado dispone de una caja de herramientas que combina:

- **Aportación de acciones/activos:** los socios aportan sus acciones de las operativas a una holding (a cambio de acciones de la holding), creando o reorganizando la cadena de control.
- **Escisión:** para **separar** negocios o activos que estaban juntos (crear la sociedad patrimonial que tendrá los inmuebles; separar dos líneas de negocio).
- **Fusión:** para **simplificar** estructuras (fusionar subsidiarias redundantes; fusionar la NewCo con la *target* tras una compra).

- **Constitución de NewCos:** crear sociedades nuevas como vehículos (de adquisición, de inversión, de *joint venture*).

Ejemplos de arquitecturas combinadas:

- **Carve-out para venta:** un grupo quiere vender una de sus tres divisiones. Primero **escinde** la división a una nueva sociedad (limpia, con solo los activos y pasivos de ese negocio); luego **vende las acciones** de esa nueva sociedad (share deal) a un comprador. Resultado: el comprador recibe un negocio aislado y limpio; el vendedor conserva el resto; y, bien diseñado, con eficiencia fiscal.
- **Reorganización pre-inversión (entrada de un fondo):** una empresa familiar quiere que un fondo de PE invierta solo en su negocio rentable, no en sus inmuebles. Se **escinden** los inmuebles a una sociedad patrimonial de la familia; el fondo invierte en la operativa "ligera".
- **LBO (private equity):** el fondo constituye una **NewCo**, le inyecta capital y **deuda** (el apalancamiento), la **NewCo compra** la *target* y luego **se fusiona** con ella (fusión apalancada), de modo que el flujo de la *target* sirva la deuda. (Profundizaremos en el Libro 5.)
- **Holding para sucesión familiar:** se crea una holding familiar que concentra las acciones de las operativas; el patriarca transmite/hereda acciones de la holding a las distintas ramas, ordenando la sucesión sin fragmentar el control operativo (se combina con un protocolo familiar y, a veces, un fideicomiso).

La advertencia antiabuso. Toda reorganización debe tener una **razón de negocio** legítima además de la fiscal. Las reglas antiabuso (y la **norma general antiabuso** del CFF) facultan a la autoridad a **recaracterizar** operaciones que carezcan de **razón de negocio** y busquen solo un beneficio fiscal indebido. El abogado serio diseña reorganizaciones con **sustancia económica** real y documenta su **propósito de negocio**; no "esquemas" artificiales. Esta es una frontera ética y técnica capital.

14.E · CRITERIOS DE ELECCIÓN DE LA ESTRUCTURA (LOS CUATRO EJES)

Llegamos al método que **integra todo el libro**: ¿cómo se elige la estructura óptima? No por intuición ni por costumbre, sino ponderando **cuatro ejes**. Internaliza este marco; es la forma en que un socio de M&A piensa una operación.

Eje 1 — Riesgo (pasivos). ¿Qué tan grande e inacotable es el riesgo de **pasivos ocultos** revelado por la due diligence?

- Riesgo **alto e inacotable** → favorece **asset deal** (aislar) o escisión previa (separar lo contaminado) → si se queda en share deal, exige blindaje fuerte (reps, indemnización, escrow).
- Riesgo **bajo o acotable** → el share deal o la fusión son viables con protección contractual normal.

Eje 2 — Continuidad (contratos, permisos, relaciones). ¿Qué tan importante es **conservar** los contratos, permisos, concesiones y relaciones de la empresa, y qué tan **transferibles** son?

- Continuidad **crítica** y activos/contratos **difíciles de transferir** (permisos intransferibles, muchos contratos clave) → favorece **share deal o fusión** (continuidad automática).
- Continuidad **poco relevante** o pocos contratos → el asset deal es manejable.
- **Ojo con el *change of control***: si los contratos clave tienen esa cláusula, ni siquiera el share deal garantiza continuidad → hay que obtener consentimientos (condición al closing, Libro 2).

Eje 3 — Fiscalidad. ¿Cuál estructura genera el **menor costo fiscal** total para las partes?

- ¿Hay **neutralidad fiscal** disponible (fusión/escisión que cumplan requisitos)?
- ¿El asset deal dispara impuestos sobre activos e inmuebles, pero da *step-up* de base?
- ¿Cómo se reparte la carga fiscal entre comprador y vendedor (afecta el precio neto)?

- **Este eje, con frecuencia, es el decisivo** —y siempre se resuelve **con el asesor fiscal**—.

Eje 4 — Autorizaciones y tiempo. ¿Qué **autorizaciones** requiere cada estructura y cuánto **tiempo** consume?

- ¿Notificación a la **COFEC** (competencia)? ¿Autorización **sectorial** (banca, energía)? ¿Autorización **fiscal** para la reorganización? ¿Límites de **inversión extranjera**?
- Los plazos de **oposición de acreedores** (3 meses en fusión, 45 días en escisión) afectan el calendario.
- A veces la estructura más limpia jurídicamente es la **más lenta o incierta** en autorizaciones, y se elige otra por **velocidad y certeza**.

El método de decisión (cómo lo hace un socio):

1. **Define el objetivo de negocio** del cliente (comprar todo, comprar una parte, combinar, separar, reorganizar, preparar venta).
2. **Trae los hallazgos de la due diligence** (¿riesgo de pasivos?, ¿continuidad en juego?, ¿*change of control*?).
3. **Pondera los cuatro ejes** con el equipo (legal + fiscal + financiero): casi nunca un eje manda solo; se busca el **equilibrio**.
4. **Diseña la estructura** (a menudo **combinada**: escindir y luego vender; comprar y luego fusionar; crear holding) que mejor equilibra los cuatro ejes y sirve al objetivo.
5. **Verifica la sustancia / razón de negocio** (antiabuso) y documenta el propósito.
6. **Traduce la estructura al contrato** correcto: SPA (share deal), APA (asset deal), convenio de fusión, proyecto de escisión, acuerdos de reorganización (Libro 4).

La idea que debe quedarte grabada: no hay estructura "mejor" en abstracto; hay una óptima para cada operación, que resulta de equilibrar riesgo, continuidad, fiscalidad y autorizaciones a la luz del objetivo de negocio. El abogado que domina ese equilibrio —y que sabe **combinar** las figuras para construir la arquitectura precisa— es quien de verdad **arma deals**, y no solo los documenta. Ese es el salto de calidad que persigue este libro.

15. Explicación intuitiva

Tres imágenes para fijar las estructuras y no olvidarlas nunca.

La metáfora de la casa con inquilinos y deudas. Comprar una empresa por **share deal** es como comprar una casa **con todo dentro**: los muebles, pero también el inquilino moroso, la hipoteca y la demanda del vecino. Te quedas con la casa y **todos** sus enredos, porque compraste la **escritura**. El **asset deal** es como decirle al dueño: "no quiero tu casa con sus líos; véndeme **solo** el comedor, el refrigerador y el jardín". Te llevas lo bueno y dejas atrás la hipoteca y el inquilino —aunque, ojo, hay líos que **la ley pega al mueble** (como ciertos impuestos o derechos de los trabajadores que vienen con el negocio)—. La **fusión** es **tirar la barda** entre dos casas vecinas para hacer una sola casa más grande, y que los dos dueños sean ahora **co-dueños**. La **escisión** es **partir** una casa enorme en dos casas independientes, una para cada cosa.

La metáfora del trasplante vs. la mudanza. La **fusión** y la **escisión** funcionan como un **trasplante en bloque**: el patrimonio pasa entero, "conectado", de una sociedad a otra **automáticamente** (sucesión universal) —como mover un órgano completo con sus venas ya conectadas—. El **asset deal** funciona como una **mudanza pieza por pieza**: hay que **empacar y trasladar cada cosa** (cada activo, cada contrato), y para algunas necesitas **permiso** (el consentimiento de la contraparte). Por eso la fusión/escisión preserva la continuidad casi sin esfuerzo, y el asset deal es laborioso pero permite **dejar cosas atrás**.

La metáfora del cirujano. El abogado de estructuras es un **cirujano de empresas**: con el bisturí de la **escisión** separa un órgano enfermo (un negocio contaminado) del cuerpo sano; con la **fusión** une dos cuerpos; con la **holding** organiza el esqueleto del grupo; y elige siempre la técnica que cause **menos hemorragia** (riesgo), deje **menos cicatriz fiscal** y **consERVE la función** (continuidad). No opera por costumbre: estudia la radiografía (la due diligence) y elige la técnica óptima para **ese** paciente.

La intuición central: **la estructura es la decisión de "cómo" se mueve la propiedad y el riesgo**. Dos operaciones con el mismo precio y la misma empresa pueden tener resultados **radicalmente distintos** según la estructura: una deja al comprador con un pasivo oculto devastador, otra lo aísla; una paga el doble de impuestos que la otra; una conserva el contrato clave, otra lo pierde. Elegir bien la estructura **crea o destruye más valor** que casi cualquier cláusula del contrato.

16. Ejemplos simples

Ejemplo 1 — El pasivo que decide la estructura. Una empresa tiene una contingencia ambiental enorme y difícil de cuantificar en una de sus plantas. El comprador solo quiere la **otra** planta y la marca. *Solución: asset deal* —compra solo la planta sana y la marca, deja la planta contaminada (y su pasivo) en la sociedad vendedora—. Si fuera share deal, heredaría el pasivo ambiental.

Ejemplo 2 — El permiso intransferible. Una empresa opera con una **concesión** que, por ley, no puede cederse, pero que **sobrevive** si la sociedad titular sigue siendo la misma. *Solución: share deal* (comprar las acciones) —la sociedad, y por tanto la concesión, continúan; un asset deal perdería la concesión—.

Ejemplo 3 — Combinar dos iguales. Dos despachos/empresas de tamaño similar quieren unirse creando una marca nueva, sin que una "absorba" a la otra. *Solución: fusión por integración* —ambas se extinguen y nace una sociedad nueva de la que ambos grupos son codueños—.

Ejemplo 4 — Separar para vender. Un grupo con tres negocios quiere **vender solo uno**. *Solución: escisión* del negocio a vender a una nueva sociedad, y luego **venta de las acciones** de esa sociedad (share deal). El comprador recibe un negocio limpio y aislado.

17. Ejemplos complejos

Ejemplo complejo 1 — El carve-out fiscalmente eficiente. Un conglomerado quiere vender su división de alimentos (que

comparte sociedad con la división de bebidas, su joya). Un *asset deal* obligaría a transferir cientos de activos y contratos individualmente (lento, con riesgo de perder contratos por falta de consentimiento) y podría disparar impuestos. *Solución diseñada*: **(1)** escisión parcial de la división de alimentos a una **NewCo** (sucesión universal: los contratos pasan en bloque, sin cesión individual), buscando **neutralidad fiscal** de la escisión; **(2)** venta de las **acciones** de la NewCo (*share deal*) al comprador, con su SPA, reps e indemnización. Resultado: el comprador recibe un negocio aislado y "envuelto" en una sociedad limpia; el vendedor conserva bebidas; y la carga fiscal se minimiza. Ilustra cómo **combinar escisión + share deal** supera a un *asset deal* directo.

Ejemplo complejo 2 — La fusión apalancada (anticipo del LBO). Un fondo de PE quiere comprar *Target, S.A.* por 1,000, financiando 600 con deuda. *Solución*: el fondo crea **NewCo**, le aporta 400 de capital y NewCo contrata **600 de deuda**; NewCo **compra** las acciones de Target; luego NewCo **se fusiona** con Target (fusión por absorción), de modo que la deuda y los activos/flujos de Target queden en la **misma** sociedad y el flujo operativo **sirva la deuda**. Aquí la fusión no busca "combinar dos negocios", sino **colocar la deuda sobre los activos** que la pagarán. *Complejidad*: hay que cuidar la protección de acreedores de la fusión, las reglas fiscales (deducibilidad de intereses, neutralidad) y los límites a la asistencia financiera. (Detalle en el Libro 5.)

Ejemplo complejo 3 — El change of control que rompe la continuidad del share deal. Una empresa de distribución se compra por **share deal** (para conservar sus 200 contratos sin cederlos uno por uno). Pero la due diligence revela que su contrato más rentable —con un proveedor extranjero— tiene una cláusula de **change of control** que permite al proveedor **terminarlo** si cambia el dueño. *Problema*: la gran ventaja del *share deal* (continuidad automática) **no aplica** a ese contrato. *Solución*: volver el **consentimiento** del proveedor una **condición al closing** (Libro 2); si no se obtiene, ajustar precio o pre-

ver un derecho de salida. Muestra que la estructura interactúa con los hallazgos de la DD y con el contrato.

18. Casos reales (operaciones estilizadas y referentes)

Nota de método (Manifiesto XI.5): casos estilizados con fines didácticos; verifica los detalles antes de citarlos profesionalmente.

Las grandes fusiones "entre iguales" y sus riesgos (Daimler-Chrysler, 1998). La unión de Daimler-Benz y Chrysler se presentó como una "fusión entre iguales", pero terminó (años después) en una **separación** que destruyó enorme valor. *Lección:* la estructura jurídica (fusión por integración) no garantiza el éxito si la **integración real** —culturas, operaciones, gobierno— falla. La estructura es condición necesaria, no suficiente; el valor se gana o se pierde en la integración (eco del Libro 1).

Los grandes spin-offs (escisiones) para "desbloquear valor". Numerosos conglomerados se han **escindido** en empresas independientes bajo la tesis de que "la suma de las partes vale más que el todo" (el mercado valora mejor empresas enfocadas que conglomerados difíciles de analizar). Ejemplos repetidos en industria, energía y consumo a nivel global. *Lección:* la **escisión** es una herramienta estratégica para **crear valor** separando negocios, no solo un tecnicismo societario.

Asset deals en adquisiciones de empresas en problemas (distressed M&A). Cuando se compra una empresa en crisis o en concurso, el comprador suele preferir un **asset deal** (o una venta de activos dentro del procedimiento concursal) precisamente para **adquirir los activos sanos sin heredar** la maraña de pasivos. *Lección:* la estructura **asset deal** es la herramienta natural para aislar valor en situaciones de riesgo de pasivos elevado (conecta con el libro de Concurso Mercantil del Nivel III).

Grupo Modelo – AB InBev (2013, ~20,100 mdd  verificar), o quién decide de verdad la estructura. Para obtener la autorización antimonopolio en Estados Unidos, la operación tuvo que incorporar la **desinversión del negocio**

de Corona en ese mercado —vendido a Constellation Brands— como condición estructural.

La lección es la más importante de este libro y contradice la intuición del principiante: la estructura no la dicta la fiscalidad. La puede **rediseñar la autoridad de competencia**, y lo hace en las operaciones grandes. Un diseño impecable en el eje fiscal y de pasivos puede ser inviable en el eje regulatorio, y por eso los cuatro ejes del §6 se analizan **en paralelo desde el primer día**, no en secuencia. Ver Competencia Económica y Control de Concentraciones.

Y su corolario práctico: en toda operación con riesgo de concentración, el diseño debe incluir de antemano **qué se está dispuesto a desinvertir** (los *remedies*) y qué no. Llegar a esa conversación sin haberla preparado es negociar la estructura desde la debilidad.

19. Casos empresariales

El grupo familiar que se reorganiza antes de crecer. Una familia tiene, en **una sola sociedad**, una fábrica, los inmuebles donde opera y una pequeña distribuidora. Quiere: proteger los inmuebles del riesgo de la fábrica, profesionalizar, y dejar la distribuidora lista para una eventual venta. *Solución empresarial:* **escindir** en tres —una patrimonial con los inmuebles (que los arrienda a la fábrica), la operativa fabril, y la distribuidora— y colocar las tres bajo una **holding** familiar. Resultado: riesgo separado, activos blindados, y la distribuidora "empaquetada" para vender sus acciones cuando convenga. Una sola decisión estructural resuelve tres objetivos de negocio.

El comprador estratégico que integra tras comprar. Una empresa compra a una competidora (share deal, para conservar sus contratos y permisos) y, una vez cerrada la compra y obtenidas las autorizaciones, **fusiona** la adquirida con su propia operación para integrar equipos, eliminar duplicidades y capturar sinergias. *Lección:* en la práctica, **share deal + fusión posterior** es una secuencia clásica: primero adquirir (con continuidad), luego integrar (con simplificación).

20. Casos corporativos (la conexión integral)

Integremos todo el programa en un caso. *Inversiones Cima* (un fondo de PE) quiere adquirir la **división industrial** de *Grupo Río, S.A.* —una sociedad que también tiene una división inmobiliaria que Cima no quiere—, financiando parte con deuda.

- **Nivel I-II (Obligaciones, Garantías, Responsabilidad):** se analizan las obligaciones y garantías que acompañan a los activos de la división industrial y los pasivos contingentes (responsabilidad civil).
- **Nivel III (Sociedades/LGSM, Gobierno Corporativo):** la **escisión** y la eventual **fusión** se rigen por la LGSM (asambleas extraordinarias, oposición de acreedores, responsabilidad solidaria); los **deberes del consejo** de Grupo Río al aprobar la reorganización y la venta (Revlon, *fairness opinion*) son clave.
- **Libro 1 (Fundamentos de M&A):** la operación se mapea (estructura, fases, asignación de riesgo).
- **Libro 2 (Due Diligence):** la DD revela que la división inmobiliaria tiene pasivos ambientales y fiscales que Cima **no** quiere heredar → empuja a **aislar** la industrial.
- **Libro 3 (este):** se diseña la arquitectura: **(1)** Grupo Río **es-cinde** la división industrial a una **NewCo limpia** (sucesión universal: contratos y permisos pasan en bloque, con neutralidad fiscal); **(2)** Cima crea su **vehículo de adquisición** con capital + deuda; **(3)** el vehículo **compra las acciones** de la NewCo (share deal, con SPA, reps, indemnización, escrow); **(4)** posible **fusión** posterior del vehículo con la NewCo (fusión apalancada). Todo verificando **razón de negocio** (antiabuso) y **autorizaciones** (COFEC).
- **Libro 4 (siguiente):** la estructura se documenta (convenio/proyecto de escisión, SPA, contratos de financiamiento, acuerdos de la fusión).

Moraleja: la elección de estructura es el **punto donde el abogado corporativo demuestra su maestría integradora:** combina figuras societarias (escisión, fusión, NewCo, share

deal) para servir un objetivo de negocio, aislando el riesgo detectado en la DD, optimizando la fiscalidad y respetando las autorizaciones. No es un tecnicismo: es **ingeniería jurídica de creación de valor**.

21. Casos internacionales

Las directivas europeas sobre fusiones y escisiones. La Unión Europea ha **armonizado** el régimen de las fusiones y escisiones (y de las fusiones **transfronterizas**) entre sus Estados miembros, facilitando las reorganizaciones de grupos paneuropeos con protecciones comunes a acreedores y socios. *Lección:* la lógica de la sucesión universal y de la protección de acreedores/minorías es **universal** en el civil law; cambian los detalles, no la arquitectura conceptual.

Las reorganizaciones transfronterizas y el *forum shopping* estructural. En operaciones multinacionales, la estructura debe coordinar **varias jurisdicciones** a la vez: una fusión puede ser neutral fiscalmente en un país y gravada en otro; una escisión válida en México puede requerir pasos adicionales para sus efectos en el extranjero. Los grupos eligen, dentro de la legalidad, las jurisdicciones y vehículos (holdings en ciertos países) que optimizan fiscalidad y certeza —siempre bajo la lupa de las reglas **antiabuso** internacionales (BEPS, sustancia económica)—.

El estándar internacional de "razón de negocio" (sustancia económica). A nivel global, las autoridades fiscales (y los estándares BEPS de la OCDE) han endurecido la exigencia de que las reorganizaciones tengan **sustancia económica y propósito de negocio** real, no solo ventaja fiscal. *Lección para el abogado mexicano de élite:* diseñar estructuras que resistan el escrutinio antiabuso **mexicano e internacional**, con sustancia y documentación de su propósito, es hoy parte esencial del oficio. La era de los "esquemas" artificiales terminó; la del **diseño con sustancia** es la norma.

22. Derecho comparado

Las estructuras de reorganización existen en todos los sistemas, pero con diferencias relevantes en su regulación y en las protecciones. Tabla comparada para el abogado de M&A:

JURISDICCIÓN / SISTEMA	TRATAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS (FUSIÓN, ESCISIÓN, ADQUISICIONES)
México (Civil Law)	Fusión y escisión reguladas en la LGSM (arts. 222-226 y 228 ◊ Bis); protección de acreedores por oposición (3 meses fusión / 45 días escisión) y responsabilidad solidaria (escisión); derecho de separación del socio disidente; neutralidad fiscal condicionada (LISR/CFF). Share/asset deal por derecho común + LGSM.
EE.UU. (Common Law)	Régimen estatal (cada estado su ley societaria). La fusión es muy flexible (incluye la <i>triangular merger</i> —fusión a través de una subsidiaria— y la <i>reverse triangular merger</i> , muy usadas en M&A). Fuerte desarrollo de los appraisal rights (derecho de separación) y de los deberes fiduciarios.
Delaware	El estándar de referencia: DGCL muy sofisticada en fusiones (incluida la <i>short-form merger</i> de matriz-subsidiaria y, hoy, la fusión sin nuevo voto tras una OPA exitosa). <i>Case law</i> riquísimo sobre appraisal y deberes del consejo. La "lengua franca" de las estructuras de M&A.
España (Civil Law)	Ley de Modificaciones Estructurales regula con detalle fusión, escisión, cesión global de activo/pasivo y traslado de domicilio; fuerte protección de acreedores y socios; armonización con directivas de la UE.
Reino Unido (Common Law)	Las adquisiciones de sociedades cotizadas se rigen por el Takeover Code ; las reorganizaciones suelen hacerse vía scheme of arrangement (un mecanismo aprobado por la corte, muy usado para adquisiciones y reestructuras).
Unión Europea	Directivas que armonizan fusiones (incluidas las transfronterizas), escisiones y movilidad de sociedades, con protecciones comunes a acreedores y trabajadores.
UNIDROIT / soft law	Principios sobre contratos comerciales que rigen los acuerdos de adquisición internacionales (buena fe, interpretación), supletorios del diseño contractual de la operación.
Civil Law vs. Common Law (síntesis)	El civil law regula la fusión/escisión como modificaciones estructurales tasadas, con protección legal de acreedores (oposición) y socios (separación). El common law ofrece más flexibilidad de ingeniería (triangular mergers, schemes) y confía en <i>appraisal</i> y deberes fiduciarios. En M&A transfronterizo, conviven ambas lógicas.

Lección comparada: dos figuras del common law que el abogado mexicano debe conocer aunque no existan idénticas aquí: la ***reverse triangular merger*** (el comprador crea una subsidiaria que se fusiona con la *target*, sobreviviendo la *tar-*

get como filial del comprador —preserva los contratos de la *target* y evita votos individuales—) y el ***scheme of arrangement*** británico. Aparecen constantemente en deals internacionales y en la estructura de adquisiciones de empresas con presencia en EE.UU. o Reino Unido.

La ingeniería estadounidense, y qué debería importar a México. El *Internal Revenue Code* dedica su **Subcapítulo C** a las reorganizaciones y tipifica varias (las conocidas como **tipo A, B y C**), cada una con sus requisitos para preservar la neutralidad fiscal. Es, con distancia, el catálogo más sofisticado del mundo, y su rasgo interesante no es fiscal sino **contractual**: figuras como el *reverse triangular merger* se diseñaron precisamente para que **la sociedad objetivo sobreviva** y por tanto sus contratos, permisos y licencias **no se disparen** por cambio de control.

México reconoce la fusión y la escisión (LGSM ☺) con neutralidad fiscal condicionada al cumplimiento de requisitos, pero sin esa riqueza de vehículos.

La lección aprovechable, y es concreta: cuando diseñes una adquisición en la que los contratos clave tienen cláusulas de *change of control* —el caso del cliente concentrado que aparece en todo este nivel— la pregunta correcta no es "*¿share o asset?*", sino "**¿qué estructura permite que la sociedad objetivo siga siendo la misma persona jurídica?**". Esa es la lógica del *reverse triangular merger*, y es importable como razonamiento aunque el vehículo no exista aquí con ese nombre.

23. Derecho mexicano

El régimen mexicano de las estructuras se concentra en la **LGSM** y se complementa con la legislación fiscal, laboral y de competencia:

- **Fusión (LGSM, arts. 222-226 ☺):** acuerdo en asamblea extraordinaria de **cada** sociedad; inscripción en el RPC y publicación; **efectos a los 3 meses** salvo pago/garantía/consentimiento de acreedores; **derecho de oposición** judicial de los acreedores (suspende la fusión); transmisión universal del patrimonio a la fusionante o nueva sociedad; extinción de las fusionadas sin liquidación.

- **Escisión (LGSM, art. 228 Bis c):** acuerdo en asamblea extraordinaria con **mayoría reforzada**; contenido obligatorio de la resolución (reparto de activos, pasivos y capital; estados financieros); publicación e inscripción; **derecho de oposición** de acreedores (**45 días naturales**); **responsabilidad solidaria** de las beneficiarias (y escidente en la parcial) frente a acreedores durante el plazo legal; reparto de acciones entre los socios; **derecho de separación** del disidente.
- **Compraventa de acciones (share deal):** Código de Comercio y supletoriamente Código Civil; transmisión por **endoso** e inscripción en el **libro de registro de accionistas** (acciones nominativas); régimen especial para emisoras (LMV). Documentada en un **SPA**.
- **Compraventa de activos (asset deal):** reglas de compraventa y **cesión** de cada bien/derecho; inmuebles ante notario e inscripción; cesión de contratos con consentimiento cuando se requiera; cesión de créditos con notificación al deudor; transmisión de PI ante el IMPI. Documentada en un **APA**.
- **Régimen fiscal (LISR, CFF):** requisitos de **neutralidad** para fusiones y escisiones (permanencia accionaria, continuidad, avisos; ciertas reorganizaciones requieren **autorización**); reglas **antiabuso** (norma general antiabuso del CFF: exigencia de **razón de negocio**).
- **Materia laboral (LFT): sustitución patronal** —continuidad de las relaciones laborales y de los derechos de los trabajadores cuando cambia el titular de la empresa o del establecimiento—.
- **Competencia (LFCE):** notificación de **concentraciones** a la COFEC y prohibición de *gun jumping*.

Nota de método: verifica el texto vigente de la LGSM y de la legislación fiscal antes de aplicar plazos, mayorías y requisitos en un caso real (Manifiesto XI.5).

24. Jurisprudencia relevante

Nota de método: verifica vigencia y datos de identificación antes de citar.

Los criterios mexicanos relevantes giran en torno a las **protecciones** de las reorganizaciones:

- **Derecho de oposición de los acreedores** en fusión y escisión: criterios sobre quién tiene interés jurídico, el efecto suspensivo de la oposición y su tramitación.
- **Responsabilidad solidaria en la escisión:** alcance y temporalidad de la responsabilidad de las beneficiarias frente a los acreedores de la escidente.
- **Derecho de separación del socio:** supuestos y forma de ejercerlo y de valorar las acciones a reembolsar.
- **Sustitución patronal (materia laboral):** criterios sobre la continuidad de los derechos de los trabajadores y la responsabilidad del patrón sustituto y sustituido durante el periodo legal.
- **Materia fiscal:** criterios sobre los requisitos de neutralidad de fusiones y escisiones y sobre la recaracterización por **falta de razón de negocio**.

En el ámbito **anglosajón** (de gran influencia práctica), el *case law* de **Delaware** sobre *appraisal rights* (valuación de las acciones del disidente) y sobre los deberes del consejo en fusiones es estudio constante para el diseño de operaciones internacionales.

25. Criterios de la Suprema Corte / reguladores

- **SCJN / tribunales:** criterios sobre el **derecho de oposición**, la **responsabilidad solidaria** en escisión, el **derecho de separación** y la **sustitución patronal**, que delinear las protecciones de acreedores, socios y trabajadores en las reorganizaciones.
- **COFEC:** guías y resoluciones sobre **concentraciones** (cuándo una fusión/adquisición es notificable, umbrales, *gun jumping*).

- **SAT:** criterios sobre los requisitos de **neutralidad fiscal** de fusiones y escisiones y sobre la **norma general antiabuso** (razón de negocio); reglas sobre avisos y autorizaciones de reorganización.
- **CNBV (emisoras):** régimen de fusiones y reorganizaciones de sociedades públicas y su interacción con OPAs e información al mercado.

26. Doctrina nacional

La doctrina mexicana sobre fusión y escisión proviene del **derecho societario y mercantil**: los autores clásicos de sociedades mercantiles (que analizan la fusión como modificación estructural y la escisión desde su incorporación en 1992), complementados por la doctrina **fiscal** (sobre la neutralidad y el antiabuso de las reorganizaciones) y la **laboral** (sustitución patronal). La práctica de los grandes despachos corporativos ha desarrollado, además, un cuerpo de **know-how transaccional** (cómo combinar escisiones, fusiones y share deals para reorganizaciones eficientes) que vive más en los precedentes y en la formación interna que en los tratados académicos.

27. Doctrina internacional

- **Derecho societario de Delaware y EE.UU. (DGCL, tratados de corporations):** referencia sobre fusiones (incluidas las triangulares), *appraisal rights* y deberes del consejo en operaciones estructurales.
- **Literatura de M&A y deal structuring (manuales de los grandes despachos, Practical Law):** el "cómo" práctico de estructurar adquisiciones, carve-outs y reorganizaciones.
- **OCDE — BEPS y sustancia económica:** el marco internacional **antiabuso** que condiciona el diseño fiscal de las reorganizaciones transfronterizas.
- **Directivas de la UE sobre modificaciones estructurales:** el modelo armonizado de fusión/escisión (incluidas las transfronterizas) en el civil law europeo.

- **Doctrina de finanzas corporativas (para LBO y fusión apalancada):** conecta la estructura con el financiamiento y la valuación (anticipa los Libros 5 y el Nivel V).

28. Opiniones críticas (postura del Consejo Editorial)

Primero: la estructura crea (o destruye) más valor que muchas cláusulas. Sostenemos que la elección de estructura es **subvalorada** por el abogado novel, que se concentra en redactar cláusulas y descuida el diseño. Una estructura mal elegida puede costar millones en impuestos o en pasivos heredados que ninguna cláusula repara. El abogado de élite **piensa la estructura primero**.

Segundo: ninguna estructura es buena o mala en abstracto. Criticamos el dogmatismo ("el asset deal siempre es mejor para el comprador", "la fusión siempre es neutral"). La respuesta correcta es **siempre** el equilibrio de los cuatro ejes para el caso concreto. El buen abogado razona, no aplica recetas.

Tercero: la sustancia por encima del esquema. Advertimos con firmeza contra las reorganizaciones **artificiales** diseñadas solo para eludir impuestos. Además del riesgo legal (recharacterización antiabuso), hay una cuestión **ética y de criterio profesional**: el abogado serio diseña con **razón de negocio** real y documenta su propósito. La era de los "esquemas" terminó.

Cuarto: la estructura debe servir al negocio, no al revés. Criticamos las reorganizaciones que complican tanto la estructura (decenas de sociedades, cadenas interminables) que el grupo se vuelve ingobernable y costoso de administrar. La **elegancia** —la estructura más simple que logra el objetivo— es una virtud, no un lujo.

Y la crítica de fondo, que el Consejo asume aunque incomode a la profesión. La sofisticación estructural habilita el **arbitraje fiscal y regulatorio**: estructuras que existen únicamente para minimizar impuestos, sin sustancia económica. Es lo que el proyecto **BEPS** y las normas generales antiabuso (**GAAR**, en México el art. 5o.-A CFF ☺) vienen a combatir, y la

crítica es legítima: el ingenio estructural puede desplazar valor del fisco —y por tanto de la sociedad— hacia los accionistas **sin crear riqueza real**.

Nuestra postura no es que el abogado deba renunciar a estructurar con eficiencia: es que debe saber distinguir dos cosas que se parecen mucho en un diagrama y no se parecen en nada ante una autoridad. Una estructura que reordena un negocio real y de paso es eficiente fiscalmente, se defiende. Una que no reordena nada y solo produce un beneficio fiscal, no —y el profesional que la diseña está construyendo un pasivo latente para su cliente y para sí mismo—. Es el mismo criterio del módulo 06 de la Columna VI: la pregunta no es si es defendible hoy, sino si lo será cuando alguien lo examine sabiendo cómo terminó.

La matriz de tres columnas con la que se decide en la práctica. Cuando el diagrama se vuelve discutible, un socio ordena la decisión así: **fiscal · pasivos · aprobaciones**. Se escriben las tres columnas para cada estructura candidata y se elige la que mejor equilibra, no la que gana en una sola.

29. Debate doctrinal

- **Share deal vs. asset deal: ¿quién soporta los pasivos "que siguen al negocio"?** Debate sobre el alcance de las excepciones (laboral, fiscal, ambiental) que pegan ciertos pasivos al activo/negocio aunque se pacte lo contrario. *Postura del Consejo:* el comprador de un asset deal debe **mapear** estas excepciones en la DD y **no** confiar en que "el asset deal lo aísla de todo"; muchas veces necesita, además, reps e indemnización del vendedor.
- **¿La escisión perjudica a los acreedores?** Tensión entre la **libertad de reorganización** de la empresa y la **protección del acreedor** cuyo deudor reparte su patrimonio. *Postura del Consejo:* la **responsabilidad solidaria** y el **derecho de oposición** equilibran bien la tensión; el problema real son las escisiones diseñadas para **defraudar** acreedores (dejar las deudas en una sociedad vacía), que deben combatirse con la acción de fraude y la responsabilidad solidaria.

- **Neutralidad fiscal vs. antiabuso: ¿dónde está la línea?** ¿Cuándo una reorganización tiene "razón de negocio" legítima y cuándo es un abuso? *Postura del Consejo:* la línea está en la **sustancia económica real**; una reorganización con propósito de negocio genuino (separar riesgos, preparar una venta, ordenar la sucesión) que **además** sea eficiente fiscalmente es legítima; una que **solo** busque el beneficio fiscal, sin sustancia, no.
- **Flexibilidad anglosajona vs. tipicidad del civil law.** ¿Es mejor la libertad de ingeniería del common law (triangular mergers, schemes) o la seguridad de las figuras tasadas del civil law? *Postura del Consejo:* cada sistema tiene su virtud; el abogado mexicano de élite debe **conocer ambos** porque opera en deals transfronterizos donde conviven.
- **¿La neutralidad fiscal de las reestructuras es un incentivo legítimo o una puerta a la elusión?** El argumento a favor es el del §6: no gravar lo que no realiza valor evita un impuesto a la eficiencia. El argumento en contra es que la frontera entre reorganizar y disfrazar es porosa y se explota. *Postura del Consejo:* la neutralidad es correcta como principio y **la razón de negocios del art. 5o.-A CFF ☐ es su contrapeso necesario**, no su enemigo. Un sistema con neutralidad y sin cláusula antiabuso invita al abuso; uno con antiabuso y sin neutralidad castiga la reorganización honesta.
- **El límite del *asset deal*: la responsabilidad del sucesor.** Aquí hay un punto que suele sorprender al comprador. Elegir activos no siempre aísla del todo: distintos ordenamientos y materias imponen que **ciertos pasivos sigan al negocio** aunque no se hayan asumido en el contrato —de forma característica en materia **laboral** (la sustitución patronal), **fiscal y ambiental**—. La razón es de política pública: si bastara con comprar los activos para dejar atrás las obligaciones, el *asset deal* sería un instrumento de fraude a los acreedores. *Postura del Consejo:* nunca se venda al cliente el *asset deal* como un blindaje absoluto; es un filtro **fuerte y con excepciones nombradas**, y esas excepciones

se cubren con indemnidad específica, no con la estructura. Ver Derecho Laboral y Derecho Ambiental.

30. Errores comunes

- **Elegir la estructura por costumbre, no por análisis.** "Siempre hacemos share deal" → se heredan pasivos evitables o se pagan impuestos de más. *Corrección:* aplica los **cuatro ejes** a cada caso.
- **Crear que el asset deal aísla de TODO.** Olvidar que los pasivos **laborales, fiscales y ambientales** pueden seguir al negocio por mandato legal. *Corrección:* mapea las excepciones y refuerza con reps e indemnización.
- **Olvidar el *change of control* en el share deal.** Suponer que la continuidad es automática cuando un contrato clave permite terminar por cambio de dueño. *Corrección:* identifícalo en la DD y vuélvelo condición al closing.
- **Diseñar sin el asesor fiscal.** Elegir estructura ignorando la fiscalidad —el eje que a menudo decide—. *Corrección:* integra al fiscalista desde el **diseño**, no al final.
- **Ignorar la protección de acreedores.** No prever el derecho de oposición (plazos de 3 meses / 45 días) ni la responsabilidad solidaria → calendario irreal o impugnaciones. *Corrección:* planea los plazos y el pago/garantía a acreedores.
- **Reorganizaciones sin razón de negocio.** Esquemas artificiales solo por la ventaja fiscal → recaracterización antiabuso. *Corrección:* sustancia económica real y propósito documentado.
- **Sobre-complicar la estructura.** Crear decenas de sociedades difíciles de administrar. *Corrección:* la estructura más **simple** que logra el objetivo.
- **No documentar el reparto en la escisión.** Ambigüedad sobre qué activo/pasivo fue a cada beneficiaria → conflictos. *Corrección:* descripción precisa y exhaustiva en el proyecto.

31. Mitos frecuentes

- **"El asset deal siempre conviene al comprador." Falso.** Conviene cuando el riesgo de pasivos es alto; pero puede

disparar impuestos, hacer perder contratos/permisos y exigir cientos de cesiones. Es un cálculo de los cuatro ejes.

- **"La fusión y la escisión siempre son neutrales fiscalmente." Falso.** Solo si **cumplen los requisitos** de la ley (permanencia, continuidad, avisos, a veces autorización). Mal hechas, gatillan impuestos.
- **"En el share deal hay que ceder los contratos uno por uno." Falso.** En el share deal la sociedad no cambia: los contratos **continúan** automáticamente (salvo *change of control*). La cesión individual es del **asset deal**.
- **"La escisión sirve solo para dividir empresas en problemas." Falso.** Es una herramienta estratégica para **crear valor**: carve-outs, blindaje de activos, preparación de ventas, sucesión familiar.
- **"La fusión combina dos negocios, así que siempre crea valor." Falso.** La estructura jurídica no garantiza el éxito; el valor depende de la **integración real** (Daimler-Chrysler).
- **"Una holding sirve solo para evadir impuestos." Falso.** Sirve para separar riesgo, organizar el control, blindar activos y ordenar la sucesión; la eficiencia fiscal **legítima** es un beneficio adicional, no su única razón.

32. Preguntas difíciles

1. **¿Por qué a veces conviene escindir y luego vender acciones, en vez de hacer un asset deal directo?** Porque la **escisión** transmite el negocio en **bloque** (sucesión universal: los contratos y permisos pasan sin cesión individual ni, en principio, consentimientos), puede ser **fiscalmente neutral**, y deja el negocio "envuelto" en una sociedad limpia cuyas **acciones** se venden con un SPA. Combina lo mejor del aislamiento con la continuidad.
2. **¿Cómo se protege al acreedor cuya deudora se escinde y "se lleva" los activos a otra sociedad?** Con el **derecho de oposición** (puede oponerse judicialmente en 45 días) y, sobre todo, con la **responsabilidad solidaria** de las beneficiarias (y la escidente) frente a los acreedores durante el plazo legal: la división del patrimonio **no** lo desampara.

3. **¿Qué es una reverse triangular merger y por qué se usa tanto en EE.UU.? El comprador crea una subsidiaria que se fusiona con la target, sobreviviendo la target** como filial del comprador. Se usa porque **preserva** la target (y sus contratos y permisos, evitando muchos consentimientos) y permite adquirir el 100% sin negociar con cada accionista individualmente.
4. **Si la fusión hereda todos los pasivos igual que el share deal, ¿qué la distingue?** Que la fusión **combina** patrimonios y sociedades (los socios de ambas se integran; una sociedad puede extinguirse), mientras que el share deal solo cambia al dueño de las acciones. La fusión es **integración**; el share deal, **cambio de control**. Se usan en momentos distintos (a menudo: share deal para adquirir, fusión para integrar después).
5. **¿Cuándo una reorganización "fiscalmente eficiente" cruza la línea del abuso?** Cuando carece de **razón de negocio** y **sustancia económica** real, y su **único** propósito es el beneficio fiscal. La línea está en la sustancia: separar riesgos, preparar una venta u ordenar la sucesión son razones legítimas; un rodeo artificial sin sustancia, no.

33. Casos de examen (con respuesta modelo)

Caso A. *Tu cliente quiere comprar una empresa cuyo principal valor es una concesión gubernamental intransferible, pero cuya due diligence revela una contingencia fiscal grande e incierta. ¿Qué estructura recomiendas?* **Respuesta modelo:** Tensión entre dos ejes. La **continuidad** exige **share deal** (la concesión, al ser intransferible, solo sobrevive si la sociedad titular no cambia → un asset deal la perdería). Pero el **riesgo** fiscal empuja a aislar. **Solución:** **share deal** (para conservar la concesión) **blindado** con una **indemnización especial** por la contingencia fiscal (al 100%, sin tope), **escrow** por el plazo de prescripción, y rep fiscal robusta. Es decir: se conserva la estructura que da continuidad y el riesgo se neutraliza por **contrato**, no por estructura. Razonar el equilibrio de ejes.

Caso B. *Un grupo quiere vender una de sus divisiones, que comparte sociedad con su negocio principal. Quiere rapidez,*

conservar los contratos de la división y eficiencia fiscal. ¿Cómo lo estructuras? **Respuesta modelo:** Escisión de la división a una **NewCo** (sucesión universal → contratos pasan en bloque sin cesión individual; busca **neutralidad fiscal** cumpliendo requisitos), seguida de **venta de las acciones** de la NewCo (share deal con SPA, reps, indemnización). Mencionar: planear el **derecho de oposición** de acreedores (45 días) y verificar **razón de negocio**. Combina continuidad + aislamiento + eficiencia.

Caso C. *Comprador y target son competidores; la fusión resultante tendría alta cuota de mercado. ¿Qué consideración estructural domina?* **Respuesta modelo:** Domina el **eje de autorizaciones**: la operación es una **concentración notificable** a la **COFEC**; hay que evaluar el riesgo de objeción/condiciones, **no consumir** antes de la autorización (*gun jumping*), y manejar la información sensible con **clean teams** durante la DD. El calendario y la certeza regulatoria pueden incluso decidir si la operación es viable.

34. Simulador (ejercicio tipo despacho)

Instrucciones: eres asociado de M&A. Tu cliente, un fondo de PE, quiere adquirir la **división de autopartes** de *Industrias Vega, S.A.* (que también tiene una división de bienes raíces que el fondo NO quiere), financiando 50% con deuda. Diseña la estructura antes de leer la guía.

1. **Objetivo de negocio:** enúncialo en una frase.
2. **Hallazgos relevantes de la DD (supuestos):** la división inmobiliaria tiene pasivos ambientales; la de autopartes tiene contratos clave con grandes armadoras (algunos con *change of control*); hay una contingencia fiscal menor y acotable.
3. **Aplica los cuatro ejes:** riesgo, continuidad, fiscalidad, autorizaciones. ¿Hacia qué empuja cada uno?
4. **Diseña la arquitectura** (combinando figuras).
5. **Indica los documentos** que se necesitarán (Libro 4).

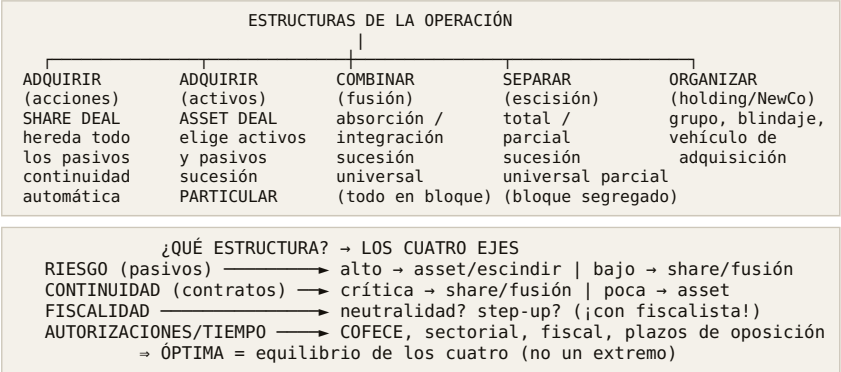
Guía de solución (resumen). (1) Adquirir la división de autopartes **aislada** de los pasivos inmobiliarios, conservando sus contratos, con eficiencia fiscal y apalancamiento. (3) **Riesgo:** alto en inmobiliaria → **aislar** (no comprar esa división). **Continuidad:** contratos con armadoras valiosos → favorece transmisión en bloque (escisión) y/o share deal; cuidar *change of control* (consentimientos como condición). **Fiscalidad:** buscar **neutralidad** de la escisión + *step-up*/deducción de intereses del apalancamiento (con fiscalista). **Autorizaciones:** posible notificación a COFECE. (4) **Arquitectura:** (i) Industrias Vega **escinde** la división de autopartes a una **NewCo limpia** (sucesión universal de contratos; neutralidad fiscal); (ii) el fondo crea un **vehículo de adquisición** con capital + deuda; (iii) el vehículo **compra las acciones** de la NewCo (share deal); (iv) posible **fusión** vehículo-NewCo (fusión apalancada); (v) **consentimientos** de armadoras con *change of control* como **condición al closing**; verificar **razón de negocio**. (5) **Documentos:** proyecto/ acuerdo de **escisión**, SPA de las acciones de NewCo (reps, indemnización, escrow), contratos de **financiamiento**, acuerdos de la **fusión**, consentimientos de terceros.

35. Flashcards

- **¿Share deal vs. asset deal en una frase?** Acciones (la sociedad entera, con todos sus pasivos) vs. activos seleccionados (se eligen activos y pasivos, con excepciones legales).
- **¿Qué pasivos siguen al negocio aun en un asset deal?** Laborales, fiscales y ambientales (por mandato legal).
- **¿Fusión por absorción vs. por integración?** Una subsiste y absorbe / todas se extinguen y nace una nueva.
- **¿Escisión total vs. parcial?** La escidente desaparece y re-parte todo / subsiste y segrega una parte.
- **¿Qué es la sucesión universal?** Transmisión en bloque y automática del patrimonio (fusión y escisión).
- **¿Plazo de oposición de acreedores?** Fusión: **3 meses**; escisión: **45 días naturales**.
- **¿Qué es la responsabilidad solidaria en la escisión?** Las beneficiarias (y escidente) responden solidariamente ante acreedores durante el plazo legal.

- **¿Qué es el derecho de separación?** El socio disidente puede salirse y exigir el reembolso de sus acciones.
- **¿Qué es la neutralidad fiscal?** Que la fusión/escisión no se grave como enajenación si cumple requisitos.
- **¿Los cuatro ejes de elección?** Riesgo · Continuidad · Fiscalidad · Autorizaciones.
- **¿Qué es una reverse triangular merger?** Una subsidiaria del comprador se fusiona con la target, que sobrevive como filial (preserva contratos, evita consentimientos).
- **¿Carve-out clásico?** Escindir el negocio a una NewCo y luego vender sus acciones (share deal).

36. Mapas mentales



37. Cuadros comparativos

Las cuatro estructuras de un vistazo

	SHARE DEAL	ASSET DEAL	FUSIÓN	ESCISIÓN
Qué se mueve	Acciones	Activos selectos	Patrimonios completos	Patrimonio dividido
Pasivos	Todos	Seleccionados (+ excepciones)	Todos (en bloque)	Repartidos (solidaria)
Transmisión	—	Particular (bien por bien)	Universal	Universal (del bloque)
Continuidad contratos	Automática*	Cesión individual	Automática*	Automática* (del bloque)
Protección acreedores	(la del contrato)	(cesión/consentimiento)	Oposición 3 meses	Oposición 45 días + solidaria
Documento típico	SPA	APA	Convenio de fusión	Proyecto/ acuerdo de escisión

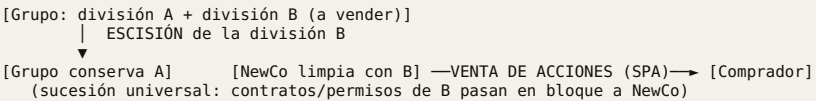
salvo cláusulas de change of control.*

Quién prefiere qué (share vs. asset)

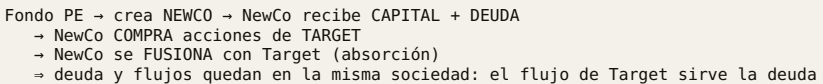
	PREFIERE SHARE DEAL	PREFIERE ASSET DEAL
Vendedor	✓ (vende todo, se libra de pasivos)	
Comprador		✓ (elige activos, aísla pasivos, step-up)
Razón fiscal	Un hecho gravable	Step-up de base, pero más gravámenes

38. Diagramas

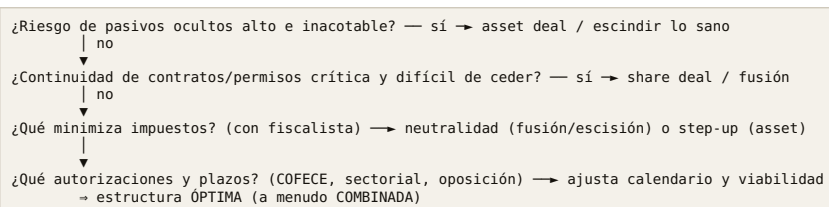
Carve-out (escisión + venta de acciones):



LBO / fusión apalancada (anticipo Libro 5):



Decisión de estructura (árbol):



39. Mnemotecnias

- **Las cuatro estructuras (AAFE):** Acciones (share) · Activos (asset) · Fusión · Escisión.
- **Share deal:** *"compro la sociedad con TODO su pasado"* → due diligence + reps fuertes.
- **Asset deal:** *"elijo lo bueno y dejo lo malo... pero lo laboral, fiscal y ambiental me persigue"*.
- **Fusión:** *"dos se hacen uno; todo pasa en bloque"* (sucesión universal).
- **Escisión:** *"uno se hace dos; reparto en bloque, respondo solidario"*.
- **Los cuatro ejes (RCFA):** Riesgo · Continuidad · Fiscalidad · Autorizaciones.
- **Oposición de acreedores:** *"Fusión, 3 meses; Escisión, 45 días"*.
- **Regla de oro:** *"no hay estructura mejor; hay estructura óptima para cada caso"*.
- **Antiabuso:** *"sin razón de negocio, no hay estructura que aguante"*.

40. Resumen ejecutivo

Toda operación de M&A debe **encarnar en una estructura jurídica**, y esa elección no es un tecnicismo: determina qué se adquiere, qué pasivos se heredan, si los contratos y permisos continúan, cuántos impuestos se pagan y qué protecciones tienen acreedores y minorías. Hay cuatro grandes estructuras. El **share deal** compra las **acciones** —la sociedad entera, con **todos** sus pasivos (conocidos u ocultos) y con **continuidad automática** de contratos y permisos (salvo *change of control*)—. El **asset deal** compra **activos seleccionados** —permite **aislar** pasivos, pero exige transmisión **individual** de cada bien y con-

trato, y ciertos pasivos (laborales, fiscales, ambientales) **siguen al negocio** por mandato legal—. La **fusión combina** dos o más sociedades en una (por absorción o por integración), con **sucesión universal** del patrimonio. La **escisión divide** una sociedad (total o parcial), también por sucesión universal del bloque segregado, con protección de acreedores vía **oposición y responsabilidad solidaria**.

El rasgo técnico que distingue a las reorganizaciones societarias (fusión, escisión) del asset deal es la **sucesión universal**: el patrimonio pasa **en bloque y automáticamente**, sin ceder bien por bien —lo que las vuelve ideales para los *carve-outs* y las integraciones—. Y el arte del abogado está en **combinar** las figuras (escindir y luego vender; crear una NewCo y fusionarla; armar holdings) para construir la arquitectura que resuelve el problema. La **fiscalidad** (neutralidad vs. step-up) suele ser el factor decisivo, y toda reorganización exige **razón de negocio** real para resistir el escrutinio **antiabuso**.

El método que integra el libro son **los cuatro ejes —riesgo, continuidad, fiscalidad y autorizaciones—**: no existe una estructura "mejor" en abstracto, sino una **óptima para cada operación**, que equilibra esos ejes a la luz del objetivo de negocio y de los hallazgos de la due diligence. El abogado que domina ese equilibrio —y que sabe **diseñar y ejecutar** la arquitectura, no solo describirla— es quien de verdad **arma deals**. Con este libro tienes el dominio técnico de las estructuras; en el Libro 4 aprenderás a **documentarlas**.

41. Checklist

Diseño de la estructura:

- [] ¿Cuál es el **objetivo de negocio** (comprar todo/parte, combinar, separar, reorganizar, preparar venta)?
- [] ¿Qué dicen los **cuatro ejes** —riesgo, continuidad, fiscalidad, autorizaciones— para este caso?
- [] ¿La estructura es **share deal, asset deal, fusión, escisión** o una **combinación**? ¿Por qué?
- [] ¿Integraste al **asesor fiscal** desde el diseño? ¿Hay neutralidad disponible? ¿Step-up?

- [] ¿La reorganización tiene **razón de negocio** y sustancia (antiabuso)? ¿Está documentada?

Ejecución (según la figura):

- [] **Share deal:** ¿transmisión válida de acciones (endoso, libro de registro)? ¿*Change of control* en contratos clave → consentimientos?
- [] **Asset deal:** ¿identificación precisa de activos y pasivos asumidos? ¿Cesiones y consentimientos? ¿Permisos transferibles o nuevos? ¿Pasivos que siguen al negocio (laboral/fiscal/ambiental)?
- [] **Fusión:** ¿acuerdo en asamblea extraordinaria de cada sociedad? ¿Inscripción y publicación? ¿Plazo de **3 meses** o pago/garantía a acreedores? ¿Relación de canje? ¿Derecho de separación?
- [] **Escisión:** ¿asamblea con mayoría reforzada? ¿Contenido del art. 228 Bis ⚡ (reparto de activos/ pasivos/capital)? ¿Publicación? ¿Plazo de **oposición 45 días**? ¿Responsabilidad solidaria? ¿Reparto de acciones y derecho de separación?

Autorizaciones y cierre:

- [] ¿Notificación a **COFEC** / autorización **sectorial** / límites de **inversión extranjera**?
- [] ¿Calendario realista considerando plazos de oposición y autorizaciones?
- [] ¿La estructura está **documentada** en el contrato correcto (SPA / APA / convenio de fusión / proyecto de escisión)?

42. Bibliografía comentada

- **Ley General de Sociedades Mercantiles (arts. 222-226 y 228 ⚡ Bis).** **Lectura imprescindible:** el derecho positivo de la fusión y la escisión en México (proceso, oposición, solidaridad). Estúdialo con el texto vigente en la mano.
- **Ley del Impuesto sobre la Renta y Código Fiscal de la Federación (reorganizaciones y norma antiabuso).** Los requisitos de **neutralidad fiscal** y la exigencia de **razón de negocio:** el eje que a menudo decide la estructura.

- **Doctrina societaria y mercantil mexicana (sociedades mercantiles).** El marco conceptual de las modificaciones estructurales y de la protección de acreedores y socios.
- **DGCL de Delaware y tratados de corporations (EE.UU.).** Las fusiones triangulares y los *appraisal rights*; vocabulario imprescindible del M&A internacional.
- **Directivas de la UE sobre modificaciones estructurales (incluidas transfronterizas).** El modelo armonizado del civil law europeo.
- **OCDE — BEPS y sustancia económica.** El marco antiabuso internacional para reorganizaciones transfronterizas.
- **Manuales de deal structuring (Practical Law, materiales de despachos).** El "cómo" práctico de combinar figuras para carve-outs, LBOs y reorganizaciones.

43. Ruta hacia el siguiente libro

Ya sabes **qué arquitectura** usar y **cómo ejecutarla**. El siguiente paso es **documentarla**: plasmar la operación en los contratos que la hacen vinculante y que asignan el riesgo entre las partes.

- **Siguiente libro:** *Libro 4 · Documentación: Term Sheet, SPA, APA, SHA* — el dominio cláusula por cláusula de los contratos del M&A: el **Term Sheet/LOI**, el **SPA** (Share Purchase Agreement) con sus *representations & warranties, covenants*, condiciones, indemnización, MAC y *disclosure schedules*; el **APA** (Asset Purchase Agreement) para los asset deals; y el **SHA** (Shareholders Agreement / convenio de accionistas) con *drag along, tag along*, derechos de veto y gobierno. Es donde **todo** lo aprendido se convierte en texto vinculante.
- **Conexión inmediata:** cada estructura de este libro tiene su documento —share deal → SPA; asset deal → APA; fusión → convenio de fusión; escisión → proyecto de escisión; entrada de socios/inversionistas → SHA—. Y los hallazgos de la due diligence (Libro 2), que viste cómo empujan la estructura (Libro 3), se traducen ahora en **cláusulas concretas** (Libro

4). Los tres libros forman una cadena: **investigar → estructurar → documentar**.

◆ **¿Por qué esto importa para un abogado corporativo?**

Porque la estructura es **el núcleo del trabajo de ingeniería jurídica** del abogado de M&A, y donde más se distingue del litigante o del generalista. Cualquiera puede documentar una compraventa de acciones; pero **diseñar** la arquitectura de una operación compleja —reorganizar un grupo, aislar un pasivo, preparar un carve-out, armar el vehículo de un LBO, ordenar una sucesión familiar— de forma que minimice riesgo e impuestos y preserve la continuidad del negocio, es trabajo de **alto valor** que solo hacen quienes dominan las estructuras a fondo. Además, la decisión de estructura **crea o destruye más valor** que casi cualquier cláusula: una estructura mal elegida cuesta millones en impuestos o pasivos heredados que ningún contrato repara. El abogado que piensa la estructura **primero** —y que sabe combinar fusión, escisión, share/asset deal y holdings como piezas de un mismo tablero— es el que las empresas y los fondos buscan para sus operaciones más importantes.

◆ Cómo piensa un socio de un despacho internacional

"Antes de redactar una sola cláusula, dibujo la estructura en una hoja en blanco: cajas y flechas, quién compra qué, qué se queda dónde. Y me hago cuatro preguntas en orden. Primero, riesgo: ¿hay algún pasivo que mi cliente NO deba tocar ni con un palo? Si lo hay, lo aísla —asset deal, o escindo lo sano y vendo eso—. Segundo, continuidad: ¿qué contratos y permisos no pueden perderse, y se transfieren fácil? Si la respuesta es 'son críticos y difíciles de mover', voy a share deal o fusión, donde todo pasa en bloque. Tercero —y esto es donde gano o pierdo el deal—, llamo a mi fiscalista y diseñamos juntos: ¿hay neutralidad en una fusión o escisión?, ¿conviene el step-up de un asset deal?, ¿quién absorbe qué impuesto? Cuarto, autorizaciones: ¿COFECE?, ¿regulador sectorial?, ¿cuánto tiempo me comen los plazos de oposición? Casi nunca uso una figura sola: la magia está en combinarlas —escindo y luego vendo acciones, o creo una NewCo y la fusiono—. Y jamás monto un esquema sin razón de negocio real: un diseño elegante sin sustancia es una bomba de tiempo. La estructura óptima no es la más ingeniosa; es la que sirve al objetivo del cliente con el menor riesgo, el menor impuesto y la mayor continuidad."

◆ Errores que cuestan millones

1. **Heredar un pasivo evitable por elegir mal la estructura.** Hacer un share deal "por costumbre" y recibir una contingencia fiscal o ambiental que un asset deal o una escisión previa habrían aislado. *Prevención:* aplicar los cuatro ejes; aislar el riesgo alto e inacotable.
2. **Crear que el asset deal aísla de todo y olvidar los pasivos que siguen al negocio.** Recibir pasivos **laborales, fiscales o ambientales** que la ley pega al activo pese al contrato. *Prevención:* mapear las excepciones legales y reforzar con reps e indemnización.
3. **Perder un contrato o permiso clave por el *change of control* o por la intransferibilidad.** Asumir continuidad que no existe. *Prevención:* identificarlo en la DD; consentimientos como condición al closing; elegir la estructura que preserva el activo.
4. **Diseñar sin el fiscalista y disparar impuestos innecesarios.** Ignorar la neutralidad disponible o gatillar

gravámenes evitables. *Prevención*: fiscalista desde el **diseño**, no al final.

5. **Reorganización sin razón de negocio (abuso)**. Esquema artificial recaracterizado por la autoridad, con impuestos, multas y daño reputacional. *Prevención*: sustancia económica real y propósito de negocio documentado.

Cierre del Libro 3. Ya dominas las **arquitecturas de la transacción**: comprar acciones o activos, fusionar, escindir, y combinarlas en reorganizaciones y holdings; conoces su proceso en la LGSM, sus protecciones de acreedores y minorías, sus efectos fiscales y, sobre todo, el método de los **cuatro ejes** para elegir la óptima. Has pasado de **conocer** las estructuras (Libro 1) a **diseñarlas y ejecutarlas**. Con la investigación (Libro 2) y la estructuración (Libro 3) en tu poder, falta convertir todo en **texto vinculante**: avanzamos al **Libro 4 · Documentación**, donde aprenderás, cláusula por cláusula, el Term Sheet, el SPA, el APA y el SHA —el lenguaje en el que se escriben los deals—. La cadena del M&A se completa: **investigar → estructurar → documentar**.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE IV

[Nivel IV · Libro 4] La Documentación de la Operación: Term Sheet, SPA, APA y SHA

☞ **Apóstrofe de vigencia** — **léela cada vez**. El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

Investigaste (Libro 2) y estructuraste (Libro 3). Ahora todo debe convertirse en **texto vinculante**. Este es el libro donde el M&A se vuelve **palabra escrita y exigible**: el **Term Sheet/LOI** que fija las bases, el **SPA** (compraventa de acciones) y el **APA** (compraventa de activos) que consuman la operación, y el **SHA** (convenio entre accionistas) que gobierna la convivencia después. Aquí la diferencia entre un abogado bueno y uno extraordinario se mide **cláusula por cláusula**: una palabra —"material", "a mi leal saber y entender", "salvo lo revelado"— puede mover millones. Este es el libro más operativo y, probablemente, el más rentable de toda la biblioteca.

Etiquetas: corporate law · M&A · contratos · term sheet · SPA · APA · SHA · reps & warranties · indemnización · MAC **Prerrequisitos:** Libro 1 · Fundamentos de M&A, Libro 2 · Due Diligence y Libro 3 · Estructuras + Contratos Parte General, Obligaciones, Contratos Mercantiles y Gobierno Corporativo. **Estándar:** V3 (43 secciones + secciones transversales). ⌚ **Tiempo estimado de dominio:** 6–8 semanas (≈ 70–90 h de estudio activo). Lectura de reconocimiento: 12–15 h. *Estúdialo en bloques:* *arquitectura documental* y *Term Sheet/LOI* → *anatomía del SPA* (reps, covenants, condiciones, indemnización, MAC) → *disclosu-*

re schedules y mecanismos de precio → APA (asset deal) → SHA (convenio de accionistas).

Aviso de método. Tratado, no repaso. Aquí aprenderás a **leer y redactar** los contratos del M&A entendiendo **por qué** existe cada cláusula, **a quién protege, cómo se negocia y qué pasa si falta o falla**. Cada cláusula se conecta con la due diligence (de dónde nace) y con la estructura (qué documento corresponde a cada arquitectura). No memorices cláusulas: **entiende su lógica**.

NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL (VISTA RÁPIDA)

Litigio	★★★★☆
Corporate	★★★★★
M&A	★★★★★
Mercado de Valores	★★★★☆
Venture Capital	★★★★★
Private Equity	★★★★★
Gobierno Corporativo	★★★★★
Compliance	★★★☆☆
Derecho Bancario	★★★★☆
Empresa Familiar	★★★★☆

Es la competencia más visible y mejor remunerada del abogado de M&A: redactar y negociar el SPA y el SHA. Quien domina la documentación con criterio —no como formulario— se vuelve indispensable en cualquier operación.

1. Introducción

Una operación de M&A vive, finalmente, en **documentos**. Todo lo que investigaste en la due diligence y todo lo que diseñaste en la estructura debe **plasmarse por escrito** en contratos que sean claros, completos y, sobre todo, **exigibles**. Este libro estudia los **cuatro documentos nucleares** del M&A:

1. El **Term Sheet** (u hoja de términos) y la **LOI/Carta de Intención** —el acuerdo **preliminar** que fija las bases de la negociación, mayormente **no vinculante**—.
2. El **SPA** (*Share Purchase Agreement* / contrato de compraventa de acciones) —el contrato **definitivo** del *share deal*, el documento rey del M&A—.
3. El **APA** (*Asset Purchase Agreement* / contrato de compraventa de activos) —el contrato definitivo del *asset deal*—.

4. El **SHA** (*Shareholders Agreement* / convenio entre accionistas) —el contrato que **gobierna la relación** entre los socios después de la operación (capital, decisiones, salidas)—.

La idea rectora del libro: **el contrato de M&A no describe una compraventa; la diseña como un sistema de asignación de riesgo a lo largo del tiempo**. A diferencia de comprar un coche (pagas, te lo llevas, fin), en M&A el contrato regula un **proceso**: lo que cada parte declara (reps), lo que promete hacer y no hacer entre la firma y el cierre (covenants), las condiciones para cerrar, qué pasa si algo sale mal después (indemnización), cómo se ajusta el precio, y cómo conviven los socios durante años (SHA). Cada cláusula es una **pieza de ingeniería** que responde a un riesgo concreto —muchos de ellos detectados en la due diligence—.

Por eso este libro no es un formulario. Vas a aprender la **gramática del riesgo**: por qué existe cada cláusula, a quién favorece, cómo se negocia la palabra exacta, y qué consecuencia tiene su redacción. Quien entiende esa gramática puede leer cualquier SPA del mundo y detectar en minutos dónde está el riesgo y quién lo soporta. Esa es la habilidad que define al abogado de transacciones de élite.

2. Objetivos del libro

Al terminar, el lector será capaz de:

- **Distinguir y articular** los cuatro documentos del M&A (Term Sheet/LOI, SPA, APA, SHA) y saber **cuál corresponde** a cada estructura (Libro 3) y **en qué fase** se usa cada uno (Libro 1).
- **Manejar un Term Sheet/LOI**: distinguir lo **vinculante** (exclusividad, confidencialidad, ley aplicable) de lo **no vinculante** (precio, estructura) y entender por qué esa distinción es crítica.
- **Disecionar la anatomía del SPA** cláusula por cláusula: objeto y precio, **representations & warranties, covenants, condiciones** (CP), **indemnización** (con *caps, baskets*, supervivencia), **MAC, closing y signing**.

- **Entender los *disclosure schedules*** y su diálogo con la due diligence y con las reps (qué se revela deja de estar garantizado; el debate del *sandbagging*).
- **Dominar los mecanismos de precio:** precio fijo, *locked box*, *completion accounts*, ajuste por capital de trabajo y deuda neta, *earn-out*, *escrow*.
- **Comprender el APA:** cómo se describe el perímetro de activos y pasivos, las cesiones y consentimientos, y en qué se diferencia su estructura de la del SPA.
- **Dominar el SHA:** cláusulas de gobierno (consejo, vetos, *deadlock*), de capital (preferencias, antidilución) y de transferencia y salida (*lock-up*, *ROFR/ROFO*, *tag along*, *drag along*, *put/call*).
- **Traducir** hallazgos de la due diligence en cláusulas concretas (rep específica, indemnización especial, condición, ajuste) y **leer** un contrato detectando dónde está el riesgo y quién lo soporta.

3. Importancia profesional

La redacción y negociación de la documentación es **la competencia más visible y mejor remunerada** del abogado de M&A. Es el producto tangible por el que el cliente paga: el contrato que protege su inversión. Un socio de M&A se distingue, ante todo, por su **maestría en el SPA y el SHA** —saber qué cláusula pedir, cómo redactarla, hasta dónde ceder en la negociación y qué riesgo esconde cada palabra del borrador de la contraparte—.

Esta habilidad tiene una característica peculiar: es **acumulativa y muy difícil de improvisar**. Un buen contrato de M&A es el resultado de décadas de práctica destilada en cláusulas estándar de mercado, cada una de las cuales existe porque **algún deal salió mal** y la cláusula nació para evitar que se repita. Quien entiende esa historia —por qué la cláusula MAC se redacta así tras el caso *Akorn*, por qué los *caps* y *baskets* limitan la indemnización, por qué el *sandbagging* se pacta expresamente— lee los contratos con una profundidad que un formulario jamás da.

Para **tu perfil específico** —estructuración de operaciones complejas, M&A, gobierno corporativo y contratos estratégicos—, este libro es **central**: el SPA/APA es donde se documenta la operación; el SHA es donde se diseña el **gobierno corporativo contractual** (cómo deciden los socios, cómo entran y salen inversionistas); y el Term Sheet es donde se sientan las bases de cualquier contrato estratégico. Dominar esta documentación es dominar el **lenguaje en el que se escriben los acuerdos corporativos**.

4. Historia y origen

Los contratos del M&A moderno son, en su forma actual, una **creación de la práctica anglosajona** del siglo XX, especialmente de los grandes despachos de Nueva York y Londres. A diferencia de las figuras societarias (que vienen de la ley), la **arquitectura del SPA** —con sus *representations & warranties*, *covenants*, *conditions* e *indemnification*— se desarrolló como un **producto de la autonomía contractual**: los abogados, ante operaciones cada vez más grandes y riesgosas, fueron inventando cláusulas para asignar el riesgo de lo desconocido entre comprador y vendedor.

El origen conceptual está en el **derecho de contratos del common law** y en su lógica de *warranties* (garantías cuyo incumplimiento da derecho a daños) y *conditions* (condiciones cuyo incumplimiento permite no cumplir o terminar). Sobre esa base, la práctica transaccional construyó un edificio sofisticado: las reps para distribuir el riesgo informativo, los *disclosure schedules* para que el vendedor revele excepciones, la indemnización con sus topes y mínimos para acotar la responsabilidad, la cláusula MAC para el riesgo del período entre firma y cierre.

El **Term Sheet** y la **LOI** nacieron de la necesidad práctica de **fijar las bases** de una negociación compleja antes de invertir en la due diligence y en la redacción del contrato definitivo —un "apretón de manos" estructurado que ordena el proceso sin comprometer aún a las partes en lo sustancial—. El **SHA**, por su parte, evolucionó del derecho societario y de la necesidad de los socios de regular **contractualmente** lo que los estatutos

no alcanzan a cubrir (especialmente la convivencia entre mayoritarios y minoritarios, y entre fundadores e inversionistas).

En **México y el civil law**, estos documentos se **adoptaron e integraron** a partir de los años 1990, adaptando las cláusulas anglosajonas al marco del Código Civil y de Comercio. Hoy un SPA mexicano se parece muchísimo a uno de Nueva York — porque el M&A es global—, pero se interpreta y ejecuta conforme al derecho mexicano, lo que genera matices finos que el abogado debe dominar.

5. Evolución histórica

La documentación del M&A ha evolucionado en tres movimientos:

1) De la compraventa simple al contrato de asignación de riesgo. Originalmente, comprar una empresa se documentaba como una compraventa más. Con el tiempo, y a medida que los deals revelaban riesgos ocultos (pasivos, contingencias, información falsa), el contrato se transformó en un **sistema sofisticado de asignación de riesgo**: las reps, la indemnización y la MAC convirtieron el SPA en una **máquina de distribuir lo desconocido** entre las partes.

2) La estandarización de mercado. La repetición de miles de operaciones generó **estándares de mercado** para cada cláusula: rangos típicos de *caps* (qué porcentaje del precio puede reclamarse), de plazos de supervivencia de las reps, de *baskets*. Surgieron documentos de referencia (como el *Model Stock Purchase Agreement* de la ABA) y bases de *precedents*. El abogado moderno negocia sabiendo qué es "de mercado" y qué es "agresivo".

3) La era de los seguros y la eficiencia. En las últimas dos décadas apareció el **seguro de representations & warranties (W&I insurance)**, que traslada a una aseguradora el riesgo de que las reps sean falsas, permitiendo a los vendedores salir "limpios" (sin escrow ni responsabilidad prolongada) y agilizando los deals. Esto ha **reconfigurado** la negociación de la indemnización en muchas operaciones. En paralelo, la tecnología (gestión de borradores, control de versiones, revisión

asistida) ha acelerado la producción de contratos, aunque el **criterio** sigue siendo humano.

6. Contexto económico

La documentación del M&A tiene una función económica precisa: **reducir los costos de transacción y distribuir el riesgo de forma eficiente** para que el deal se haga y cree valor. Tres ideas económicas la gobiernan:

- **El contrato como respuesta a la asimetría de información.** Como vimos en la due diligence (Libro 2), el vendedor sabe más que el comprador. Las **reps & warranties** son el mecanismo económico que corrige esa asimetría *en el contrato*: el vendedor "garantiza" un estado de cosas y, si miente u omite, paga (indemnización). Esto permite al comprador pagar un precio justo en vez de descontar por miedo a lo desconocido.
- **La asignación eficiente del riesgo.** La teoría dice que cada riesgo debe asignarse a quien mejor puede **controlarlo o soportarlo**. El SPA hace exactamente eso: los riesgos del pasado de la empresa (que el vendedor conocía o debía conocer) se le asignan vía reps; los riesgos futuros del negocio (que el comprador ahora controla) los asume el comprador; los riesgos concretos detectados se asignan específicamente (indemnización especial). Una buena redacción **minimiza el riesgo mal asignado**, que es puro valor destruido.
- **Los límites a la responsabilidad como precio implícito.** Los *caps, baskets* y plazos de supervivencia no son "trucos del vendedor": son la forma de **poner precio** al riesgo residual. Un vendedor que garantiza sin límite cobraría más (o no vendería); un *cap* es, en el fondo, un reparto económico de cuánto riesgo retiene cada parte. La negociación de estos límites es, en realidad, una **negociación de precio encubierta**.

Y la razón profunda por la que un SPA es como es: es un contrato incompleto. Esta es, probablemente, la idea teórica más útil de todo el libro, y viene de la economía de los contratos (Grossman, Hart y Moore; el programa por el que Hart reci-

bió el Nobel). Su punto es demoledor por lo obvio: **es imposible prever todos los estados posibles del mundo** entre la firma y el cierre, y mucho menos en los años siguientes. Ningún documento, por largo que sea, puede enumerar todas las contingencias.

Si eso es cierto, entonces un SPA **no busca cubrir todo** —sería una tarea imposible—. Busca algo más inteligente: **asignar los derechos de control y el riesgo residual**. Es decir, contestar de antemano dos preguntas para todo lo que nadie previó: *¿quién decide?* y *¿quién paga?*

Con esa lente, las cuatro cláusulas de riesgo dejan de ser una lista y se vuelven un sistema con reparto de funciones:

CLÁUSULA	QUÉ GOBIERNA	QUÉ RIESGO ASIGNA
Declaraciones y garantías	El estado del mundo a la firma	El riesgo de información asimétrica (Akerlof): operan como un seguro contractual sobre lo que el vendedor sabe y el comprador no
Covenants	La conducta entre firma y cierre	El riesgo de que la empresa se administre mal o se vacíe en el intervalo
Condiciones de cierre	Los hechos que deben ocurrir	El riesgo de que el mundo cambie antes de cerrar (autorizaciones, MAC)
Indemnización (<i>cap, basket, survival, escrow</i>)	Las consecuencias de que algo resulte falso	El riesgo residual: quién paga, hasta cuánto y con qué respaldo

La consecuencia práctica para tu forma de redactar. Cuando no puedas prever un escenario —y no vas a poder— deja de intentar describirlo y **decide quién lo soporta**. Un contrato que asigna bien el riesgo de lo desconocido es mejor que uno que intenta enumerarlo y falla. Ahí está la diferencia entre un redactor prolijo y un abogado que entiende lo que está haciendo.

7. Contexto político y regulatorio

La libertad para diseñar los contratos del M&A es amplia (autonomía de la voluntad), pero opera dentro de límites regulatorios que el abogado debe respetar:

- **Límites del orden público y la ley imperativa.** Por más que las partes pacten, no pueden contravenir normas impe-

rativas: ciertas protecciones de minorías, reglas societarias de la LGSM, derechos laborales irrenunciables, normas de competencia. Una cláusula que las viole es **nula**.

- **Derecho de la competencia (COFECE).** Las cláusulas de **no competencia** del vendedor (muy comunes en el SPA) deben ser **razonables** en objeto, tiempo y territorio para no constituir una restricción ilícita a la competencia. Y el calendario de *closing* debe respetar la prohibición de *gun jumping*.
- **Régimen de las emisoras (LMV).** Si la *target* es pública, la documentación interactúa con el régimen de OPAs, revelación de información e información privilegiada.
- **Inversión extranjera y sectores regulados.** Los contratos deben respetar los límites a la participación foránea y prever las autorizaciones sectoriales como condiciones.
- **Validez y forma.** El derecho mexicano impone requisitos de forma para ciertos actos (transmisión de inmuebles ante notario, inscripciones registrales), que el contrato debe satisfacer para ser plenamente eficaz frente a terceros.

8. Contexto social

La documentación de M&A, aunque técnica, refleja y administra **relaciones humanas tensas**. El SPA es el producto de una **negociación adversarial** entre comprador y vendedor, cada uno tratando de quedarse con la mejor asignación de riesgo; el contrato es la **foto del equilibrio de poder** alcanzado (un comprador fuerte logra reps amplias, caps altos y *pro-sandbagging*; un vendedor fuerte, lo contrario). Leer un contrato es, en parte, leer **quién tenía más poder** en la mesa.

El SHA, por su parte, regula una **convivencia de años** entre personas que seguirán siendo socios: fundadores e inversionistas, familia y fondo, mayoritarios y minoritarios. Sus cláusulas (vetos, resolución de *deadlocks*, salidas) son, en el fondo, mecanismos para **manejar el conflicto humano** antes de que ocurra —un "acuerdo prenupcial" empresarial—. El abogado que redacta un SHA está diseñando **cómo se llevarán las personas** cuando las cosas vayan bien y, sobre todo, cuando vayan mal.

Hay también una dimensión de **confianza y reputación**: aunque el contrato lo prevea todo, las partes prefieren no litigar (es caro y destruye relaciones). Por eso muchos mecanismos (escrow, ajustes, arbitraje) buscan resolver los conflictos **sin guerra**. El buen abogado redacta para **prevenir el litigio**, no solo para ganarlo.

9. Contexto empresarial

Desde la óptica del negocio, los documentos del M&A cumplen funciones estratégicas que el abogado debe entender para servir bien a su cliente:

- **El Term Sheet ordena el proceso y "amarra" al vendedor.** Antes de gastar en due diligence y abogados, el comprador quiere **exclusividad** (que el vendedor no negocie con otros) y unas bases claras. El Term Sheet le da eso. Para el vendedor, fija expectativas y filtra compradores serios.
- **El SPA protege la inversión y reparte el riesgo del pasado.** Es el documento donde el comprador **blinda** lo que pagó: reps que cubren lo desconocido, indemnización para cobrar si algo sale mal, ajustes para pagar el precio correcto. Para el vendedor, es donde **acota su responsabilidad** (caps, plazos) y logra un "corte limpio".
- **El APA permite comprar selectivamente.** Cuando la estrategia es adquirir solo una parte (una línea, una planta, una cartera), el APA es el vehículo: describe con precisión qué se lleva y qué se deja.
- **El SHA diseña el futuro del control y de la salida.** Para un fondo de PE/VC, el SHA es **tan importante como el precio**: define sus derechos de gobierno (asientos, vetos), su protección económica (preferencias, antidilución) y, sobre todo, **cómo y cuándo saldrá** (drag along, tag along, derechos de venta). Para los fundadores, define cuánto control conservan. El SHA es el **contrato del poder y del dinero futuro**.

En suma: el abogado que domina estos documentos no solo "redacta"; **diseña la asignación de riesgo, el gobierno y las salidas** de la operación. Conversa con el negocio (¿qué te preo-

cupa?, ¿qué riesgo no quieres?, ¿cómo y cuándo quieres salir?) y traduce esas respuestas en cláusulas. Esa es la diferencia entre un mecanógrafo de contratos y un **arquitecto de operaciones**.

10. Definiciones doctrinales

La doctrina transaccional define los documentos y conceptos centrales así:

- **Term Sheet / Hoja de términos:** documento que resume las **condiciones económicas y estructurales esenciales** de una operación propuesta, generalmente **no vinculante** en cuanto al fondo, que sirve de base para negociar el contrato definitivo. La doctrina lo describe como la "**columna vertebral comercial**" del deal.
- **Letter of Intent (LOI) / Carta de Intención:** comunicación formal por la que una parte expresa su **intención** de realizar la operación bajo ciertos términos. Funcionalmente se solapa con el Term Sheet; suele incorporar **algunas cláusulas vinculantes** (exclusividad, confidencialidad, gastos).
- **SPA (Share Purchase Agreement) / Contrato de compra-venta de acciones:** contrato **definitivo y vinculante** por el cual el vendedor transmite al comprador las **acciones o partes sociales** de la *target* a cambio de un precio, regulando exhaustivamente la asignación del riesgo (reps, covenants, condiciones, indemnización). Es el documento central del *share deal*.
- **APA (Asset Purchase Agreement) / Contrato de compra-venta de activos:** contrato definitivo por el cual el vendedor transmite **activos (y, en su caso, pasivos) determinados** al comprador. Es el documento central del *asset deal*; su rasgo distintivo es la **descripción precisa del perímetro** (qué activos y pasivos se incluyen y cuáles se excluyen).
- **SHA (Shareholders Agreement) / Convenio entre accionistas:** contrato entre los socios de una sociedad (y a veces la sociedad misma) que regula sus **relaciones internas**: go-

bierno (cómo se decide), capital (preferencias, dilución) y transmisión/salida (cómo entran y salen socios). Complementa —y a veces "blinda"— los estatutos sociales.

- **Representations & warranties (declaraciones y garantías / manifestaciones):** afirmaciones de hecho que una parte (típicamente el vendedor) hace sobre sí misma y sobre la *target* a una fecha determinada, y de cuya **falsedad** responde. La doctrina las define como el mecanismo de **asignación contractual del riesgo informativo**.
- **Covenants (obligaciones de hacer / no hacer):** compromisos de conducta de las partes, especialmente **entre la firma (*signing*) y el cierre (*closing*)** —p. ej., operar el negocio en el curso ordinario, no repartir dividendos extraordinarios— y, a veces, posteriores al cierre (no competencia, no captación).
- **Conditions precedent (CP) / condiciones suspensivas:** hechos que deben **cumplirse** para que nazca la obligación de cerrar (autorizaciones, consentimientos, veracidad de las reps a la fecha de cierre).
- **Indemnification / indemnización:** mecanismo por el cual una parte se obliga a **resarcir** a la otra por las pérdidas derivadas del incumplimiento de reps/covenants o de contingencias identificadas.
- **MAC / MAE (*Material Adverse Change / Effect*):** cláusula que permite al comprador **no cerrar** (o renegociar) si entre la firma y el cierre ocurre un **cambio sustancialmente adverso** en la *target*.

11. Definiciones legales y marco normativo

Estos contratos son, en esencia, **creación de la autonomía de la voluntad**, pero se asientan en el marco legal mexicano:

- **Libertad contractual y obligatoriedad (CCF y Código de Comercio).** El principio *pacta sunt servanda* (los contratos legalmente celebrados obligan a las partes) y la **autonomía de la voluntad** son la base legal: las partes pueden diseñar libremente las cláusulas (reps, indemnización, MAC) **dentro**

de los límites de la ley, el orden público y las buenas costumbres.

- **Compraventa (CCF / Código de Comercio).** El SPA y el APA son, en su núcleo, **compraventas** (de acciones o de activos), reguladas supletoriamente por las reglas de la compraventa: cosa, precio, obligaciones de transmitir y de pagar, **saneamiento** por vicios ocultos y por evicción —que las reps e indemnización **complementan y modulan** contractualmente—.
- **Transmisión de acciones (LGSM / LMV).** La transmisión de acciones nominativas opera por **endoso** e inscripción en el **libro de registro de accionistas**; el SPA documenta la obligación, pero la transmisión societaria se perfecciona conforme a la LGSM (o la LMV para emisoras).
- **Cesión de derechos y de deudas (CCF).** En el APA, la transmisión de contratos y créditos se rige por las reglas de la **cesión de derechos** (notificación al deudor) y de la **asunción de deudas** (consentimiento del acreedor cuando se requiera).
- **Vicios del consentimiento (CCF).** El **dolo**, el **error** y la **mala fe** pueden viciar el contrato; esto sustenta la responsabilidad del vendedor que **mintió** en sus reps más allá de lo pactado.
- **Convenios entre accionistas (LGSM / LMV).** El derecho mexicano **reconoce y da eficacia** a los convenios entre accionistas (particularmente en la **S.A.P.I.** conforme a la LMV, que valida cláusulas como restricciones a la transmisión, derechos de veto, *drag/tag along*, opciones), lo que dio base legal sólida al **SHA** en México.
- **Condición y término (CCF).** Las **condiciones suspensivas** (CP del *closing*) y los **plazos** se rigen por la teoría general de las obligaciones (que estudiaste en Nivel I-II).

Nota de método: la eficacia de ciertas cláusulas "importadas" del common law (p. ej., *sandbagging*, ciertos límites de indemnización) depende de su **compatibilidad** con el derecho mexicano; el abogado debe redactarlas con anclaje en figuras locales (renuncias, penas convencionales, condiciones) para que sean exigibles. Verifica siempre la ley vigente (Manifiesto XI.5).

12. Definición sencilla

Piensa en comprar una empresa como en **un matrimonio con acuerdo prenupcial muy detallado**.

- El **Term Sheet / LOI** es el **noviazgo formal**: "queremos casarnos bajo estas condiciones generales, y mientras tanto prometemos no salir con nadie más (exclusividad) y no contar nuestros secretos (confidencialidad)". Casi nada es obligatorio todavía, salvo esas dos promesas.
- El **SPA** es el **contrato de matrimonio**: lo dice todo. Qué aportas, qué me aseguras que es verdad de ti ("no tengo deudas ocultas" = reps), qué prometes hacer hasta la boda ("no gastarás el dinero común" = covenants), qué tiene que pasar para casarnos ("que tus papás autoricen" = condiciones), y **qué pasa si me mentiste** ("me compensas" = indemnización). Incluso prevé qué ocurre si justo antes de la boda descubrimos un desastre (MAC = me puedo echar para atrás).
- El **APA** es como decir: "no me caso contigo entero; me quedo **solo con tu casa y tu coche**, no con tus deudas ni con tu suegra". Compras piezas, no a la persona completa.
- El **SHA** es el **reglamento de convivencia** para cuando ya vivimos juntos (varios socios): quién decide qué, quién pone cuánto, y —clave— **cómo nos divorciamos** sin destruirnos (cómo y cuándo puede irse cada quien, y a qué precio).

La pregunta de fondo en todos: *¿qué me aseguras?, ¿qué pasa si sale mal?, ¿cómo entro y cómo salgo?* Todo el libro responde, cláusula por cláusula, esas tres preguntas.

13. Conceptos fundamentales

Fija este vocabulario; es el idioma del M&A y lo usarás en cada operación de tu carrera:

Documentos y fases:

- **Term Sheet / LOI / MOU:** acuerdos **preliminares** (bases de la negociación), mayormente no vinculantes salvo cláusulas específicas.
- **SPA / APA:** contratos **definitivos** de compraventa (acciones / activos).
- **SHA:** convenio que **gobierna** la relación entre socios.
- **Signing vs. Closing:** la **firma** del contrato vs. el **cierre** (pago y transmisión); entre ambos se cumplen las condiciones (Libro 1).

El núcleo del SPA:

- **Representations & warranties (reps):** declaraciones de hecho garantizadas (sobre el título de las acciones, estados financieros, contratos, litigios, impuestos, cumplimiento, etc.).
- **Fundamental reps:** las reps "esenciales" (título de las acciones, capacidad, autoridad) que reciben protección reforzada (sin tope, plazo largo).
- **Covenants:** obligaciones de hacer/no hacer, pre-cierre (operación ordinaria) y post-cierre (no competencia, no captación).
- **Conditions precedent (CP):** condiciones para cerrar (autorizaciones, consentimientos, veracidad de reps —*bring-down*—, ausencia de MAC).
- **Indemnification:** la obligación de resarcir; viene modulada por:
- **Cap (tope):** monto máximo de responsabilidad (a menudo un % del precio).
- **Basket / deductible:** umbral mínimo de pérdidas acumuladas antes de poder reclamar (tipo *tipping* o *true deductible*).
- **De minimis:** monto mínimo por reclamación individual para que cuente.

- **Survival (supervivencia):** plazo durante el cual las reps siguen vivas y reclamables.
- **Special / specific indemnity:** indemnización específica por un riesgo **concreto y conocido** (de la due diligence), normalmente **fuera** de caps y baskets.
- **MAC / MAE:** cláusula de cambio adverso relevante (derecho a no cerrar).
- **Disclosure schedules:** anexos donde el vendedor **revela excepciones** a sus reps (lo revelado deja de estar garantizado).
- **Sandbagging:** si el comprador que **sabía** que una rep era falsa puede igual reclamar (*pro-sandbagging*) o no (*anti-sandbagging*); se pacta expresamente.

Mecanismos de precio:

- **Locked box:** precio fijo basado en un balance de referencia pasado, sin ajuste posterior (el riesgo/ beneficio pasa al comprador desde la fecha del *box*).
- **Completion accounts:** ajuste del precio según el balance al cierre (capital de trabajo, deuda neta, caja).
- **Earn-out:** parte del precio **diferida y condicionada** a resultados futuros de la *target*.
- **Escrow / holdback:** retención de parte del precio en garantía de indemnizaciones.

El núcleo del SHA:

- **Drag along (derecho de arrastre):** la mayoría que vende puede **obligar** a la minoría a vender en las mismas condiciones.
- **Tag along (derecho de acompañamiento):** la minoría puede **sumarse** a la venta de la mayoría en las mismas condiciones (protección).
- **ROFR / ROFO (derecho del tanto / de primera oferta):** derechos preferentes de los socios para adquirir antes que un tercero.
- **Lock-up:** prohibición temporal de transmitir acciones.

- **Preferencia de liquidación:** derecho del inversionista a cobrar primero (un múltiplo de su inversión) en una venta o liquidación.
- **Antidilución:** protección del inversionista frente a emisiones futuras a menor precio (*down round*).
- **Vetos / reserved matters:** decisiones que requieren el consentimiento del inversionista/minoría.
- **Deadlock:** mecanismo para resolver **empates/bloqueos** en la toma de decisiones (p. ej., *buy-sell* o "ruleta rusa").
- **Put / Call options:** opciones de **venta** (put, el socio obliga a que le compren) y de **compra** (call, obliga a que le vendan) bajo ciertas condiciones.

Con este vocabulario, entramos al **desarrollo absoluto**, donde diseccionamos cada documento por dentro.

14. Desarrollo absoluto

Esta es la sección central del libro. La desarrollamos en cinco bloques: **(A)** el **Term Sheet / LOI** —las bases de la negociación y la trampa de lo "no vinculante"—; **(B)** la **anatomía del SPA, parte I** —estructura, *representations & warranties, covenants y conditions*—; **(C)** la **anatomía del SPA, parte II** —*indemnification, MAC, disclosure schedules y sandbagging*—; **(D)** los **mecanismos de precio y el APA** —cómo se fija y ajusta el precio, y las particularidades del *asset deal*—; y **(E)** el **SHA** —gobierno, capital y salidas—. Estúdialos en ese orden: primero las bases, luego el contrato rey por dentro, después el precio y el *asset deal*, y al final el contrato del poder y la salida.

14.A · EL TERM SHEET / LOI (LAS BASES Y LA TRAMPA DE LO "NO VINCULANTE")

El **Term Sheet** (u hoja de términos) y la **LOI** (carta de intención) son el **primer documento** de una operación: resumen las condiciones esenciales sobre las que las partes acuerdan **negociar** el contrato definitivo. Funcionalmente son casi lo mismo (el Term Sheet suele ser esquemático, por puntos; la LOI tiene forma de carta); a menudo se usan combinados.

Qué contiene un Term Sheet típico:

- **Las partes y la estructura:** quién compra, quién vende, y **qué estructura** (share deal, asset deal, fusión —Libro 3—).
- **El precio y su forma:** monto o rango, forma de pago (caja, acciones, diferido), mecanismo de precio (locked box vs. completion accounts —sección 14.D—), *earn-out*, *escrow*.
- **Las condiciones esenciales:** due diligence satisfactoria, autorizaciones (COFECE), consentimientos, financiamiento.
- **El calendario:** plazos para la due diligence, la negociación y el cierre.
- **Las cláusulas de proceso (las que SÍ suelen ser vinculantes):** **exclusividad** (*no-shop*: el vendedor no negocia con otros por un periodo), **confidencialidad** (NDA), **gastos** (quién paga qué), **ley aplicable y jurisdicción/arbitraje**.

La distinción crítica: vinculante vs. no vinculante. Esta es la lección capital del Term Sheet, y un error aquí cuesta carísimo. Por regla general:

- Es **NO vinculante** lo **sustantivo**: el precio, la estructura, los términos comerciales. ¿Por qué? Para que las partes puedan **retirarse** si la due diligence revela problemas o si la negociación del SPA fracasa, sin quedar obligadas a comprar/vender.
- Es **VINCULANTE** lo **procesal**: la exclusividad, la confidencialidad, los gastos, la ley aplicable. El comprador **exige** exclusividad vinculante porque va a **invertir** mucho dinero en la due diligence y no quiere que el vendedor lo use para subir el precio con otros postores.

La trampa. Un Term Sheet **mal redactado** puede volverse **vinculante sin querer**. Si el lenguaje sugiere un acuerdo cerrado sobre lo sustantivo (o si no se dice claramente que no obliga), un tribunal podría considerar que existe un **contrato** o, al menos, una **responsabilidad precontractual** (*culpa in contrahendo*: responsabilidad por romper de mala fe una negociación avanzada). Por eso **toda** hoja de términos sería incluye una cláusula expresa y destacada que dice, en esencia: "*salvo las cláusulas X, Y y Z (exclusividad, confidencialidad,*

gastos, ley aplicable), este documento NO es vinculante y no obliga a las partes a celebrar la operación". Redactar bien esa cláusula es de las primeras cosas que aprende —a golpes— un abogado junior.

Para qué sirve, entonces, si casi nada obliga. Sirve muchísimo: **ordena** la negociación, **alinea** expectativas, **filtra** a las partes no serias, **amarra** al vendedor con la exclusividad mientras el comprador invierte en la due diligence, y crea un **compromiso moral y reputacional** (retractarse de lo acordado en un Term Sheet, aunque no obligue legalmente, tiene costo de reputación). Es el **mapa** que guía la redacción del SPA.

14.B · ANATOMÍA DEL SPA, PARTE I (ESTRUCTURA, REPS, COVENANTS, CONDICIONES)

El SPA es el documento rey. Un SPA típico de M&A tiene una **estructura estándar** que debes conocer como la palma de tu mano, porque se repite (con variaciones) en todo el mundo:

1. **Definiciones.** El glosario del contrato (términos en mayúscula). Aburrido pero **crítico**: la definición de "Pérdidas", "Conocimiento", "Cambio Adverso Relevante" o "Deuda" puede decidir un litigio.
2. **Objeto y precio.** Qué se vende (las acciones), por cuánto, forma de pago y mecanismo de precio.
3. **Representations & warranties** del vendedor (y algunas del comprador).
4. **Covenants** (obligaciones pre-cierre y post-cierre).
5. **Conditions precedent** (condiciones para cerrar).
6. **Indemnification** (con caps, baskets, supervivencia).
7. **Terminación** (cuándo y cómo se puede abandonar la operación; cláusula MAC).
8. **Misceláneos / boilerplate** (ley aplicable, arbitraje, notificaciones, cesión, integridad del acuerdo).
9. **Anexos**, incluidos los **disclosure schedules**.

Veamos las tres primeras piezas sustantivas (las demás, en 14.C):

Representations & warranties (el corazón de la asignación de riesgo). Son las **afirmaciones de hecho** que el

vendedor garantiza sobre la *target*, referidas a una fecha. Si resultan **falsas**, el comprador tiene derecho a **indemnización** (o, si se descubre antes del cierre, a no cerrar). Su función económica —ya lo vimos— es **corregir la asimetría de información**: el vendedor "pone por escrito" que la empresa es como dice, y responde si no. Las reps típicas cubren:

- **Fundamentales**: título y propiedad de las acciones, capacidad y autoridad para vender, validez del contrato. (Reciben protección reforzada: sin tope, plazo largo.)
- **Del negocio**: estados financieros veraces, ausencia de pasivos no revelados, contratos materiales vigentes, **cumplimiento legal**, situación **fiscal**, **laboral**, **litigios**, propiedad **intelectual**, **permisos**, inmuebles, seguros, ausencia de cambios desde cierta fecha.

La **negociación de las reps** es un arte fino. Tres "perillas" clave:

- **Knowledge qualifier ("a leal saber y entender")**: el vendedor solo garantiza lo que **sabe** (no lo desconocido). El comprador prefiere reps **sin** este calificador (responsabilidad objetiva); el vendedor, **con** él. ¿Y "conocimiento" de quién, y con qué deber de investigar? Se define con cuidado.
- **Materiality qualifier ("en todos los aspectos materiales")**: acota la rep a lo relevante, evitando reclamaciones por nimiedades. El comprador teme que vacíe la rep; se negocia el umbral.
- **Alcance temporal y de excepciones**: "salvo lo revelado en el *disclosure schedule*" (sección 14.C).

Covenants (las obligaciones de conducta). Regulan **qué deben (y no deben) hacer** las partes, sobre todo **entre el signing y el closing** (el periodo *interim*), cuando el vendedor todavía controla la empresa pero ya la "vendió". Los más importantes:

- **Conduct of business (operación en el curso ordinario)**: el vendedor se obliga a **seguir operando normalmente** y a **no** hacer cosas que cambien la empresa (no repartir dividendos extraordinarios, no endeudarse, no vender activos cla-

ve, no subir sueldos, no contratar/despedir masivamente). Protege al comprador de recibir una empresa "vaciada" o alterada entre la firma y el cierre.

- **Access (acceso):** el comprador puede seguir revisando información (due diligence confirmatoria).
- **Reasonable/best efforts (esfuerzos para cerrar):** ambas partes se obligan a gestionar las autorizaciones (COFECE) y consentimientos necesarios.
- **Post-cierre: no competencia y no captación** (*non-compete, non-solicit*) del vendedor —razonables en tiempo, territorio y objeto para ser válidas (orden público de competencia)—, cooperación fiscal, confidencialidad.

Conditions precedent (las condiciones para cerrar). Son los **requisitos que deben cumplirse** para que nazca la obligación de cerrar. Si no se cumplen, la parte beneficiada **no está obligada** a cerrar (y puede terminar). Las típicas:

- **Autorizaciones regulatorias** (COFECE, sectoriales) y **consentimientos** de terceros (los *change of control* detectados en la due diligence —Libro 2—).
- **Bring-down de las reps:** que las reps **sigan siendo ciertas** a la fecha de cierre (no solo a la firma).
- **Cumplimiento de covenants** hasta el cierre.
- **Ausencia de MAC** (que no haya ocurrido un cambio adverso relevante —sección 14.C—).
- **Entregables del cierre:** los documentos, renunciaciones de consejeros, libros, etc.

Idea integradora: observa cómo el SPA es un **sistema temporal**. Las **reps** miran al **pasado y presente** (cómo es la empresa). Los **covenants** miran al **periodo intermedio** (qué se hace entre firma y cierre). Las **condiciones** son la **puerta del cierre**. Y la **indemnización** (14.C) mira al **futuro** (qué pasa si algo de lo garantizado resulta falso). Cuatro piezas, cuatro momentos: pasado, intermedio, cierre, futuro. Entender esa **línea de tiempo** es entender el SPA.

14.C · ANATOMÍA DEL SPA, PARTE II (INDEMNIZACIÓN, MAC, DISCLOSURE SCHEDULES, SANDBAGGING)

Aquí están las cláusulas donde se libra la **batalla más dura** de la negociación, porque definen **cuánto y cómo paga el vendedor** si algo sale mal. Domínalas: son las que más distinguen al abogado experto.

La indemnización (*indemnification*): el mecanismo de cobro. Si una rep resulta falsa o se materializa un riesgo cubierto, el vendedor debe **resarcir** al comprador por las **pérdidas** ("Losses", término cuya definición se negocia: ¿incluye daño indirecto, lucro cesante, multiplicadores?). Pero esa obligación viene **modulada** por una serie de límites que son, en el fondo, un **reparto económico del riesgo residual**:

- **Cap (tope):** el monto **máximo** que el vendedor pagará. Suele expresarse como un **% del precio** (las reps del negocio a menudo se topan en un porcentaje; las **fundamentales**, hasta el 100% del precio o sin tope). Cuanto más alto el cap, más riesgo retiene el vendedor → es **negociación de precio encubierta**.
- **Basket (cesta) / deducible:** un **umbral mínimo** de pérdidas **acumuladas** que deben superarse antes de poder reclamar. Dos modalidades: ***tipping basket*** (superado el umbral, se cobra **todo** desde el primer peso) y ***true deductible*** (solo se cobra **el exceso** sobre el umbral, como el deducible de un seguro). Evita litigios por minucias.
- **De minimis:** un monto **mínimo por reclamación individual** para que cuente hacia el basket (filtra reclamaciones triviales).
- **Survival (supervivencia):** el **plazo** durante el cual cada rep sigue "viva" y reclamable tras el cierre (típicamente 12-24 meses para las del negocio; **más largo o indefinido** para las fundamentales, fiscales y ambientales, que suelen seguir su propia prescripción legal).
- **Special / specific indemnity (indemnización especial):** para un riesgo **concreto y conocido** de la due diligence (Libro 2), se pacta una indemnización **específica**, normalmen-

te fuera de caps y baskets y al 100% —porque no es un riesgo "desconocido" que la rep general deba cubrir, sino uno **identificado** que el vendedor debe asumir nominalmente—.

- **Recuperación y mitigation:** reglas sobre cómo se calcula la pérdida (descontando seguros, beneficios fiscales) y el deber del comprador de **mitigar** el daño.
- **Garantía del cobro: escrow/holdback** (retención de parte del precio) o, cada vez más, **seguro de W&I** (la aseguradora cubre el incumplimiento de las reps).

El "paquete de indemnización" es, en realidad, una negociación de cuánto riesgo retiene cada parte. Comprador quiere: caps altos, baskets bajos, supervivencia larga, reps sin *knowledge qualifier*, *pro-sandbagging*, escrow grande. Vendedor quiere lo contrario y un "corte limpio". El punto de equilibrio refleja el poder de negociación y el precio.

La cláusula MAC / MAE (*Material Adverse Change/Effect*): la válvula de escape. Permite al comprador **no cerrar** (o renegociar) si, entre la firma y el cierre, ocurre un **cambio sustancialmente adverso** en la *target*. Es de las cláusulas **más negociadas y litigadas**, porque define **quién soporta el riesgo de que el mundo cambie** entre firma y cierre. Claves de su redacción:

- **Definición de "material" y "adverso":** ¿qué tan grave y duradero debe ser el cambio? Los tribunales (Delaware, *Akorn v. Fresenius* —Libro 2—) exigen un umbral **muy alto**: un golpe **sustancial y duradero** al poder de generar ganancias de la empresa, no un mal trimestre.
- **Las carve-outs (exclusiones):** el vendedor pelea por **excluir** de la MAC los riesgos **sistémicos** (crisis económicas, pandemias, guerras, cambios de ley, condiciones de la industria) —porque no son culpa de la empresa—; el comprador acepta excluirlos **salvo** que afecten a la *target* **desproporcionadamente** respecto de su industria. La redacción de estas exclusiones es donde se gana o se pierde la cláusula.

- **Función:** rara vez se invoca con éxito (el umbral es altísimo), pero su valor está en la **amenaza:** da al comprador poder para **renegociar** si las cosas empeoran de verdad antes del cierre.

Los *disclosure schedules* (anexos de revelación): la otra cara de las reps. Son los anexos donde el vendedor **revela las excepciones** a sus reps. Si la rep dice "no hay litigios", el *disclosure schedule* lista los litigios que **sí** existen; con eso, la rep se entiende **cierta salvo por lo revelado**. Función doble:

- **Para el vendedor, son su escudo:** lo que **revela** aquí deja de ser un incumplimiento de la rep (ya lo dijo). Por eso el vendedor tiene incentivo a **revelar mucho** (vacunarse). Conecta directamente con la due diligence: lo que el comprador descubrió y el vendedor reveló, queda "fuera" de la garantía.
- **Para el comprador, son información y delimitación:** le dicen exactamente **qué excepciones** está aceptando. El comprador debe **leerlos con lupa:** una revelación amplia o ambigua puede vaciar una rep. Se negocian reglas sobre si una revelación en una sección "cuenta" para las demás (*general disclosure*).

El *sandbagging* (¿puede reclamar el que ya sabía?). Pregunta fina y muy práctica: si el comprador, **por la due diligence, sabía** que una rep era falsa, y **aun así cierra**, ¿puede luego **reclamar** la indemnización?

- ***Pro-sandbagging* (a favor del comprador):** sí puede reclamar, **aunque supiera**; lo que importa es lo que dice el contrato, no lo que el comprador conocía. El comprador prefiere esta cláusula.
- ***Anti-sandbagging* (a favor del vendedor):** no puede reclamar por algo que **conocía** al cerrar (sería de mala fe cobrar por un riesgo que aceptaste con conocimiento). El vendedor prefiere esta.
- **Se pacta expresamente** en el SPA; si el contrato calla, la respuesta depende del derecho aplicable (en algunos sistemas se presume una, en otros la otra). En México, el silencio

lleva a discutir buena fe y dolo —por eso conviene **pactarlo claramente**—. Este es el punto exacto donde la **due diligence (Libro 2) y el contrato se cruzan**: lo que descubriste investigando puede ayudarte o perjudicarte según esta cláusula.

Cómo encaja todo (del hallazgo de la DD a la cláusula). Cierra el círculo de los Libros 2 y 3: un **riesgo desconocido** se cubre con **reps generales + indemnización (con caps/baskets)**; un **riesgo concreto y conocido**, con **indemnización especial** (sin tope, fuera de cesta); un **riesgo subsanable antes de cerrar**, con **condición al cierre**; el **riesgo de que el mundo cambie** entre firma y cierre, con la **MAC**; y lo que el vendedor **revela**, sale de la garantía vía **disclosure schedules**. El SPA es, literalmente, la **due diligence convertida en cláusulas**.

14.D · MECANISMOS DE PRECIO Y EL APA (CÓMO SE FIJA EL PRECIO Y EL CONTRATO DEL ASSET DEAL)

Los mecanismos de precio (cómo se determina y ajusta lo que se paga). El "precio" de una empresa rara vez es un número fijo y simple, porque la empresa **cambia** entre el momento en que se acuerda el precio y el cierre (gana o pierde caja, sube o baja su deuda, varía su capital de trabajo). El SPA debe definir **cómo se fija y ajusta** el precio. Las dos grandes filosofías:

- **Completion accounts (cuentas al cierre):** se acuerda un **precio base** (sobre un *enterprise value*) y se **ajusta** tras el cierre según el balance **real al día del cierre**, típicamente por tres variables: **deuda neta** (más deuda → menos precio), **caja** (más caja → más precio) y **capital de trabajo** (respecto de un nivel "normal" objetivo). Ventaja: el precio refleja la empresa **exactamente al cierre**. Desventaja: exige un **balance de cierre auditado** y suele generar **disputas** sobre las cifras (que se resuelven con un experto independiente).
- **Locked box (caja cerrada):** se fija un **precio fijo** sobre un balance de referencia **pasado** (el "*box*") y **no hay ajuste posterior**; desde la fecha del *box*, los riesgos y beneficios económicos pasan al **comprador** (con protección contra "fugas de valor" —*leakage*—, como dividendos o pagos a los

vendedores entre el *box* y el cierre). Ventaja: **certeza** y simplicidad, sin disputas post-cierre. Desventaja: exige confianza en un balance pasado y una due diligence financiera sólida. Muy popular en Europa y en deals de *private equity*.

A esto se suman dos mecanismos que **difieren o condicionan** parte del precio:

- **Earn-out:** una porción del precio se paga **en el futuro** solo si la *target* **alcanza ciertos resultados** (ventas, EBITDA, hitos). Sirve para **cerrar la brecha de valuación** (el vendedor cree que vale más; el comprador, menos: " demuéstremelo y te pago más"). Es **fuentes frecuente de litigios** (cómo se mide el resultado, qué pasa si el comprador gestiona la empresa de forma que reduzca el *earn-out*), por lo que su redacción debe ser **quirúrgica**.
- **Escrow / holdback:** retención de parte del precio en garantía de indemnizaciones (visto en 14.C); también puede retenerse para garantizar el **ajuste** de *completion accounts*.

El APA (*Asset Purchase Agreement*): el contrato del asset deal. Cuando la estructura elegida (Libro 3) es la compra de **activos** y no de acciones, el documento es el **APA**. Comparte mucho con el SPA (tiene reps, covenants, condiciones, indemnización, MAC), pero su **diferencia esencial** está en cómo describe lo que se transmite:

- **El perímetro: activos incluidos y excluidos.** El corazón del APA es la **descripción precisa** de los ***purchased assets*** (qué se compra: inmuebles, maquinaria, inventario, contratos, PI, cuentas por cobrar, permisos) y de los ***excluded assets*** (qué se queda el vendedor). Cualquier ambigüedad genera conflicto: en un APA, **lo que no está claramente incluido, se queda fuera**.
- **Pasivos asumidos y excluidos (*assumed / excluded liabilities*).** El APA define **qué pasivos** asume el comprador (a veces ninguno; a veces los del negocio en marcha) y cuáles **no** (los "del pasado", que quedan con el vendedor). Aquí está la **gran ventaja** del asset deal (aislar pasivos —Libro 3—) y su límite: recuerda que ciertos pasivos (**laborales, fiscales,**

ambientales) pueden **seguir al negocio** por mandato legal, pese a lo pactado.

- **Las cesiones y consentimientos (la complejidad del asset deal).** Como no se transmite una sociedad sino activos uno por uno (**sucesión particular** —Libro 3—), el APA debe articular la **cesión** de cada contrato (con el **consentimiento** de la contraparte cuando se requiera), la transmisión de inmuebles (ante notario, con inscripción), la cesión de créditos (con notificación al deudor) y la transferencia de PI (ante el IMPI). Esto vuelve el cierre del asset deal **más complejo y condicionado** que el de un share deal: muchos consentimientos se convierten en **condiciones al cierre**.
- **Cuestiones laborales (sustitución patronal).** El APA debe resolver la suerte de los **trabajadores** (¿se transfieren por sustitución patronal?, ¿se recontratan?, ¿quién asume los pasivos laborales acumulados?), un punto sensible y muchas veces decisivo.

SPA vs. APA (cuadro mental):

	SPA (ACCIONES)	APA (ACTIVOS)
Qué se transmite	Acciones (la sociedad entera)	Activos y pasivos descritos
Pasivos	Todos (de la sociedad)	Solo los asumidos (+ excepciones legales)
Transmisión	Una operación	Cesión individual + consentimientos
Reps clave	Título de acciones, todo el negocio	Título de cada activo , perímetro
Cierre	Más simple	Más complejo (consentimientos como CP)
Estructura del Libro 3	Share deal	Asset deal

La conexión que cierra el sistema: el documento **sigue a la estructura**, y la estructura **sigue a la due diligence**. Si la DD reveló pasivos ocultos graves → estructura *asset deal* (Libro 3) → documento **APA** con perímetro y pasivos cuidadosamente delimitados. Si la prioridad era continuidad → *share deal* → **SPA** con reps fuertes y consentimientos por *change of control*

como condiciones. **Investigar → estructurar → documentar**: la cadena completa del M&A, ahora visible de principio a fin.

14.E · EL SHA (CONVENIO ENTRE ACCIONISTAS): GOBIERNO, CAPITAL Y SALIDAS

El SPA/APA consume la **compra**; el SHA (*Shareholders Agreement* / convenio entre accionistas) gobierna la **convivencia posterior** entre los socios. Es el contrato clave cuando, tras la operación, **varios socios** quedan juntos: fundadores e inversionistas (VC/PE), familia y fondo, socio estratégico y control. Para un fondo, el SHA es **tan importante como el precio**, porque define su **poder**, su **protección económica** y su **salida**. Es también el instrumento del **gobierno corporativo contractual** —tu área de interés—. Sus cláusulas se agrupan en tres familias:

1) Gobierno (¿quién decide?).

- **Composición del consejo**: cuántos asientos tiene cada socio (el inversionista suele negociar uno o más, y a veces un **observador**). Define el equilibrio de poder en la administración.
- **Reserved matters / vetos (materias reservadas)**: la lista de **decisiones importantes** que requieren el **consentimiento** del inversionista/minoría, aunque no controle el consejo: endeudarse por encima de X, emitir acciones, vender activos clave, cambiar el giro, aprobar el presupuesto, contratar/remover al CEO, hacer otra adquisición, repartir dividendos. Es la **principal protección de poder** del minoritario: no gobierna el día a día, pero **bloquea** lo que le importa.
- **Información**: derecho a recibir estados financieros, reportes e información de gestión (*information rights*).
- **Resolución de bloqueos (deadlock)**: *qué pasa cuando los socios no se ponen de acuerdo en una decisión clave y se paraliza la empresa. Mecanismos: escalamiento a los directivos/accionistas principales, mediación, y —si no hay solución— mecanismos de compra-venta forzosa**: buy-sell / "ruleta rusa" (un socio pone un precio; el otro elige

si compra o vende a ese precio), **Texas shoot-out** (ofertas selladas al alza), o la **disolución***. Son cláusulas delicadas: mal diseñadas, favorecen a quien tiene más dinero para comprar.

2) Capital y economía (¿quién pone y quién cobra cuánto?).

- **Preferencia de liquidación (*liquidation preference*):** *derecho del inversionista a cobrar primero en una venta o liquidación, normalmente un múltiplo* de su inversión (1x, a veces más), antes de que los fundadores reciban nada. Puede ser non-participating (cobra su preferencia *o convierte a ordinario, lo que más le convenga) o participating (cobra su preferencia y además participa como ordinario —más agresiva—). Es la protección económica central del VC/PE.*
- **Antidilución:** protege al inversionista si la empresa emite acciones nuevas a un **precio menor** que el que él pagó (*down round*). Modalidades: **full ratchet** (muy agresiva: ajusta su precio al nuevo, más bajo) y **weighted average** (promedio ponderado, la estándar y más equilibrada).
- **Derechos de preferencia (*preemptive rights / pro rata*):** derecho a **suscribir** acciones en emisiones futuras para **mantener su porcentaje** (no diluirse).
- **Compromisos de aportación / *pay-to-play*:** reglas sobre futuras rondas y consecuencias de no participar.

3) Transmisión y salida (¿cómo entro y, sobre todo, cómo salgo?). Esta es la familia **más característica** del SHA, porque diseña las **salidas** —lo que más importa a un inversionista—:

- **Lock-up:** prohibición temporal de **vender** acciones (típico para fundadores: que no se vayan pronto).
- **ROFR / ROFO (derecho del tanto / de primera oferta):** antes de vender a un tercero, el socio debe **ofrecer** primero a los demás (ROFR: igualar la oferta de un tercero; ROFO: ofrecer antes de buscar tercero). Evita la entrada de extraños no deseados.

- **Tag along (derecho de acompañamiento):** si el socio mayoritario vende, el **minoritario puede sumarse** y vender su parte **en las mismas condiciones**. Es **protección del minoritario**: que no lo dejen "atrapado" con un nuevo socio de control que no eligió.
- **Drag along (derecho de arrastre):** si una mayoría (o el inversionista) decide vender el 100%, puede **obligar** a los demás socios a **vender también** en las mismas condiciones. Es **clave para el inversionista/PE**: garantiza que podrá vender la empresa **entera** (que es lo que un comprador quiere) sin que un minoritario lo bloquee. La tensión **drag (mayoría) vs. tag (minoría)** es el corazón de la negociación de salidas.
- **Put / Call options:** **put** (el socio puede **obligar** a que le **compre**n su parte, p. ej., el inversionista si no hay salida en X años) y **call** (puede **obligar** a que le **vendan**, p. ej., la empresa recompra al fundador que se va). Definen salidas "forzadas" bajo ciertos disparadores.
- **Cláusulas de salida del inversionista:** compromisos de buscar un **exit** (venta o IPO) en cierto horizonte, derechos de **registro** (para vender en bolsa), y *redemption* (rescate).
- **Bad leaver / good leaver:** para fundadores/ejecutivos accionistas: el que se va "mal" (incumpliendo, por causa) pierde o vende barato sus acciones no consolidadas; el que se va "bien" conserva más. Alinea el incentivo de permanencia.

Cómo se relaciona el SHA con los estatutos. El SHA es un **contrato entre los socios** (eficacia **inter partes**); los **estatutos** son la "constitución" de la sociedad (eficacia **frente a todos**). Lo ideal es que las cláusulas del SHA que se pueda **se reflejen en los estatutos** (para oponerlas a terceros y a la sociedad), pero algunas, por su naturaleza, viven solo en el SHA. En México, la **S.A.P.I.** (regulada por la LMV) fue diseñada precisamente para **dar validez societaria** a muchas de estas cláusulas (restricciones a la transmisión, vetos, drag/tag, opciones), por lo que es el **vehículo preferido** para operaciones con inversionistas (VC/PE) —conexión directa con el Libro 7 (PE y VC) y con Gobierno Corporativo—.

Idea integradora del SHA. Mientras el SPA mira al **momento de la compra** (asignar el riesgo del pasado), el SHA mira a la **vida futura** de la sociedad: cómo se **decide** (gobierno), cómo se **reparte el dinero** (capital) y cómo se **entra y sale** (transmisión). Diseñar un buen SHA es **anticipar el conflicto** entre socios y resolverlo por escrito **antes** de que ocurra —el verdadero "acuerdo prenupcial" empresarial—. Para el abogado que quiere especializarse en **gobierno corporativo y operaciones complejas**, dominar el SHA es dominar el **instrumento donde se diseña el poder corporativo**.

15. Explicación intuitiva

Tres imágenes para fijar la documentación del M&A.

La metáfora del seguro de auto. Las **reps & warranties** son como las **declaraciones** que haces al contratar un seguro ("el coche no ha chocado, lo maneja solo mi hijo de 30, no es de uso comercial"). Si **mientes** en una declaración y luego chocas, la aseguradora **no paga** (incumpliste una rep → hay consecuencia). La **indemnización** es el mecanismo de pago, y el **deducible** del seguro es exactamente el **basket** (no reclamas por debajo de cierto monto), mientras que la **suma asegurada máxima** es el **cap**. La **MAC** es como una cláusula que dice "si el coche se destruye totalmente **antes** de que empiece la póliza, no hay contrato". Toda la lógica del SPA es **lógica de seguro**: declaras, te cubren dentro de límites, y hay supuestos de escape.

La metáfora del acuerdo prenupcial (para el SHA). El SHA es el **acuerdo prenupcial** de los socios: se firma cuando todos están felices y optimistas, precisamente para decidir **en frío** lo que harán cuando vengan los problemas. ¿Quién decide las cosas importantes (vetos)? ¿Quién cobra primero si nos separamos (preferencia de liquidación)? ¿Puedo obligarte a vender conmigo (drag)? ¿Puedo subirme a tu venta (tag)? ¿Cómo nos divorciamos si no nos ponemos de acuerdo (deadlock)? Nadie firma un prenupcial pensando en el divorcio, pero **el que no lo firma se arruina cuando llega**.

La metáfora de la línea de tiempo (para el SPA). Imagina el SPA como una **película con cuatro actos**:

- **Acto 1 (pasado/presente):** "Te juro que la empresa es así" → **reps.**
- **Acto 2 (entre firma y cierre):** "Y me porto bien hasta que cerremos" → **covenants.**
- **Acto 3 (la puerta del cierre):** "Cerramos solo si se cumplen estas condiciones" → **conditions.**
- **Acto 4 (futuro):** "Y si mentiste, me pagas (dentro de estos límites)" → **indemnización.** Si entiendes esa secuencia —pasado, intermedio, cierre, futuro—, **nunca te perderás** en un SPA, por largo que sea.

La intuición central: la documentación del M&A **no describe una compraventa; construye un sistema de asignación de riesgo a lo largo del tiempo.** Cada cláusula responde a una pregunta —¿qué me aseguras?, ¿qué pasa entre firma y cierre?, ¿qué condiciones?, ¿qué pasa si sale mal?, ¿cómo decidimos y salimos?— y la respuesta **reparte un riesgo** entre las partes. Leer un contrato es, en el fondo, **mapear quién soporta cada riesgo.** Esa es la habilidad.

16. Ejemplos simples

Ejemplo 1 — La rep que se activa. El SPA dice: "no existen litigios laborales salvo los del *disclosure schedule* 3.12". Tras el cierre, aparece un juicio laboral **no listado**, de 2 millones. La rep era **falsa** → se activa la **indemnización**. Pero si las pérdidas del comprador (2M) no superan el **basket** de 3M, **no puede reclamar** todavía; si con otras reclamaciones se supera, cobra (según sea *tipping* o *deducible*).

Ejemplo 2 — La condición que salva al comprador. El SPA pone como **condición al cierre** obtener la autorización de la COFECE. La COFECE **no autoriza**. El comprador **no está obligado a cerrar** y puede **terminar** sin penalización: la condición no se cumplió.

Ejemplo 3 — El tag along en acción. Un fondo (mayoritario) vende su 60% a un tercero. El fundador (minoritario, 40%) ejerce su **tag along** y **se suma** a la venta en las mismas condi-

ciones: vende su 40% al mismo precio por acción, en vez de quedarse atrapado con un nuevo socio de control desconocido.

Ejemplo 4 — El earn-out que cierra la brecha. El vendedor pide 100; el comprador ofrece 80 porque duda de las proyecciones. Acuerdan **80 fijos + 20 de *earn-out*** pagaderos si la empresa alcanza cierto EBITDA en dos años. Si lo logra, el vendedor cobra los 20; si no, no. Cada quien arriesga su parte de la discrepancia.

17. Ejemplos complejos

Ejemplo complejo 1 — La guerra de la cláusula MAC. Se firma un SPA en enero; el cierre es en junio (pendiente la COFECE). En marzo, una crisis golpea a la *target*: sus ventas caen 40%. El comprador quiere **salir** invocando la **MAC**. ¿Puede? Depende de la **redacción**: si la crisis es **sistémica** (afecta a toda la industria) y la MAC **excluye** los eventos sistémicos, el comprador **no** puede salir (asumió ese riesgo) —**salvo** que la *target* esté afectada **desproporcionadamente** frente a sus competidores—. Aquí se ve por qué cada palabra de las *carve-outs* de la MAC vale millones: la misma caída puede ser o no ser una MAC según cómo se redactó la exclusión. (Eco de *Akorn v. Fresenius*, Libro 2.)

Ejemplo complejo 2 — Sandbagging y disclosure. Durante la due diligence, el comprador **descubre** un problema de cumplimiento ambiental, pero el vendedor **no** lo incluye en el *disclosure schedule* y la rep dice "cumplimos con la normativa ambiental". Tras el cierre, el comprador **reclama** por incumplimiento de la rep. El vendedor responde: "¡pero tú **lo sabías** por la due diligence!". ¿Quién gana? **Depende de la cláusula de sandbagging**: si es *pro-sandbagging*, el comprador **cobra** (lo que importa es la rep escrita); si es *anti-sandbagging*, **no** (sabía y aun así cerró). Lección: el comprador que detecta algo en la DD debe **insistir en que se revele y se cubra con indemnización especial**, o asegurarse de tener cláusula *pro-sandbagging*—no confiar en reclamar después—.

Ejemplo complejo 3 — El deadlock que paraliza una JV. Dos socios al 50/50 en una *joint venture* no se ponen de acuer-

do sobre una inversión clave; el consejo se **empata** y la empresa se **paraliza**. El SHA preveía una **cláusula de ruleta rusa**: el socio A ofrece comprar la parte de B (o venderle la suya) a un precio; B elige si **compra o vende** a ese precio. A, que tiene más caja, pone un precio bajo sabiendo que B no podrá comprar y tendrá que vender barato. *Lección*: las cláusulas de **deadlock mal diseñadas favorecen a quien tiene más dinero**; un buen abogado las calibra (p. ej., con valuación independiente) para que sean justas. El diseño del SHA **anticipa y resuelve** estos conflictos —o los agrava—.

18. Casos reales (operaciones estilizadas y referentes)

Nota de método (Manifiesto XI.5): casos estilizados con fines didácticos; verifica los detalles antes de citarlos profesionalmente.

Las batallas por la cláusula MAC (Tyson Foods, Genesco, Akorn). Una serie de casos en Delaware definió el **altísimo umbral** para invocar una MAC y abandonar un deal. Durante años, **ningún** comprador logró salir por MAC (los tribunales exigían un golpe sustancial y **duradero**), hasta *Akorn v. Fresenius* (2018), el **primer** caso en que una corte validó la salida —por fraude regulatorio grave de la *target*—. *Lección*: la MAC es más **amenaza negociadora** que botón de escape fácil; su valor está en el poder de **renegociar**, no en una salida sencilla.

La pandemia y las cláusulas MAC (2020). La crisis sanitaria global disparó disputas sobre si era una MAC que permitía abandonar deals firmados antes. La respuesta dependió, caso por caso, de las **carve-outs** (¿excluía la MAC las "pandemias" o los "eventos sistémicos"?) y del impacto **desproporcionado** en la *target*. *Lección*: la redacción de las exclusiones de la MAC —que parecía *boilerplate*— resultó valer cientos de millones. Nada en un SPA es "relleno".

Los *earn-outs* litigados. Innumerables disputas post-cierre nacen de *earn-outs*: el vendedor acusa al comprador de gestionar la empresa para **no** alcanzar la meta (y no pagar); el comprador dice que la meta simplemente no se cumplió. *Leción*: el *earn-out* cierra la brecha de valuación pero **abre** la

puerta al litigio; debe redactarse con métricas objetivas, *covenants* de gestión y mecanismos de resolución claros.

Twitter/X – Musk (2022, ~44,000 mdd  verificar): el caso que demuestra que estas cláusulas no son relleno. Después de firmar, el comprador intentó desistirse invocando información sobre cuentas automatizadas. No pudo. El acuerdo contenía una MAC estrecha* —que no cubría lo que se alegaba— y una cláusula de specific performance (cumplimiento forzoso). Con esa combinación, el tribunal de Delaware estaba en posición de *obligarlo a cerrar, y cerró.

La lección, y hay que subrayarla porque es contraintuitiva. Casi todo el mundo cree que un comprador con suficiente dinero para pagar daños puede arrepentirse de una operación. Es la vieja idea de Holmes sobre el *common law*: el contrato te da la opción de cumplir o de pagar por no cumplir (la *efficient breach*). La cláusula de *specific performance* existe precisamente para **eliminar esa opción** —invierte la lógica de Holmes: aquí no se quiere permitir el pago de daños, se quiere forzar el cierre—.

Es decir: **la MAC y los remedios deciden si tu cliente puede arrepentirse.** Redactarlos con desgana es regalar o destruir una opción que vale el precio entero de la operación. Y por eso la MAC se negocia palabra por palabra, no por analogía con un precedente.

Y la contraparte doctrinal del caso: *Akorn v. Fresenius* (Del. Ch. 2018) fijó, del otro lado, **cuándo sí** se puede abandonar por MAC. El estándar de Delaware es exigente y su criterio útil es el de la **durabilidad**: un deterioro que importa es el que afecta al negocio de forma duradera, no una mala coyuntura ni un trimestre malo. Entre los dos casos queda dibujada la frontera práctica: la MAC no es una puerta de salida cómoda, y quien la redacte pensando que lo es, se equivoca en las dos direcciones.

19. Casos empresariales

El fondo de PE que negocia el SHA tanto como el precio. Un fondo invierte en una empresa familiar tomando el 40%. En el SPA negocia precio y reps; pero invierte **igual energía** en el SHA: asegura **dos asientos** en el consejo, una lista amplia de

vetos (endeudamiento, adquisiciones, cambio de CEO), una **preferencia de liquidación 1x**, **antidilución** *weighted average*, y —lo más importante— un **drag along** que le permitirá **vender la empresa entera** en 5-7 años (su *exit*). *Lección:* para el inversionista profesional, **cómo gobierna y cómo sale** vale tanto como **cuánto paga**. El abogado que solo negocia el precio le falla a su cliente.

La empresa familiar que se blinda con un SHA (protocolo familiar). Tres hermanos heredan la empresa. Para evitar que el conflicto la destruya, firman un **SHA/protocolo familiar**: reglas de **gobierno** (consejo con un independiente, mayorías para decisiones clave), de **transmisión** (ROFR para que las acciones no salgan de la familia; reglas para herederos), y de **resolución de conflictos** (mediación antes que litigio; mecanismo de salida para el hermano que quiera irse). *Lección:* el SHA es la herramienta para que la empresa familiar **sobreviva a la siguiente generación** —conecta con tu interés en gobierno corporativo y empresa familiar—.

20. Casos corporativos (la conexión integral)

Integremos todo el programa y todo el Nivel IV. *Fondo Andes* invierte en *TechMX, S.A.P.I.*, una empresa tecnológica con tres fundadores, comprando una participación y suscribiendo acciones nuevas.

- **Nivel I-II (Contratos, Obligaciones):** el SPA y el SHA son **contratos** regidos por la teoría general (consentimiento, objeto, condiciones, obligaciones de hacer/no hacer).
- **Nivel III (Sociedades, Gobierno Corporativo, LMV):** la **S.A.P.I.** da validez societaria a las cláusulas del SHA (vetos, drag/tag, preferencias); el gobierno corporativo del consejo se diseña en el SHA.
- **Libro 1 (Fundamentos M&A):** la operación se mapea (signing/closing, asignación de riesgo).
- **Libro 2 (Due Diligence):** la DD de TechMX revela que la **PI clave** está a nombre de un fundador y hay un litigio menor → se traduce en cláusulas.

- **Libro 3 (Estructuras):** se decide la estructura (inversión primaria —suscripción— + secundaria —compra de acciones de un fundador saliente—).
- **Libro 4 (este):** se documenta todo: **Term Sheet** (con la valuación y los términos clave del SHA), **SPA/Subscription Agreement** (con rep específica e **indemnización especial** por la PI del fundador, y **condición al cierre** de transferir esa PI a la sociedad), y **SHA** (vetos, preferencia de liquidación, antidilución, drag/tag, vesting de los fundadores con *good/bad leaver*).

Moraleja: la documentación es el **punto de convergencia final** de toda la operación y de toda tu formación. El abogado que la domina **traduce** la investigación (DD), la arquitectura (estructura) y la estrategia del cliente en **texto exigible**. No hay habilidad más definitoria del abogado de M&A.

21. Casos internacionales

El SPA como lengua franca global. Un SPA negociado en México para una operación transfronteriza se parece muchísimo a uno de Nueva York o Londres: misma estructura (reps, covenants, conditions, indemnification, MAC), mismo vocabulario (en inglés). *Lección para tu carrera:* el **inglés jurídico de transacciones** no es opcional en el M&A de élite; el contrato "habla inglés" aunque la ley aplicable sea mexicana. Dominar la **terminología y la lógica** de estas cláusulas en inglés es parte del oficio.

Las diferencias civil law / common law en la interpretación. Aunque la **forma** del SPA es global, su **interpretación y ejecución** dependen de la **ley aplicable**. En el common law prima el **texto literal** del contrato (lo escrito es lo que vale; de ahí contratos larguísimos que lo definen todo). En el civil law (México) pesan más la **buena fe**, la **intención de las partes** y las normas **imperativas** y supletorias del Código —lo que puede **modular** cláusulas importadas (p. ej., la eficacia del *sandbagging* o de ciertas renunciaciones)—. *Lección:* el abogado mexicano de élite redacta cláusulas anglosajonas **ancladas** en figuras lo-

cales (penas convencionales, condiciones, renunciaciones válidas) para que sean **exigibles** aquí.

El seguro de Reps & Warranties (W&I insurance). Práctica internacional ya común en México: una **aseguradora** cubre el riesgo de que las reps sean falsas, permitiendo al vendedor un "corte limpio" (sin escrow ni responsabilidad prolongada) y agilizando el deal. Reconfigura la negociación de la indemnización (el comprador reclama a la **aseguradora**, no al vendedor). *Lección:* las aseguradoras **exigen** una due diligence sólida para emitir la póliza —otra vez, la DD (Libro 2) es la base de todo—.

22. Derecho comparado

Los contratos del M&A son globales en su **forma**, pero su **interpretación y exigibilidad** varían según la tradición jurídica. Tabla comparada esencial para el abogado de M&A:

JURISDICCIÓN / SISTEMA	TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL M&A
México (Civil Law)	SPA/APA/SHA por autonomía de la voluntad sobre la base de la compraventa y el saneamiento (CCF/CCom). La S.A.P.I. (LMV) da validez societaria al SHA (vetos, drag/tag, opciones). Interpretación por buena fe e intención; normas imperativas modulan cláusulas importadas (sandbagging, ciertas renunciaciones).
EE.UU. (Common Law)	Cuna del SPA moderno. Predomina la literalidad del texto y la autonomía contractual : el contrato lo define todo (de ahí su extensión). Régimen estatal; <i>case law</i> abundante sobre reps, indemnización y MAC.
Delaware	El estándar de referencia mundial. <i>Case law</i> decisivo sobre MAC (Akorn, Tyson), interpretación de reps e <i>indemnification</i> , y <i>sandbagging</i> (Delaware tiende a ser pro-sandbagging salvo pacto). La "lengua franca" del M&A.
Reino Unido (Common Law)	<i>Caveat emptor</i> fuerte; el comprador se protege con warranties y el vendedor con la disclosure (<i>disclosure letter</i>). Tiende a ser anti-sandbagging (no se reclama por lo conocido). Cláusulas algo más "ligeras" que las de EE.UU.
España (Civil Law)	<i>Manifestaciones y garantías</i> (las reps) sobre la base de la compraventa y el saneamiento por vicios ocultos del Código Civil; fuerte influencia anglosajona vía despachos internacionales.
Unión Europea	Sin contrato único, pero con impacto del derecho de competencia (cláusulas de no competencia razonables; gun jumping) y de protección de datos en la documentación.
UNIDROIT (Principios)	Marco supletorio para contratos internacionales: buena fe , deberes de información, responsabilidad precontractual (relevante para el Term Sheet/LOI) e interpretación.
CISG	Aunque regula mercaderías (no acciones), su lógica de conformidad y de deberes de examen/notificación ilumina la racionalidad de reps y saneamiento.
Civil Law vs. Common Law (síntesis)	Common law : literalidad, autonomía, contratos exhaustivos, tendencia pro-sandbagging (EE.UU.). Civil law : buena fe, intención, normas imperativas, saneamiento legal como red de seguridad. En M&A transfronterizo conviven : forma anglosajona, ejecución local.

Lección comparada clave: el abogado mexicano de élite redacta cláusulas **anglosajonas** (porque son el estándar global) pero las **ancla en el derecho mexicano** (penas convencionales, condiciones, renunciaciones válidas, definición de pérdidas compatible con el CCF) para que sean **exigibles aquí**.

Importar una cláusula sin adaptarla es un error de novato que puede volverla **inejecutable**.

LOS TRES RE-ANCLAJES QUE HAY QUE HACER SIEMPRE

El SPA es una construcción anglosajona trasplantada, y el trabajo del abogado mexicano **no es traducirlo: es re-anclarlo**. Tres puntos concretos donde eso se decide:

1 · No importes figuras vacías. La *consideration* —el requisito de contraprestación del *common law*— no se exige en el derecho mexicano. Una cláusula que la invoque no añade validez: añade ruido. Aquí rige el **artículo 1832 del CCF** ☺ ✓ (*cotejado verbatim en fuentes-legales/*): *"en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley."* Esa amplitud es una **ventaja**: da espacio a la ingeniería contractual sin formalismos innecesarios.

2 · Engánchalo a la compraventa del Código. El SPA es, en su naturaleza, una compraventa: el **artículo 2248 del CCF** ☺ ✓ define que *"habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero."* De ahí se sigue algo que el *common law* no tiene: el régimen legal de **saneamiento** opera como **piso** debajo de tus *reps*. Es una red de seguridad adicional, y conviene no renunciar a ella por descuido al redactar las limitaciones de responsabilidad.

3 · Cuida cómo se transmiten realmente las acciones. El **artículo 129 de la LGSM** ☺ ✓ dispone que *"la sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el registro"* y que deberá inscribir las transmisiones a petición de cualquier titular. Traducción operativa: **el SPA no transmite por sí solo la titularidad frente a la sociedad**. Sin endoso y sin inscripción en el libro de registro de acciones, tu cliente pagó y no es accionista para efectos societarios. Es uno de los errores de cierre más caros y más evitables, y por eso está en el Closing Checklist.

La regla, en una línea: conserva la **lógica** anglosajona de asignación de riesgo y sustituye sus **soportes** por los del derecho mexicano. Quien copia, produce cláusulas inejecutables; quien re-ancha, produce un SPA que gana en Nueva York y se ejecuta en México.

23. Derecho mexicano

La documentación del M&A se asienta en estos pilares del derecho mexicano:

- **Autonomía de la voluntad y *pacta sunt servanda* (CCF, CCom).** La base que permite diseñar libremente reps, indemnización, MAC, vetos, drag/tag —dentro de los límites de la ley, el orden público y las buenas costumbres—.
- **Compraventa y saneamiento (CCF / CCom).** El SPA y el APA son compraventas; el **saneamiento por vicios ocultos y por evicción** es la red de seguridad legal que las reps e indemnización **complementan y modulan**. Un comprador puede tener acción por saneamiento **además** de la contractual.
- **Vicios del consentimiento (CCF).** **Dolo y mala fe** del vendedor (mentir u ocultar) pueden generar **nulidad** y responsabilidad **más allá** de los límites contractuales (caps, baskets) —un argumento poderoso del comprador engañado—.
- **Transmisión de acciones (LGSM / LMV).** Endoso e inscripción en el libro de registro; régimen especial de la S.A.B.; la **S.A.P.I.** como vehículo que valida las cláusulas del SHA.
- **Cesión de derechos y asunción de deudas (CCF).** Base del APA (cesión de contratos y créditos; consentimiento del acreedor para asumir deudas).
- **Penas convencionales y condiciones (CCF).** Figuras locales en las que se **anchan** cláusulas como el *break-up fee*, ciertos *earn-outs* y mecanismos de indemnización para que sean exigibles.
- **Cláusulas de no competencia:** válidas si son **razonables** en tiempo, territorio y objeto (límite del derecho de competencia y de la libertad de trabajo/comercio).

- **Arbitraje (CCom / convenciones internacionales).** El M&A mexicano usa intensamente el **arbitraje** (confidencial, especializado, ejecutable internacionalmente) como foro de resolución de disputas; la cláusula arbitral es *boilerplate* crítico.

Nota de método: verifica la compatibilidad y la redacción exigible de cada cláusula importada con el derecho mexicano vigente antes de usarla (Manifiesto XI.5). La forma anglosajona **no** garantiza eficacia local.

24. Jurisprudencia relevante

Nota de método: verifica vigencia y datos de identificación antes de citar.

En México, los criterios relevantes giran en torno a las **figuras que sostienen** la documentación:

- **Saneamiento por vicios ocultos y por evicción:** alcance de la responsabilidad del vendedor por defectos no aparentes; relación con las garantías contractuales (reps).
- **Dolo, mala fe y vicios del consentimiento:** cuándo la ocultación de información vicia el contrato y permite reclamar más allá de lo pactado.
- **Interpretación de los contratos (intención de las partes, buena fe — CCF):** clave para interpretar reps, indemnización, MAC y disclosure schedules.
- **Penas convencionales:** su validez y la facultad de los jueces de moderarlas (relevante para break-up fees y mecanismos indemnizatorios).
- **Validez de convenios entre accionistas (S.A.P.I. / LMV):** reconocimiento de la eficacia de vetos, restricciones a la transmisión y drag/tag.
- **Arbitraje:** criterios sobre validez de la cláusula arbitral, arbitrabilidad y reconocimiento/ ejecución de laudos.

En el ámbito **anglosajón** (de gran influencia práctica), el *case law* de **Delaware** sobre **MAC** (Akorn, Tyson, Genesco), **sandbagging** e interpretación de reps/indemnización es **estu-**

dio obligado, porque modela cómo se redactan e interpretan estas cláusulas en todo el mundo.

25. Criterios de la Suprema Corte / reguladores

- **SCJN / tribunales:** criterios sobre **interpretación contractual, buena fe, dolo, saneamiento y penas convencionales**, que delimitan la eficacia y los límites de las cláusulas del SPA/APA/SHA en México.
- **COFEC:** criterios sobre **cláusulas de no competencia** (razonabilidad) y sobre el respeto al calendario regulatorio (gun jumping) que condicionan covenants y condiciones del SPA.
- **CNBV (emisoras):** régimen de revelación y de OPAs que afecta la documentación cuando la *target* es pública.
- **Tribunales arbitrales (CANACO, ICC):** aunque sus laudos son confidenciales, la práctica arbitral mexicana e internacional ha desarrollado criterios sobre interpretación de SPAs (reps, earn-outs, MAC) que nutren la redacción contractual.

26. Doctrina nacional

La doctrina mexicana sobre la documentación del M&A proviene de **dos vertientes**: la **civil/mercantil** clásica (compraventa, saneamiento, vicios del consentimiento, interpretación de contratos, obligaciones), que da el marco de fondo; y el **know-how transaccional** de los grandes despachos corporativos, que ha adaptado las cláusulas anglosajonas (reps, indemnización, MAC, drag/tag) al derecho mexicano y vive más en los *precedents*, los seminarios especializados y la formación interna que en tratados académicos. La **S.A.P.I.** y la doctrina de la LMV aportaron el sustento societario del SHA.

27. Doctrina internacional

- **American Bar Association — Model Stock Purchase Agreement with Commentary y Model Asset Purchase Agreement.** **Lectura imprescindible:** el SPA y el APA cláusula por cláusula, con comentario sobre por qué existe y

cómo se negocia cada una. El mejor material del mundo para dominar la documentación.

- **Doctrina de Delaware y tratados de M&A (EE.UU.).** Interpretación de reps, indemnización, MAC y sandbagging; el *case law* que modela la práctica.
- **Practical Law / PLC y precedents de los grandes despachos.** Los estándares de mercado de cada cláusula (qué cap, qué basket, qué supervivencia son "de mercado").
- **Doctrina de deal-making y negociación (Harvard — Subramanian, Dealmaking).** El contrato como resultado de una negociación estratégica.
- **Materiales sobre W&I insurance.** La práctica del seguro de reps & warranties y su efecto en la negociación de la indemnización.
- **UNIDROIT — Principios de los Contratos Comerciales Internacionales.** Buena fe, responsabilidad precontractual e interpretación en operaciones transfronterizas.

28. Opiniones críticas (postura del Consejo Editorial)

Primero: entender la lógica, no memorizar el formulario. Sostenemos que el peor error en la formación del abogado de M&A es aprender los contratos como **plantillas**. Una cláusula copiada sin entender **por qué existe, a quién protege y qué pasa si falla** es una bomba de tiempo. Este libro enseña la **gramática del riesgo**, no un formulario.

Segundo: la negociación de la indemnización ES negociación de precio. Criticamos que se traten los *caps*, *baskets* y la MAC como "cláusulas técnicas" separadas del precio. Son **reparto económico del riesgo**: cada concesión en indemnización tiene un valor monetario. El abogado que las negocia sin hablar con el cliente sobre el **precio** y el **riesgo** que está dispuesto a asumir, negocia a ciegas.

Tercero: nada en un SPA es boilerplate. La pandemia y los casos de MAC demostraron que las cláusulas "de relleno" (exclusiones de la MAC, ley aplicable, definiciones) pueden valer

cientos de millones. Despreciamos la actitud de "esto es estándar, no lo leas". **Todo** se lee y se entiende.

Cuarto: el SHA es subestimado y decisivo. Advertimos que muchos abogados ponen toda la energía en el SPA (la compra) y descuidan el SHA (la convivencia). Pero para el inversionista, el SHA —gobierno y salida— vale tanto como el precio. Y para la empresa familiar, es lo que la **salva o la destruye** en la siguiente generación.

Quinto: adaptar, no copiar, las cláusulas anglosajonas. Importar un SPA de Nueva York sin anclarlo en el derecho mexicano produce cláusulas **inejecutables**. El abogado de élite domina **ambos** mundos.

Sexto, y es una crítica dirigida contra nuestra propia profesión. Los SPA crecen. Cien páginas, doscientas, más *schedules* interminables. Cada versión incorpora la cláusula que salvó a alguien en un litigio ajeno, y ninguna versión quita nada. El resultado es una **carrera armamentista contractual** con tres efectos que conviene mirar de frente:

- **Eleva los costos de transacción** de toda operación, incluidas las que no los justifican.
- **Favorece a quien tiene más recursos legales**, porque la parte con el equipo más grande impone el documento y su lectura.
- **Y no está claro que proteja más.** Un contrato que nadie del lado del cliente ha leído completo protege menos de lo que aparenta: los riesgos verdaderamente relevantes se pierden entre los irrelevantes, exactamente como el reporte de *due diligence* de cuatrocientas páginas que criticamos en el Libro 2.

La pregunta incómoda, entonces, es si la extensión protege al cliente o transfiere renta al despacho. La reacción existe y tiene nombre: el movimiento de **redacción en lenguaje claro** (*plain-language drafting*), cuya referencia obligada es **Kenneth Adams, A Manual of Style for Contract Drafting**.

Postura del Consejo: la extensión no es una virtud ni un defecto en sí. La prueba es funcional y la recomendamos como

control de calidad: **si no puedes explicarle a tu cliente, en dos minutos, qué hace una cláusula y qué pasaría sin ella, esa cláusula no está defendiendo a nadie.** Y una regla de oficio que se deriva: la cláusula que se copió "porque venía en el modelo" es la que más probabilidades tiene de contradecir a otra del mismo contrato.

29. Debate doctrinal

- **¿Pro-sandbagging o anti-sandbagging?** ¿Debe poder reclamar el comprador que **sabía** que la rep era falsa? *Postura del Consejo:* en el plano de la **autonomía**, lo que las partes pacten; pero recomendamos **pactarlo expresamente** (no dejarlo al silencio) y, en México, ser consciente de que la **buena fe** y el **dolo** del CCF pueden modular el resultado. El comprador debe preferir *pro-sandbagging* explícito; el vendedor, *anti*.
- **¿Locked box o completion accounts?** ¿Certeza (precio fijo) o exactitud (ajuste al cierre)? *Postura del Consejo:* depende del deal —*locked box* da certeza y evita disputas (ideal con DD financiera sólida y vendedor confiable); *completion accounts* da precisión (mejor cuando el capital de trabajo es volátil o hay desconfianza)—. No hay respuesta única.
- **¿Hasta dónde llega la MAC?** ¿Quién soporta el riesgo de que "el mundo cambie" entre firma y cierre? *Postura del Consejo:* el equilibrio razonable es que el **comprador** asuma los riesgos **sistémicos** (no son culpa de nadie) y el **vendedor** responda por lo **específico de la target** y por el impacto **desproporcionado**. La pelea está en las *carve-outs*, y ahí se gana o se pierde.
- **¿El seguro de W&I diluye el cuidado en la due diligence?** *Postura del Consejo:* no debería —la aseguradora **exige** DD rigurosa para emitir la póliza—; el seguro **complementa**, no sustituye, ni la due diligence ni el criterio.
- **Drag along vs. tag along: ¿de quién es la operación?** Tensión entre el poder de la **mayoría/ inversionista** de vender todo (drag) y la protección de la **minoría** de no quedar atrapada (tag). *Postura del Consejo:* ambos son legítimos y deben

coexistir con salvaguardas (precio mínimo, mismas condiciones, umbrales); el abogado de la minoría debe **pelear el tag** y acotar el drag (precio justo, no por debajo de la inversión).

30. Errores comunes

- **Tratar el Term Sheet como inofensivo.** Redactarlo sin la cláusula clara de "no vinculante" y quedar atrapado en un compromiso o en responsabilidad precontractual. *Corrección:* distingue expresamente lo vinculante (exclusividad, confidencialidad) de lo no vinculante (precio, estructura).
- **Copiar cláusulas sin entenderlas.** Usar un SPA "plantilla" sin saber por qué existe cada cláusula ni a quién protege. *Corrección:* domina la **lógica** de cada cláusula antes de redactarla.
- **Descuidar las definiciones.** Subestimar el glosario ("Pérdidas", "Conocimiento", "Deuda"): una definición floja vacía o dispara una cláusula. *Corrección:* negocia las definiciones con la misma seriedad que el clausulado.
- **Negociar la indemnización sin pensar en el precio.** Tratar caps/baskets/MAC como tecnicismos separados del valor. *Corrección:* recuerda que son **reparto económico del riesgo** = precio encubierto.
- **Redactar mal las *carve-outs* de la MAC.** Dejar ambiguo quién soporta los riesgos sistémicos. *Corrección:* redacta con precisión las exclusiones y la regla del impacto desproporcionado.
- **Confiar en reclamar después en vez de revelar/cubrir.** Detectar algo en la DD y no exigir indemnización especial ni cláusula pro-sandbagging. *Corrección:* traduce el hallazgo en cláusula **antes** de cerrar.
- **Descuidar el SHA.** Poner toda la energía en el SPA y dejar el SHA (gobierno, salida) como un anexo. *Corrección:* para el inversionista y la empresa familiar, el SHA es **decisivo**.
- **Importar cláusulas anglosajonas sin anclarlas en derecho mexicano.** Volverlas inejecutables. *Corrección:* an-

cla en penas convencionales, condiciones y renunciaciones válidas del CCF.

- **Earn-out mal redactado.** Métricas ambiguas y sin covenants de gestión → litigio asegurado. *Corrección:* métricas objetivas, reglas de gestión y mecanismo de resolución.

31. Mitos frecuentes

- **"El Term Sheet no obliga a nada." Falso.** Sus cláusulas de exclusividad, confidencialidad y gastos **sí** obligan, y un mal redactado puede generar responsabilidad precontractual.
- **"Las reps son relleno; lo que importa es el precio." Falso.** Las reps **son** parte del precio: asignan el riesgo del pasado y determinan cuánto puede reclamar el comprador.
- **"La cláusula MAC me deja salir si el negocio empeora." Falso (casi siempre).** El umbral es altísimo (sustancial y duradero) y las exclusiones suelen cubrir los riesgos sistémicos. Es más amenaza para renegociar que botón de escape.
- **"El asset deal me aísla de todos los pasivos, y el APA lo garantiza." Falso.** Los pasivos laborales, fiscales y ambientales pueden seguir al negocio pese al APA.
- **"Si lo descubrí en la due diligence, igual puedo reclamar después." Depende.** Solo con cláusula *pro-sandbagging*; con *anti-sandbagging*, no. Mejor revelar y cubrir con indemnización especial.
- **"El SHA es un trámite posterior." Falso.** Para el inversionista vale tanto como el precio (gobierno + salida); para la familia, decide la supervivencia del negocio.
- **"Un SPA de Nueva York funciona igual en México." Falso.** La forma es global; la **exigibilidad** es local. Hay que adaptarlo.

32. Preguntas difíciles

1. **¿Por qué lo que el vendedor revela en el *disclosure schedule* lo protege a él?** Porque la rep se entiende cierta "**salvo lo revelado**": al revelar una excepción, el vendedor **ya no incumple** la rep respecto de eso (el comprador lo aceptó con conocimiento). Por eso el vendedor tiene incentivo a re-

velar mucho (vacunarse) y el comprador a leer los schedules con lupa.

2. **¿Cómo se conecta la due diligence (Libro 2) con el SPA?**
Directamente: riesgo **desconocido** → reps + indemnización (con caps/baskets); riesgo **concreto conocido** → indemnización **especial** (sin tope); riesgo **subsancable** → condición al cierre; riesgo de **cambio** entre firma y cierre → MAC; lo **revelado** → sale por disclosure schedules. El SPA es la DD hecha cláusulas.
3. **¿Por qué un fondo pelea el *drag along*?** Porque su negocio es **comprar y vender** (exit); el drag le garantiza poder vender la **empresa entera** (lo que un comprador quiere) sin que un minoritario lo bloquee. Sin drag, su salida queda a merced de terceros.
4. **¿Locked box o completion accounts para una empresa con capital de trabajo muy volátil?** Tiende a convenir **completion accounts** (ajuste al cierre), porque captura las variaciones reales; el *locked box* (precio fijo) dejaría el riesgo de esa volatilidad al comprador desde la fecha del box.
5. **¿Qué diferencia a una rep "fundamental" de una "del negocio", y por qué importa?** Las fundamentales (título de acciones, capacidad, autoridad) tocan la **esencia** de lo que se compra; por eso reciben protección **reforzada** (sin tope, supervivencia larga/indefinida). Las del negocio se topan y caducan antes. La distinción define **cuánto y por cuánto tiempo** responde el vendedor.

33. Casos de examen (con respuesta modelo)

Caso A. *En la due diligence detectaste un litigio fiscal concreto de 5 millones, probable pero no seguro. El vendedor se niega a bajar el precio. ¿Cómo lo proteges en el SPA? Respuesta modelo:* Como es un riesgo **concreto y conocido**, no basta la rep general: se pacta una **indemnización especial** por ese litigio específico, **al 100% y fuera de caps y baskets**, respaldada por un **escrow** suficiente por el plazo de resolución, con **control de la defensa** del litigio definido. Alternativamente, un **ajuste/retención** de precio por el monto en riesgo. Razonar: riesgo conocido → indemnización específica, no rep general.

Caso B. *Firmas un SPA en enero con cierre en mayo (pendiente COFECE). En marzo, una recesión golpea a toda la industria y la target pierde 30% de ventas. Tu cliente comprador quiere salir. ¿Puede invocar la MAC? Respuesta modelo:* Depende de las **carve-outs** de la MAC. Si excluye los **eventos sistémicos** (recesiones, condiciones de la industria) —lo habitual—, el comprador **no** puede salir, **salvo** que la target esté afectada **desproporcionadamente** frente a sus competidores. Además, el umbral exige un impacto **sustancial y duradero**, no un mal trimestre. Probablemente **no** procede la salida; sí puede servir como palanca de **renegociación**. Citar la lógica de Akorn/Tyson.

Caso C. *Un fondo invierte 40% en una empresa familiar y quiere asegurar su salida en 6 años. ¿Qué cláusulas del SHA son imprescindibles? Respuesta modelo:* **Drag along** (para vender el 100% sin bloqueo de la familia), **derechos de registro/compromiso de exit** (venta o IPO en el horizonte), **preferencia de liquidación** (cobrar primero), **vetos** sobre decisiones que afecten su salida, y **tag along** (por si la familia vende antes). Sin drag y sin compromiso de exit, su salida queda atrapada. Conectar: para el inversionista, la **salida** es lo central del SHA.

34. Simulador (ejercicio tipo despacho)

Instrucciones: eres asociado de M&A. Representas al **comprador** (un fondo) en la adquisición del 100% de *Distribuidora Sol*, S.A. La DD reveló: (i) un contrato clave con *change of control*; (ii) una contingencia fiscal concreta de 8M; (iii) capital de trabajo estacional muy volátil; (iv) la PI de la marca a nombre de un accionista. Diseña la **protección documental** antes de leer la guía.

1. ¿Qué mecanismo de **precio** propones, dada la volatilidad del capital de trabajo?
2. ¿Cómo proteges la **contingencia fiscal concreta**?
3. ¿Cómo aseguras la **continuidad del contrato clave** con *change of control*?
4. ¿Cómo resuelves la **PI a nombre del accionista**?
5. ¿Qué pides en **indemnización** (cap, basket, supervivencia, sandbagging) como comprador?

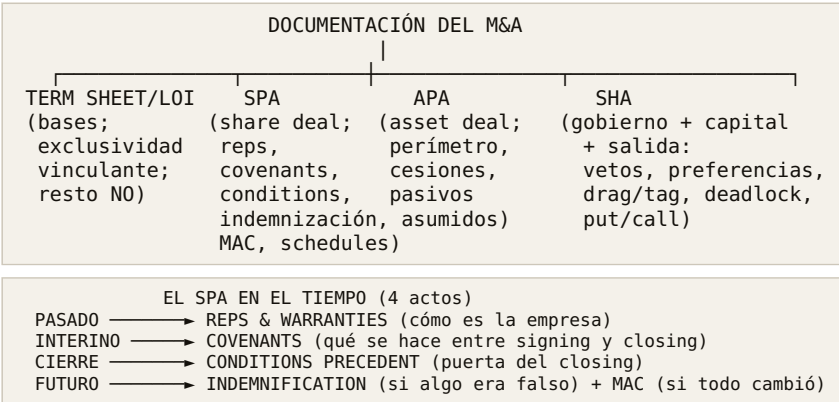
Guía de solución (resumen). (1) **Completion accounts** (ajuste por capital de trabajo, deuda neta y caja al cierre), por la volatilidad estacional; alternatively **locked box** con un *target* de capital de trabajo bien calibrado. (2) **Indemnización especial** por la contingencia fiscal (100%, fuera de cap/basket) + **escrow** por el plazo de prescripción + control de la defensa. (3) **Consentimiento** de la contraparte como **condición al cierre** (CP); si no se obtiene, derecho a no cerrar o ajustar precio. (4) **Condición al cierre de transferir la PI** a la sociedad + rep específica + indemnización por titularidad. (5) Como comprador: **cap alto** (o 100% para fundamentales/fiscales), **basket bajo** (idealmente *typing*), **supervivencia larga** (fiscales/ fundamentales hasta su prescripción), reps *sin knowledge qualifier* donde se pueda, y cláusula **pro-sandbagging**. Y **escrow** o **W&I insurance** para asegurar el cobro.

35. Flashcards

- **¿Qué es vinculante en un Term Sheet?** Lo procesal (exclusividad, confidencialidad, gastos, ley aplicable); lo sustantivo (precio, estructura), normalmente NO.
- **¿Las cuatro piezas del SPA en el tiempo?** Reps (pasado) · Covenants (interino) · Conditions (cierre) · Indemnización (futuro).
- **¿Qué son las reps & warranties?** Afirmaciones de hecho garantizadas; si son falsas → indemnización.
- **¿Cap, basket, de minimis, survival?** Tope máximo · umbral mínimo acumulado · mínimo por reclamación · plazo de vigencia de la rep.
- **¿Indemnización especial?** Para riesgo concreto y conocido (de la DD), normalmente sin tope y fuera de cesta.
- **¿Qué es la MAC?** Cláusula que permite no cerrar ante un cambio adverso sustancial y duradero; umbral altísimo.
- **¿Qué son los disclosure schedules?** Anexos donde el vendedor revela excepciones a sus reps (lo revelado deja de estar garantizado).
- **¿Sandbagging?** Si el comprador que sabía puede reclamar (pro) o no (anti); se pacta expresamente.

- **¿Locked box vs. completion accounts?** Precio fijo sobre balance pasado / ajuste según balance al cierre.
- **¿Earn-out?** Parte del precio diferida y condicionada a resultados futuros.
- **¿Drag vs. tag along?** La mayoría obliga a vender (drag) / la minoría puede sumarse a la venta (tag).
- **¿Preferencia de liquidación?** Derecho del inversionista a cobrar primero (un múltiplo) en venta/ liquidación.
- **¿SPA vs. APA?** Compra de acciones (sociedad entera) / compra de activos (perímetro descrito).

36. Mapas mentales



37. Cuadros comparativos

Los cuatro documentos

	TERM SHEET/ LOI	SPA	APA	SHA
Función	Bases del deal	Comprar acciones	Comprar activos	Gobernar a los socios
Vinculante	Parcial	Total	Total	Total
Momento	Inicio	Firma/cierre	Firma/cierre	Tras la inversión
Núcleo	Exclusividad, precio	Reps, indemnización, MAC	Perímetro, pasivos	Vetos, drag/tag, salida

Qué quiere cada parte en la indemnización

VARIABLE	COMPRADOR QUIERE	VENDEDOR QUIERE
Cap (tope)	Alto	Bajo
Basket (umbral)	Bajo	Alto
Supervivencia	Larga	Corta
Knowledge qualifier	Sin él (objetivo)	Con él
Sandbagging	Pro	Anti
Escrow	Grande	Pequeño / W&I

Drag vs. Tag (la tensión de la salida)

	DRAW ALONG	TAG ALONG
A favor de	Mayoría / inversionista	Minoría
Efecto	Obliga a la minoría a vender	Permite a la minoría sumarse
Objetivo	Vender el 100% sin bloqueo	No quedar atrapado con nuevo control

38. Diagramas

Del hallazgo (DD) a la cláusula (SPA):

Riesgo DESCONOCIDO → rep general + indemnización (cap/basket)
Riesgo CONCRETO y CONOCIDO → indemnización ESPECIAL (sin tope, fuera de cesta)
Riesgo SUBSANABLE → condición al cierre (CP)
Riesgo de CAMBIO (firma-cierre) ► cláusula MAC
Lo que el vendedor REVELA → disclosure schedules (sale de la garantía)

Anatomía del SPA (mapa de secciones):

1. Definiciones → 2. Objeto y Precio → 3. Reps & Warranties
→ 4. Covenants → 5. Conditions Precedent → 6. Indemnification
→ 7. Terminación / MAC → 8. Boilerplate (ley, arbitraje) → 9. Anexos (disclosure schedules)

El SHA (tres familias):

GOBIERNO consejo, vetos, información, deadlock	CAPITAL preferencia liq., antidilución, preemptive rights	SALIDA lock-up, ROFR/ROFO, tag along, drag along, put/call, exit/IP0, leaver
---	--	---

39. Mnemotecnias

- **SPA en el tiempo (RCCI):** Reps (pasado) · Covenants (interino) · Conditions (cierre) · Indemnización (futuro).
- **Term Sheet:** "lo sustantivo no obliga; lo procesal sí" (exclusividad y confidencialidad vinculan).
- **Indemnización:** "cap arriba, basket abajo, survival el reloj".

- **Riesgo conocido vs. desconocido:** *"lo desconocido → rep general; lo conocido → indemnización especial"*.
- **MAC:** *"firmar no es cerrar; pero salir por MAC casi nunca"* (umbral altísimo).
- **Disclosure:** *"lo que revelo, ya no lo garantizo"*.
- **Sandbagging:** *"pro = el comprador cobra aunque supiera; anti = no"*.
- **Salidas del SHA:** *"drag arrastra (mayoría), tag acompaña (minoría)"*.
- **Regla de oro:** *"no copies cláusulas; entiende qué riesgo reparte cada una"*.

40. Resumen ejecutivo

La documentación es donde el M&A se vuelve **texto vinculante y exigible**. Cuatro documentos nucleares. El **Term Sheet / LOI** fija las bases de la negociación: lo **sustantivo** (precio, estructura) es **no vinculante** —para poder retirarse—, pero lo **procesal** (exclusividad, confidencialidad, gastos, ley aplicable) **sí** obliga; redactar mal la cláusula de "no vinculante" es un error caro. El **SPA** (compraventa de acciones) es el documento rey: un **sistema de asignación de riesgo en el tiempo** —las **reps & warranties** garantizan cómo es la empresa (pasado), los **covenants** regulan la conducta entre firma y cierre (interino), las **conditions precedent** son la puerta del cierre, y la **indemnización** (con *cap, basket, de minimis* y *survival*) responde si algo era falso (futuro), mientras la **MAC** cubre el riesgo de que el mundo cambie entre firma y cierre—. Los **disclosure schedules** revelan excepciones a las reps (lo revelado deja de estar garantizado), y el **sandbagging** define si el comprador que ya sabía puede reclamar. El **precio** se fija y ajusta vía *locked box* o *completion accounts*, con *earn-out* y *escrow*. El **APA** (compraventa de activos) replica la estructura del SPA pero su corazón es la **descripción del perímetro** (activos/pasivos incluidos y excluidos) y las **cesiones y consentimientos**. Y el **SHA** gobierna la convivencia de los socios: **gobierno** (consejo, vetos, deadlock), **capital** (preferencia de liquidación,

antidilución) y **salida** (lock-up, ROFR/ROFO, **tag along, drag along**, put/call).

La lección que atraviesa el libro: **no se memorizan cláusulas, se entiende la gramática del riesgo**. Cada cláusula existe porque responde a una pregunta —¿qué me aseguras?, ¿qué pasa entre firma y cierre?, ¿qué condiciones?, ¿qué pasa si sale mal?, ¿cómo gobernamos y cómo salimos?— y cada respuesta **reparte un riesgo** entre las partes. El SPA es, literalmente, **la due diligence convertida en cláusulas**, y el documento **sigue a la estructura**, que **sigue a la due diligence**: la cadena **investigar → estructurar → documentar** queda completa.

Para tu perfil —operaciones complejas, M&A, gobierno corporativo y contratos estratégicos— este libro es central: el SPA/ APA documenta la operación, el SHA **diseña el gobierno corporativo y las salidas por contrato**, y el Term Sheet sienta las bases de todo acuerdo estratégico. Dominar esta documentación —con criterio, no como formulario, y anclada en el derecho mexicano— es dominar el **lenguaje en el que se escriben los acuerdos corporativos**.

41. Checklist

Term Sheet / LOI:

- [] ¿Cláusula **expresa** de "no vinculante" para lo sustantivo, con las excepciones vinculantes (exclusividad, confidencialidad, gastos, ley aplicable) claramente identificadas?
- [] ¿Exclusividad (*no-shop*) por un plazo razonable que proteja la inversión en la due diligence?

SPA / APA:

- [] ¿Las **definiciones** clave ("Pérdidas", "Conocimiento", "Deuda", "MAC") están negociadas?
- [] ¿Las **reps** cubren todo lo relevante? ¿Distingues fundamentales vs. del negocio? ¿*Knowledge* y *materiality qualifiers* calibrados?
- [] ¿Los **covenants** protegen el periodo interino (operación ordinaria) y el post-cierre (no competencia razonable)?

- [] ¿Las **condiciones al cierre** recogen autorizaciones (CO-FECE), consentimientos por *change of control*, *bring-down* de reps y ausencia de MAC?
- [] ¿La **indemnización** (cap, basket, de minimis, survival) refleja el reparto de riesgo y el precio acordado? ¿Indemnizaciones **especiales** para los riesgos concretos de la DD?
- [] ¿La **MAC** y sus *carve-outs* asignan claramente el riesgo sistémico vs. específico?
- [] ¿Definiste **sandbagging** (pro/anti) y el **mecanismo de precio** (locked box / completion accounts, earn-out, escrow)?
- [] **APA**: ¿perímetro de activos/pasivos preciso? ¿Cesiones y consentimientos como CP? ¿Cuestión laboral resuelta?
- [] ¿Las cláusulas importadas están **ancladas** en derecho mexicano (exigibles)? ¿Cláusula **arbitral**?

SHA:

- [] **Gobierno**: ¿asientos de consejo, **vetos/materias reservadas**, información, mecanismo de *deadlock*?
- [] **Capital**: ¿preferencia de liquidación, antidilución, derechos de preferencia?
- [] **Salida**: ¿lock-up, ROFR/ROFO, **tag along**, **drag along**, put/call, compromiso de exit/IPO, *good/bad leaver*?
- [] ¿Lo que se pueda está **reflejado en los estatutos** (S.A.P.I.) para oponerlo a terceros?

42. Bibliografía comentada

- **American Bar Association — Model Stock Purchase Agreement with Commentary y Model Asset Purchase Agreement. Imprescindible**: el SPA y el APA cláusula por cláusula con comentario. El mejor material del mundo para dominar la documentación.
- **Subramanian, Dealmaking (Harvard)**. El contrato como producto de una **negociación** estratégica (setup, MAC, earn-out, drag/tag).

- **Jurisprudencia de Delaware (Akorn, Tyson, Genesco).** Interpretación de la **MAC**, el *sandbagging* y las reps; modela la redacción global.
- **Practical Law / PLC y precedents de despachos.** Los **estándares de mercado** de cada cláusula (qué cap, basket y survival son "de mercado").
- **Ley del Mercado de Valores (S.A.P.I.) y doctrina societaria mexicana.** El sustento legal del **SHA** en México (validez de vetos, drag/tag, opciones).
- **Código Civil Federal / Código de Comercio (compraventa, saneamiento, vicios del consentimiento, penas convencionales).** La base local en la que se **anclan** las cláusulas para que sean exigibles.
- **Materiales sobre W&I insurance.** Cómo el seguro de reps & warranties reconfigura la indemnización.
- **Lou Kling & Eileen Nugent, *Negotiated Acquisitions of Companies, Subsidiaries and Divisions*.** La obra de referencia de la práctica transaccional estadounidense: si quieres **una sola** fuente avanzada sobre por qué cada cláusula del SPA está redactada así, es esta.
- **Kenneth Adams, *A Manual of Style for Contract Drafting*.** El antídoto contra la carrera armamentista del §28: cómo se redacta con precisión y sin grasa. Cámbiale el vicio de copiar modelos.
- **Grossman, Hart & Moore, sobre derechos de propiedad y contratos incompletos** (*Journal of Political Economy*, 1990, y trabajos previos). El fundamento teórico del §6: por qué ningún contrato puede prever todo y qué hace entonces un buen contrato.
- **Banco de Formatos** de esta obra (term sheet, SPA, acta) para el nivel básico: leer un modelo completo antes de estudiar sus cláusulas por separado.

43. Ruta hacia el siguiente libro

Ya dominas el **lenguaje del M&A**: sabes leer y redactar el Term Sheet, el SPA, el APA y el SHA entendiendo la lógica de

cada cláusula. Con esto cierras la **cadena nuclear** del M&A: **investigar (Libro 2) → estructurar (Libro 3) → documentar (Libro 4)**. El siguiente paso —según la ampliación que acordamos para tu perfil— es entender **cómo se financian** las operaciones: la otra mitad de casi todo deal grande.

- **Siguiente libro:** *Libro 5 · Derecho Bancario y Financiamiento Corporativo* — la deuda bancaria y **sindicada**, las **garantías** (reales y personales) y los paquetes de garantías, los **covenants financieros**, el *project finance*, el **acquisition finance** (cómo se financia específicamente una compra/LBO) y los **bonos**. Es la columna que falta para estructurar operaciones complejas: casi ningún deal grande se paga solo con caja.
- **Conexión inmediata:** los **covenants** y las **condiciones** que viste en el SPA tienen su gemelo en los contratos de financiamiento (los *facilities agreements*); el **escrow** y los mecanismos de precio se entienden mejor sabiendo cómo se fondea el comprador; y el **LBO** que anticipamos en el Libro 3 (NewCo + deuda + fusión apalancada) se documenta con los contratos que estudiarás a continuación.

◆ ¿Por qué esto importa para un abogado corporativo?

Porque la documentación es **el producto tangible y mejor remunerado** del abogado de M&A: el contrato que protege la inversión del cliente. Un socio se distingue, ante todo, por su **maestría en el SPA y el SHA** —saber qué cláusula pedir, cómo redactarla, hasta dónde ceder y qué riesgo esconde cada palabra del borrador de la contraparte—. Esta habilidad es **acumulativa y difícil de improvisar**: cada cláusula estándar existe porque algún deal salió mal y nació para evitar que se repita; quien entiende esa historia lee los contratos con una profundidad que ningún formulario da. Y para quien quiere especializarse en **operaciones complejas, gobierno corporativo y contratos estratégicos**, este libro es la columna vertebral: el SPA/APA documenta la operación, el **SHA diseña el gobierno y las salidas por contrato**, y el Term Sheet sienta las bases de todo acuerdo. Dominar esta documentación es **ha-**

blar el idioma en que se toman y se blindan las grandes decisiones corporativas.

♦ **Cómo piensa un socio de un despacho internacional**

"Cuando recibo el borrador de un SPA, no lo leo de corrido: lo leo como un mapa de riesgos. Voy directo a tres lugares. Primero, las reps & warranties y sus calificadores: ¿qué garantiza el vendedor, y cuánto lo diluyen los 'a mi leal saber y entender' y los 'en aspectos materiales'? Cada calificador que acepto es un riesgo que le quito al vendedor y se lo paso a mi cliente. Segundo, el paquete de indemnización: cap, basket, supervivencia, escrow. Esto no es técnica jurídica aislada: es precio. Si acepto un cap del 10% en vez del 30%, le acabo de regalar al vendedor una rebaja de riesgo que vale millones; lo negocio hablando con mi cliente de cuánto riesgo quiere retener. Tercero, la MAC y sus exclusiones: ahí se decide quién carga con que el mundo cambie entre la firma y el cierre. Y en el SHA, mi obsesión es la salida: el precio de entrada se negocia un día, pero la salida define el retorno de toda la inversión —drag, tag, preferencia, compromiso de exit—. Mi regla con los asociados: ninguna cláusula es relleno y ninguna se copia sin entender qué riesgo reparte. El que redacta sin entender, tarde o temprano firma una bomba."

♦ **Errores que cuestan millones**

1. **Term Sheet que obliga sin querer.** Redactarlo de forma que parezca un acuerdo cerrado y quedar atrapado en un compromiso o en responsabilidad precontractual. *Prevención:* cláusula expresa de "no vinculante" con las excepciones procesales bien delimitadas.
2. **MAC con carve-outs mal redactadas.** Que una crisis te deje sin salida (o que se la dé a la contraparte) por una exclusión ambigua. *Prevención:* redactar con precisión riesgo sistémico vs. específico y la regla del impacto desproporcionado.
3. **No traducir el hallazgo de la DD a una cláusula.** Detectar un riesgo concreto y conformarse con la rep general (topada y con basket) en vez de exigir **indemnización especial** sin tope. *Prevención:* riesgo conocido → indemnización específica.

4. **Descuidar el SHA (gobierno y salida).** Para el inversionista, una salida mal diseñada (sin drag, sin compromiso de exit) atrapa su capital; para la familia, la falta de reglas destruye la empresa. *Prevención:* negociar el SHA con la misma energía que el precio.
5. **Importar cláusulas anglosajonas sin anclarlas en derecho mexicano.** Volverlas **inejecutables** (sandbagging, ciertas renunciaciones, penas). *Prevención:* anclar en figuras del CCF/CCom y pactar arbitraje.

Cierre del Libro 4. Has aprendido a **convertir la operación en texto vinculante:** el Term Sheet que ordena, el SPA y el APA que consuman y asignan el riesgo, y el SHA que gobierna la convivencia y diseña las salidas. Más importante que las cláusulas, te llevas la **gramática del riesgo:** la capacidad de leer cualquier contrato de M&A y ver, en minutos, **dónde está el riesgo y quién lo soporta.** Con esto cierras la cadena nuclear del M&A —**investigar → estructurar → documentar**— y tienes ya el oficio central del abogado de transacciones. Ahora ampliamos hacia tu perfil: en el **Libro 5 · Derecho Bancario y Financiamiento Corporativo** aprenderás **cómo se paga** todo esto —la deuda, las garantías, los covenants financieros, el acquisition finance—, la otra mitad de casi cualquier operación compleja.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE IV

[Nivel IV · Libro 5] Derecho Bancario y Financiamiento Corporativo

☞ **Apóstrofe de vigencia** — **léela cada vez**. El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

Casi ningún deal grande se paga solo con caja. Detrás de cada adquisición, cada expansión, cada proyecto de infraestructura, hay **deuda** —y un entramado de contratos, garantías y reglas que la rigen—. Este libro estudia **cómo se financia una empresa y cómo se financia una operación**: el crédito bancario y sindicado, las garantías reales y personales, los *covenants* financieros, el *project finance*, el **acquisition finance** (el motor del LBO que ya viste en el Libro 3) y los bonos. Es la **otra mitad** del trabajo del abogado de operaciones complejas: quien domina la documentación del M&A (Libro 4) y la del financiamiento se vuelve capaz de estructurar el deal completo —el equity y la deuda—. Este libro fue añadido a la biblioteca específicamente para tu perfil.

Etiquetas: corporate law · financiamiento · derecho bancario · crédito sindicado · garantías · covenants · project finance · acquisition finance · bonos **Prerrequisitos:** Libro 1 · Fundamentos de M&A, Libro 3 · Estructuras y Libro 4 · Documentación + Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC), Garantías y Derechos Reales de Garantía, Obligaciones y Mercado de Valores (LMV). **Estándar:** V3 (43 secciones + secciones transversales). ⌚ **Tiempo estimado de dominio:** 6–7 semanas (≈ 60–75 h de estudio activo). Lectura de reconocimiento: 10–12 h. *Estúdialo en bloques: el sistema financiero y el crédito → el contrato de crédito y sus covenants → garantías y paquetes de*

garantías → crédito sindicado → project finance y acquisition finance → bonos y mercado de deuda.

Aviso de método. Tratado, no repaso. Aprenderás a **estructurar y documentar deuda** entendiendo la lógica del prestamista (¿cómo me aseguro de cobrar?) y la del deudor (¿cómo obtengo capital sin atarme de manos?). Cada figura se conecta con el M&A (Libros 1-4): el financiamiento es lo que **paga** la operación, y sus contratos son el gemelo de los que ya dominas.

NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL (VISTA RÁPIDA)

Litigio	★★★☆☆
Corporate	★★★★★
M&A	★★★★★
Mercado de Valores	★★★★★
Venture Capital	★★★☆☆
Private Equity	★★★★★
Gobierno Corporativo	★★★☆☆
Compliance	★★★★☆
Derecho Bancario	★★★★★
Empresa Familiar	★★★☆☆

Para tu perfil (financiamiento empresarial + operaciones complejas), es columna vertebral: estructurar la deuda que paga las operaciones —deuda bancaria, sindicada, project y acquisition finance, bonos— es de las prácticas más técnicas, mejor pagadas y más demandadas del derecho corporativo.

1. Introducción

Una empresa, para existir y crecer, necesita **capital**. Ese capital viene de dos grandes fuentes: **equity** (lo que aportan los dueños: acciones, utilidades reinvertidas) y **deuda** (lo que presta un tercero y debe devolverse con intereses). El **financiamiento corporativo** es el campo que estudia **cómo una empresa obtiene capital de deuda** —de bancos, del mercado, de fondos— y **cómo se estructuran, documentan y garantizan** esos financiamientos. El **derecho bancario**, por su parte, es el marco que regula a las **instituciones** que prestan (los bancos) y a sus operaciones.

Este libro une ambos porque, en la práctica del abogado corporativo, van de la mano: cuando una empresa se financia, lo hace mayoritariamente a través de **bancos** (sujetos a regula-

ción bancaria) y de **instrumentos** (créditos, bonos) cuya arquitectura jurídica hay que dominar. La idea rectora del libro: **la deuda es un contrato de confianza garantizada en el tiempo**. El prestamista entrega dinero hoy a cambio de la promesa de recuperarlo mañana con interés; todo el derecho del financiamiento gira en torno a **proteger esa recuperación** — mediante garantías (si no me pagas, ejecuto un bien), *covenants* (te obligo a mantener tu salud financiera) y mecanismos de control (vigilo y puedo acelerar la deuda si te deterioras)—.

¿Por qué es central para el M&A y para tu perfil? Porque **casi ninguna operación grande se paga solo con caja**. La adquisición de una empresa se financia con una mezcla de equity y deuda; el LBO de un fondo de *private equity* (que viste en el Libro 3) **se construye sobre deuda** (*acquisition finance*); un proyecto de infraestructura se levanta con *project finance*. El abogado que domina el M&A pero **no** entiende el financiamiento solo ve **la mitad** del deal. Quien domina ambos —el *equity* (Libros 1-4) y la *deuda* (este libro)— puede estructurar la **operación completa**, que es exactamente lo que define al especialista en operaciones corporativas complejas que quieres ser.

A lo largo del libro verás un patrón familiar: los contratos de financiamiento tienen **reps, covenants, condiciones, eventos de incumplimiento e indemnización**, igual que el SPA. No es coincidencia: ambos son **sistemas de asignación de riesgo en el tiempo**. Si dominaste el Libro 4, tienes ya medio camino andado; aquí aprenderás el **otro lado de la mesa**: el del que pone el dinero.

2. Objetivos del libro

Al terminar, el lector será capaz de:

- **Comprender** el sistema financiero y bancario mexicano: quién presta, bajo qué regulación (CNBV, Banxico), y los grandes tipos de financiamiento (bancario, bursátil, de fondos).
- **Disecionar el contrato de crédito** (el *facilities agreement*): el tipo de facilidad (simple, revolving, a plazo), las **disposi-**

ciones y amortización, los intereses (tasa, *spread*), las **reps**, los **covenants** (afirmativos, negativos y **financieros**) y los **eventos de incumplimiento** (*events of default*) con la **aceleración**.

- **Dominar las garantías:** reales (hipoteca, prenda —incluida la prenda sin transmisión de posesión—, fideicomiso de garantía) y personales (aval, fianza, obligación solidaria, *guarantee*), y cómo se arma un **paquete de garantías** (*security package*).
- **Entender el crédito sindicado:** por qué varios bancos prestan juntos, los roles (*agent*, *arranger*), el reparto del riesgo y la documentación (LMA/LSTA).
- **Estructurar el *project finance*:** financiamiento "sin recurso" basado en el flujo de un proyecto, el vehículo (SPV), la cascada de pagos y el paquete de garantías sobre el proyecto.
- **Estructurar el *acquisition finance* y el LBO:** cómo se financia una adquisición, el *bridge*, la deuda *senior* y subordinada, el *intercreditor agreement*, y los límites a la **asistencia financiera**.
- **Comprender los bonos y el mercado de deuda:** emisión de deuda en el mercado de valores (LMV), el *indenture/acta de emisión*, el *trustee*, y la diferencia con el crédito bancario.
- **Conectar** el financiamiento con el M&A: cómo la deuda **paga** la operación y cómo sus contratos dialogan con el SPA y la estructura.

3. Importancia profesional

El financiamiento es una de las prácticas **más técnicas, mejor remuneradas y más demandadas** del derecho corporativo, y para **tu perfil específico** —financiamiento empresarial y estructuración de operaciones complejas— es **indispensable**. Los abogados de *banking & finance* de los grandes despachos trabajan en las operaciones más grandes del mercado: financiamientos sindicados de miles de millones, *project finance* de infraestructura y energía, financiamiento de adquisiciones,

emisiones de bonos. Es una práctica con **alto volumen de trabajo, alta sofisticación y alta retribución**.

Hay una razón estructural para su valor: el financiamiento es **transversal a toda la economía**. Toda empresa se endeuda; todo proyecto se financia; toda adquisición grande tiene un componente de deuda. El abogado que domina el financiamiento **nunca se queda sin trabajo**, porque incluso en las crisis (cuando el M&A se enfría) florece la **reestructuración de deuda** (la otra cara: qué pasa cuando el deudor no puede pagar —conecta con Concurso Mercantil—).

Para el abogado de **M&A**, entender el financiamiento es lo que lo vuelve un **arquitecto completo** de operaciones. El que estructura la compra (equity, SPA) pero no entiende cómo se fondea (deuda, *facilities*, garantías, *intercreditor*) depende de otro para la mitad del deal. El que domina ambos **lidera** la operación entera y dialoga de igual a igual con los bancos, los fondos y los asesores financieros. Esa integración —equity + deuda— es precisamente la marca del **especialista en operaciones corporativas complejas**.

4. Historia y origen

El crédito es tan antiguo como el comercio: ya en Mesopotamia y en Roma existían el préstamo con interés (*mutuum*) y las garantías (la *fiducia*, la *pignus*/prenda, la *hypotheca*). El derecho romano —que estudiaste en el Nivel I— legó las categorías básicas que aún usamos: el préstamo, la garantía real sobre un bien, la garantía personal de un tercero. La **banca** como institución nace en la Italia medieval y renacentista (los grandes banqueros florentinos y genoveses), que desarrollaron el crédito mercantil, la letra de cambio y las primeras redes de financiamiento internacional.

El **financiamiento corporativo moderno** se desarrolla con la empresa industrial y el capitalismo financiero de los siglos XIX y XX. Surgen los grandes bancos comerciales y de inversión, el **crédito sindicado** (varios bancos prestando juntos para repartir el riesgo de operaciones enormes), el **mercado de bonos** (la empresa se financia directamente del público

inversionista, sin intermediación bancaria), y —en la segunda mitad del siglo XX— las técnicas sofisticadas como el ***project finance*** (financiar un proyecto por su propio flujo) y el ***leveraged buyout*** (comprar empresas con deuda, el motor del *private equity*, que explotó en los años 1980).

En **México**, el derecho bancario y del crédito se estructuró a lo largo del siglo XX (la **LGTOC** de 1932 —que ya estudiaste— reguló los títulos y operaciones de crédito; sucesivas leyes bancarias regularon a las instituciones). Hitos relevantes: la **nacionalización bancaria** de 1982 y la posterior **reprivatización** (1990s); la crisis de 1994-95 (el "error de diciembre") y el rescate bancario; la apertura a la banca extranjera; y la modernización de las **garantías** (la creación de la **prenda sin transmisión de posesión** y del **fideicomiso de garantía** para facilitar el crédito empresarial). Hoy México tiene un marco de financiamiento moderno, plenamente integrado a los estándares internacionales.

5. Evolución histórica

La evolución del financiamiento corporativo puede leerse en tres movimientos:

1) De la garantía sobre el bien a la garantía sobre el flujo. Originalmente, el crédito se garantizaba con **bienes** (hipoteca sobre el inmueble, prenda sobre la cosa): "si no pagas, me quedo con tu bien". Con la sofisticación, el financiamiento aprendió a garantizarse sobre el **flujo de efectivo** —el *project finance* presta contra los **ingresos futuros** de un proyecto, no contra activos físicos— y sobre **conjuntos dinámicos** (prenda sobre inventarios y cuentas por cobrar que rotan). El foco pasó del **activo estático** al **flujo y el negocio en marcha**.

2) Del banco único al sindicato y al mercado. El crédito empezó siendo **bilateral** (un banco, un deudor). Al crecer las operaciones, ningún banco quería (ni podía) asumir solo el riesgo de prestar miles de millones: nació el **crédito sindicado** (muchos bancos, un solo contrato, riesgo repartido). Y para operaciones aún mayores, la empresa fue directamente al **mercado de capitales** emitiendo **bonos** (deuda fragmentada

entre miles de inversionistas). El financiamiento se **desintermedió** y **distribuyó**.

3) La estandarización y la ingeniería de la deuda. La repetición generó **documentación estándar** (los modelos de la **LMA** —Loan Market Association— en Europa y la **LSTA** en EE.UU.), y la deuda se volvió **objeto de ingeniería**: tramos *senior* y subordinados, deuda *mezzanine*, *unitranche*, *high-yield bonds*, titulización (convertir cuentas por cobrar en valores). Aparecieron los ***intercreditor agreements*** para ordenar la prelación entre acreedores, y el LBO convirtió la deuda en el **motor de la adquisición de empresas**. El abogado de financiamiento moderno es, en parte, un **ingeniero de estructuras de capital**.

6. Contexto económico

El financiamiento corporativo es **economía pura** aplicada al derecho. Tres ideas económicas lo gobiernan:

- **El valor del dinero en el tiempo y el interés como precio del riesgo.** Un peso hoy vale más que un peso mañana (puede invertirse, hay inflación, hay riesgo de no recuperarlo). El **interés** es el **precio** de ese tiempo y de ese riesgo: cuanto más riesgoso el deudor, mayor la tasa (el *spread* sobre la tasa de referencia). Todo el derecho del financiamiento busca **reducir el riesgo del prestamista** —y, al reducirlo, **abatar** el crédito para el deudor—. Una garantía sólida o *covenants* estrictos **bajan la tasa**.
- **La estructura de capital (deuda vs. equity) y el apalancamiento.** Las empresas combinan deuda y equity. La **deuda** tiene ventajas (los intereses suelen ser **deducibles**; el acreedor no diluye al dueño ni vota) pero también **riesgo** (hay que pagarla pase lo que pase; demasiada deuda lleva a la insolvencia). El **apalancamiento** (financiar con deuda) **amplifica** los rendimientos del equity cuando las cosas van bien —y las pérdidas cuando van mal—. El LBO del *private equity* es apalancamiento llevado al extremo: comprar una empresa con mucha deuda para multiplicar el retorno del equity.

- **La asimetría de información y el riesgo de crédito.** El prestamista sabe menos que el deudor sobre la salud real del negocio. Los **covenants** (obligaciones de mantener ciertos ratios, de informar, de no endeudarse más) y las **garantías** son los mecanismos económicos para **mitigar** esa asimetría y el riesgo de que el deudor se deteriore o actúe en perjuicio del acreedor (el problema de **riesgo moral**: que tras recibir el préstamo, el deudor tome más riesgo del prometido).

POR QUÉ EXISTE LA DEUDA, Y POR QUÉ EXISTEN LOS COVENANTS

Dos preguntas distintas con dos respuestas teóricas precisas. Conviene tenerlas nombradas, porque son las que te permiten explicarle a un director financiero **por qué** su contrato dice lo que dice.

Por qué una empresa se endeuda. El punto de partida es **Modigliani y Miller** (1958): en un mundo sin impuestos ni costos de quiebra, la estructura de capital sería irrelevante. Su propio matiz de 1963 introdujo lo que cambió todo: los intereses son **deducibles**, y ese **escudo fiscal** vuelve la deuda más barata que el capital. Pero el escudo no crece indefinidamente, porque a mayor deuda aumentan los **costos de insolvencia** —el riesgo de quiebra, la pérdida de flexibilidad, los proveedores que exigen anticipo—. De la tensión entre esas dos fuerzas sale la **teoría del trade-off**: existe un nivel de apalancamiento donde el beneficio fiscal marginal iguala el costo esperado de insolvencia. Es la traducción teórica de la sexta causa de muerte del tratado V-05: apalancamiento **más un golpe**.

Por qué el contrato limita al deudor. Porque una vez recibido el dinero, los intereses del accionista y del acreedor divergen. Es el **conflicto de agencia de la deuda** (Jensen y Meckling, 1976), y tiene formas con nombre propio que conviene reconocer al negociar:

CONDUCTA	EN QUÉ CONSISTE	EL COVENANT QUE LA ATAJA
Sustitución de activos (<i>asset substitution</i>)	Tomar más riesgo del prometido: el accionista gana con el escenario alto y el acreedor pierde con el bajo	Limitaciones de inversión, de cambio de giro y de disposición de activos
Dilución de la deuda	Endeudarse más y con mejor prelación, degradando al acreedor original	Limitación de endeudamiento adicional y de gravámenes (<i>negative pledge</i>)
Extracción de valor	Repartir dividendos o pagar a partes relacionadas con dinero que respalda la deuda	Restricción de pagos y de operaciones con relacionadas
Debt overhang (Myers)	Dejar de invertir en proyectos buenos porque el beneficio iría a los acreedores	Es el problema inverso: justifica los <i>cure rights</i> y la flexibilidad de inversión

De ahí la formulación clásica de **Smith y Warner**: los *covenants* no son fricción burocrática, son el mecanismo que **reduce el costo de agencia de la deuda** — y al reducirlo, **abaratan el crédito**. Es decir: el cliente que pelea por eliminar todos los *covenants* está peleando, sin saberlo, por una tasa más alta.

Visto en clave de análisis económico, un covenant es un mecanismo de control contingente: transfiere derechos de decisión al acreedor **precisamente cuando los ratios se deterioran**, que es justo el momento en que el conflicto de agencia se agrava porque la empresa se acerca a la insolvencia. Es gobierno corporativo por contrato. Y el *intercreditor agreement* resuelve por anticipado la "carrera" entre acreedores: un problema de acción colectiva que, sin acuerdo previo, destruye valor para todos.

7. Contexto político y regulatorio

El financiamiento opera dentro de un marco regulatorio **intenso**, porque la banca es una actividad de **interés público** (maneja el ahorro de la gente y es sistémicamente crítica):

- **Regulación bancaria (Ley de Instituciones de Crédito, CNBV, Banxico).** Los bancos están fuertemente regulados: requieren **autorización** para operar, cumplen reglas de **capitalización** (Basilea), **provisiones**, límites de exposición, y supervisión de la **CNBV** (Comisión Nacional Bancaria y de

Valores) y del **Banco de México**. El abogado debe saber qué puede y no puede hacer un banco.

- **Protección al usuario y transparencia (CONDUSEF, leyes de transparencia financiera).** Reglas sobre información, comisiones y trato a los clientes.
- **Prevención de lavado de dinero (PLD/AML) y "conoce a tu cliente" (KYC).** Obligaciones estrictas de identificación del cliente y reporte de operaciones, centrales en cualquier financiamiento.
- **Garantías y su ejecución (LGTOC, leyes de garantías, registros).** El marco que regula cómo se constituyen y, sobre todo, cómo se **ejecutan** las garantías (la efectividad de una garantía depende de poder ejecutarla rápido si el deudor no paga —de ahí figuras como el fideicomiso de garantía—).
- **Mercado de valores (LMV) para los bonos.** La emisión de deuda en el mercado está regulada por la LMV y supervisada por la CNBV (revelación, prospecto, calificación crediticia).
- **Insolvencia (Ley de Concursos Mercantiles).** El "qué pasa si no paga" —la prelación de los acreedores, el tratamiento de las garantías en el concurso— condiciona todo el diseño del financiamiento (conecta con el libro de Concurso Mercantil del Nivel III).

8. Contexto social

El financiamiento tiene una profunda dimensión social, porque el **crédito es el motor del desarrollo** y, a la vez, una fuente de **crisis** cuando se descontrola. El acceso al crédito permite a las empresas crecer, generar empleo e invertir; su ausencia ahoga a las pequeñas y medianas empresas (un problema social persistente en México, donde el crédito a las PyMEs es escaso y caro). El abogado de financiamiento participa, en ese sentido, en la **canalización del capital hacia la economía productiva**.

Pero el crédito mal gestionado produce **crisis sistémicas** con enorme costo social: la crisis mexicana de 1994-95, la crisis financiera global de 2008 (originada en el crédito hipotecario

tóxico), las crisis de deuda soberana. Estas crisis recuerdan que el financiamiento no es un juego puramente privado: cuando los bancos quiebran, **toda la sociedad paga** (rescates con dinero público, recesión, desempleo). De ahí la regulación intensa y la dimensión ética de la actividad.

Hay también una tensión social entre **acreedor y deudor** que el derecho debe equilibrar: proteger al acreedor (para que haya crédito) sin desamparar al deudor (para que una deuda no se convierta en esclavitud o en despojo abusivo). Las reglas sobre **ejecución de garantías**, sobre **intereses usurarios** y sobre la **reestructuración** de deudas en crisis buscan ese equilibrio. El financiamiento "ESG" y el crédito responsable (que considera el impacto ambiental y social de lo que financia) son la frontera actual de esta dimensión.

9. Contexto empresarial

Desde la óptica de la empresa, el financiamiento es una **decisión estratégica de primer orden**: cuánto endeudarse, en qué moneda, a qué plazo, con qué garantías, a qué tasa. Estas decisiones determinan la **estructura de capital** y, con ella, el riesgo y el rendimiento del negocio. El abogado de financiamiento trabaja al lado del **director financiero (CFO)** y de los **asesores financieros** para traducir la estrategia de capital en **contratos**.

Las situaciones empresariales típicas que requieren financiamiento (y abogado):

- **Capital de trabajo y operación**: créditos revolventes y líneas para el día a día.
- **Inversión y expansión (CapEx)**: créditos a plazo para comprar maquinaria, construir plantas, crecer.
- **Adquisiciones (acquisition finance)**: financiar la compra de otra empresa (el componente de deuda del M&A; el LBO del *private equity*).
- **Proyectos de gran escala (project finance)**: infraestructura, energía, donde el financiamiento se estructura sobre el flujo del proyecto.

- **Refinanciamiento y reestructuración:** cambiar deuda cara por barata, extender plazos, o renegociar cuando hay problemas de pago.
- **Acceso al mercado (bonos):** emitir deuda directamente al público inversionista, sin (o además de) banco.

Para el abogado, entender la **lógica del negocio** detrás de cada financiamiento es clave: no es lo mismo documentar una línea de capital de trabajo que estructurar el *acquisition finance* de un LBO o el *project finance* de una planta de energía. Cada uno tiene su **arquitectura de riesgo**, sus garantías típicas y sus *covenants* característicos. El gran abogado de financiamiento **conversa con el negocio** (¿para qué es la deuda?, ¿de dónde saldrá el repago?, ¿qué puede salir mal?) y diseña la estructura de deuda que mejor sirve al objetivo con el riesgo bien asignado —exactamente como el abogado de M&A hace con la estructura de la operación—.

10. Definiciones doctrinales

La doctrina del derecho bancario y financiero define los conceptos centrales así:

- **Crédito / Financiamiento:** operación por la cual una parte (**acreditante/prestamista**) pone a disposición de otra (**acreditado/prestatario**) una suma de dinero, que esta se obliga a **restituir** en un plazo, con **intereses**. La doctrina lo define como un **cambio de bienes presentes por bienes futuros** mediado por la confianza (*credere* = confiar).
- **Apertura de crédito (LGTOC):** el contrato típico mexicano por el cual el acreditante se obliga a poner una **suma a disposición** del acreditado (o a contraer una obligación por su cuenta), pudiendo este **disponer** de ella; puede ser **simple** (una sola disposición) o **revolvente/en cuenta corriente** (puede disponer, pagar y volver a disponer).
- **Derecho bancario:** rama que regula la **organización y actividad de las instituciones de crédito** y sus operaciones (activas —prestar—, pasivas —captar— y de servicios). La doctrina lo sitúa entre el derecho público (regulación, supervisión) y el privado (contratos).

- **Garantía:** todo mecanismo que **refuerza** la probabilidad de cumplimiento de una obligación. La doctrina distingue **garantías reales** (recaen sobre un **bien**: hipoteca, prenda, fideicomiso de garantía) y **garantías personales** (un **tercero** se obliga: aval, fianza, obligación solidaria, *guarantee*).
- **Covenant (cláusula de protección):** obligación de conducta del deudor pactada para **proteger** al acreedor durante la vida del crédito. La doctrina financiera los clasifica en **afirmativos** (obligan a hacer), **negativos** (prohíben hacer) y **financieros** (obligan a mantener ciertos **ratios**).
- **Sindicación:** técnica por la cual **varios prestamistas** (un **sindicato** de bancos) otorgan conjuntamente un crédito a un mismo deudor bajo un **único contrato**, repartándose el monto y el riesgo, coordinados por un **banco agente**.
- **Project finance:** estructura de financiamiento de un **proyecto** específico (típicamente de infraestructura o energía) en la que el repago proviene **principalmente del flujo de efectivo del propio proyecto** y las garantías se constituyen sobre sus activos y contratos, con **recurso limitado o nulo** contra los patrocinadores.
- **Acquisition finance:** financiamiento cuyo destino es **adquirir** una empresa o activos; incluye el *leveraged buyout* (LBO), donde la deuda se repaga, en parte, con el **flujo de la empresa adquirida**.
- **Bono / Obligación:** título de deuda **negociable** que la empresa (o el Estado) emite en el **mercado**, fraccionando un gran financiamiento entre **múltiples inversionistas**, con promesa de pagar intereses (**cupón**) y devolver el principal al vencimiento.

11. Definiciones legales y marco normativo

El financiamiento se asienta en un entramado normativo mexicano amplio:

- **Apertura de crédito y operaciones de crédito (LGTOC).** La **Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito** —que estudiaste en el Nivel III— regula la **apertura de crédito**, el préstamo mercantil, el descuento, el crédito documentario,

y las **garantías** mercantiles, incluida la **prenda** (con y sin transmisión de posesión) y el **fideicomiso de garantía**. Es la base del derecho del crédito en México.

- **Instituciones de crédito (Ley de Instituciones de Crédito - LIC).** Regula la **organización, operación y supervisión** de los bancos: autorización, operaciones permitidas, capitalización, límites, y el papel de la CNBV y de **Banxico**. Define qué es un banco y qué puede hacer.
- **Garantías reales (Código Civil —hipoteca, prenda civil—; LGTOC —prenda mercantil, prenda sin transmisión de posesión—; Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito).** El marco de constitución, registro y **ejecución** de las garantías sobre bienes.
- **Fideicomiso de garantía (LGTOC).** Figura clave del financiamiento moderno mexicano: el deudor **transmite** bienes a un fiduciario en garantía, lo que permite una ejecución **más ágil** que la hipoteca o la prenda tradicionales.
- **Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG).** Sistema de **publicidad** de las garantías sobre bienes muebles, que da certeza sobre la prelación.
- **Mercado de valores y bonos (LMV).** Regula la **emisión** de deuda en el mercado (certificados bursátiles, obligaciones), el prospecto, la calificación y el papel del **representante común** de los tenedores.
- **Banco de México (Ley del Banco de México).** Regula aspectos de las operaciones de crédito (tasas, ciertas reglas) y la política monetaria que afecta el costo del dinero.
- **Concursos Mercantiles (LCM).** Determina qué pasa con la deuda y las garantías si el deudor **cae en insolvencia**: la **prelación** de los acreedores (los garantizados cobran antes), el tratamiento de las garantías y la reestructuración.

Nota de método: verifica el texto y la numeración vigentes de la LGTOC, la LIC, la LMV y la LCM antes de aplicarlas en un caso real (Manifiesto XI.5). Aquí las citamos para que ubiques **dónde vive** cada figura del financiamiento.

12. Definición sencilla

Imagina que **le prestas dinero a un amigo** para que abra una taquería. Si eres prudente, harás varias cosas que son, exactamente, el derecho del financiamiento:

- **El contrato (apertura de crédito):** "Te presto 100 mil, me los devuelves en 2 años con intereses". Pones por escrito cuánto, a qué plazo, a qué tasa.
- **La garantía real (hipoteca/prenda):** "Y para asegurarme, si no me pagas, me quedo con tu **coche**" (prenda) o "con tu **local**" (hipoteca). Si el amigo no paga, **ejecutas** el bien y te cobras.
- **La garantía personal (aval/fianza):** "Además, que tu **papá firme** como aval, por si tú no puedes". Otra persona responde si el deudor falla.
- **Los covenants:** "Mientras me debas, te pongo reglas: **no pidas más préstamos** sin avisarme (negativo), **mándame tus números** cada mes (afirmativo), y **mantén la taquería rentable** —que tus ventas cubran al menos X (financiero)—". Lo vigilas para que no se deteriore.
- **El evento de incumplimiento y la aceleración:** "Si dejas de pagar dos meses, o rompes una regla, **toda la deuda se vuelve exigible de inmediato**" (no esperas los 2 años: aceleras).

Eso es todo el libro en una taquería: **prestar con garantías, reglas y un botón de emergencia**. Cuando en vez de un amigo es una empresa, y en vez de 100 mil son 100 millones, y en vez de un prestamista son 15 bancos (sindicato), la **lógica es idéntica** —solo cambia la sofisticación de los contratos—.

13. Conceptos fundamentales

Fija este vocabulario; es el idioma del financiamiento y dialoga con el del M&A (Libro 4):

El crédito y su contrato:

- **Acreditante/prestamista (*lender*) vs. acreditado/prestario (*borrower*):** quien presta vs. quien recibe.

- **Facility (facilidad de crédito):** la línea o crédito otorgado. Tipos: **a plazo** (*term loan*: se dispone y se amortiza), **revolvente** (*revolving*: se dispone, paga y vuelve a disponer), **punto** (*bridge*: temporal, hasta un financiamiento permanente).
- **Disposición (*drawdown*) y amortización:** cuándo se toma el dinero y cómo se devuelve (en cuotas —*amortizing*— o todo al final —*bullet*—).
- **Tasa de interés y *spread*:** tasa de referencia (TIIE, SOFR) + un **margen** (*spread*) según el riesgo del deudor.
- **Comisiones:** de apertura, de disponibilidad (*commitment fee*), de agencia.

Las protecciones del acreedor:

- **Representations & warranties:** declaraciones del deudor (igual que en el SPA) sobre su situación legal y financiera.
- **Covenants: afirmativos** (entregar información, mantener seguros y licencias, pagar impuestos), **negativos** (no endeudarse más —*negative pledge*—, no vender activos clave, no repartir dividendos, no dar garantías a otros) y **financieros** (mantener ratios: apalancamiento máximo —*Debt/EBITDA*—, cobertura de intereses, capital de trabajo mínimo).
- **Conditions precedent (CP):** condiciones para disponer del crédito (garantías constituidas, opiniones legales, documentos).
- **Events of default (eventos de incumplimiento):** los hechos que permiten al acreedor **acelerar** (no pago, incumplimiento de covenants, **cross-default** —incumplir otra deuda—, insolvencia, *material adverse change*).
- **Aceleración (*acceleration*):** hacer **exigible de inmediato** toda la deuda ante un evento de incumplimiento. El "botón de emergencia" del acreedor.

Las garantías:

- **Reales (sobre un bien): hipoteca** (inmuebles), **prenda** (muebles; con o **sin transmisión de posesión**), **fideicomiso de garantía** (transmisión a un fiduciario; ejecución ágil).

- **Personales (un tercero responde):** **aval** (en títulos de crédito), **fianza**, **obligación solidaria**, **guarantee**/garantía corporativa (la matriz garantiza a la filial).
- **Security package (paquete de garantías):** el **conjunto** de garantías de una operación (hipotecas, prendas sobre acciones e inventarios, fideicomiso, garantías de la matriz).
- **Prelación / *ranking*:** el **orden** en que cobran los acreedores (los garantizados y *senior* antes que los quirografarios y subordinados).

Estructuras avanzadas:

- **Crédito sindicado:** muchos bancos, un contrato; roles de **arranger** (estructura/coloca) y **agent** (administra).
- **Project finance:** financiamiento por el **flujo del proyecto**; **SPV** (vehículo del proyecto), **cascada de pagos** (*cash waterfall*), recurso limitado.
- **Acquisition finance / LBO:** deuda para **adquirir**; **deuda senior** y **subordinada/mezzanine**; **intercreditor agreement** (acuerdo entre acreedores sobre prelación y ejecución).
- **Asistencia financiera:** límites a que la **empresa adquirida** financie o garantice su **propia** compra (regla anti-abuso clave en los LBO).
- **Bono / certificado bursátil:** deuda emitida en el **mercado**; **indenture/acta de emisión**, **trustee/representante común**, **covenants** del bono.

Con este vocabulario, entramos al **desarrollo absoluto**.

14. Desarrollo absoluto

Esta es la sección central. La desarrollamos en cinco bloques: **(A)** el **contrato de crédito** —su anatomía, reps, covenants y eventos de incumplimiento—; **(B)** las **garantías** —reales y personales— y el **paquete de garantías**; **(C)** el **crédito sindicado** —cómo prestan muchos bancos juntos—; **(D)** el **project finance** y el **acquisition finance/LBO** —las dos grandes estructuras—; y **(E)** los **bonos** y el **mercado de deuda**. Estúdialos en orden: primero el contrato base, luego cómo se asegura (garan-

tías), después cómo se reparte (sindicación), las estructuras avanzadas, y al final la deuda de mercado.

14.A · EL CONTRATO DE CRÉDITO (EL *FACILITIES AGREEMENT* POR DENTRO)

El contrato de crédito —en su versión sofisticada, el *facilities agreement*— es al financiamiento lo que el SPA es al M&A: el documento rey. Si dominaste el SPA (Libro 4), reconocerás su arquitectura, porque ambos son **sistemas de asignación de riesgo en el tiempo**. Sus piezas:

1) Las definiciones y la facilidad. Define el **tipo y monto** del crédito y cómo funciona:

- **Term loan (a plazo):** se dispone (una o varias veces) y se **amortiza** según un calendario (en cuotas o *bullet* —todo al vencimiento—). Típico para inversión (CapEx) y adquisiciones.
- **Revolving (revolvente):** una línea de la que el deudor **dispone, paga y vuelve a disponer** hasta un límite. Típico para capital de trabajo.
- **Bridge (puente):** financiamiento **temporal** que se repaga con un financiamiento permanente posterior (p. ej., un *bridge* para cerrar rápido una adquisición, refinanciado luego con bonos).
- **Tramos (tranches):** un mismo contrato puede tener varios (un *term* para la adquisición, un *revolving* para operación).

2) Las disposiciones, intereses y pagos. Cómo se toma y se devuelve el dinero:

- **Disposición (drawdown):** condiciones y mecánica para tomar el crédito.
- **Interés: tasa de referencia** (TIIE en México, SOFR en USD) + **spread** (el margen según el riesgo del deudor; a veces el spread **baja** si mejoran los ratios —*margin ratchet*—).
- **Amortización y prepago:** calendario de pago; reglas de **prepago voluntario** (a veces con penalización —*make-whole*—) y **prepago obligatorio** (con ciertos eventos: venta de activos, exceso de caja, emisión de deuda nueva —*mandatory prepayment*—).

- **Comisiones:** apertura, disponibilidad (*commitment fee* sobre lo no dispuesto), agencia.

3) Las representations & warranties del deudor. Igual que en el SPA: declaraciones sobre su existencia legal, capacidad, que no hay litigios ni incumplimientos ocultos, que su información financiera es veraz, que no está en insolvencia. Su falsedad es un **evento de incumplimiento**.

4) Los covenants (el corazón del control del acreedor). Aquí está la mayor diferencia de énfasis con el SPA: en el crédito, los covenants son **intensísimos** porque el acreedor vigila al deudor durante **toda la vida** del préstamo. Tres familias:

- **Afirmativos (obligaciones de hacer):** entregar **estados financieros** y reportes de cumplimiento periódicos, mantener su existencia, **seguros**, licencias y permisos, pagar impuestos, permitir inspecciones, dar aviso de problemas.
- **Negativos (prohibiciones):** no endeudarse más allá de ciertos límites, **no otorgar garantías** a otros acreedores (*negative pledge*: "no le des a otro una garantía mejor que la mía"), **no vender** activos clave, **no fusionarse ni reestructurarse** sin consentimiento, **no repartir dividendos** por encima de límites, **no cambiar el giro**, no hacer adquisiciones o inversiones grandes.
- **Financieros (*financial covenants*): los más característicos.** Obligan a mantener **ratios** que miden la salud financiera, calculados periódicamente:
- **Apalancamiento (*Leverage: Deuda/EBITDA*):** la deuda no debe exceder X veces la utilidad operativa.
- **Cobertura de intereses (*Interest Coverage: EBITDA/Intereses*):** la utilidad debe cubrir los intereses al menos X veces.
- **Cobertura del servicio de deuda (*DSCR*):** el flujo debe cubrir el servicio total (principal + intereses) —clave en *project finance*—.

- A veces capital de trabajo mínimo, deuda neta máxima, *gearing*, etc.

Los covenants financieros son el **tablero de salud** del deudor: si los rompe (un *breach*), el acreedor tiene una **alerta temprana** y puede actuar **antes** de que el deudor caiga en impago. Son la diferencia entre un acreedor que reacciona a tiempo y uno que se entera cuando ya no hay nada que rescatar.

5) Los events of default (eventos de incumplimiento) y la aceleración. La pieza de cierre: los hechos que permiten al acreedor **acelerar** (declarar exigible **toda** la deuda de inmediato) y **ejecutar garantías**:

- **No pago** (de principal o intereses).
- **Incumplimiento de covenants** (especialmente los financieros).
- **Falsedad de una rep.**
- **Cross-default / cross-acceleration**: si el deudor incumple **otra** deuda, también incumple esta (para que un acreedor no se quede atrás mientras otros aceleran).
- **Insolvencia / concurso** del deudor.
- **Material Adverse Change** (cambio adverso relevante) y **cambio de control** (*change of control*: si el deudor cambia de dueño, el acreedor puede exigir el pago —eco directo del Libro 2—).

6) El boilerplate: ley aplicable, **arbitraje/jurisdicción**, agente, cesión de la participación (los bancos pueden **vender** su parte del crédito en el mercado secundario), notificaciones.

Idea integradora: observa el paralelismo con el SPA y la diferencia de énfasis. El SPA asigna el riesgo del **pasado** de la empresa (reps fuertes, indemnización). El contrato de crédito asigna el riesgo del **futuro** del deudor (covenants intensos, monitoreo continuo, aceleración). El SPA mira hacia atrás; el crédito, hacia adelante. Pero ambos usan la **misma gramática**: reps, covenants, condiciones, eventos de incumplimiento. Dominada una, la otra se aprende rápido —y juntas te dan la visión completa de la operación—.

14.B · LAS GARANTÍAS Y EL PAQUETE DE GARANTÍAS (CÓMO SE ASEGURA EL COBRO)

Si el contrato de crédito es la promesa de pago, las **garantías** son lo que la vuelve **creíble y cobrable**. Una garantía es un mecanismo que le da al acreedor un **camino de cobro** si el deudor no paga. Es, junto con los covenants, la principal herramienta de **mitigación del riesgo de crédito** —y, por tanto, lo que **abarat**a la tasa—. Dominar las garantías y su **ejecución** es esencial para tu perfil (financiamiento empresarial). Conecta directamente con el libro de **Garantías** del Nivel II.

Garantías reales (recaen sobre un BIEN). Le dan al acreedor un **derecho preferente** sobre un bien específico: si el deudor no paga, el acreedor **ejecuta** ese bien y se cobra con su producto, **antes** que otros acreedores. Las principales en México:

- **Hipoteca (sobre inmuebles):** el clásico. El inmueble queda gravado (sin entregarse al acreedor); se constituye ante notario e **inscribe** en el Registro Público de la Propiedad. Ventaja: sólida. Desventaja: su **ejecución judicial** puede ser **lenta**.
- **Prenda (sobre muebles):** sobre bienes muebles, acciones, créditos. Dos modalidades:
- **Prenda con transmisión de posesión:** el bien se **entrega** al acreedor (clásica; poco práctica para bienes productivos —no puedes preñar la maquinaria que necesitas usar—).
- **Prenda sin transmisión de posesión (LGTOC): innovación clave** del derecho mexicano: el deudor **conserva y usa** el bien (maquinaria, inventarios, cuentas por cobrar) pero queda gravado a favor del acreedor, con inscripción en el **RUG** (Registro Único de Garantías Mobiliarias). Permite garantizar con **activos productivos en rotación** (inventario que entra y sale, cuentas que se cobran y renuevan).
- **Prenda sobre acciones:** muy importante en M&A y LBO: se preñan las **acciones** de la empresa adquirida, de modo que si no se paga el crédito, el acreedor **toma el control** de la empresa.

- **Fideicomiso de garantía (LGTOC): la estrella del financiamiento moderno.** El deudor (fideicomitente) **transmite** la propiedad de bienes a un **fiduciario** (un banco/institución), que los mantiene en garantía del acreedor (fideicomisario); si el deudor no paga, el fiduciario **ejecuta** según lo pactado (a menudo una **venta extrajudicial**, mucho más **ágil** que la ejecución judicial de una hipoteca). Es el vehículo preferido para garantizar financiamientos complejos porque combina **solidez** y **rapidez de ejecución**, y permite estructurar **cascadas de pago** (típico en project finance).

Garantías personales (un TERCERO responde con su patrimonio). Añaden el patrimonio de otra persona como respaldo:

- **Aval:** garantía **cambiaria** (en títulos de crédito, como el pagaré que documenta el crédito); el avalista responde igual que el obligado principal.
- **Fianza:** un fiador se obliga a pagar si el deudor no lo hace (puede ser **civil** o de una **afianzadora**); típicamente **subsidiaria** (el acreedor primero va contra el deudor) salvo renuncia a los beneficios de orden y excusión.
- **Obligación solidaria:** un coobligado responde **solidariamente** (el acreedor puede ir directo contra él, sin agotar al deudor). Más fuerte que la fianza.
- **Guarantee / garantía corporativa:** muy común en grupos: la **matriz garantiza** la deuda de la **filial** (*upstream/downstream guarantees*). En financiamientos internacionales, las *guarantees* de las sociedades del grupo son parte central del paquete.

El security package (paquete de garantías): la visión de conjunto. En una operación seria, el acreedor no se conforma con una sola garantía: arma un **paquete** que cubre el crédito desde varios ángulos. Un paquete típico de un financiamiento corporativo o de adquisición puede incluir:

- **Prenda sobre las acciones** de la empresa deudora (y de las filiales clave).

- **Hipoteca o fideicomiso** sobre los **inmuebles** y activos fijos.
- **Prenda sin transmisión de posesión** sobre **inventarios y cuentas por cobrar**.
- **Cesión/fideicomiso de los flujos** (que los ingresos del negocio entren a una cuenta controlada).
- **Garantías corporativas** de la matriz y las filiales (*guarantees* cruzadas). El objetivo: que el acreedor pueda **cobrase de todo lo relevante** y que ningún activo valioso quede fuera de su alcance. El diseño del paquete es **ingeniería jurídica fina** —hay que constituir, **registrar** y poder **ejecutar** cada garantía, en cada jurisdicción donde haya activos—.

La clave que casi nadie entiende al principio: la **garantía vale lo que vale su EJECUCIÓN**. Una garantía hermosa sobre el papel **no sirve de nada** si no puedes ejecutarla rápido y con certeza cuando el deudor no paga. Por eso el abogado de financiamiento piensa siempre **desde el final**: "si esto sale mal, ¿cómo y qué tan rápido me cobro?". Esa pregunta explica por qué el **fideicomiso de garantía** (ejecución extrajudicial ágil) le ganó terreno a la hipoteca (ejecución judicial lenta), y por qué la **prelación** en el concurso (¿cobro antes o después que otros?) condiciona todo el diseño. La garantía es una **opción de cobro**, y su valor está en poder **ejercerla**.

Conexión con el concurso mercantil (Nivel III). El gran examen de una garantía es la **insolvencia** del deudor. En el concurso, los acreedores **con garantía real** (hipotecarios, prendarios, fideicomisarios) tienen **prelación**: cobran del producto de su bien **antes** que los acreedores comunes (quirografarios). Por eso una garantía real bien constituida es **oro** en una crisis, y por eso el *negative pledge* (la prohibición de dar garantías a otros) es tan importante: el acreedor no quiere que aparezcan otros con mejor prelación que él. Todo el diseño de garantías es, en el fondo, una **apuesta sobre quién cobra primero si todo se derrumba**.

14.C · EL CRÉDITO SINDICADO (CÓMO PRESTAN MUCHOS BANCOS JUNTOS)

Cuando una empresa necesita financiamiento **muy grande** (cientos o miles de millones), **ningún banco quiere** —ni regu-

latoriamente puede— prestarlo solo: concentrar tanto riesgo en un solo deudor es imprudente y choca con los límites de exposición de la regulación bancaria. La solución es el **crédito sindicado: varios prestamistas otorgan conjuntamente** el crédito a un mismo deudor, bajo un **único contrato**, repartiéndose el monto y, con él, el riesgo. Es la forma estándar de financiar las grandes operaciones corporativas y de adquisición.

Por qué se syndica (la lógica económica):

- **Diversificación del riesgo:** cada banco presta solo una parte, distribuyendo el riesgo de impago.
- **Límites regulatorios y de capital:** la regulación limita cuánto puede un banco prestar a un solo deudor; el sindicato sorteja ese límite sumando capacidades.
- **Relación y oportunidad:** los bancos participan para mantener la relación con un cliente importante y ganar comisiones, aunque no quieran (o no puedan) tomar todo el riesgo.

Los roles del sindicato (quién hace qué):

- **Mandated Lead Arranger (MLA) / Banco estructurador:** el banco (o bancos) que **estructura** la operación, la negocia con el deudor y **organiza el sindicato** (busca a los demás bancos para que participen). Gana comisiones de estructuración. Es el **arquitecto** del financiamiento.
- **Underwriting (aseguramiento) vs. best efforts:** el arranger puede **comprometerse a prestar todo** (underwriting: asume el riesgo de colocar las participaciones entre otros bancos) o solo **esforzarse** por conseguir los participantes (best efforts). El underwriting da **certeza** al deudor (clave en adquisiciones: el comprador necesita saber que tendrá el dinero para cerrar —el *committed financing*—).
- **Agent (banco agente):** una vez cerrado el crédito, **un** banco actúa como **administrador** del sindicato durante la vida del préstamo: recibe los pagos del deudor y los distribuye, monitorea los covenants, canaliza la comunicación, y **coordina** las decisiones de los bancos. No decide solo: actúa según las instrucciones de la **mayoría** de los prestamistas (*Majority Lenders*).

- **Security Agent / Trustee (agente de garantías):** administra las **garantías** en beneficio de **todos** los prestamistas (a menudo vía un fideicomiso, para que las garantías sirvan al sindicato como un todo).
- **Bancos participantes:** los demás prestamistas, que toman una parte del crédito.

La documentación del sindicato. Aquí entra un estándar global que debes conocer: los **modelos de la LMA** (*Loan Market Association*, dominante en Europa, Medio Oriente y muchos mercados, incluido el uso en México para deuda internacional) y de la **LSTA** (*Loan Syndications and Trading Association*, en EE.UU.). Estos modelos **estandarizan** el *facilities agreement* sindicado, lo que agiliza las operaciones y crea un lenguaje común. El contrato es esencialmente el *facilities agreement* del 14.A, **más** las cláusulas propias del sindicato:

- **Mecánica de agencia:** cómo actúa el agente, su exención de responsabilidad, su reemplazo.
- **Decisiones del sindicato:** qué requiere **mayoría** de prestamistas (*Majority Lenders*, p. ej., 66⅔%) y qué requiere **unanimidad** (decisiones fundamentales: bajar la tasa, extender el plazo, liberar garantías —los *all lender matters*—).
- **Cláusulas de reparto (*pro rata sharing*):** si un banco cobra de más (p. ej., ejecuta una garantía por su cuenta), debe **compartir** con los demás, para que todos estén en igualdad (*pari passu*).
- **Transferencia y cesión (*assignment/transfer*):** los bancos pueden **vender** su participación en el **mercado secundario** de préstamos (a otros bancos o fondos), lo que da liquidez a la deuda.
- **Yank-the-bank / snooze-you-lose:** mecanismos para manejar a bancos que bloquean o no responden.

La dinámica de poder en el sindicato. Una tensión central del crédito sindicado es **mayoría vs. minoría de prestamistas**: la mayoría puede tomar muchas decisiones (modificar covenants, otorgar *waivers*), pero ciertas decisiones fundamentales requieren **unanimidad** para proteger a los bancos

minoritarios (nadie quiere que la mayoría le baje la tasa o libere sus garantías sin su consentimiento). Esta dinámica se vuelve **crítica en una reestructuración**: cuando el deudor tiene problemas y hay que renegociar, alinear a 15 o 20 bancos con intereses distintos es un arte (y a veces un *holdout* —un banco que se niega— puede bloquear todo). El abogado del sindicato debe dominar estas reglas de decisión.

Conexión con el M&A. El crédito sindicado es el **vehículo típico del *acquisition finance*** (14.D): cuando un comprador o un fondo de PE necesita financiar una adquisición grande, no va a un solo banco: arma un **sindicato** que le da el *committed financing* (el compromiso firme de prestar) que necesita para **poder cerrar** la operación. La **carta de compromiso** del financiamiento (*commitment letter*) y su certeza son condición para firmar el SPA: el vendedor quiere saber que el comprador **tendrá el dinero**. Aquí ves cómo el financiamiento (este libro) y la documentación del M&A (Libro 4) se **entrelazan** en una sola operación.

14.D · PROJECT FINANCE Y ACQUISITION FINANCE / LBO (LAS DOS GRANDES ESTRUCTURAS)

Aquí están las **dos estructuras estrella** del financiamiento corporativo avanzado, las que más valor agregan al abogado de operaciones complejas. Ambas comparten una idea revolucionaria: **financiar contra el flujo futuro**, no solo contra activos presentes.

PROJECT FINANCE (financiar un proyecto por su propio flujo). Es la técnica para financiar **grandes proyectos** —una carretera, un aeropuerto, una planta de energía, una mina— donde el repago de la deuda proviene **principalmente del flujo de efectivo que generará el propio proyecto**, y no del balance general de los patrocinadores. Sus rasgos:

- **El SPV (vehículo de propósito específico):** se crea una **sociedad nueva** (*Special Purpose Vehicle*) cuyo **único** objeto es desarrollar y operar el proyecto. La deuda la toma el **SPV**, no los patrocinadores. Esto **aisla** el proyecto (su riesgo no contamina a los patrocinadores, ni viceversa).

- **Recurso limitado o nulo (*non-recourse / limited recourse*):** si el proyecto fracasa, los prestamistas se cobran de los **activos y flujos del proyecto**, pero **no** (o solo limitadamente) pueden ir contra el patrimonio de los patrocinadores. El riesgo se "encierra" en el SPV. Por eso el análisis del prestamista se centra **obsesivamente** en la **viabilidad del proyecto** (¿generará el flujo prometido?).
- **El paquete de contratos del proyecto:** como el repago depende del flujo, los prestamistas exigen que ese flujo esté **asegurado por contratos sólidos**: contratos de construcción (*EPC*), de operación, de suministro de insumos, y —crucial— de **venta del producto** (un *offtake agreement* o *PPA* —contrato de compra de energía— que garantice que alguien comprará lo que el proyecto produzca). Los prestamistas analizan **cada** contrato porque de ellos depende su repago.
- **La cascada de pagos (*cash waterfall*):** todos los ingresos del proyecto entran a **cuentas controladas** (vía fideicomiso) y se distribuyen en un **orden estricto**: primero gastos de operación, luego servicio de la deuda, luego reservas (cuenta de reserva del servicio de deuda —*DSRA*—), y solo al final, lo que sobra, a los patrocinadores (dividendos). Los prestamistas cobran **antes** que los dueños.
- **El paquete de garantías:** prenda sobre las acciones del SPV, fideicomiso sobre los activos y los flujos, cesión de los contratos del proyecto y de los seguros. Todo amarrado para que, si algo falla, los prestamistas puedan **tomar el control del proyecto**.
- **Covenants financieros específicos:** el rey es el **DSCR** (*Debt Service Coverage Ratio*: que el flujo cubra el servicio de la deuda X veces).

El *project finance* es **ingeniería jurídica y financiera pura**: se construye una "mini-economía" (el SPV con sus contratos, cuentas y garantías) diseñada para que la deuda se pague sola con el flujo del proyecto. Es de las prácticas más sofisticadas y demandadas (infraestructura, energía, renovables).

ACQUISITION FINANCE y LBO (financiar la compra de una empresa). Es el financiamiento cuyo destino es **adquirir** una empresa, y su forma extrema es el **Leveraged Buyout (LBO)** —el motor del *private equity* que anticipaste en el Libro 3—. La idea audaz: comprar una empresa **endeudándose**, de modo que la deuda se repague, en buena parte, con el **propio flujo de la empresa adquirida**. Sus piezas:

- **La estructura (recuerda el Libro 3):** el fondo crea una **NewCo**, le aporta **equity** y le consigue **deuda**; la **NewCo compra** la *target*; luego (a menudo) **se fusiona** con ella (fusión apalancada) para que la deuda y el flujo queden en la **misma** sociedad.
- **Los tramos de deuda (la estructura de capital del LBO):**
- **Deuda senior (garantizada):** la de menor riesgo y menor tasa; cobra primero; con el paquete de garantías completo. Suele ser sindicada.
- **Deuda subordinada / mezzanine / high-yield:** mayor riesgo, mayor tasa; cobra **después** de la senior; a veces con componentes de equity (*warrants*). Llena el espacio entre la deuda senior y el equity del fondo.
- **Equity del fondo:** lo que pone el PE; cobra **al final** (pero captura el *upside*).
- **El intercreditor agreement (acuerdo entre acreedores):** pieza **esencial** cuando hay varios niveles de deuda. Regula la **relación entre los acreedores senior y subordinados**: el **orden de cobro** (prelación), quién puede **ejecutar** garantías y cuándo (el subordinado normalmente debe "esperar" —*standstill*—), cómo se reparte lo recuperado, y qué pasa en una reestructuración. Es el contrato que **ordena la jerarquía** de la deuda; dominarlo es marca de sofisticación.
- **El committed financing y el certain funds:** para poder firmar el SPA y comprometerse a comprar, el comprador necesita **certeza** de que tendrá el dinero al cierre. Por eso negocia una **carta de compromiso** (*commitment letter*) de los bancos con condiciones mínimas (*certain funds*): el banco se obliga a fondear salvo por contadísimas excepciones.

Sin esto, el comprador no puede asumir obligaciones firmes frente al vendedor.

El límite jurídico clave: la asistencia financiera (*financial assistance*). Aquí una regla que debes conocer bien: ¿puede la **empresa adquirida** dar garantías o usar sus activos para financiar **su propia compra**? Esto es la "asistencia financiera", y muchos sistemas la **restringen o prohíben** (porque perjudica a los acreedores y minoritarios de la *target*: sus activos respaldan una deuda que no la benefició a ella, sino a quien la compró). En el LBO, esto es un punto **crítico**: el fondo querría usar los activos de la *target* como garantía de la deuda de adquisición, pero hay que estructurarlo **cuidadosamente** para no violar las reglas de asistencia financiera, capitalización y protección de acreedores. La **fusión** posterior (NewCo + *target*) es una de las formas de lograr que el flujo y los activos de la *target* sirvan la deuda **dentro** de la legalidad —pero exige cuidar la oposición de acreedores y las reglas societarias—. El abogado que estructura un LBO debe **dominar esta frontera**.

14.E · LOS BONOS Y EL MERCADO DE DEUDA (FINANCIARSE SIN BANCO)

La última gran vía de financiamiento es ir **directamente al mercado**: emitir **bonos** (en México, típicamente **certificados bursátiles** u **obligaciones**) que se colocan entre **múltiples inversionistas** (fondos, aseguradoras, afores, público). En vez de un banco que presta, **miles de inversionistas** compran fracciones de la deuda. Es la **desintermediación**: la empresa se fondea sin (o además de) la banca.

Cómo funciona una emisión de bonos:

- **El instrumento:** un **bono** es un título de deuda negociable que promete pagar **intereses** (el **cupón**, periódico) y devolver el **principal** al **vencimiento**. Se compra y vende en el mercado (tiene **liquidez**, a diferencia de un crédito bancario).
- **El proceso (mercado de valores - LMV):** la empresa (emisora) prepara un **prospecto** (revelación exhaustiva de su si-

tuación —conecta con el Libro de Mercado de Valores—, obtiene una **calificación crediticia** (de agencias como S&P, Moody's, Fitch, HR Ratings: la nota que mide el riesgo de impago y determina la tasa), y **coloca** los bonos a través de intermediarios (casas de bolsa), bajo la supervisión de la CNBV.

- **El *indenture* / acta de emisión:** el documento que rige el bono. Contiene —otra vez— **covenants** (afirmativos, negativos y, a veces, financieros), **eventos de incumplimiento** y los términos del pago. Los bonos *high-yield* (de empresas más riesgosas) tienen covenants más estrictos, parecidos a los de un crédito.
- **El *trustee* / representante común:** como los tenedores son **muchos y dispersos**, se nombra un **representante común** que actúa **en nombre de todos** los tenedores (vigila el cumplimiento, ejerce acciones, coordina decisiones). Es el equivalente al "agente" del sindicato, pero para bonistas.

Bono vs. crédito bancario (cuándo conviene cada uno):

	CRÉDITO BANCARIO	BONO (MERCADO)
Quién presta	Banco(s)	Múltiples inversionistas
Negociación	Bilateral/sindicato	Términos de mercado, estandarizados
Flexibilidad	Alta (renegociable con el banco)	Baja (difícil renegociar con miles)
Garantías	Frecuentes (paquete)	A veces quirografarios (sin garantía)
Covenants	Intensos, monitoreados	Más ligeros (salvo high-yield)
Liquidez	Baja (aunque hay mercado secundario)	Alta (se negocian en bolsa)
Revelación	Privada	Pública (prospecto, calificación)
Plazo/monto	Flexible	Suele ser mayor plazo y monto

La decisión de estructura de capital de deuda. Una empresa sofisticada combina **ambos**: créditos bancarios (revolventes para operación, flexibles) y bonos (para deuda de largo plazo y gran monto). El abogado, junto con el CFO y los

asesores, ayuda a diseñar el **mix óptimo** según costo, plazo, flexibilidad y apetito del mercado. En las adquisiciones grandes, es común el patrón **bridge-to-bond**: un crédito puente bancario para **cerrar rápido** la compra, **refinanciado** después con una emisión de bonos de largo plazo. Aquí ves, una vez más, cómo todas las piezas del financiamiento —crédito, sindicado, acquisition finance, bonos— se **combinan** en una sola operación. Y cómo el abogado que las domina **todas** puede estructurar el deal **completo**: el equity (Libros 1-4) y la deuda (este libro). Esa es la marca del especialista en operaciones corporativas complejas.

15. Explicación intuitiva

Tres imágenes para fijar el financiamiento corporativo.

La metáfora del préstamo entre amigos con candados. Prestarle a una empresa es como prestarle a un amigo, pero con **candados** que un amigo prudente pondría. El **contrato** dice cuánto y a qué plazo. Las **garantías** son los candados sobre sus cosas ("si no pagas, me quedo con tu coche/local"). Los **covenants** son las reglas mientras te debe ("no te endeudes más, mándame tus números, mantente sano"). Y el **evento de incumplimiento + aceleración** es el botón de emergencia ("si rompes una regla, me debes todo **ya**"). Cuanto mejores los candados y las reglas, **más barato** el préstamo (menos riesgo → menos tasa). Todo el libro es **prestar con candados inteligentes**.

La metáfora de la represa (para el project finance). Un *project finance* es como financiar la construcción de una **represa hidroeléctrica** prometiendo pagar **solo con la electricidad que generará**. El prestamista no mira el bolsillo de los dueños (recurso limitado); mira **el río**: ¿lloverá lo suficiente?, ¿hay quién compre la luz (offtake)?, ¿quién construye bien la represa (EPC)? Y construye un sistema de **tuberías de dinero** (la cascada de pagos): toda el agua —el ingreso— entra a un depósito controlado y se reparte en orden estricto: primero mantener la represa, luego pagar la deuda, y solo lo que sobra, a los dueños. Es financiar **un flujo futuro encerrado en una caja** (el SPV).

La metáfora de la palanca (para el LBO). El LBO es **apalancamiento** —y "palanca" no es casualidad—. Con una palanca, una fuerza pequeña mueve un peso grande. En el LBO, un fondo pone **poco equity** y mucha **deuda** para comprar una empresa cara; si la empresa va bien y la deuda se paga sola con su flujo, el poco equity captura un retorno **enorme** (la palanca amplifica). Pero si la empresa va mal, la deuda **aplasta** (la palanca amplifica también las pérdidas). Por eso el LBO es **poderoso y peligroso**: la misma palanca que multiplica las ganancias puede quebrar a la empresa.

La intuición central: el financiamiento es **confianza con candados, en el tiempo**. El prestamista entrega dinero hoy contra una promesa futura, y todo el derecho del financiamiento existe para **proteger esa recuperación** —garantías (de dónde me cobro), covenants (cómo te vigilo), aceleración (cuándo reacciono)—. Y la lógica avanzada (project, LBO) consiste en aprender a prestar contra el **flujo futuro**, no solo contra bienes presentes. Quien entiende eso entiende cómo se **paga** cualquier operación.

16. Ejemplos simples

Ejemplo 1 — El covenant financiero que avisa a tiempo. Un banco presta a una empresa con un covenant: "Deuda/EBITDA no mayor a 3.0x". Al cierre del trimestre, el ratio sube a 3.4x (la empresa se deterioró). **Se rompió el covenant** → es un **evento de incumplimiento**. El banco no necesariamente acelera, pero tiene una **alerta temprana** y poder para **renegociar** (pedir más garantías, subir la tasa, exigir un plan). El covenant funcionó como **detector de humo**.

Ejemplo 2 — La garantía que se ejecuta. Una empresa no paga un crédito garantizado con un **fideicomiso de garantía** sobre un inmueble. El fiduciario, según lo pactado, **vende el inmueble extrajudicialmente** y paga al acreedor con el producto —rápido, sin un juicio de años—. Si hubiera sido una hipoteca tradicional, el banco habría enfrentado una ejecución judicial **lenta**. La elección de la garantía **importó**.

Ejemplo 3 — El negative pledge. Un banco presta sin garantía pero con un **negative pledge** ("no le darás a otro acreedor una garantía sobre tus activos"). Después, la empresa intenta dar una hipoteca a otro banco. Eso **viola el covenant** → evento de incumplimiento. El negative pledge protege al acreedor quirografario de que otros se le adelanten en la prelación.

Ejemplo 4 — El committed financing para cerrar. Un comprador quiere firmar un SPA, pero el vendedor exige certeza de pago. El comprador obtiene una **carta de compromiso** de un banco (*commitment letter*) que asegura el financiamiento salvo condiciones mínimas. Con ese *committed financing*, puede firmar el SPA con confianza. Financiamiento y M&A se entrelazan.

17. Ejemplos complejos

Ejemplo complejo 1 — El LBO y la asistencia financiera. Un fondo de PE quiere comprar *Manufacturas SA* por 1,000: pone 400 de equity y consigue 600 de deuda. Quiere usar los **activos de Manufacturas** como garantía de los 600. *Problema:* eso es **asistencia financiera** (la target garantizando su propia compra), restringida para proteger a sus acreedores y minoritarios. *Solución estructurada:* crea una **NewCo** que toma la deuda y compra Manufacturas; luego **fusiona** NewCo con Manufacturas (fusión apalancada) para que, ya como una sola sociedad, los activos y el flujo sirvan la deuda —cuidando la **oposición de acreedores** de la fusión (Libro 3), las reglas de capitalización y los límites de asistencia financiera—. Aquí convergen el Libro 3 (estructura), el Libro 5 (deuda) y el límite legal de asistencia financiera.

Ejemplo complejo 2 — La cascada de pagos de un project finance. Una planta solar se financia con *project finance*. Todos sus ingresos (la venta de energía bajo un **PPA** de 20 años) entran a un **fideicomiso** con cuentas en cascada: (1) gastos de operación y mantenimiento; (2) impuestos; (3) **servicio de la deuda** (intereses + principal); (4) fondeo de la **cuenta de reserva del servicio de deuda (DSRA)**; (5) cumplimiento del **DSCR**; y solo si todo lo anterior está cubierto, (6) **dividendos** a

los patrocinadores. Si el DSCR cae bajo cierto nivel, se **bloquean los dividendos** (*cash trap*) hasta recuperarlo. *Lección:* los prestamistas cobran **antes** que los dueños, y el dinero fluye por un orden **jurídicamente blindado**.

Ejemplo complejo 3 — La reestructuración y el intercreditor. Una empresa apalancada entra en crisis y no puede pagar. Tiene **deuda senior** (bancos) y **deuda mezzanine** (un fondo). El **intercreditor agreement** define qué pasa: la mezzanine está **subordinada** (no cobra hasta que la senior esté satisfecha) y sujeta a un **standstill** (no puede ejecutar sus garantías por un periodo, dejando a la senior llevar la batuta de la reestructuración). El fondo mezzanine, aunque quiera actuar, está **contractualmente atado**. *Lección:* en la crisis, el **intercreditor** decide quién manda y quién espera —por eso se negocia tan duro al inicio—.

18. Casos reales (operaciones estilizadas y referentes)

Nota de método (Manifiesto XI.5): casos estilizados con fines didácticos; verifica los detalles antes de citarlos profesionalmente.

Los grandes LBO y el poder (y peligro) del apalancamiento (RJR Nabisco, 1988). El legendario LBO de RJR Nabisco —narrado en *Barbarians at the Gate*— por unos 25 mil millones de dólares marcó la cúspide de la era de los LBO de los años 1980. Mostró el **poder** del apalancamiento para adquirir empresas gigantes con poco equity, y también sus **excesos**. *Lección:* el LBO es una herramienta poderosísima de creación de valor (y de riesgo); el abogado que lo estructura maneja deuda, garantías, intercreditor y los límites de asistencia financiera al máximo nivel.

Las crisis de deuda y la importancia de los covenants y garantías (2008-2009). La crisis financiera global mostró qué pasa cuando el apalancamiento se descontrola y las garantías resultan débiles. Muchos financiamientos con covenants laxos (*covenant-lite*) dejaron a los acreedores **sin alertas tempranas**. *Lección:* los covenants y las garantías **no son formalismos**: son lo que protege al acreedor cuando el ciclo se voltea. La tendencia *covenant-lite* (deuda con pocos covenants, popu-

lar en mercados eufóricos) sigue siendo objeto de debate por el riesgo que traslada al prestamista.

El project finance de la infraestructura mexicana. Grandes proyectos de energía, carreteras y aeropuertos en México se han financiado con estructuras de *project finance* (a menudo combinando crédito bancario y emisión de bonos/certificados bursátiles). *Lección:* el *project finance* es la técnica que **hace posible** la infraestructura de gran escala, y una práctica de altísimo valor para el abogado mexicano —especialmente en energía y renovables—.

Silicon Valley Bank (marzo de 2023): la estructura de capital se activa en 72 horas. Un banco cae por un mecanismo que ningún *covenant* de su cartera de créditos habría detectado: **riesgo de duración**. Su cartera de bonos perdió valor de mercado al subir las tasas, la noticia se difundió, y los depositantes —que pueden retirar a la vista— retiraron. Un *bank run* clásico, en días.

Credit Suisse (2023): cuando la prelación esperada no se respeta. En el rescate por UBS, los tenedores de bonos **AT1** —instrumentos híbridos de capital regulatorio— fueron **borrados por unos 17,000 millones**  **verificar** mientras los accionistas conservaban algo de valor. Eso invirtió el orden que los inversionistas creían pactado, y detonó litigios.

Las dos lecciones para un abogado, y son de oficio puro.

Primera: lee la prelación en el documento, no en la intuición. "Deuda antes que capital" es una regla general, no una ley física: los términos concretos del instrumento y el marco regulatorio de resolución bancaria pueden alterarla. Si tu cliente compra un híbrido, la cláusula de absorción de pérdidas es **la** cláusula, no una del montón.

Segunda: la velocidad es un riesgo jurídico. Estos episodios no dan tiempo para negociar renunciaciones ni reestructuras: se resuelven en un fin de semana. Por eso el trabajo valioso se hace antes —en el *headroom* del *covenant*, en los *cure rights*, en la definición de EBITDA— y no cuando ya empezó. Es el mismo principio del protocolo de crisis: lo que no decidiste en frío, no lo vas a decidir bien a las tres de la mañana.

19. Casos empresariales

La empresa familiar que crece con deuda inteligente. Una empresa familiar rentable quiere construir una segunda planta (CapEx de 200 millones) sin diluir a la familia (sin vender equity). *Solución:* un **crédito a plazo** (term loan) garantizado con **hipoteca** sobre la nueva planta y **prenda sin transmisión de posesión** sobre la maquinaria, con covenants financieros razonables. La familia **crece sin perder control** (la deuda no diluye ni vota). *Lección:* la deuda es la herramienta para crecer **conservando la propiedad** —clave para empresas familiares—.

El CFO que diseña el mix de deuda. Una empresa mediana tiene solo créditos bancarios de corto plazo (caros y con riesgo de refinanciamiento). El CFO, con sus abogados, **reestructura** su deuda: emite un **bono** de largo plazo (certificado bursátil) para fondear la deuda permanente, y deja una **línea revolvente** bancaria solo para capital de trabajo. Resultado: deuda más **barata, larga y estable**. *Lección:* el **mix de deuda** (banco vs. mercado, corto vs. largo) es una decisión estratégica donde el abogado aporta valor.

20. Casos corporativos (la conexión integral)

Integremos el financiamiento con todo el Nivel IV. *Fondo Cumbre* (PE) adquiere *Logística Total*, S.A. por 1,500 millones, financiando 900 con deuda.

- **Libros 1-2 (M&A, Due Diligence):** se mapea la operación y la DD revela el flujo de caja y los activos (que servirán de garantía y de fuente de repago de la deuda).
- **Libro 3 (Estructuras):** se crea una **NewCo** que tomará la deuda y comprará/se fusionará con Logística (estructura del LBO).
- **Libro 4 (Documentación):** se negocia el **SPA** (con su precio, reps, MAC); el cierre se condiciona al **committed financing** (certeza de la deuda).
- **Libro 5 (este):** se estructura el **acquisition finance**: un **crédito sindicado senior** de 700 (con un *security package*:

prenda sobre acciones de la NewCo/target, hipoteca sobre inmuebles, prenda sin transmisión sobre la flota, fideicomiso de flujos) y **deuda mezzanine** de 200 (subordinada, regida por un **intercreditor agreement**). Se cuida la **asistencia financiera** vía la fusión apalancada. Los **covenants financieros** (Deuda/EBITDA, DSCR) vigilan a la empresa adquirida.

- **(Adelanto Libro 7, PE/VC):** el equity del fondo y el SHA con la administración cierran la estructura.

Moraleja: una adquisición real es **equity + deuda**, y el abogado completo orquesta **ambos**. El que solo sabe M&A negocia el SPA pero depende de otro para los 900 de deuda; el que domina **también** el financiamiento estructura la **operación entera** —y se vuelve indispensable—. Esa integración es, exactamente, el perfil de **especialista en operaciones corporativas complejas** que persigues.

21. Casos internacionales

Los estándares globales: LMA y LSTA. La documentación del crédito sindicado internacional se rige por los modelos de la **LMA** (Loan Market Association, dominante en Europa/EMEA y muy usada en deuda internacional de empresas mexicanas) y de la **LSTA** (en EE.UU.). *Lección para tu carrera:* el financiamiento de élite **habla inglés** y usa estos estándares; dominar la terminología y la lógica de un *LMA facilities agreement* es parte del oficio del abogado de *banking & finance* internacional.

Garantías transfronterizas y conflicto de leyes. Cuando un grupo con activos en varios países se financia, el **paquete de garantías** debe constituirse y poder **ejecutarse** en cada jurisdicción (una hipoteca mexicana se rige por ley mexicana; una prenda sobre acciones de una filial extranjera, por la ley de esa filial). El abogado coordina **equipos locales** y cuida que la garantía sea **ejecutable** donde está el activo. La pregunta de siempre: "si esto falla, ¿puedo cobrarme **aquí y allá?**".

La transición de tasas de referencia (LIBOR → SOFR). Un ejemplo de cómo el financiamiento global evoluciona: la tasa

de referencia internacional **LIBOR** fue **reemplazada** por tasas como **SOFR**, lo que obligó a renegociar y adaptar miles de contratos de crédito en todo el mundo. *Lección:* el abogado de financiamiento debe estar al día de la **mecánica de las tasas** y de los cambios regulatorios que afectan los contratos —un detalle técnico que mueve enormes cantidades de dinero—.

El financiamiento sostenible (green/sustainability-linked loans). Tendencia internacional creciente: créditos cuya tasa se ajusta según el cumplimiento de **metas ESG** (ambientales/sociales) del deudor, o destinados a proyectos verdes. *Lección:* el financiamiento incorpora cada vez más la dimensión de **sostenibilidad** —frontera que conecta con el Libro 8 (ESG) y que el abogado moderno debe conocer—.

22. Derecho comparado

El financiamiento es global en su técnica, pero el marco regulatorio y de garantías varía. Tabla comparada esencial:

JURISDICCIÓN / SISTEMA	TRATAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO Y LAS GARANTÍAS
México (Civil Law)	Crédito regido por LGTOC y LIC ; garantías reales (hipoteca, prenda con/sin posesión, fideicomiso de garantía) con registro (RUG); supervisión CNBV/Banxico ; bonos por LMV ; insolvencia por LCM . Documentación internacional usa estándares LMA .
EE.UU. (Common Law)	Garantías mobiliarias unificadas bajo el UCC Article 9 (sistema muy eficiente de <i>security interests</i> y <i>perfection</i> por registro). Mercado de leveraged loans y high-yield bonds enorme; estándar LSTA . <i>Chapter 11</i> (reorganización) muy desarrollado.
Reino Unido (Common Law)	Figuras potentes: fixed and floating charges (la <i>floating charge</i> grava activos cambiantes —inventarios— sin inmovilizarlos), debentures ; estándar LMA ; régimen de <i>financial assistance</i> históricamente estricto (flexibilizado para privadas). Centro global del crédito sindicado.
España (Civil Law)	Hipoteca, prenda (incl. sin desplazamiento), hipoteca mobiliaria; influencia de las directivas UE ; uso de estándares LMA en deuda internacional.
Unión Europea	Armonización bancaria (MREL , unión bancaria, supervisión del BCE), garantías financieras (Directiva de Financiamiento Collateral), y régimen de <i>financial assistance</i> en la directiva de sociedades.
UNIDROIT / soft law	Principios y guías sobre garantías mobiliarias (que inspiraron reformas como el RUG mexicano) y sobre operaciones de crédito internacionales.
Basilea (BCBS)	Estándares internacionales de capital y liquidez bancaria (Basilea III) que condicionan cuánto y cómo prestan los bancos en todo el mundo.
Civil Law vs. Common Law (síntesis)	El common law ofrece garantías muy flexibles (<i>floating charge</i> , UCC Art. 9 ☞) y mercados de deuda profundísimos; el civil law tiende a garantías más tasadas pero ha innovado (fideicomiso de garantía, prenda sin posesión, RUG) para competir. La documentación sindicada (LMA/LSTA) es el lenguaje común global.

Lección comparada: dos figuras del common law que el abogado mexicano debe conocer: la **floating charge** británica (gravar activos en rotación) —cuyo equivalente funcional mexicano es la **prenda sin transmisión de posesión**— y el **UCC Article 9** estadounidense (el sistema de garantías mobiliarias más eficiente del mundo), cuya lógica inspiró el **RUG**. Y

el estándar documental: el M&A "habla inglés" (Libro 4) y el financiamiento también, vía **LMA/LSTA**.

23. Derecho mexicano

El financiamiento en México se asienta en:

- **LGTOC:** apertura de crédito (simple y revolvente), préstamo mercantil, descuento, **prenda** (con y **sin transmisión de posesión**), **fideicomiso de garantía**, y los **títulos de crédito** (pagaré) que suelen documentar la deuda. Es la columna del derecho del crédito.
- **Ley de Instituciones de Crédito (LIC):** organización, operaciones y supervisión de los bancos; autorización, capitalización, límites; papel de **CNBV** y **Banxico**.
- **Garantías reales:** **hipoteca** (CCF, ante notario y registro); **prenda** (LGTOC); **fideicomiso de garantía** (LGTOC, con ejecución extrajudicial ágil); inscripción en el **RUG** (garantías mobiliarias) y en el **RPP** (inmuebles).
- **Garantías personales:** aval (LGTOC), fianza (CCF / Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas), obligación solidaria (CCF).
- **Mercado de deuda (LMV):** emisión de **certificados bursátiles** y obligaciones; prospecto; **representante común** de los tenedores; supervisión de la **CNBV**.
- **Ley del Banco de México:** reglas sobre operaciones de crédito y tasas; política monetaria (costo del dinero).
- **Ley de Concursos Mercantiles (LCM):** **prelación** de los acreedores (los garantizados cobran antes), tratamiento de las garantías y la reestructuración en insolvencia.
- **Prevención de lavado (LFPIORPI):** obligaciones de identificación (KYC) y reporte en operaciones financieras.
- **Usura:** límites y criterios contra los intereses **usurarios** (la SCJN ha desarrollado la facultad de los jueces de reducir intereses notoriamente excesivos).

Nota de método: verifica el texto y la numeración vigentes de la LGTOC, LIC, LMV, LCM y la normativa de la CNBV/Banxico antes de aplicarlos (Manifiesto XI.5).

24. Jurisprudencia relevante

Nota de método: verifica vigencia y datos de identificación antes de citar.

Criterios mexicanos relevantes:

- **Intereses usurarios:** la línea jurisprudencial de la SCJN que faculta a los jueces a **analizar de oficio** y **reducir** los intereses notoriamente excesivos (a partir de la interpretación del art. 21 ⚖.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) —doctrina capital del crédito en México—.
- **Ejecución de garantías:** criterios sobre la ejecución de la **hipoteca**, la **prenda** y el **fideicomiso de garantía** (validez de la ejecución extrajudicial pactada, requisitos).
- **Fideicomiso de garantía:** criterios sobre su validez, su naturaleza y los límites de la ejecución.
- **Prelación de acreedores en el concurso (LCM):** criterios sobre el orden de cobro y el tratamiento de los acreedores con garantía real.
- **Capacidad y representación para contratar crédito:** criterios sobre poderes y facultades para obligar a la sociedad.

En el ámbito internacional, la práctica (más que la jurisprudencia publicada) ha consolidado la interpretación de los contratos **LMA/LSTA** y de los *intercreditor agreements*, estudio obligado para el financiamiento transfronterizo.

25. Criterios de la Suprema Corte / reguladores

- **SCJN:** la doctrina de **usura** (reducción de intereses excesivos) y los criterios sobre **ejecución de garantías** y **fideicomiso de garantía** son los más relevantes para el financiamiento.
- **CNBV:** regulación y supervisión de bancos (capitalización, provisiones, límites) y del mercado de deuda (emisiones, revelación, calificación).
- **Banco de México:** reglas sobre operaciones de crédito, tasas de referencia (TIIE) y su transición, y la política monetaria que fija el costo del dinero.

- **CONDUSEF:** protección al usuario de servicios financieros (más relevante en crédito de consumo que corporativo, pero presente).
- **SHCP / SAT:** tratamiento fiscal de los intereses (deducibilidad, retención) y reglas que afectan la estructura de la deuda (límites a la deducción de intereses —relevante en LBO—).

26. Doctrina nacional

La doctrina mexicana del financiamiento proviene del **derecho bancario y mercantil** (los autores de títulos y operaciones de crédito, derecho bancario y el análisis de la LGTOC y la LIC), del **derecho de garantías** (hipoteca, prenda, fideicomiso —conecta con el libro de Garantías del Nivel II—) y del **derecho del mercado de valores** (para los bonos). A esto se suma el **know-how transaccional** de los despachos de *banking & finance*, que adaptaron los estándares internacionales (LMA, project finance, LBO) al marco mexicano y desarrollaron la práctica del **fideicomiso de garantía** y las estructuras de financiamiento complejas. La doctrina de **concursos mercantiles** aporta la perspectiva del "qué pasa si no se paga".

27. Doctrina internacional

- **Documentación LMA / LSTA y guías de los grandes despachos.** El estándar global del crédito sindicado; material de trabajo del abogado de *banking & finance*.
- **Doctrina de *project finance* (Yescombe, *Principles of Project Finance*).** La obra de referencia sobre la estructura, los contratos y los riesgos del *project finance*.
- **Doctrina de *acquisition finance* y LBO.** Cómo se estructura la deuda de adquisición, los tramos, el *intercreditor* y los límites de asistencia financiera.
- **UCC Article 9 (EE.UU.) y la doctrina de *secured transactions*.** El sistema de garantías mobiliarias más influyente; inspiró reformas globales.
- **Basilea (BCBS) y doctrina de regulación bancaria.** Los estándares de capital y liquidez que rigen a los bancos.

- **Doctrina de finanzas corporativas (estructura de capital — Modigliani-Miller, y sus matizaciones).** La base económica de la decisión deuda/equity (conecta con el Nivel V).

28. Opiniones críticas (postura del Consejo Editorial)

Primero: el financiamiento es la "otra mitad" indispensable del M&A. Sostenemos que la mayor carencia de muchos abogados de M&A es **no entender la deuda**. Quien domina el SPA pero no el *facilities agreement*, el *intercreditor* y las garantías, ve solo la mitad del deal. Para tu perfil, este libro **no es accesorio**: es columna vertebral.

Segundo: una garantía vale lo que vale su ejecución. Insistimos: el error del novato es enamorarse de garantías "bonitas" en el papel sin pensar en **cómo y qué tan rápido** se ejecutan. El auge del **fideicomiso de garantía** sobre la hipoteca es la prueba: la **ejecutabilidad** manda. Piensa siempre **desde el final**.

Tercero: los covenants no son formalismo, son el sistema de alerta. Criticamos la cultura **covenant-lite** de los mercados eufóricos: prestar con pocos covenants traslada el riesgo al acreedor y le quita las **alertas tempranas**. Cuando el ciclo se voltea, los covenants son lo que separa al acreedor que reacciona a tiempo del que se entera cuando ya no hay nada que rescatar.

Cuarto: el apalancamiento es poder y es peligro. El LBO crea enorme valor, pero la misma palanca que multiplica ganancias **quiebra** empresas cuando el flujo no alcanza. El abogado responsable estructura el apalancamiento con realismo (no sobre proyecciones heroicas) y respeta los **límites de asistencia financiera** y de protección de acreedores —que no son trabas, sino salvaguardas del sistema—.

Quinto: dominar los estándares globales (LMA/LSTA) y el inglés del financiamiento. Como en el M&A, el financiamiento de élite es global. El abogado mexicano que aspira a operaciones complejas debe manejar estos estándares con fluidez.

Y la crítica que el Consejo asume, aunque incomode al oficio. El apalancamiento excesivo tiene una propiedad asimé-

trica que 2008 y 2023 volvieron a exhibir: **las ganancias son privadas y una parte de las pérdidas se socializa** —vía rescates, vía contagio, vía el costo que paga el sistema—. La crítica **macroprudencial** posterior a 2008 reprocha que la ingeniería financiera —y la jurídica que la documenta— privilegió el retorno sobre la **resiliencia**.

No es una objeción moral abstracta: tiene consecuencia profesional. El abogado que documenta un financiamiento no es responsable de la política macroprudencial, y sí es responsable de una cosa concreta: **que su cliente entienda cuánta pista le queda**. Un director financiero que firma con el covenant a un mal trimestre de distancia y no lo sabe, no fue bien asesorado —aunque cada cláusula esté impecable.

Postura del Consejo: la métrica de calidad de este trabajo no es cerrar el financiamiento al costo más bajo. Es que **el cliente conozca, en números, la distancia entre su empresa y el precipicio**, y que la haya elegido.

29. Debate doctrinal

- **¿Covenant-lite sí o no?** ¿Conviene la deuda con pocos covenants (más flexible para el deudor) o con covenants estrictos (más protección para el acreedor)? *Postura del Consejo:* depende del poder de negociación y del ciclo; pero advertimos que el *covenant-lite* **traslada riesgo** al acreedor y le quita alertas tempranas —prudencia en los mercados eufóricos—.
- **¿Hasta dónde llega la asistencia financiera prohibida?** ¿Cuándo un LBO cruza la línea de hacer que la *target* financie su propia compra? *Postura del Consejo:* la línea protege a los **acreedores y minoritarios** de la target; la fusión apalancada es legítima si se respetan la oposición de acreedores, la capitalización y el interés social —no es un mero tecnicismo a sortear—.
- **¿Fideicomiso de garantía vs. garantías tradicionales?** ¿Es sano que el fideicomiso (ejecución extrajudicial ágil) desplace a la hipoteca? *Postura del Consejo:* la **agilidad de ejecución** es valiosa (abарata el crédito), pero debe

equilibrarse con la **protección del deudor** frente a ejecuciones abusivas (debido proceso, valuación justa).

- **Intereses: libertad contractual vs. usura.** ¿Deben los jueces poder **reducir** intereses pactados libremente? *Postura del Consejo:* la doctrina de la SCJN sobre usura es un **equilibrio correcto**: la libertad contractual no ampara intereses **notoriamente excesivos** que conviertan el crédito en despojo; pero la intervención judicial debe ser **excepcional** para no ahuyentar el crédito.
- **Banco vs. mercado (crédito vs. bonos): ¿qué es mejor para la empresa?** *Postura del Consejo:* no hay respuesta única —el crédito da **flexibilidad** (renegociable); el bono da **plazo, monto y liquidez** pero es **rígido**—. La empresa sofisticada **combina** ambos según necesidad.
- **¿Covenant-lite o protección robusta?** En los años de tasas bajas y exceso de liquidez, el mercado fue del deudor y los acreedores renunciaron a *covenants* de mantenimiento. Los críticos advirtieron que se estaba destruyendo la **señal temprana de deterioro**. *Postura del Consejo:* el valor de un *covenant* es **procíclico** —parece fricción inútil en el auge y resulta salvador en la caída—, y medir su utilidad en la parte alta del ciclo es un error de método. Y hay una asimetría que el abogado debe explicar: sin *covenants*, el acreedor no se entera antes; se entera **cuando ya no hay nada que negociar**.
- **Dos filosofías de control que conviene no confundir.** El crédito bancario usa ***maintenance covenants***: se prueban **periódicamente** (cada trimestre la empresa debe estar dentro del ratio). El *high yield* usa ***incurrence covenants***: se prueban **solo cuando la empresa quiere hacer algo** (endeudarse más, pagar dividendos). La diferencia es enorme en la práctica: con los primeros, un mal trimestre te pone en incumplimiento sin que hayas hecho nada; con los segundos, puedes deteriorarte sin incumplir mientras no actúes. *Lección de negociación:* cuando el cliente pide "los *covenants* del mercado", hay que preguntar **de qué mercado**.

30. Errores comunes

- **Garantía que no se puede ejecutar rápido.** Constituir una hipoteca de ejecución judicial lenta cuando el fideicomiso de garantía (ejecución ágil) era posible. *Corrección:* piensa **desde la ejecución**; elige la garantía por su ejecutabilidad.
- **No registrar la garantía.** Una prenda sin transmisión de posesión no inscrita en el RUG pierde prelación frente a terceros. *Corrección:* registra siempre; la publicidad da prelación.
- **Covenants laxos (covenant-lite).** Prestar sin covenants financieros adecuados y quedarse sin alertas tempranas. *Corrección:* exige los ratios clave (apalancamiento, cobertura) y reportes periódicos.
- **Ignorar el negative pledge.** No prohibir que el deudor dé garantías a otros y que aparezcan acreedores con mejor prelación. *Corrección:* negative pledge robusto.
- **LBO sin cuidar la asistencia financiera.** Usar los activos de la target para su propia compra violando la ley. *Corrección:* estructura vía NewCo + fusión, respetando oposición de acreedores y capitalización.
- **Olvidar el committed financing.** Firmar un SPA sin certeza de la deuda y no poder cerrar. *Corrección:* asegura *certain funds* (commitment letter) antes de comprometerte.
- **Descuidar el intercreditor.** Tener deuda senior y subordinada sin un acuerdo claro de prelación y ejecución → caos en la crisis. *Corrección:* negocia el *intercreditor* al inicio, no en el incendio.
- **Subestimar la prelación en el concurso.** Diseñar garantías sin pensar en cómo se tratarán en una insolvencia. *Corrección:* analiza la prelación de la LCM desde el diseño.
- **Importar contratos LMA sin anclarlos en derecho mexicano.** Cláusulas inejecutables localmente. *Corrección:* adapta al marco mexicano (garantías, ejecución, usura).

31. Mitos frecuentes

- **"La garantía me asegura el cobro." Falso/matizado.** Solo si puedes **ejecutarla** rápido y tienes buena prelación. Una garantía no ejecutable o mal registrada vale poco.
- **"Más deuda siempre es mejor (apalancarse para crecer)." Falso.** El apalancamiento amplifica ganancias y **pérdidas**; demasiada deuda lleva a la insolvencia. El nivel óptimo es un equilibrio.
- **"Los covenants son trámite." Falso.** Son el **sistema de alerta** del acreedor; sin ellos, se entera del problema demasiado tarde.
- **"El project finance no tiene riesgo porque es non-recourse." Falso.** El riesgo se concentra en el **proyecto** (¿generará el flujo?); por eso el análisis de viabilidad y de los contratos del proyecto es obsesivo.
- **"En el LBO, la empresa adquirida puede garantizar libremente su compra." Falso.** Hay **límites de asistencia financiera** que proteger; debe estructurarse con cuidado.
- **"Un bono es igual que un crédito, solo que en el mercado." Falso.** El bono es **rígido** (difícil renegociar con miles de tenedores), líquido y público; el crédito es flexible y privado. Sirven a necesidades distintas.
- **"El derecho bancario es solo regulación aburrida." Falso.** Es la base de las operaciones más grandes y mejor pagadas; estructurar deuda es ingeniería de alto nivel.

32. Preguntas difíciles

1. **¿Por qué un covenant financiero protege al acreedor antes del impago?** Porque mide la **salud** del deudor (ratios) periódicamente; si se deteriora y rompe el covenant, el acreedor tiene una **alerta temprana** y poder para actuar (renegociar, pedir garantías, acelerar) **antes** de que el deudor deje de pagar. Es prevención, no reacción.
2. **¿Por qué el fideicomiso de garantía le ganó terreno a la hipoteca?** Por la **ejecución**: el fideicomiso permite una venta **extrajudicial** ágil del bien según lo pactado, mientras la

hipoteca suele requerir una ejecución **judicial** lenta. La garantía vale lo que vale su ejecución.

3. **¿Cómo se financia un LBO sin violar la asistencia financiera?** Vía una **NewCo** que toma la deuda y compra la target, seguida de una **fusión** (apalancada) que junta deuda y flujo en una sola sociedad, **respetando** la oposición de acreedores, la capitalización y el interés social. La estructura (Libro 3) resuelve el límite legal.
4. **¿Qué hace el intercreditor agreement y por qué es tan importante?** Ordena la relación entre acreedores **senior** y **subordinados**: prelación de cobro, quién ejecuta y cuándo (*standstill* del subordinado), reparto de lo recuperado. En la crisis, **decide quién manda**; por eso se negocia duro al inicio.
5. **¿Por qué el committed financing es condición para firmar el SPA?** Porque el comprador no puede comprometerse firmemente a comprar si no tiene **certeza** de que tendrá el dinero al cierre. La *commitment letter* con *certain funds* le da esa certeza, que el vendedor exige. Financiamiento y M&A se entrelazan.

33. Casos de examen (con respuesta modelo)

Caso A. *Un banco va a prestar 300 millones a una empresa industrial para una nueva planta. ¿Qué paquete de garantías y covenants recomiendas?* **Respuesta modelo:** **Garantías:** **hipoteca o fideicomiso de garantía** sobre la planta y el terreno; **prenda sin transmisión de posesión** sobre la maquinaria, inventarios y cuentas por cobrar (inscritas en el RUG); **prenda sobre acciones** de la empresa; eventualmente **garantía corporativa** de la matriz. **Covenants:** afirmativos (estados financieros, seguros, permisos), negativos (negative pledge, límites a endeudamiento adicional, no vender activos clave, no dividendos por encima de límites) y **financieros** (Deuda/EBITDA máximo, cobertura de intereses, DSCR). **Eventos de incumplimiento** con cross-default y aceleración. Razonar: cubrir el cobro desde varios ángulos + vigilar la salud + alerta temprana.

Caso B. *Un fondo de PE quiere comprar una empresa por 2,000 millones, con 1,200 de deuda, y usar los activos de la empresa como garantía. ¿Qué problema hay y cómo lo resuelves?*

Respuesta modelo: El problema es la **asistencia financiera** (la target garantizando su propia compra), restringida para proteger a sus acreedores/minoritarios. **Solución:** estructura el LBO vía **NewCo** (toma la deuda, compra la target) + **fusión apalancada** posterior, cuidando la **oposición de acreedores** (Libro 3), la capitalización y el interés social. Estructurar la deuda en **tramos** (senior + mezzanine) con un **intercreditor agreement**, y asegurar **committed financing** para poder firmar el SPA.

Caso C. *Una empresa quiere financiar una planta de energía renovable de 500 millones sin endeudar a sus accionistas. ¿Qué estructura propones?* **Respuesta modelo:** **Project finance:** crear un **SPV** que tome la deuda (recurso limitado a los patrocinadores); asegurar el flujo con un **PPA** (contrato de venta de energía) y contratos **EPC** y de operación sólidos; constituir un **fideicomiso** con **cascada de pagos** (operación → servicio de deuda → reserva DSRA → dividendos) y un paquete de garantías sobre el proyecto; covenants de **DSCR**. Razonar: el repago viene del **flujo del proyecto**, encerrado en el SPV.

34. Simulador (ejercicio tipo despacho)

Instrucciones: eres asociado de *banking & finance*. Representas a un **sindicato de bancos** que financiará la adquisición de *Alimentos del Bajío, S.A.* por un fondo de PE (deuda de 800 millones). Diseña la operación antes de leer la guía.

1. ¿Qué **estructura de deuda** propones (tramos)?
2. ¿Qué **paquete de garantías** exiges?
3. ¿Qué **covenants financieros** pones?
4. ¿Cómo manejas la **asistencia financiera**?
5. ¿Qué documentos y roles del **sindicato** se necesitan?

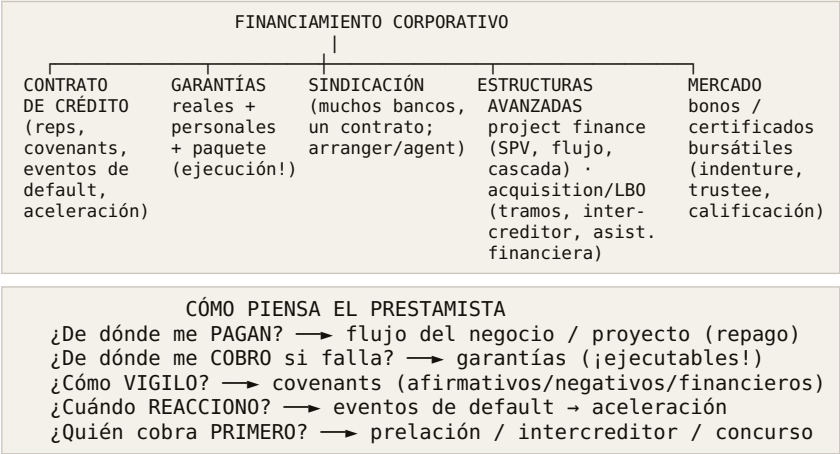
Guía de solución (resumen). (1) Deuda **senior** sindicada (la mayor parte) + posible **mezzanine** subordinada, con **intercreditor agreement**. (2) Prenda sobre **acciones** de la NewCo/tar-get, **hipoteca/fideicomiso** sobre inmuebles, **prenda sin transmisión** sobre maquinaria/ inventarios/cuentas por cobrar, **fideicomiso de flujos** (cuentas controladas), **garantees** de las filiales. (3) Deuda/EBITDA máximo (decreciente en el tiempo), cobertura de intereses, DSCR, límite de CapEx; con *cash sweep* (prepago obligatorio con exceso de caja). (4) Estructura **NewCo + fusión apalancada**, cuidando oposición de acreedores, capitalización e interés social. (5) *Commitment letter* con *certain funds*; *facilities agreement* estándar **LMA**; roles de **MLA/arranger, agent** y **security agent**; *intercreditor agreement*; opiniones legales como CP.

35. Flashcards

- **¿Qué es una apertura de crédito?** Contrato por el que el acreditante pone una suma a disposición del acreditado, que dispone y restituye con intereses (simple o revolvente).
- **¿Tres tipos de covenants?** Afirmativos (hacer), negativos (no hacer), financieros (mantener ratios).
- **¿Ejemplos de covenant financiero?** Deuda/EBITDA, cobertura de intereses, DSCR.
- **¿Qué es la aceleración?** Hacer exigible toda la deuda de inmediato ante un evento de incumplimiento.
- **¿Cross-default?** Incumplir otra deuda dispara el incumplimiento de esta.
- **¿Garantías reales vs. personales?** Sobre un bien (hipoteca, prenda, fideicomiso) vs. un tercero responde (aval, fianza, obligación solidaria, guarantee).
- **¿Prenda sin transmisión de posesión?** El deudor conserva y usa el bien (maquinaria, inventarios), pero queda gravado (inscrito en el RUG).
- **¿Fideicomiso de garantía?** Transmisión de bienes a un fiduciario en garantía, con ejecución extrajudicial ágil.
- **¿Qué es la sindicación?** Varios bancos prestan juntos bajo un contrato; roles de arranger y agent.

- **¿Project finance?** Financiar un proyecto por su propio flujo, vía un SPV, con recurso limitado y cascada de pagos.
- **¿LBO?** Comprar una empresa con mucha deuda, repagada con el flujo de la adquirida.
- **¿Intercreditor agreement?** Acuerdo que ordena prelación y ejecución entre acreedores senior y subordinados.
- **¿Asistencia financiera?** Límite a que la target financie/garantice su propia compra.
- **¿Bono vs. crédito?** Deuda de mercado (rígida, líquida, pública) vs. deuda bancaria (flexible, privada).

36. Mapas mentales



37. Cuadros comparativos

Garantías reales

	HIPOTECA	PRENDA SIN POSESIÓN	FIDEICOMISO DE GARANTÍA
Objeto	Inmuebles	Muebles (maquinaria, inventarios)	Bienes transmitidos al fiduciario
Pose-sión	Deudor conserva	Deudor conserva y usa	Fiduciario (titular)
Regis-tro	RPP	RUG	Según bienes
Ejecu-ción	Judicial (lenta)	Judicial/pactada	Extrajudicial ágil

Crédito bancario vs. Bono

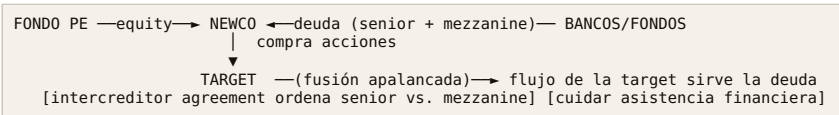
	CRÉDITO	BONO
Prestamista	Banco(s)	Inversionistas múltiples
Flexibilidad	Alta	Baja
Liquidez	Baja	Alta
Covenants	Intensos	Más ligeros (salvo high-yield)
Revelación	Privada	Pública (prospecto)

Tramos de deuda en un LBO

TRAMO	RIESGO	TASA	COBRA
Senior (garantizada)	Bajo	Baja	Primero
Mezzanine/subordinada	Medio-alto	Alta	Después
Equity (fondo)	Alto	—	Al final (capta upside)

38. Diagramas

Estructura de un LBO (acquisition finance):



Cascada de pagos del project finance:

INGRESOS DEL PROYECTO (a cuenta controlada / fideicomiso)
1) Gastos de operación y mantenimiento
2) Impuestos
3) Servicio de la deuda (intereses + principal)
4) Cuenta de reserva del servicio de deuda (DSRA)
5) Cumplimiento del DSCR (si no se cumple → cash trap)
6) Dividendos a los patrocinadores (lo que sobra)

39. Mnemotecnias

- **Cómo piensa el prestamista (PCVR):** ¿De dónde me Pagan?
· ¿De dónde me Cobro (garantías)? · ¿Cómo Vigilo (covenants)? · ¿Cuándo Reacciono (aceleración)?
- **Tres covenants:** "hacer (afirmativos), no hacer (negativos), mantenerse sano (financieros)".
- **Garantía:** "vale lo que vale su ejecución".
- **Fideicomiso de garantía:** "transmito para ejecutar rápido".

- **Project finance:** *"presto al proyecto, no al dueño; me pago del flujo, no del bolsillo"*.
- **LBO / palanca:** *"poco equity, mucha deuda: amplifica ganancias... y pérdidas"*.
- **Asistencia financiera:** *"la comprada no paga su propia compra (sin estructurar bien)"*.
- **Intercreditor:** *"senior manda, subordinado espera (standstill)"*.
- **Regla de oro:** *"el financiamiento es confianza con candados, en el tiempo"*.

40. Resumen ejecutivo

El **financiamiento corporativo** estudia cómo una empresa obtiene **capital de deuda** y cómo se estructura, documenta y garantiza. Su idea rectora: **la deuda es confianza garantizada en el tiempo** —el prestamista entrega dinero hoy contra una promesa futura, y todo el derecho del financiamiento existe para **proteger esa recuperación**—. El **contrato de crédito** (*facilities agreement*) es el documento rey y, como el SPA, un sistema de asignación de riesgo: define la facilidad (a plazo, revolvente, puente), los intereses (tasa + *spread*), las **reps**, los **covenants** (afirmativos, negativos y, sobre todo, **financieros** —Deuda/EBITDA, cobertura, DSCR—) y los **eventos de incumplimiento** con la **aceleración**. Las **garantías** —reales (hipoteca, prenda con/sin posesión, **fideicomiso de garantía**) y personales (aval, fianza, obligación solidaria, *guarantee*)— dan el camino de cobro, y la lección capital es que **una garantía vale lo que vale su ejecución** (de ahí el auge del fideicomiso de garantía). El **crédito sindicado** reparte grandes financiamientos entre muchos bancos (roles de *arranger* y *agent*, documentación **LMA/LSTA**). Y las dos estructuras estrella: el **project finance** (financiar un proyecto por su propio **flujo**, vía un **SPV** con recurso limitado y **cascada de pagos**) y el **acquisition finance/LBO** (financiar una adquisición con tramos de deuda **senior** y **subordinada**, un **intercreditor agreement**, y el cuidado de la **asistencia financiera**). Por último, los **bonos** permiten financiarse en el **mercado**, sin banco.

La gran lección para tu perfil: el financiamiento es la **otra mitad** de casi todo deal grande. El que domina el M&A (Libros 1-4) y la deuda (este libro) puede estructurar la **operación completa** —el *equity* y la deuda—, dialogar de igual a igual con bancos y fondos, y **liderar** la transacción entera. Esa integración es, exactamente, la marca del **especialista en operaciones corporativas complejas y financiamiento empresarial** que quieres ser. Y observa el hilo: los contratos de financiamiento usan la **misma gramática** del SPA (reps, covenants, condiciones, eventos de incumplimiento), aplicada al riesgo **futuro** del deudor; dominada una, la otra se aprende rápido.

41. Checklist

Estructura del financiamiento:

- [] ¿De dónde vendrá el **repago** (flujo del negocio, del proyecto, de la empresa adquirida)?
- [] ¿Qué **tipo y tramos** de deuda (term, revolving, puente; senior, mezzanine)?
- [] ¿Crédito **bilateral, sindicado o bono** (o una combinación, bridge-to-bond)?

Protección del acreedor:

- [] ¿**Reps** del deudor adecuadas? ¿**Covenants** afirmativos, negativos (negative pledge) y **financieros** (ratios) bien calibrados?
- [] ¿**Eventos de incumplimiento** completos (no pago, breach, cross-default, insolvencia, MAC, change of control) con **aceleración**?
- [] ¿**Paquete de garantías** que cubra lo relevante (acciones, inmuebles, muebles, flujos, guarantees)? ¿Están **registradas** (RUG/RPP)?
- [] ¿Las garantías son **ejecutables** rápido (fideicomiso vs. hipoteca)? ¿Buena **prelación** en un concurso?

Estructuras avanzadas:

- [] **Project finance**: ¿SPV, contratos del proyecto (EPC, offtake/PPA), cascada de pagos, DSCR, recurso limitado?

- [] **LBO**: ¿tramos + **intercreditor agreement**? ¿**Asistencia financiera** resuelta (NewCo + fusión)? ¿**Committed financing** (*certain funds*) para firmar el SPA?
- [] ¿Documentación **LMA/LSTA anclada** en derecho mexicano (garantías, ejecución, usura)?

42. Bibliografía comentada

- **Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC)**. **Imprescindible**: apertura de crédito, prenda (con y sin posesión), fideicomiso de garantía. La base del derecho del crédito mexicano.
- **Ley de Instituciones de Crédito (LIC) y normativa de la CNBV/Banxico**. El marco de la banca y sus operaciones.
- **Yescombe, *Principles of Project Finance***. La obra de referencia mundial sobre la estructura, los contratos y los riesgos del *project finance*.
- **Documentación LMA / LSTA y guías de *banking & finance* de los grandes despachos**. El estándar global del crédito sindicado y del *acquisition finance*; material de trabajo diario.
- **Ley del Mercado de Valores (bonos/certificados bursátiles)**. El marco de la deuda de mercado.
- **Ley de Concursos Mercantiles (LCM)**. La prelación de acreedores y el tratamiento de las garantías en la insolvencia: el "qué pasa si no se paga".
- **Doctrina de la SCJN sobre usura**. La facultad judicial de reducir intereses excesivos: doctrina capital del crédito en México.
- **Doctrina de finanzas corporativas (estructura de capital)**. La base económica de la decisión deuda/equity (conecta con el Nivel V).
- **Philip Wood, *Law and Practice of International Finance***. La referencia de nivel intermedio-avanzado sobre financiamiento internacional: si vas a documentar crédito sindicado o transfronterizo, es la obra a la que se vuelve.

- **Smith & Warner, *On Financial Contracting* (*Journal of Financial Economics*, 1979).** El artículo que explicó los *covenants* como solución al costo de agencia de la deuda. Es la fuente teórica del §6 y se lee en una tarde.
- **Modigliani & Miller (*American Economic Review*, 1958, y su corrección de 1963); Jensen & Meckling (1976); Myers sobre *debt overhang*.** Los cuatro trabajos que fundamentan por qué existe la deuda y por qué el contrato limita al deudor.
- **Guías LMA y LSTA (resúmenes) y materiales sobre *high yield e indenture*.** Para el nivel básico y para reconocer las dos gramáticas documentales del §29.

43. Ruta hacia el siguiente libro

Ya dominas **cómo se paga** una operación: la deuda, las garantías, el crédito sindicado, el project y el acquisition finance, y los bonos. Tienes ahora las **dos mitades** del deal: el *equity* (Libros 1-4) y la deuda (este libro). El siguiente paso —según la ampliación para tu perfil— es la otra gran familia de contratos: los **acuerdos estratégicos** que no son ni una compraventa ni un financiamiento, sino **alianzas** para crear valor juntos.

- **Siguiente libro: Libro 6 · Contratos Estratégicos y Joint Ventures** — las **joint ventures** (sociedades conjuntas y JV contractuales), las alianzas estratégicas, los acuerdos de **suministro y distribución** de largo plazo, los acuerdos marco, los MOU, y los **contratos estratégicos** que estructuran la colaboración entre empresas. Es la familia contractual que completa tu perfil (operaciones complejas + contratos estratégicos).
- **Conexión inmediata:** las **joint ventures** combinan lo que ya sabes —una estructura societaria (Libro 3), un acuerdo de socios tipo SHA (Libro 4) y, a menudo, financiamiento (este libro)— al servicio de una **colaboración**. Y muchos contratos estratégicos (suministro, distribución) son los **contratos materiales** que revisaste en la due diligence (Libro 2) y que sostienen el valor de las empresas.

♦ ¿Por qué esto importa para un abogado corporativo?

Porque casi **ningún deal grande se paga solo con caja**: detrás de cada adquisición, expansión o proyecto hay **deuda**, y estructurarla es una de las prácticas más técnicas, demandadas y mejor pagadas del derecho corporativo. Para tu perfil —financiamiento empresarial y operaciones complejas— este libro es **columna vertebral**: el abogado que domina el M&A pero no la deuda ve **la mitad** del deal y depende de otro para fondear la operación; el que domina **ambos** —equity y deuda— estructura la transacción **completa**, dialoga de igual a igual con bancos y fondos, y **lidera**. Además, el financiamiento es **anti-cíclico**: cuando el M&A se enfría, florece la **reestructuración** de deuda, de modo que esta competencia te da trabajo en todos los climas. Y desarrolla una habilidad mental valiosísima —**pensar como el que pone el dinero**: ¿de dónde me pagan?, ¿de dónde me cobro si falla?, ¿cómo vigilo?, ¿cuándo reacciono?— que te hace un negociador y un estructurador mucho más completo.

◆ Cómo piensa un socio de un despacho internacional

"Cuando estructuro un financiamiento, pienso como el que va a recuperar el dinero, no como el que lo presta sin más. Me hago cuatro preguntas en orden. Primero: ¿de dónde sale el repago? — el flujo del negocio, del proyecto, de la empresa adquirida—; si esa fuente no es sólida, ninguna garantía me salva. Segundo: ¿de dónde me cobro si falla? —y aquí mi obsesión no es tener garantías 'bonitas', sino garantías que pueda ejecutar rápido y con certeza; por eso prefiero un fideicomiso de garantía a una hipoteca de ejecución eterna, y por eso reviso la prelación en un concurso desde el día uno—. Tercero: ¿cómo vigilo al deudor? —covenants financieros que me den alertas tempranas antes de que deje de pagar; el covenant-lite de los mercados eufóricos me parece un regalo peligroso al deudor—. Cuarto: ¿cuándo y cómo reacciono? —eventos de incumplimiento claros, cross-default, y un botón de aceleración que funcione—. Y en un LBO, mi cuidado extra es la asistencia financiera y el intercreditor: que la estructura sea legal y que, si todo se incendia, esté clarísimo quién manda y quién espera. El abogado que entiende esto no solo documenta deuda: diseña cómo se recupera el capital, que es lo que de verdad importa."

◆ Errores que cuestan millones

1. **Garantía inejecutable o mal registrada.** Una hipoteca de ejecución lentísima o una prenda no inscrita en el RUG dejan al acreedor sin cobro real o sin prelación. *Prevención:* elegir garantías por su **ejecutabilidad** y **registrarlas** siempre.
2. **Covenant-lite (sin alertas).** Prestar sin covenants financieros y enterarse del deterioro cuando ya no hay nada que rescatar. *Prevención:* ratios clave + reportes periódicos.
3. **LBO que viola la asistencia financiera.** Usar los activos de la target para su propia compra sin estructurar, exponiendo la operación a nulidad y responsabilidad. *Prevención:* New-Co + fusión apalancada, respetando oposición de acreedores y capitalización.
4. **Firmar el SPA sin committed financing.** Comprometerse a comprar sin certeza de la deuda y no poder cerrar

(incumpliendo frente al vendedor). *Prevención: certain funds* (commitment letter) antes de obligarse.

5. **Ignorar el intercreditor.** Tener deuda senior y subordinada sin reglas claras de prelación y ejecución, y desatar el caos en la crisis. *Prevención: negociar el intercreditor agreement al inicio, no en el incendio.*

Cierre del Libro 5. Has aprendido **cómo se financia** una empresa y una operación: el contrato de crédito y sus covenants, las garantías y la obsesión por su ejecución, el crédito sindicado, el project finance, el acquisition finance/LBO con su intercreditor y sus límites, y los bonos. Con esto tienes ya las **dos mitades** del deal —el *equity* (Libros 1-4) y la **deuda** (este libro)— y puedes pensar como el que pone el dinero, no solo como el que estructura la compra. Eres, en formación, un abogado capaz de orquestar la **operación completa**. Ahora cerramos la familia contractual de tu perfil: en el **Libro 6 · Contratos Estratégicos y Joint Ventures** aprenderás a estructurar la **colaboración** entre empresas —las alianzas que crean valor sin comprar ni prestar, sino **uniendo fuerzas**—.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE IV

[Nivel IV · Libro 6] Contratos Estratégicos y Joint Ventures

☞ **Apóstrofe de vigencia — léela cada vez.** El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

No todo se resuelve comprando (M&A) o prestando (financiamiento). A veces, la mejor jugada no es **adquirir** a otra empresa ni **financiarla**, sino **aliarse** con ella: unir fuerzas para entrar a un mercado, desarrollar un proyecto, compartir tecnología o asegurar un suministro crítico. Este libro estudia la **tercera gran familia** de operaciones corporativas: los **contratos estratégicos** y las **joint ventures (JV)** —las estructuras de **colaboración** entre empresas que crean valor sin que una compre a la otra—. Es una práctica de altísima sofisticación: una JV combina, en un solo proyecto, una estructura societaria (Libro 3), un convenio de socios tipo SHA (Libro 4) y, a menudo, financiamiento (Libro 5), todo al servicio de una alianza. Este libro fue añadido a la biblioteca específicamente para completar tu perfil.

Etiquetas: corporate law · contratos estratégicos · joint ventures · alianzas · suministro · distribución · colaboración empresarial **Prerrequisitos:** Libro 3 · Estructuras, Libro 4 · Documentación y Libro 5 · Financiamiento + Contratos Parte General, Contratos Civiles en Particular, Contratos Mercantiles y Sociedades (LGSM). **Estándar:** V3 (43 secciones + secciones transversales). ⌚ **Tiempo estimado de dominio:** 4–5 semanas (≈ 45–55 h de estudio activo). Lectura de reconocimiento: 8–10 h. *Estúdialo en bloques: la lógica de la colaboración → joint ventures (societaria y contractual) → el contrato de JV (gobierno,*

aportaciones, salida) → contratos de distribución y suministro estratégicos → alianzas, MOU y acuerdos marco.

Aviso de método. Tratado, no repaso. Aprenderás a **estructurar la colaboración** entre empresas: cuándo conviene una JV societaria o contractual, cómo se diseña su gobierno y sus salidas (los conflictos más difíciles del derecho corporativo), y cómo se redactan los contratos estratégicos de largo plazo. Se conecta con todo el Nivel IV: la JV es M&A, estructura, SHA y financiamiento **combinados**.

NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL (VISTA RÁPIDA)

Litigio	★★★★☆
Corporate	★★★★★
M&A	★★★★☆
Mercado de Valores	★★☆☆☆
Venture Capital	★★★☆☆
Private Equity	★★★★☆
Gobierno Corporativo	★★★★★
Compliance	★★★★☆
Derecho Bancario	★★★☆☆
Empresa Familiar	★★★★☆

Para tu perfil (contratos estratégicos + operaciones complejas), es esencial: las JV y las alianzas son de las operaciones más difíciles de estructurar (gobierno compartido, conflictos, salidas) y de las que más valor agrega un abogado experto. Transversal a M&A, energía, infraestructura, tecnología e internacionalización.

1. Introducción

Una empresa que quiere crecer o lograr un objetivo estratégico tiene, en esencia, **tres caminos: comprar** (M&A: adquirir a otra empresa o sus activos —Libros 1-4—), **construir** sola (crecimiento orgánico, a veces con financiamiento —Libro 5—), o **colaborar** (aliarse con otra empresa para hacer juntos lo que ninguna haría sola). Este libro estudia el **tercer camino**: las estructuras jurídicas de la **colaboración empresarial**, que van desde un simple contrato de distribución de largo plazo hasta una **joint venture** compleja en la que dos gigantes crean una empresa conjunta para un proyecto de miles de millones.

La **joint venture (JV)** —"empresa conjunta" o "coinvertición"— es la figura central: dos o más empresas (los **socios** o **venturers**) **unen recursos** (capital, tecnología, mercados, know-how) para un **propósito común**, compartiendo el control, las utilidades y los riesgos. Puede tomar forma **societaria** (crean una sociedad nueva —*JV co*— de la que son socios) o **puramente contractual** (se obligan por contrato a colaborar, sin crear una sociedad). Junto a la JV, este libro abarca los demás **contratos estratégicos**: las **alianzas** estratégicas, los acuerdos de **distribución** y **suministro** de largo plazo, los acuerdos de **licencia** y transferencia de tecnología, los **acuerdos marco**, y los instrumentos preliminares (**MOU**, cartas de intención).

La idea rectora del libro: **colaborar es más difícil de estructurar que comprar**. En una adquisición, uno manda (el comprador toma el control) y la relación termina (el vendedor se va). En una colaboración, **nadie manda del todo** —el control es **compartido**—, la relación es de **largo plazo**, y los intereses de los socios, aunque alineados en el objetivo común, **divergen** en mil detalles (quién pone qué, quién decide, cómo se reparten las ganancias, qué pasa si uno quiere salir o si no se ponen de acuerdo). Por eso la JV es uno de los **retos más exigentes** del derecho corporativo: hay que diseñar un **matrimonio empresarial** que funcione cuando las cosas van bien y, sobre todo, que se pueda **disolver civilizadamente** cuando van mal. Aquí convergen todo lo que aprendiste: estructura (Libro 3), gobierno y salidas tipo SHA (Libro 4) y, a menudo, financiamiento (Libro 5).

2. Objetivos del libro

Al terminar, el lector será capaz de:

- **Distinguir** los tres caminos de crecimiento (comprar, construir, colaborar) y saber **cuándo conviene una colaboración** frente a una adquisición.
- **Diferenciar** los tipos de joint venture: **societaria** (*equity JV*: se crea una sociedad) y **contractual** (*contractual JV*: solo contrato), y elegir la adecuada.

- **Estructurar y documentar una JV:** la elección del vehículo, las **aportaciones** de cada socio, el **gobierno compartido** (consejo paritario, vetos, resolución de *deadlock*), el reparto de utilidades, la **propiedad intelectual** y la **exclusividad**, y —lo más crítico— las **cláusulas de salida**.
- **Dominar los mecanismos de bloqueo y salida** (los más difíciles): *deadlock* (ruleta rusa, Texas shoot-out), *put/call*, *drag/tag*, disolución —reutilizando lo aprendido en el SHA—.
- **Estructurar contratos estratégicos** de largo plazo: **distribución** (y su diferencia con la agencia y el franquiciamiento), **suministro** (con cláusulas *take-or-pay*, precio, exclusividad), **licencia** y transferencia de tecnología.
- **Manejar los instrumentos preliminares:** MOU, cartas de intención, acuerdos de exclusividad y confidencialidad (NDA), distinguiendo lo vinculante de lo no vinculante (eco del Term Sheet, Libro 4).
- **Identificar los límites regulatorios:** derecho de la **competencia** (las JV y las cláusulas de exclusividad/no competencia pueden restringir la competencia), inversión extranjera, y normas sectoriales.
- **Conectar** la colaboración con el resto del Nivel IV: ver la JV como la **combinación** de estructura, SHA y financiamiento al servicio de una alianza.

3. Importancia profesional

Para tu perfil —**contratos estratégicos** y estructuración de operaciones complejas— este libro es **esencial**. Las joint ventures y las alianzas son de las operaciones **más sofisticadas y exigentes** que estructura un abogado corporativo, porque combinan **todas** las disciplinas: derecho societario, contractual, de competencia, fiscal, de propiedad intelectual y, a menudo, internacional. Y son **menos estandarizadas** que un SPA: cada JV es **a la medida** del proyecto y de la relación entre los socios, lo que exige **criterio y creatividad**, no plantillas.

La demanda es alta y transversal. Las JV son el vehículo natural para: la **internacionalización** (una empresa extranje-

ra que entra a México suele hacerlo aliándose con un socio local que aporta conocimiento del mercado y, a veces, cumple requisitos de inversión extranjera); los **proyectos de infraestructura y energía** (consorcios que se unen para una licitación o un proyecto —conectan con el *project finance* del Libro 5—); la **tecnología** (alianzas para desarrollar productos, compartir PI); y la **expansión** en general (compartir el costo y el riesgo de una apuesta grande). El abogado que sabe estructurar JV trabaja en operaciones estratégicas de primer nivel.

Hay además una razón profunda por la que esta práctica forma a un gran abogado: las JV obligan a **anticipar el conflicto**. Como nadie manda del todo y la relación es de largo plazo, el abogado debe **prever, por escrito, qué pasará** cuando los socios no se pongan de acuerdo (deadlock), cuando uno quiera salir, cuando cambien las circunstancias. Diseñar buenos mecanismos de **gobierno y salida** es de lo más difícil y valioso del oficio —y la misma habilidad que usaste en el SHA (Libro 4), llevada al extremo—. Quien domina las JV domina el arte de **estructurar relaciones de poder compartido**.

4. Historia y origen

La colaboración entre comerciantes para empresas comunes es **antiquísima**. El derecho romano conoció la *societas* (un contrato por el cual varias personas ponían bienes o trabajo en común para repartir ganancias) —antecedente directo de la idea de "asociarse para un fin común"—. En la Edad Media y el Renacimiento, las grandes **expediciones comerciales** (las rutas marítimas, el comercio con Oriente) se financiaban y organizaban como **aventuras conjuntas** (*joint adventures* —de ahí, etimológicamente, "joint venture"—): varios mercaderes ponían capital y riesgo en un viaje común, repartiendo lo ganado. La **commenda** medieval (un inversor pasivo y un comerciante activo que compartían un negocio) prefigura las estructuras de coinversión.

La **joint venture moderna** se desarrolla con la empresa industrial y, sobre todo, con la **expansión internacional** de las corporaciones en el siglo XX. Cuando las empresas de un país querían operar en otro —con mercados, regulaciones y

culturas distintas—, descubrieron que **aliarse con un socio local** era a menudo mejor (y a veces obligatorio, por reglas de inversión extranjera) que ir solas. La JV se volvió el vehículo clásico de la **inversión extranjera directa**, especialmente en sectores estratégicos y en países que limitaban la propiedad foránea.

En **México**, las JV proliferaron con la apertura económica (a partir de los años 1980-90 y, sobre todo, con el TLCAN/T-MEC): empresas extranjeras entraron al mercado mexicano **aliándose** con socios locales, tanto por estrategia (conocimiento del mercado) como por requisitos legales (sectores con límites a la inversión extranjera, donde la JV permitía estructurar la participación). Hoy las JV son habituales en energía, infraestructura, automotriz, consumo y tecnología. Los **contratos estratégicos** (distribución, suministro, licencia) acompañaron esta evolución como las herramientas de la colaboración menos intensa que la coinversión.

5. Evolución histórica

La evolución de las estructuras de colaboración puede leerse en tres movimientos:

1) De la aventura puntual a la alianza permanente. Las primeras "joint adventures" eran **puntuales** (un viaje, una expedición): se unían, repartían y se separaban. Con la empresa moderna, la colaboración se volvió **permanente y estructurada**: JV societarias diseñadas para operar negocios durante años o décadas, con gobierno, capital y reglas estables.

2) De la colaboración informal al diseño jurídico sofisticado. Lo que empezó como acuerdos basados en la **confianza** (un apretón de manos entre socios) se transformó, ante la magnitud y complejidad de los proyectos, en **arquitecturas jurídicas detalladas**: contratos de JV de cientos de páginas, con mecanismos finos de gobierno, *deadlock* y salida. La experiencia (muchas JV terminaron en conflictos destructivos) enseñó que **lo no previsto se convierte en litigio**, y que el valor del abogado está en **anticipar** y regular el conflicto por adelantado.

3) **La especialización de los contratos estratégicos y el escrutinio de competencia.** Los contratos de **distribución, suministro y licencia** se sofisticaron (cláusulas de exclusividad, territorios, precios, *take-or-pay*, mínimos), y a la vez quedaron bajo el **escrutinio creciente del derecho de la competencia**: las restricciones verticales (exclusividades, fijación de precios de reventa) y las JV entre competidores pueden **restringir la competencia** y, por tanto, están reguladas. La frontera moderna es estructurar la colaboración de modo que cree valor **sin** violar la ley de competencia.

6. Contexto económico

La colaboración empresarial responde a una lógica económica clara: **lograr juntos lo que ninguno lograría solo (o lo lograría peor)**. Tres ideas la gobiernan:

- **Sinergias y complementariedad de recursos.** Cada empresa tiene activos distintos: una tiene **tecnología**, otra **acceso al mercado**; una tiene **capital**, otra **know-how operativo**; una conoce el **mercado local**, otra tiene la **marca global**. La JV **combina** esos recursos complementarios para crear un valor que la suma de las partes por separado no alcanzaría. Económicamente, la JV existe cuando **colaborar genera más valor** que comprar, construir o no hacer nada.
- **Compartir el costo y el riesgo de una apuesta grande.** Algunos proyectos son **demasiado grandes o riesgosos** para una sola empresa (una planta de miles de millones, la entrada a un mercado incierto, el desarrollo de una tecnología). La JV permite **repartir** ese costo y ese riesgo entre los socios —cada uno arriesga menos, y entre todos hacen posible lo que individualmente sería imprudente—.
- **Los costos de la colaboración (por qué no siempre conviene).** Pero colaborar **cuesta**: hay que **coordinarse** (gobierno compartido = decisiones más lentas), surgen **conflictos de interés** (los socios compiten en otros mercados, o uno quiere reinvertir y otro repartir), y existe el riesgo de **comportamiento oportunista** (que un socio se apropie del know-how o de los clientes y luego se vaya). La teoría econó-

mica (costos de transacción, Coase, Williamson) explica que la empresa elige entre **comprar** (integrar: control total, sin negociar con un socio), **contratar** (mercado: flexible pero sin control) o **colaborar** (JV: un híbrido que comparte control y riesgo). La JV conviene cuando los beneficios de combinar recursos superan los costos de coordinarse y el riesgo de oportunismo.

EL *HOLD-UP*: EL PROBLEMA QUE EXPLICA CASI TODA CLÁUSULA DE UNA JV

Hay un concepto que ordena este libro entero, y viene de **Williamson**: los **activos específicos de la relación**. Son las inversiones que valen mucho **dentro** de la alianza y poco o nada **fuera** de ella: una línea de producción adaptada al producto del socio, un equipo entrenado en su tecnología, una marca conjunta, una red de distribución construida para un solo cliente.

Y aquí está el problema: **en el momento en que haces esa inversión, quedas expuesto**. Antes de invertir tenías alternativas; después, tu contraparte sabe que salirte te cuesta más que aguantar. Eso permite que renegocie condiciones a tu costa, y se llama ***hold-up*** —literalmente, un secuestro—. No requiere mala fe: basta con que la otra parte advierta que tu poder de negociación cayó.

De ese riesgo se derivan, una por una, las cláusulas que a un principiante le parecen pesimistas:

LA CLÁUSULA	EL <i>HOLD-UP</i> QUE PREVIENE
Compromisos de aportación con calendario y penalidad	Que el socio no aporte lo prometido cuando tú ya aportaste
Propiedad de la IP creada y licencias de reversión	Que al salir se quede con lo que se desarrolló con tu tecnología
No competencia y no solicitud	Que use lo aprendido para competirte con tu propio equipo y clientela
<i>Deadlock, put/call, tag/drag</i>	Que te deje atrapado sin salida ni precio
Destino de los activos y de la clientela al disolver	Que la disolución sea el mecanismo para quedarse con el valor

La consecuencia práctica, y es la regla del libro: la entrada se diseña pensando en la salida. No por desconfianza, sino porque el momento de mayor equilibrio de poder entre las partes es **antes de firmar** — y por tanto es el único momento en que puedes obtener protecciones simétricas. Un socio que se niega a discutir la salida te está dando información valiosa sobre cómo será el matrimonio.

Y LA RAZÓN POR LA QUE NINGÚN CONTRATO DE JV PUEDE SER SUFICIENTEMENTE DETALLADO

Aquí conecta con la teoría de los **contratos incompletos** (Grossman, Hart y Moore; Nobel de Hart en 2016), que ya viste aplicada al SPA en el Libro 4: es imposible prever todos los estados del mundo, y en una JV el horizonte es de años, no de meses. Por tanto lo que importa no es la cantidad de definiciones, sino **quién tiene el derecho de control residual** —quién decide sobre lo que nadie previó—.

De ahí una jerarquía que conviene tener clara al repartir tu tiempo de negociación: **una cláusula de *deadlock* bien hecha y un cuadro de mayorías de veto bien calibrado valen más que mil definiciones.**

Y el contrapunto necesario, porque el derecho no lo es todo: la literatura de **contratos relacionales** (Macaulay, Macneil) documentó algo que cualquier empresario sabe y muchos abogados olvidan — en relaciones de largo plazo, **las partes resuelven la mayoría de sus diferencias sin abrir el contrato.** La confianza acumulada y la disposición a renegociar hacen más trabajo que la letra. El contrato no es el mecanismo cotidiano de gobierno: es la red de seguridad para cuando ese mecanismo falla. Escribirlo como si fuera lo único que existe produce alianzas rígidas; escribirlo como si nunca fuera a usarse produce socios atrapados.

7. Contexto político y regulatorio

Las estructuras de colaboración operan bajo límites regulatorios importantes que el abogado debe dominar:

- **Derecho de la competencia (COFEC): el límite central.** Las JV y los contratos estratégicos pueden **restringir la competencia** y, por tanto, están bajo escrutinio. Dos frentes:

- (i) una JV entre **competidores** puede ser una **concentración notificable** a la COFECE (si supera umbrales) y, si reduce la competencia, puede ser objetada; además, no debe servir de **fachada para coludirse** (fijar precios, repartirse mercados —prácticas monopólicas absolutas, gravísimas—).
- (ii) Las **restricciones verticales** de los contratos de distribución/suministro (exclusividades, territorios, fijación de precios de reventa) pueden ser **prácticas monopólicas relativas** si dañan la competencia. Estructurar la colaboración **sin violar** la competencia es el reto regulatorio número uno.
- **Inversión extranjera.** Las JV son, a menudo, el vehículo para que un socio extranjero participe en sectores con **límites a la inversión foránea**; la estructura debe respetar esos límites (a veces obliga a que el socio mexicano tenga la mayoría, o a usar ciertos vehículos).
 - **Normas sectoriales.** En energía, infraestructura, telecomunicaciones, minería, etc., las JV y consorcios deben cumplir las reglas del sector y, a veces, obtener autorizaciones.
 - **Propiedad intelectual y transferencia de tecnología.** Las alianzas tecnológicas involucran licencias y transferencia de PI, con su propia regulación (IMPI, normas de competencia sobre licencias).
 - **Contratación pública.** Los consorcios que se unen para **licitaciones públicas** deben cumplir las reglas de adquisiciones y obra pública.

8. Contexto social

La colaboración empresarial tiene una dimensión social y relacional intensa, porque una JV es, en el fondo, una **relación humana de largo plazo** entre organizaciones (y entre las personas que las dirigen). El **factor cultural** es decisivo: muchas JV —especialmente las internacionales— fracasan no por mala redacción del contrato, sino por **choques culturales y de estilo de gestión** entre los socios (la forma de tomar decisiones, el ritmo, la tolerancia al riesgo). El abogado que estructu-

ra una JV debe entender que está diseñando una **convivencia**, y que el contrato es solo el esqueleto: la carne es la relación.

Hay también una dimensión de **confianza y reputación**. Las JV se construyen sobre la confianza mutua, pero el buen abogado sabe que la confianza **no basta**: hay que prever, por escrito, qué pasa cuando la confianza se rompe (porque tarde o temprano, en muchos casos, se tensiona). Diseñar mecanismos de **resolución de conflictos y de salida** civilizada es, en cierto modo, un acto de **realismo social**: proteger la relación **anticipando** su posible deterioro, para que un divorcio no destruya el valor creado.

Finalmente, las alianzas tienen impacto en el **ecosistema empresarial y social**: las JV de infraestructura y energía construyen lo que la sociedad necesita; las alianzas tecnológicas aceleran la innovación; pero las colaboraciones entre competidores, mal usadas, pueden **dañar a los consumidores** (precios más altos, menos opciones) —de ahí el escrutinio de competencia—. El abogado opera en esa tensión entre la **colaboración que crea valor** y la **colusión que lo destruye**.

9. Contexto empresarial

Desde la óptica del negocio, las estructuras de colaboración sirven a objetivos estratégicos muy diversos. El abogado debe entender el **objetivo** para estructurar la alianza correcta:

- **Entrar a un nuevo mercado (especialmente internacional)**: aliarse con un **socio local** que aporta conocimiento, red, marca o cumplimiento de requisitos de inversión extranjera. La JV clásica de internacionalización.
- **Desarrollar un proyecto de gran escala**: un **consorcio** que une a varias empresas para una planta, una carretera, una licitación (combinándose con *project finance* —Libro 5—).
- **Acceder a tecnología o capacidades**: alianzas de I+D, licencias de tecnología, JV para desarrollar un producto que ninguno haría solo.
- **Asegurar suministro o distribución**: contratos de **suministro** de largo plazo (asegurar un insumo crítico) o de **dis-**

tribución (acceder a canales de venta) —colaboración menos intensa que la JV—.

- **Compartir costo y riesgo:** repartir una apuesta grande e incierta entre socios.
- **Preparar una futura adquisición:** a veces la JV es un **paso previo** —los socios colaboran, se conocen, y uno termina comprando al otro (la JV con opción de compra)—.

La decisión clave que el abogado ayuda a tomar: **¿colaborar o comprar?** Si quieres **control total** y la otra empresa está dispuesta a venderse, **compra** (M&A). Si quieres **combinar recursos** manteniendo a la otra como socio activo, o no puedes/no quieres comprar (por costo, por riesgo, por regulación), **colabora** (JV o contrato estratégico). Y si decides colaborar, la siguiente pregunta es **cuánto**: desde un contrato de suministro (colaboración ligera) hasta una JV societaria (colaboración profunda, casi un "mini-M&A compartido"). El gran abogado de operaciones complejas maneja **todo el espectro** —comprar, financiar, colaborar— y elige (o combina) la herramienta que mejor sirve la estrategia del cliente.

10. Definiciones doctrinales

La doctrina define las figuras centrales de la colaboración así:

- **Joint Venture (JV) / Empresa conjunta / Coinversión:** acuerdo por el cual **dos o más empresas** unen recursos para un **propósito común**, compartiendo el **control, las utilidades y los riesgos**. La doctrina la define como una forma de **cooperación interempresarial** a medio camino entre el **mercado** (contratar) y la **jerarquía** (fusionarse): ni totalmente independientes, ni totalmente integradas.
- **Equity JV (JV societaria / de capital):** JV en la que los socios **constituyen una sociedad nueva** (la *JV co* o *NewCo*) de la que son **accionistas**, aportando capital y recursos. La colaboración se **institucionaliza** en una persona jurídica con su propio gobierno y patrimonio.
- **Contractual JV (JV contractual / sin sociedad):** JV en la que los socios colaboran **solo por contrato, sin** crear una sociedad: se obligan a coordinar conductas, aportar recur-

sos y repartir resultados, pero cada uno conserva su personalidad y su patrimonio (típico en consorcios para una obra o proyecto específico). En México se asocia a la figura de la **asociación en participación (A en P)** o a consorcios contractuales.

- **Alianza estratégica:** término amplio para cualquier **acuerdo de cooperación** entre empresas con un fin estratégico (compartir tecnología, mercados, I+D), que puede o no llegar al nivel de una JV.
- **Contrato de distribución:** acuerdo por el que un **distribuidor** se obliga a **comprar y revender** los productos del **proveedor** en un territorio, **por cuenta y riesgo propios** (compra para revender), a diferencia del agente (que vende por cuenta del principal) y del franquiciatario (que opera un modelo de negocio bajo licencia).
- **Contrato de suministro:** acuerdo por el que un **proveedor** se obliga a **entregar bienes de forma continuada o periódica** a un **adquirente**, durante un plazo, a un precio y condiciones pactados. Asegura el abasto de un insumo (o la colocación de una producción).
- **Contrato de licencia / transferencia de tecnología:** acuerdo por el que el **titular** de una propiedad intelectual (patente, marca, know-how, software) **autoriza** a otro a usarla, a cambio de regalías, en ciertas condiciones.
- **MOU (*Memorandum of Understanding*) / Carta de intención:** documento **preliminar** que expresa la **intención** de las partes de colaborar bajo ciertos términos, normalmente **no vinculante** en lo sustantivo (eco directo del Term Sheet del Libro 4).

11. Definiciones legales y marco normativo

A diferencia de la sociedad mercantil (regulada con detalle en la LGSM), la JV **no es un tipo contractual único y nominado** en el derecho mexicano: es una **operación** que se **encarna** en

figuras jurídicas existentes. El marco normativo se arma combinando varias fuentes:

- **Autonomía de la voluntad (CCF, Código de Comercio).** La base: las partes pueden diseñar libremente su colaboración (el contrato de JV, la alianza) dentro de los límites de la ley, el orden público y la competencia. La JV contractual es, ante todo, un **contrato atípico** amparado por la libertad contractual.
- **Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM).** Si la JV es **societaria**, se constituye una sociedad (típicamente **S. de R.L.** —flexible, ideal para JV con pocos socios— o **S.A.**, y cada vez más la **S.A.P.I.** por la validez que da a las cláusulas de socios). El **convenio de JV** funciona como un **SHA** (Libro 4) que rige la relación entre los socios de la JV co.
- **Asociación en Participación (A en P) (LGSM).** Figura mexicana clave para la **JV contractual**: un **asociante** (que opera y aparece frente a terceros) y uno o varios **asociados** (que aportan y participan en resultados) colaboran en un negocio **sin crear una persona jurídica** ni aparecer los asociados frente a terceros. Útil para coinversiones sin sociedad.
- **Contratos mercantiles típicos y atípicos (Código de Comercio, LGTOC, leyes especiales).** La **distribución**, el **suministro** y la **comisión** se rigen por las reglas mercantiles (algunos son atípicos, regidos por la autonomía de la voluntad y por analogía); el **franquiciamiento** tiene reglas específicas (Ley de la Propiedad Industrial). La **licencia** de PI se rige por la **Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial** y la de derechos de autor.
- **Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).** Límite central: las JV entre competidores (concentraciones notificables; prohibición de colusión) y las restricciones verticales de los contratos de distribución/suministro (prácticas monopólicas relativas).

- **Ley de Inversión Extranjera.** Cuando hay un socio extranjero, define límites y condiciones de su participación (relevante para JV de internacionalización).
- **Código Civil (contratos en general, asociación civil, co-propiedad).** Marco supletorio de las obligaciones y, para fines no lucrativos, la asociación civil.

Nota de método: la JV es una **operación**, no un contrato típico único; se estructura **eligiendo y combinando** vehículos (sociedad, A en P, contratos). Verifica el texto vigente de la LGSM, la LFCE y las leyes de PdI/inversión extranjera antes de aplicarlos (Manifiesto XI.5).

12. Definición sencilla

Imagina que tú eres **muy bueno cocinando** y tu amigo tiene **un local en la mejor esquina** de la ciudad. Ninguno de los dos, solo, puede abrir el gran restaurante: tú no tienes local, él no sabe cocinar. Tienen tres caminos:

- **Comprar (M&A):** tú le **compras el local** (o él te compra tu receta) y mandas tú solo. Uno se queda con todo y el otro se va.
- **Contratar (contrato estratégico):** él te **renta el local** (suministro/arrendamiento) o tú le **vendes tus platillos** para que él los revenda (distribución). Colaboran, pero cada quien sigue por su lado, sin un negocio común.
- **Aliarse (joint venture):** **abren juntos el restaurante**, como **socios**. Tú pones la cocina y las recetas; él, el local y el dinero. Reparten las ganancias, **comparten las decisiones**, y comparten el riesgo si va mal. Eso es una **joint venture**.

Y si abren juntos, deben decidir **antes** las preguntas difíciles, que son exactamente las cláusulas de la JV: ¿quién **pone qué** (aportaciones)?, ¿quién **decide** el menú y los precios (gobierno)?, ¿qué pasa si **no se ponen de acuerdo** (deadlock)?, ¿cómo se **reparten** las ganancias?, ¿de quién son las **recetas** si se separan (propiedad intelectual)?, y —lo más importante— ¿qué pasa si uno **quiere salirse o vender su parte** (salida)? Una JV es un **matrimonio de negocios**: hay que pactar el "pre-

nupcial" **antes** de la boda, porque si la sociedad se agria sin reglas, el restaurante (el valor) se destruye en la pelea.

13. Conceptos fundamentales

Fija este vocabulario; muchos términos ya los conoces del SHA (Libro 4) —porque una JV societaria **usa** un SHA—:

Tipos y vehículos de colaboración:

- **Equity JV (societaria):** se crea una **JV co** (sociedad); los socios son accionistas.
- **Contractual JV (sin sociedad):** colaboración solo por contrato; en México, a menudo vía **asociación en participación (A en P)** o consorcio.
- **Asociación en Participación (A en P):** **asociante** (opera y aparece frente a terceros) + **asociado** (aporta y participa en resultados, oculto frente a terceros); **sin** personalidad jurídica.
- **Consorcio:** unión contractual de empresas para un **proyecto u obra** específicos (típico en licitaciones e infraestructura).

El contrato de JV (gobierno, capital, salida — como un SHA):

- **Aportaciones (*contributions*):** lo que cada socio pone (capital, activos, tecnología, mercado, personal). Se valúan y definen su participación.
- **Gobierno compartido: consejo paritario** (asientos por socio), **materias reservadas/vetos** (decisiones que requieren acuerdo de ambos), y la regla de mayorías.
- **Deadlock (bloqueo):** el problema **característico** de la JV 50/50: qué hacer cuando los socios **no se ponen de acuerdo** y el negocio se paraliza. Mecanismos: escalamiento, mediación, y de salida forzosa (**ruleta rusa, Texas/Mexican shoot-out, cooling-off**).
- **Reparto de utilidades y reinversión:** cómo y cuándo se distribuyen las ganancias.

- **Exclusividad y no competencia:** compromisos de canalizar cierto negocio a la JV y de no competir con ella (¡cuidado con la competencia económica!).
- **Propiedad intelectual:** de quién es la PI **aportada** y la **creada** por la JV; qué pasa con ella al terminar.
- **Salida (exit):** **lock-up**, **ROFR/ROFO**, **tag along**, **drag along**, **put/call**, disolución y liquidación de la JV. La parte más crítica (reutiliza el SHA).

Contratos estratégicos:

- **Distribución:** el distribuidor **compra para revender** por cuenta y riesgo propios (vs. **agencia:** vende por cuenta del principal; vs. **franquicia:** opera un modelo bajo licencia).
- **Suministro:** entrega **continuada** de bienes; cláusulas de **precio** (fijo, indexado), **volumen** (mínimos, **take-or-pay** —pagas tomes o no—), **exclusividad** y plazo.
- **Licencia / transferencia de tecnología:** autorización de uso de PI a cambio de **regalías**; alcance, territorio, exclusividad, mejoras.
- **Acuerdo marco (*framework/master agreement*):** contrato "paraguas" que fija las condiciones generales de una relación de largo plazo, bajo el cual se celebran órdenes o contratos específicos.

Instrumentos preliminares:

- **MOU / Carta de intención / Heads of Terms:** documento **preliminar** de la colaboración, mayormente **no vinculante** salvo cláusulas de proceso (exclusividad, confidencialidad) —eco del Term Sheet—.
- **NDA (acuerdo de confidencialidad):** protege la información que las partes comparten al explorar la alianza.

Con este vocabulario, entramos al **desarrollo absoluto**.

14. Desarrollo absoluto

Esta es la sección central. La desarrollamos en cinco bloques: **(A)** la **decisión de colaborar** y los **tipos de JV** (societaria vs. contractual); **(B)** el **contrato de JV, parte I** —aportaciones, go-

bierno compartido y operación—; **(C)** el **contrato de JV, parte II** —deadlock y salida, los mecanismos más difíciles—; **(D)** los **contratos de distribución y suministro** estratégicos; y **(E)** las **alianzas, licencias e instrumentos preliminares** (MOU, acuerdos marco). Estúdialos en orden: primero cuándo y cómo colaborar, luego la JV por dentro (gobierno y salida), y después los contratos estratégicos de menor intensidad.

14.A · LA DECISIÓN DE COLABORAR Y LOS TIPOS DE JOINT VENTURE

La decisión: ¿comprar, construir o colaborar? Antes de estructurar nada, el abogado ayuda al cliente a elegir el **camino**. La pregunta clave: ¿qué quiere lograr y con qué grado de control y compromiso?

- Si quiere **control total** y la otra empresa puede venderse → **comprar (M&A)**.
- Si puede lograrlo **solo** (con tiempo y capital/deuda) → **construir** (orgánico + financiamiento).
- Si necesita **combinar recursos** con otro (que aporta lo que a él le falta), o **compartir el riesgo**, o **no puede/no quiere comprar** (costo, regulación, que el otro no se vende) → **colaborar**.

Y si decide colaborar, hay un **espectro de intensidad**:

MENOS intenso ←			→ MÁS intenso
Contrato de suministro o distribución (colaboración puntual/comercial)	Alianza/acuerdo de cooperación (I+D, licencias)	JV contractual (consorcio, A en P; sin sociedad)	JV societaria (equity JV: crean una sociedad)

Cuanto más a la derecha, **más profunda** la colaboración (más recursos comprometidos, más control compartido, más largo plazo) y **más compleja** la estructura jurídica. La JV societaria es casi un "mini-M&A compartido"; el contrato de suministro es colaboración comercial ligera.

Los dos grandes tipos de JV:

1) Equity JV (JV societaria / de capital). Los socios **constituyen una sociedad nueva** (la *JV co*) de la que son accionistas,

y a ella aportan capital y recursos. Es la forma **más institucional y duradera**.

- **Ventajas:** **personalidad jurídica propia** (la JV contrata, contrata personal, es dueña de activos en su nombre); **limitación de responsabilidad** (el riesgo se acota al capital de la JV co, protegiendo a los socios); claridad de **gobierno** (consejo, asambleas); facilidad para **financiarse** (la JV co toma deuda) y para **transmitir** participaciones (vender acciones).
- **Desventajas:** más **costosa y rígida** de constituir y operar; exige acuerdos societarios detallados; disolverla es más complejo.
- **Vehículo típico en México:** **S. de R.L.** (flexible, ideal para pocos socios, ventajas fiscales para socios extranjeros), **S.A.** o, cada vez más, **S.A.P.I.** (por la validez que da a las cláusulas de socios —vetos, drag/tag—). El **convenio entre los socios de la JV** funciona como un **SHA** (Libro 4).

2) Contractual JV (JV contractual / sin sociedad). Los socios colaboran **solo por contrato, sin** crear una sociedad. Cada uno conserva su personalidad y patrimonio, y se obligan a coordinar conductas, aportar recursos y repartir resultados.

- **Ventajas:** **flexible, rápida y barata** de montar; ideal para colaboraciones **acotadas en el tiempo o el objeto** (un proyecto, una obra, una licitación); evita los costos de constituir y operar una sociedad.
- **Desventajas:** **no hay personalidad jurídica** (la "JV" no puede contratar ni ser dueña en su nombre; lo hacen los socios o el líder del consorcio); la **responsabilidad** puede ser directa (a veces solidaria frente a terceros); el gobierno y la separación de patrimonios son más difusos.
- **Vehículos típicos en México:** la **asociación en participación (A en P)** —asociante + asociado(s), sin personalidad ni aparición de los asociados frente a terceros— y el **consorcio contractual** (típico para obras y licitaciones).

¿Cuál elegir? Regla práctica: para una colaboración **duradera, de gran escala, con activos y personal propios y necesidad de financiarse** → **equity JV** (sociedad). Para una

colaboración **acotada (un proyecto, una obra), temporal y donde no conviene crear una sociedad → contractual JV** (A en P / consorcio). La fiscalidad, la regulación (inversión extranjera) y la responsabilidad frente a terceros también pesan en la decisión —y, como en el Libro 3, casi siempre se decide **con el fiscalista**—.

14.B · EL CONTRATO DE JV, PARTE I (APORTACIONES, GOBIERNO Y OPERACIÓN)

El **contrato de JV** (en la equity JV, el *Joint Venture Agreement* + los estatutos de la JV co; es, en esencia, un **SHA especializado** —Libro 4—) regula la vida de la colaboración. Sus piezas, parte I:

1) El propósito y el alcance (scope). Define **para qué** existe la JV y qué puede (y no puede) hacer. Es más importante de lo que parece: delimita el **negocio común** y, con ello, qué actividades los socios canalizan a la JV y cuáles conservan para sí (la frontera con la **exclusividad** y la **no competencia**). Un *scope* mal definido genera conflictos sobre qué oportunidades "pertenecen" a la JV.

2) Las aportaciones (contributions). Lo que cada socio **pone**, que rara vez es solo dinero:

- **Capital** (efectivo).
- **Activos** (inmuebles, plantas, equipos).
- **Intangibles** (tecnología, **propiedad intelectual**, marcas, know-how).
- **Acceso al mercado** (red de clientes, canales de distribución, licencias regulatorias).
- **Personal y gestión** (ejecutivos, capacidad operativa). El reto: **valuar** aportaciones heterogéneas (¿cuánto "vale" la tecnología de uno frente al capital del otro?) para definir el **porcentaje** de cada socio. Esta valuación, y el equilibrio de poder que define, es de las negociaciones más delicadas. También se pactan las **aportaciones futuras** (¿qué pasa si la JV necesita más capital? —*capital calls*— y qué le ocurre al socio que **no** aporta —dilución, *default*—).

3) El gobierno compartido (el corazón de la JV). Aquí está la **diferencia esencial** con una empresa de un solo dueño: en la JV **el control se comparte**, y diseñar ese reparto es el arte central. Piezas:

- **El consejo de administración:** su **composición** refleja el poder pactado. En una JV 50/50, suele ser **paritario** (igual número de consejeros por socio) —lo que crea el riesgo de **empate/deadlock**—. En una JV con un socio mayoritario, este controla el consejo, pero el minoritario se protege con vetos.
- **Las materias reservadas / vetos (*reserved matters*):** la lista de **decisiones importantes** que requieren el **acuerdo de ambos socios** (o del minoritario), aunque uno controle el consejo: cambiar el *scope*, endeudarse, hacer inversiones grandes, aprobar el presupuesto, nombrar/remover al director general, repartir o no utilidades, admitir nuevos socios, modificar estatutos. Es la **principal protección** del socio que no controla el día a día. Negociar **qué** entra en esta lista (y con qué mayoría) es una batalla central.
- **La dirección y la operación:** quién nombra al **CEO/director general** y al equipo clave; cómo se toman las decisiones operativas del día a día (que **no** pueden requerir consenso para todo, o la JV se paraliza). El equilibrio: el socio operador gestiona con agilidad, pero rinde cuentas y respeta los vetos.
- **La información y la transparencia:** derecho de cada socio a recibir información financiera y de gestión, auditar, y supervisar (especialmente el socio no operador).

4) La operación y las relaciones con los socios. Una JV rara vez opera aislada: típicamente hay **contratos entre la JV y sus socios** (un socio le **suministra** insumos, otro le **licencia** tecnología, otro le **distribuye** el producto). Estos **contratos relacionados** (*ancillary agreements*) son tan importantes como el contrato de JV, y deben pactarse **a precio de mercado** (*arm's length*) para que un socio no extraiga valor en perjuicio del otro (un riesgo análogo a las **operaciones con partes relacionadas** del gobierno corporativo —Nivel III—). Aquí se ve

cómo la JV combina **estructura, gobierno y contratos** en un solo sistema.

5) **Utilidades, reinversión y financiamiento.** Cómo y cuándo se **reparten** las ganancias (un foco de conflicto: un socio puede querer **dividendos** y el otro **reinvertir** para crecer), y cómo se **financia** la JV (capital adicional de los socios vs. deuda de la JV co —conecta con el Libro 5—). La **política de dividendos vs. reinversión** debe pactarse, porque enfrenta intereses legítimos distintos.

14.C · EL CONTRATO DE JV, PARTE II (DEADLOCK Y SALIDA: LOS MECANISMOS MÁS DIFÍCILES)

Aquí está lo **más difícil y característico** de la JV: qué hacer cuando los socios **no se ponen de acuerdo** (deadlock) y cómo permite la **salida** de un socio. Son los mecanismos que **previenen que un conflicto destruya el valor** —y los que más distinguen a un abogado experto—. Reutilizan y profundizan lo que aprendiste en el SHA (Libro 4).

El deadlock (bloqueo): el problema de la JV 50/50. Cuando dos socios tienen el mismo poder (gobierno paritario) y **no logran acordar** una decisión clave, el negocio se **paraliza**. El contrato debe prever un **camino de salida del bloqueo**, escalando de lo suave a lo drástico:

- **Escalamiento y *cooling-off*:** primero, la decisión "sube" a los **directivos máximos** o a los **presidentes** de cada socio (que negocien al más alto nivel), con un periodo de enfriamiento. Muchos bloqueos se resuelven aquí.
- **Mediación / experto independiente:** un tercero ayuda a destrabar (mediación) o decide un punto técnico (experto).
- **Mecanismos de compra-venta forzosa (si nada funciona):** los más drásticos, diseñados para que el bloqueo **no eternice** la parálisis, forzando que **uno compre al otro**:
- **Ruleta rusa (*Russian roulette*):** un socio (A) fija un **precio por acción** y le da a B la opción de **comprar** la parte de A o **vender** la suya a A, **a ese precio**. Como A no sabe qué hará B, tiene incentivo a fijar un **precio justo** (si lo pone muy

bajo, B le compra barato; si muy alto, B le vende caro). Resuelve el bloqueo separando a los socios.

- **Texas / Mexican shoot-out:** ambos socios presentan **ofertas selladas** para comprar al otro; gana (compra) **el que ofrece más**. Empuja a ofrecer el precio real.
- **Multiple choice / put-call:** variantes con opciones de venta (put) y compra (call) bajo disparadores.

Advertencia de criterio (igual que en el SHA): estos mecanismos **favorecen a quien tiene más dinero** (el socio con más caja puede comprar; el que no la tiene, se ve forzado a vender). El abogado del socio **más débil financieramente** debe negociarlos con cuidado (valuación independiente, plazos, excepciones) para que no se conviertan en una expropiación encubierta.

- **Disolución (la opción nuclear):** si el bloqueo es irresoluble, la JV se **disuelve y liquida** (se reparten activos, se terminan los contratos). Es el "divorcio total"; costoso, pero a veces la única salida.

Las cláusulas de salida (exit): cómo entra y sale un socio. Como la JV es de largo plazo, debe prever cómo un socio **transmite su participación** o **abandona**. Reutiliza el arsenal del SHA:

- **Lock-up:** prohibición de vender durante un periodo inicial (que los socios se comprometan).
- **ROFR / ROFO (derecho del tanto / de primera oferta):** antes de vender a un tercero, ofrecer al otro socio (para que no entre un extraño no deseado al "matrimonio").
- **Tag along:** si un socio vende, el otro puede **sumarse** a la venta (protección).
- **Drag along:** un socio (o mayoría) que vende puede **arrastrar** al otro a vender el 100% (clave si se quiere vender la JV entera a un tercero).
- **Put / Call options:** **put** (un socio obliga al otro a **comprarle** su parte ante ciertos disparadores: incumplimiento, deadlock, cambio de control del socio) y **call** (obliga a que le **vendan**). Muy usadas para estructurar salidas pactadas (p.

ej., un socio extranjero con opción de comprar la parte del local en X años).

- **Cambio de control del socio:** ¿qué pasa si **el socio** (no la JV) es adquirido por un tercero —quizá un competidor—? Suele pactarse un derecho del otro socio a **comprar** o a **terminar** (no quiere quedar "casado" con un competidor que compró a su socio).
- **Incumplimiento y *default*:** consecuencias si un socio incumple (no aporta, viola la exclusividad): desde indemnización hasta opción de compra forzosa de su parte (a descuento).

La propiedad intelectual al salir (punto crítico en JV tecnológicas). ¿De quién es la **PI aportada** (vuelve a su dueño) y la **PI creada** por la JV (¿se reparte?, ¿se licencia a los socios?, ¿se queda quien opera?)? Y al terminar: ¿pueden los socios **usar** lo aprendido y desarrollado, o hay restricciones? Mal resuelto, esto genera litigios feroces (un socio acusa al otro de "robarse" la tecnología de la JV). Debe pactarse **desde el inicio**.

La gran lección de la JV. A diferencia del M&A (donde uno manda y la relación termina), la JV es una **relación de poder compartido y de largo plazo**, y por eso el abogado debe **diseñar el divorcio antes de la boda**. Las cláusulas de deadlock y salida no son pesimismo: son **realismo**. La mayoría del valor que un abogado de JV agrega está en **anticipar el conflicto** y darle una salida ordenada por escrito, para que, si la relación se agria, el valor creado **no se destruya** en una guerra. Quien domina esto domina el arte de estructurar **relaciones de poder compartido** —una habilidad transferible a todo el gobierno corporativo—.

14.D · CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ESTRATÉGICOS

Bajando en intensidad de colaboración, llegamos a los **contratos estratégicos comerciales** de largo plazo, que estructuran relaciones sin crear una sociedad común. Son omnipresentes y, bien negociados, **estratégicos** (aseguran mercados, insumos o canales).

El contrato de distribución. El **distribuidor** se obliga a **comprar** los productos del **proveedor/fabricante** y **revenderlos** en un territorio, **por su cuenta y riesgo** (gana en el margen de reventa). Es clave **distinguirlo** de figuras parecidas:

- **vs. Agencia (comisión mercantil):** el **agente** promueve y vende **por cuenta del principal** (no compra para revender; gana una **comisión**). El riesgo y la propiedad de la mercancía no pasan al agente.
- **vs. Franquicia:** el **franquiciatario** opera un **modelo de negocio completo** (marca, know-how, sistemas) bajo licencia del franquiciante, pagando regalías; está fuertemente regulada (Ley de la Propiedad Industrial). Cláusulas clave del contrato de distribución: **territorio** y **exclusividad** (¿el distribuidor es el único en la zona?, ¿puede vender productos de competidores?), **objetivos/mínimos de compra, precios** (¡cuidado!: fijar el **precio de reventa** puede ser una práctica monopólica), **plazo y renovación, terminación** y —muy litigado— las **consecuencias de la terminación** (¿indemnización al distribuidor por la clientela generada?, manejo del inventario). El derecho de la **competencia** vigila las restricciones (exclusividades, territorios, precios).

El contrato de suministro. El **proveedor** se obliga a **entregar bienes de forma continuada o periódica** al **adquirente** durante un plazo. Asegura el **abasto** de un insumo crítico (para el comprador) o la **colocación** de una producción (para el proveedor). Cláusulas clave:

- **Volumen:** cantidades, mínimos y máximos; cláusula **take-or-pay** (el comprador paga aunque **no** tome el producto —común en energía y commodities: garantiza ingresos al proveedor que invirtió en capacidad—).
- **Precio:** fijo, **indexado** (a un índice o commodity), con fórmulas de revisión; protege contra la volatilidad de largo plazo.

- **Exclusividad:** ¿el comprador debe comprarle **solo** a este proveedor?, ¿el proveedor le vende **solo** a este comprador? (otra vez, ojo con la competencia).
- **Calidad, entrega y *force majeure*:** estándares, plazos, y qué pasa ante eventos de fuerza mayor (relevante para cadenas de suministro —lección de las disrupciones recientes—).
- **Plazo, terminación e incumplimiento.**

La dimensión estratégica. Estos contratos no son "papeleo comercial": un contrato de suministro de largo plazo puede ser la **columna vertebral** de un negocio (asegura el insumo sin el cual no opera), y un contrato de distribución define el **acceso al mercado**. En la **due diligence** (Libro 2), estos son precisamente los **contratos materiales** que se revisan con lupa (y donde se buscan las cláusulas de *change of control*). El abogado que los redacta bien **protege el corazón operativo** de la empresa.

14.E · ALIANZAS, LICENCIAS E INSTRUMENTOS PRELIMINARES

Cerramos el espectro de la colaboración con tres familias adicionales que todo abogado de operaciones estratégicas debe dominar.

Las alianzas estratégicas y de I+D. Más allá de la JV formal, existen **alianzas** de cooperación que no llegan a crear una sociedad ni a la intensidad de una equity JV, pero estructuran una colaboración estratégica:

- **Alianzas de I+D (investigación y desarrollo):** dos empresas colaboran para **desarrollar** una tecnología o producto, compartiendo costos, riesgos y —punto crítico— la **propiedad intelectual** de lo desarrollado (¿de quién es?, ¿se licencian mutuamente?, ¿quién explota qué campo?).
- **Alianzas comerciales y de comercialización:** colaboración para vender productos combinados, *co-branding*, programas conjuntos.
- **Alianzas estratégicas con participación minoritaria:** una empresa toma una **participación minoritaria** en otra (sin control) como respaldo de una alianza comercial o tecnoló-

gica (a medio camino entre el contrato y la JV). Frecuente en tecnología. El reto de las alianzas: son **menos estructuradas** que una JV societaria, lo que les da **flexibilidad** pero también **ambigüedad** (gobierno difuso, salida poco clara). El abogado debe darles la **estructura mínima necesaria** sin sobre-formalizarlas.

Los contratos de licencia y transferencia de tecnología.

El titular de una **propiedad intelectual** (patente, marca, derecho de autor, **know-how**, software) **autoriza** a otro a usarla a cambio de **regalías**. Es la herramienta central de las alianzas tecnológicas y de la expansión (licenciar la marca o la tecnología a un socio en otro mercado). Cláusulas clave:

- **Alcance de la licencia:** qué PI, para qué **uso/campo**, en qué **territorio**, **exclusiva** o no.
- **Regalías:** cómo se calculan (porcentaje de ventas, monto fijo, por unidad) y se pagan/auditan.
- **Mejoras (*improvements*):** ¿de quién son las **mejoras** que el licenciataria haga a la tecnología? (*grant-back* al licenciante). Punto delicado.
- **Control de calidad** (esencial en licencias de marca, para no degradarla), **confidencialidad** del know-how, **duración** y qué pasa al terminar (¿puede el licenciataria seguir usando lo aprendido?).
- **Límites de competencia:** las licencias pueden contener restricciones (territorios, exclusividades) que el derecho de la competencia vigila.

Los instrumentos preliminares (MOU, cartas de intención, acuerdos marco). Toda colaboración seria empieza con documentos **preliminares**, y aquí se repite — amplificada— la lección del **Term Sheet** (Libro 4):

- **MOU (*Memorandum of Understanding*) / Carta de intención / *Heads of Terms*:** expresan la **intención** de colaborar y las **bases** de la futura alianza. Regla de oro (idéntica al Term Sheet): lo **sustantivo** (los términos de la colaboración) suele ser **no vinculante**, pero ciertas cláusulas (**confidencialidad/NDA**, **exclusividad**, **gastos**, **ley aplicable**) sí vin-

culan. **Cuidado con la trampa:** un MOU mal redactado puede generar obligación o **responsabilidad precontractual** si sugiere un acuerdo cerrado o se rompe de mala fe una negociación avanzada. Debe decir **expresamente** qué obliga y qué no.

- **Acuerdo marco (*framework* / *master agreement*):** un contrato "**paraguas**" que fija las **condiciones generales** de una relación de largo plazo, bajo el cual se celebran luego **órdenes o contratos específicos** (*statements of work*, órdenes de compra). Muy usado en suministro, tecnología y servicios: se negocia **una vez** el marco (responsabilidad, propiedad intelectual, confidencialidad, ley aplicable) y se agiliza cada operación concreta. Ordena y da eficiencia a relaciones complejas y repetitivas.
- **NDA (acuerdo de confidencialidad):** el **primer** documento de casi toda colaboración: protege la información sensible que las partes comparten al **explorar** la alianza (igual que en el M&A —Libro 1—).

La visión de conjunto del libro. Observa cómo todo el espectro de la colaboración —del NDA inicial al MOU, del contrato de suministro a la alianza, de la JV contractual a la equity JV— es una **graduación de compromiso y control compartido**. Y observa cómo la JV, en su forma más completa, **integra todo lo que aprendiste:** una **estructura** societaria (Libro 3), un **convenio de socios** tipo SHA con gobierno, deadlock y salida (Libro 4), **contratos relacionados** de suministro/distribución/licencia (este libro y los anteriores) y, a menudo, **financiamiento** (Libro 5), todo al servicio de una **alianza estratégica**. Por eso la JV es la operación que mejor **sintetiza** la formación del abogado corporativo: comprar, financiar y colaborar dejan de ser temas aislados y se vuelven **herramientas combinables** de un mismo oficio —el de **estructurar operaciones corporativas complejas**, exactamente tu objetivo—.

15. Explicación intuitiva

Tres imágenes para fijar la colaboración empresarial.

La metáfora del matrimonio (para la JV). Comprar una empresa es como **adoptar** (tomas el control, mandas tú); colaborar en una JV es **casarte** (poder compartido, decisiones de a dos, patrimonio común). Y como en todo matrimonio serio, lo inteligente es firmar un **prenupcial detallado**: ¿quién aporta qué (aportaciones)?, ¿quién decide qué (gobierno y vetos)?, ¿qué hacemos si **no nos ponemos de acuerdo** (deadlock)?, y —lo más importante— **¿cómo nos divorciamos** sin destruirnos (salida)? Nadie se casa pensando en el divorcio, pero el abogado que **no** diseña el divorcio condena a sus clientes a una guerra si la relación se agria. La JV es **diseñar el matrimonio Y el divorcio, antes de la boda**.

La metáfora de los engranajes (para el espectro de colaboración). Imagina dos máquinas (empresas) que quieren trabajar juntas. Pueden: **rozarse** (un contrato de suministro: se tocan en un punto, cada una gira por su lado), **engranarse parcialmente** (una alianza: comparten algunos dientes), o **fundir un engranaje común** (una JV: construyen una pieza nueva que ambas mueven). Cuanto más se integran, más valor combinado pueden crear —pero más difícil es **separarse** sin romper algo—. El abogado elige **cuánto** deben engranarse según el objetivo.

La metáfora del condominio (para el deadlock). Una JV 50/50 es como un edificio con **dos dueños al 50%**: para cualquier decisión importante (pintar, vender, rentar) necesitan **ponerse de acuerdo**. Si no lo logran, el edificio se **deteriora** mientras pelean (deadlock). Por eso pactan, de antemano, una regla: "si no nos ponemos de acuerdo, uno le **compra** al otro a un precio justo (ruleta rusa) o **vendemos**". El mecanismo de deadlock es el **plan de emergencia** para que el desacuerdo no pudra el activo común.

La intuición central: colaborar es más difícil de estructurar que comprar, porque nadie manda del todo y la relación dura. En el M&A, el control resuelve los conflictos (manda el dueño); en la JV, el control está **compartido**, así que los conflictos hay que **resolverlos por contrato, anticipadamente**. El valor del abogado de JV está, sobre todo, en **prever el con-**

flicto (gobierno, deadlock, salida) y en elegir el **grado de integración** correcto (del contrato de suministro a la equity JV). Quien domina esto sabe estructurar **relaciones de poder compartido** —el reto más fino del derecho corporativo—.

16. Ejemplos simples

Ejemplo 1 — La JV de internacionalización. Una empresa europea de alimentos quiere entrar a México pero no conoce el mercado ni los canales. Se **alía** (equity JV 50/50) con un distribuidor mexicano: la europea aporta **marca y producto**; el mexicano, **red de distribución y conocimiento del mercado**. Crean una JV co que comercializa los productos en México. Ninguno lo habría hecho igual de bien solo.

Ejemplo 2 — El consorcio para una licitación. Tres constructoras se unen en un **consorcio contractual** (sin crear sociedad) para participar juntas en la licitación de una carretera: una aporta experiencia en túneles, otra en pavimentos, otra capacidad financiera. Si ganan, ejecutan la obra juntas bajo el consorcio. Colaboración **acotada al proyecto**.

Ejemplo 3 — El suministro take-or-pay. Una planta de energía firma un contrato de **suministro de gas** de 15 años con cláusula **take-or-pay**: pague o no use todo el gas, **paga** un mínimo. Esto le da al proveedor (que invirtió en un gasoducto) **ingresos garantizados** para financiar su inversión, y a la planta, **abasto asegurado**. Colaboración de largo plazo que **hace bancable** el proyecto.

Ejemplo 4 — La distribución exclusiva. Un fabricante de maquinaria nombra a una empresa como su **distribuidor exclusivo** en el sureste: el distribuidor compra y revende, no puede vender máquinas de competidores, y tiene metas mínimas de compra. Acceso al mercado para el fabricante; un negocio para el distribuidor.

17. Ejemplos complejos

Ejemplo complejo 1 — La JV con deadlock que se activa. Dos socios al 50/50 en una JV de manufactura no se ponen de acuerdo: uno quiere **reinvertir** todas las utilidades para cre-

cer; el otro quiere **repartir** dividendos. El consejo paritario se **empata**; la JV se paraliza. El contrato preveía escalamiento a los presidentes (fracasa) y luego una **ruleta rusa**: el socio A ofrece comprar la parte de B (o venderle la suya) a \$100M. B, que tiene caja, **compra** a ese precio. La JV pasa a un solo dueño y se desbloquea. *Lección*: sin el mecanismo, la parálisis habría destruido el negocio; con él, el conflicto se resolvió (uno salió, pagado a un precio que él mismo aceptó implícitamente al no fijarlo más alto).

Ejemplo complejo 2 — La JV y el derecho de la competencia. Dos **competidores** en el mercado de bebidas quieren crear una JV para **producir juntos** los envases (un insumo común), buscando ahorros de escala. *Riesgos*: (i) la JV podría ser una **concentración notificable** a la COFECE; (ii) más grave, al colaborar, los competidores **intercambian información sensible** (costos, volúmenes) que podría facilitar una **colusión** en el mercado de bebidas (donde siguen compitiendo). *Solución*: limitar el *scope* de la JV **estrictamente** a los envases; establecer **murallas de información** (que la JV no sea un canal para coordinar precios de bebidas); notificar a la COFECE; y asesoría de competencia continua. *Lección*: la colaboración entre competidores camina por la **línea fina** entre la sinergia lícita y la colusión ilícita.

Ejemplo complejo 3 — La JV tecnológica y la PI. Una empresa con **tecnología** y otra con **capital y mercado** crean una JV para desarrollar y vender un producto. Años después, la JV ha desarrollado **mejoras valiosas** sobre la tecnología original. Surge el conflicto al querer salir: ¿de quién es la **PI creada** por la JV?, ¿puede el socio tecnológico **llevarse** las mejoras?, ¿puede el otro **seguir usándolas**? *Lección*: si la PI (aportada, creada, mejoras, licencias de salida) **no se pactó con precisión al inicio**, la salida se convierte en una guerra. En las JV tecnológicas, la **cláusula de PI** es tan importante como la de precio.

18. Casos reales (operaciones estilizadas y referentes)

Nota de método (Manifiesto XI.5): casos estilizados con fines didácticos; verifica los detalles antes de citarlos profesionalmente.

Sony Ericsson: la JV que funcionó (y luego se deshizo ordenadamente). Sony (electrónica de consumo) y Ericsson (telecomunicaciones) crearon una **JV 50/50** para fabricar teléfonos móviles, combinando las fortalezas de ambos. Operó exitosamente durante una década y luego, cuando la estrategia de los socios divergió, Sony **compró** la parte de Ericsson (ejerciendo, en esencia, una salida pactada). *Lección:* una JV bien diseñada **crea valor mientras los intereses se alinean** y prevé una **salida ordenada** cuando divergen —el ciclo natural de muchas JV—.

Las JV de internacionalización en México (automotriz, consumo, energía). Innumerables empresas extranjeras entraron a México vía JV con socios locales (por estrategia o por requisitos de inversión extranjera en ciertos sectores). *Lección:* la JV es **el vehículo clásico de la inversión extranjera directa**, y el abogado mexicano que la domina participa en la entrada de capital global al país.

Las JV que terminaron en conflicto (lección de lo que falla). Muchas JV célebres fracasaron no por mala idea de negocio, sino por **choques culturales y de gobierno** y por **mecanismos de salida mal diseñados** (socios atrapados en un deadlock sin salida, o peleando por la PI). *Lección:* el éxito de una JV depende tanto de la **química entre socios** como de la **calidad jurídica** de su gobierno y sus salidas. El abogado no puede dar la química, pero **sí** puede —y debe— dar las salidas.

Y el destino de la JV paritaria sin válvula de escape: la disolución judicial. Cuando un 50/50 se bloquea y no hay mecanismo pactado, el conflicto no se resuelve en la asamblea: migra a un tribunal. Y ese camino tiene tres características que conviene explicarle al cliente **antes** de que acepte la paridad sin desempate:

- **Es lento.** Años, durante los cuales la empresa no invierte, no contrata y pierde clientes.
- **Destruye valor.** Lo que se reparte al final es una empresa deteriorada, no la que estaba en disputa.
- **Y el resultado no lo controlan las partes.** Deciden terceros, con información incompleta y criterios generales.

La jurisprudencia comparada sobre sociedades cerradas — los casos de **opresión de minorías** y de disolución por bloqueo— existe precisamente porque este escenario es frecuente. Pero acudir a ella es haber perdido: **es el remedio para quien no diseñó el mecanismo.**

La conclusión del libro, en una línea: un 50/50 sin válvula de escape no es un acuerdo entre iguales. Es una bomba de tiempo con dos llaves y ninguna cerradura.

19. Casos empresariales

La empresa familiar que se alía en vez de vender. Una empresa familiar mexicana, líder regional, recibe una oferta de compra de una multinacional. En vez de **vender** (perder el negocio de la familia), negocia una **JV**: la multinacional aporta capital, tecnología y mercados internacionales; la familia conserva el 50% y el conocimiento del mercado local. La familia **crece con un socio global sin dejar de ser dueña**. *Lección:* la JV es una **alternativa a vender** para quien quiere crecer conservando participación y control —relevante para empresas familiares—.

El proveedor que asegura su futuro con un contrato estratégico. Un fabricante de autopartes depende de un solo gran cliente (una armadora). Para reducir el riesgo, negocia un **contrato de suministro de largo plazo** con volúmenes mínimos y fórmula de precio indexada: asegura ingresos por años y **hace bancable** su inversión en una nueva planta (el contrato de largo plazo sirve de respaldo para el financiamiento —conexión con el Libro 5—). *Lección:* un contrato estratégico bien estructurado **estabiliza el negocio y habilita el financiamiento**.

20. Casos corporativos (la conexión integral)

Integremos todo el Nivel IV en una operación. *GlobalTech* (extranjera, con tecnología) y *MexCorp* (mexicana, con mercado y

capital) crean una **JV** para fabricar y vender equipos en México, financiada en parte con deuda.

- **Libros 1-2 (M&A, Due Diligence):** cada socio hace **due diligence** del otro y de los activos que se aportarán (la tecnología de GlobalTech, la red de MexCorp).
- **Libro 3 (Estructuras):** se decide el **vehículo**: una **S.A.P.I.** (JV co) por la validez que da a las cláusulas de socios; se estructuran las **aportaciones** (GlobalTech aporta PI y licencia tecnología; MexCorp aporta capital y una planta vía escisión).
- **Libro 4 (Documentación):** el **convenio de JV** funciona como un **SHA** (gobierno paritario, vetos, **deadlock** —ruleta rusa—, drag/tag, put/call); se firman los **contratos relacionados** (licencia de tecnología de GlobalTech a la JV, suministro, distribución), a precio de mercado.
- **Libro 5 (Financiamiento):** la JV co toma un **crédito** para construir, garantizado con sus activos (fideicomiso, prenda); los socios dan **garantees** proporcionales.
- **Libro 6 (este):** se integra todo en la **arquitectura de la colaboración**, cuidando el **derecho de la competencia** (scope acotado, murallas de información si los socios compiten en algo) y la **inversión extranjera**.

Moraleja: la JV es la operación que **sintetiza toda la formación** del abogado corporativo: due diligence, estructura, SHA, contratos estratégicos y financiamiento, **combinados** al servicio de una alianza. El que la domina ha integrado **todo** el Nivel IV —y es, en formación, el **especialista en operaciones corporativas complejas** que persigues—.

21. Casos internacionales

Las JV como vehículo global de inversión extranjera. En muchos países (China es el ejemplo histórico más citado, pero aplica en numerosos mercados emergentes), la JV con un socio local fue —o sigue siendo— **obligatoria o muy conveniente** para entrar a sectores estratégicos. *Lección:* el abogado de JV opera en un campo intrínsecamente **internacional**, donde se

cruzan el derecho local de inversión extranjera, el societario y el de competencia.

Los choques culturales y la *governance* en JV transfronterizas. La experiencia global muestra que las JV internacionales fracasan, sobre todo, por **diferencias culturales y de estilo de gestión** entre socios de distintos países (ritmo de decisión, tolerancia al riesgo, formalidad). *Lección:* el abogado que estructura una JV transfronteriza debe diseñar un **gobierno** que funcione pese a esas diferencias (mecanismos claros de decisión y de resolución de conflictos) y entender que el **idioma del contrato** (inglés) y la **ley aplicable** y el **arbitraje** internacional son decisiones críticas.

El escrutinio global de la colaboración entre competidores. Las autoridades de competencia de todo el mundo (la COFECE en México, la Comisión Europea, el DOJ/FTC en EE.UU.) vigilan que las JV y alianzas entre competidores **no se conviertan en colusión**. Las JV grandes a menudo requieren autorización en **varias jurisdicciones** a la vez. *Lección:* estructurar una alianza internacional entre competidores exige coordinar el análisis de competencia **multijurisdiccional** — una capa de complejidad que distingue al abogado sofisticado —.

22. Derecho comparado

Las estructuras de colaboración existen en todos los sistemas; cambian los vehículos típicos y el rigor del control de competencia. Tabla comparada:

JURISDICCIÓN / SISTEMA	TRATAMIENTO DE JV Y CONTRATOS ESTRATÉGICOS
México (Civil Law)	JV como operación (no contrato típico único): se usa S. de R.L./S.A./S.A.P.I. (equity JV) o asociación en participación /consorcio (contractual JV). Convenio de socios validado por la S.A.P.I. (LMV) . Distribución/suministro mayormente atípicos (autonomía de la voluntad); franquicia regulada (LPD). Control de competencia: LFCE/COFECE .
EE.UU. (Common Law)	JV vía LLC (muy flexible, el vehículo preferido) o <i>partnership/corporation; operating agreement</i> detalladísimo. Distribución/franquicia con regulación estatal y federal; fuerte antitrust (Sherman Act) sobre JV entre competidores y restricciones verticales.
Reino Unido (Common Law)	JV vía <i>limited company</i> o LLP ; <i>shareholders'/JV agreement</i> muy desarrollado; régimen de competencia (CMA) y de la UE históricamente influyente.
España / UE (Civil Law)	JV vía sociedades (S.L./S.A.) o UTE (Unión Temporal de Empresas, para obras/proyectos —análoga al consorcio—); fuerte control de concentraciones y de acuerdos restrictivos (Comisión Europea); reglamentos de exención por categorías para acuerdos verticales y de I+D.
Unión Europea	Marco robusto: control de concentraciones (las <i>full-function JV</i> se notifican), y reglamentos de exención (vertical, I+D, especialización) que dan "puerto seguro" a ciertas alianzas; doctrina muy desarrollada sobre cooperación entre competidores.
UNIDROIT / soft law	Principios sobre contratos comerciales internacionales (buena fe, interpretación) aplicables a JV y alianzas transfronterizas; guías sobre contratos de largo plazo.
Civil Law vs. Common Law (síntesis)	El common law ofrece vehículos flexibilísimos (LLC, LLP) y una cultura contractual exhaustiva; el civil law usa sus sociedades y figuras como la A en P / UTE. En ambos, el derecho de la competencia es el límite clave, y la documentación de JV internacional converge (en inglés, con arbitraje).

Lección comparada: dos vehículos que el abogado mexicano debe conocer: la **LLC** estadounidense (el vehículo de JV más flexible del mundo —su *operating agreement* inspira la práctica) y la **UTE** española (para colaboraciones temporales en obras, análoga a nuestro consorcio). Y la constante global: la JV entre competidores y las cláusulas de exclusividad están **siempre** bajo la lupa del derecho de la competencia.

23. Derecho mexicano

En México, las estructuras de colaboración se arman combinando estas fuentes:

- **Autonomía de la voluntad (CCF, Código de Comercio):** base de la JV contractual y de los contratos estratégicos atípicos (distribución, suministro, alianzas).
- **LGSM:** para la **equity JV**, se constituye una sociedad (**S. de R.L.** —flexible, ideal para JV; ventajas fiscales para socios de EE.UU.—, **S.A.** o **S.A.P.I.**); el convenio de socios funciona como **SHA**.
- **Asociación en Participación (LGSM):** vehículo de la **JV contractual** sin personalidad jurídica (asociante + asociados).
- **Contratos mercantiles (Código de Comercio y leyes especiales):** la **comisión** (agencia), el **suministro** y la **distribución** (atípicos, regidos por la voluntad y por analogía); la **franquicia** (Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial).
- **Propiedad intelectual (LFPPI, Ley Federal del Derecho de Autor):** licencias y transferencia de tecnología, marcas, patentes.
- **Ley Federal de Competencia Económica (LFCE):** **concentraciones** (JV notificables), **prácticas monopolísticas absolutas** (colusión entre competidores —gravísima—) y **relativas** (restricciones verticales: exclusividad, fijación de precio de reventa, ventas atadas).
- **Ley de Inversión Extranjera:** límites y condiciones a la participación de socios extranjeros en la JV.
- **Ley de Adquisiciones y Ley de Obras Públicas:** para **consorcios** que participan en licitaciones públicas.

Nota de método: la JV es una **operación a la medida**; verifica el texto vigente de la LGSM, la LFCE, la LFPPI y la Ley de Inversión Extranjera, y estructura **con el fiscalista**, antes de aplicar (Manifiesto XI.5).

24. Jurisprudencia relevante

Nota de método: verifica vigencia y datos de identificación antes de citar.

Criterios mexicanos relevantes (en las figuras que sostienen la colaboración):

- **Asociación en participación:** naturaleza, efectos frente a terceros y entre las partes, y su tratamiento (incluido el fiscal).
- **Contratos atípicos (distribución, suministro):** criterios sobre su validez, interpretación (integración por la buena fe y los usos) y las **consecuencias de la terminación** (indemnización al distribuidor por clientela, preavisos razonables).
- **Convenios entre accionistas (S.A.P.I. / LMV):** validez de las cláusulas de gobierno, vetos y transmisión que rigen la equity JV.
- **Prácticas monopólicas (LFCE):** criterios de la COFECE y de los tribunales sobre concentraciones, colusión entre competidores y restricciones verticales (cuándo una exclusividad o una fijación de precios daña la competencia).
- **Cláusula compromisoria / arbitraje:** validez y alcance del arbitraje en disputas de JV y contratos estratégicos (foro habitual de estos conflictos).

En el ámbito internacional, la práctica de los **JV agreements** (LLC operating agreements, shareholders' agreements) y la doctrina de competencia de la UE y EE.UU. sobre cooperación entre competidores son referencia obligada.

25. Criterios de la Suprema Corte / reguladores

- **SCJN / tribunales:** criterios sobre **contratos atípicos** (distribución, suministro), **asociación en participación**, interpretación contractual y consecuencias de la terminación de relaciones de largo plazo.
- **COFECE (el regulador clave):** guías y resoluciones sobre **concentraciones** (cuándo una JV es notificable), **prácticas monopólicas absolutas** (colusión disfrazada de colabora-

ción) y **relativas** (restricciones verticales en distribución/ suministro). Su criterio **condiciona el diseño** de toda alianza entre competidores.

- **IMPI:** registro y disputas de **licencias** de marcas y patentes y de **franquicias**.
- **Comisión de competencia / reguladores sectoriales:** en energía, telecom, etc., autorizaciones de consorcios y JV.

26. Doctrina nacional

La doctrina mexicana sobre JV y contratos estratégicos proviene del **derecho mercantil y societario** (la sociedad como vehículo de la equity JV, la asociación en participación), del **derecho de contratos** (los atípicos: distribución, suministro, las reglas de integración e interpretación) y, crecientemente, del **derecho de la competencia** (el análisis de concentraciones y restricciones). A esto se suma el **know-how transaccional** de los despachos corporativos, que han adaptado los *JV agreements* internacionales al marco mexicano y desarrollado la práctica de estructurar coinversiones (especialmente de inversión extranjera). La doctrina de **propiedad intelectual** aporta el tratamiento de las licencias y la transferencia de tecnología.

27. Doctrina internacional

- **Doctrina y modelos de *JV agreements* (LLC operating agreements, shareholders' agreements).** El "cómo" práctico de estructurar el gobierno, el deadlock y la salida de una JV; material de los grandes despachos.
- **Doctrina de derecho de la competencia (UE — directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal; EE.UU. — *antitrust guidelines for collaborations among competitors*).** El marco para estructurar alianzas entre competidores sin violar la competencia.
- **Doctrina de *alliance management y strategy* (Harvard, INSEAD).** Por qué las alianzas crean valor y por qué fracasan (la dimensión estratégica y cultural, más allá de lo jurídico).

- **Doctrina de contratos internacionales (UNIDROIT, ICC — contratos modelo de distribución, agencia, JV—).** Modelos y principios para la colaboración transfronteriza.
- **Doctrina de propiedad intelectual y licencias.** El tratamiento de la PI aportada, creada y las mejoras en alianzas tecnológicas.

28. Opiniones críticas (postura del Consejo Editorial)

Primero: colaborar es más difícil de estructurar que comprar, y se subestima. Sostenemos que muchos abogados tratan la JV como "una sociedad más" y descuidan lo esencial: el **gobierno compartido** y, sobre todo, las **salidas**. Una JV sin mecanismos de deadlock y salida bien diseñados es una **bomba de tiempo**.

Segundo: diseña el divorcio antes de la boda. Insistimos: el mayor valor del abogado de JV está en **anticipar el conflicto**. No es pesimismo: es realismo. La mayoría de las JV atraviesan tensiones; las que sobreviven (o se separan sin destruir valor) son las que **pactaron las salidas desde el inicio**.

Tercero: cuidado con la línea de la competencia. Advertimos con firmeza: la colaboración entre **competidores** camina por una línea fina. Una JV legítima puede degenerar en un **canal de colusión** (intercambio de información sensible, coordinación de precios). El abogado debe acotar el *scope*, levantar **murallas de información** y vigilar el cumplimiento de la LFCE —porque las prácticas monopólicas absolutas son de las infracciones **más graves** (sanciones enormes, incluso penales) —.

Cuarto: la PI y los contratos relacionados valen tanto como el convenio de JV. Criticamos que se ponga toda la atención en el convenio principal y se descuiden los *ancillary agreements* (licencia, suministro, distribución entre la JV y los socios) y la **propiedad intelectual** (aportada, creada, mejoras). Ahí se extrae —o se destruye— valor, y ahí nacen los litigios al separarse.

Quinto: elige bien el grado de integración. No toda colaboración debe ser una equity JV. A veces un **contrato de sumi-**

nistro o una alianza logra el objetivo con menos costo y rigidez. El abogado sofisticado recomienda el **mínimo de integración** que cumple el objetivo —ni más (rigidez) ni menos (ambigüedad)—.

Y la crítica que hay que decirle al cliente antes de firmar: las JV fracasan mucho. La tasa de fracaso de las alianzas es notoriamente alta $\triangle$ —las estimaciones varían según cómo se defina el fracaso—, y las causas se repiten con una monotonía que debería alertarnos:

- **Nacen por moda o por miedo:** "aliarse con el líder del sector" sin haber resuelto qué decide cada quién.
- **Asimetría de aportaciones:** uno aporta dinero y el otro "conocimiento del mercado". La segunda aportación se agota; la primera queda en el balance.
- **Hold-up progresivo:** la relación se desequilibra a medida que uno invierte en activos específicos.
- **Y un sesgo conductual bien documentado:** al negociar, las partes **sobreestiman la cooperación futura y subestiman el conflicto**. Están en su mejor momento, con expectativas altas, y la conversación sobre la ruptura se siente desleal. Es exactamente el momento en que hay que tenerla.

Postura del Consejo: la contribución más valiosa del abogado en una JV no es redactar bien el objeto social. Es **insistir, contra la incomodidad de todos, en que se pacte la salida** — y hacerlo con el argumento correcto, que no es de desconfianza sino de simetría: "*la salida se negocia ahora porque ahora los dos tienen el mismo poder; dentro de tres años, no.*" Ese encuadre está en el módulo 04 de la Columna VI.

29. Debate doctrinal

- **¿Equity JV o contractual JV?** ¿Crear una sociedad (institucional, sólida, rígida) o colaborar solo por contrato (flexible, pero sin personalidad ni separación patrimonial clara)? *Postura del Consejo:* depende de la **duración, escala y necesidad de financiarse y de activos propios**: equity JV para lo duradero y grande; contractual (A en P/consorcio) para lo acotado y temporal.

- **¿Cómo diseñar el deadlock sin favorecer al más rico?** Los mecanismos de compra-venta forzosa (ruleta rusa) **favorecen a quien tiene más caja**. *Postura del Consejo:* deben calibrarse con **valuación independiente**, plazos y excepciones para proteger al socio financieramente más débil; o preferir mecanismos menos brutales (mediación, experto) antes de la opción nuclear.
- **¿Hasta dónde la exclusividad y la no competencia?** Las cláusulas que canalizan negocio a la JV y prohíben competir con ella crean valor, pero **restringen la competencia**. *Postura del Consejo:* deben ser **razonables y proporcionales** (en objeto, tiempo, territorio) para no caer en práctica monopólica; acotadas a lo necesario para proteger la JV.
- **¿De quién es la PI creada por la JV?** *Postura del Consejo:* no hay respuesta única (puede ser de la JV, repartida, o licenciada a los socios), pero **debe pactarse con precisión desde el inicio** —incluido qué pasa con las **mejoras** y al **terminar**—; la ambigüedad es la causa número uno de litigios al salir.
- **Colaboración vs. colusión: ¿dónde está la línea?** *Postura del Consejo:* la línea está en si la alianza **crea eficiencias reales** (sinergias, nuevos productos, ahorros que benefician al mercado) o si **solo sirve para reducir la competencia** (coordinar precios, repartir mercados). Lo primero es legítimo; lo segundo, gravísimo. El abogado debe asegurar que la JV esté del lado correcto —y poder **demostrarlo**—.

30. Errores comunes

- **No diseñar la salida.** Crear una JV sin mecanismos de **deadlock** y **exit** claros: cuando surge el conflicto, los socios quedan atrapados y el valor se destruye. *Corrección:* pacta deadlock, put/call, drag/tag y disolución **desde el inicio**.
- **Gobierno paritario sin desempate.** Una JV 50/50 con consejo paritario y sin mecanismo de deadlock se **paraliza** ante el primer desacuerdo. *Corrección:* prevé escalamiento, experto y compra-venta forzosa.

- **Ignorar el derecho de la competencia.** Estructurar una JV o exclusividad entre competidores sin análisis de la LFCE → riesgo de concentración no notificada o, peor, **colusión**. *Corrección:* acota el *scope*, levanta murallas de información, notifica si procede.
- **PI mal pactada.** No definir de quién es la PI aportada, creada y las mejoras → guerra al separarse. *Corrección:* cláusula de PI precisa desde el inicio.
- **Descuidar los contratos relacionados.** Olvidar que los contratos entre la JV y los socios (licencia, suministro) deben ser a **precio de mercado** → un socio extrae valor del otro. *Corrección:* *arm's length* y aprobación por el socio no interesado.
- **Sobre-integrar o sub-integrar.** Crear una equity JV pesada cuando bastaba un contrato de suministro (rigidez innecesaria), o una alianza informal cuando se necesitaba una sociedad (ambigüedad). *Corrección:* elige el **grado de integración** adecuado al objetivo.
- **MOU que obliga sin querer.** Redactar una carta de intención que parezca un acuerdo cerrado. *Corrección:* cláusula expresa de "no vinculante" salvo confidencialidad/exclusividad (eco del Term Sheet).
- **Subestimar el factor cultural.** Confiar solo en el contrato e ignorar el choque de culturas de gestión (causa frecuente de fracaso en JV internacionales). *Corrección:* gobierno claro + mecanismos de resolución + realismo sobre la relación.

31. Mitos frecuentes

- **"Una JV es solo una sociedad más." Falso.** Es una **relación de poder compartido y de largo plazo**; su dificultad está en el gobierno y, sobre todo, en las salidas —no en constituir la sociedad—.
- **"Si confiamos el uno en el otro, no hace falta pactar las salidas." Falso/peligroso.** La confianza no basta: las JV se tensionan, y el que no diseñó el divorcio termina en guerra. Diseñar la salida **protege** la relación.

- **"Colaborar siempre es mejor que ir solo." Falso.** Colaborar tiene costos (coordinación, conflictos, oportunismo); conviene solo cuando combinar recursos crea más valor que esos costos.
- **"Distribución, agencia y franquicia son lo mismo." Falso.** El distribuidor compra para revender (riesgo propio); el agente vende por cuenta del principal (comisión); el franquiciatario opera un modelo bajo licencia. Son figuras distintas con consecuencias distintas.
- **"La JV entre competidores no tiene problema si es para un fin legítimo." Falso/matizado.** Aun con fin legítimo, puede ser concentración notificable y, si facilita intercambio de información sensible o coordinación, derivar en colusión. Hay que estructurarla con cuidado.
- **"Un MOU no obliga a nada." Falso.** Sus cláusulas de confidencialidad y exclusividad **sí** vinculan, y uno mal redactado puede generar responsabilidad precontractual.

32. Preguntas difíciles

1. **¿Por qué la JV es más difícil de estructurar que una adquisición?** Porque en el M&A **uno manda** (el comprador controla) y la **relación termina** (el vendedor se va); en la JV el **control es compartido** y la relación es de **largo plazo**, así que los conflictos no los resuelve un jefe, sino que hay que **anticiparlos y regularlos por contrato** (gobierno, deadlock, salida).
2. **¿Cómo evitar que una JV entre competidores se vuelva colusión?** Acotando el **scope** estrictamente al objeto de la JV; levantando **murallas de información** (que los datos sensibles de la JV no fluyan a las áreas comerciales que compiten); notificando a la COFECCE si es concentración; y vigilando que la JV no sea un foro para coordinar precios o repartir mercados.
3. **¿Por qué la ruleta rusa incentiva un precio justo?** Porque el socio que **fija** el precio no sabe si el otro **comprará** o **venderá** a ese precio: si lo pone muy bajo, el otro le compra ba-

rato (pierde); si muy alto, el otro le vende caro (paga de más). El equilibrio es un **precio justo**.

4. **¿Equity JV o contractual JV para un consorcio que va a una licitación de obra?** Normalmente **contractual** (consorcio / A en P): es una colaboración **acotada al proyecto y temporal**; crear una sociedad sería costoso y rígido para algo con fin y plazo definidos.
5. **¿Por qué la PI es el punto más litigado al disolver una JV tecnológica?** Porque la JV genera **valor intangible** (mejoras, desarrollos, know-how conjunto) cuya **titularidad y uso futuro**, si no se pactaron con precisión, ambos socios reclaman. Resolver la PI **al inicio** (aportada, creada, mejoras, licencias de salida) evita la guerra.

33. Casos de examen (con respuesta modelo)

Caso A. *Una empresa extranjera quiere entrar a México aliándose con un socio local 50/50. Te piden estructurar la JV. ¿Qué es lo más importante que debes resolver?* **Respuesta modelo:** Tres ejes. **(1) Vehículo:** una **S.A.P.I.** (por la validez que da a las cláusulas de socios) o **S. de R.L.** **(2) Gobierno:** consejo **paritario** con **materias reservadas/vetos** claras y, crucial, un **mecanismo de deadlock** (escalamiento → experto → ruleta rusa) para la parálisis 50/50. **(3) Salida:** lock-up, ROFR, tag/drag, **put/call** (típico: el extranjero con opción de comprar al local en X años). Más: **contratos relacionados** (licencia/suministro) a precio de mercado, **PI** bien pactada, y revisión de **inversión extranjera y competencia**. Razonar: el control compartido y la salida son lo crítico.

Caso B. *Dos competidores quieren crear una JV para producir juntos un insumo común. ¿Qué riesgo dominante hay y cómo lo manejas?* **Respuesta modelo:** El riesgo dominante es de **competencia económica**: (i) la JV puede ser una **concentración notificable** a la COFECE; (ii) más grave, al colaborar, los competidores podrían **intercambiar información sensible y coludirse** en el mercado donde compiten (práctica monopólica absoluta, gravísima). *Manejo:* limitar el **scope** estrictamente al insumo; **murallas de información**; notificar a la COFECE;

asesoría de competencia continua. La colaboración debe crear **eficiencias reales**, no reducir la competencia.

Caso C. *Un fabricante quiere asegurar la venta de su producción a un gran comprador por 10 años. ¿Qué contrato propones y qué cláusulas son clave?* **Respuesta modelo:** Un **contrato de suministro** de largo plazo. Cláusulas clave: **volumen** (mínimos, posible **take-or-pay** que garantice ingresos y haga **banca-ble** la inversión del fabricante), **precio** (fórmula **indexada** para la volatilidad de 10 años), **exclusividad** (con cuidado de competencia), **calidad/entrega**, **fuerza mayor**, y **terminación/incumplimiento**. Conectar: un suministro take-or-pay puede respaldar el **financiamiento** (Libro 5) de la planta.

34. Simulador (ejercicio tipo despacho)

Instrucciones: eres asociado. Tu cliente, una empresa **mexicana de tecnología**, quiere aliarse con una **multinacional** para desarrollar y vender un producto en México: la multinacional aporta capital y tecnología base; tu cliente, conocimiento del mercado y desarrollo local. Estructura la colaboración antes de leer la guía.

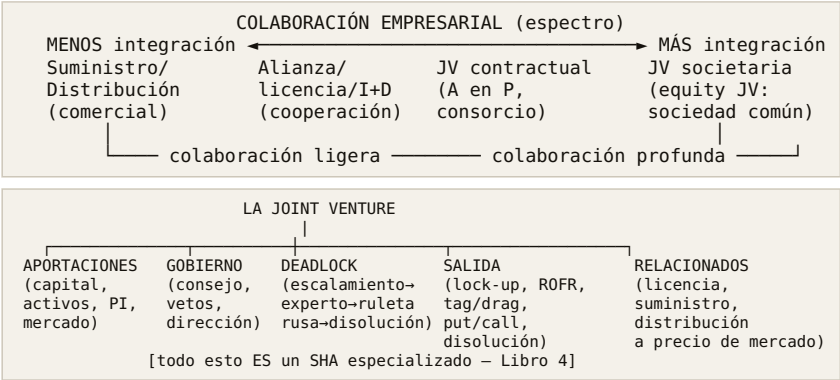
1. ¿**Colaborar o vender**? ¿Qué grado de integración propones?
2. ¿Qué **vehículo** (equity vs. contractual; qué tipo de sociedad)?
3. ¿Cómo diseñas el **gobierno** y el **deadlock**?
4. ¿Cómo resuelves la **propiedad intelectual** (aportada, creada, mejoras, al salir)?
5. ¿Qué **límites regulatorios** revisas?

Guía de solución (resumen). (1) Colaborar (no vender: el cliente quiere participar del upinside y conservar su desarrollo); **equity JV** (duradera, con activos y financiamiento). (2) **S.A.P.I.** (valida vetos, drag/tag, put/call). (3) Consejo **paritario** o según aportaciones; **vetos** sobre decisiones clave; **deadlock**: escalamiento → mediación/experto → ruleta rusa; **salida**: lock-up, ROFR, tag/drag, put/call. (4) **PI aportada** vuelve a su dueño; **PI creada** por la JV → de la JV, con **licencias de salida** a ambos socios; **mejoras** → reglas de *grant-back*; todo pactado al inicio. (5) **Inversión extranjera** (participación del socio extranjero), **competencia** (si compiten en algo, scope acotado + murallas), **PI/IMPI** (registro de licencias), y **fiscal** (con el fiscalista).

35. Flashcards

- **¿Tres caminos de crecimiento?** Comprar (M&A), construir (orgánico + deuda), colaborar (JV/contratos estratégicos).
- **¿Equity JV vs. contractual JV?** Crean una sociedad (accionistas) vs. colaboran solo por contrato (A en P/consorcio, sin sociedad).
- **¿Por qué la JV es difícil?** Control **compartido** + relación de **largo plazo** → hay que anticipar el conflicto por contrato.
- **¿Qué es el deadlock y cómo se resuelve?** Bloqueo en la decisión (50/50); se resuelve con escalamiento, experto y compra-venta forzosa (ruleta rusa, Texas shoot-out).
- **¿Por qué la ruleta rusa da precio justo?** El que fija el precio no sabe si comprará o venderá a ese precio → incentivo a ser justo.
- **¿Materias reservadas/vetos?** Decisiones que requieren acuerdo de ambos socios (protección del que no controla el día a día).
- **¿Distribución vs. agencia vs. franquicia?** Compra para revender (riesgo propio) / vende por cuenta del principal (comisión) / opera un modelo bajo licencia.
- **¿Take-or-pay?** El comprador paga un mínimo aunque no tome el producto (garantiza ingresos al proveedor).
- **¿Asociación en participación?** JV contractual sin personalidad: asociante (opera) + asociado (aporta, oculto).
- **¿Cuál es el límite regulatorio clave de las JV?** El **derecho de la competencia** (concentraciones y colusión entre competidores).
- **¿Qué es un MOU?** Documento preliminar de colaboración, no vinculante salvo confidencialidad/ exclusividad.
- **¿Qué integra una JV completa?** Estructura (L3) + SHA/go-bierno (L4) + contratos relacionados + a veces financiamiento (L5).

36. Mapas mentales



37. Cuadros comparativos

Comprar vs. Colaborar

	COMPRAR (M&A)	COLABORAR (JV)
Control	Total (uno manda)	Compartido
Relación	Termina (el vendedor se va)	Largo plazo
Conflictos	Los resuelve el dueño	Se anticipan por contrato
Documento	SPA/APA	Convenio de JV (≈ SHA)
Dificultad de estructura	Alta	Mayor (gobierno + salida)

Equity JV vs. Contractual JV

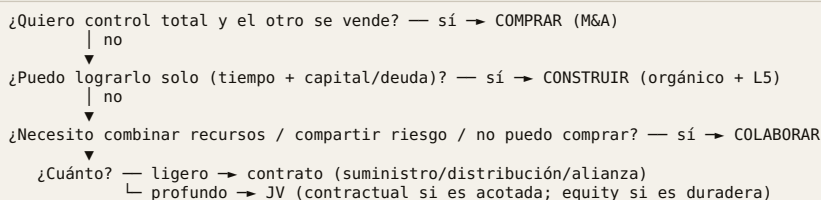
	EQUITY JV	CONTRACTUAL JV
Crea sociedad	Sí (JV co)	No
Personalidad jurídica	Sí	No
Responsabilidad	Limitada al capital	Directa/solidaria
Vehículo MX	S. de R.L./S.A./S.A.P.I.	A en P / consorcio
Mejor para	Largo plazo, gran escala	Proyecto acotado, temporal

Distribución vs. Agencia vs. Franquicia

	DISTRIBUCIÓN	AGENCIA	FRANQUICIA
Actúa	Por cuenta propia	Por cuenta del principal	Bajo modelo licenciado
Compra para revender	Sí	No	Opera el negocio
Gana	Margen de venta	Comisión	Utilidad (paga regalías)

38. Diagramas

Decisión: ¿comprar, construir o colaborar?



La JV integra todo el Nivel IV:

JOINT VENTURE = ESTRUCTURA (L3, el vehículo)
 + SHA/GOBIERNO+SALIDA (L4, el convenio de socios)
 + CONTRATOS RELACIONADOS (licencia/suministro/distribución)
 + FINANCIAMIENTO (L5, la JV co toma deuda)

al servicio de una ALIANZA ESTRATÉGICA

39. Mnemotecnias

- **Tres caminos (CCC):** Comprar · Construir · Colaborar.
- **La JV es un matrimonio:** "diseña el matrimonio Y el divorcio, antes de la boda".
- **Lo difícil de la JV:** "control compartido + largo plazo = anticipa el conflicto".
- **Deadlock (escala):** "hablar (escalamiento) → un tercero (experto/mediación) → separarse (ruleta rusa) → disolver".
- **Ruleta rusa:** "el que pone el precio no sabe si compra o vende: por eso es justo".
- **Distribución:** "compro para revender (riesgo mío), no vendo por cuenta ajena (agente)".
- **Competidores en JV:** "colaborar sí, coludir no: scope acotado y murallas de información".

- **MOU:** *"lo sustantivo no obliga; confidencialidad y exclusividad sí".*
- **Regla de oro:** *"colaborar es más difícil que comprar; el valor está en prever la salida".*

40. Resumen ejecutivo

Más allá de comprar (M&A) y financiar (deuda), la **tercera gran vía** de la estrategia corporativa es **colaborar**: unir fuerzas con otra empresa para crear valor sin que una compre a la otra. Este libro estudia ese espectro, del contrato de suministro a la joint venture societaria. La **joint venture (JV)** es la figura central: dos o más empresas unen recursos para un propósito común, compartiendo **control, utilidades y riesgos**. Puede ser **equity JV** (crean una sociedad —la *JV co*— de la que son socios; duradera, institucional, con personalidad propia, vía S. de R.L./S.A./S.A.P.I.) o **contractual JV** (colaboran solo por contrato, sin sociedad; flexible y acotada, vía asociación en participación o consorcio). El **contrato de JV** es, en esencia, un **SHA especializado** (Libro 4): regula las **aportaciones** (capital, activos, tecnología, mercado), el **gobierno compartido** (consejo, vetos), y —lo más difícil y característico— el **deadlock** (escalamiento → experto → ruleta rusa/shoot-out → disolución) y la **salida** (lock-up, ROFR, tag/drag, put/call). Junto a la JV, los **contratos estratégicos: distribución** (comprar para revender, distinta de la agencia y la franquicia), **suministro** (entrega continuada, con *take-or-pay*, precio indexado, exclusividad), **licencia** y transferencia de tecnología, **alianzas** de I+D, y los instrumentos preliminares (**MOU**, acuerdo marco, **NDA**).

La lección rectora: **colaborar es más difícil de estructurar que comprar**, porque nadie manda del todo y la relación es de largo plazo; por eso el mayor valor del abogado está en **anticipar el conflicto** —diseñar el gobierno, el deadlock y la salida antes de que surja el problema— y en elegir el **grado de integración** correcto. El límite regulatorio omnipresente es el **derecho de la competencia** (las JV entre competidores y las exclusividades pueden restringir la competencia o degenerar en colusión). Y la síntesis para tu perfil: la **JV integra todo el Nivel IV** —estructura (L3), SHA/gobierno (L4), contratos rela-

cionados y financiamiento (L5)— al servicio de una alianza. Quien la domina ha unido comprar, financiar y colaborar en un solo oficio: el de **estructurar operaciones corporativas complejas**.

41. Checklist

La decisión y el vehículo:

- [] ¿**Comprar, construir o colaborar**? Si colaborar, ¿qué **grado de integración** (suministro, alianza, JV contractual, equity JV)?
- [] ¿**Equity JV** (sociedad: S. de R.L./S.A./S.A.P.I.) o **contractual JV** (A en P/consorcio)? ¿Por qué?

El contrato de JV (gobierno y salida):

- [] ¿**Aportaciones** valuadas y porcentajes claros? ¿**Capital calls** futuros y consecuencias del que no aporta?
- [] ¿**Gobierno**: consejo, **materias reservadas/vetos**, dirección, información?
- [] ¿**Deadlock**: escalamiento → experto/mediación → compra-venta forzosa → disolución? ¿Calibrado para no favorecer al más rico?
- [] ¿**Salida**: lock-up, ROFR/ROFO, tag, drag, put/call, cambio de control del socio, default?
- [] ¿**PI** (aportada, creada, mejoras, al salir) pactada con precisión?
- [] ¿**Contratos relacionados** (licencia/suministro/distribución JV-socios) a **precio de mercado**?

Contratos estratégicos y límites:

- [] **Distribución/suministro**: ¿territorio, exclusividad, mínimos/take-or-pay, precio, terminación e indemnización?
- [] ¿Revisaste el **derecho de la competencia** (concentración notificable, colusión entre competidores, restricciones verticales)?
- [] ¿**Inversión extranjera** y normas **sectoriales**?
- [] **MOU/preliminares**: ¿claro qué es vinculante (confidencialidad/exclusividad) y qué no?

42. Bibliografía comentada

- **Doctrina y modelos de *Joint Venture Agreements* (y LLC operating agreements / shareholders' agreements).** El "cómo" práctico del gobierno, el deadlock y la salida; material de los grandes despachos.
- **Ley General de Sociedades Mercantiles (S. de R.L., S.A. y asociación en participación).** Los vehículos de la JV en México.
- **Ley del Mercado de Valores (S.A.P.I.).** El vehículo que valida las cláusulas de socios (vetos, drag/tag) de la equity JV.
- **Ley Federal de Competencia Económica y guías de la COFECE.** El límite clave: concentraciones, colusión y restricciones verticales en alianzas y distribución.
- **Directrices de cooperación horizontal (UE) y *Antitrust Guidelines for Collaborations* (EE.UU.).** El marco para estructurar alianzas entre competidores sin violar la competencia.
- **Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y doctrina de licencias.** PI aportada, creada, mejoras; franquicia.
- **Contratos modelo de la ICC (distribución, agencia, JV) y UNIDROIT.** Referencias para la colaboración internacional.

43. Ruta hacia el siguiente libro

Has completado la **familia contractual de tu perfil**: ya dominas comprar (Libros 1-4), financiar (Libro 5) y **colaborar** (este libro). El siguiente paso es entrar al mundo de los **inversionistas profesionales** que usan todas estas herramientas para crear valor: los fondos.

- **Siguiente libro:** *Libro 7 · Private Equity y Venture Capital* — cómo invierten los fondos de **capital privado** (PE) y de **capital de riesgo** (VC): la estructura del fondo (GP/LP), la tesis de inversión, las **rondas** de VC (semilla, Serie A, B...), los *term sheets* de inversión, las **preferencias de liquidación** y la **antidilución**, el **vesting** de fundadores, el **LBO** del PE (que ya viste en estructura y financiamiento), y las **salidas**

(venta, IPO). Es donde convergen el M&A, el SHA, el financiamiento y la JV en la lógica del **inversionista**.

- **Conexión inmediata:** la inversión de un fondo en una empresa **es** una operación que combina todo lo que ya sabes — una compra/suscripción (Libro 4), un **SHA** con preferencias y salidas (Libro 4), a veces **deuda/LBO** (Libros 3 y 5), y a menudo se estructura como una forma de **coinversión** (este libro)—. El Libro 7 te enseña a verlo desde el lado del **inversionista profesional**.

♦ ¿Por qué esto importa para un abogado corporativo?

Porque la colaboración —la JV, la alianza, el contrato estratégico— es la **tercera herramienta** del estratega corporativo, junto a comprar y financiar, y para tu perfil (contratos estratégicos + operaciones complejas) es **esencial**. Las JV son de las operaciones **más exigentes** que existen: combinan derecho societario, contractual, de competencia, fiscal, de PI e internacional, y son **a la medida** (no hay plantilla), lo que exige criterio y creatividad. Son, además, el **vehículo natural** de la internacionalización, de los grandes proyectos de infraestructura y energía, y de las alianzas tecnológicas —operaciones estratégicas de primer nivel—. Y forman al abogado en la habilidad más fina del gobierno corporativo: **estructurar relaciones de poder compartido y anticipar el conflicto**. El que domina la colaboración, sumada a la compra (Libros 1-4) y al financiamiento (Libro 5), maneja **todo el repertorio** de las operaciones corporativas complejas —exactamente el especialista que quieres ser—.

◆ Cómo piensa un socio de un despacho internacional

"Cuando un cliente me dice 'quiero hacer negocios con esta otra empresa', mi primera pregunta no es jurídica, es estratégica: ¿quieres comprarla, construir solo, o aliarte? Si la respuesta es aliarse, la segunda pregunta es ¿cuánto? —porque montar una equity JV para algo que un contrato de suministro resolvería es matar moscas a cañonazos—. Y si vamos a una JV de verdad, mi obsesión no es el día de la boda, sino el día del divorcio: paso más tiempo negociando el deadlock y las salidas que las cláusulas felices, porque sé que el 50/50 que hoy se quieren, mañana puede no ponerse de acuerdo en nada, y si no diseñé la salida, el activo común se pudre en la pelea. Vigilo tres cosas más como un halcón: el derecho de la competencia (si mi cliente y el socio compiten en algo, acoto el scope y levanto murallas de información —una JV no puede ser la coartada de una colusión—); la propiedad intelectual (de quién es lo que la JV cree, y quién se lo lleva al salir); y los contratos entre la JV y los socios, que deben ser a precio de mercado para que nadie ordeñe a la JV. Estructurar una JV es lo más cerca que estoy de ser arquitecto y consejero matrimonial a la vez."

◆ Errores que cuestan millones

1. **JV sin mecanismos de salida ni deadlock.** Socios atrapados en una parálisis 50/50 que destruye el negocio mientras pelean. *Prevención:* deadlock escalonado y salidas (put/call, drag/tag, disolución) desde el inicio.
2. **Cruzar la línea de la competencia.** Estructurar una alianza entre competidores que se convierte en canal de **colusión** (sanciones gravísimas, incluso penales). *Prevención:* scope acotado, murallas de información, notificación a la COFEC, eficiencias reales demostrables.
3. **PI mal pactada.** No definir de quién es lo que la JV crea ni qué pasa con las mejoras al salir → litigio feroz que destruye el valor. *Prevención:* cláusula de PI precisa al inicio.
4. **Contratos relacionados que ordeñan a la JV.** Permitir que un socio le venda/compre a la JV fuera de mercado, extrayendo valor del otro. *Prevención:* *arm's length* y aprobación del socio no interesado.

5. **Confundir el grado de integración.** Una equity JV rígida cuando bastaba un contrato (o una alianza informal cuando se necesitaba estructura). *Prevención:* el **mínimo de integración** que cumple el objetivo.

Cierre del Libro 6. Has completado la **tercera vía** de la estrategia corporativa —la colaboración— y, con ella, la **familia contractual de tu perfil**: de la JV societaria a la contractual, de la distribución al suministro estratégico, de las alianzas de I+D a los acuerdos marco. Más importante que las figuras, te llevas la lección de que **estructurar una relación de poder compartido y anticipar su ruptura** es uno de los retos más finos del derecho corporativo —y que la JV **sintetiza** todo lo aprendido: estructura, SHA, contratos y financiamiento al servicio de una alianza—. Ya manejas el repertorio completo: **comprar, financiar y colaborar**. Ahora subimos al lugar donde estas herramientas se usan con mayor intensidad y sofisticación: en el **Libro 7 · Private Equity y Venture Capital** aprenderás a verlas desde el lado del **inversionista profesional** que las combina para crear —y capturar— valor.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE IV

[Nivel IV · Libro 7] Private Equity y Venture Capital

☞ **Apóstrofe de vigencia** — **léela cada vez**. El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en ../../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

Hasta aquí aprendiste a **comprar** (M&A), **financiar** (deuda) y **colaborar** (JV). Ahora subes al lugar donde todas esas herramientas se usan con la **máxima intensidad y sofisticación**: el mundo de los **inversionistas profesionales**. El **private equity (PE)** y el **venture capital (VC)** son los fondos que invierten capital de terceros en empresas —maduras (PE) o emergentes (VC)— para hacerlas crecer y **venderlas con ganancia** años después. Para el abogado corporativo, son los **clientes más sofisticados y exigentes**, y dominar su lógica —cómo se estructura un fondo, cómo invierte, cómo se protege y cómo sale— es entrar a la élite de la práctica. Este libro reúne y eleva todo lo aprendido: el LBO (Libros 3 y 5), el SHA con sus preferencias y salidas (Libro 4) y la coinversión (Libro 6), vistos desde el lado del **fondo**.

Etiquetas: corporate law · private equity · venture capital · fondos · LBO · term sheet de inversión · cap table · exit **Prerrequisitos**: todo el Nivel IV previo, en especial Libro 3 · Estructuras, Libro 4 · Documentación (SHA), Libro 5 · Financiamiento (LBO) y Libro 6 · JV + Gobierno Corporativo y Mercado de Valores (LMV). **Estándar**: V3 (43 secciones + secciones transversales). ⌚ **Tiempo estimado de dominio**: 6–8 semanas (≈ 70–90 h de estudio activo). Lectura de reconocimiento: 12–15 h. *Estúdialo en bloques*: la lógica del fondo (GP/LP) → private equity y el LBO → venture capital y las rondas → el term sheet de

inversión (preferencias, antidilución, vesting) → el cap table y las salidas (exit).

Aviso de método. Tratado, no repaso. Aprenderás a pensar como el **inversionista profesional**: cómo levanta y estructura un fondo, cómo invierte (PE vía LBO; VC vía rondas), cómo se **protege** (preferencias, vetos, antidilución, vesting) y cómo **sale** (venta, IPO) —porque el retorno se realiza en la salida—. Cada figura reúne lo aprendido en todo el Nivel IV.

NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL (VISTA RÁPIDA)

Litigio	★★☆☆☆
Corporate	★★★★★
M&A	★★★★★
Mercado de Valores	★★★★☆
Venture Capital	★★★★★
Private Equity	★★★★★
Gobierno Corporativo	★★★★★
Compliance	★★★★☆
Derecho Bancario	★★★★☆
Empresa Familiar	★★★☆☆

Los fondos de PE/VC son los clientes más sofisticados y recurrentes del abogado corporativo de élite, y generan un flujo constante de operaciones (inversión, gestión, salida). Dominar su lógica es entrar al corazón de la práctica de operaciones complejas.

1. Introducción

El **private equity (PE)** y el **venture capital (VC)** son dos formas de **inversión de capital privado**: fondos que reúnen dinero de inversionistas y lo invierten en **empresas que no cotizan en bolsa** (de ahí "privado"), con un objetivo claro: **hacerlas crecer y venderlas con ganancia** en un horizonte de años. La diferencia entre ambos está, sobre todo, en el **tipo de empresa** y la **etapa**:

- El **private equity** invierte en empresas **maduras y consolidadas** (con flujo, historia, activos), típicamente **comprando el control** (a menudo con deuda —el **LBO**—) para profesionalizarlas, hacerlas crecer y revenderlas.
- El **venture capital** invierte en empresas **jóvenes y de alto crecimiento** (*startups*), tomando participaciones **minorita-**

rias en sucesivas **rondas** de financiación, apostando a que algunas se vuelvan muy valiosas (aunque muchas fracasen).

La idea rectora del libro: **el inversionista profesional compra para vender, y todo lo que hace está orientado a la salida (el exit)**. A diferencia de un dueño que quiere conservar su empresa, el fondo tiene un **horizonte definido** (típicamente 5-10 años) y una **misión única**: comprar bien, crear valor, y **salir** (vender o sacar a bolsa) con la mayor ganancia. Esta lógica —*entrar pensando en cómo salir*— explica **cada** decisión y **cada** cláusula que el fondo negocia: por qué pide preferencia de liquidación (cobrar primero al salir), por qué quiere drag along (poder vender el 100%), por qué exige vetos (proteger su inversión hasta la salida), por qué estructura un LBO (amplificar el retorno con deuda).

Para el abogado corporativo, los fondos de PE/VC son los **clientes más valiosos y exigentes**: hacen operaciones constantemente (invierten, gestionan, salen), son sofisticadísimos, y su trabajo reúne **todo** lo que has aprendido en el Nivel IV. Una inversión de PE es un M&A (compra) + estructura (New-Co) + financiamiento (LBO) + SHA (gobierno y salida) + due diligence, todo combinado. Una inversión de VC es una suscripción + un SHA especializadísimo (preferencias, antidilución, vesting) + una apuesta sobre el crecimiento. Este libro te enseña a verlo **desde el lado del fondo** —y, con ello, a integrar toda tu formación en la lógica del inversionista que mueve el capital del mundo—.

2. Objetivos del libro

Al terminar, el lector será capaz de:

- **Comprender la estructura de un fondo** de PE/VC: la relación **GP/LP** (*General Partner / Limited Partners*), el *fund*, las comisiones (*management fee* y ***carried interest***), el ciclo de vida del fondo (*fundraising*, inversión, gestión, *exit*) y los vehículos (en México y *offshore*).
- **Dominar la lógica del private equity**: la **tesis de inversión** (comprar, mejorar, vender), el **LBO** (apalancamiento para amplificar el retorno —reuniendo los Libros 3 y 5—), la

creación de valor operativa y financiera, y los *exits* (venta estratégica, *secondary*, IPO).

- **Dominar la lógica del venture capital:** las etapas (semilla, Serie A, B, C...), la **valuación** (*pre-money* / *post-money*), la **dilución**, el *power law* (pocos éxitos pagan muchos fracasos) y el papel del VC en el ecosistema de *startups*.
- **Disecionar el term sheet de inversión** de VC/PE: la **valuación**, la **preferencia de liquidación** (1x, participating/non-participating), la **antidilución** (full ratchet / weighted average), los **derechos de gobierno** (board, vetos/*protective provisions*), los **derechos de información**, el **pro-rata**, y el **vesting** de fundadores (*good/bad leaver*).
- **Leer y construir un cap table** (tabla de capitalización): cómo se reparte la propiedad, cómo cambia con cada ronda, y el efecto de las opciones (*ESOP*) y los instrumentos convertibles (*SAFE*, nota convertible).
- **Dominar las salidas (exit):** la venta estratégica (*trade sale*), la venta secundaria, el *IPO*, y los mecanismos del SHA que las habilitan (drag along, registration rights, redemption).
- **Conectar** el PE/VC con todo el Nivel IV: ver la inversión del fondo como la **síntesis** de M&A, estructura, financiamiento, SHA y due diligence, vista desde el inversionista.

3. Importancia profesional

Para el abogado corporativo de élite, los fondos de **PE y VC son los clientes más codiciados**: hacen operaciones **constantemente** (un fondo invierte en varias empresas, las gestiona durante años, y sale de ellas), son **sofisticadísimos** (saben exactamente lo que quieren), y pagan por el **mejor trabajo**. Atender a un fondo de PE/VC significa estar en el **centro del deal flow** del mercado: ver y estructurar las operaciones más interesantes, una tras otra.

Para **tu perfil específico** —estructuración de operaciones complejas, M&A, gobierno corporativo, financiamiento—, el PE/VC es el campo donde **todo converge**. Una operación de PE típica reúne: un **M&A** (la compra), una **estructura** (NewCo, holding —Libro 3—), un **financiamiento/LBO** (Libro 5), un

SHA (gobierno y salida —Libro 4—), una **due diligence** (Libro 2), y a veces una **JV** o coinversión (Libro 6). Una operación de VC reúne una suscripción y un SHA especializadísimo. Dominar el PE/VC es, en la práctica, **dominar la aplicación integrada** de todo lo que has estudiado —y hacerlo para los clientes más exigentes—.

Hay además una razón de **trayectoria profesional**: muchos de los mejores abogados corporativos terminan **trabajando con o dentro de fondos** (como asesores externos recurrentes, como *general counsel* del fondo, o incluso pasando al lado de la inversión). El PE/VC es también un motor de la **economía** (financia la innovación —VC— y la consolidación y profesionalización de empresas —PE—), por lo que entenderlo te conecta con cómo se mueve el capital y se crea valor en el mundo real. Para quien aspira a la élite del derecho corporativo, el PE/VC **no es opcional**: es el destino natural.

4. Historia y origen

El **private equity** moderno nace en Estados Unidos a mediados del siglo XX, pero explota en los **años 1980** con la era de los **leveraged buyouts (LBO)**: firmas como KKR (Kohlberg Kravis Roberts) demostraron que se podían comprar empresas enormes usando **mucha deuda** y poco capital propio, reestructurarlas y revenderlas con ganancias extraordinarias. El icónico LBO de **RJR Nabisco** (1988) —narrado en *Barbarians at the Gate*— marcó la cúspide (y los excesos) de esa era. Desde entonces, el PE se institucionalizó: hoy mueve **billones** de dólares globalmente, con firmas como Blackstone, KKR, Carlyle y Apollo.

El **venture capital** tiene raíces igualmente estadounidenses: la inversión en empresas tecnológicas emergentes que floreció con **Silicon Valley** a partir de los años 1960-70 (la financiación de semiconductores, luego computación, internet, biotecnología). Firms como Sequoia, Kleiner Perkins y Andreessen Horowitz financiaron a las empresas que definieron la era digital (Apple, Google, Amazon y muchas más nacieron con capital de riesgo). El VC desarrolló su propia lógica: apostar a **muchas**

startups sabiendo que la mayoría fracasará, pero que **unas pocas** generarán retornos que pagan todo el resto (el *power law*).

En **México y América Latina**, el PE/VC se desarrolló más tarde (sobre todo desde los años 2000, y con fuerza en la última década). El **PE** mexicano creció con la consolidación de sectores y la profesionalización de empresas familiares; surgieron vehículos locales como los **CKDs** (Certificados de Capital de Desarrollo) y **CERPIs** que permiten a las **afores** invertir en capital privado. El **VC** latinoamericano vivió un *boom* notable, con el surgimiento de *unicornios* regionales (empresas valuadas en más de mil millones de dólares) y la llegada de fondos globales. La figura societaria de la **S.A.P.I.** (creada en la LMV) fue diseñada, en buena parte, **para** facilitar estas inversiones (validando las cláusulas de los inversionistas). Hoy el PE/VC es una práctica jurídica vibrante y creciente en México.

5. Evolución histórica

La evolución del capital privado puede leerse en tres movimientos:

1) Del LBO oportunista a la creación de valor operativa. El PE de los años 1980 era, en buena medida, **ingeniería financiera**: comprar con deuda, recortar, revender (a veces "descuartizando" empresas). El PE maduro **cambió el énfasis**: hoy el valor se crea no solo con apalancamiento, sino **mejorando operativamente** las empresas (profesionalizar la gestión, expandir, hacer adquisiciones complementarias —*buy-and-build*—, optimizar). El abogado acompaña esa creación de valor (las adquisiciones *add-on*, la gobernanza, la preparación para la venta).

2) La sofisticación de los instrumentos del VC. El VC desarrolló un **arsenal jurídico propio** y cada vez más estandarizado: las **acciones preferentes** con sus preferencias de liquidación y antidilución, el **vesting** de fundadores, los instrumentos de inversión rápida (**nota convertible**, y luego el **SAFE** —*Simple Agreement for Future Equity*, creado por Y Combinator—), los *term sheets* estándar (los modelos de NVCA en EE.UU.). Esta

estandarización aceleró la inversión y creó un **lenguaje común** global del VC.

3) La globalización y la institucionalización del capital privado. El PE/VC pasó de ser una actividad de nicho a una **clase de activo institucional**: los grandes inversionistas (fondos de pensiones, aseguradoras, fondos soberanos, *endowments*) destinan porciones significativas de su portafolio al capital privado. En México, los **CKDs/CERPIs** abrieron el capital privado a las **afores**. Y el VC se globalizó: los fondos invierten cross-border, y ecosistemas como el latinoamericano atrajeron capital global. El resultado: más capital, más operaciones, y una práctica jurídica cada vez más sofisticada y estandarizada internacionalmente.

6. Contexto económico

El PE/VC es **economía financiera** en estado puro. Tres ideas la gobiernan:

- **El fondo como intermediario que busca retornos superiores.** Un fondo de PE/VC reúne capital de **inversionistas** (LPs) que buscan **retornos superiores** a los del mercado público (a cambio de menos liquidez y más riesgo). El fondo (gestionado por el GP) invierte ese capital en empresas privadas, buscando un retorno medido por el **IRR** (*tasa interna de retorno*) y el **múltiplo** —el **MOIC** (*multiple on invested capital*): cuántas veces devuelve el capital—. **Las dos métricas se leen juntas y por una razón que conviene entender**: el IRR incorpora el tiempo y por eso se puede mejorar simplemente cerrando antes; el MOIC ignora el tiempo y mide la magnitud. Un fondo puede tener un IRR brillante y un MOIC mediocre (salió rápido de poco) o al revés (multiplicó mucho, en demasiados años). Cuando alguien te presume solo una de las dos, pregunta por la otra —es la misma disciplina del VPN frente a la TIR del Libro 2 del Nivel V—. Su modelo de negocio: cobrar una **comisión de gestión** (*management fee*, ~2% anual) y, sobre todo, quedarse con una parte de las **ganancias** (*carried interest* o *carry*, ~20% de las utilidades por encima de un umbral —*hurdle rate*—). El célebre "**2 y 20**".

- **La creación de valor: cómo el fondo gana dinero.** El PE crea valor de tres formas: **(i) apalancamiento** (el LBO: usar deuda para amplificar el retorno del equity —Libro 5—); **(ii) mejora operativa** (crecer, profesionalizar, hacer add-ons, optimizar márgenes); y **(iii) multiple expansion** (vender a un múltiplo mayor que al que compró —comprar barato, vender caro—). El VC crea valor distinto: apuesta al **crecimiento exponencial** de *startups*, donde el valor viene del **potencial** (no del flujo actual).
- **El power law del venture capital.** La economía del VC es **asimétrica**: de cada 10 inversiones, varias fracasan (pérdida total), algunas devuelven el capital, y **una o dos** generan retornos enormes (10x, 50x, 100x) que **pagan todo el portafolio y más**. Esto explica la lógica del VC: no busca evitar fracasos (son inevitables), sino **no perderse el gran éxito**; por eso invierte en muchas, apuesta al **upside** ilimitado, y estructura sus protecciones (preferencias) para los escenarios intermedios. El PE, en cambio, busca retornos más **consistentes** (menos fracasos, menos *home runs*).

DOS SOLUCIONES OPUESTAS AL MISMO PROBLEMA

VC y PE existen para financiar lo que la banca no puede —innovación de altísimo riesgo el primero, transformación operativa apalancada el segundo— y lo interesante es que **resuelven el mismo problema de agencia por vías contrarias**. Entender esto explica por qué sus documentos no se parecen.

El VC **resuelve la agencia con información y etapas**. No puede usar deuda: una empresa sin flujo no la soporta. Entonces usa **financiamiento por rondas contra hitos y valores convertibles** con derechos de control contingentes (Gilson y Black; Kaplan y Strömberg). La lógica: no entrego todo el capital de golpe, entrego un tramo, y el siguiente depende de que se cumpla lo prometido. **El control se reasigna según el desempeño**, no de una vez.

El PE **resuelve la agencia con deuda y concentración de propiedad**. Es la tesis de Jensen en *Eclipse of the Public Corporation* (1989): en una empresa pública con accionariado disperso, el *management* dispone de **flujo de caja libre discre-**

cional y nadie lo vigila de cerca. El LBO ataca las dos cosas a la vez: concentra la propiedad en un dueño con incentivo y capacidad de vigilar, y **la deuda disciplina** —porque el servicio de la deuda consume el flujo que antes era discrecional—. El apalancamiento no es solo una palanca de retorno: en esta teoría, es un **mecanismo de gobierno**.

Traducción para tu trabajo. Cuando negocies para un fondo de VC, tu materia prima es la **cap table** y los derechos de control por ronda. Cuando negocies para un fondo de PE, es el **paquete de deuda y sus covenants** (Libro 5). Y cada término del *term sheet* —preferencia de liquidación, antidilución, *vesting* de fundadores, *pool* de opciones— es **teoría de agencia aplicada**: no son costumbres del mercado, son respuestas a un problema de incentivos que puedes nombrar.

Incluso el *carried interest* del propio fondo lo es: alinea al gestor con sus inversionistas, y a la vez crea su propio conflicto —una participación en la ganancia sin participación proporcional en la pérdida incentiva a **apostar con dinero ajeno**—. Saber esto es lo que te permite leer un contrato de fondo sin ingenuidad.

7. Contexto político y regulatorio

El PE/VC opera bajo un marco regulatorio que el abogado debe dominar:

- **Regulación de los fondos y los vehículos.** La estructura del fondo está regulada: en México, los **CKDs** y **CERPIs** (vehículos bursátiles que permiten a las **afores** y otros institucionales invertir en capital privado) están bajo la **LMV** y la supervisión de la **CNBV**; los fondos *offshore* (típicamente en jurisdicciones como Delaware, Cayman) tienen su propia regulación. La relación GP/LP se rige por el contrato del fondo (*Limited Partnership Agreement* / *LPA*).
- **La S.A.P.I. y el marco societario (LMV/LGSM).** La **S.A.P.I.** fue diseñada para **dar validez societaria** a las cláusulas que exigen los inversionistas (preferencias, vetos, drag/tag, opciones, *vesting*), siendo el vehículo preferido para las empresas que reciben inversión de PE/VC en México.
- **Competencia (COFECE).** Las adquisiciones de control del PE (LBO) pueden ser **concentraciones notificables**; los fon-

dos que tienen varias empresas de un mismo sector deben cuidar la competencia.

- **Mercado de valores (LMV) para las salidas vía IPO.** Si el *exit* es una **salida a bolsa**, entra el régimen de emisoras (prospecto, revelación, OPAs).
- **Fiscal.** La estructura de los fondos y de las inversiones es **muy sensible fiscalmente** (cómo se gravan el *carry*, las ganancias de capital, los vehículos *offshore*); el diseño fiscal es central y se hace con especialistas.
- **Regulación de startups y fintech.** El VC invierte a menudo en sectores regulados emergentes (fintech —Ley Fintech en México—, salud digital, etc.), donde la regulación condiciona el negocio.

8. Contexto social

El PE/VC tiene una dimensión social y un debate público intensos. Por el lado **positivo**: el **VC financia la innovación** —las empresas que transforman la economía (tecnología, salud, energía limpia) suelen nacer con capital de riesgo—, generando empleo, productividad y avance tecnológico; y el **PE profesionaliza y rescata empresas** (moderniza compañías ineficientes, salva empresas en problemas, permite la sucesión de empresas familiares cuyos dueños quieren retirarse). El capital privado es un motor de **dinamismo económico**.

Por el lado **crítico**: el PE ha sido cuestionado por los **excesos del apalancamiento** (cargar de deuda a empresas, a veces llevándolas a la quiebra mientras el fondo ya extrajo su ganancia), por los **recortes** (reducir empleos para mejorar márgenes y vender), y por la **extracción de valor** a corto plazo. El debate sobre si el PE "crea" o "extrae" valor es genuino y matizado (hay de todo: fondos que construyen y fondos que descuartizan). El abogado serio entiende esta tensión y opera con **criterio ético**: estructurar operaciones que creen valor real, no solo que extraigan.

Para el **fundador** de una *startup*, el VC tiene una dimensión humana intensa: recibir capital de riesgo significa **ceder parte del control y de la propiedad** a cambio de recursos para cre-

cer, y aceptar la presión de un inversionista que **quiere salir** con ganancia. El abogado del fundador debe equilibrar la necesidad de capital con la protección del fundador (que no lo diluyan o expulsen injustamente —de ahí la importancia del *vesting*, el *good/bad leaver*, y de no ceder vetos excesivos—). Hay un **conflicto estructural de intereses** entre fundador (quiere crecer y conservar control) e inversionista (quiere retorno y salida), y el abogado opera en esa tensión.

9. Contexto empresarial

Desde la óptica empresarial, el PE/VC cumple funciones distintas según la etapa de la empresa:

- **Para la *startup* (VC):** el capital de riesgo es, a menudo, la **única forma** de financiar el crecimiento de una empresa joven que **no tiene flujo ni activos** para obtener deuda bancaria. El VC aporta **capital + acompañamiento** (mentoría, red de contactos, credibilidad). A cambio, el fundador cede equity y acepta la lógica de crecer rápido para una eventual salida.
- **Para la empresa madura (PE):** el private equity ofrece **capital + profesionalización + una salida para los dueños actuales**. Sirve para: financiar el crecimiento (orgánico o por adquisiciones), **profesionalizar** una empresa familiar, permitir la **sucesión** (los dueños venden y se retiran), **rescatar** una empresa en problemas (*turnaround*), o tomar una empresa pública y volverla privada (*public-to-private*).
- **Para los inversionistas (LPs):** el PE/VC es una **clase de activo** que ofrece (en teoría) retornos superiores a cambio de iliquidez y riesgo; las afores, aseguradoras y family offices invierten en fondos para diversificar y buscar rendimiento.

La decisión empresarial clave: **¿conviene recibir capital de un fondo?** Para una *startup*, el VC puede ser el combustible del crecimiento, pero a costa de control y con presión de salida. Para una empresa madura, el PE puede traer capital y profesionalización, pero significa ceder el control (o venderse) a un socio cuyo objetivo es **revender en años**. El abogado ayuda a entender qué se gana y qué se cede, y a **estructurar la en-**

trada del fondo protegiendo los intereses de su cliente (sea el fondo o la empresa/ fundador). Entender la **lógica del fondo** —que entra pensando en cómo salir— es esencial para negociar bien de cualquiera de los dos lados de la mesa.

10. Definiciones doctrinales

La doctrina financiera y jurídica define los conceptos centrales así:

- **Private Equity (PE) / Capital privado:** inversión de capital en empresas **maduras que no cotizan**, típicamente **adquiriendo el control** (a menudo con apalancamiento —LBO—), para crear valor y revender en un horizonte de años. La doctrina lo define como una **clase de activo** de inversión alternativa orientada al **control y la transformación** de empresas establecidas.
- **Venture Capital (VC) / Capital de riesgo:** inversión en empresas **jóvenes de alto crecimiento** (*startups*), mediante participaciones **minoritarias** en sucesivas **rondas**, apostando al crecimiento exponencial de unas pocas que compensan los fracasos de muchas (*power law*).
- **Fondo (*fund*):** vehículo de inversión que **reúne capital** de varios inversionistas para invertirlo según una estrategia, con un horizonte definido. Jurídicamente, suele estructurarse como una **sociedad/asociación** (en EE.UU., *Limited Partnership*; en México, vía **CKD/CERPI** o vehículos *offshore*).
- **GP (*General Partner*) / Gestor:** quien **gestiona** el fondo, toma las decisiones de inversión y responde por ellas; cobra comisión de gestión y *carry*. Es el "**administrador**" del fondo.
- **LP (*Limited Partner*) / Inversionista:** quien **aporta el capital** al fondo (afores, aseguradoras, fondos de pensiones, family offices, soberanos), con responsabilidad limitada a su aportación y un papel **pasivo** (no gestiona).
- **Carried interest (*carry*):** la **participación en las ganancias** que cobra el GP (típicamente ~20% de las utilidades por

encima de un umbral —*hurdle*—). Es el principal incentivo del gestor.

- **LBO (*Leveraged Buyout*):** adquisición de una empresa financiada en gran parte con **deuda**, repagada con el flujo de la propia empresa adquirida (visto en Libros 3 y 5).
- **Term Sheet de inversión:** documento que fija los **términos** de la inversión del fondo (valuación, preferencias, gobierno), mayormente **no vinculante** salvo cláusulas de proceso (eco del Libro 4).
- **Preferencia de liquidación (*liquidation preference*):** derecho del inversionista a **cobrar primero** (un múltiplo de su inversión) en una venta o liquidación, antes que los ordinarios.
- **Cap table (tabla de capitalización):** el registro de **quién posee qué** porcentaje del capital de la empresa, y cómo cambia con cada ronda, opción e instrumento convertible.
- **Exit (salida):** la operación por la que el fondo **realiza su inversión** —vendéndola (a un estratégico o a otro fondo) o sacándola a bolsa (IPO)—. Es el momento en que se materializa el retorno.

11. Definiciones legales y marco normativo

El PE/VC se asienta en un entramado de derecho societario, bursátil y contractual:

- **Estructura del fondo:** la relación **GP/LP** se rige por el contrato del fondo (**LPA — *Limited Partnership Agreement***, en vehículos extranjeros) o por las reglas del vehículo mexicano. En México, los **CKDs** (Certificados de Capital de Desarrollo) y **CERPIs** (Certificados de Proyectos de Inversión) son **vehículos bursátiles** (regulados por la **LMV** y la **CNBV**) que permiten a las **afores** y otros institucionales invertir en capital privado/proyectos. Muchos fondos usan también vehículos *offshore* (Delaware LP, Cayman) por eficiencia.
- **La S.A.P.I. (LMV): el vehículo de la empresa invertida.** La **Sociedad Anónima Promotora de Inversión** fue creada

(LMV) precisamente para **dar validez societaria** a las cláusulas que exigen los inversionistas de PE/VC: **restricciones a la transmisión** (lock-up, ROFR, tag/drag), **derechos de veto**, **acciones con derechos especiales** (preferencias), **opciones** (put/call) y **convenios entre accionistas**. Es el vehículo estándar de la empresa que recibe inversión.

- **Acciones preferentes y series (LGSM/LMV).** El derecho societario permite **distintas series de acciones** con derechos diferenciados (las acciones **preferentes** del inversionista, con preferencia de liquidación y derechos de gobierno, frente a las **ordinarias** de los fundadores).
- **Instrumentos convertibles.** Las **notas convertibles** (deuda que se convierte en acciones en la siguiente ronda) y los **SAFE** (*Simple Agreement for Future Equity* —no es deuda ni equity hasta la conversión—) se estructuran sobre la base contractual (autonomía de la voluntad), adaptados al derecho mexicano.
- **Convenios entre accionistas (SHA — Libro 4).** El corazón documental de la inversión: validado por la S.A.P.I., rige gobierno, preferencias, antidilución, vesting y salidas.
- **Mercado de valores (LMV) para el IPO.** Si la salida es a bolsa, aplica el régimen de emisoras.
- **Competencia (LFCE), fiscal (LISR/CFF) e inversión extranjera.** Condicionan las adquisiciones (LBO), la estructura fiscal del fondo y del *carry*, y la participación extranjera.

Nota de método: la estructura de fondos e inversiones es **intensamente fiscal y regulatoria**; verifica el marco vigente (LMV, reglas de CKD/CERPI, LISR) y estructura **con especialistas fiscales** antes de aplicar (Manifiesto XI.5).

12. Definición sencilla

Imagina dos tipos de inversionistas que ayudan a las empresas a crecer, para luego venderlas con ganancia:

El Venture Capital (VC) es como un "buscador de estrellas". Apuesta a **muchas bandas de garage** (*startups*): le da dinero a 10 bandas jóvenes a cambio de un pedazo de cada una. Sabe que **7 fracasarán**, 2 quedarán bien, y **1 se volverá una**

superestrella que vale tanto que **paga las otras 9 y deja enorme ganancia**. No busca evitar fracasos (son inevitables); busca **no perderse la estrella**. Por eso invierte en muchas, en **etapas** (primero poco dinero —semilla—, luego más si la banda despega —Serie A, B...—), y se protege para los casos intermedios.

El Private Equity (PE) es como un "renovador de casas". Compra una **casa sólida pero descuidada** (una empresa madura), normalmente con **un préstamo grande** (apalancamiento: pone poco de su dinero y mucho prestado), la **renueva** (la profesionaliza, la hace crecer), y la **revende** más cara unos años después. Su ganancia viene de **comprar bien, mejorar, y vender mejor** —amplificada por la deuda—.

Lo que ambos tienen en común, y que **explica todo lo que hacen: entran pensando en cómo salir**. No quieren quedarse con la empresa para siempre; quieren **venderla con ganancia** en unos años. Por eso, cada cláusula que negocian responde a una pregunta: *si esto va bien, ¿cómo me aseguro de cobrar mucho?*; *si va regular, ¿cómo recupero al menos lo mío (preferencia de liquidación)?*; *si quiero vender todo, ¿cómo obligo a los demás a vender conmigo (drag along)?*; *mientras tanto, ¿cómo protejo mi inversión (vetos)?*. El fondo es un inversionista con **fecha de salida**, y eso lo explica todo.

13. Conceptos fundamentales

Fija este vocabulario; es el idioma del capital privado y reúne términos del SHA (Libro 4) y del LBO (Libro 5):

La estructura del fondo:

- **GP / LP:** gestor (administra, cobra carry) / inversionista (aporta capital, pasivo).
- **Management fee / Carried interest:** comisión de gestión (~2%) / participación en ganancias (~20%) = "**2 y 20**".
- **Hurdle rate / Preferred return:** rendimiento mínimo que se da a los LPs antes de que el GP cobre carry.
- **Commitment / Drawdown / Capital call:** capital comprometido por el LP / llamadas de capital cuando el fondo invierte.

- **Vintage y ciclo de vida del fondo:** *fundraising* → periodo de inversión → gestión → *exit*/ desinversión (típicamente 10 años).
- **CKD / CERPI:** vehículos mexicanos para que las afores inviertan en capital privado.

Private Equity:

- **Buyout / LBO:** compra de control, con apalancamiento (Libros 3 y 5).
- **Buy-and-build / add-ons:** crear valor adquiriendo empresas complementarias.
- **Multiple expansion:** vender a un múltiplo mayor que al que se compró.
- **Turnaround / distressed:** rescate de empresas en problemas.
- **Dry powder:** capital comprometido aún no invertido.

Venture Capital:

- **Etapas:** pre-seed/semilla → **Serie A** → **Serie B, C...** (cada ronda, más capital y mayor valuación si la empresa crece).
- **Pre-money / Post-money:** valuación **antes** / **después** de la nueva inversión (post = pre + inversión).
- **Dilución:** reducción del porcentaje de los socios existentes al emitir acciones nuevas.
- **Cap table:** tabla de capitalización (quién posee qué).
- **SAFE / Nota convertible:** instrumentos de inversión rápida que **convierten** en acciones en la siguiente ronda (con *des-cuento* y/o *cap* de valuación).
- **ESOP / pool de opciones:** acciones reservadas para **empleados** (incentivo); diluye a todos.
- **Unicornio:** *startup* valuada en más de mil millones de dólares.
- **Power law / home run:** la lógica de que pocos éxitos enormes pagan muchos fracasos.

El term sheet de inversión y el SHA (protecciones del inversionista — reúne el Libro 4):

- **Preferencia de liquidación:** cobrar primero (1x, 2x; *participating / non-participating*).
- **Antidilución:** protección si una ronda futura es a menor precio (*full ratchet / weighted average*).
- **Protective provisions / vetos:** decisiones que requieren consentimiento del inversionista.
- **Board seats / información:** asientos en el consejo y derechos de información.
- **Pro-rata / preemptive rights:** derecho a invertir en rondas futuras para no diluirse.
- **Vesting de fundadores:** las acciones del fundador se "ganan" con el tiempo (típico 4 años con 1 de *cliff*); **good leaver / bad leaver** (cómo se va).
- **Drag along / Tag along / ROFR:** salida (arrastrar / acompañar / preferencia) —del SHA—.
- **Registration rights:** derecho a exigir que se registren las acciones para venderlas en un IPO.

Salidas (*exit*):

- **Trade sale (venta estratégica):** vender a otra empresa del sector (M&A).
- **Secondary buyout:** vender a otro fondo de PE.
- **IPO (oferta pública inicial):** sacar la empresa a bolsa.
- **Redemption / recompra:** que la empresa o los socios recompren la participación del fondo.

Con este vocabulario, entramos al **desarrollo absoluto**.

14. Desarrollo absoluto

Esta es la sección central. La desarrollamos en cinco bloques: **(A) la estructura del fondo** (GP/LP, comisiones, ciclo de vida); **(B) el private equity y el LBO** (la tesis, la creación de valor, el apalancamiento); **(C) el venture capital y las rondas** (etapas, valuación, dilución, instrumentos); **(D) el term sheet de inversión y el SHA** (preferencias, antidilución, vetos, vesting — el corazón documental—); y **(E) el cap table y las salidas**

(cómo se reparte la propiedad y cómo sale el fondo). Estúdialos en orden: primero cómo se organiza el dinero (el fondo), luego cómo invierte (PE y VC), después cómo se documenta y protege (term sheet/SHA), y al final cómo se realiza el retorno (cap table y exit).

14.A · LA ESTRUCTURA DEL FONDO (GP / LP, COMISIONES, CICLO DE VIDA)

Antes de invertir en una sola empresa, hay que entender **cómo se organiza el dinero del inversionista profesional: el fondo**. Un fondo de PE/VC no es una empresa que invierte su propio dinero; es un **vehículo** que reúne capital de terceros para invertirlo según una estrategia.

La relación GP / LP (la arquitectura básica).

- Los **LPs** (*Limited Partners* / **inversionistas**) son quienes **ponen el capital**: afores, aseguradoras, fondos de pensiones, *endowments*, family offices, fondos soberanos. Son **pasivos** (no gestionan) y su responsabilidad se **limita** a su aportación. Buscan retornos superiores a cambio de iliquidez y riesgo.
- El **GP** (*General Partner* / **gestor**) es quien **gestiona** el fondo: define la estrategia, busca las inversiones, las ejecuta, las administra y las vende. Toma las decisiones y **responde** por ellas. El GP aporta normalmente una pequeña parte del capital (*GP commitment*, para "tener piel en el juego") y se lleva las comisiones.
- El **contrato que los une** es el **LPA** (*Limited Partnership Agreement*) —en vehículos extranjeros— o las reglas del vehículo mexicano (CKD/CERPI). Regula: la estrategia, los compromisos de capital, las comisiones, la gobernanza, los conflictos de interés, y la distribución de las ganancias.

Las comisiones: el "2 y 20". El modelo de negocio del GP:

- **Management fee (~2% anual)**: comisión sobre el capital comprometido/gestionado, que paga los gastos operativos del GP (equipo, oficina). Es ingreso **fijo**.
- **Carried interest / carry (~20%)**: la **participación en las ganancias** del fondo, por encima de un **hurdle rate** (rendi-

miento mínimo garantizado a los LPs, p. ej., 8%). Es el **gran incentivo**: el GP gana de verdad cuando el fondo genera retornos. Alinea al GP con los LPs (ambos ganan si las inversiones van bien). El *carry* suele estar sujeto a *vesting* y a mecanismos de **clawback** (devolver si al final el fondo no alcanzó el hurdle).

El ciclo de vida del fondo (típicamente ~10 años).

1. **Fundraising (captación)**: el GP **levanta** el fondo, convenciendo a los LPs de comprometer capital. Define el tamaño objetivo, la estrategia y los términos (LPA).
2. **Periodo de inversión (~años 1-5)**: el GP **invierte** el capital en empresas (las *portfolio companies*), haciendo *capital calls* (llamadas de capital a los LPs) conforme cierra cada inversión.
3. **Gestión / creación de valor (~años 3-8)**: el GP **trabaja** las empresas del portafolio (profesionaliza, hace crecer, add-ons), buscando aumentar su valor.
4. **Desinversión / exit (~años 5-10)**: el GP **vende** las empresas (trade sale, secondary, IPO) y **distribuye** las ganancias a los LPs (devolviendo primero su capital + hurdle, luego repartiéndolo el resto 80/20).
5. **Liquidación**: el fondo se cierra. Mientras tanto, el GP suele estar **levantando el siguiente fondo**.

Los vehículos en México. Para que las **afores** (la gran bolsa de capital institucional mexicano) puedan invertir en capital privado, se crearon vehículos bursátiles: los **CKDs** (Certificados de Capital de Desarrollo) y **CERPIs** (Certificados de Proyectos de Inversión), regulados por la LMV y la CNBV. Estos vehículos cotizan en bolsa pero invierten en activos privados, conectando el ahorro para el retiro con el capital privado. Muchos fondos usan además estructuras *offshore* (Delaware, Cayman) por eficiencia fiscal y familiaridad de los inversionistas globales. El abogado de fondos estructura estos vehículos —una práctica especializada y muy técnica—.

Por qué importa para el abogado de la operación. Aunque tú asesores la **inversión concreta** (la compra de una empresa por el fondo), entender la **estructura del fondo** explica

el **comportamiento** del cliente: por qué tiene **prisa por invertir** (el periodo de inversión corre), por qué **debe vender** (el fondo tiene fecha de cierre), por qué le obsesiona el **retorno y el exit** (de ahí su *carry*), y por qué negocia tan duro las protecciones (responde ante sus LPs). El fondo no es un dueño cualquiera: es un **gestor de dinero ajeno con una fecha de salida y un incentivo de retorno**. Eso explica todo lo demás.

14.B · EL PRIVATE EQUITY Y EL LBO (COMPRAR, MEJORAR, VENDER — CON APALANCAMIENTO)

El **private equity** invierte en empresas **maduras**, normalmente **comprando el control**. Su modelo, en una frase: **comprar bien, crear valor, vender mejor** —y amplificar el retorno con **deuda** (el LBO)—.

La tesis de inversión. Antes de comprar, el fondo define una **tesis**: por qué esta empresa, a este precio, puede valer mucho más en 5 años. Las palancas de creación de valor:

- **Mejora operativa:** profesionalizar la gestión, optimizar costos y márgenes, mejorar la estrategia comercial. Crear valor **operando mejor**.
- **Crecimiento:** expansión orgánica + **buy-and-build** (adquirir empresas complementarias —*add-ons*— para crecer por consolidación, comprando a múltiplos bajos y vendiendo el conjunto a un múltiplo mayor).
- **Apalancamiento (el LBO):** usar **deuda** para financiar la compra, de modo que **poco equity** controle un activo grande, **amplificando** el retorno sobre el equity (Libro 5).
- **Multiple expansion:** vender a un **múltiplo mayor** que el de compra (comprar barato en un momento o sector poco valorado, vender caro cuando mejora).

El LBO en detalle (reuniendo Libros 3 y 5). El *leveraged buyout* es la técnica característica del PE. Recordando y profundizando:

- **La estructura (Libro 3):** el fondo crea una **NewCo**, le aporta **equity** (su capital) y le consigue **deuda** (de bancos/fondos); la NewCo **compra** la *target*; luego (a menudo) **se fusio-**

na con ella (fusión apalancada), de modo que el **flujo de la target sirva la deuda**.

- **El financiamiento (Libro 5):** la deuda se estructura en **tramos** (senior + mezzanine), con un **intercreditor agreement**, cuidando la **asistencia financiera**, y con **garantías** sobre los activos y acciones de la target. El fondo asegura el **committed financing** para poder cerrar.
- **La matemática de la palanca:** si el fondo compra una empresa por 100 (40 de equity + 60 de deuda) y la vende en 5 años por 160, tras pagar la deuda (que se redujo con el flujo, digamos a 30), el equity recibe 130 —**más de 3x** sobre los 40 invertidos—. La deuda **amplificó** el retorno. Pero si la empresa va mal y vale 70, tras pagar la deuda (60) el equity recibe solo 10 —**una pérdida brutal**—. La palanca amplifica en **ambas** direcciones; por eso el LBO es poderoso y peligroso.

La creación de valor operativa (el PE maduro). El PE moderno no vive solo del apalancamiento: crea valor **mejorando la empresa**. El fondo instala gobierno corporativo profesional (consejo, métricas, incentivos a la dirección), define un **plan de 100 días** y un **plan de creación de valor**, hace adquisiciones complementarias, y prepara la empresa para una **venta atractiva**. El abogado acompaña todo: la adquisición inicial, las adquisiciones *add-on*, la gobernanza (el SHA con la dirección), y —al final— la **preparación y ejecución de la salida**.

El gobierno de la empresa adquirida. Cuando el PE compra el control, instala su gobierno vía un **SHA** (Libro 4) con los **co-inversionistas** y la **dirección** (a la que suele dar equity con *vesting* e incentivos —*management equity plan*—, para alinearla con la creación de valor y la salida). Aquí ves cómo el PE reúne **M&A + estructura + financiamiento + SHA + gobierno corporativo** en una sola operación —la síntesis de todo el Nivel IV—.

El exit (la razón de ser). El PE compra **para vender**. Las salidas típicas: **trade sale** (vender a un comprador estratégico del sector), **secondary buyout** (vender a otro fondo de PE), o **IPO** (sacar la empresa a bolsa). Toda la operación —desde la

compra— se diseña pensando en **maximizar el valor de la salida** en el horizonte del fondo. El abogado que entiende esto estructura **desde el inicio** pensando en **cómo se venderá** (que la empresa sea "vendible": gobierno limpio, contratos en orden, sin contingencias —la due diligence inversa—).

14.C · EL VENTURE CAPITAL Y LAS RONDAS (ETAPAS, VALUACIÓN, DILUCIÓN, INSTRUMENTOS)

El **venture capital** invierte en empresas **jóvenes de alto crecimiento** (*startups*) tomando participaciones **minoritarias** en sucesivas **rondas**. Su lógica es radicalmente distinta a la del PE: no compra control ni usa deuda (las *startups* no tienen flujo ni activos), sino que **apuesta al crecimiento exponencial** de unas pocas, sabiendo que muchas fracasarán (*power law*). Domina su mecánica:

Las etapas (rondas) de financiación. Una *startup* exitosa pasa por rondas sucesivas, cada una con más capital y (si crece) mayor valuación:

- **Pre-seed / Semilla (*seed*):** el primer capital, para validar la idea y construir el producto. Montos pequeños; inversionistas ángeles, fondos *seed*, aceleradoras. Alto riesgo, alta participación potencial.
- **Serie A:** cuando la *startup* tiene tracción (usuarios, ingresos iniciales) y necesita capital para **escalar** el modelo. Entran fondos de VC institucionales. Aquí se "profesionaliza" la estructura (term sheet completo, SHA, consejo).
- **Serie B, C, D...:** rondas sucesivas para **acelerar el crecimiento** (expandir geografías, productos, equipo). Montos crecientes, valuaciones crecientes (si todo va bien), y entrada de fondos más grandes.
- **Late stage / pre-IPO:** rondas grandes antes de una eventual salida a bolsa o venta.

La valuación: pre-money y post-money. Concepto **fundamental** que el abogado debe dominar:

- **Pre-money:** cuánto vale la empresa **antes** de la nueva inversión.
- **Post-money = Pre-money + inversión.**

- **El porcentaje del inversionista = inversión / post-money.**
- *Ejemplo:* si una *startup* tiene un *pre-money* de 8 y el VC invierte 2, el *post-money* es 10, y el VC se queda con **20%** (2/10). Los fundadores, que tenían el 100%, pasan a tener el **80%** —se **diluyeron**—.

La dilución (el corazón de la matemática del cap table).

Cada vez que la empresa **emite acciones nuevas** (en cada ronda, o al crear el pool de opciones), los socios existentes **reducen su porcentaje** (aunque el **valor** de su parte puede subir si la valuación crece). Entender y proyectar la dilución a lo largo de las rondas es esencial: un fundador puede pasar del 100% al 20-30% tras varias rondas —pero de un pastel mucho más grande—. El abogado del fundador cuida que la dilución sea **razonable** y que el fundador conserve incentivo y (idealmente) cierto control.

El pool de opciones (ESOP). Las *startups* reservan un porcentaje del capital (un *pool*, típicamente 10-20%) para **incentivar a empleados** clave con opciones sobre acciones (*stock options*). Punto fino de negociación: el pool suele crearse (o ampliarse) **antes** de la ronda, lo que hace que **los fundadores** (no el nuevo inversionista) absorban su dilución (el *option pool shuffle*) —un detalle que mueve porcentajes y que el abogado debe vigilar—.

Los instrumentos de inversión rápida (semilla): nota convertible y SAFE. En etapas tempranas, negociar una valuación es difícil (la empresa es muy incipiente). Por eso se usan instrumentos que **posponen** la valuación a la siguiente ronda:

- **Nota convertible:** es **deuda** que, en lugar de pagarse, **convierte en acciones** en la siguiente ronda (la Serie A), normalmente con un **descuento** (premio por entrar antes) y/o un **valuation cap** (techo de valuación a la que convierte, para premiar al inversionista temprano). Devenga interés y tiene vencimiento (es deuda).
- **SAFE (Simple Agreement for Future Equity):** creado por Y Combinator; **no es deuda ni equity** hasta que convierte; más simple que la nota (sin interés ni vencimiento).

También usa **descuento** y/o **cap**. Se ha vuelto el instrumento estándar de las rondas semilla (adaptado al derecho mexicano con cuidado).

- *Por qué se usan:* permiten **invertir rápido y barato** sin pelear la valuación, dejándola para cuando la empresa esté más madura (la Serie A). El abogado debe entender la **mecánica de conversión** (cómo y a qué precio se vuelven acciones), que afecta el cap table.

El power law y su efecto en la negociación. Como el VC sabe que **la mayoría de sus inversiones fracasarán** y que el retorno vendrá de **una o dos** que exploten, estructura sus protecciones (preferencias, antidilución) para los escenarios **intermedios y malos** (recuperar algo si la empresa se vende barato), mientras que en el escenario **bueno** (la estrella) todos ganan tanto que las protecciones importan menos. Esta lógica explica por qué el VC insiste en la **preferencia de liquidación** (su red de seguridad para los casos regulares) y por qué, a la vez, **apuesta al upside** ilimitado.

La distinción que un fundador debe entender antes de firmar: preferencia *no participativa* frente a *participativa*.

Es de las cláusulas que más dinero mueven y de las que menos se explican.

- **No participativa (1x):** el inversionista **elige** entre recuperar su inversión **o** convertir a comunes y cobrar su porcentaje. Lo que le convenga, pero **no las dos cosas**.
- **Participativa (*double dip*):** recupera su inversión y **además** participa en el remanente según su porcentaje. Cobra dos veces del mismo pastel.

Ejemplo mínimo: el fondo invirtió 20 por el 25 % y la empresa se vende en 100. Con preferencia **no participativa** elige lo mejor entre 20 y el 25 % de 100 (= 25): cobra **25**. Con preferencia **participativa** cobra 20 **más** el 25 % de los 80 restantes (= 20): cobra **40**. Quince de diferencia salen del bolsillo de los fundadores, por una palabra.

Y el agravante: cuando se acumulan varias rondas participativas, en una venta mediana **los fundadores pueden recibir cero** aunque la empresa se haya vendido por una cifra respetable. El mercado ha ido convergiendo hacia la no participativa $\triangle$, pero aparece cuando el fundador negocia desde la debilidad —y ahí es donde su abogado tiene que saber hacer esta cuenta en la mesa—.

El fundador y su abogado deben entender esta lógica para negociar: ceder lo que protege al VC en los malos escenarios (donde de todas formas hay poco) y pelear lo que importa en los buenos (control, dilución razonable, vesting justo).

14.D · EL TERM SHEET DE INVERSIÓN Y EL SHA (LAS PROTECCIONES DEL INVERSIONISTA)

Aquí está el **corazón documental** de la inversión de PE/VC, y donde se concentra el trabajo del abogado. La inversión se documenta con: un **term sheet** (las bases, mayormente no vinculante —eco del Libro 4—), los **documentos de la inversión** (contrato de suscripción/compra de acciones), y —lo más importante— un **SHA especializadísimo** (el convenio entre accionistas, validado por la S.A.P.I.) que contiene las **protecciones del inversionista**. Domina estas cláusulas: son las que definen el poder y el dinero.

1) La valuación y la estructura de la inversión. Cuánto invierte el fondo, a qué **valuación** (pre/post-money), por qué **porcentaje**, y mediante qué instrumento (acciones **preferentes** de una nueva serie, suscripción primaria —dinero a la empresa— y/o secundaria —compra a socios existentes—).

2) La preferencia de liquidación (*liquidation preference*): la protección económica central. El derecho del inversionista a **cobrar primero** en una venta o liquidación, antes que los ordinarios (fundadores). Es su **red de seguridad**. Variables:

- **El múltiplo: 1x** (recupera su inversión) es lo estándar y razonable; 2x o más es agresivo.
- ***Non-participating*** (lo estándar y equilibrado): el inversionista elige lo que más le convenga —o cobra su preferencia (su 1x) o convierte a ordinario y cobra su porcentaje—, pero **no ambos**.
- ***Participating* ("double-dip", agresiva):** cobra su preferencia **y además** participa como ordinario en el resto. Muy favorable al inversionista, castiga a los fundadores.
- ***Por qué importa:*** en una venta **mediocre** (la empresa se vende por poco), la preferencia hace que el inversionista **recupere lo suyo** mientras los fundadores reciben poco o nada; en una venta **excelente**, el inversionista convierte y todos ganan. Es la cláusula que protege al VC en los escenarios regulares (recuerda el *power law*).

3) La antidilución (*anti-dilution*): protección contra rondas a la baja. Protege al inversionista si una **ronda futura** se hace a un precio **menor** que el que él pagó (un *down round*, señal de que la empresa se desvalorizó). Modalidades:

- ***Weighted average* (promedio ponderado): la estándar y equilibrada.** Ajusta el precio de conversión del inversionista de forma **proporcional** al tamaño del down round.
- ***Full ratchet* (la agresiva):** ajusta el precio del inversionista **al nuevo precio más bajo**, como si hubiera entrado a ese

precio —castiga severamente a los fundadores—. Poco común y muy peleada.

4) Los derechos de gobierno (*protective provisions* / *vetos y board*). El inversionista, aunque sea minoritario, se protege con:

- **Asientos en el consejo (*board seats*):** uno o más consejeros (y a veces un *observer*).
- **Materias reservadas / vetos (*protective provisions*):** decisiones que requieren su **consentimiento** aunque no controle el consejo: vender la empresa, emitir más acciones, endeudarse, cambiar el giro, modificar estatutos, aprobar el presupuesto, contratar/remover al CEO, hacer adquisiciones. Su **protección de poder** clave.
- **Derechos de información:** estados financieros, reportes, presupuesto, acceso.

5) Los derechos sobre futuras rondas y la propiedad.

- **Pro-rata / preemptive rights:** derecho a **invertir en rondas futuras** para mantener su porcentaje (no diluirse) —importante para los buenos fondos, que quieren "doblar la apuesta" en sus ganadores—.
- **ROFR / co-sale (tag along):** derechos preferentes y de acompañamiento en ventas de acciones (del SHA).

6) El vesting de fundadores (*founder vesting*): proteger el "capital humano". *Crucial y a veces malentendido. Las acciones del fundador se "ganan" (vest) con el tiempo (típicamente 4 años*, con un cliff de 1 año —no gana nada el primer año, luego mensual—). ¿Por qué? Porque el inversionista invierte en la empresa por su equipo fundador; si un fundador se va pronto*, no debe quedarse con todas sus acciones (sería injusto para los que se quedan y para el inversionista). Por eso:*

- **Good leaver / bad leaver:** el que se va "**bien**" (sin causa, por razones legítimas) conserva lo *vested*; el que se va "**mal**" (incumpliendo, por causa) puede perder acciones o venderlas a descuento.

- *El abogado del fundador negocia que el vesting sea **justo** (reconocer tiempo ya trabajado —*vesting acreditado*—, aceleración si lo despiden sin causa o si se vende la empresa —*single/double trigger acceleration*—).*

7) Otras cláusulas clave: **drag along** (el inversionista/ mayoría puede forzar la venta del 100% —su salida—), **tag along** (acompañamiento), **lock-up, no competencia** de los fundadores, **opciones** (put/call), y **registration rights** (derecho a exigir el registro de acciones para un IPO).

La idea integradora. Observa que el SHA de una inversión de PE/VC es el **SHA del Libro 4 llevado a su máxima sofisticación**, todo orientado por la lógica del inversionista: **proteger la inversión hasta la salida y asegurar la salida misma**. Preferencia de liquidación (cobrar primero), antidilución (no desvalorizarse), vetos (controlar lo importante), pro-rata (seguir invirtiendo en los ganadores), vesting (retener al equipo), drag along (poder vender todo). Cada cláusula responde a "**entré pensando en cómo salir**". Dominar este term sheet es dominar el lenguaje en que se negocian las inversiones de capital privado.

14.E · EL CAP TABLE Y LAS SALIDAS (LA PROPIEDAD Y LA REALIZACIÓN DEL RETORNO)

El cap table (tabla de capitalización). Es el mapa de la **propiedad** de la empresa: quién posee qué porcentaje, en qué tipo de acciones (ordinarias, preferentes de cada serie), más las opciones (ESOP) y los instrumentos convertibles (SAFE, notas) pendientes de convertir. El abogado de PE/VC **vive en el cap table**: cada ronda, cada opción, cada conversión lo **modifica**, y proyectar su evolución (el *cap table "fully diluted"* —como si todo convirtiera—) es esencial para entender quién controla y quién cobra qué.

- **Por qué importa:** el cap table determina el **control** (quién tiene mayoría, quién tiene vetos), la **dilución** (cómo cambia cada porcentaje en cada ronda), y el **reparto en la salida** (cuánto recibe cada quien, aplicando las preferencias de liquidación). Un cap table "**sucio**" (mal documentado, con promesas informales de equity, convertibles olvidados) es

un **red flag** grave en la due diligence (Libro 2) y puede hundir una ronda o una venta.

- **El waterfall de la salida:** cuando la empresa se vende, el dinero se reparte en **cascada** según el cap table y las preferencias: primero la **deuda**, luego las **preferencias de liquidación** de los inversionistas (en orden de antigüedad, a veces), y al final los **ordinarios** (fundadores y empleados). Calcular ese *waterfall* —quién recibe cuánto en distintos precios de venta— es trabajo fino del abogado.

Las salidas (exit): la realización del retorno. Todo el capital privado existe **para esto**: el fondo invierte para **salir con ganancia**. Las vías:

- **Trade sale (venta estratégica): la más común.** Vender la empresa a un **comprador estratégico** del sector (vía un **M&A** —Libros 1-4—). El comprador paga por las sinergias. El **drag along** del SHA permite al fondo **forzar** la venta del 100%. Aquí se cierra el círculo: la **salida del fondo es la compra de otro** (todo lo que estudiaste de M&A se aplica, ahora del lado del vendedor).
- **Secondary buyout:** vender a **otro fondo de PE** (el siguiente dueño que seguirá creando valor). Frecuente cuando la empresa aún tiene recorrido pero el fondo actual debe salir (su plazo se acaba).
- **IPO (oferta pública inicial):** sacar la empresa a la **bolsa** (régimen de la LMV —emisoras—). Es la salida más prestigiosa (y rara), que da liquidez y valuación de mercado; los **registration rights** del SHA permiten al fondo vender sus acciones tras el IPO.
- **Recompra / redemption:** que la empresa o los socios **recompre** la participación del fondo (salida pactada, típica si no hay venta ni IPO en el horizonte —de ahí las opciones *put*—).

La preparación de la salida (la due diligence inversa). Un buen fondo —y su abogado— **preparan la empresa para venderse** desde mucho antes: gobierno corporativo limpio, contratos en orden, contingencias resueltas, cap table claro, finan-

zas auditadas. ¿Por qué? Porque el comprador hará **due diligence** (Libro 2), y todo lo que encuentre **mal** bajará el precio o matará el deal. Aquí se cierra el gran círculo del Nivel IV: **el fondo, que entró pensando en cómo salir, prepara la empresa para que pase la due diligence del próximo comprador** —la due diligence que tú aprendiste a hacer en el Libro 2, ahora vista desde el lado del vendedor que se prepara para ella—. Todo el M&A es un ciclo, y el PE/VC lo recorre completo: comprar, crear valor, vender. El abogado que lo entiende ha integrado **toda** su formación.

15. Explicación intuitiva

Tres imágenes para fijar la lógica del capital privado.

La metáfora del jardinero (VC) y el restaurador de casas (PE). El VC es un **jardinero que planta muchas semillas**: riega 10, sabe que 7 no brotarán, 2 darán plantas modestas, y **1 será un árbol enorme** que da más fruto que todas las demás juntas. No se obsesiona con las que mueren (es ley de la naturaleza); se obsesiona con **no quedarse sin la semilla del árbol gigante**, así que planta muchas y cuida las que despuntan (las rondas: da más agua a la que crece). El PE es un **restaurador de casas**: compra una casa sólida pero descuidada, **con una hipoteca grande** (apalancamiento), la **remodela** (la mejora) y la **revende** más cara. Su arte es comprar bien, mejorar, y vender mejor —con la palanca de la deuda multiplicando su ganancia (y su riesgo)—.

La metáfora del fondo como "club de inversión con administrador" (GP/LP). Imagina un **club** donde muchos ricos (los LP) ponen su dinero en una bolsa común, y contratan a un **administrador experto** (el GP) para que lo invierta. El administrador cobra una **cuota fija** (2%, para sus gastos) y, sobre todo, se queda con el **20% de las ganancias** (el *carry*) —así se esfuerza en ganar mucho—. El club tiene **fecha de cierre** (10 años): el administrador debe invertir, hacer crecer, y **vender todo** para repartir. Eso explica por qué el fondo siempre tiene **prisa por invertir y obsesión por vender**: no es su dinero, y el reloj corre.

La metáfora del "entré pensando en cómo salir". La clave de **todo** el PE/VC: a diferencia de un dueño que ama su empresa y la quiere para siempre, el fondo es un **inquilino con contrato de salida**. Desde el día que entra, ya está pensando en el día que sale. Por eso pide **preferencia de liquidación** (si la casa se vende barata, que al menos me devuelvan lo mío primero), **drag along** (poder vender la casa entera sin que un inquilino menor lo impida), y **vetos** (que nadie haga nada que arruine la casa antes de venderla). Cada cláusula se entiende preguntando: *¿cómo protege esto mi inversión hasta que salga, y cómo asegura mi salida?*

La intuición central: el inversionista profesional **compra para vender**, y esa lógica explica cada una de sus decisiones y cláusulas. El VC apuesta al *power law* (pocos éxitos enormes), invierte en etapas y se protege para los escenarios regulares; el PE compra control, crea valor y apalanca. Ambos están orientados por el **exit**. El abogado que internaliza "*entró pensando en cómo salir*" entiende —y puede negociar— **todo** lo demás.

16. Ejemplos simples

Ejemplo 1 — Pre-money y dilución. Una *startup* vale 8 (pre-money) y un VC invierte 2. Post-money = 10; el VC se queda con **20%**; los fundadores pasan de 100% a **80%**. Si en la siguiente ronda (Serie B) entra otro inversionista con 25%, todos se **diluyen** proporcionalmente —pero de un pastel más grande—.

Ejemplo 2 — Preferencia de liquidación que protege. Un VC invirtió 10 por el 25% con preferencia **1x non-participating**. La empresa se vende por **20** (mal resultado). El VC elige: ¿su preferencia (recupera **10**) o su 25% (= 5)? Elige la preferencia: **recupera sus 10**; los fundadores se reparten los otros 10. Sin la preferencia, habría recibido solo 5. La preferencia lo **protegió** en el mal escenario.

Ejemplo 3 — El LBO y la palanca. Un fondo compra una empresa por 100 (40 equity + 60 deuda). En 5 años la mejora y la vende por 150; la deuda bajó a 40 (se pagó con el flujo). El

equity recibe **110** sobre 40 invertidos = **2.75x**. La deuda **amplificó** el retorno.

Ejemplo 4 — El vesting que protege al equipo. Tres fundadores tienen 33% cada uno, con **vesting de 4 años**. Uno se va **al año y medio**. Como solo "ganó" (*vested*) ~37% de sus acciones, **devuelve el resto** a la empresa (para los que se quedan y el equipo). El vesting evitó que un fundador que abandonó se quedara con un tercio de la empresa.

17. Ejemplos complejos

Ejemplo complejo 1 — El down round y la antidilución. Un VC entró en la Serie A a \$10/acción con antidilución ***weighted average***. La empresa tropieza y la Serie B se hace a **\$6/acción** (down round). La antidilución **ajusta** el precio de conversión del VC de la Serie A (lo baja parcialmente, de forma ponderada), dándole **más acciones** para compensar la pérdida de valor —a costa de **diluir más a los fundadores**—. Si la cláusula hubiera sido ***full ratchet***, el ajuste sería al precio completo de \$6, castigando brutalmente a los fundadores. *Lección:* la modalidad de antidilución (*weighted* vs. *full ratchet*) puede mover enormes porcentajes en un down round; el abogado del fundador pelea por ***weighted average***.

Ejemplo complejo 2 — La preferencia *participating* que cambia el reparto. Un fondo invirtió 30 por el 30% con preferencia **1x participating**. La empresa se vende por 100. El fondo cobra **primero** su preferencia (30) y **además** participa con su 30% en los 70 restantes (= 21): recibe **51** (no 30). Los fundadores reciben 49 en vez de 70. *Lección:* la preferencia ***participating*** ("double-dip") es mucho más favorable al inversionista; el abogado del fundador pelea por ***non-participating*** (donde el fondo elegiría entre 30 o su 30% de 100 = 30, recibiendo 30, no 51).

Ejemplo complejo 3 — El cap table "sucio" que casi mata una ronda. Una *startup* va a su Serie B, pero la due diligence del nuevo inversionista revela un **cap table sucio**: promesas informales de equity a un ex socio, **SAFEs** olvidados sin convertir, opciones mal documentadas. Nadie sabe con certeza

quién posee qué. El inversionista **frena** la ronda hasta limpiarlo (formalizar conversiones, resolver la promesa al ex socio, documentar el ESOP). *Lección:* el cap table es la **fuentes de verdad** de la propiedad; un cap table desordenado es un **red flag** que puede hundir una ronda o una venta. La higiene del cap table es trabajo constante del abogado.

18. Casos reales (operaciones estilizadas y referentes)

Nota de método (Manifiesto XI.5): casos estilizados con fines didácticos; verifica los detalles antes de citarlos profesionalmente.

RJR Nabisco (1988): el LBO que definió una era. La compra apalancada de RJR Nabisco por KKR (~25 mil millones de dólares), narrada en *Barbarians at the Gate*, marcó la cúspide de los LBO de los años 1980: mostró el **poder** del apalancamiento para adquirir empresas gigantes con relativamente poco equity, y también sus **excesos** (guerras de ofertas, deuda extrema). *Lección:* es el caso fundacional del PE; ilustra la mecánica y los riesgos del LBO al máximo nivel.

Los unicornios y el power law del VC. Los grandes éxitos del venture capital (las empresas tecnológicas que pasaron de garaje a gigantes globales) ilustran el **power law**: un fondo que invirtió temprano en una de ellas pudo generar retornos que **pagaron todo su portafolio muchas veces**. *Lección:* explica por qué el VC apuesta al *upside* ilimitado y tolera muchos fracasos —no busca acertar siempre, busca **no perderse el home run**—.

El auge del VC en América Latina y los unicornios regionales. La última década vio el surgimiento de *unicornios* latinoamericanos (en fintech, e-commerce, logística) financiados por VC global y regional. *Lección:* el VC dejó de ser solo un fenómeno de Silicon Valley; el abogado mexicano de hoy participa en un ecosistema de capital de riesgo vibrante y en crecimiento —una oportunidad para tu generación—.

WeWork / SoftBank (2019): el gobierno del fundador llevado al extremo. Una empresa que llegó a una valuación reportada de ~47,000 mdd [△ verificar](#) y que la perdió en semanas cuando el proceso de salida a bolsa expuso su gobierno

corporativo y sus pérdidas. El caso alimentó el debate sobre las **acciones de voto múltiple**: ¿protegen la visión de largo plazo del fundador, o lo **entronizan** eliminando el único mecanismo que podía corregirlo? La respuesta honesta es que hacen las dos cosas, y que la diferencia la marca el consejo —cuando existe de verdad.

FTX (2022): capital de élite sin los controles que su propia teoría prescribe. Fondos de primer nivel invirtieron sin asientos en el consejo y sin derechos de información significativos. El fraude los borró.

La lección es más incómoda de lo que parece, y es la razón por la que este caso está aquí. No fracasaron por falta de conocimiento: el VC **inventó** los mecanismos de gobierno por etapas y control contingente que acabas de estudiar en el §6. Los abandonaron. En mercados eufóricos, la competencia por entrar en la operación "caliente" hace que el capital **renuncie a sus propias protecciones** —el FOMO del módulo 04 de la Columna V operando con miles de millones—.

Y de ahí la conclusión profesional que te toca: **en VC, el term sheet y el gobierno no son formalismo. Son la diferencia entre invertir y donar.** El abogado que insiste en el asiento en el consejo cuando todos tienen prisa por firmar no está siendo lento: está haciendo el único trabajo que importa. Ver el patrón 2 de Reconocer el desastre antes.

19. Casos empresariales

El PE que profesionaliza una empresa familiar. Una empresa familiar exitosa pero **sin sucesión clara** (los hijos no quieren operarla) recibe la inversión de un fondo de PE, que compra el control: aporta **capital, gobierno profesional y un plan de crecimiento**, y le da a la familia una **salida** (vender ahora) o la oportunidad de **reinvertir** una parte (*rollover*) para ganar en la futura venta. El fondo profesionaliza, hace crecer, y en 5-7 años **revende** la empresa (más grande y mejor gestionada) a un estratégico. *Lección:* el PE es una **solución de sucesión y crecimiento** para empresas familiares —relevante para tu perfil—.

La startup que negocia su Serie A. Una *startup* con tracción levanta su Serie A: un VC ofrece invertir 5 a un pre-mo-

ney de 15 (25% post-money) con preferencia 1x non-participating, antidilución weighted average, un asiento en el consejo, vetos razonables, y vesting de 4 años para los fundadores. El abogado de los fundadores **negocia**: acepta la preferencia 1x non-participating (estándar) y la weighted average (equilibrada), pero pelea por **acotar los vetos** (que no paralizen la operación), por **aceleración del vesting** si los despiden sin causa, y por un **pool de opciones** que no los diluya en exceso. *Lección*: el abogado del fundador no rechaza las protecciones del VC (son de mercado), pero **las equilibra** para proteger a su cliente.

20. Casos corporativos (la conexión integral)

Una operación de PE reúne **todo el Nivel IV**. *Fondo Sierra* (PE) adquiere el control de *Distribuidora Nacional, S.A.* por 2,000 millones (40% equity del fondo, 60% deuda), para profesionalizarla y revenderla en 6 años.

- **Libro 2 (Due Diligence)**: el fondo hace **due diligence** exhaustiva (legal, financiera —QoE—, fiscal, laboral) de la target. Los hallazgos definen precio y protecciones.
- **Libro 3 (Estructuras)**: crea una **NewCo** que tomará la deuda y comprará la target, con miras a una **fusión apalancada** posterior; cuida la asistencia financiera.
- **Libro 4 (Documentación)**: negocia el **SPA** (precio, reps, MAC, indemnización, escrow) con los vendedores; y el **SHA** con la dirección y co-inversionistas (gobierno, *management equity plan* con vesting, drag along para la futura salida).
- **Libro 5 (Financiamiento)**: estructura el **LBO** —deuda senior sindicada + mezzanine, intercreditor, garantías, covenants— y asegura el *committed financing*.
- **Libro 6 (JV/coinversión)**: si co-invierte con otro fondo, estructura la **coinversión** (un SHA entre los fondos).
- **Libro 7 (este)**: orquesta todo desde la **lógica del fondo** —crear valor y preparar la salida—; en 6 años, ejecuta el **exit** (trade sale o IPO), aplicando el M&A del lado del **vendedor** y preparando la empresa para la **due diligence del comprador**.

Moraleja: el PE/VC es la **síntesis suprema** del derecho corporativo: due diligence + estructura + documentación + financiamiento + coinversión, todo orientado por la lógica del inversionista que **compra para vender**. El abogado que domina el PE/VC ha integrado **toda** su formación y la aplica para los clientes más exigentes —el destino del especialista en operaciones complejas—.

21. Casos internacionales

Los estándares globales del VC (NVCA) y la convergencia documental. Los *term sheets* y documentos de VC se han **estandarizado** internacionalmente (los modelos de la **NVCA** —National Venture Capital Association— en EE.UU. son referencia global), lo que crea un **lenguaje común**: un fundador en México, en Brasil o en India negocia esencialmente las mismas cláusulas (preferencia, antidilución, vesting, vetos). *Lección:* el VC "habla un idioma global"; dominar estos estándares (en inglés) es parte del oficio.

Las estructuras offshore y la planeación fiscal de los fondos. Los fondos globales suelen estructurarse en jurisdicciones como **Delaware o Cayman** (por familiaridad de los inversionistas y eficiencia fiscal), invirtiendo luego en empresas locales. Esto crea estructuras **multijurisdiccionales** (el fondo allá, la empresa acá) que el abogado debe coordinar, cuidando la **fiscalidad** (cómo se gravan las ganancias y el *carry*) y el **cumplimiento** (sustancia económica, antiabuso —ecos del Libro 3—). *Lección:* el PE/VC internacional exige coordinar el derecho de fondos *offshore* con el derecho local de la inversión.

El escrutinio creciente: ESG y regulación del capital privado. A nivel global, el capital privado enfrenta **mayor escrutinio**: exigencias **ESG** de los LPs (que sus inversiones sean sostenibles), regulación de los fondos, y debate público sobre el impacto del PE. *Lección:* el abogado de PE/VC moderno debe conocer las **exigencias ESG** (que conectan con el Libro 8) y la regulación creciente de la industria —la frontera actual de la práctica—.

22. Derecho comparado

El PE/VC es una industria global; cambian los vehículos y el marco fiscal/regulatorio. Tabla comparada:

JURISDICCIÓN / SISTEMA	TRATAMIENTO DEL PE/VC
México (Civil Law)	Empresa invertida vía S.A.P.I. (valida preferencias, vetos, drag/tag, opciones, vesting). Fondos vía CKD/CERPI (afores, LMV/CNBV) o vehículos <i>offshore</i> . SAFE/notas adaptados al CCF. Salidas vía M&A o IPO (LMV).
EE.UU. (Common Law)	La cuna. Fondos vía Delaware LP ; empresas vía Delaware C-Corp (VC) o LLC. Documentación estándar NVCA ; <i>case law</i> de Delaware sobre deberes y cláusulas. SAFE (Y Combinator). El mercado más profundo del mundo.
Reino Unido (Common Law)	Hub europeo del PE/VC; fondos vía LP inglés ; documentación de la BVCA ; régimen fiscal del <i>carry</i> muy debatido.
Islas Cayman / Delaware (offshore)	Jurisdicciones preferidas para domiciliar fondos globales (familiaridad de los LP, eficiencia fiscal, flexibilidad). El "back-end" de gran parte del capital privado mundial.
Unión Europea	Regulación de gestores de fondos (AIFMD), iniciativas de capital de riesgo (EuVECA), y creciente énfasis ESG (SFDR) sobre los fondos.
India / Brasil / mercados emergentes	Adaptaron los estándares globales (NVCA) a su marco local; ecosistemas de VC en fuerte crecimiento (como el latinoamericano).
Civil Law vs. Common Law (síntesis)	El common law (EE.UU./Delaware) ofrece los vehículos y la documentación estándar que el mundo copia (NVCA, Delaware LP/C-Corp); el civil law (México) adaptó figuras propias (S.A.P.I. , CKD/CERPI) para dar validez a las mismas cláusulas. La documentación de la inversión converge globalmente (en inglés).

Lección comparada: el PE/VC es quizá el campo **más globalizado y estandarizado** del derecho corporativo. La **S.A.P.I.** mexicana fue diseñada precisamente para "hablar el mismo idioma" que la *Delaware C-Corp* del VC global (validar preferencias, vetos, vesting). El abogado mexicano de PE/VC opera con estándares **plenamente internacionales** (NVCA, term sheets globales) anclados en vehículos locales.

23. Derecho mexicano

El PE/VC en México se asienta en:

- **S.A.P.I. (LMV):** el vehículo de la empresa invertida; **valida** las cláusulas del inversionista (restricciones a la transmisión, vetos, acciones con derechos especiales —preferencias—, opciones, convenios entre accionistas). Pieza central.
- **CKD y CERPI (LMV/CNBV):** vehículos bursátiles para que las **afores** y otros institucionales inviertan en capital privado/proyectos. El "lado del fondo" en México.
- **Acciones de distintas series y derechos (LGSM/LMV):** base para las acciones **preferentes** del inversionista frente a las **ordinarias** de los fundadores.
- **Instrumentos convertibles (autonomía de la voluntad):** notas convertibles y **SAFE** adaptados al derecho mexicano (estructurados con cuidado, pues el SAFE nació en el common law).
- **Convenios entre accionistas (SHA):** el corazón documental, validado por la S.A.P.I.
- **Mercado de valores (LMV):** régimen de emisoras para la salida vía **IPO**.
- **Competencia (LFCE):** las adquisiciones de control (LBO) pueden ser concentraciones notificables.
- **Fiscal (LISR/CFF):** tratamiento de las **ganancias de capital**, del **carry**, y de los vehículos (CKD/CERPI vs. *offshore*); área crítica y especializada.
- **Ley Fintech y regulación sectorial:** relevante para el VC que invierte en sectores regulados emergentes.

Nota de método: la estructura de fondos e inversiones es **intensamente fiscal**; verifica el marco vigente (LMV, reglas de CKD/CERPI, LISR, criterios de la CNBV) y estructura con especialistas antes de aplicar (Manifiesto XI.5).

24. Jurisprudencia relevante

Nota de método: verifica vigencia y datos de identificación antes de citar.

Criterios mexicanos relevantes (en las figuras que sostienen el PE/VC):

- **Validez de los convenios entre accionistas (S.A.P.I. / LMV):** eficacia de las preferencias, vetos, restricciones a la transmisión, drag/tag y opciones —el fundamento de las protecciones del inversionista—.
- **Acciones con derechos especiales (LGSM/LMV):** validez de las distintas series y de las preferencias de liquidación.
- **Interpretación de contratos atípicos (SAFE, notas convertibles):** cómo se interpretan y ejecutan estos instrumentos importados, conforme a la buena fe y la intención.
- **Deberes de los administradores designados por el inversionista (gobierno corporativo):** los deberes fiduciarios de los consejeros nombrados por el fondo (conecta con Gobierno Corporativo).
- **Materia fiscal:** criterios sobre ganancias de capital, vehículos de inversión y tratamiento del carry.

En el ámbito internacional, el **case law de Delaware** sobre deberes fiduciarios en operaciones de PE (conflictos en LBO, transacciones con el control) y la **documentación NVCA** son referencia obligada.

25. Criterios de la Suprema Corte / reguladores

- **SCJN / tribunales:** criterios sobre validez de **convenios entre accionistas**, interpretación de contratos atípicos y deberes de los administradores —que delinear las protecciones del inversionista—.
- **CNBV:** regulación de los **CKD/CERPI** (vehículos de capital privado), del régimen de **emisoras** (para IPO) y de la S.A.P.I./S.A.B.
- **COFEC:** concentraciones en las adquisiciones de control del PE (LBO notificables).
- **SAT/SHCP:** tratamiento fiscal de las ganancias de capital, el *carried interest* y los vehículos de inversión —determinante en el diseño de los fondos—.

- **CONSAR:** regulación de la inversión de los **afores** en capital privado (vía CKD/CERPI), que ha sido clave para el desarrollo del PE/VC mexicano.

26. Doctrina nacional

La doctrina mexicana sobre PE/VC es **relativamente reciente** y proviene, sobre todo, de la **práctica de los despachos especializados** y de las asociaciones de la industria (como AMEX-CAP —la asociación mexicana de capital privado—), más que de tratados académicos clásicos. Se nutre del **derecho societario y bursátil** (la S.A.P.I., los CKD/CERPI), del **derecho de contratos** (los SHA, los instrumentos convertibles adaptados) y del **derecho fiscal**. La doctrina mexicana ha hecho el trabajo de **adaptar** los estándares globales (term sheets NVCA, SAFE, preferencias) al marco jurídico nacional —un esfuerzo de "traducción" jurídica que el abogado mexicano de PE/VC continúa—.

27. Doctrina internacional

- **Documentación estándar NVCA (EE.UU.) y BVCA (Reino Unido).** Los *term sheets* y documentos modelo de VC; el lenguaje común global. **Material imprescindible.**
- **Y Combinator — el SAFE y su documentación.** El instrumento estándar de las rondas semilla y su racional.
- **Doctrina de private equity y LBO (finanzas corporativas).** La mecánica del apalancamiento, la creación de valor y el retorno (IRR, múltiplos).
- **Brad Feld & Jason Mendelson, *Venture Deals*.** Obra de referencia (práctica) sobre cómo funcionan los *term sheets* de VC, cláusula por cláusula —lectura muy recomendada para entender la negociación—.
- **Doctrina de Delaware sobre deberes fiduciarios en PE/VC.** Conflictos de interés, transacciones con el control, deberes de los consejeros designados.
- **Literatura sobre estructura de fondos (LPA, GP/LP, carry).** Cómo se arman y gobiernan los fondos.

28. Opiniones críticas (postura del Consejo Editorial)

Primero: "entró pensando en cómo salir" lo explica todo. Sostenemos que la clave para entender (y negociar con) el PE/VC es internalizar que el fondo es un inversionista con **fecha de salida**. Quien no entiende esto malinterpreta cada cláusula; quien lo entiende, las predice todas.

Segundo: el PE crea o extrae valor —y la diferencia importa éticamente. Reconocemos el debate: hay fondos que **construyen** (profesionalizan, hacen crecer, dejan empresas mejores) y fondos que **extraen** (apalancan en exceso, recortan, vacían y se van). El abogado serio entiende la diferencia y opera con criterio: estructurar operaciones que creen **valor real**, no solo que extraigan a costa de la empresa, los trabajadores o los acreedores.

Tercero: el abogado del fundador debe equilibrar, no rendirse. Advertimos contra dos errores opuestos: el abogado que **rechaza** las protecciones del VC (que son de mercado y razonables —el fundador no conseguirá capital sin ellas—) y el que **cede todo** (vetos excesivos, preferencias participating, full ratchet, vesting brutal). El buen abogado del fundador **acepta lo estándar y pelea lo que importa**: control razonable, dilución moderada, vesting justo con aceleración, antidilución weighted (no full ratchet), preferencia non-participating.

Cuarto: el cap table es sagrado. Insistimos: la higiene del cap table (documentar cada acción, opción y convertible) es trabajo constante y subestimado. Un cap table sucio hunde rondas y ventas. El abogado de PE/VC **vive en el cap table**.

Quinto: la fiscalidad estructura todo. El diseño de fondos e inversiones es **intensamente fiscal** (carry, ganancias de capital, vehículos). Subestimar al fiscalista es el error que más caro cuesta en esta práctica.

Sexto: sobre el gran debate —¿el PE crea valor o lo extrae?— nuestra postura es que la pregunta está mal formulada. La evidencia empírica está genuinamente dividida [△] y por buenas razones: hay casos documentados de mejora real de productividad y gobierno, y hay casos de extracción —

recapitalizaciones con dividendo (*dividend recaps*) que cargan deuda para pagarse a sí mismos, venta de activos (*asset stripping*), ingeniería fiscal agresiva, y traslado de riesgo a acreedores y empleados—.

Que las dos cosas ocurran no es una contradicción: **son dos usos del mismo instrumento**. El apalancamiento que disciplina al *management* (Jensen) es el mismo que, llevado más allá del punto de *trade-off*, traslada el riesgo a terceros que no lo votaron. La diferencia no está en la técnica: está en **dónde se pone el nivel de deuda y quién absorbe el escenario malo**.

Postura del Consejo: al abogado no le corresponde tomar partido en el debate académico, y sí le corresponde saber **de qué lado está la operación que está documentando** — y decirlo. Hay dos preguntas que lo revelan y ninguna requiere ser economista:

1. **¿De dónde sale el retorno prometido?** Si sale de mejora operativa, hay una tesis. Si sale solo del apalancamiento y de la venta de activos, el retorno es transferencia, no creación.
2. **¿Quién soporta el escenario malo?** Si la respuesta es "los acreedores, los proveedores y los trabajadores, y el fondo ya recuperó su capital vía dividendo", eso no es una estructura eficiente: es una externalidad con documentación impecable.

Hacer esas dos preguntas es, en esta práctica, la forma concreta del escepticismo informado — y conecta con la frontera del módulo 06 de la Columna VI: que una estructura sea legal no la vuelve defendible ante quien la examine sabiendo cómo terminó.

29. Debate doctrinal

- **¿El PE crea valor o lo extrae?** *Postura del Consejo*: **ambos existen**; depende del fondo y de la operación. El PE que profesionaliza, hace crecer y deja una empresa mejor **crea** valor; el que apalanca en exceso y vacía **extrae** (a veces

destruyendo la empresa). El abogado debe estar del lado de la creación.

- **Preferencia *participating* vs. *non-participating*.** ¿Debe el inversionista cobrar su preferencia **y además** participar (*participating*), o elegir entre una u otra (*non-participating*)? *Postura del Consejo:* la ***non-participating 1x*** es lo **equilibrado y de mercado**; la *participating* (*double-dip*) es agresiva y castiga desproporcionadamente a los fundadores —el abogado del fundador debe resistirla—.
- **Antidilución: *weighted average* vs. *full ratchet*.** *Postura del Consejo:* la ***weighted average*** es justa (ajuste proporcional); la ***full ratchet*** es punitiva (trata al inversionista como si hubiera entrado al precio más bajo, diluyendo brutalmente a los fundadores) y solo se justifica en circunstancias excepcionales.
- **¿Cuánto control debe ceder el fundador?** Tensión entre la necesidad de capital y la conservación del control. *Postura del Consejo:* el fundador debe ceder los **vetos razonables** que protegen la inversión del VC, pero resistir los que **paralizan** la operación o lo expulsan injustamente; el equilibrio protege a ambos (un fundador sin incentivo ni control destruye el valor que el VC busca).
- **El *carried interest* y su tratamiento fiscal.** Debate global: ¿debe el *carry* gravarse como **ganancia de capital** (tasa baja) o como **ingreso ordinario** (tasa alta)? *Postura del Consejo:* es un debate de política fiscal legítimo (¿es el *carry* un retorno de inversión o una remuneración por servicios?); el abogado debe **conocer** el tratamiento vigente y estructurar conforme a derecho, sin esquemas abusivos.
- **¿Es sano el nivel de apalancamiento del PE?** *Postura del Consejo:* el apalancamiento moderado crea valor; el **excesivo** traslada un riesgo enorme a la empresa y sus acreedores (y puede quebrarla). La prudencia —y el respeto a la protección de acreedores y a la asistencia financiera— es la línea correcta.

30. Errores comunes

- **No entender la lógica de salida del fondo.** Negociar con un fondo sin recordar que "entró pensando en cómo salir" → no anticipar su insistencia en drag along, preferencia y exit. *Corrección:* lee cada cláusula como protección de la inversión hasta la salida.
- **Cap table sucio.** Promesas informales de equity, SAFEs sin convertir, opciones mal documentadas → hunde rondas y ventas en la due diligence. *Corrección:* higiene constante del cap table.
- **Ceder preferencia *participating* o *full ratchet* sin pelearlas.** El abogado del fundador acepta cláusulas agresivas que castigan desproporcionadamente. *Corrección:* pelear non-participating 1x y weighted average (lo de mercado).
- **Vesting injusto o sin aceleración.** No negociar reconocimiento del tiempo trabajado ni aceleración si despiden al fundador sin causa o se vende la empresa. *Corrección:* vesting justo con *single/double trigger acceleration*.
- **Vetos excesivos que paralizan.** Ceder al inversionista vetos sobre decisiones operativas, no solo las estratégicas → la empresa se paraliza. *Corrección:* acotar los vetos a lo verdaderamente relevante.
- **Olvidar la asistencia financiera en el LBO.** Usar los activos de la target para su propia compra sin estructurar → ilegal (Libro 5). *Corrección:* NewCo + fusión apalancada bien estructurada.
- **Subestimar la fiscalidad.** Estructurar el fondo o la inversión sin fiscalista → consecuencias caras en carry, ganancias de capital, vehículos. *Corrección:* fiscalista desde el diseño.
- **No preparar la empresa para la salida.** Llegar al exit con gobierno sucio, contingencias y cap table desordenado → la due diligence del comprador baja el precio o mata el deal. *Corrección:* preparar la "due diligence inversa" desde antes.

31. Mitos frecuentes

- **"El VC quiere quedarse con mi empresa." Falso.** El VC quiere que crezcas y **salir con ganancia**; su éxito es tu éxito (en el upside). No quiere operarla ni conservarla.
- **"Más valuación siempre es mejor para el fundador." Falso/matizado.** Una valuación inflada hoy puede causar un **down round** doloroso mañana (con antidilución que te diluye) y dificultar futuras rondas. A veces una valuación realista es mejor.
- **"La preferencia de liquidación solo importa si quiebro." Falso.** Importa sobre todo en ventas **mediocres** (las más probables): determina quién cobra cuánto. Define el reparto en casi todos los escenarios salvo el gran éxito.
- **"El PE solo gana con deuda (ingeniería financiera)." Falso/parcial.** El apalancamiento ayuda, pero el PE maduro crea valor sobre todo **operando mejor** (crecimiento, profesionalización, add-ons).
- **"El SAFE es deuda." Falso.** El SAFE **no es deuda ni equity** hasta que convierte (sin interés ni vencimiento); la **nota convertible** sí es deuda. Son distintos.
- **"El carry es solo un sueldo grande del gestor." Falso.** Es una **participación en las ganancias** por encima de un umbral (hurdle), con clawback; alinea al GP con los LPs (solo gana si el fondo gana).
- **"Levantar capital de un fondo es siempre bueno." Falso.** Trae capital, pero también dilución, pérdida de control y presión de salida. Hay que evaluar si conviene.

32. Preguntas difíciles

1. **¿Por qué el fondo insiste tanto en el drag along?** Porque su negocio es **salir con ganancia**, y la salida más común es vender la empresa **entera** a un comprador (que quiere el 100%). El drag along le permite **forzar** a los demás socios a vender con él, garantizando que un minoritario no bloquee su exit. Sin drag, su salida queda a merced de terceros.

2. **¿Por qué una valuación muy alta puede perjudicar al fundador?** Porque crea expectativas que, si no se cumplen, llevan a un **down round** (ronda a menor precio), que activa la **antidilución** del inversionista (diluyendo más al fundador) y daña la moral y la capacidad de levantar capital. Una valuación **realista y sostenible** suele ser mejor que una inflada.
3. **Preferencia non-participating 1x: ¿qué elige el inversionista en una venta?** Compara: ¿le conviene más su **preferencia** (recuperar 1x su inversión) o **convertir** a ordinario y cobrar su **porcentaje**? Elige lo mayor. En ventas **bajas**, la preferencia (recupera lo suyo); en ventas **altas**, convierte (su % vale más). Por eso "non-participating" es equilibrada: no cobra ambas.
4. **¿Por qué existe el vesting de fundadores si ya son dueños?** Porque el inversionista invierte por el **equipo**; si un fundador **se va pronto**, no es justo que conserve todas sus acciones (perjudica a los que se quedan y al inversionista). El vesting hace que las acciones se "**ganen**" con permanencia, alineando el incentivo de quedarse y construir.
5. **¿Cómo se conecta la salida del fondo con la due diligence (Libro 2)?** La salida del fondo suele ser la **compra de otro** (trade sale): el comprador hará **due diligence** de la empresa. Por eso el fondo **prepara** la empresa (gobierno limpio, cap table ordenado, contingencias resueltas) para **pasar** esa due diligence —la "due diligence inversa"—. El M&A es un ciclo: el fondo lo recorre completo (compra, crea valor, vende).

33. Casos de examen (con respuesta modelo)

Caso A. *Representas a un fundador en su Serie A. El VC pide preferencia 1x participating, antidilución full ratchet, vetos amplios y vesting de 4 años sin aceleración. ¿Qué negocias?* **Respuesta modelo:** Aceptar lo estándar y **pelear lo agresivo**: cambiar la preferencia a **1x non-participating** (no participating/double-dip); la antidilución a **weighted average** (no full ratchet); **acotar los vetos** a decisiones verdaderamente estratégicas (no operativas); y negociar **aceleración del vesting** (single trigger

si lo despiden sin causa; double trigger en cambio de control) y reconocimiento del tiempo ya trabajado. Razonar: las protecciones del VC son legítimas, pero estas versiones son **agresivas** y castigan desproporcionadamente al fundador.

Caso B. *Un fondo de PE quiere comprar el control de una empresa familiar por LBO. ¿Qué reúne esta operación de todo el Nivel IV?* **Respuesta modelo:** **Due diligence** (L2) de la target; **estructura** NewCo + fusión apalancada (L3, cuidando asistencia financiera); **SPA** con los vendedores y **SHA** con la dirección (*management equity plan* con vesting) (L4); **LBO** —deuda senior + mezzanine, intercreditor, garantías, covenants, *committed financing*— (L5); posible **coinversión** con otro fondo (L6); y todo orientado por la **lógica del fondo** (crear valor, preparar y ejecutar el **exit** en 5-7 años) (L7). Es la síntesis del Nivel IV.

Caso C. *Una startup tiene un cap table con SAFEs sin convertir, una promesa verbal de 5% a un ex asesor y opciones mal documentadas. Va a su Serie B. ¿Qué haces antes de la ronda?* **Respuesta modelo:** **Limpiar el cap table** antes de la ronda: documentar la **conversión** de los SAFEs (calcular su efecto con descuento/cap), resolver y formalizar (o liberar) la **promesa al ex asesor**, y documentar correctamente el **pool de opciones (ESOP)**. Presentar un cap table **fully diluted** claro. Razonar: un cap table sucio es un *red flag* que frena la ronda; la higiene es condición para invertir.

34. Simulador (ejercicio tipo despacho)

Instrucciones: eres asociado. Representas a un **fondo de VC** que invertirá **3 millones** en una *startup* de fintech, a un **pre-money de 9** (Serie A). Diseña los términos clave antes de leer la guía.

1. ¿Qué **porcentaje** obtiene el fondo? (calcula con pre/post-money)
2. ¿Qué **preferencia de liquidación** y **antidilución** propones (de mercado)?
3. ¿Qué **derechos de gobierno** pides?
4. ¿Qué **vesting** para los fundadores?

5. ¿Qué cuidas en el **cap table** y para la **salida**?

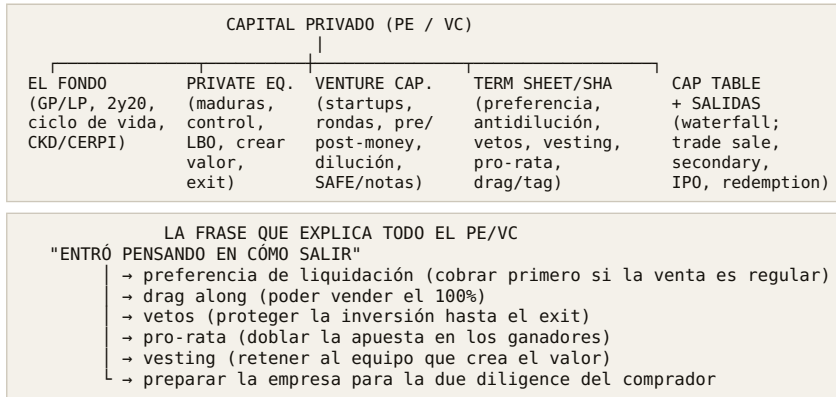
Guía de solución (resumen). (1) Post-money = $9 + 3 = 12$; el fondo obtiene 25% (3/12). (2) Preferencia **1x non-participating** (de mercado); antidilución **weighted average** (equilibrada). (3) Un **asiento** en el consejo; **protective provisions/vetos** sobre lo estratégico (vender, emitir acciones, endeudarse, cambiar giro, presupuesto, CEO); **información** periódica; **pro-rata** para futuras rondas. (4) Vesting de fundadores **4 años con cliff de 1**, good/bad leaver, con aceleración negociada. (5) Cap table **fully diluted** limpio (ESOP del 10-15% definido, convertibles documentados); pensar el **exit** desde ahora (drag along, registration rights). Anclar todo en una **S.A.P.I.**

35. Flashcards

- **¿PE vs. VC?** PE: empresas maduras, control, LBO. VC: startups, minoritario, rondas.
- **¿GP vs. LP?** Gestor (administra, cobra carry) / inversionista (aporta capital, pasivo).
- **¿"2 y 20"?** Management fee ~2% + carried interest ~20% de las ganancias.
- **¿Pre-money vs. post-money?** Valuación antes / después de la inversión (post = pre + inversión).
- **¿% del inversionista?** Inversión / post-money.
- **¿Preferencia de liquidación?** Cobrar primero (1x); non-participating (elige) vs. participating (double-dip).
- **¿Antidilución?** Protección en down round; weighted average (justa) vs. full ratchet (punitiva).
- **¿Vesting de fundadores?** Las acciones se ganan con el tiempo (4 años + cliff de 1); good/bad leaver.
- **¿SAFE vs. nota convertible?** SAFE no es deuda ni equity (sin interés/vencimiento) / nota es deuda (interés, vencimiento); ambos convierten con descuento y/o cap.
- **¿Cap table?** Mapa de quién posee qué; cambia con cada ronda; debe estar "limpio".
- **¿Power law?** Pocos éxitos enormes pagan muchos fracasos (lógica del VC).
- **¿Drag along (por qué le importa al fondo)?** Le permite forzar la venta del 100% (su exit).

- **¿Exits?** Trade sale, secondary buyout, IPO, redemption.
- **¿La frase que lo explica todo?** "El fondo entró pensando en cómo salir".

36. Mapas mentales



37. Cuadros comparativos

Private Equity vs. Venture Capital

	PRIVATE EQUITY	VENTURE CAPITAL
Empresa	Madura, con flujo	Joven, alto crecimiento
Participación	Control (mayoría)	Minoritaria
Apalancamiento	Sí (LBO)	No (startups sin flujo)
Riesgo	Menor, consistente	Alto (power law)
Cómo crea valor	Operar mejor + apalancar + multiple	Crecimiento exponencial
Instrumento	Compra de acciones / LBO	Acciones preferentes, SAFE, notas

Preferencia de liquidación

	NON-PARTICIPATING (ESTÁNDAR)	PARTICIPATING (AGRESIVA)
Cobra	Preferencia o su % (elige)	Preferencia y además su %
Favorece a	Equilibrio	Inversionista (castiga fundador)

Antidilución

	WEIGHTED AVERAGE (JUSTA)	FULL RATCHET (PUNITIVA)
Ajuste	Proporcional al down round	Al precio más bajo (total)
Efecto en fundador	Moderado	Severo

38. Diagramas

El ciclo del fondo:

FUNDRAISING (levantar capital de LPs)
 → INVERSIÓN (capital calls; comprar/invertir en empresas)
 → GESTIÓN / CREACIÓN DE VALOR (operar, crecer, add-ons)
 → EXIT (trade sale / secondary / IPO) → DISTRIBUIR a LPs (capital + hurdle, luego 80/20)
 → (mientras tanto: levantar el SIGUIENTE fondo)

El waterfall de la salida (reparto):

PRECIO DE VENTA
 1) Pagar la DEUDA
 2) PREFERENCIAS DE LIQUIDACIÓN de los inversionistas (por antigüedad)
 3) Lo que sobra → ORDINARIOS (fundadores + empleados con opciones)
 [non-participating: el inversionista elige preferencia 0 conversión, lo mayor]

El gran círculo del M&A (cómo el Nivel IV se cierra):

EL FONDO COMPRA (M&A, L1-4; due diligence, L2; estructura, L3; LB0, L5)
 → CREA VALOR (gobierno, SHA, add-ons; L4-6)
 → PREPARA LA SALIDA (due diligence inversa; cap table limpio)
 → VENDE (su exit = la COMPRA de otro → vuelve al inicio del ciclo)

39. Mnemotecnias

- **La frase maestra:** *"el fondo entró pensando en cómo salir"* (explica cada cláusula).
- **PE vs. VC:** *"PE compra maduras con deuda; VC siembra startups en rondas"*.
- **2 y 20:** *"2% por gestionar; 20% por ganar"*.
- **Pre/post-money:** *"post = pre + lo que entra; mi % = lo que pongo / post"*.
- **Preferencia:** *"non-participating elige; participating se lleva ambas (double-dip)"*.
- **Antidilución:** *"weighted es justa; full ratchet es castigo"*.
- **Vesting:** *"las acciones se ganan quedándote (4 años, cliff de 1)"*.
- **SAFE:** *"ni deuda ni equity hasta que convierte"*.
- **Cap table:** *"si está sucio, no hay ronda ni venta"*.
- **Power law:** *"muchas semillas, un árbol gigante paga todo"*.

- **Regla de oro:** "el PE/VC es la síntesis del Nivel IV: comprar, crear valor, vender".

40. Resumen ejecutivo

El **private equity (PE)** y el **venture capital (VC)** son las formas de **inversión de capital privado**: fondos que reúnen dinero de inversionistas (los **LP**) y lo invierten —gestionados por el **GP**— en empresas que no cotizan, para hacerlas crecer y **venderlas con ganancia** en años. El **PE** invierte en empresas **maduras**, comprando el **control** (a menudo con deuda —el **LBO**—) y creando valor por mejora operativa, crecimiento, apalancamiento y *multiple expansion*. El **VC** invierte en **startups** en **rondas** sucesivas (semilla, Serie A, B...), tomando participaciones minoritarias y apostando al *power law* (pocos éxitos enormes pagan muchos fracasos). El fondo se estructura como **GP/LP** con el modelo "**2 y 20**" (comisión de gestión + *carried interest*) y un ciclo de vida de ~10 años; en México, los vehículos son los **CKD/CERPI** (para afores) y la **S.A.P.I.** (para la empresa invertida). La inversión se documenta con un **term sheet** y un **SHA especializadísimo** cuyas cláusulas —**preferencia de liquidación, antidilución, vetos, pro-rata, vesting de fundadores, drag/tag along**— protegen la inversión hasta la salida. El **cap table** mapea la propiedad, y las **salidas** (*trade sale, secondary, IPO, redemption*) realizan el retorno.

La frase que lo explica **todo: el fondo entró pensando en cómo salir**. Su horizonte definido y su incentivo de retorno (el *carry*) explican cada decisión y cada cláusula —la preferencia (cobrar primero en ventas regulares), el drag along (vender el 100%), los vetos (proteger hasta el exit), el vesting (retener al equipo)—. Y la gran síntesis para tu perfil: el **PE/VC reúne todo el Nivel IV** —due diligence (L2), estructura (L3), documentación/SHA (L4), financiamiento/LBO (L5) y coinversión (L6)—, orientado por la lógica del inversionista que **compra para vender**. El gran círculo del M&A se cierra: el **exit del fondo es la compra de otro**, y por eso el fondo prepara la empresa para **pasar la due diligence** del próximo comprador —la misma que tú aprendiste a hacer en el Libro 2—. El abogado que domina el PE/VC ha integrado toda su formación y la

aplica para los clientes más exigentes: es, en formación, el **especialista en operaciones corporativas complejas** que persigues.

41. Checklist

Estructura del fondo (si asesoras al fondo):

- [] ¿**GP/LP** y vehículo (CKD/CERPI / *offshore*) bien estructurados? ¿LPA con comisiones (2y20), hurdle, clawback, gobernanza, conflictos?
- [] ¿Diseño **fiscal** del fondo y del *carry* con especialistas?

La inversión (term sheet y SHA):

- [] ¿**Valuación** (pre/post-money) y **porcentaje** claros? ¿Instrumento (preferentes / SAFE / nota)?
- [] ¿**Preferencia de liquidación** (1x non-participating de mercado)? ¿**Antidilución** (weighted average)?
- [] ¿**Gobierno**: asientos, **vetos** acotados a lo estratégico, información, **pro-rata**?
- [] ¿**Vesting** de fundadores justo (4 años + cliff, good/bad leaver, aceleración)?
- [] ¿**Drag along / tag along / ROFR** y **registration rights** para la salida?
- [] ¿Todo anclado en una **S.A.P.I.** (validez societaria)?

PE / LBO:

- [] ¿**Due diligence** (L2), **estructura** NewCo + fusión (L3), **LBO** con intercreditor y *committed financing* (L5)? ¿**Asistencia financiera** resuelta?
- [] ¿*Management equity plan* (vesting/incentivos a la dirección)?

Cap table y salida:

- [] ¿**Cap table** *fully diluted* limpio y documentado (SAFEs, opciones, convertibles)?
- [] ¿Empresa **preparada para la salida** (gobierno limpio, contingencias resueltas) para pasar la due diligence del comprador?

42. Bibliografía comentada

- **Brad Feld & Jason Mendelson, *Venture Deals*. Lectura imprescindible (práctica):** cómo funcionan los *term sheets* de VC cláusula por cláusula, desde la óptica de fundadores e inversionistas.
- **Documentación estándar NVCA (EE.UU.) y de la BVCA (Reino Unido).** Los modelos globales de documentos de VC; el lenguaje común.
- **Y Combinator — el SAFE y su documentación.** El instrumento estándar de las rondas semilla.
- **Ley del Mercado de Valores (S.A.P.I., CKD/CERPI) y normativa de la CNBV/CONSAR.** El marco mexicano de la empresa invertida y de los vehículos de los fondos.
- **Doctrina y materiales de PE/LBO (finanzas corporativas).** La mecánica del apalancamiento, la creación de valor, el IRR y los múltiplos.
- **AMEXCAP (asociación mexicana de capital privado) y guías de la industria.** La práctica del PE/VC en México.
- **Jurisprudencia de Delaware sobre deberes fiduciarios en PE/VC.** Conflictos de interés y deberes de los consejeros designados por el fondo.
- ***Barbarians at the Gate* (Burrough & Helyar).** El relato del LBO de RJR Nabisco; entender la cultura, el poder y los excesos del PE.

43. Ruta hacia el siguiente libro

Has llegado a la **cumbre del Nivel IV**: el PE/VC, donde todo lo aprendido —comprar, financiar, colaborar— se integra en la lógica del inversionista profesional. Solo falta el libro que **cierra el nivel** elevando la mirada de la operación a la **empresa como institución de poder y responsabilidad** en el largo plazo.

- **Siguiente libro (cierra el Nivel IV):** *Libro 8 · Gobierno corporativo avanzado, Compliance y ESG* — el gobierno corporativo de élite (consejos sofisticados, comités, deberes fidu-

ciarios reforzados en operaciones —Revlon/Unocal—), el **compliance** (programas de cumplimiento, anticorrupción —FCPA—, prevención de lavado, líneas de denuncia) y el **ESG** (sostenibilidad, criterios ambientales, sociales y de gobernanza que hoy condicionan la inversión y la reputación). Es la capa que da **legitimidad y sostenibilidad** a todo lo demás.

- **Conexión inmediata:** los fondos de PE/VC son hoy de los mayores impulsores del **gobierno corporativo profesional** (lo instalan en sus empresas) y del **ESG** (sus LPs lo exigen). El **compliance** es lo que protege a la empresa y a sus directivos en cada operación que has estudiado. El Libro 8 te dará el marco que **legitima y protege** toda la práctica corporativa.

♦ ¿Por qué esto importa para un abogado corporativo?

Porque los fondos de **PE y VC son los clientes más sofisticados, recurrentes y valiosos** del abogado corporativo de élite, y atenderlos significa estar en el **centro del deal flow** del mercado —ver y estructurar las operaciones más interesantes, una tras otra—. Para tu perfil, el PE/VC es donde **todo converge**: una operación de PE reúne due diligence, estructura, documentación, financiamiento y gobierno; una de VC, un SHA especializadísimo y una apuesta sobre el crecimiento. Dominar el PE/VC es dominar la **aplicación integrada** de toda tu formación, para los clientes que pagan por el mejor trabajo. Y es, además, un destino natural de carrera: muchos de los mejores abogados corporativos terminan asesorando a fondos de forma recurrente, como *general counsel* de un fondo, o pasando al lado de la inversión. El PE/VC es el motor que financia la innovación (VC) y profesionaliza las empresas (PE): entenderlo te conecta con **cómo se mueve el capital y se crea valor** en el mundo real.

◆ Cómo piensa un socio de un despacho internacional

"Cuando represento a un fondo, la primera regla que le enseño a mis asociados es: todo se explica porque el fondo entró pensando en cómo salir. No es un dueño que ama la empresa; es un gestor de dinero ajeno con una fecha de salida y un carry que cobrar. Por eso, cuando negocio el SHA, mi brújula es el exit: la preferencia de liquidación es su red de seguridad para la venta regular; el drag along es su garantía de poder vender el 100%; los vetos protegen su inversión hasta que salga; el vesting retiene al equipo que crea el valor que venderá. Cuando represento al fundador, mi trabajo es otro: el VC necesita esas protecciones —sin ellas no hay capital—, así que no las rechazo; las equilibro. Acepto la 1x non-participating y la weighted average (son de mercado), pero peleo a muerte por acotar los vetos a lo estratégico, por un vesting con aceleración si lo despiden, y por una dilución que le deje incentivo. Y en un PE/LBO, vivo en tres documentos a la vez: el SPA de la compra, el facilities agreement de la deuda, y el SHA con la dirección —porque la operación es M&A + financiamiento + gobierno, todo junto—. Y desde el día uno pienso en el día de la venta: preparo la empresa para que pase la due diligence del próximo comprador. El abogado que domina el PE/VC no hace una cosa: hace todas a la vez."

◆ Errores que cuestan millones

1. **No entender la lógica de salida del fondo.** Negociar sin ver que cada cláusula protege la inversión hasta el exit → ceder o pelear lo equivocado. *Prevención:* lee todo desde "entró pensando en cómo salir".
2. **Cap table sucio.** SAFEs sin convertir, promesas informales, opciones mal documentadas → hunde rondas y ventas en la due diligence. *Prevención:* higiene constante del cap table fully diluted.
3. **Ceder cláusulas agresivas (participating, full ratchet, vetos operativos, vesting sin aceleración).** El abogado del fundador acepta lo que castiga desproporcionadamente. *Prevención:* aceptar lo de mercado, pelear lo agresivo.
4. **LBO que ignora la asistencia financiera o sobre-apalanca.** Estructura ilegal o empresa aplastada por la deuda. *Pre-*

vención: NewCo + fusión bien estructurada; apalancamiento prudente.

5. **No preparar la salida.** Llegar al exit con gobierno sucio y contingencias que la due diligence del comprador castiga, bajando el precio o matando el deal. *Prevención:* due diligence inversa desde antes.

Cierre del Libro 7. Has subido a la **cumbre del Nivel IV**: el mundo del capital privado, donde el inversionista profesional **compra para vender** y donde **todo** lo que aprendiste —due diligence, estructura, documentación, financiamiento, coinversión— se integra en una sola lógica. Te llevas la frase que lo explica todo —"el fondo entró pensando en cómo salir"— y la capacidad de ver una operación de PE/VC como la síntesis del derecho corporativo. Ya manejas el repertorio completo del estructurador de operaciones complejas: comprar, financiar, colaborar e invertir como un fondo. Solo falta la capa que da **legitimidad y sostenibilidad** a todo: en el **Libro 8 · Gobierno Corporativo Avanzado, Compliance y ESG** —que cierra el Nivel IV— aprenderás el marco que **protege y legitima** a la empresa y a quienes la dirigen en cada operación que has estudiado.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE IV

[Nivel IV · Libro 8] Gobierno Corporativo Avanzado, Compliance y ESG

☛ **Apóstrofe de vigencia** — **léela cada vez**. El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☛ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en .../.../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☛ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

Has aprendido a comprar, financiar, colaborar e invertir como un fondo. Pero todas esas operaciones ocurren **dentro** de empresas que son, ante todo, **instituciones de poder y responsabilidad** —y que deben operar de forma **legítima, controlada y sostenible** para sobrevivir y crear valor en el largo plazo—.

Este libro cierra el Nivel IV elevando la mirada de la **operación** a la **institución**: el **gobierno corporativo avanzado** (cómo se ejerce y controla el poder en la empresa, los deberes fiduciarios reforzados en las operaciones), el **compliance** (los sistemas que previenen que la empresa y sus directivos incurran en ilícitos —corrupción, lavado—) y el **ESG** (los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que hoy condicionan la inversión, el financiamiento y la reputación). Es la capa que **legitima y protege** todo lo que has estudiado.

Etiquetas: corporate law · gobierno corporativo · deberes fiduciarios · compliance · anticorrupción · ESG · sostenibilidad · consejo **Prerrequisitos:** todo el Nivel IV previo + Gobierno Corporativo (Nivel III), Sociedades (LGSM) y Mercado de Valores (LMV). **Estándar:** V3 (43 secciones + secciones transversales). ⌚ **Tiempo estimado de dominio:** 5–6 semanas (≈ 55–65 h de estudio activo). Lectura de reconocimiento: 10–12 h. *Estúdialo en bloques: el gobierno corporativo avanzado (con-*

sejo, deberes reforzados) → los deberes fiduciarios en operaciones (Revlon, Unocal, conflictos) → el compliance (programas, anticorrupción, lavado) → el ESG (los tres pilares, materialidad, reporting) → la integración (gobierno + compliance + ESG como sistema).

Aviso de método. Tratado, no repaso. Aprenderás cómo se **ejerce, controla y legitima el poder** en la empresa moderna: los deberes reforzados del consejo en cada operación que estudias-te, los sistemas que protegen a la empresa y a sus directivos (compliance), y los criterios que hoy condicionan el capital (ESG). Es la capa transversal que da **sostenibilidad y legitimidad** a toda la práctica corporativa.

NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL (VISTA RÁPIDA)

Litigio	★★★★☆
Corporate	★★★★★
M&A	★★★★★
Mercado de Valores	★★★★★
Venture Capital	★★★★☆
Private Equity	★★★★★
Gobierno Corporativo	★★★★★
Compliance	★★★★★
Derecho Bancario	★★★★☆
Empresa Familiar	★★★★★

Es la capa transversal de toda la práctica corporativa: el gobierno define quién decide y responde; el compliance protege a la empresa y a sus directivos; el ESG condiciona el acceso al capital. Para tu perfil (gobierno corporativo + operaciones complejas), es columna vertebral y cierre natural del Nivel IV.

1. Introducción

Una empresa no es solo un conjunto de operaciones (comprar, financiar, colaborar, invertir): es una **institución** que concentra **poder** (decisiones que afectan a accionistas, trabajadores, acreedores, clientes y a la sociedad) y que, por ello, exige **responsabilidad y control**. Este libro estudia las tres dimensiones que regulan ese poder en la empresa moderna, y que se han vuelto **centrales** para el abogado corporativo de élite:

1. El **gobierno corporativo avanzado**: el sistema de **poder, control y responsabilidad** dentro de la empresa —cómo se

compone y opera un consejo sofisticado, cómo funcionan los comités, y cómo se aplican los **deberes fiduciarios** (diligencia y lealtad) **reforzados** en las operaciones que has estudiado (M&A, financiamiento, conflictos de interés)—. Ya conociste sus fundamentos en el Nivel III; aquí lo llevamos al **nivel de las operaciones complejas**.

2. El **compliance** (cumplimiento normativo): los **sistemas** que la empresa instala para **prevenir, detectar y corregir** que ella o sus directivos incurran en ilícitos —especialmente **corrupción** (FCPA y leyes locales), **lavado de dinero**, y otras infracciones graves—. El compliance es lo que **protege** a la empresa y a quienes la dirigen.
3. El **ESG** (*Environmental, Social, Governance*): los **criterios de sostenibilidad** —ambientales, sociales y de gobernanza— que hoy **condicionan** la inversión (los fondos y LPs los exigen), el financiamiento (créditos verdes/sostenibles), la reputación y, crecientemente, la regulación.

La idea rectora del libro: **el poder corporativo, para crear valor de forma sostenible, debe ser legítimo, controlado y responsable**. El gobierno corporativo define **quién decide y responde**; el compliance asegura que se decida **dentro de la ley**; y el ESG, que se decida considerando el **impacto** de largo plazo (ambiental, social) y no solo la ganancia inmediata. Las tres dimensiones convergen en una sola idea moderna: una empresa **bien gobernada, que cumple la ley y opera de forma sostenible vale más, atrae mejor capital, resiste las crisis y perdura**. Y al revés: una empresa con mal gobierno, sin compliance o que ignora el ESG, **destruye valor** (escándalos, sanciones, pérdida de inversión y reputación, hasta el colapso —Enron, los grandes casos de corrupción—).

Para el abogado corporativo, y especialmente para **tu perfil** (gobierno corporativo entre tus áreas centrales), esta es una **práctica de élite y en auge**: asesorar consejos, diseñar programas de compliance, estructurar el gobierno de las empresas en cada operación, y navegar las exigencias ESG. Es la capa que **legitima y protege** toda la práctica corporativa —y, no por casualidad, **cierra** el Nivel IV—.

2. Objetivos del libro

Al terminar, el lector será capaz de:

- **Dominar el gobierno corporativo avanzado:** la composición y dinámica de un **consejo** sofisticado (independientes, comités —auditoría, prácticas societarias, riesgos—), la separación de roles, y el gobierno en empresas públicas (S.A.B./LMV), familiares y participadas por fondos.
- **Aplicar los deberes fiduciarios reforzados en operaciones:** el deber de **diligencia** (decidir informado, *business judgment rule*) y de **lealtad** (conflictos, operaciones con partes relacionadas) en M&A y financiamiento, y los estándares de Delaware (**Revlon**, **Unocal**, **Caremark**, **Van Gorkom**) que modelan la práctica global.
- **Diseñar y evaluar un programa de compliance:** sus elementos (*tone at the top*, evaluación de riesgos, políticas, capacitación, **canal de denuncias**, investigaciones internas, monitoreo), el **compliance anticorrupción** (FCPA, UK Bribery Act, Ley General de Responsabilidades Administrativas) y la **prevención de lavado** (PLD/AML, KYC).
- **Comprender el ESG:** sus tres pilares (ambiental, social, gobernanza), la **materialidad** ESG, el *reporting* y los estándares, las finanzas sostenibles (bonos verdes, créditos vinculados a sostenibilidad), y el riesgo del *greenwashing*.
- **Integrar las tres dimensiones** en cada operación: cómo el gobierno, el compliance y el ESG se aplican en un M&A (deberes del consejo, due diligence de compliance/ESG), un financiamiento (covenants ESG), una inversión de PE/VC (los fondos como impulsores del gobierno y el ESG).
- **Asesorar a un consejo de administración:** el rol del abogado como asesor del órgano de mayor responsabilidad y prestigio del derecho de los negocios.

3. Importancia profesional

Para el abogado corporativo —y de manera muy especial para **tu perfil**, que sitúa el **gobierno corporativo** entre tus áreas

centrales—, esta es una de las prácticas de **mayor responsabilidad, prestigio y crecimiento**. Asesorar a un **consejo de administración** en sus decisiones críticas (una venta, una operación con el control, una crisis) es el rol de **mayor confianza** del derecho de los negocios: el abogado se vuelve el **consejero del órgano que decide y responde**. Y el **compliance** y el **ESG** son áreas en **expansión acelerada**, demandadas por empresas, fondos y reguladores.

Hay tres razones de fondo para su importancia creciente. **Primera, la transversalidad:** el gobierno corporativo está presente en **cada** operación que has estudiado —los deberes del consejo al vender (M&A), al endeudarse (financiamiento), al aliarse (JV), al recibir inversión (PE/VC)—; el **compliance** protege en todas; el **ESG** condiciona el capital de todas. **Segunda, el riesgo:** los fallos de gobierno, **compliance** o **ESG destruyen empresas** (Enron, los grandes casos de corrupción, los desastres ambientales) y generan **responsabilidad personal** para directivos y consejeros —de ahí que el asesor que los protege sea invaluable—. **Tercera, el capital:** los inversionistas institucionales (afores, fondos, LPs) **exigen** hoy buen gobierno y **ESG**; sin ellos, la empresa **pierde acceso al capital**.

Para ti, este libro **cierra el círculo:** tras dominar las operaciones (comprar, financiar, colaborar, invertir), aprendes el marco que las **legitima y protege**. El abogado que estructura operaciones complejas y domina el gobierno, el **compliance** y el **ESG** no es solo un técnico de transacciones: es un **asesor integral** de la empresa como institución —exactamente el perfil del abogado corporativo de élite que persigues—.

4. Historia y origen

El **gobierno corporativo** como disciplina nace del **problema de agencia** que ya estudiaste (Nivel III): en la gran empresa moderna, los **dueños** (accionistas dispersos) no son los que **manejan** la empresa (los administradores), lo que crea el riesgo de que estos sirvan a su propio interés y no al de la sociedad. **Berle y Means** (*The Modern Corporation and Private Property*, 1932) describieron esta separación entre propiedad y control; **Jensen y Meckling** (1976) la formalizaron como la

"teoría de la agencia". El gobierno corporativo es el conjunto de mecanismos (consejo, deberes fiduciarios, controles) que alinea a los administradores con el interés de la sociedad. Los grandes **escándalos** (Enron, WorldCom a principios de los 2000) detonaron reformas históricas (la **Sarbanes-Oxley Act** de 2002 en EE.UU.) que reforzaron el gobierno, la auditoría y la responsabilidad.

El **compliance** moderno tiene un origen ligado a la **antico-rupción**: la **FCPA** (*Foreign Corrupt Practices Act*) de EE.UU., de 1977 (tras los escándalos de pagos corporativos a funcionarios extranjeros, destapados con el caso Watergate), creó la obligación de no sobornar y de llevar controles contables —y, con ella, la necesidad de **programas de cumplimiento**—. La **OCDE** (Convención Anticohecho, 1997), la **UK Bribery Act** (2010) y, en México, la **Ley General de Responsabilidades Administrativas** (parte del Sistema Nacional Anticorrupción, 2016) ampliaron el marco. La prevención del **lavado de dinero** (con orígenes en los años 1980-90, reforzada tras el 11-S) añadió la otra gran rama del compliance. Hoy el compliance es una **función corporativa consolidada**.

El **ESG** es el más **reciente** y el de evolución más rápida. Sus raíces están en la **inversión socialmente responsable** y en la creciente conciencia sobre el **cambio climático** y la **responsabilidad social** de las empresas. El término "ESG" se popularizó a partir de un informe de Naciones Unidas de 2004 ("*Who Cares Wins*") y de los **Principios de Inversión Responsable (PRI)** de la ONU (2006). En la última década, el ESG pasó de ser un tema "de nicho" a un **factor central** de la inversión y el financiamiento globales, con un cuerpo creciente (y aún en formación) de estándares y regulación.

5. Evolución histórica

Las tres dimensiones han evolucionado en paralelo, convergiendo hacia un sistema integrado:

1) Del gobierno "de papel" al gobierno sustantivo. El gobierno corporativo empezó siendo, en muchas empresas, **formalismo** (un consejo de membrete, independientes solo en el

nombre). Los escándalos (Enron) forzaron un giro hacia el **gobierno sustantivo**: independientes **reales**, comités con **dientes** (auditoría, prácticas societarias), responsabilidad efectiva de los consejeros, y una cultura de **rendición de cuentas**. El gobierno dejó de ser cumplimiento formal para volverse **creación y protección de valor**.

2) Del compliance reactivo al preventivo y a la cultura. El compliance nació **reactivo** (cumplir para evitar sanciones tras un problema). Maduró hacia lo **preventivo** (programas que **anticipan** el riesgo) y, hoy, hacia la **cultura de integridad** (*tone at the top, ethics & compliance*): no basta tener políticas; hay que **vivir** una cultura ética. Las autoridades (DOJ) premian los **programas efectivos** (no de papel) al evaluar sanciones —el incentivo cambió de "tener un manual" a "tener una cultura que funcione"—.

3) Del ESG voluntario al ESG material y regulado. El ESG empezó como **voluntario y reputacional** (reportes de "responsabilidad social"). Evolucionó hacia el **ESG material y financiero** (los riesgos climáticos y sociales como **riesgos del negocio** que afectan el valor) y, crecientemente, hacia el **ESG regulado** (obligaciones de **revelación** climática y de sostenibilidad en la UE —CSRD, SFDR— y en otras jurisdicciones). En paralelo, surgió la reacción crítica al **greenwashing** (aparentar sostenibilidad sin serlo) y un debate sobre el alcance y la consistencia del ESG. Es un campo **en plena formación**, lo que exige al abogado mantenerse **actualizado**.

6. Contexto económico

Las tres dimensiones tienen una sólida lógica **económica**:

- **El gobierno corporativo reduce los costos de agencia y crea valor.** Un buen gobierno (independientes, comités, transparencia, deberes fiduciarios efectivos) **alinea** a los administradores con los accionistas, **reduce** el riesgo de expropiación (que el control extraiga valor a costa de las minorías —*tunneling*—) y **mejora** la calidad de las decisiones. La evidencia: las empresas **bien gobernadas valen más** (cotizan con "prima de gobierno"), atraen mejor inversión y re-

sisten mejor las crisis. El gobierno corporativo no es un costo: es **creación de valor**.

- **El compliance evita pérdidas catastróficas.** El costo de un programa de compliance es **pequeño** frente al costo de un escándalo: multas enormes (los grandes casos de corrupción han costado **miles de millones**), responsabilidad penal de directivos, pérdida de contratos (inhabilitación para contratar con el gobierno), y **daño reputacional** que destruye valor. El compliance es un **seguro** contra pérdidas catastróficas —y, bien hecho, un facilitador del negocio (permite operar en mercados y con contrapartes que lo exigen)—.
- **El ESG y el acceso al capital y al largo plazo.** El ESG responde a dos lógicas económicas: **(i) la gestión de riesgo de largo plazo** (los riesgos climáticos, sociales y de gobernanza son **riesgos del negocio** —físicos, regulatorios, reputacionales— que afectan el valor; ignorarlos es imprudente); y **(ii) el acceso al capital** (los grandes inversionistas institucionales —fondos, afores, LPs— y los financiadores **canalizan** capital hacia empresas con buen ESG, y lo **retiran** de las que no, de modo que el ESG afecta el **costo y la disponibilidad** del capital). Hay debate sobre cuánto del ESG es creación de valor genuina vs. moda, pero su **impacto en el capital** es real e indiscutible.

7. Contexto político y regulatorio

Las tres dimensiones tienen un marco regulatorio denso y en expansión:

- **Gobierno corporativo:** en México, la **Ley del Mercado de Valores (LMV)** regula el gobierno de las **emisoras** (S.A.B.): consejeros independientes, comités de **auditoría** y de **prácticas societarias**, deberes de los administradores, operaciones con partes relacionadas. La **LGSM** regula el gobierno de las sociedades en general. El **Código de Principios de Gobierno Corporativo** (del CCE) y los **Principios de la OCDE** son los estándares de mejores prácticas.
- **Anticorrupción:** la **FCPA** (EE.UU.) y la **UK Bribery Act** tienen **alcance extraterritorial** (aplican a empresas con nexo

con esos países); en México, el **Sistema Nacional Anticorrupción** y la **Ley General de Responsabilidades Administrativas** sancionan el cohecho y prevén la **responsabilidad de las personas morales** (con atenuantes para quien tenga un programa de **integridad** —compliance—).

- **Prevención de lavado (PLD/AML):** la **Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)** y la normativa financiera imponen obligaciones de **identificación** (KYC), reporte y controles.
- **ESG y revelación de sostenibilidad:** un marco **emergente y heterogéneo**: en la UE, obligaciones de revelación robustas (**CSRD** —reporte de sostenibilidad—, **SFDR** —para productos financieros—, **taxonomía verde**); estándares internacionales (**ISSB**, **GRI**); y, en México y otras jurisdicciones, requerimientos crecientes (de la bolsa, de los reguladores) aún en formación. El ESG es el área más **dinámica y menos consolidada** regulatoriamente.
- **Protección de datos, competencia, laboral, ambiental:** todo el marco sectorial que el compliance debe vigilar.

8. Contexto social

Estas tres dimensiones son, quizá, las de **mayor carga social** del derecho corporativo, porque tocan directamente la pregunta: **¿para qué y para quién existe la empresa?** El debate entre el ***shareholder primacy*** (la empresa existe para maximizar el valor de los **accionistas** —Friedman—) y el ***stakeholder capitalism*** (la empresa debe servir a **todos sus grupos de interés**: accionistas, pero también trabajadores, clientes, comunidades, medio ambiente) es el trasfondo social del gobierno corporativo y del ESG. El abogado moderno opera en esa tensión, que no es solo filosófica: define cómo se toman las decisiones y a quién deben responder los administradores.

El **compliance** tiene una dimensión social profunda: la corrupción **corroe** las instituciones, distorsiona los mercados, encarece los servicios y daña a los más pobres; el lavado financia el crimen. El abogado de compliance contribuye, en su

escala, a la **integridad** del sistema económico y a combatir males sociales graves. No es solo "evitar multas": es participar en la construcción de una economía **más limpia**.

El **ESG** es la dimensión donde la empresa se conecta más explícitamente con los **grandes desafíos sociales**: el cambio climático (E), los derechos humanos, las condiciones laborales y la diversidad (S), y la integridad del gobierno (G). Refleja la creciente expectativa social de que las empresas —actores de enorme poder— asuman **responsabilidad** por su impacto. El abogado serio entiende que el ESG no es solo *marketing*: es una **transformación** (aún imperfecta y debatida) de cómo la sociedad espera que operen las empresas. Y debe distinguir el ESG **genuino** del *greenwashing* (aparentar sin hacer), que es un fraude reputacional y, crecientemente, legal.

9. Contexto empresarial

Desde la óptica de la empresa, las tres dimensiones cumplen funciones estratégicas:

- **El gobierno corporativo: la "constitución" operativa de la empresa.** Define cómo se decide, quién responde y cómo se controlan los conflictos. Una empresa bien gobernada toma **mejores decisiones**, protege a sus accionistas (especialmente las minorías), **atrae capital** y se **vende mejor** (un buen gobierno es un activo en una venta o un IPO). Para una **empresa familiar**, el gobierno (un consejo profesional, reglas claras, un protocolo familiar) es lo que le permite **sobrevivir a la sucesión** y profesionalizarse —relevante para tu perfil—. Para una empresa **participada por un fondo**, el gobierno es lo que el fondo **instala** para crear valor.
- **El compliance: licencia para operar y escudo.** Un buen programa de compliance es, a la vez, una **licencia para operar** (permite hacer negocios en mercados y con contrapartes que lo exigen —muchas grandes empresas no contratan con quien no tiene compliance—) y un **escudo** (protege a la empresa y a sus directivos de responsabilidad, y atenúa sanciones si algo falla). Es también un **diferenciador reputacional**.

- **El ESG: acceso al capital y resiliencia.** El ESG se ha vuelto una condición de **acceso al capital** (los inversionistas y financiadores lo exigen), un factor de **reputación** (clientes y talento prefieren empresas responsables), y una herramienta de **gestión de riesgo de largo plazo** (anticipar riesgos climáticos, sociales y regulatorios). Una empresa con buen ESG es más **resiliente** y **financiable**.

Para el abogado, entender estas funciones es clave: el gobierno, el compliance y el ESG **no son trámites**, sino **creadores de valor y protectores** de la empresa. El abogado que ayuda a una empresa a gobernarse bien, cumplir la ley y operar de forma sostenible la hace **más valiosa, más financiable y más duradera** —y se vuelve un asesor indispensable—. Esta es la culminación de tu formación: del técnico de operaciones al **asesor de la empresa como institución**.

10. Definiciones doctrinales

La doctrina define los conceptos centrales así:

- **Gobierno corporativo (*corporate governance*):** el **sistema de poder, control y responsabilidad** por el cual se dirige y controla una empresa; el conjunto de relaciones entre la administración, el consejo, los accionistas y demás grupos de interés. La doctrina lo define como el mecanismo que resuelve el **problema de agencia** (alinear a quienes manejan la empresa con el interés de quienes la poseen) y protege a los inversionistas.
- **Deber fiduciario:** la obligación de los administradores de actuar en el **interés de la sociedad** (no el propio), que se desdobra en el deber de **diligencia/cuidado** (actuar de manera **informada**, prudente y de buena fe) y el deber de **lealtad** (sin conflictos de interés, sin aprovechar oportunidades de la sociedad).
- **Business Judgment Rule (regla del juicio de negocio):** principio que **protege** a los administradores de responsabilidad por decisiones de negocio que salieron mal, **siempre que** hayan decidido de manera **informada, de buena fe y**

sin conflicto de interés. No protege la deslealtad ni la decisión no informada.

- **Consejero independiente:** miembro del consejo **sin vínculos** (económicos, familiares, laborales) con la administración o el control que comprometan su juicio; su función es aportar **objetividad** y proteger a las minorías.
- **Compliance (cumplimiento normativo):** la función y el conjunto de **sistemas** (políticas, procedimientos, controles, cultura) que una organización implementa para **prevenir, detectar y corregir** incumplimientos de la ley y de sus normas internas, especialmente en áreas de alto riesgo (corrupción, lavado, competencia, datos).
- **Programa de compliance / integridad:** el conjunto estructurado de elementos (evaluación de riesgos, políticas, capacitación, canal de denuncias, investigaciones, monitoreo) que materializa la función de compliance. La ley mexicana lo llama "**política de integridad**".
- **Corrupción / cohecho:** ofrecer, prometer o dar (o solicitar/recibir) un beneficio indebido para influir en una actuación, especialmente de un **servidor público** (cohecho) —el núcleo de lo que la FCPA y las leyes anticorrupción combaten—.
- **ESG (*Environmental, Social, Governance*):** marco de criterios **no financieros** (ambientales, sociales y de gobernanza) usado para evaluar la **sostenibilidad** y el impacto de una empresa, y crecientemente integrado en las decisiones de **inversión y financiamiento**.
- **Materialidad ESG / doble materialidad:** qué temas ESG son **relevantes**. La **materialidad financiera** (cómo el ESG afecta el **valor** de la empresa) y la **doble materialidad** (además, cómo la empresa **impacta** al medio ambiente y la sociedad) —concepto clave del *reporting* europeo—.
- **Greenwashing:** práctica de **aparentar** un compromiso ambiental/sostenible **mayor** que el real; un fraude reputacional y, crecientemente, una infracción legal.

11. Definiciones legales y marco normativo

El marco normativo de las tres dimensiones, en México y con referentes internacionales:

- **Gobierno corporativo:**
- **LGS**: gobierno de las sociedades en general (asamblea, consejo, vigilancia, deberes de los administradores).
- **Ley del Mercado de Valores (LMV)**: régimen reforzado para las **emisoras (S.A.B.): consejeros independientes**, comités de **auditoría** y de **prácticas societarias**, deberes de **diligencia** y **lealtad** de los consejeros, régimen de **operaciones con partes relacionadas** y de información. También la **S.A.P.I.** (gobierno flexible para empresas con inversionistas).
- **Código de Principios de Gobierno Corporativo (CCE)** y **Principios de la OCDE**: mejores prácticas (soft law).
- **Compliance / anticorrupción / lavado:**
- **Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA)** y el **Sistema Nacional Anticorrupción**: sancionan el cohecho y la corrupción; prevén la **responsabilidad de las personas morales** y reconocen la "**política de integridad**" (programa de compliance) como **atenuante**.
- **Código Penal Federal**: delitos de cohecho, y la **responsabilidad penal de las personas jurídicas** (con el compliance como factor atenuante).
- **FCPA (EE.UU.)** y **UK Bribery Act**: anticorrupción con **alcance extraterritorial** (aplican a empresas con nexo con esos países).
- **LFPIORPI (ley antilavado)** y normativa financiera: prevención de lavado, identificación (**KYC**), reportes.
- **ESG:**
- **Marco emergente**: en la **UE**, la **CSRD** (reporte de sostenibilidad), la **SFDR** (productos financieros) y la **taxonomía** verde; estándares internacionales (**ISSB/IFRS S1-S2**, **GRI**, **TCFD** —riesgos climáticos—); en México, requerimientos crecientes de la **bolsa (BMV/BIVA)** y de reguladores, y guías

de finanzas sostenibles. Es el marco **menos consolidado y más cambiante**.

Nota de método: el ESG y el compliance son áreas **en rápida evolución**; verifica el marco vigente (LMV, LGRA, LFPIORPI, normativa ESG aplicable) antes de aplicar, pues cambia con frecuencia (Manifiesto XI.5).

12. Definición sencilla

Imagina la empresa como un **país pequeño**, y verás las tres dimensiones con claridad:

- **El gobierno corporativo es la "constitución y los poderes" del país.** Define **quién manda** (la asamblea de accionistas = los ciudadanos; el consejo = el congreso/gobierno; la dirección = los funcionarios que ejecutan), **cómo se toman las decisiones**, y **cómo se controlan los abusos** (los consejeros independientes y los comités = los contrapesos). Un país bien gobernado, con pesos y contrapesos, funciona mejor y no cae en manos de un tirano (el accionista de control que abusa).
- **El compliance son las "reglas y la policía interna" del país.** Son los sistemas para asegurar que el país (la empresa) y sus funcionarios **no cometan delitos** —que nadie soborne, robe o lave dinero—: las leyes internas (políticas), la capacitación, la **línea de denuncia anónima** (como un "buzón ciudadano"), y las investigaciones cuando algo huele mal. Sin esta "policía interna", el país se corrompe y colapsa (Enron).
- **El ESG es la "responsabilidad del país con el planeta y su gente."** Mide si el país (la empresa) cuida el **medio ambiente** (E: no contamina, reduce emisiones), trata bien a su **gente y comunidades** (S: trabajadores, derechos humanos, diversidad), y se **gobierna con integridad** (G: buen gobierno corporativo). Hoy, los "inversionistas extranjeros" (los fondos) **solo le prestan o invierten** a los países (empresas) que se portan bien en estos tres frentes.

La idea sencilla: una empresa, como un país, necesita **buen gobierno** (decidir bien y con contrapesos), **cumplir la ley** (no

corromperse) y **ser responsable** con su entorno (sostenibilidad). Las tres cosas juntas la hacen **legítima, confiable y duradera** —y le dan acceso al dinero de los inversionistas serios—.

13. Conceptos fundamentales

Fija este vocabulario; integra y eleva lo que viste en Gobierno Corporativo (Nivel III):

Gobierno corporativo avanzado:

- **Consejo de administración:** el órgano que dirige y supervisa; su composición (ejecutivos, patrimoniales, **independientes**) define el equilibrio de poder.
- **Comités:** **auditoría** (vigila finanzas y controles), **prácticas societarias** (operaciones con partes relacionadas, compensación), **riesgos**, nominaciones. Dan profundidad y objetividad.
- **Deberes fiduciarios:** **diligencia** (decidir informado —*business judgment rule*—) y **lealtad** (sin conflictos, sin tomar oportunidades societarias).
- **Operaciones con partes relacionadas (OPR):** transacciones con personas vinculadas al control; deben revelarse, aprobarse por independientes y ser a **precio de mercado** (riesgo de *tunneling*).
- **Estándares de Delaware (referentes globales):** **Business Judgment Rule**; ***Smith v. Van Gorkom*** (decidir informado); ***Revlon*** (deber de maximizar el precio cuando la venta es inevitable); ***Unocal*** (defensas anti-OPA proporcionales); ***Ca-remark*** (deber de supervisión/vigilancia —base del compliance—).

Compliance:

- **Tone at the top:** el compromiso **genuino** de la alta dirección con la integridad (sin él, el compliance es papel).
- **Evaluación de riesgos (*risk assessment*):** identificar los riesgos de incumplimiento propios del negocio.
- **Políticas y procedimientos, capacitación:** las reglas y su difusión.

- **Canal de denuncias (*whistleblowing* / línea ética):** mecanismo (anónimo, sin represalias) para reportar conductas indebidas.
- **Investigaciones internas:** cómo se investiga una denuncia o sospecha.
- **Debida diligencia de terceros:** revisar a socios, distribuidores, proveedores (el riesgo de corrupción suele venir por **intermediarios**).
- **Monitoreo y mejora continua:** el programa debe **funcionar y evolucionar**, no ser estático.
- **FCPA / UK Bribery Act / LGRA:** los marcos anticorrupción.
- **PLD/AML, KYC:** prevención de lavado e identificación del cliente.

ESG:

- **Los tres pilares:** **E** (ambiental: emisiones, energía, agua, residuos, clima); **S** (social: trabajadores, derechos humanos, comunidades, diversidad, clientes); **G** (gobernanza: el gobierno corporativo, ética, transparencia —el "G" es el gobierno corporativo—).
- **Materialidad / doble materialidad:** qué temas ESG importan (financiera + de impacto).
- **Reporting y estándares:** ISSB/IFRS S1-S2, GRI, TCFD, CSRD/SFDR (UE).
- **Finanzas sostenibles: bonos verdes, créditos vinculados a sostenibilidad** (*sustainability-linked loans* —cuya tasa depende de metas ESG, Libro 5—).
- **Greenwashing:** aparentar sostenibilidad sin serlo (riesgo legal y reputacional).
- **Stakeholder vs. shareholder:** el debate sobre a quién sirve la empresa.

Con este vocabulario, entramos al **desarrollo absoluto**.

14. Desarrollo absoluto

Esta es la sección central. La desarrollamos en cinco bloques: **(A) el gobierno corporativo avanzado** (el consejo sofisticado

y sus comités); **(B)** los **deberes fiduciarios en operaciones** (diligencia y lealtad reforzados en M&A y conflictos —los estándares de Delaware—); **(C)** el **compliance** (el programa, anticorrupción, lavado); **(D)** el **ESG** (los tres pilares, materialidad, finanzas sostenibles); y **(E)** la **integración** (gobierno + compliance + ESG como un solo sistema en cada operación). Estúdialos en orden: del órgano que decide, a sus deberes, a los sistemas que lo protegen, a los criterios que lo condicionan, y a su integración.

14.A · EL GOBIERNO CORPORATIVO AVANZADO (EL CONSEJO SOFISTICADO Y SUS COMITÉS)

En el Nivel III conociste los fundamentos del gobierno corporativo (el problema de agencia, el consejo, los deberes fiduciarios). Aquí lo llevamos al **nivel avanzado**: cómo opera un **consejo sofisticado** en una empresa pública o participada por fondos, y cómo se diseña para **decidir bien y proteger valor**.

El consejo de administración: composición y equilibrio de poder. El consejo es el **órgano que dirige y supervisa** la empresa (define la estrategia, vigila a la dirección, aprueba lo relevante). Su **composición** define el equilibrio de poder y su calidad:

- **Consejeros ejecutivos / patrimoniales / independientes.** Los **independientes** son la pieza clave del gobierno avanzado: sin vínculos con el control ni la administración, aportan **objetividad** y protegen a las **minorías**. La LMV exige un **mínimo de independientes** en las emisoras (al menos el 25%). La **independencia real** (no de membrete) es lo que distingue al buen gobierno.
- **El tamaño y la diversidad del consejo:** ni tan pequeño que concentre, ni tan grande que diluya responsabilidad; con **diversidad** de perfiles (financiero, operativo, legal, sectorial) y, cada vez más, de género y origen (dimensión ESG).
- **La separación de roles:** la tendencia de buen gobierno separa al **presidente del consejo** del **director general (CEO)** —para que quien preside la supervisión no sea el mismo que dirige la operación—; o, si se combinan,

nombrar un **consejero independiente líder** (*lead director*) como contrapeso.

Los comités del consejo (donde está la profundidad del gobierno). El consejo no puede analizar todo a fondo en sesión plenaria; delega en **comités especializados** (integrados —o presididos— por **independientes**), que son el **corazón operativo** del gobierno avanzado:

- **Comité de auditoría:** vigila la **integridad financiera** (estados financieros, controles internos, auditor externo), la gestión de riesgos y —clave para el compliance— el funcionamiento del **canal de denuncias** y las investigaciones. Es el comité más importante; la LMV lo exige en las S.A.B. integrado **solo por independientes**.
- **Comité de prácticas societarias:** vigila las **operaciones con partes relacionadas (OPR)**, la **compensación** de los directivos, y las prácticas de gobierno. Protege contra el abuso del control.
- **Comité de riesgos:** identifica y vigila los riesgos materiales (financieros, operativos, de cumplimiento, ESG).
- **Comité de nominaciones / gobierno / sostenibilidad:** propone consejeros, evalúa el desempeño del consejo, y (cada vez más) supervisa la estrategia ESG.

Las dinámicas del buen gobierno (lo que lo hace funcionar de verdad).

- **Información de calidad y a tiempo:** el consejo solo decide bien si recibe **información completa, clara y oportuna** (no a última hora ni incompleta). El derecho a información es base del deber de diligencia.
- **Cultura de cuestionamiento (*challenge*):** un buen consejo **cuestiona** a la dirección (no es un sello de goma); los independientes hacen las preguntas incómodas.
- **Evaluación y rendición de cuentas:** el consejo se **autoevalúa**, mide su desempeño y el de la dirección, y responde por sus decisiones.

- **Gestión de conflictos:** los consejeros con conflicto en un asunto se **abstienen**; las decisiones sensibles (OPR, operaciones con el control) pasan por **independientes**.

El gobierno según el tipo de empresa (tu perfil).

- **Empresa pública (S.A.B. / LMV):** gobierno **robusto y regulado** (independientes, comités de auditoría y prácticas societarias obligatorios, revelación, protección de minorías —OPAs—).
- **Empresa familiar:** el reto es **profesionalizar** el gobierno (consejo con independientes, separar la familia de la gestión, un **protocolo familiar** y reglas de sucesión) para que sobreviva a las generaciones —conecta con tu interés y con el Libro 6—.
- **Empresa participada por un fondo (PE/VC):** el fondo **instala** gobierno profesional (asientos en el consejo, vetos, métricas, incentivos a la dirección —Libro 7—). Los fondos son hoy de los mayores **impulsores del buen gobierno**.

Por qué importa. Un consejo bien diseñado y que funciona **decide mejor, protege a las minorías, detecta los riesgos a tiempo (incluido el de compliance) y crea valor**. El abogado que asesora al consejo —diseñando su estructura, sus comités y sus procesos, y guiándolo en sus deberes— ocupa el rol de **mayor confianza** del derecho corporativo. Es la práctica que corona tu perfil de gobierno corporativo.

14.B · LOS DEBERES FIDUCIARIOS EN OPERACIONES (DILIGENCIA, LEALTAD Y LOS ESTÁNDARES DE DELAWARE)

Aquí el gobierno corporativo se conecta directamente con **cada operación** que estudiaste: cuando una empresa vende, compra, se endeuda o hace una operación con su control, los **administradores** deben cumplir sus **deberes fiduciarios** —y el abogado que los asesora debe asegurar que el **proceso** los proteja—. Los estándares de **Delaware** (la jurisdicción de referencia mundial) modelan cómo se aplican, y todo abogado de M&A debe dominarlos.

Los dos deberes fundamentales (repaso y profundización).

- **Deber de diligencia / cuidado:** decidir de manera **informada**, prudente y de buena fe. No exige acertar (las decisiones de negocio pueden salir mal), sino **decidir bien el proceso:** con información completa, asesores, tiempo y deliberación.
- **Deber de lealtad:** anteponer el **interés de la sociedad** al propio; no tener conflictos no revelados, no aprovechar **oportunidades de la sociedad**, no extraer valor (OPR a precio no de mercado, *tunneling*). La deslealtad es lo **más grave** y **no** está protegida por la *business judgment rule*.

La Business Judgment Rule (el escudo del consejo). Es el principio que **protege** a los administradores de responsabilidad por una decisión de negocio que salió mal, **siempre que** hayan decidido de forma **informada, de buena fe y sin conflicto**. Su efecto práctico es enorme: si el consejo siguió un **buen proceso**, los tribunales **no sustituyen** su juicio de negocio (aunque el resultado haya sido malo). Por eso el abogado se obsesiona con el **proceso:** información, asesores, *fairness opinion*, deliberación documentada en actas. **El proceso impecable es la mejor defensa.**

Los estándares de Delaware (referentes globales que debes conocer).

- **Smith v. Van Gorkom (1985) — el deber de informarse.** El consejo aprobó la venta de la empresa **sin** información ni análisis adecuados (en una sola reunión apresurada). Delaware lo encontró **responsable** por violar el deber de **diligencia** (no se informó). *Lección capital:* decidir **sin informarse** rompe la business judgment rule y genera responsabilidad. El abogado debe asegurar información, asesores y *fairness opinion*.
- **Revlon (1986) — el deber de maximizar el precio.** Cuando la **venta o el cambio de control de la empresa es inevitable**, el deber del consejo cambia: ya no es preservar la empresa, sino **obtener el mejor precio** para los accionistas (el consejo se vuelve "subastador"). *Lección:* en una venta

de control, el consejo debe demostrar que buscó **maximizar el valor** (proceso competitivo, *market check*). Aplica directamente al M&A (Libros 1-4).

- **Unocal (1985) — las defensas anti-OPA proporcionales.** Ante una **oferta hostil**, el consejo puede **defenderse**, pero sus defensas deben ser **proporcionales** a la amenaza y en interés de los **accionistas** (no para **atrincherarse** y conservar su puesto). *Lección:* las defensas anti-toma de control tienen límites; no pueden servir al interés personal de los administradores.
- **Caremark (1996) — el deber de supervisión (la base del compliance).** Los consejeros tienen el deber de **vigilar** que la empresa tenga **sistemas de cumplimiento** adecuados; la **ausencia total** de supervisión (no instalar controles, ignorar señales de alarma) genera responsabilidad. *Lección capital:* **Caremark es el puente entre el gobierno corporativo y el compliance** —el consejo debe asegurar que exista un programa de compliance efectivo, o responde—.

Las situaciones de conflicto (donde los deberes se ponen a prueba). Los deberes fiduciarios se tensionan al máximo cuando hay **conflicto de interés**:

- **Operaciones con partes relacionadas (OPR):** transacciones con el control o personas vinculadas. Deben **revelarse**, aprobarse por **independientes** (un **comité especial**), y ser a **precio de mercado**. Sin esto, se presume deslealtad.
- **Management Buyout (MBO):** cuando la **propia dirección** compra la empresa (conflicto evidente: están a ambos lados de la mesa). Exige un **comité especial independiente** que negocie de verdad, *fairness opinion*, y a veces aprobación de la **mayoría de la minoría**.
- **Operaciones con el accionista de control:** sujetas al escrutinio más estricto (*entire fairness*: precio justo + proceso justo), salvo que se usen las protecciones (comité independiente + voto de la minoría) que pueden restaurar la business judgment rule.

La aplicación práctica para el abogado. En cada operación del Nivel IV, el abogado que asesora al consejo debe asegurar que se cumplan estos deberes mediante el **proceso**: (1) información completa y asesores (diligencia —Van Gorkom—); (2) *fairness opinion* de un banco en operaciones relevantes; (3) manejo de conflictos (revelar, abstenerse, **comité especial** de independientes —en MBO o con el control—); (4) en una venta, demostrar que se **maximizó el valor** (*Revlon*); (5) documentar **todo** en actas. Este "**proceso fiduciario impecable**" es lo que protege al consejo (y a la operación) de impugnaciones y responsabilidad. Dominar esto es lo que convierte al abogado de M&A en **asesor del consejo** —el rol de mayor responsabilidad—.

14.C · EL COMPLIANCE (EL PROGRAMA, ANTICORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAVADO)

El **compliance** es la función que asegura que la empresa y sus directivos **operen dentro de la ley**. Nació ligado a la **anticorrupción** (FCPA, 1977) y, con *Caremark*, se volvió un **deber del consejo**. Domina su lógica: es lo que **protege** a la empresa y a quienes la dirigen de pérdidas catastróficas (multas, responsabilidad penal, inhabilitación, daño reputacional).

Los elementos de un programa de compliance efectivo. Las autoridades (el DOJ de EE.UU., y en México la LGRA con su "política de integridad") evalúan si un programa es **real y funciona**, no si existe en papel. Sus elementos esenciales:

1. **Tone at the top (compromiso de la alta dirección):** el **elemento más importante**. Sin un compromiso **genuino** del consejo y la dirección con la integridad, ningún programa funciona (es papel). La cultura se construye desde arriba.
2. **Evaluación de riesgos (*risk assessment*):** identificar los **riesgos propios** del negocio (¿opera en países o sectores de riesgo?, ¿hace negocios con el gobierno?, ¿usa intermediarios?). El programa debe ser **proporcional al riesgo**.
3. **Políticas y procedimientos:** las reglas claras (código de ética, política anticorrupción, de regalos, de conflictos de interés, de terceros).

4. **Capacitación y comunicación:** que la gente **conozca y entienda** las reglas (capacitación periódica, adaptada a los roles de riesgo).
5. **Canal de denuncias (*whistleblowing* / línea ética):** un mecanismo **anónimo y sin represalias** para reportar conductas indebidas. Es una de las herramientas más efectivas (la mayoría de los fraudes se detectan por denuncias). El comité de auditoría lo supervisa.
6. **Investigaciones internas:** cómo se **investiga** una denuncia o sospecha (con independencia, confidencialidad, debido proceso) y cómo se **corrige** (sanciones, remediación).
7. **Debida diligencia de terceros (*third-party due diligence*):** **crucial en anticorrupción**, porque el riesgo suele venir por **intermediarios** (agentes, distribuidores, consultores que pagan sobornos "por cuenta" de la empresa). Hay que **investigar y vigilar** a los terceros.
8. **Monitoreo, auditoría y mejora continua:** el programa debe **medirse, auditarse y evolucionar** (no ser estático). Las autoridades premian los programas que **mejoran** tras detectar fallas.

El compliance anticorrupción (el núcleo). Las leyes anticorrupción son el corazón del compliance moderno:

- **FCPA (EE.UU.) y UK Bribery Act:** prohíben **sobornar a funcionarios** (la FCPA, a funcionarios **extranjeros**; la UK Bribery Act, también el soborno **privado**), con **alcance extraterritorial** (un nexo mínimo con EE.UU./RU basta para aplicarlas). Sanciones **enormes** (miles de millones en los grandes casos). La FCPA también exige **controles contables** (que los libros reflejen la realidad —no "cajas negras" para sobornos—).
- **México — Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y Sistema Nacional Anticorrupción:** sancionan el cohecho y prevén la **responsabilidad de las personas morales**; clave: tener una "**política de integridad**" (programa de compliance) es un **atenuante** expreso de la sanción. El **Código Penal** también prevé responsabili-

dad penal de las personas jurídicas, con el compliance como factor.

- **La sucesión de responsabilidad en M&A (conexión con el Libro 2):** quien **compra** una empresa que incurrió en corrupción puede **heredar** la responsabilidad —por eso la **due diligence de compliance** (Libro 2) es esencial, y por eso "no investigué" agrava la posición—.

La prevención de lavado de dinero (PLD/AML). La otra gran rama: evitar que la empresa sea usada para **lavar** recursos de procedencia ilícita. Sus pilares: **KYC** (*Know Your Customer* —identificar y conocer al cliente—), monitoreo de operaciones, **reporte** de operaciones inusuales o relevantes a las autoridades, y controles. En México, la **LFPIORPI** (ley antilavado) impone obligaciones a actividades "vulnerables" y al sistema financiero.

Por qué el compliance es deber del consejo (Caremark). Recuerda *Caremark* (14.B): los consejeros tienen el **deber de supervisión** —asegurar que exista un programa de compliance efectivo y atender las señales de alarma—. Un consejo que **ignora** el compliance puede ser **responsable**. Por eso el compliance no es solo cosa de un "oficial de cumplimiento": es una **responsabilidad de gobierno** que llega hasta el consejo. El abogado que diseña el programa y asesora al consejo sobre su deber de supervisión protege a la empresa y a sus consejeros.

El compliance como facilitador (no solo escudo). Más allá de evitar sanciones, un buen compliance es una **licencia para operar**: muchas grandes empresas y fondos **no contratan ni invierten** con quien no tiene compliance; permite operar en mercados regulados y con socios exigentes; y es un **diferenciador reputacional**. El compliance bien entendido **habilita** el negocio.

14.D · EL ESG (LOS TRES PILARES, MATERIALIDAD Y FINANZAS SOSTENIBLES)

El **ESG** (*Environmental, Social, Governance*) es el marco de criterios de **sostenibilidad** que hoy **condiciona** la inversión, el financiamiento y la reputación de las empresas. Es la

dimensión más **reciente y dinámica** —en plena formación regulatoria—, y la frontera actual del derecho corporativo.

Los tres pilares.

- **E — Ambiental (*Environmental*):** el impacto de la empresa en el medio ambiente: **emisiones** de carbono (y el camino a la descarbonización —*net zero*—), uso de **energía** y **agua**, **residuos** y contaminación, **biodiversidad**, y la exposición de la empresa a los **riesgos climáticos** (físicos —inundaciones, sequías— y de transición —cambios regulatorios y de mercado hacia una economía baja en carbono—). Es el pilar más desarrollado y el motor del ESG.
- **S — Social:** la relación de la empresa con las **personas: trabajadores** (condiciones laborales, seguridad, diversidad e inclusión), **derechos humanos** (en la empresa y en su **cadena de suministro** —trabajo forzado, infantil—), **comunidades** donde opera, y **clientes** (seguridad de productos, privacidad). Es el pilar más difuso de medir, pero de creciente relevancia.
- **G — Gobernanza (*Governance*):** es el **gobierno corporativo** que estudiaste (14.A-B): consejo, independientes, deberes fiduciarios, ética, transparencia, control de la corrupción, derechos de los accionistas. El "**G**" conecta el ESG con todo lo anterior —y es, en muchos sentidos, el **fundamento**: sin buena gobernanza, los compromisos E y S no se cumplen—.

La materialidad ESG (qué temas importan). No todos los temas ESG son relevantes para toda empresa: una minera tiene riesgos ambientales enormes; una tecnológica, riesgos sociales (datos, talento). La **materialidad** identifica los temas ESG **relevantes** para cada empresa. Dos conceptos:

- **Materialidad financiera:** cómo los factores ESG afectan el **valor** de la empresa (un riesgo climático, una multa ambiental, un conflicto social que paraliza una operación). Es la lógica del "**riesgo del negocio**".
- **Doble materialidad (concepto europeo):** además de lo anterior, cómo la empresa **impacta** al medio ambiente y la sociedad (no solo cómo el ESG la afecta a ella, sino cómo ella

afecta al mundo). La **CSRD** europea adopta la doble materialidad.

El reporting y los estándares (el ESG se mide y se revela). El ESG dejó de ser un relato voluntario para volverse **medible y reportable**, con estándares en consolidación:

- **ISSB / IFRS S1-S2:** el estándar global emergente de revelación de sostenibilidad y clima (busca unificar el campo).
- **GRI (*Global Reporting Initiative*):** estándar de reporte de impacto (orientado a *stakeholders*).
- **TCFD:** marco de revelación de **riesgos climáticos** (muy influyente).
- **UE — CSRD (reporte de sostenibilidad), SFDR (productos financieros) y taxonomía verde:** la regulación **más avanzada y obligatoria** del mundo en ESG.
- **México:** requerimientos crecientes de la **bolsa (BMV/BIVA)** y guías de finanzas sostenibles; marco aún en formación.

Las finanzas sostenibles (la conexión con el financiamiento — Libro 5). El ESG se ha integrado al financiamiento:

- **Bonos verdes / sociales / sostenibles:** deuda cuyos recursos se destinan a proyectos ambientales/sociales, con verificación del uso.
- **Créditos vinculados a la sostenibilidad (*sustainability-linked loans*):** créditos cuya **tasa de interés** sube o baja según el cumplimiento de **metas ESG** del deudor (vistos en el Libro 5). Alinean el costo del capital con el desempeño sostenible.
- **El capital ESG:** los grandes inversionistas (fondos, afores, LPs —Libro 7—) **canalizan** capital hacia empresas con buen ESG y lo **retiran** de las que no; el ESG afecta el **acceso y el costo del capital**.

El riesgo del greenwashing. El **greenwashing** —aparentar un compromiso sostenible **mayor** que el real— es un riesgo creciente, **legal y reputacional**: las autoridades y los reguladores (especialmente en la UE y EE.UU.) sancionan las

declaraciones ESG **falsas o engañosas**, y los inversionistas castigan el engaño. *Lección para el abogado*: las afirmaciones ESG de una empresa (en sus reportes, bonos verdes, marketing) deben ser **veraces, sustentadas y verificables** —no un relato—.

El debate sobre el ESG (postura realista). El ESG es un campo **debatido**: hay críticas legítimas (falta de estándares consistentes, *greenwashing*, uso político del término, dudas sobre si todo el ESG crea valor financiero). El abogado serio adopta una postura **realista**: el ESG **genuino** —gestionar los riesgos ambientales y sociales **materiales** como riesgos del negocio, con transparencia y sustancia— es **creación de valor y gestión de riesgo de largo plazo**, y una **condición de acceso al capital**; el ESG **de relato** (*greenwashing*) es un riesgo. El valor está en la **sustancia**, no en la etiqueta.

Por qué importa para el abogado. El ESG ya **condiciona** las operaciones que estudiaste: la **due diligence** incluye ESG (Libro 2); el **financiamiento** se vincula a metas ESG (Libro 5); los **fondos** exigen ESG a sus empresas (Libro 7); las **emisoras** deben revelarlo (LMV). El abogado moderno debe entender el ESG para asesorar en todas ellas, asegurar el cumplimiento de la regulación emergente, y **proteger** a la empresa del riesgo de *greenwashing*. Es la frontera —y el futuro— de la práctica corporativa.

14.E · LA INTEGRACIÓN (GOBIERNO + COMPLIANCE + ESG COMO UN SOLO SISTEMA)

La lección final del libro —y del Nivel IV— es que el gobierno corporativo, el compliance y el ESG **no son tres temas separados**, sino **un solo sistema de legitimidad, control y sostenibilidad** que opera en **cada operación** que has estudiado. Verlos integrados es lo que distingue al asesor corporativo de élite.

Cómo se conectan los tres.

- **El gobierno corporativo es la base**: define **quién decide y responde**. Sin buen gobierno (un consejo que cumple sus deberes y supervisa), ni el compliance ni el ESG funcionan

—son el consejo y la dirección quienes los instalan y vigilan—.

- **El compliance es el control:** asegura que las decisiones del gobierno se tomen **dentro de la ley**. Y —vía *Caremark*— el compliance **es un deber del gobierno** (el consejo debe asegurar que exista). Gobierno y compliance están entrelazados.
- **El ESG es la sostenibilidad:** asegura que las decisiones consideren el **impacto** de largo plazo (ambiental, social) además de la ganancia. Y su "G" es el gobierno corporativo. Los tres comparten ADN.

Cómo se aplican en cada operación del Nivel IV (la integración práctica):

- **En un M&A (Libros 1-4):** el **gobierno** exige los deberes fiduciarios del consejo al vender/comprar (Revlon, Van Gorkom, *fairness opinion*, comité especial si hay conflicto); el **compliance** exige **due diligence anticorrupción** (no heredar responsabilidad —Libro 2—) y revisar la integridad de la target; el **ESG** se integra en la due diligence (riesgos ambientales/sociales) y en la valuación.
- **En un financiamiento (Libro 5):** el **gobierno** aprueba el endeudamiento con la diligencia debida; el **compliance** asegura el KYC y el cumplimiento; el **ESG** aparece en los **créditos vinculados a sostenibilidad** y los **bonos verdes**.
- **En una JV o alianza (Libro 6):** el **gobierno** de la JV (consejo, vetos); el **compliance** (que la JV no sea canal de corrupción o colusión, due diligence de los socios); el **ESG** (estándares compartidos).
- **En una inversión de PE/VC (Libro 7):** los **fondos** son hoy de los mayores **impulsores** de los tres: instalan **gobierno** profesional en sus empresas, exigen **compliance** (due diligence de integridad, programas), y demandan **ESG** (porque sus **LPs** lo exigen). Para un fondo, una empresa con buen gobierno, compliance y ESG **vale más y se vende mejor**.

El abogado como arquitecto del sistema. El abogado corporativo de élite no ve estos temas como "cumplimiento

regulatorio aislado", sino como un **sistema integrado** que **legitima, controla y hace sostenible** a la empresa —y que, bien diseñado, **crea valor** (mejor capital, mejor reputación, mejor precio de venta, menor riesgo) y **protege** (a la empresa y a sus directivos de responsabilidad)—. Su rol:

- **Diseñar** el gobierno (consejo, comités, deberes) y guiar al consejo en su cumplimiento.
- **Construir** el programa de compliance (y asesorar al consejo sobre su deber de supervisión —Caremark—).
- **Integrar** el ESG (asegurar el cumplimiento de la regulación emergente, evitar el greenwashing, aprovechar las finanzas sostenibles).
- **Aplicarlo todo en cada operación** (los deberes en el M&A, el compliance en la due diligence, el ESG en el financiamiento y la inversión).

El cierre del Nivel IV. Con esta integración cierras el corazón de tu formación: dominas las **operaciones** (comprar —M&A—, investigar —DD—, estructurar, documentar, financiar, colaborar, invertir como un fondo) y el **marco que las legitima y protege** (gobierno, compliance, ESG). Has pasado del **técnico de transacciones** al **asesor integral de la empresa como institución** —el rol de mayor responsabilidad, prestigio y valor del derecho corporativo, y exactamente el perfil de **especialista en estructuración de operaciones complejas, M&A, gobierno corporativo, financiamiento y contratos estratégicos** que te propusiste alcanzar—.

15. Explicación intuitiva

Tres imágenes para fijar las tres dimensiones.

La metáfora del país (gobierno corporativo). Ya la vimos: la empresa es un país pequeño. El **gobierno corporativo** es su **constitución y sus poderes** —la asamblea (ciudadanos), el consejo (congreso/ gobierno), la dirección (funcionarios), y los **contrapesos** (independientes, comités) que evitan que un tirano (el control abusivo) haga lo que quiera—. Los **deberes fiduciarios** son el "juramento del cargo": los gobernantes (administradores) deben servir al país (la sociedad), no a sí mismos.

Y la **business judgment rule** dice: "si gobernaste con buena información, de buena fe y sin robar, no te castigamos aunque la decisión saliera mal" —protege el buen proceso, no el buen resultado—.

La metáfora del sistema inmune (compliance). El **compliance** es el **sistema inmunológico** de la empresa: detecta y combate las "infecciones" (corrupción, lavado, ilícitos) **antes** de que enfermen al cuerpo. El *tone at the top* es la salud general (un cuerpo fuerte resiste); la evaluación de riesgos identifica dónde es vulnerable; las políticas y capacitación son las "defensas"; el **canal de denuncias** es el sistema de alarma que detecta la infección temprano; y las investigaciones son la respuesta inmune. Una empresa **sin** sistema inmune (sin compliance) puede verse sana por fuera, pero una infección (Enron, un gran caso de corrupción) la **mata**. Y —vía *Caremark*— los "médicos" (el consejo) responden si **no instalaron** el sistema inmune.

La metáfora del examen de admisión (ESG). El ESG es como el **examen de admisión** al club de los inversionistas serios. Antes, para que te prestaran o invirtieran, bastaba con ser rentable. Hoy, los grandes inversionistas (fondos, afores) también te **examinan** en tres materias: ¿cuidas el **planeta** (E)?, ¿tratas bien a tu **gente** (S)?, ¿te **gobiernas** con integridad (G)? Si repruebas, te **niegan o encarecen** el capital y te castigan reputacionalmente. Y ojo: copiar en el examen (**greenwashing** — fingir que eres sostenible—) se detecta y se sanciona. El ESG es el nuevo **boleto de entrada** al capital.

La intuición central: el poder corporativo, para crear valor de forma **duradera**, debe ser **legítimo** (buen gobierno: decidir bien y con contrapesos), **limpio** (compliance: dentro de la ley) y **responsable** (ESG: cuidando el impacto de largo plazo). Las tres dimensiones son **una sola idea**: una empresa bien gobernada, que cumple la ley y opera de forma sostenible **vale más, accede mejor al capital, resiste las crisis y perdura**. Es el marco que **legitima y protege** todo lo que aprendiste a hacer.

16. Ejemplos simples

Ejemplo 1 — La business judgment rule protege. Un consejo aprueba, **bien informado** (con análisis, asesores y deliberación), la expansión a un nuevo mercado. La expansión **fracasa** y la empresa pierde dinero. ¿Responden los consejeros? **No**: decidieron de forma informada, de buena fe y sin conflicto — la business judgment rule los protege—. El buen **proceso** los blindo, aunque el resultado fuera malo.

Ejemplo 2 — El conflicto que exige comité especial. El director general quiere **comprar** la empresa (un MBO): está a **ambos lados** de la mesa (conflicto evidente). Para proteger a los accionistas, el consejo forma un **comité de independientes** que negocia el precio de verdad, con su propia *fairness opinion*. Sin ese comité, la operación sería atacable por **deslealtad**.

Ejemplo 3 — El soborno por intermediario (compliance). Una empresa contrata a un "consultor" en un país de riesgo que, sin contrato claro y con pagos sospechosos, **soborna** a un funcionario para ganar un contrato. La empresa puede ser responsable bajo la **FCPA** —aunque el soborno lo pagó el intermediario—. La **due diligence de terceros** (revisar al consultor) lo habría prevenido.

Ejemplo 4 — El crédito vinculado a sostenibilidad (ESG). Una empresa obtiene un crédito cuya **tasa baja** si reduce sus emisiones de carbono en 20% en tres años, y **sube** si no lo logra. El ESG se vuelve **dinero**: el costo del capital depende del desempeño sostenible (conexión con el Libro 5).

17. Ejemplos complejos

Ejemplo complejo 1 — Van Gorkom en la vida real: la venta apresurada. El consejo de una empresa recibe una oferta de compra atractiva y, presionado por el tiempo, la **aprueba en una sola reunión**, sin *fairness opinion*, sin explorar otras ofertas (*market check*), sin análisis del banquero. La venta se cierra, pero un grupo de accionistas **demandan**: el consejo violó el deber de **diligencia** (no se informó —Van Gorkom—) y, en

una venta de control, no demostró que **maximizó el valor** (Revlon). *Lección:* incluso una venta a buen precio puede generar responsabilidad si el **proceso** fue deficiente. El abogado debe imponer el proceso: información, *fairness opinion*, *market check*, deliberación documentada.

Ejemplo complejo 2 — La adquisición con problema de compliance heredado. Una empresa compra (share deal) a otra que, según revela tardíamente la due diligence, **sobornó** sistemáticamente a funcionarios en varios países. La compradora —sujeta a la FCPA— puede **heredar** la responsabilidad penal y regulatoria (sucesión de responsabilidad), además de pasivos enormes. *Solución integrada:* due diligence anticorrupción **profunda** (Libro 2); si se procede, **remediación** documentada, autodenuncia ante las autoridades (que mitiga), indemnización especial y escrow del vendedor (Libro 4), y —si el problema es sistémico e irremediable— considerar el *walk away*. *Lección:* gobierno (deber de supervisión), compliance (due diligence) y M&A (estructura/contrato) se **integran** en un solo problema.

Ejemplo complejo 3 — El greenwashing que estalla. Una empresa emite un **bono verde** y promociona sus "metas net zero", pero la realidad es que sus emisiones **siguen subiendo** y el uso de los recursos del bono no es realmente "verde". Un regulador (o inversionistas) detecta la discrepancia: **greenwashing**. Consecuencias: sanciones, demandas de inversionistas (declaraciones falsas), y **daño reputacional** grave. *Lección:* las afirmaciones ESG (en bonos verdes, reportes, marketing) deben ser **veraces, sustentadas y verificables**; el abogado debe vigilar que no haya brecha entre el relato y la realidad —el greenwashing es un riesgo legal real—.

18. Casos reales (operaciones estilizadas y referentes)

Nota de método (Manifiesto XI.5): casos estilizados con fines didácticos; verifica los detalles antes de citarlos profesionalmente.

Enron (2001): el colapso por mal gobierno y fraude. El gigante energético colapsó por **fraude contable** masivo (ocultar deuda en vehículos fuera de balance) facilitado por un **go-**

bierno corporativo fallido (consejo que no supervisó, conflictos de interés, auditor cómplice). Su caída arrastró a la auditora Arthur Andersen y detonó la **Sarbanes-Oxley Act** (2002), que revolucionó el gobierno corporativo y la auditoría. *Lección:* el **mal gobierno mata empresas**; la supervisión del consejo (Caremark) y la integridad financiera no son opcionales.

Los grandes casos FCPA (Siemens, Odebrecht). Casos emblemáticos de corrupción transnacional resultaron en sanciones **multimillonarias** (miles de millones de dólares) y reformas profundas de compliance. Odebrecht, en particular, sacudió a toda América Latina (incluido México) con su esquema sistemático de sobornos. *Lección:* la corrupción tiene un **costo catastrófico** (financiero, penal, reputacional, geopolítico); el compliance anticorrupción es indispensable, y la due diligence de integridad en M&A, crítica.

La ola ESG y su contracorriente. En la última década, el ESG se volvió central en la inversión global (grandes gestores condicionando capital al ESG), seguido de una **reacción crítica** (debate sobre su consistencia, acusaciones de greenwashing, e incluso un retroceso político en algunos mercados). *Lección:* el ESG es real e impactante en el acceso al capital, pero es un campo **en disputa y formación**; el abogado debe distinguir la **sustancia** del relato y mantenerse actualizado.

19. Casos empresariales

La empresa familiar que se profesionaliza para sobrevivir. Una empresa familiar de tercera generación, con conflictos entre ramas y sin reglas claras, está al borde de la fractura. Instala un **gobierno profesional**: un consejo con **independientes**, un **protocolo familiar** (reglas de entrada de familiares, sucesión, resolución de conflictos), comités, y separación entre la **propiedad** (familia) y la **gestión** (directivos profesionales). Resultado: la empresa **sobrevive a la transición**, se profesionaliza y se vuelve más valiosa y financiable. *Lección:* el gobierno corporativo es la herramienta que permite a la empresa familiar **perdurar** —relevante para tu perfil—.

La empresa que convierte el compliance en ventaja competitiva. Una empresa mexicana que quiere proveer a grandes multinacionales (que exigen compliance a sus proveedores) implementa un **programa robusto** (anticorrupción, ética, due diligence de terceros). Resultado: **accede** a contratos que antes le estaban vedados, y el compliance se vuelve una **licencia para operar** y un **diferenciador**. *Lección:* el compliance bien hecho no es solo escudo: **habilita el negocio**.

20. Casos corporativos (la conexión integral)

Integremos las tres dimensiones con todo el Nivel IV. *Fondo Horizonte* (PE) adquiere el control de *Industrias del Centro, S.A.* y la prepara para revenderla en 6 años.

- **Gobierno (este libro, 14.A-B):** el fondo instala un **consejo profesional** (con independientes y comités); en la **compra**, asesora a su propio gobierno y vigila los **deberes fiduciarios** del consejo vendedor (Revlon, *fairness opinion*); estructura un **management equity plan** alineando a la dirección.
- **Compliance (14.C):** la **due diligence** (Libro 2) incluye un componente **anticorrupción** profundo (no heredar responsabilidad); tras la compra, el fondo **instala un programa de compliance** robusto (que protege a la empresa, a los directivos y al propio fondo, y la hace más vendible).
- **ESG (14.D):** los LPs del fondo **exigen** ESG; el fondo evalúa los riesgos ambientales/sociales en la due diligence, implementa mejoras ESG (que aumentan el valor y el atractivo para el comprador futuro), y financia con un **crédito vinculado a sostenibilidad** (Libro 5).
- **Toda la operación (Libros 1-7):** due diligence (L2), estructura/LBO (L3, L5), SPA y SHA (L4), todo orientado a la **salida** (L7) —y la empresa, con **buen gobierno, compliance y ESG**, se vende **mejor** (pasa la due diligence del comprador con buena nota)—.

Moraleja: el gobierno, el compliance y el ESG **no son un apéndice** de la operación: son lo que la hace **legítima, segura y valiosa**. Una empresa bien gobernada, limpia y sostenible **vale más y se vende mejor** —y el abogado que integra estas

tres dimensiones en cada operación es el **asesor integral** que las empresas y los fondos más valoran—.

21. Casos internacionales

Sarbanes-Oxley y la convergencia global del gobierno. Tras Enron, la **Sarbanes-Oxley** (EE.UU., 2002) reforzó el gobierno corporativo (independencia del comité de auditoría, responsabilidad de los directivos por los estados financieros, controles internos) e **influyó globalmente** (muchos países, incluido México vía la LMV, adoptaron principios similares). *Lección:* el gobierno corporativo tiene **estándares convergentes** internacionalmente (OCDE, Sarbanes-Oxley, códigos de mejores prácticas).

El alcance extraterritorial de la FCPA y la UK Bribery Act. Estas leyes anticorrupción aplican a empresas con **nexo** con EE.UU./RU **aunque** el soborno ocurra en otro país. Una empresa mexicana que cotice en EE.UU., use el sistema financiero estadounidense o tenga relación con una empresa estadounidense puede quedar **sujeta**. *Lección:* el compliance anticorrupción es **global**; el abogado mexicano de operaciones complejas debe conocer la FCPA tanto como la ley local.

La regulación ESG europea como estándar global emergente. La **CSRD** y la **SFDR** de la UE son la regulación de sostenibilidad más avanzada del mundo, y —por el "**efecto Bruselas**"— influyen globalmente (empresas de otros países que operan o se financian en Europa deben cumplirlas). *Lección:* aunque México aún esté formando su marco ESG, las empresas mexicanas con operaciones o capital internacional ya enfrentan exigencias ESG **europeas**. El abogado debe conocer este marco emergente.

22. Derecho comparado

Las tres dimensiones tienen marcos comparados ricos. Tabla:

JURISDICCIÓN / SISTEMA	GOBIERNO, COMPLIANCE Y ESG
México (Civil Law)	Gobierno: LMV (S.A.B.: independientes, comités de auditoría y prácticas societarias), LGSM, Código del CCE. Compliance: LGRA/Sistema Nacional Anticorrupción (política de integridad como atenuante), LFPIORPI (antilavado). ESG: marco emergente (BMV/BIVA, finanzas sostenibles).
EE.UU. (Common Law)	Gobierno: Sarbanes-Oxley , Dodd-Frank, reglas de la SEC/ NYSE-Nasdaq; <i>case law</i> de Delaware (deberes fiduciarios). Compliance: FCPA (anticorrupción), guías del DOJ sobre programas efectivos. ESG: debatido y politizado; revelación climática de la SEC en disputa.
Delaware	El referente mundial de deberes fiduciarios : Van Gorkom, Revlon, Unocal, Caremark (deber de supervisión = base del compliance), <i>entire fairness</i> . Modela el gobierno global.
Reino Unido (Common Law)	Gobierno: UK Corporate Governance Code ("comply or explain"). Compliance: UK Bribery Act (anticorrupción amplia, extraterritorial). ESG: revelación climática obligatoria (TCFD).
Unión Europea	Gobierno: directivas de derechos de accionistas. Compliance: marcos anticorrupción y antilavado. ESG: el marco más avanzado del mundo — CSRD (reporte de sostenibilidad), SFDR (productos financieros), taxonomía verde , directiva de debida diligencia en sostenibilidad (CSDDD) —.
OCDE / soft law	Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE (estándar global), Convención Anticohecho , Líneas Directrices para Empresas Multinacionales (conducta responsable).
Estándares ESG globales	ISSB/IFRS S1-S2 (revelación de sostenibilidad/clima), GRI , TCFD , PRI (inversión responsable).
Civil Law vs. Common Law (síntesis)	El common law (Delaware) desarrolló el <i>case law</i> de deberes fiduciarios que el mundo cita; el civil law (México) los codifica (LMV, LGSM) y adopta los estándares OCDE. En compliance, la FCPA/UK Bribery Act marcan el estándar global; en ESG, la UE lidera. La práctica converge internacionalmente.

Lección comparada: el gobierno corporativo "habla Delaware" (sus *case law* —Caremark, Revlon— son referencia universal); el compliance "habla FCPA" (estándar global anticorrupción); y el ESG "habla europeo" (CSRD/SFDR como marco más avanzado). El abogado mexicano de élite debe **conocer**

los tres referentes porque condicionan a las empresas mexicanas con operaciones o capital internacional.

DOS ARQUITECTURAS DEL CONSEJO, Y QUÉ LE FALTA A MÉXICO

Frente al problema de agencia del §6, el mundo desarrolló **dos respuestas estructurales distintas**, y conocerlas evita creer que el modelo que uno conoce es el único posible.

El consejo unitario (Estados Unidos, Reino Unido, México): un solo órgano que administra y vigila, con **consejeros independientes** y comités —de auditoría, de prácticas societarias— como contrapeso interno. La vigilancia se logra por composición.

El consejo dual con cogestión (Alemania): dos órganos separados. Una dirección que gestiona y un **consejo de vigilancia** que supervisa, en el cual —y esto es lo distintivo— **se sientan representantes de los trabajadores**. La vigilancia se logra por separación estructural y por pluralidad de intereses representados. Es, de hecho, una respuesta institucional al debate *shareholder/stakeholder* del §29: Alemania no lo resolvió con declaraciones de propósito, lo resolvió con asientos.

El estándar global que hoy damos por natural no cayó del cielo: lo fijaron el **Cadbury Report** británico (1992) —que introdujo la separación de funciones, los independientes y el comité de auditoría— y los **Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE**, de donde bebe el Código de Principios y Mejores Prácticas mexicano ☞.

Y aquí la observación que importa para tu práctica, dicha sin complacencia. México **adoptó el andamiaje**: la LMV exige independientes y comités, el Código de Principios existe, las emisoras reportan. Lo que no tiene es el **acervo jurisprudencial** que en Delaware llena de contenido concreto los deberes fiduciarios. Un consejero mexicano tiene el deber de diligencia; lo que no tiene es un cuerpo de sentencias que le diga **cuánta diligencia basta** en un caso parecido al suyo.

Consecuencia práctica: el trabajo de tu opinión legal y de tus actas **suple** esa ausencia. Donde en Delaware el consejero se orienta por *Van Gorkom* y *Caremark*, aquí se orienta por lo que su abogado le explicó y por lo que quedó documentado. Es más responsabilidad para ti, no menos.

23. Derecho mexicano

El marco mexicano de las tres dimensiones:

- **Gobierno corporativo:**
- **LMV:** régimen de las **S.A.B.** (consejeros independientes —mínimo 25%—, comités de **auditoría** y de **prácticas societarias** integrados por independientes, deberes de **diligencia** y **lealtad**, OPR, protección de minorías —OPAs—); la **S.A.P.I.** (gobierno flexible).
- **LGSM:** gobierno de las sociedades en general (asamblea, consejo, vigilancia, deberes).
- **Código de Principios de Gobierno Corporativo (CCE):** mejores prácticas (soft law).
- **Compliance / anticorrupción / antilavado:**
- **Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y Sistema Nacional Anticorrupción:** sancionan el cohecho; **responsabilidad de las personas morales**; la "**política de integridad**" (compliance) como **atenuante**.
- **Código Penal Federal:** delitos de cohecho; **responsabilidad penal de las personas jurídicas** (con compliance como factor).
- **LFPIORPI (antilavado):** identificación (KYC), reportes, actividades vulnerables.
- **ESG:** marco **emergente** —requerimientos de la **BMV/BIVA**, guías de finanzas sostenibles, y la influencia de los estándares internacionales (ISSB) y europeos (vía empresas con operaciones/capital internacional)—.

Nota de método: el compliance y, sobre todo, el ESG son áreas **en rápida evolución** en México; verifica el marco vigente antes de aplicar (Manifiesto XI.5).

24. Jurisprudencia relevante

Nota de método: verifica vigencia y datos de identificación antes de citar.

Criterios relevantes:

- **Deberes de los administradores (diligencia y lealtad — LMV/LGSM):** alcance de la responsabilidad de los consejeros y directivos; el deber de actuar de manera **informada y leal**.
- **Operaciones con partes relacionadas:** requisitos de revelación, aprobación por independientes y precio de mercado.
- **Responsabilidad de las personas morales (LGRA / Código Penal):** alcance y el valor de la **política de integridad** como atenuante.
- **Antilavado (LFPIORPI):** criterios sobre las obligaciones de identificación y reporte.
- **Protección de minorías (LMV):** OPAs, derecho de los accionistas minoritarios.

En el ámbito internacional, el **case law de Delaware** (Caremark, Revlon, Unocal, Van Gorkom) es **estudio obligado** —modela los deberes fiduciarios globalmente—, junto con las **resoluciones FCPA** del DOJ/SEC (que orientan el diseño de los programas de compliance).

LA LÍNEA CAREMARK: EL DEBER DE VIGILANCIA, Y POR QUÉ REVIVIÓ

Merece desarrollo propio porque es la doctrina que convierte una falla de *compliance* en **responsabilidad personal del consejero**.

In re Caremark (Del. Ch. 1996) estableció que el consejo tiene un **deber de vigilancia** (*oversight*): no basta con no participar en el ilícito; hay que haber implantado un sistema razonable de información y control que permita **enterarse**. Durante años se consideró la reclamación más difícil de ganar del derecho societario —el estándar exigía prácticamente una falla total del sistema—.

Marchand v. Barnhill (Del. 2019) la reactivó. Su aportación fue precisar que cuando existe un **riesgo esencial y regulado** en el corazón del negocio —en ese caso, la seguridad alimentaria—, el consejo debe tener un mecanismo específico de vigilancia **sobre ese riesgo**, y no puede ampararse en que "había

reportes" genéricos. Es decir: la vigilancia se juzga **contra el riesgo propio de esa empresa**.

La lectura conjunta de los grandes escándalos, y es la tesis de esta sección. Enron, Odebrecht, Siemens y Wells Fargo se cuentan habitualmente como fracasos de negocio o como casos de corrupción. Son, antes que eso, **fallas de vigilancia**: en todos, la información existía en algún nivel de la organización y no llegó —o llegó y no se actuó—.

Eso es exactamente lo que el módulo 08 de la Columna IV llama *tu capacidad de enterarte a tiempo*, visto a escala de una corporación. Y por eso el *compliance* no es papelería: es el sistema nervioso que permite al consejo cumplir un deber que la ley le impone.

Cómo se traduce a tu escritorio: un programa se diseña para que resista el escrutinio de un fiscal y de un juez, y eso significa que debe poder **demostrar** tres cosas con documentos —que se identificaron los riesgos propios del negocio, que existía un canal por el que la información subía, y que cuando subió, alguien actuó y quedó registrado—. Un programa que no puede demostrar las tres es cosmético, aunque tenga un manual de doscientas páginas.

25. Criterios de la Suprema Corte / reguladores

- **SCJN / tribunales:** criterios sobre **deberes de los administradores**, OPR, y responsabilidad corporativa.
- **CNBV:** regulación y supervisión del **gobierno de las emisoras** (S.A.B.), revelación, OPAs.
- **Sistema Nacional Anticorrupción / Secretaría de la Función Pública / Tribunales administrativos:** aplicación de la **LGRA** (sanciones, responsabilidad de personas morales, política de integridad).
- **UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) y CNBV:** aplicación del régimen **antilavado**.
- **BMV / BIVA y reguladores financieros:** requerimientos y guías **ESG** y de finanzas sostenibles (emergentes).

26. Doctrina nacional

La doctrina mexicana sobre gobierno corporativo es **sólida** (a partir de la LMV y de la influencia de la OCDE y de Delaware),

desarrollada por la academia, los reguladores (CNBV) y organismos como el **Consejo Coordinador Empresarial** (autor del Código de Principios de Gobierno Corporativo). En **compliance**, la doctrina creció con el Sistema Nacional Anticorrupción (2016) y la práctica de los despachos (programas de integridad, anticorrupción, antilavado). En **ESG**, la doctrina es **incipiente** y se nutre sobre todo de los estándares internacionales y de la práctica de los despachos y las asociaciones (finanzas sostenibles). Es un campo donde el abogado mexicano está **construyendo** la doctrina conforme la regulación madura.

27. Doctrina internacional

- **Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE.** El estándar global; referencia obligada.
- **Kraakman, Hansmann et al., *The Anatomy of Corporate Law*.** Análisis funcional y comparado del gobierno corporativo.
- **Jurisprudencia y doctrina de Delaware (deberes fiduciarios).** Caremark, Revlon, Unocal, Van Gorkom; el marco que modela el gobierno global.
- **FCPA Resource Guide (DOJ/SEC) y *Evaluation of Corporate Compliance Programs* (DOJ).** Los documentos que definen qué es un **programa de compliance efectivo**; lectura imprescindible.
- **Principios de Inversión Responsable (PRI) de la ONU, ISSB, GRI, TCFD.** Los estándares del ESG y la inversión responsable.
- **Berle & Means; Jensen & Meckling.** Las raíces (problema de agencia) del gobierno corporativo.
- **Doctrina del *stakeholder capitalism* vs. *shareholder primacy* (Friedman; Business Roundtable 2019).** El debate sobre el propósito de la empresa.

28. Opiniones críticas (postura del Consejo Editorial)

Primero: el gobierno, el compliance y el ESG crean valor — no son costos ni trámites. Sostenemos con firmeza que estas

tres dimensiones, bien entendidas, **crean y protegen valor**: una empresa bien gobernada, limpia y sostenible vale más, accede mejor al capital, resiste las crisis y se vende mejor. Tratarlas como "carga regulatoria" es un error de quien no entiende su lógica económica.

Segundo: la sustancia por encima del papel (en las tres). El gobierno "de membrete" (independientes que no lo son), el compliance "de manual" (programa que nadie vive) y el ESG "de relato" (greenwashing) son **peor que nada**: dan falsa seguridad y, cuando estallan, agravan el daño. El valor está en la **sustancia**: independientes reales, cultura de integridad genuina, ESG con hechos.

Tercero: Caremark conecta gobierno y compliance —y eleva la responsabilidad del consejo. Insistimos en que el compliance es un **deber de gobierno**: el consejo debe asegurar que exista un programa efectivo y atender las señales de alarma. El abogado que asesora al consejo debe hacerle ver esta responsabilidad —y protegerlo cumpliéndola—.

Cuarto: postura realista sobre el ESG. Reconocemos el debate (falta de estándares consistentes, greenwashing, uso político). Nuestra postura: el ESG **material y genuino** —gestionar los riesgos ambientales y sociales relevantes como riesgos del negocio, con transparencia— es **gestión de riesgo y acceso al capital**; el ESG **de relato** es un riesgo. El abogado debe perseguir la sustancia y proteger del greenwashing, sin caer ni en el cinismo ("todo es moda") ni en la ingenuidad ("todo ESG es bueno").

Quinto: el abogado como asesor del consejo —el rol de mayor responsabilidad. Para tu perfil, dominar estas tres dimensiones te habilita para el rol más prestigioso del derecho corporativo: **asesor del consejo de administración**. Es la culminación de la formación: del técnico de operaciones al consejero de la institución.

Y la crítica que esta materia debe hacerse a sí misma: el gobierno corporativo puede ser teatro. La acusación de **box-ticking** —cumplir la casilla sin cumplir la función— es la más

sería que se le hace a esta disciplina, y está bien fundada. Tres formas concretas en que ocurre:

- **Independientes que no son independientes.** Formalmente cumplen el requisito; en la práctica fueron invitados por el fundador, le deben la posición y no lo contradicen. WeWork y Theranos son los casos de manual (patrón 2 de Reconocer el desastre antes).
- **Remuneración desacoplada del desempeño.** El trabajo de **Bebchuk y Fried** en *Pay Without Performance* documentó cómo los paquetes se diseñan de modo que pagan bien casi en cualquier escenario, y cómo el consejo capturado no lo corrige.
- **ESG como relato.** Las acusaciones de *greenwashing* y de politización de la agenda no son ruido: hay reportes de sostenibilidad que miden lo que es fácil de medir en lugar de lo que importa.

Postura del Consejo: la existencia del teatro no invalida la institución —invalida su versión cosmética—. Y la distinción es verificable con una sola prueba, que recomendamos aplicar a cualquier consejo que asesores: **¿cuándo fue la última vez que este órgano dijo no a la dirección, y consta?** Si la respuesta es nunca, no hay contrapeso, hay ceremonia. Un abogado que pregunta eso —y que redacta el acta de modo que la respuesta quede registrada— está haciendo más por el gobierno de esa empresa que todo el código de mejores prácticas.

29. Debate doctrinal

- **¿Shareholder primacy o stakeholder capitalism?** ¿La empresa existe para maximizar el valor de los **accionistas** (Friedman) o debe servir a **todos los grupos de interés** (trabajadores, comunidades, medio ambiente)? *Postura del Consejo:* el debate es real y no resuelto; nuestra posición es que, en el **largo plazo**, atender a los *stakeholders* (incluido el ESG) **es** crear valor sostenible para los accionistas —no son objetivos opuestos, salvo en el cortoplacismo—.
- **¿El ESG crea valor o es una moda costosa?** *Postura del Consejo:* el ESG **material** (riesgos relevantes del negocio)

crea valor y es gestión de riesgo; el ESG **inflado o de relato** es costo y riesgo (greenwashing). La clave es la **materialidad y la sustancia**.

- **¿Funcionan los programas de compliance o son "teatro de cumplimiento"?** *Postura del Consejo:* un programa **de papel** es teatro inútil (y agrava la sanción cuando estalla); un programa **efectivo** (tone at the top genuino, riesgos, canal de denuncias que funciona, mejora continua) **sí** previene y protege. La diferencia es la **cultura**, no el manual.
- **¿Hasta dónde llega el deber de supervisión del consejo (Caremark)?** ¿Responden los consejeros por **cualquier** fallo de compliance, o solo por la **ausencia total** de supervisión? *Postura del Consejo:* el estándar (Caremark) exige **buen fe** en instalar y vigilar sistemas, no perfección; pero la tendencia es a **endurecer** la responsabilidad del consejo por ignorar señales de alarma —lo que eleva la importancia del abogado asesor—.
- **¿Independencia real o de membrete?** *Postura del Consejo:* la independencia **formal** (cumplir el requisito) sin independencia **real** (criterio propio, disposición a cuestionar) es un fraude al gobierno; el valor está en independientes que **de verdad** protejan a las minorías y cuestionen a la dirección.

30. Errores comunes

- **Decidir sin informarse (Van Gorkom).** El consejo aprueba una operación relevante sin información, asesores ni *fairness opinion* → pierde la business judgment rule y responde. *Corrección:* imponer el proceso (información, asesores, deliberación documentada).
- **No manejar los conflictos.** Permitir que un conflictuado decida (MBO, operación con el control) sin comité especial de independientes → deslealtad. *Corrección:* revelar, abstenerse, comité especial, precio de mercado.
- **Gobierno "de membrete".** Independientes que no lo son, comités sin dientes → falsa protección. *Corrección:* independencia y comités **reales**.

- **Compliance de papel.** Tener un manual que nadie vive (sin tone at the top, sin canal de denuncias efectivo) → no previene y agrava la sanción. *Corrección:* programa **efectivo** con cultura genuina.
- **Ignorar la due diligence de terceros.** No revisar a intermediarios, socios y proveedores → heredar riesgo de corrupción. *Corrección:* third-party due diligence.
- **Olvidar Caremark (deber de supervisión).** Un consejo que no instala ni vigila el compliance → responsabilidad. *Corrección:* asegurar un programa efectivo y atender señales de alarma.
- **Greenwashing.** Afirmaciones ESG infladas o falsas (bonos verdes, reportes, marketing) → sanción y daño reputacional. *Corrección:* afirmaciones veraces, sustentadas y verificables.
- **Tratar gobierno/compliance/ESG como trámite aislado.** No integrarlos en las operaciones. *Corrección:* verlos como un **sistema** que legitima y protege cada deal.

31. Mitos frecuentes

- **"La business judgment rule protege cualquier decisión."** Falso. Solo protege la decisión **informada, de buena fe y sin conflicto**. No protege la deslealtad ni la decisión no informada.
- **"El gobierno corporativo es burocracia que frena al negocio."** Falso. El buen gobierno **mejora** las decisiones, atrae capital y crea valor; las empresas bien gobernadas valen más.
- **"El compliance es solo tener un manual y un oficial de cumplimiento."** Falso. Es **cultura** (tone at the top), riesgos, canal de denuncias que funciona, investigaciones y mejora continua. El papel sin cultura no protege.
- **"Si el soborno lo pagó un intermediario, la empresa no responde."** Falso. Bajo la FCPA y leyes locales, la empresa puede responder por los pagos de sus **terceros**. De ahí la due diligence de terceros.

- **"El ESG es solo marketing/relaciones públicas." Falso/matizado.** El ESG **material** es gestión de riesgo y acceso al capital; el ESG **de relato** (greenwashing) sí es marketing —y un riesgo legal—.
- **"El consejo no responde por fallas de compliance." Falso.** Vía **Caremark**, los consejeros responden si **no instalaron ni vigilaron** sistemas de cumplimiento.
- **"Un bono verde es verde solo por llamarse así." Falso.** Debe destinarse a proyectos realmente sostenibles, con verificación; lo contrario es greenwashing sancionable.

32. Preguntas difíciles

1. **¿Cómo protege la business judgment rule, y cuándo NO aplica?** Protege a los administradores de responsabilidad por decisiones que salieron mal, **si** decidieron **informados, de buena fe y sin conflicto** (premia el buen **proceso**). No aplica ante **deslealtad** (conflicto, *tunneling*) ni ante **falta de información** (Van Gorkom). Por eso el abogado se obsesiona con el proceso.
2. **¿Por qué Caremark conecta gobierno y compliance?** Porque establece que los consejeros tienen el **deber de supervisión**: deben asegurar que la empresa tenga **sistemas de compliance** efectivos y atender las señales de alarma. Así, el compliance deja de ser solo cosa del "oficial de cumplimiento" y se vuelve un **deber del consejo** —y el abogado que asesora al consejo debe garantizarlo—.
3. **En una venta de control, ¿qué exige Revlon?** Que el consejo busque **maximizar el precio** para los accionistas (se vuelve "subastador"): proceso competitivo, *market check*, demostrar que se obtuvo el mejor valor razonable. No basta vender a buen precio; hay que **demostrar** que se maximizó.
4. **¿Por qué la due diligence de terceros es central en anti-corrupción?** Porque el riesgo de corrupción suele venir por **intermediarios** (agentes, distribuidores, consultores que sobornan "por cuenta" de la empresa), y la empresa puede responder por sus pagos. Investigar y vigilar a los terceros es la principal defensa.

5. **¿Cómo distinguir ESG genuino de greenwashing?** El ESG **genuino** gestiona riesgos **materiales** con **hechos verificables** (metas reales, datos, verificación independiente); el **greenwashing** es **relato** sin sustancia (afirmaciones infladas, sin respaldo). La prueba: ¿las afirmaciones ESG son veraces, sustentadas y verificables, o solo marketing?

33. Casos de examen (con respuesta modelo)

Caso A. *El consejo de una empresa va a aprobar su venta. ¿Qué debe hacer el abogado para proteger a los consejeros y a la operación?* **Respuesta modelo:** Asegurar un **proceso fiduciario impecable**: (1) información completa y asesores (diligencia — Van Gorkom—); (2) **fairness opinion** de un banco; (3) en una venta de control, demostrar que se **maximizó el valor** (*market check*, proceso competitivo —Revlon—); (4) manejar conflictos (si la dirección participa en la compra —MBO—, **comité especial** de independientes); (5) **documentar todo** en actas. Así la **business judgment rule** protege al consejo aunque alguien impugne.

Caso B. *Tu cliente comprará una empresa que opera en sectores y países de alto riesgo de corrupción. ¿Qué exiges en materia de compliance?* **Respuesta modelo:** **Due diligence anticorrupción profunda** (Libro 2): revisar pagos, intermediarios, contratos con el gobierno, historial. Si hay hallazgos: evaluar exposición FCPA/local, exigir **remediación**, considerar autodenuncia (atenúa), **indemnización especial y escrow** del vendedor (Libro 4), y —si es sistémico e irremediable— *walk away*. Tras la compra: **instalar un programa de compliance** efectivo (tone at the top, riesgos, canal de denuncias, third-party due diligence, monitoreo). Fundar: la **sucesión de responsabilidad** y el deber de supervisión (Caremark).

Caso C. *Una empresa quiere emitir un bono verde y promocionar metas "net zero". ¿Qué cuidas como abogado?* **Respuesta modelo:** Cuidar el riesgo de **greenwashing**: verificar que los recursos del bono se destinen a proyectos **realmente** sostenibles (con marco de bono verde y **verificación independiente**); que las metas "net zero" estén **sustentadas** (línea base,

plan, datos verificables); y que las afirmaciones públicas sean **veraces y no engañosas** (no haya brecha entre el relato y la realidad). De lo contrario: riesgo de sanción regulatoria, demandas de inversionistas y daño reputacional.

34. Simulador (ejercicio tipo despacho)

Instrucciones: eres asociado. Asesoras al **consejo de administración** de una empresa pública (S.A.B.) que va a (a) aprobar una adquisición relevante con conflicto (el CEO tiene interés), y (b) revisar su programa de compliance tras una denuncia anónima de un posible soborno. Diseña tu asesoría antes de leer la guía.

1. ¿Cómo proteges al consejo en la **decisión con conflicto** (deberes fiduciarios)?
2. ¿Qué exiges para que la operación resista impugnaciones (proceso)?
3. ¿Qué haces ante la **denuncia** de soborno (compliance)?
4. ¿Qué responsabilidad del **consejo** está en juego (Caremark)?
5. ¿Cómo integras el **ESG** en la operación y en la empresa?

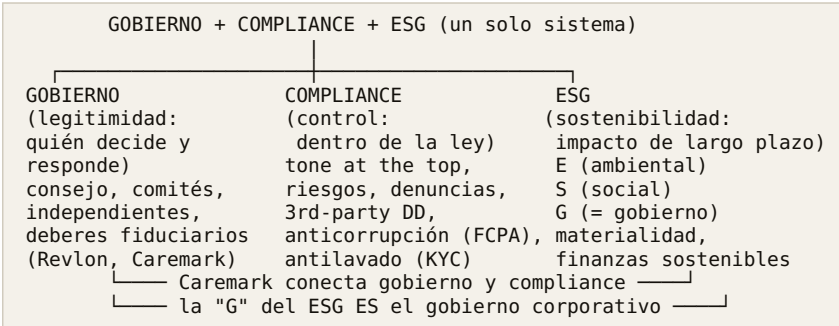
Guía de solución (resumen). (1) El CEO conflictuado **se abstiene**; se forma un **comité especial de independientes** que analiza y negocia, con su propia **fairness opinion**. (2) Información completa, asesores, deliberación **documentada** en actas; si aplica Revlon (venta de control), maximizar valor; revelar la operación con parte relacionada y aprobarla por el comité de **prácticas societarias**. (3) Activar una **investigación interna** (independiente, confidencial); preservar evidencia; evaluar exposición (FCPA/LGRA); remediar y, si procede, autodenunciar; reportar al **comité de auditoría**. (4) El **deber de supervisión** (Caremark): el consejo debe asegurar que el programa de compliance sea efectivo y atender la señal de alarma —ignorarla genera responsabilidad—. (5) Evaluar riesgos ESG de la target en la due diligence; integrar estándares; asegurar que cualquier comunicación ESG sea veraz (no greenwashing).

35. Flashcards

- **¿Gobierno corporativo?** Sistema de poder, control y responsabilidad en la empresa (resuelve el problema de agencia).

- **¿Deberes fiduciarios?** Diligencia (decidir informado) y lealtad (sin conflictos).
- **¿Business judgment rule?** Protege la decisión informada, de buena fe y sin conflicto (no la desleal ni la no informada).
- **¿Van Gorkom?** Decidir sin informarse viola la diligencia.
- **¿Revlon?** En venta de control, deber de maximizar el precio.
- **¿Unocal?** Defensas anti-OPA proporcionales (no para atrincherarse).
- **¿Caremark?** Deber de supervisión del consejo = base del compliance.
- **¿Elementos del programa de compliance?** Tone at the top, riesgos, políticas, capacitación, canal de denuncias, investigaciones, due diligence de terceros, monitoreo.
- **¿FCPA?** Ley anticorrupción de EE.UU. (extraterritorial); prohíbe sobornar funcionarios + controles contables.
- **¿"Política de integridad" (México)?** El programa de compliance; atenuante en la LGRA.
- **¿Los tres pilares ESG?** Ambiental, Social, Gobernanza (la "G" = gobierno corporativo).
- **¿Doble materialidad?** Cómo el ESG afecta el valor + cómo la empresa impacta al mundo.
- **¿Greenwashing?** Aparentar sostenibilidad sin serlo (riesgo legal y reputacional).
- **¿La idea integradora?** Gobierno (legitimidad) + compliance (control) + ESG (sostenibilidad) = valor + protección.

36. Mapas mentales



DEBERES FIDUCIARIOS EN OPERACIONES

DILIGENCIA → decidir INFORMADO (Van Gorkom; fairness opinion)
LEALTAD → sin conflictos (OPR, MBO → comité especial de independientes)
EN VENTA DE CONTROL → maximizar precio (Revlon)
ANTE OPA → defensas proporcionales (Unocal)
SUPERVISIÓN → asegurar compliance (Caremark)
⇒ PROCESO IMPECABLE = business judgment rule = protección

37. Cuadros comparativos

Las tres dimensiones

	GOBIERNO	COMPLIANCE	ESG
Pre-gunta	¿Quién decide y responde?	¿Se decide dentro de la ley?	¿Se decide de forma sostenible?
Núcleo	Consejo, deberes fiduciarios	Programa, anticorrupción, lavado	E, S, G; materialidad
Referente	Delaware (Caremark, Revlon)	FCPA / DOJ	UE (CSRD/SFDR), ISSB
Protege	Decisiones, minorías	Empresa y directivos	Acceso al capital, reputación

Los estándares de Delaware

CASO	PRINCIPIO
Van Gorkom	Deber de informarse (diligencia)
Revlon	Maximizar precio en venta de control
Unocal	Defensas anti-OPA proporcionales
Caremark	Deber de supervisión (compliance)

ESG genuino vs. greenwashing

	ESG GENUINO	GREENWASHING
Base	Hechos verificables	Relato sin sustancia
Metas	Reales, medidas	Infladas, vagas
Resultado	Valor + acceso al capital	Riesgo legal y reputacional

38. Diagramas

El proceso fiduciario impecable (en una operación):

DECISIÓN RELEVANTE DEL CONSEJO

- información completa + asesores (diligencia)
- fairness opinion (operaciones relevantes)
- manejo de conflictos (abstención + comité especial si hay conflicto)
- venta de control: market check / maximizar valor (Revlon)
- documentar todo en actas
- ⇒ BUSINESS JUDGMENT RULE protege al consejo

El programa de compliance efectivo:

TONE AT THE TOP (cultura genuina, lo primero)
 → evaluación de RIESGOS → políticas + capacitación
 → CANAL DE DENUNCIAS (anónimo, sin represalias)
 → investigaciones + remediación
 → due diligence de TERCEROS → monitoreo + mejora continua
 [el consejo SUPERVISA – Caremark]

39. Mnemotecnias

- **Deberes fiduciarios:** *"diligencia = decide informado; lealtad = sin robar"*.
- **Business judgment rule:** *"buen proceso te protege, aunque el resultado sea malo; la deslealtad no"*.
- **Los 4 de Delaware:** *"Van Gorkom (infórmate), Revlon (maximiza), Unocal (defiéndete proporcional), Caremark (supervisa)"*.
- **Caremark:** *"el consejo debe instalar el sistema inmune (compliance) o responde"*.
- **Compliance:** *"tono arriba, denuncia abajo, terceros vigilados, cultura siempre"*.
- **Anticorrupción:** *"el soborno del intermediario también te quema (FCPA)"*.
- **ESG:** *"E ambiente, S gente, G gobierno; con hechos, no con relato"*.
- **Greenwashing:** *"verde de mentira, multa de verdad"*.
- **Regla de oro:** *"gobierno (legítimo) + compliance (limpio) + ESG (sostenible) = vale más y perdura"*.

40. Resumen ejecutivo

Las operaciones corporativas ocurren **dentro** de empresas que son **instituciones de poder y responsabilidad**, y que deben operar de forma **legítima, controlada y sostenible** para crear valor duradero. Este libro estudia las tres dimensiones que regulan ese poder. El **gobierno corporativo avanzado** define **quién decide y responde**: un consejo sofisticado (con **independientes** reales y **comités** —auditoría, prácticas societarias, riesgos—) que cumple sus **deberes fiduciarios** —**diligencia** (decidir informado, protegido por la *business judgment*

rule) y **lealtad** (sin conflictos)— reforzados en cada operación por los estándares de **Delaware** (*Van Gorkom* —informarse—, *Revlon* —maximizar el precio en venta de control—, *Unocal* —defensas proporcionales—, *Caremark* —deber de supervisión—). El **compliance** asegura operar **dentro de la ley** mediante un programa **efectivo** (tone at the top, evaluación de riesgos, políticas, capacitación, **canal de denuncias**, investigaciones, **due diligence de terceros**, monitoreo), con el núcleo **anticorrupción** (FCPA, UK Bribery Act, LGRA) y **antilavado** (KYC); y —vía *Caremark*— es un **deber del consejo**. El ESG condiciona el **acceso al capital** y la reputación a través de sus tres pilares (E ambiental, S social, G = gobierno), la **materialidad**, el *reporting* (ISSB, CSRD/SFDR) y las **finanzas sostenibles** (bonos verdes, créditos vinculados a sostenibilidad), con el riesgo del **greenwashing**.

La idea rectora: el poder corporativo, para crear valor de forma sostenible, debe ser **legítimo** (buen gobierno), **limpio** (compliance) y **responsable** (ESG) —y las tres dimensiones forman **un solo sistema** que se aplica en cada operación del Nivel IV—. *Caremark* conecta gobierno y compliance (el consejo debe asegurar el cumplimiento); la "G" del ESG **es** el gobierno corporativo. Una empresa bien gobernada, que cumple la ley y opera de forma sostenible **vale más, accede mejor al capital, resiste las crisis y perdura**. Para tu perfil, este libro corona tu formación: dominas las **operaciones** (M&A, due diligence, estructura, documentación, financiamiento, contratos estratégicos, PE/VC) y el marco que las **legitima y protege**, habilitándote para el rol de mayor responsabilidad y prestigio: **asesor del consejo de administración** —el asesor integral de la empresa como institución—. Con este libro **cierra el Nivel IV**, el corazón del objetivo.

41. Checklist

Gobierno corporativo:

- [] ¿Consejo equilibrado con **independientes reales** y **comités** (auditoría, prácticas societarias, riesgos) con dientes?

- [] ¿Separación de roles (presidente/CEO o *lead director*)? ¿Información de calidad y a tiempo? ¿Cultura de cuestionamiento?
- [] **En operaciones:** ¿deberes fiduciarios protegidos por el **proceso** (información, *fairness opinion*, comité especial si hay conflicto, maximizar valor en venta —Revlon—, actas)?

Compliance:

- [] ¿**Tone at the top** genuino? ¿Evaluación de **riesgos** propia del negocio?
- [] ¿Políticas, capacitación, **canal de denuncias** (anónimo, sin represalias) e investigaciones?
- [] ¿**Due diligence de terceros** (intermediarios, socios, proveedores)?
- [] ¿Programa **anticorrupción** (FCPA/LGRA) y **antilavado** (KYC)? ¿Monitoreo y mejora continua?
- [] ¿El **consejo supervisa** el compliance (Caremark)?

ESG:

- [] ¿**Materialidad** ESG identificada (riesgos relevantes del negocio)?
- [] ¿Gestión real de los tres pilares (E, S, G) y *reporting* conforme a estándares aplicables?
- [] ¿Finanzas sostenibles aprovechadas (bonos verdes, créditos vinculados)? ¿**Sin greenwashing** (afirmaciones veraces, sustentadas, verificables)?

Integración:

- [] ¿Gobierno, compliance y ESG **integrados** en cada operación (M&A, financiamiento, JV, PE/VC)?

42. Bibliografía comentada

- **Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE.** El estándar global; referencia obligada.
- **Jurisprudencia de Delaware (Caremark, Revlon, Unocal, Smith v. Van Gorkom).** Los deberes fiduciarios que modelan el gobierno global; **estudio imprescindible** para M&A.

- **FCPA Resource Guide (DOJ/SEC) y *Evaluation of Corporate Compliance Programs* (DOJ).** Qué es un programa de compliance **efectivo**; lectura imprescindible.
- **Ley del Mercado de Valores (gobierno de la S.A.B.) y Código de Principios de Gobierno Corporativo (CCE).** El derecho positivo y las mejores prácticas mexicanas.
- **Ley General de Responsabilidades Administrativas (política de integridad) y LFPIORPI (antilavado).** El marco anticorrupción y antilavado mexicano.
- **ISSB/IFRS S1-S2, GRI, TCFD; CSRD/SFDR (UE); PRI (ONU).** Los estándares del ESG y la inversión responsable.
- **Kraakman, Hansmann et al., *The Anatomy of Corporate Law*.** Análisis funcional del gobierno corporativo.
- **El debate del propósito de la empresa (Friedman; Business Roundtable 2019).** Shareholder vs. stakeholder. Lee las **dos** puntas: Friedman (*The New York Times*, 1970) y **R. Edward Freeman**, cuya *teoría de los stakeholders* dio la formulación académica al otro lado. Y lee la objeción, que es la más interesante de las tres: **Lucian Bebchuk** ha argumentado que el *stakeholderism* puede funcionar como una cortina que **aisla a los administradores de la rendición de cuentas** —si respondes ante todos, en la práctica no respondes ante nadie—. No hay que estar de acuerdo con él; hay que poder contestarle.
- **Bebchuk & Fried, *Pay Without Performance* (2004).** El estudio de referencia sobre remuneración desacoplada del desempeño y sobre por qué el consejo, capturado, no la corrige. Es el sustento del debate del *say-on-pay* y lectura obligada antes de opinar sobre un plan de compensación.
- **John C. Coffee, *Gatekeepers* (2006).** Por qué fallan los guardianes del sistema —auditores, abogados, analistas, calificadoras— cuando sus incentivos los alinean con quien les paga. **Es el libro que un abogado corporativo debería leer con más incomodidad**, porque el guardián del que habla también eres tú. Conecta con el módulo 06 de la Columna VI.

- **Kaplan & Walker y la literatura de efectividad de programas de *compliance*.** La pregunta empírica que importa: qué distingue un programa que reduce la sanción esperada de uno que solo agrega costo.
- **Jurisprudencia de Delaware sobre el deber de vigilancia:** *In re Caremark* (Del. Ch. 1996) y *Marchand v. Barnhill* (Del. 2019).
- **Estándares internacionales:** *Resource Guide to the FCPA* (DOJ/SEC), Convención Anticohecho de la **OCDE**, recomendaciones del **GAFI** en materia de prevención de lavado, **Cadbury Report** (1992) y Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE.

43. Ruta hacia el siguiente nivel

Has **completado el Nivel IV · Corporate Law** —el corazón del objetivo—. Dominas el ciclo completo de las operaciones corporativas (comprar, investigar, estructurar, documentar, financiar, colaborar, invertir como un fondo) y el marco que las legitima y protege (gobierno, compliance, ESG). Eres, en formación, un **especialista en estructuración de operaciones corporativas complejas** —exactamente tu objetivo—.

- **Siguiente nivel:** *Nivel V · Maestría* —donde el abogado aprende a **pensar como un socio de un despacho internacional** más allá del derecho: **negociación de alto nivel, finanzas y contabilidad para abogados, valuación de empresas, y estrategia corporativa y teoría de juegos**. Es la capa que convierte al excelente técnico jurídico en un **asesor estratégico integral**.
- **Conexión inmediata:** todo lo que estructuraste en el Nivel IV se **negocia** (negociación), se **valúa** (finanzas, valuación) y responde a una **estrategia** (game theory, corporate strategy). El Nivel V te da las herramientas **no jurídicas** que distinguen al abogado de negocios de élite —las que te permiten dialogar de igual a igual con banqueros, fondos y CEOs—.

◆ ¿Por qué esto importa para un abogado corporativo?

Porque el gobierno corporativo, el compliance y el ESG son la **capa transversal** que legitima y protege **toda** la práctica corporativa, y —para tu perfil, que sitúa el gobierno corporativo entre tus áreas centrales— son una de las prácticas de **mayor responsabilidad y prestigio**: asesorar a un **consejo de administración** en sus decisiones críticas es el rol de **mayor confianza** del derecho de los negocios. Estas tres dimensiones definen **quién decide y responde** (gobierno), aseguran que se decida **dentro de la ley** (compliance) y de forma **sostenible** (ESG); sus fallos **destruyen empresas** (Enron, los grandes casos de corrupción) y generan **responsabilidad personal** de directivos y consejeros —de ahí que el asesor que los protege sea invaluable—. Y son una **condición de acceso al capital**: los inversionistas institucionales (afores, fondos, LPs) **exigen** buen gobierno y ESG. El abogado que domina estas tres dimensiones —además de las operaciones— no es un técnico de transacciones: es un **asesor integral de la empresa como institución**, el perfil del abogado corporativo de élite.

◆ Cómo piensa un socio de un despacho internacional

"Cuando asesoro a un consejo, mi obsesión es el proceso y los deberes. Para cada decisión crítica —vender, una operación con el control, una crisis— me aseguro de tres cosas. Primero, diligencia: que el consejo esté informado —información completa, asesores, fairness opinion—, porque así la business judgment rule lo protege aunque el resultado salga mal (la lección de Van Gorkom). Segundo, lealtad: cazo los conflictos; si la dirección está del otro lado (un MBO) o hay una operación con el control, formo un comité de independientes que negocie de verdad. Tercero, documento todo —actas, información, opiniones—, porque si algún día hay litigio, el proceso impecable es la mejor defensa. En compliance, vivo por Caremark: le hago ver al consejo que tiene el deber de asegurar que el programa funcione —no que exista en papel— y de atender cada señal de alarma; un canal de denuncias que la gente usa vale más que mil manuales. Y en ESG, mi regla es sustancia, no relato: aprovecho las finanzas sostenibles, pero vigilo como un halcón que no haya brecha entre lo que la empresa dice y lo que hace —el greenwashing es una bomba reputacional y legal—. Asesorar al consejo es el rol de mayor responsabilidad que existe: ahí no soy un técnico de contratos, soy el guardián de la legitimidad de la empresa."

◆ Errores que cuestan millones

1. **Decidir sin informarse (Van Gorkom).** El consejo aprueba una operación relevante sin información ni *fairness opinion* → pierde la business judgment rule y responde. *Prevención:* imponer el proceso (información, asesores, deliberación documentada).
2. **No manejar un conflicto de interés.** Permitir que un conflictuado decida (MBO, operación con el control) sin comité especial → deslealtad, nulidad, responsabilidad. *Prevención:* revelar, abstenerse, comité especial de independientes, precio de mercado.
3. **Compliance de papel e ignorar las señales de alarma (Caremark).** Un programa que nadie vive y un consejo que ignora una denuncia → responsabilidad y escándalo catastrófico (Enron). *Prevención:* programa efectivo con cultura genuina; el consejo supervisa y actúa ante las alarmas.

4. **Heredar corrupción por due diligence floja.** Comprar una empresa que sobornó y heredar la responsabilidad (FCPA). *Prevención:* due diligence anticorrupción profunda, third-party DD, remediación.
5. **Greenwashing.** Afirmaciones ESG infladas o falsas (bonos verdes, reportes) → sanción regulatoria, demandas y daño reputacional. *Prevención:* afirmaciones veraces, sustentadas y verificables; cerrar la brecha entre relato y realidad.

Cierre del Libro 8 y del Nivel IV. Has completado el **corazón de tu formación**: el **Corporate Law**. A lo largo de ocho libros aprendiste a **comprar** (Fundamentos de M&A), **investigar** (Due Diligence), **estructurar** (Fusiones, Escisiones, Adquisiciones), **documentar** (Term Sheet, SPA, APA, SHA), **financiar** (Derecho Bancario y Financiamiento Corporativo), **colaborar** (Contratos Estratégicos y Joint Ventures), **invertir como un fondo** (Private Equity y Venture Capital) y, ahora, a **gobernar, cumplir y sostener** (este libro). Dominas el **ciclo completo** de las operaciones corporativas y el marco que las **legitima y protege**. Has pasado del estudiante de derecho al **especialista en estructuración de operaciones corporativas complejas, M&A, gobierno corporativo, financiamiento y contratos estratégicos** —exactamente el perfil que te propusiste—. Pero el abogado de élite no solo sabe derecho: **piensa como un socio de negocios**. Por eso cruzamos al **Nivel V · Maestría**, donde aprenderás las herramientas que coronan al gran abogado corporativo: **negociación, finanzas, valuación y estrategia**. El destino —ser uno de los mejores— está cada vez más cerca.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE IV

[Nivel IV · Libro 9] Fiscal Corporativo y Planeación Fiscal de Operaciones

☞ **Apóstrofe de vigencia** — **léela cada vez**. El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ☞ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en *.../fuentes-legales/*). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ☞ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

Ninguna operación corporativa se decide solo por su lógica jurídica o de negocio: se decide, casi siempre, por **cuánto impuesto deja**. El mismo *deal* —comprar una empresa— puede costar millones de más o de menos según **cómo se estructure fiscalmente**. Este libro enseña a pensar la dimensión fiscal de las operaciones corporativas: por qué la estructura importa, cómo tributa una compraventa de acciones frente a una de activos, qué hace "neutral" a una fusión o escisión, y dónde está la línea —infranqueable— entre la **planeación legítima** y la **evasión**. Es la capa que convierte a un abogado corporativo competente en uno **indispensable**: el que se sienta en la mesa cuando se decide la estructura, no el que solo redacta lo ya decidido.

Etiquetas: corporate law · fiscal · planeación fiscal · M&A tax · reestructuras · neutralidad fiscal · elusión vs. evasión **Prerrequisitos:** Fundamentos de M&A, Estructuras: fusiones, escisiones, adquisiciones, Sociedades (LGSM), Economía para Juristas y, idealmente, Finanzas y Contabilidad para Abogados. **Estándar:** V3 (43 secciones + secciones transversales).

✓ **Registro de verificación (2026-07 · cotejo verbatim).** Los fundamentos fiscales que usa este libro fueron cotejados **pala-bra por palabra** contra los textos oficiales vigentes archivados en fuentes-legales/: **CFF** (última reforma DOF 09-04-2026) y **LISR** (última reforma DOF 01-04-2024). **Verificado** ✓: **ISR** de personas morales **30%** (art. 9 LISR ☞); **razón de negocios / norma antiabuso** (art. 5º-A CFF ☞); **operaciones inexistentes EFOS** (art. 69-B CFF ☞); **pérdidas fiscales = diez ejercicios si-guientes** (art. 57 LISR ☞); **facultades de comprobación** (art. 42 CFF ☞); **caducidad 5 años** (art. 67 CFF ☞); **prescripción 5 años** (art. 146 CFF ☞). Detalle en Derecho Fiscal y en el Protocolo. ⚠ Tasas, tarifas, montos (UMA) y estímulos cambian cada ejercicio: reverifícalos con la ley del año.

🕒 **Tiempo estimado de dominio:** 6–8 semanas (≈ 60–80 h de estudio activo). Lectura de reconocimiento: 10–12 h. *Estúdialo en bloques: la lógica del impuesto sobre la renta corporativo → la fiscalidad de la compraventa (acciones vs. activos) → la neutralidad en fusiones y escisiones → la planeación fiscal y sus límites → la dimensión internacional.*

⚠ **AVISO DE VERIFICACIÓN (crítico en esta materia).** El derecho fiscal es el que **más cambia y más se cita con números:** tasas, artículos de la LISR/CFF/LIVA y reglas misceláneas se re-forman **cada año**. Por eso este libro, siguiendo el Protocolo de Verificación, enseña la **lógica y la estructura** (que no caduca) y **marca con ⚠ todo número de artículo, tasa o regla específica como "verificar contra el texto vigente"**. Nunca apliques una cifra de este libro a un caso real sin confirmarla en la ley vigente y con un fiscalista. Aquí aprendes a *pensar* la fiscalidad de las operaciones, no a memorizar tasas que mañana serán otras.

Aviso de método. Tratado, no repaso. Entenderás la fiscalidad desde las dos lógicas que la mueven: la del **fisco** (¿dónde se generó la riqueza y cómo la gravó?) y la del **contribuyente** (¿cómo organizo legalmente mis operaciones para no pagar de más?). Cada figura se conecta con el M&A (Libros 1-8): el impuesto es, muchas veces, **la variable que decide la estructura del deal**.

NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL (VISTA RÁPIDA)

Litigio	★★★☆☆
Corporate	★★★★★
M&A	★★★★★
Mercado de Valores	★★★★☆
Venture Capital	★★★★☆
Private Equity	★★★★★
Gobierno Corporativo	★★★☆☆
Compliance	★★★★★
Derecho Bancario	★★★☆☆
Empresa Familiar	★★★★★

Para tu perfil, esta es de las áreas de mayor ventaja competitiva: muy pocos abogados corporativos dominan fiscal, y casi ninguna operación se estructura sin él. Dominar la dimensión fiscal del deal —y, en tu caso, el ángulo fiscal-corporativo— te vuelve el abogado al que se consulta antes de decidir, no después.

1. Introducción

Imagina dos formas de comprar la misma empresa por el mismo precio. En una, el vendedor paga un impuesto moderado y el comprador conserva ciertos beneficios fiscales del negocio adquirido. En la otra, el vendedor paga un impuesto mucho mayor y el comprador pierde esos beneficios. **Mismo precio, mismo negocio, resultados económicos radicalmente distintos** — y la única diferencia fue *cómo se estructuró fiscalmente la operación*. Esa es, en una imagen, la razón de ser de este libro.

El **derecho fiscal corporativo** estudia cómo tributan las empresas y, sobre todo, **cómo tributan sus operaciones**: la obtención de utilidades, su distribución, la compraventa de negocios, las fusiones, las escisiones, las reestructuras y los flujos transfronterizos. La **planeación fiscal** es el arte —legítimo— de organizar esas operaciones, dentro de la ley, para que el costo fiscal sea el menor posible. No es un tema "de contadores": es una variable jurídica de primer orden que el abogado corporativo de élite **debe** dominar, porque la estructura legal de un *deal* y su estructura fiscal son dos caras de la misma moneda.

La idea rectora del libro: **el impuesto sigue a la sustancia económica**. El sistema fiscal busca gravar la riqueza donde realmente se genera; la planeación legítima organiza la realidad económica de forma fiscalmente eficiente; y la evasión — el lado oscuro— finge una realidad que no existe para no pagar. Toda esta materia gira en torno a esa tensión entre **forma y sustancia**.

2. Objetivos del libro

Al terminar, el lector será capaz de:

- Entender la **lógica** del impuesto sobre la renta corporativo (cómo se grava la utilidad de una empresa y la distribución a sus dueños) sin depender de memorizar tasas.
- Analizar la **fiscalidad de una compraventa de empresa**: las consecuencias, muy distintas, de comprar **acciones** frente a comprar **activos**, y por qué comprador y vendedor suelen preferir estructuras opuestas.
- Comprender el régimen de **neutralidad fiscal** en fusiones y escisiones: qué requisitos hacen que una reestructura **no** detone impuesto, y por qué.
- Distinguir con claridad **planeación legítima (elusión) vs. evasión**, y operar siempre del lado correcto de esa línea.
- Reconocer la dimensión **internacional**: doble tributación, tratados, precios de transferencia y el porqué de las estructuras *cross-border*.
- Integrar lo fiscal en el diseño de una operación de M&A **desde el inicio**, no como un trámite final.

3. Importancia profesional

En la práctica corporativa de élite, la pregunta fiscal aparece **antes** que casi cualquier otra: "*¿cómo estructuramos esto?*" es, en el fondo, una pregunta fiscal tanto como jurídica. El abogado que solo redacta el contrato que otros diseñaron cobra como ejecutor; el que **diseña la estructura** —y entiende por qué una fusión inversa, una escisión previa o una compra de activos cambia el resultado fiscal— se sienta en la mesa de decisiones y cobra como arquitecto.

Además, lo fiscal es **transversal**: toca el M&A (estructura del deal), el financiamiento (deducibilidad de intereses), el gobierno corporativo (distribución de dividendos), la empresa familiar (sucesión patrimonial) y el venture capital/private equity (vehículos de inversión). Pocas áreas dan tanto apalancamiento profesional. Y son notoriamente escasos los abogados que dominan **a la vez** lo corporativo y lo fiscal: esa intersección es un nicho de altísimo valor.

4. Historia de la institución

El impuesto sobre la renta —gravar lo que una persona o empresa **gana**— es relativamente moderno. Durante siglos los Estados se financiaron sobre todo con impuestos al **consumo**, al comercio y a la propiedad. El impuesto sobre la renta como lo conocemos surge con fuerza a partir del siglo XIX y se generaliza en el XX, cuando los Estados modernos necesitaron financiar funciones crecientes y encontraron en la **renta** —la capacidad económica real de cada quien— la base más justa y productiva para tributar.

Nota de método (Principio Supremo): las fechas y atribuciones históricas precisas (qué país introdujo primero el ISR, en qué año) deben **verificarse** en fuentes históricas; aquí interesa la **lógica evolutiva** —del impuesto al consumo y al comercio hacia el impuesto a la renta— más que una cronología memorizada.

En México, el impuesto sobre la renta se consolidó a lo largo del siglo XX y ha sido objeto de **reformas constantes**; su ley vigente (Ley del Impuesto sobre la Renta) convive con el Código Fiscal de la Federación, la Ley del IVA y un cuerpo enorme de reglas administrativas. ⚠ *Las leyes concretas y sus fechas deben verificarse contra el texto vigente.*

5. Evolución histórica

La evolución del derecho fiscal corporativo sigue tres grandes movimientos:

1. **De gravar cosas a gravar riqueza.** Del impuesto sobre bienes y consumo hacia el impuesto sobre la **renta** (la utilidad), que mide mejor la capacidad económica.

2. **De lo nacional a lo internacional.** Con la globalización, las empresas operan en varios países; el derecho fiscal desarrolló **tratados para evitar la doble tributación**, reglas de **precios de transferencia** y, recientemente, esfuerzos globales contra la erosión de la base gravable (el movimiento conocido como **BEPS**, impulsado por la OCDE). [△](#) *Verificar el estado vigente de estas iniciativas.*
3. **De la forma a la sustancia.** La gran tendencia moderna: las autoridades y los tribunales cada vez miran menos la **forma jurídica** de una operación y más su **sustancia económica** y su **razón de negocios**, para combatir estructuras artificiales. Esta es la idea más importante de todo el libro y la que marca el futuro de la profesión.

6. Contexto económico

El impuesto es un **costo** y, como todo costo, influye en las decisiones. Las empresas no operan en un vacío fiscal: deciden cómo financiarse (deuda vs. capital), dónde establecerse, cómo repartir utilidades y cómo estructurar sus compras **mirando el efecto fiscal**. Un sistema fiscal bien diseñado busca **neutralidad** (no distorsionar decisiones económicas sanas) y **eficiencia** (recaudar sin ahogar la actividad). Cuando el impuesto castiga una operación económicamente razonable, surge la planeación; cuando la planeación se vuelve abuso, surge la reacción del fisco. Es un equilibrio dinámico, casi un juego repetido (Nivel V), entre contribuyente y autoridad.

EL DEBATE MATRIZ DEL DERECHO FISCAL, Y SUS DOS SENTENCIAS FUNDADORAS

Todo lo que sigue en este libro se apoya en una tensión de casi un siglo, y conviene conocer sus dos polos porque siguen vivos en cada discusión con la autoridad.

El polo de la forma: *IRC v. Duke of Westminster* (Reino Unido, 1936). Su idea, formulada con una claridad que todavía se cita: **cada quien puede ordenar sus negocios para que el impuesto sea el menor posible**. De ahí nace la doctrina de la **economía de opción**: si la ley ofrece dos caminos y uno paga menos, elegirlo no es abuso — es ejercer un derecho. Sin este

principio no existiría la planeación fiscal legítima, y tampoco la seguridad jurídica.

El polo de la sustancia: *Gregory v. Helvering* (Estados Unidos, 1935). El caso resolvió lo contrario en un supuesto concreto: una reorganización que cumplía **todos** los requisitos formales de la ley pero que **no tenía propósito de negocio** — existía solo para producir el efecto fiscal— no surtía efectos. Nació así la doctrina de la **sustancia económica sobre la forma**.

Los dos casos no se contradicen tanto como parece, y entender por qué es lo que te vuelve útil. *Westminster* protege la libertad de **elegir entre estructuras reales**. *Gregory* niega efectos a estructuras que **no son reales**. La pregunta que separa un caso del otro no es "*¿cumple la forma?*" sino "*¿habría hecho el contribuyente esto si el beneficio fiscal no existiera?*".

Hoy predomina la sustancia, y no por moda: se instrumentó en normas positivas. Las **GAAR** —cláusulas generales antia-buso— habilitan a la autoridad a recaracterizar lo artificioso, y en México esa función la cumple la **razón de negocios del artículo 50.-A del CFF** ☉ ✓ (*cotejado verbatim; ver también el Libro 3 de este nivel*). Estados Unidos codificó su *economic substance doctrine* en 2010.

Y la objeción formalista, que hay que tomar en serio. Si la autoridad puede recaracterizar lo que cumple la letra de la ley, ¿dónde queda la **previsibilidad**? La crítica advierte que una GAAR vaga convierte al fisco en legislador y traslada al contribuyente el riesgo de una interpretación futura. No es un argumento gremial: es un problema real de seguridad jurídica.

Postura del Consejo: la tendencia hacia la sustancia es **irreversible** y el abogado que la ignora asesora hacia un pasivo latente. Pero la respuesta al riesgo de arbitrariedad no es negar la GAAR: es **documentar la razón de negocios cuando existe**. Una estructura con propósito real, cuyo expediente acredita ese propósito desde el inicio, resiste. Una que se justifica a posteriori, no. Ese es, en esta materia, el trabajo concreto del abogado: **construir el expediente al mismo tiempo que la estructura**.

7. Contexto político

Los impuestos son el corazón del **pacto fiscal**: cuánto aporta cada quien al sostenimiento del Estado y a qué cambio. Por eso la materia fiscal es intensamente **política**: las tasas, los regímenes preferenciales, los estímulos y las reglas anti-abuso se debaten y reforman con cada gobierno y cada presupuesto. Para el abogado, esto significa una cosa práctica: **el derecho fiscal es inestable por naturaleza**, y mantenerse actualizado no es opcional. Lo que hoy es una estructura válida puede dejar de serlo con una reforma. De ahí, otra vez, la obsesión de este libro con **verificar lo vigente**.

8. Contexto social

Detrás del tecnicismo, lo fiscal tiene una dimensión social profunda: financia lo público (salud, educación, seguridad, infraestructura) y expresa una idea de **justicia distributiva** (quién paga, cuánto y según qué capacidad). En años recientes, la sociedad y los reguladores han elevado la exigencia ética: la evasión y las estructuras agresivas dejaron de verse como "viveza" y pasaron a ser un **riesgo reputacional y legal grave**. Para el abogado corporativo, esto refuerza el Principio de Integridad Ética del proyecto: la planeación legítima crea valor; la evasión destruye reputación y, tarde o temprano, patrimonio.

9. Contexto empresarial

En la vida de una empresa, lo fiscal está en **todo**: en cómo se constituye (qué vehículo y régimen elegir), en cómo factura y deduce, en cómo paga a sus dueños (sueldo vs. dividendo), en cómo se financia (los intereses suelen ser deducibles; los dividendos no), en cómo crece (una adquisición) y en cómo se reorganiza (una fusión o escisión). El director financiero y el fiscalista viven esto a diario; el abogado corporativo que **entiende su lenguaje** se vuelve su aliado natural y un asesor mucho más completo. No necesitas ser el fiscalista del *deal* — para eso hay especialistas—, pero sí **entender lo suficiente para diseñar la estructura con ellos y no contra ellos**.

10. Definiciones doctrinales

La doctrina fiscal ha construido un puñado de conceptos que vale la pena fijar (parafraseados;  *atribuciones a autores concretos, verificar*):

- **Tributo / contribución:** prestación económica que el Estado exige, con fundamento en la ley, a quienes realizan el hecho que la ley considera generador de la obligación de pagar (el *hecho imponible*). La doctrina lo describe como una obligación *ex lege* (nace de la ley, no del acuerdo).
- **Hecho imponible (o hecho generador):** el suceso económico que, descrito en la ley, hace nacer la obligación tributaria (p. ej., obtener un ingreso, realizar una enajenación). Sin hecho imponible realizado, no hay impuesto.
- **Capacidad contributiva:** principio según el cual cada quien debe contribuir conforme a su **capacidad económica real**. Es la justificación profunda del impuesto sobre la renta y un límite constitucional: no se puede gravar donde no hay riqueza.
- **Elusión (planeación fiscal):** el uso de medios **lícitos** para reducir, diferir o evitar la carga fiscal, organizando los negocios de forma fiscalmente eficiente. Es legal.
- **Evasión:** el incumplimiento **ilícito** de la obligación tributaria —ocultar ingresos, simular operaciones, falsear—. Es ilegal y a menudo delito.
- **Razón de negocios (*business purpose*):** la idea de que una operación debe tener una finalidad económica real distinta del mero ahorro fiscal; cuando solo busca el beneficio fiscal, la autoridad puede recaracterizarla.

11. Definiciones legales

 **Verificar todos los artículos contra el texto vigente.** Lo que sigue describe **dónde** vive conceptualmente cada definición en el sistema mexicano, no su redacción exacta ni su numeración (que cambian con las reformas).

- El **Código Fiscal de la Federación (CFF)** define los conceptos generales: qué es una contribución, el crédito fiscal, la

enajenación, las facultades de la autoridad, las infracciones y delitos, y —clave para este libro— la **cláusula general anti-abuso** (la regla que permite recharacterizar actos sin razón de negocios; ⚠ *verificar artículo y redacción vigentes*).

- La **Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR)** define el **ingreso acumulable**, las **deducciones autorizadas**, la base del impuesto, las tasas, el régimen de personas morales y físicas, y los regímenes especiales de **fusión y escisión** (la "neutralidad"), de dividendos y de enajenación de acciones. ⚠ *Artículos y tasas: verificar.*
- La **Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA)** grava el consumo (enajenación de bienes, prestación de servicios, etc.); importa en operaciones que involucran **activos** (un *asset deal* puede causar IVA que un *share deal* no). ⚠ *Verificar tasas y supuestos.*

Idea para fijar: no memorices el número de artículo; memoriza **qué ley regula qué**: CFF = reglas generales + anti-abuso + delitos; LISR = impuesto sobre la utilidad/ingreso; LIVA = impuesto al consumo. Con ese mapa sabes dónde buscar, que es lo que hace un profesional.

12. Definición sencilla

Si tuvieras que explicárselo a alguien sin formación, dirías:

El impuesto sobre la renta es el "porcentaje" que el Estado se queda de lo que ganas. Una empresa gana (ingresos menos gastos = utilidad) y sobre esa utilidad paga ISR. Cuando reparte lo que queda a sus dueños (dividendos), puede haber otro impuesto. Y cuando vendes algo con ganancia (una empresa, un inmueble, acciones), pagas impuesto sobre **esa ganancia**.

La planeación fiscal es, simplemente, **organizar tus cosas legalmente para no pagar más de lo necesario** —como elegir el camino con menos casetas, pero sin saltarte ninguna—. **La evasión** es no pagar las casetas que sí te tocaban: eso es ilegal.

13. Conceptos fundamentales

Glosario riguroso. Domínalo: es el vocabulario del *deal* fiscal.

CONCEPTO	QUÉ ES
Ingreso acumulable	El ingreso que la ley obliga a sumar para calcular la base del ISR.
Deducción autorizada	El gasto que la ley permite restar del ingreso (debe ser estrictamente indispensable, estar soportado y cumplir requisitos).
Base gravable	Ingreso acumulable - deducciones autorizadas; sobre ella se aplica la tasa.
Tasa	El porcentaje aplicable a la base. <i>⚠ Cambia; verificar la vigente.</i>
Enajenación	Concepto fiscal amplio de "transmitir la propiedad" (incluye venta, permuta, aportación, etc.); detona el impuesto sobre la ganancia.
Costo fiscal / base	Lo que "te costó" fiscalmente un bien o acción; la ganancia gravable es precio - costo fiscal.
Ganancia de capital	La utilidad por vender un activo o acciones por encima de su costo fiscal.
Dividendo	Distribución de utilidades a los socios; tiene su propio régimen fiscal (y a menudo doble carga: la empresa ya pagó ISR sobre la utilidad).
CUFIN (cuenta de utilidad fiscal neta)	Registro de las utilidades por las que la empresa ya pagó ISR; distribuir desde ahí evita doble impuesto. <i>⚠ Verificar régimen vigente.</i>
Pérdidas fiscales	Cuando las deducciones superan los ingresos; pueden amortizarse contra utilidades futuras (con límites y reglas anti-traspaso). Activo valioso en M&A.
Neutralidad fiscal	Régimen por el cual ciertas reestructuras (fusión, escisión) no detonan impuesto si se cumplen requisitos.
Diferimiento	No evitar el impuesto, sino posponerlo (pagar después). Por el valor del dinero en el tiempo, diferir ya es un beneficio.
Doble tributación	Que un mismo ingreso se grave dos veces (p. ej., en dos países, o a nivel empresa y a nivel socio). Los tratados y la CUFIN buscan mitigarla.
Precios de transferencia	Reglas para que operaciones entre partes relacionadas se pacten a valores de mercado (<i>arm's length</i>) y no para mover artificialmente la utilidad.
Razón de negocios	Finalidad económica real de una operación, más allá del ahorro fiscal; su ausencia activa el anti-abuso.
Cláusula general anti-abuso (GAAR)	Norma que permite a la autoridad recharacterizar actos carentes de razón de negocios cuyo único fin fue el beneficio fiscal. <i>⚠ Verificar redacción vigente del CFF.</i>

14. Desarrollo absoluto

El núcleo del libro. Aquí construimos, paso a paso, la forma de **pensar** la fiscalidad de una operación corporativa. No memorices tasas (cambian): interioriza la **lógica**.

14.A · LA LÓGICA DEL ISR CORPORATIVO (DE DÓNDE SALE EL IMPUESTO)

Toda la fiscalidad corporativa parte de una cadena sencilla:

INGRESOS	-	DEDUCCIONES	=	UTILIDAD (base)	×	TASA	=	ISR de la empresa
				(lo que queda)	→	DIVIDENDO al socio	→	(posible 2º impuesto)

Tres ideas que de aquí se desprenden y que gobiernan todo lo demás:

1. **Se grava la utilidad, no el ingreso.** Por eso las **deducciones** son el campo de batalla diario: un gasto deducible baja la base; uno no deducible no. La ley exige que la deducción sea *estrictamente indispensable*, esté *soportada* (factura/CFDI) y cumpla requisitos. ⚠ *Requisitos concretos: verificar LISR vigente.*
2. **La doble imposición económica del dividendo.** La empresa paga ISR sobre su utilidad; cuando reparte esa utilidad ya gravada a los socios, el sistema busca **no volver a gravarla** mediante la **CUFIN** (las utilidades por las que ya se pagó). Distribuir desde CUFIN no debería causar ISR adicional corporativo; distribuir por encima de CUFIN sí detona un impuesto. ⚠ *Mecánica y tasas: verificar.* La lección permanente: **el dividendo carga un costo fiscal que el interés (deuda) no carga** — y eso explica buena parte de la planeación de financiamiento.
3. **Deuda vs. capital (la asimetría madre).** Los **intereses** que paga la empresa suelen ser **deducibles** (bajan su ISR); los **dividendos** que paga **no** lo son. Por eso, fiscalmente, financiarse con deuda es a menudo más eficiente que con capital — hasta que la ley pone límites (reglas de **capitalización delgada** / *thin capitalization* y topes a la deducción de intereses, precisamente para evitar el abuso). ⚠ *Límites concretos: verificar.*

Cómo piensa un fiscalista (y debes pensar tú): ante cualquier operación, se pregunta (1) *¿qué hecho imponible se realiza?*, (2) *¿quién obtiene el ingreso o la ganancia?*, (3) *¿cuál es su costo fiscal/base?*, (4) *¿hay un régimen especial (neutralidad, diferimiento)?*, (5) *¿hay razón de negocios?*. Esas cinco preguntas resuelven el 80 % del análisis.

14.B · LA DIMENSIÓN FISCAL DEL DEAL: POR QUÉ LA ESTRUCTURA LO ES TODO

En una compraventa de empresa hay **siempre dos lados con intereses fiscales opuestos**, y entender esa tensión es entender la negociación:

- **El vendedor** quiere **minimizar el impuesto sobre su ganancia** hoy (precio - costo fiscal).
- **El comprador** quiere **maximizar lo que podrá deducir/recuperar mañana** (depreciar lo comprado, aprovechar pérdidas, intereses del financiamiento) y **no heredar contingencias fiscales** del pasado del negocio.

Estos intereses chocan, y la **estructura** del deal es el terreno donde se reparte ese costo fiscal —exactamente igual que las representaciones y garantías reparten el riesgo (Libro 4)—. Por eso el abogado que entiende fiscal **negocia mejor el precio y la estructura**: sabe que "el mismo precio" no es el mismo para cada parte una vez metido el impuesto.

Regla de oro del deal fiscal: *el precio nominal no es el precio real; el precio real es el precio después de impuestos*. Un vendedor racional prefiere \$95 con bajo impuesto a \$100 con impuesto alto. El abogado que sabe esto encuentra estructuras que **agrandan el pastel después de impuestos** y reparten esa ganancia entre las partes — eso es crear valor, no solo dividirlo.

14.C · LA DECISIÓN FISCAL CENTRAL: COMPRAR ACCIONES VS. COMPRAR ACTIVOS

Es la primera gran bifurcación de toda adquisición (la viste en el Libro 3 desde lo corporativo; aquí desde lo fiscal). La estructura cambia **quién paga, cuánto y qué se lleva el comprador**.

Compra de ACCIONES (*share deal*) — se compra la sociedad entera, con todo lo que tiene dentro.

- **Vendedor:** obtiene una **ganancia por enajenación de acciones** (precio - costo fiscal de las acciones). Suele ser su estructura preferida: a menudo el régimen de ganancia en acciones es más benigno y el cálculo del costo fiscal puede incluir utilidades retenidas. [△](#) *Régimen y cálculo: verificar.*
- **Comprador:** hereda la sociedad **con toda su historia fiscal** — sus activos a su valor fiscal actual (no puede "re-valorarlos" para depreciar más), sus pérdidas fiscales (valiosas, pero con reglas anti-traspaso), **y sus contingencias** (si el SAT revisa años después, el problema es del comprador). Por eso el *share deal* exige **due diligence fiscal** feroz e **indemnizaciones específicas** (Laboratorio, Ej. 04).

Compra de ACTIVOS (*asset deal*) — se compran bienes y derechos seleccionados, no la sociedad.

- **Comprador:** suele preferirla. Elige **qué compra** (deja atrás pasivos y contingencias ocultas), y a menudo puede **registrar los activos a su valor de compra** (*step-up*), lo que le da **más depreciación deducible** a futuro. Pero puede causar **IVA** y otros impuestos/derechos sobre la transmisión (p. ej., en inmuebles). [△](#) *Verificar IVA y régimen.*
- **Vendedor:** suele salir peor: la venta de activos puede generar **ganancia gravable a nivel de la sociedad** y, además, si luego reparte el dinero a sus socios, **otro impuesto al diviendo** — la temida **doble carga**.

El conflicto, en una frase: *el comprador suele preferir comprar activos (step-up, sin contingencias); el vendedor suele preferir vender acciones (un solo impuesto, más benigno).* La estructura final es producto de la **negociación** —y muchas veces el precio se ajusta para compensar a quien carga el costo fiscal—. Aquí el abogado fiscal-corporativo vale oro.

	SHARE DEAL (ACCIONES)	ASSET DEAL (ACTIVOS)
Suele preferirlo	Vendedor	Comprador
Contingencias del pasado	Las hereda el comprador	Se quedan con el vendedor
"Step-up" para depreciar	Generalmente no	Generalmente sí
Pérdidas fiscales del target	Pueden pasar (con límites)	No pasan (se queda la sociedad)
IVA / impuestos de transmisión	Generalmente no en la acción	Posible (activos, inmuebles)
Riesgo de doble impuesto al vendedor	Menor	Mayor

⚠ *Todo lo anterior es la lógica general; cada punto tiene excepciones y depende del régimen vigente. Verificar siempre con fiscalista.*

14.D · NEUTRALIDAD FISCAL: FUSIONES Y ESCISIONES QUE NO PAGAN (SI SE HACEN BIEN)

¿Cómo reorganiza una empresa su estructura —fusionarse, escindirse— sin que cada movimiento detone un impuesto que lo haría imposible? Mediante el régimen de **neutralidad fiscal**: la ley reconoce que en una **mera reorganización** no hay una verdadera "realización" de riqueza (los mismos dueños siguen detrás de los mismos activos, solo reordenados), y por eso permite que la operación **no cause ISR si se cumplen requisitos**.

La idea profunda: la neutralidad **no perdona** el impuesto, lo **difiere**. El costo fiscal "viaja" con los activos/acciones a la nueva estructura; el impuesto se pagará después, cuando haya una verdadera enajenación a un tercero. Es diferimiento, no exención.

Requisitos típicos (la lógica; ⚠ verificar los concretos en LISR/CFF vigentes):

- **Continuidad en la propiedad:** los mismos accionistas deben permanecer un tiempo mínimo (evita que la "fusión" sea una venta disfrazada).
- **Continuidad del negocio:** que la actividad siga, no que se liquide.

- **Requisitos formales:** avisos, contabilidad, valores fiscales que se conservan.
- **Razón de negocios:** que la reorganización tenga una finalidad económica real, no solo fiscal.

Errores que cuestan millones (anticipo): incumplir un requisito formal o de permanencia accionaria y **perder la neutralidad** — convirtiendo una reorganización que debía ser libre de impuesto en un hecho gravado por millones. La neutralidad es un beneficio **condicionado**: se respeta al pie de la letra o se pierde entera.

Cómo se usa en planeación (legítima): a veces se hace una **escisión previa** para separar el negocio que se quiere vender de los activos que se quieren conservar, y luego se vende solo esa parte; o una **fusión** para integrar y aprovechar sinergias y, en su caso, pérdidas fiscales (con límites estrictos). Todo **con razón de negocios documentada**.

14.E · PLANEACIÓN FISCAL Y LA LÍNEA INFRANQUEABLE

Aquí está el corazón ético y técnico de la materia. La planeación fiscal **legítima** descansa en un principio reconocido: **nadie está obligado a estructurar sus negocios de la forma que más impuesto pague**. Puedes elegir, entre opciones legales, la más eficiente. Eso es **elusión / economía de opción**, y es lícito.

Las herramientas legítimas de planeación son, casi siempre, **diferir, aprovechar regímenes que la ley ofrece, y elegir la estructura adecuada**:

- **Diferimiento:** posponer el impuesto (por el valor del dinero en el tiempo, pagar en 5 años vale menos que pagar hoy).
- **Aprovechar regímenes que la propia ley crea:** neutralidad en reorganizaciones, CUFIN para evitar doble impuesto, estímulos sectoriales, tratados para evitar doble tributación.
- **Elegir vehículo y estructura:** qué tipo de sociedad, dónde, share vs. asset, deuda vs. capital — todo dentro de lo que la ley permite y **con razón de negocios**.

La línea infranqueable. La diferencia entre planeación y delito no es de grado, es de **naturaleza**:

	ELUSIÓN / PLANEACIÓN (LÍCITO)	EVASIÓN (ILÍCITO — A MENUDO DELITO)
Qué hace	Organiza la realidad de forma eficiente	Oculto o falsea la realidad
La realidad económica	Es verdadera	Es fingida (simulación)
Ejemplo	Hacer una escisión real con razón de negocios	Facturar operaciones inexistentes; ocultar ingresos; testaferros
Frente al fisco	Se sostiene a la luz	Se derrumba al revisarse
Consecuencia	Ahorro legítimo	Multas, recargos, delito fiscal (defraudación), cárcel

La frontera moderna: la razón de negocios y la cláusula anti-abuso (GAAR). Hoy no basta con que una estructura sea *formalmente* legal: si su **único propósito** es el beneficio fiscal y carece de **razón de negocios** real, la autoridad puede **recaracterizarla** (tratarla como lo que económicamente es) mediante la cláusula general anti-abuso del CFF. [△ Verificar redacción vigente.](#) Esto significa que la planeación agresiva "técnicamente legal pero artificial" es un terreno cada vez más peligroso. **La sustancia vence a la forma.**

Cómo piensa un socio (y el Principio de Integridad del proyecto): el socio serio no busca la estructura "más lista", busca la **más sólida** — la que tiene razón de negocios real, se documenta bien y **sobrevive una auditoría dentro de cinco años**. La planeación agresiva que ahorra hoy y explota mañana no es un activo: es una bomba de tiempo para el cliente y para la reputación del abogado. El mejor fiscalista no es el más audaz, es **el que nunca pierde una revisión**.

Regla permanente para ti: ofrece a tus clientes **eficiencia fiscal con sustancia y documentación**, nunca trucos. La eficiencia bien hecha crea valor y fideliza; la evasión, tarde o temprano, destruye al cliente y te arrastra a ti. En fiscal, tu firma vale lo que vale tu integridad.

15. Explicación intuitiva (el modelo mental)

Piensa en el impuesto como un **peaje sobre la riqueza nueva**. Cada vez que se genera riqueza *nueva y real* (una utilidad, una

ganancia al vender algo más caro de lo que costó), hay un peaje. Y aquí están las tres intuiciones que lo explican casi todo:

1. **El peaje se cobra cuando "realizas" la ganancia, no antes.** Mientras tu empresa *vale* más pero no la vendes, no hay peaje (no realizaste nada). El día que vendes, realizas la ganancia y se activa el peaje. → Por eso **diferir** la realización (posponer la venta, usar neutralidad) pospone el peaje.
2. **Reordenar tu propia casa no es realizar riqueza.** Si mueves muebles de un cuarto a otro de tu casa (fusión, escisión entre los mismos dueños), no "vendiste" nada: por eso la **neutralidad** no cobra peaje — hasta que saques el mueble a la calle y lo vendas a un extraño.
3. **El fisco mira quién se quedó la riqueza, no la etiqueta del papel.** Si disfrazas una venta de "reorganización" pero en realidad un tercero se llevó el negocio y tú el dinero, el fisco **levanta la etiqueta** y cobra el peaje real (sustancia sobre forma / anti-abuso).

La metáfora del camino con casetas (planeación): ir de A a B legalmente puede tener varias rutas; elegir la de menos casetas es tu derecho (elusión). Lo que no puedes hacer es **pasar por la caseta sin pagar** (evasión) ni **poner una caseta de juguete fingiendo un camino que no recorres** (simulación). Misma meta, medios distintos: unos legales, otros delito.

16. Ejemplos simples (para asentar)

Cifras **ilustrativas e inventadas** para mostrar la *mecánica*, no valores reales. ⚠ Tasas y reglas: verificar las vigentes.

Ejemplo 1 — Utilidad y dividendo. Una empresa tiene ingresos por 100 y deducciones por 60 → utilidad 40. Aplica una tasa hipotética del 30 % → paga 12 de ISR. Le quedan 28. Si reparte esos 28 como dividendo desde su CUFIN (utilidades ya gravadas), no debería pagar ISR corporativo adicional. *Leción:* la utilidad se grava una vez a nivel empresa; la CUFIN evita volver a gravarla al repartir.

Ejemplo 2 — Ganancia de capital. Compraste acciones en 100 (tu costo fiscal) y las vendes en 150. Tu **ganancia** es 50; el

impuesto recae sobre esos 50, no sobre los 150. *Lección:* siempre importa el **costo fiscal/base**, no solo el precio.

Ejemplo 3 — Deuda vs. capital. Una empresa paga 10 de intereses por un préstamo: suelen ser **deducibles** (bajan su base). Si en vez de eso pagara 10 de dividendos, **no** son deducibles. *Lección:* la forma de financiarse cambia el impuesto.

17. Ejemplos complejos (multi-variable, realistas)

Compra de empresa: el mismo precio, dos estructuras. Compradora quiere adquirir "Target".

- **Vía share deal:** paga 1,000 por las acciones. El vendedor calcula ganancia (1,000 - su costo fiscal) y paga el régimen de acciones. La Compradora hereda los activos a su valor fiscal histórico (poca depreciación futura) y las contingencias fiscales de Target → exige due diligence fiscal e indemnización específica.
- **Vía asset deal:** paga 1,000 por los activos. Puede hacer **step-up** (registrarlos en 1,000 y depreciar más → menos ISR futuro) y deja atrás las contingencias, **pero** puede causar IVA y, para el vendedor, ganancia a nivel sociedad + impuesto al dividendo al subir el dinero a los socios (doble carga).
- **El abogado fiscal-corporativo** calcula el **valor después de impuestos** de cada vía para cada parte, y **propone la estructura que agranda el pastel total** —p.ej., asset deal con un ajuste de precio que compense al vendedor por su mayor carga, repartiendo entre ambos el beneficio del step-up—. Eso es crear valor con fiscal.

Reestructura previa a la venta. El dueño quiere vender solo una de sus tres líneas de negocio. Hace una **escisión** (neutral, con razón de negocios real: separar líneas para gestión independiente) para aislar esa línea en una nueva sociedad y luego vende **solo** esas acciones — más limpio y eficiente que vender activos sueltos. ⚠ *Requisitos de neutralidad y permanencia: verificar.*

18. Casos reales (jurisprudencia y operaciones estilizadas)

⚠ No se citan números de tesis ni casos con nombre por no estar verificados (Principio Supremo). Se describen patrones reales y estilizados; verificar criterios concretos en el SJF.

- **Patrón "reorganización que era venta".** La autoridad y los tribunales han desconocido "reestructuras neutrales" en las que, al levantar la forma, había en realidad una **venta a un tercero** (no había continuidad accionaria real): se pierde la neutralidad y se cobra el impuesto diferido + accesorios. *Criterio a verificar en jurisprudencia.*
- **Patrón "operaciones simuladas / facturas de operaciones inexistentes (EFOS/EDOS)".** Estructuras que deducen con comprobantes de operaciones que nunca ocurrieron: es **evasión** y delito, con consecuencias severas. Es el ejemplo arquetípico de la línea que nunca se cruza.
- **Patrón "sin razón de negocios".** Estructuras formalmente válidas pero cuyo único fin era el ahorro fiscal, recaracterizadas vía la cláusula anti-abuso. *Verificar precedentes vigentes.*

Apple-Irlanda: la versión contemporánea del debate, por una vía inesperada. La Comisión Europea sostuvo que el tratamiento fiscal concedido a la compañía constituía una **ayuda de Estado** prohibida, y el asunto culminó en el TJUE con una resolución en contra de la empresa y del Estado por unos 13,000 millones de euros ⚠ *verificar*. Lo interesante para un abogado corporativo no es la cifra: es el **instrumento**. La Comisión no atacó la estructura con derecho fiscal ni con una GAAR, sino con **derecho de la competencia** —el régimen de ayudas de Estado—.

La lección de método: el riesgo fiscal ya no llega solo por la puerta fiscal. Puede entrar por competencia (ayudas de Estado), por transparencia (obligaciones de revelación y esquemas reportables), por vía reputacional o por presión de inversionistas. Un análisis que solo consulta al fiscalista está incompleto, y es la razón por la que en este nivel insistimos en analizar **fiscal, pasivos y aprobaciones en paralelo** (Libro 3).

Y el otro frente, el reputacional. Las filtraciones documentales masivas —conocidas como *Panama Papers* y *Paradise Papers*— instalaron en la conversación pública una idea que jurídicamente es incómoda y prácticamente es decisiva: **que algo sea legal no lo vuelve necesariamente legítimo a ojos del mercado.** Estructuras impecables han costado clientes, contratos públicos y valor de marca. Cuando asesores una estructura, la pregunta completa ya no es "*¿es legal?*" sino "*¿es legal y podría explicarse en público sin que le cueste a mi cliente más de lo que le ahorra?*". Es la prueba del tercero del módulo 06 de la Columna VI.

CÓMO SE TRADUCE TODO ESTO EN UNA OPERACIÓN DE M&A

Aquí es donde este libro se conecta con el resto del nivel, y el mecanismo es concreto. Cuando el fiscalista encuentra una contingencia en el *due diligence*, no basta con reportarla: hay que **medir su vida útil**. El **artículo 67 del CFF** ☺ ✓ (*cotejado verbatim en fuentes- legales/*) dispone que las facultades de la autoridad para determinar contribuciones omitidas e imponer sanciones "*se extinguen en el plazo de cinco años*" contados desde los supuestos que el propio artículo enumera —con plazos mayores en los casos que ahí se prevén—.

Ese plazo es el que **debe gobernar el survival de las declaraciones fiscales del SPA**, y no el plazo comercial de doce o dieciocho meses. Si aceptas un *survival* corto para la materia fiscal, tu cliente se queda con la contingencia viva y sin nadie a quién cobrarle. De ahí la triple traducción que el fiscalista y tú deben producir juntos:

HALLAZGO FISCAL	SU TRADUCCIÓN CONTRACTUAL
Cuantificado y cierto	Ajuste de precio
Contingente	Declaración fiscal específica + indemnidad sin basket
De vida larga (caducidad art. 67 ☺)	Survival alineado a la caducidad, no al plazo general
Sin respaldo patrimonial confiable	Escrow o retención por el plazo correspondiente

Es exactamente el canje que se entrena en el ejercicio 12 del Laboratorio.

19. Casos empresariales (en la vida de una compañía)

- **Distribuir utilidades:** ¿sueldo a los dueños-administradores (deducible para la empresa, pero ingreso gravado para la persona) o dividendo (no deducible, con su propio régimen)? Decisión fiscal cotidiana.
- **Financiar una expansión:** ¿deuda (intereses deducibles, con límites de capitalización delgada) o aportación de capital (sin deducción, pero sin endeudar)?
- **Empresa familiar y sucesión:** cómo estructurar la transmisión del patrimonio empresarial a la siguiente generación de forma ordenada y fiscalmente eficiente (conecta con Patrimonio, Columna V). ⚠ *Régimen de herencia/donación: verificar.*

20. Casos corporativos (en transacciones)

- **El "tax structuring" del deal:** antes de firmar, fiscal y legal diseñan juntos la estructura (share/asset, escisión previa, vehículo de adquisición, cómo se financia) buscando el mejor resultado después de impuestos para el cliente.
- **Las pérdidas fiscales como activo (y trampa):** un target con pérdidas fiscales acumuladas puede ser atractivo, pero las reglas **anti-traspaso de pérdidas** limitan severamente aprovecharlas tras un cambio de control. Creerse que "compras las pérdidas" sin verificar es un error caro. ⚠ *Verificar reglas de amortización y cambio de socios.*
- **Cláusulas fiscales en el SPA:** *tax indemnity*, declaraciones fiscales (R&W), retenciones, manejo de auditorías post-cierre (*tax contest*). Aquí el Libro 4 (documentación) y este libro se encuentran.

21. Casos internacionales (*cross-border*)

- **Doble tributación:** un mismo ingreso podría gravarse en el país de la fuente y en el de residencia; los **tratados para evitar la doble tributación** (modelo OCDE) reparten la potestad y permiten acreditar impuestos. ⚠ *Verificar el tratado aplicable.*

- **Estructuras *holding*:** los grupos multinacionales usan sociedades *holding* en ciertas jurisdicciones por sus tratados y régimen — legítimo si hay sustancia; abuso (*treaty shopping*) si es una cáscara sin actividad. El movimiento global **BEPS** combate justamente las estructuras artificiales. ⚠ *Verificar estado vigente.*
- **Precios de transferencia:** las operaciones entre empresas del mismo grupo en distintos países deben pactarse a valor de mercado (*arm's length*) y documentarse, para que el grupo no mueva artificialmente la utilidad al país de menor impuesto. Es de las áreas fiscales más técnicas y litigadas del mundo corporativo.

22. Derecho comparado

La fiscalidad de operaciones tiene patrones comunes en el mundo, con variantes locales. ⚠ *Cada régimen concreto debe verificarse en la legislación vigente del país.*

JURISDICCIÓN	RASGOS DISTINTIVOS (A GRANDES TRAZOS)
México	ISR sobre utilidad; CUFIN para integrar el impuesto al dividendo; regímenes de neutralidad en fusión/escisión; cláusula anti-abuso (razón de negocios) en el CFF; IVA en asset deals.
España	Impuesto sobre Sociedades; régimen especial de neutralidad en reestructuraciones (de raíz europea); doctrina del <i>motivo económico válido</i> (equivalente a la razón de negocios).
EE. UU.	Distingue <i>taxable acquisitions</i> de reorganizaciones libres de impuesto (las célebres <i>tax-free reorganizations</i> , tipo "A", "B", "C" del Internal Revenue Code); elecciones como la §338 para tratar una compra de acciones como de activos. Sistema riquísimo en <i>tax structuring</i> .
Delaware	Su ventaja es societaria , no fiscal: el impuesto federal de EE. UU. aplica igual; muchas sociedades se forman ahí por su derecho corporativo, no por un régimen fiscal especial. Útil para no confundir "paraíso societario" con "paraíso fiscal".
UE	Directivas que armonizan la neutralidad de fusiones transfronterizas entre Estados miembros; fuerte agenda anti-abuso.
OCDE	No legisla, pero su Modelo de Convenio rige los tratados de doble tributación y su proyecto BEPS marca el estándar global anti-erosión.
Common law vs. Civil law	Más allá de la tradición, en fiscal convergen hacia la idea de sustancia sobre forma y razón de negocios; es una tendencia global, no de una sola familia jurídica.

Lección comparada para el M&A: la estructura "tax-free reorganization" de EE. UU. y la "neutralidad" de México/España/UE responden a la **misma intuición** (no gravar la mera reorganización), con requisitos distintos. Quien hace deals *cross-border* debe dominar las dos lógicas y a sus fiscalistas locales.

Tres piezas del vocabulario internacional que hay que reconocer. No para dominarlas —eso es trabajo del fiscalista— sino para no perderse en la conversación:

- **GILTI y BEAT** (Estados Unidos, reforma de 2017). Dos mecanismos que atacan, por vías distintas, el traslado de utilidades al exterior: el primero grava cierta renta de subsidiarias extranjeras; el segundo actúa como un impuesto mínimo frente a pagos erosivos a partes relacionadas en el exterior

⚠. Su efecto práctico: **volvieron mucho menos rentables las estructuras de erosión clásicas.**

- **Los pilares del proyecto BEPS de la OCDE**, incluido el impulso hacia una **tributación mínima global** ⚠. La dirección es inequívoca: reducir el espacio de la competencia fiscal entre Estados.
- **El establecimiento permanente**, que es el concepto donde más se equivoca una empresa mediana que se internacionaliza: la actividad en otro país puede generar obligación de tributar **allá** sin que nadie haya constituido una sociedad. Es la trampa de la expansión que describe La empresa por dentro.

La conclusión comparada, y es la más útil del apartado. La tendencia global es **irreversible hacia la sustancia**: cada año hay menos espacio para las estructuras sin actividad real y más obligaciones de revelación. El abogado que hoy diseña "cascarones" no está construyendo un ahorro: está construyendo un **pasivo diferido** para su cliente, que se materializará cuando la norma alcance a la estructura —y alcanzará—.

23. Derecho mexicano (régimen positivo)

⚠ **Mapa conceptual; verificar artículos y tasas vigentes.** El objetivo es que sepas **dónde vive** cada cosa, no memorizar numeración.

- **Constitución**: la obligación de contribuir de manera **proporcional y equitativa** (principios de capacidad contributiva, legalidad, proporcionalidad y equidad) es el marco superior; ningún impuesto puede violarlos. ⚠ *Artículo: verificar.*
- **Código Fiscal de la Federación (CFF)**: reglas generales, concepto de enajenación, facultades de comprobación de la autoridad, infracciones y **delitos fiscales** (defraudación), y la **cláusula general anti-abuso / razón de negocios**. ⚠ *Artículos: verificar.*
- **Ley del ISR (LISR)**: el impuesto sobre la utilidad; deducciones; régimen de personas morales; **dividendos y CUFIN**; **enajenación de acciones; fusión y escisión** (neutralidad); amortización de **pérdidas fiscales** y reglas anti-traspaso;

capitalización delgada; precios de transferencia. ⚠ *Artículos y tasas: verificar.*

- **Ley del IVA (LIVA):** impuesto al consumo; relevante en **asset deals** y prestación de servicios.
- **Resolución Miscelánea Fiscal:** reglas administrativas que **cambian cada año**; el detalle operativo vive ahí. ⚠ *Verificar la vigente.*

24. Jurisprudencia relevante

⚠ *No se citan rubros ni números de tesis por no estar verificados (Principio Supremo). Se describen líneas jurisprudenciales reconocibles; localizar y validar en el Semanario Judicial de la Federación antes de citar.*

Líneas que el estudiante debe saber que existen (y verificar):

- Criterios sobre los **principios constitucionales** de proporcionalidad y equidad tributaria como límite a las contribuciones.
- Criterios sobre **deducciones** (qué hace a un gasto "estrictamente indispensable").
- Criterios y precedentes sobre **simulación, operaciones inexistentes** y la aplicación de la **razón de negocios** / cláusula anti-abuso.
- Criterios sobre los **requisitos de la neutralidad** en fusión y escisión.

25. Criterios de la Suprema Corte

La **SCJN** ha construido la doctrina constitucional tributaria mexicana: el alcance de la **capacidad contributiva**, los límites de la **proporcionalidad y equidad**, y la constitucionalidad de diversos regímenes. ⚠ *Tesis y jurisprudencias concretas: verificar en el SJF.* Para el abogado corporativo, lo relevante no es memorizar tesis, sino saber que **un impuesto o una interpretación puede impugnarse por inconstitucional** cuando viola esos principios — una herramienta estratégica más.

26. Doctrina nacional

México tiene una tradición sólida de fiscalistas y tratadistas de derecho tributario. [△](#) *Nombres y obras concretas: verificar antes de citar* (no se listan aquí para no atribuir incorrectamente). Lo importante: la doctrina mexicana ha desarrollado con rigor los conceptos de **obligación tributaria, hecho imponible, capacidad contributiva y la distinción elusión/evasión**, y dialoga cada vez más con la doctrina internacional sobre sustancia económica y anti-abuso.

27. Doctrina internacional

A nivel global, la doctrina y los organismos (con la **OCDE** a la cabeza) han marcado la agenda moderna: **precios de transferencia** (*arm's length*), **BEPS** (erosión de la base y traslado de utilidades), **sustancia económica** y el combate al *treaty shopping*. La doctrina anglosajona aportó la rica teoría de las *tax-free reorganizations* y de la *substance over form*; la europea, la **neutralidad** armonizada y el *motivo económico válido*. [△](#) *Autores y documentos concretos: verificar*.

28. Opiniones críticas (postura del Consejo)

- **El fiscal no es accesorio: es co-arquitecto del deal.** Dejar lo fiscal "para el final" o "para el contador" es el error estratégico clásico. La postura del proyecto: el abogado corporativo de élite **integra lo fiscal desde el diseño**.
- **La era de la planeación agresiva terminó.** Con la cláusula anti-abuso y la transparencia global, las estructuras artificiales son cada vez más un pasivo. El futuro es la **eficiencia con sustancia**, no el truco.
- **La inestabilidad es estructural, no un defecto pasajero.** Quien trabaje fiscal debe asumir que **estudiará toda su vida**: cada reforma reescribe parte del tablero. Es, a la vez, una barrera de entrada y una fuente de honorarios recurrentes.

29. Debate doctrinal (controversias vivas)

- **¿Dónde termina la economía de opción y empieza el abuso?** La gran frontera: cuánta "razón de negocios" basta, y cuánto puede la autoridad recaracterizar sin caer en arbitrariedad. Tensión permanente entre **seguridad jurídica** del contribuyente y **combate al abuso** del fisco.
- **Sustancia vs. forma:** ¿hasta dónde puede el fisco ignorar la forma jurídica elegida por las partes? El péndulo se ha movido fuerte hacia la sustancia, y no todos coinciden en sus límites.
- **Justicia de la fiscalidad internacional:** el debate global (impuesto mínimo, dónde tributan las multinacionales y las grandes tecnológicas) sigue abierto y reescribiéndose. [△] *Estado vigente: verificar.*

30. Errores comunes

ERROR	POR QUÉ ES UN ERROR
Dejar lo fiscal "para el final" del deal	La estructura ya se decidió sin optimizarla; el impuesto se vuelve un costo evitable
Confundir precio nominal con precio real	El precio real es después de impuestos ; ignorar esto pierde dinero en la negociación
Creer que comprar acciones evita todos los problemas	Heredas toda la historia fiscal y las contingencias del target
Asumir que "compras las pérdidas fiscales" del target	Las reglas anti-traspaso por cambio de control suelen limitarlas o anularlas
Diseñar una "reorganización neutral" descuidando requisitos	Un requisito incumplido pierde la neutralidad : la operación pasa a ser gravada
Confundir elusión (legal) con evasión (delito)	Cruzar esa línea destruye al cliente y al abogado
Memorizar tasas y artículos como si fueran fijos	Cambian cada año; lo que perdura es la lógica
Olvidar el IVA en un asset deal	Puede aparecer un impuesto al consumo que no estaba en el modelo

31. Mitos frecuentes

- **"Planear impuestos es ilegal / inmoral."** Falso: elegir, entre opciones legales, la más eficiente es un **derecho** (economía de opción). Lo ilegal es ocultar o simular.
- **"Si está en Delaware / una isla, no paga impuestos."** Falso y peligroso: Delaware da ventaja **societaria**, no fiscal; y las estructuras *offshore* sin sustancia son hoy un imán de auditorías y sanciones.
- **"La neutralidad fiscal exenta el impuesto."** Falso: lo **difiere**; el costo fiscal viaja con los activos y se paga al enajenar a un tercero.
- **"Si mi estructura es formalmente legal, es intocable."** Falso desde la cláusula anti-abuso: sin **razón de negocios**, puede recharacterizarse.
- **"El fiscal es cosa del contador, no del abogado."** Falso: la estructura jurídica y la fiscal son inseparables; el abogado corporativo que las integra es el valioso.

32. Preguntas difíciles (para pensar como experto)

1. ¿Cuándo una "razón de negocios" es suficiente para sostener una estructura? ¿Basta *alguna* razón, o debe ser la *preponderante*? (Frontera del anti-abuso.)
2. Si comprador y vendedor prefieren estructuras fiscales opuestas, ¿cómo diseñas una que **agrande el pastel después de impuestos** y repartes ese beneficio en el precio?
3. ¿Vale la pena comprar un target por sus pérdidas fiscales si las reglas anti-traspaso las limitan? ¿Cómo lo modelas?
4. ¿Hasta dónde puede el fisco ignorar la forma jurídica elegida sin vulnerar la **seguridad jurídica** del contribuyente?
5. En una operación *cross-border*, ¿cómo evitas la doble tributación sin caer en *treaty shopping*?

33. Casos de examen (con respuesta modelo)

Caso A. Una empresa vende un inmueble que compró en 100 y hoy vale 300. ¿Sobre qué monto paga impuesto y por qué?

Respuesta modelo: sobre la **ganancia** (≈ 300 - costo fiscal actualizado de $100 = 200$), no sobre los 300. El impuesto a la renta grava la **riqueza nueva realizada**, no el valor total. $\triangle$ *La actualización del costo y la tasa: verificar LISR vigente.*

Caso B. *Comprador y vendedor discuten si la operación será share o asset deal. Explica el conflicto fiscal.*

Respuesta modelo: el comprador suele preferir **asset deal** (step-up para depreciar más, deja contingencias atrás); el vendedor suele preferir **share deal** (un solo impuesto, régimen de acciones más benigno, evita la doble carga). Se resuelve negociando estructura y precio.

Caso C. *¿Por qué una fusión bien hecha no paga impuesto y una mal hecha sí?*

Respuesta modelo: por el régimen de **neutralidad**, que **difiere** el impuesto si se cumplen los requisitos (continuidad accionaria y del negocio, formalidades, razón de negocios). Incumplir uno hace **perder la neutralidad** y la operación se grava. $\triangle$ *Requisitos: verificar.*

34. Simulador (ejercicio tipo despacho)

Rol: asociado del área corporativa, apoyando al fiscalista. **Ciente:** "Compradora, S.A.", quiere adquirir "Dulces del Valle" (¡el del Laboratorio!). **Hechos:** Dulces del Valle tiene pérdidas fiscales acumuladas, un inmueble muy apreciado, y una contingencia fiscal en revisión por el SAT. La socia te pide un **memo de estructura fiscal preliminar**.

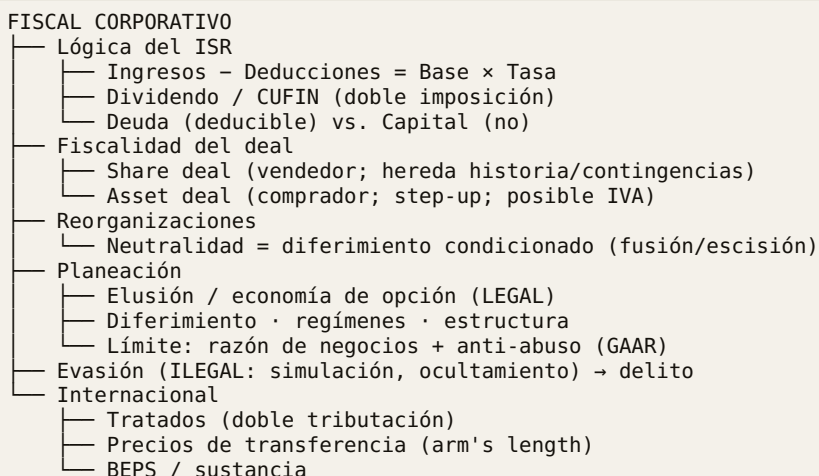
Tu tarea: (1) recomienda share vs. asset deal y por qué, considerando las pérdidas (¿se aprovechan tras el cambio de control?), el inmueble (step-up vs. heredar costo histórico) y la contingencia (¿quién la carga?); (2) propón **protecciones contractuales** (tax indemnity, escrow, R&W fiscales, condición de cierre); (3) marca **qué debes verificar** con el fiscalista y contra la ley vigente. Usa el formato de memo del Laboratorio (Ej. 01) y conecta con R&W (Ej. 04).

No hay una sola respuesta correcta: se evalúa que identifiques las tensiones fiscales, conectes con las protecciones del SPA y marques honestamente lo no verificado.

35. Flashcards (recuperación activa)

- ¿Qué grava el ISR: ingreso o utilidad? → **La utilidad** (ingresos - deducciones).
- ¿Para qué sirve la CUFIN? → Para evitar **doble impuesto** al repartir utilidades ya gravadas.
- ¿Intereses y dividendos: cuál es deducible? → **Intereses** sí (con límites); dividendos no.
- ¿Share deal o asset deal hereda contingencias? → **Share deal** (compras la sociedad entera).
- ¿Qué es el step-up? → Registrar activos comprados a su valor de compra → más depreciación deducible (típico del **asset deal**).
- ¿La neutralidad exenta o difiere? → **Difiere** el impuesto.
- ¿Elusión vs. evasión? → Elusión = legal (organizar); evasión = ilegal (ocultar/simular).
- ¿Qué activa la cláusula anti-abuso? → Operaciones **sin razón de negocios** cuyo único fin es el beneficio fiscal.
- ¿Qué son precios de transferencia? → Que operaciones entre partes relacionadas se pacten a valor de mercado (*arm's length*).

36. Mapa mental (estructura jerárquica)



37. Cuadros comparativos

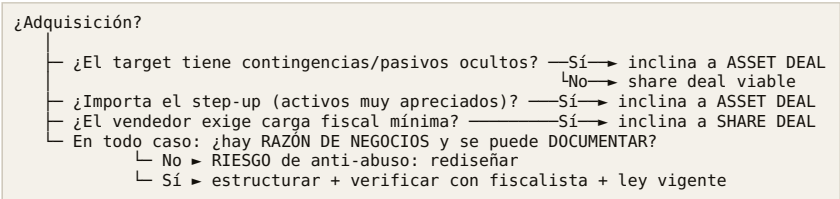
Elusión vs. evasión (el cuadro que nunca debes olvidar):

	ELUSIÓN	EVASIÓN
Legalidad	Legal	Ilegal (delito)
Realidad económica	Verdadera	Fingida/oculta
Frente a auditoría	Se sostiene	Se derrumba
Resultado	Ahorro legítimo	Multas, recargos, cárcel

Deuda vs. capital (para financiar):

	DEUDA	CAPITAL
Costo que paga	Intereses	Dividendos
¿Deducible?	Sí (con límites)	No
Riesgo	Obliga a pagar; puede llevar a insolvencia	No obliga, pero diluye/no deduce

38. Diagramas (flujo de una decisión de estructura)



39. Mnemotecnias

- **"La SUSTANCIA vence a la FORMA"** — la frase que resume el fiscal moderno.
- **"DI-RE-ES": las 3 vías legales** — **D**iferir, aprovechar **RE**gímenes, elegir **E**structura.
- **"El vendedor ama las Acciones; el comprador ama los Activos"** — para recordar la preferencia en el deal (ambos empiezan con A, pero opuestos: **Acciones** = vendedor, **Activos** = comprador).
- **"Neutral = se Difiere, no se borra."**
- **"Sin Razón de Negocios, no hay estructura que aguante."**

40. Resumen ejecutivo

- El **ISR corporativo** grava la **utilidad** (ingresos - deducciones), no el ingreso; al repartirla como dividendo hay un segundo nivel que la **CUFIN** integra. **Deuda** (intereses deducibles) y **capital** (dividendos no deducibles) tributan distinto: de ahí gran parte de la planeación.
- En una adquisición, **share deal** (compra de acciones) y **asset deal** (compra de activos) tienen consecuencias fiscales opuestas: el vendedor suele preferir acciones; el comprador, activos (step-up, sin heredar contingencias). La estructura **reparte el costo fiscal** y se negocia junto con el precio.
- Las **fusiones y escisiones** pueden ser **neutrales** (diferir el impuesto) si cumplen requisitos estrictos; incumplir uno **pierde la neutralidad**.
- La **planeación legítima** (elusión: diferir, aprovechar regímenes, elegir estructura) es un derecho; la **evasión** (simular, ocultar) es delito. La frontera moderna es la **razón de negocios** + la **cláusula anti-abuso**: *la sustancia vence a la forma*.
- Dimensión **internacional**: tratados contra doble tributación, **precios de transferencia** y **BEPS** combatiendo estructuras artificiales.
- El **abogado corporativo de élite integra lo fiscal desde el diseño del deal**, no al final. Y **verifica siempre** tasas y artículos contra el texto vigente.

41. Checklist (operativo del profesional)

Ante una operación con dimensión fiscal:

- [] ¿Identifiqué el **hecho imponible** y **quién** obtiene la ganancia/ingreso?
- [] ¿Calculé sobre la **base** correcta (precio - costo fiscal), no sobre el precio bruto?
- [] ¿Comparé **share vs. asset deal** en **valor después de impuestos** para cada parte?
- [] ¿Evalué **contingencias fiscales** del target (due diligence fiscal) y previne protección (tax indemnity, escrow, R&W, condición de cierre)?

- [] ¿Hay **pérdidas fiscales**? ¿Verifiqué las reglas **anti-traspaso** por cambio de control?
- [] Si hay reorganización, ¿cumpló **todos** los requisitos de **neutralidad**?
- [] ¿La estructura tiene **razón de negocios real y documentable** (anti-abuso)?
- [] ¿Consideré **IVA** y otros impuestos de transmisión (asset deal, inmuebles)?
- [] Si es *cross-border*: ¿tratado aplicable, precios de transferencia, sustancia?
- [] ¿**Verifiqué** todas las tasas/artículos contra el texto vigente **y con un fiscalista**?
- [] ¿La solución es **sólida** (sobrevive una auditoría en 5 años), no solo "lista"?

42. Bibliografía comentada

⚠ *No se listan títulos ni autores concretos por no estar verificados (Principio Supremo). Se indican los tipos de fuente que debes consultar y por qué.*

- **El texto vigente de la ley** (LISR, CFE, LIVA) y la **Resolución Miscelánea Fiscal** del año en curso — la fuente primaria e indispensable; **todo lo demás se verifica contra ella**.
- **Tratados de derecho tributario mexicano** de autores reconocidos — para la dogmática (hecho imponible, capacidad contributiva, obligación tributaria). *Verificar ediciones actualizadas*.
- **Materiales de la OCDE** (Modelo de Convenio y guías de precios de transferencia; proyecto BEPS) — para la dimensión internacional.
- **Criterios del SAT, jurisprudencia del SJF y precedentes del TFJA y la SCJN** — para ver cómo se aplica en la práctica y cómo se resuelve la línea elusión/abuso.
- **Guías prácticas de M&A tax de despachos** — para el "cómo se estructura" real (con cautela: verificar vigencia).
- **Las dos sentencias fundadoras, y se leen en una tarde:** *Gregory v. Helvering* (Estados Unidos, 1935) e *IRC v. Duke of*

Westminster (Reino Unido, 1936). Son los polos del debate del §6 y siguen siendo la mejor formación conceptual disponible en esta materia. Léelas antes de cualquier manual.

- **Informes del proyecto BEPS de la OCDE.** La fuente primaria de la agenda internacional: erosión de base, traslado de utilidades, *treaty shopping* y tributación mínima. Densos, y es donde está escrito lo que va a pasar.
- **Tulio Rosembuj, *El fraude de ley y el abuso de las formas*.** Para la construcción dogmática del abuso en tradición civil: es el complemento continental de las dos sentencias anglosajonas.
- **Código Fiscal de la Federación, artículos 5o.-A (razón de negocios) y 67 (caducidad)** ☞ — texto oficial en fuentes-legales/. Los dos artículos que más veces vas a necesitar en una operación.

43. Ruta hacia el siguiente libro

Lo que acabas de aprender —que **la estructura fiscal puede valer tanto como el precio**— será indispensable para integrar todo el Nivel IV: ya dominas los **fundamentos del M&A** (Libro 1), la **due diligence** (2), las **estructuras** (3), la **documentación** (4), el **financiamiento** (5), los **contratos estratégicos y JV** (6), el **PE/VC** (7), el **gobierno corporativo/compliance** (8) y ahora la **dimensión fiscal** (9) que atraviesa a todos. Con esto, el Nivel IV te da la caja de herramientas completa del arquitecto de operaciones.

El **Nivel V · Maestría** te espera para subir un escalón: **Negociación de alto nivel**, **Finanzas y contabilidad para abogados** (que profundiza el lenguaje de los números que aquí tocaste), **Valuación de empresas** (cómo se pone precio a lo que estructuras fiscalmente) y **Estrategia corporativa y Game Theory** (cómo piensa el que mueve las piezas). El fiscal que aprendiste aquí es, en muchos sentidos, donde el Derecho y las Finanzas se encuentran — y por eso es la antesala perfecta de la Maestría.

◆ ¿Por qué esto importa para un abogado corporativo?

Porque **la estructura fiscal decide operaciones**. El abogado que solo conoce el lado societario y contractual ve la mitad del tablero; el que entiende también el fiscal **diseña** la operación y se sienta donde se decide. En M&A, financiamiento, reestructuras, empresa familiar y fondos, la pregunta "¿cómo lo estructuramos?" es, en buena parte, **fiscal**. Dominar esta intersección —rara entre abogados— te vuelve indispensable y multiplica tu valor.

◆ Cómo piensa un socio de un despacho internacional

Un socio de M&A en Galicia, Creel, Mijares, Skadden o Latham **nunca** separa lo legal de lo fiscal: arma equipos donde el corporativo y el fiscalista diseñan **juntos** la estructura **antes** de redactar nada. Piensa en *valor después de impuestos*, modela escenarios (share vs. asset, con y sin escisión previa), y exige que toda estructura tenga **razón de negocios documentada** porque sabe que la pregunta del regulador, años después, será exactamente esa. Su obsesión no es la estructura más agresiva, sino la que **crea valor y sobrevive una auditoría**. El asociado que le habla en ese lenguaje —que entiende por qué una escisión previa cambia el deal— es el que sube.

◆ Errores que cuestan millones

- **Estructurar el deal sin lo fiscal y "arreglarlo después"**: la estructura ya quedó; el impuesto evitable se convierte en costo hundido.
- **Comprar acciones sin due diligence fiscal**: heredar una contingencia que el SAT factura años después, sin indemnización que la cubra.
- **Perder la neutralidad de una reorganización** por un requisito formal incumplido: convertir una operación libre de impuesto en una gravada por millones.
- **Cruzar a la evasión** (operaciones simuladas, facturas de operaciones inexistentes): multas, recargos, delito y reputación destruida.

- **Confiar en una estructura "lista" sin razón de negocios:** la cláusula anti-abuso la recharacteriza y el ahorro se vuelve contingencia.

◆ Nivel de importancia profesional

Litigio	★★★☆☆
Corporate	★★★★★
M&A	★★★★★
Mercado de Valores	★★★★☆
Venture Capital	★★★★☆
Private Equity	★★★★★
Gobierno Corporativo	★★★☆☆
Compliance	★★★★★
Derecho Bancario	★★★☆☆
Empresa Familiar	★★★★★

Para tu perfil y tu ángulo fiscal-corporativo, este es uno de los tratados de mayor ventaja competitiva de toda la biblioteca: pocos lo dominan, casi toda operación lo necesita, y es la puerta a honorarios altos y recurrentes.

Nota final de método (Principio Supremo). Este libro enseña la **lógica** de la fiscalidad de operaciones, que perdura; **no** sustituye la consulta de la ley vigente ni la asesoría de un fiscalista. Toda tasa, artículo, criterio o estructura debe **verificarse** contra el texto vigente antes de aplicarse a un caso real. En fiscal, más que en ningún lado: *verifica, no improvises*.

Nivel IV · Libro 9 · Fiscal Corporativo y Planeación Fiscal de Operaciones. Estándar V3. Subordinado al Documento Fundacional AJE y al Protocolo de Verificación.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.

PARTE IV

[Nivel IV · Libro 10] Competencia Económica y Control de Concentraciones

⦿ **Apóstrofe de vigencia** — **léela cada vez**. El Derecho cambia sin avisar: un artículo puede mudar de número, de redacción o quedar **derogado** de un día para otro. El símbolo ⦿ que aparece tras cada artículo citado en este libro significa una sola cosa: *«¿sigue vigente —y con este mismo número— hoy? No lo cites de memoria ni desde este libro: reitéralo en su código vigente»* (textos oficiales en .../.../fuentes-legales/). Caso real: el **art. 390 del CPF** que este proyecto cotejó aparece hoy como **«Derogado»**. Recuerda: un ✓ dice que el dato fue verificado *palabra por palabra a la fecha de su fuente*; la ⦿ te avisa que esa fecha ya quedó atrás y que la última palabra la tiene el código, no el libro.

Hay un momento, en casi toda operación grande de M&A, en que el *deal* se detiene y espera: la autorización de la **autoridad de competencia**. Sin ella, la compra no puede cerrarse —y cerrar sin ella puede costar la **nulidad de la operación y multas millonarias**—. Este libro enseña el derecho que regula ese momento: la **competencia económica**, las prácticas que la ley prohíbe (cárteles, abuso de poder de mercado) y, sobre todo, el **control de concentraciones**: cuándo una fusión o adquisición debe notificarse, cómo la revisa la autoridad, qué la puede bloquear o condicionar, y por qué el abogado de M&A debe pensar en competencia **desde el primer día**.

Etiquetas: corporate law · competencia económica · anti-trust · concentraciones · merger control · COFECE · prácticas monopólicas · gun-jumping **Prerrequisitos:** Fundamentos de M&A, Estructuras: fusiones, escisiones, adquisiciones, Documentación: Term Sheet, SPA, APA, SHA, Economía para Juristas, Teoría del Estado. **Estándar:** V3 (43 secciones + secciones transversales). ⌚ **Tiempo estimado de dominio:** 5–7 semanas (≈ 50–70 h de estudio activo). Lectura de reconocimiento: 8–10 h. *Estúdialo así: por qué existe la competencia → los tres pilares (cárteles, abuso, concentraciones) → el*

control de concentraciones a fondo (la pieza de M&A) → cómo integrarlo en el deal.

⚠ **AVISO DE VERIFICACIÓN.** Los **umbrales de notificación** de concentraciones, los plazos, las multas (expresadas en UMA o porcentaje de ingresos) y los artículos de la **Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) cambian con reformas y actualizaciones**. Siguiendo el Protocolo de Verificación, este libro enseña la **lógica y la estructura** (que perdura) y **marca con ⚠ todo umbral, plazo, multa o artículo concreto como "verificar contra el texto vigente"**. **Nunca** decidas si una operación se notifica sin confirmar los umbrales vigentes con un especialista en competencia.

Aviso de método. Tratado, no repaso. Entenderás la competencia desde su **lógica económica** (proteger el proceso competitivo, no a los competidores) y su **lógica de operación** (la autorización como condición de cierre). Cada figura se conecta con el M&A: aquí, la competencia es a menudo **la condición que decide si el deal vive o muere**.

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA CRÍTICA — REFORMA 2024-2025 (LA COFECE Y EL IFT DESAPARECEN)

Contenido a fecha: 2026-07. ✓ Verificado. Este libro fue re-dactado describiendo a la **COFECE** (Comisión Federal de Competencia Económica) y al **IFT** como las autoridades. **Eso ya no es el derecho vigente.** Debes leer todo el tratado con esta corrección en mente:

- En 2024 se aprobó una **reforma constitucional de "simplificación orgánica"** que ordenó **extinguir varios órganos constitucionales autónomos**, entre ellos la **COFECE** y el **IFT**.
- En consecuencia, se reformó la **Ley Federal de Competencia Económica** (publicada en el DOF y **en vigor el 17 de julio de 2025**), que **crea la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA)** como **autoridad única** en materia de competencia, sucesora de la COFECE. Las funciones de telecom/ radiodifusión del IFT se reasignaron a la nueva arquitectura regulatoria del sector.
- A finales de 2025 se encontraba en curso la **integración del Pleno de comisionados** de la CNA.

Cómo usar este tratado con la reforma: donde leas "**COFECE**", entiende "**la autoridad de competencia (hoy la CNA)**"; la **lógica** del control de concentraciones, los umbrales, el *gun-jumping*, las prácticas monopólicas y los *remedies* **se conservan sustancialmente** —por eso el tratado sigue siendo válido en su estructura—, pero **la denominación de la autoridad, los plazos y los artículos concretos deben verificarse contra el texto vigente de la LFCE reformada y las reglas secundarias que emita la CNA.** ⚠ *No cites "COFECE" como autoridad vigente en un documento real.*

Fuentes: análisis de firmas internacionales sobre la reforma (ABA Antitrust, Hogan Lovells, Chambers, Norton Rose Fulbright), 2025. Contenido reformulado. Verificar el texto de la ley en el DOF antes de aplicarlo.

NIVEL DE IMPORTANCIA PROFESIONAL (VISTA RÁPIDA)

Litigio	★★★☆☆
Corporate	★★★★☆
M&A	★★★★★
Mercado de Valores	★★★★☆
Venture Capital	★★★☆☆
Private Equity	★★★★☆
Gobierno Corporativo	★★★☆☆
Compliance	★★★★★
Derecho Bancario	★★★☆☆
Empresa Familiar	★★★☆☆

Para tu perfil, es indispensable: ninguna operación grande de M&A se diseña ni se cierra sin pasar por el filtro de competencia. Quien lo domina anticipa el mayor riesgo regulatorio de un deal.

1. Introducción

Imagina que las dos empresas más grandes de un sector quieren fusionarse. Juntas tendrían el 80 % del mercado. ¿Deberían poder hacerlo libremente? Si la respuesta fuera "sí, es su negocio", el resultado sería un **cuasi-monopolio**: precios más altos, menos opciones y menos innovación para millones de consumidores. El **derecho de la competencia económica** existe precisamente para vigilar ese tipo de situaciones: protege el **proceso de competencia** en los mercados como un bien público.

La competencia económica (o *antitrust*, en su nombre anglosajón) regula tres grandes cosas: (1) los **acuerdos entre competidores** para no competir (los **cárteles**), prohibidos de forma tajante; (2) el **abuso** de una posición dominante por parte de una empresa poderosa; y (3) las **concentraciones** —fusiones y adquisiciones— que, al juntar empresas, podrían dañar la competencia. Esta tercera rama, el **control de concentraciones**, es la que toca directamente el M&A y el corazón de tu especialidad.

La idea rectora del libro: **el derecho de la competencia protege la competencia, no a los competidores**. No busca que ninguna empresa quiebre o gane; busca que el **proceso** —la rivalidad que disciplina precios y estimula innovación—

funcione. Esa distinción, sutil pero crucial, explica casi todas sus reglas.

2. Objetivos del libro

Al terminar, el lector será capaz de:

- Entender **por qué** existe el derecho de la competencia y qué bien jurídico protege.
- Distinguir los **tres pilares**: prácticas monopólicas **absolutas** (cárteles), **relativas** (abuso de dominancia) y **concentraciones**.
- Dominar la lógica del **control de concentraciones**: cuándo una operación debe **notificarse**, cómo se analiza, y qué puede pasar (autorización, condiciones o bloqueo).
- Reconocer el riesgo de **gun-jumping** (consumar antes de la autorización) y por qué es grave.
- Integrar la competencia en el diseño de un **deal**: como **condición de cierre**, en las declaraciones, en el calendario y en la repartición del riesgo regulatorio.
- Conocer a la autoridad mexicana de competencia (**la CNA**, sucesora de la extinta **COFECE**; ver recuadro de actualización) y la lógica del **programa de inmunidad** (delación).

3. Importancia profesional

En el M&A real, la pregunta de competencia aparece tempranísimo: "*¿esta operación se tiene que notificar? ¿la autorizarán? ¿en cuánto tiempo?*". La respuesta determina el **calendario** del deal (la autorización puede tardar meses), su **estructura**, su **precio** (¿quién carga el riesgo si la autoridad la bloquea o impone condiciones?) y hasta su **viabilidad**. Un abogado corporativo que ignora competencia puede diseñar una operación que **nunca se podrá cerrar**.

Además, la competencia es un área **de altísima especialización y prestigio**: los casos de concentraciones grandes, los cárteles y el abuso de dominancia están entre los más sofisticados y mejor pagados del derecho de los negocios, y combinan derecho, **economía** y estrategia. Para tu perfil —estructuración de operaciones complejas— es una pieza que no puede faltar.

4. Historia de la institución

El derecho de la competencia moderno nace en **Estados Unidos** a finales del siglo XIX, con la **Sherman Act (1890)**, como reacción a los grandes *trusts* (de ahí "*antitrust*") que dominaban sectores enteros (petróleo, ferrocarriles, acero). La idea era impedir que el poder económico concentrado ahogara la competencia y la libertad de mercado. [⚠](#) *Fechas y leyes de EE. UU.: verificar; aquí interesa la lógica histórica.*

Europa desarrolló su propio sistema tras la Segunda Guerra Mundial, hoy con un derecho de la competencia de la **Unión Europea** muy robusto. México tuvo antecedentes desde su Constitución (la prohibición de monopolios) pero su sistema moderno se consolidó con la **Ley Federal de Competencia Económica** y, sobre todo, con la **reforma constitucional de 2013** que creó la **COFECE** (Comisión Federal de Competencia Económica) como **órgano constitucional autónomo**, y el IFT para telecomunicaciones y radiodifusión. **Sin embargo, la reforma de "simplificación orgánica" de 2024-2025 extinguió tanto la COFECE como el IFT y creó la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) como autoridad única** (ver el recuadro de *Actualización Normativa Crítica* al inicio del libro). [⚠](#) *Verificar fechas, denominaciones y el texto vigente de la LFCE reformada.*

5. Evolución histórica

Tres movimientos marcan la evolución de esta rama:

1. **De combatir monopolios a proteger el proceso competitivo.** El enfoque pasó de "romper grandes empresas" a un análisis económico fino sobre si una conducta **daña la competencia y al consumidor**.
2. **De lo nacional a lo global.** Las operaciones de empresas multinacionales deben notificarse en **varias jurisdicciones a la vez**; las autoridades cooperan y, a veces, llegan a conclusiones distintas sobre el mismo deal.
3. **Hacia la autonomía y la tecnicidad.** En México, la creación de una autoridad **autónoma** (COFECE) con fuerte componente económico refleja la tendencia mundial a despolitizar

y tecnificar la aplicación de la competencia. Hoy el debate se centra en los **mercados digitales** y las grandes plataformas.

6. Contexto económico

La competencia es, en el fondo, **economía aplicada al derecho**. Su marco teórico viene de la microeconomía: en competencia, los precios tienden al costo y los recursos se asignan eficientemente; en monopolio, el poderoso restringe la producción y sube los precios, extrayendo renta del consumidor y generando una **pérdida de eficiencia** para la sociedad. Por eso el análisis de competencia se apoya en conceptos económicos: **mercado relevante**, **poder de mercado**, **barreras de entrada**, **concentración** (índices como el HHI). El abogado de competencia trabaja codo a codo con **economistas**: es de las áreas más interdisciplinarias del derecho.

7. Contexto político

La competencia toca intereses poderosos —las grandes empresas no quieren ser limitadas— y por eso su aplicación es **políticamente sensible**. La decisión de crear una autoridad **autónoma** (fuera del control directo del Ejecutivo) busca justamente blindar las decisiones técnicas de la presión política y de los grupos económicos. Aun así, los nombramientos, los presupuestos y las reformas a la ley son terreno de disputa política. Para el abogado: la **independencia y la tecnicidad** de la autoridad son rasgos clave de cómo y por qué decide.

8. Contexto social

Aunque suene abstracta, la competencia afecta la vida diaria de todos: precios de la comida, las telecomunicaciones, las medicinas, el transporte. Un cártel que fija precios o un monopolio que abusa **le quita dinero del bolsillo a millones de personas**, sobre todo a las de menores ingresos. Por eso la competencia tiene una dimensión de **justicia social y bienestar del consumidor** que a veces se olvida tras el tecnicismo: defender la competencia es, en gran medida, defender al público.

9. Contexto empresarial

Para una empresa, la competencia es **a la vez un riesgo y una herramienta**:

- **Como riesgo**: debe cuidar no incurrir en prácticas prohibidas (un acuerdo de precios con un competidor, aunque sea informal, puede ser un cártel sancionable), y debe **notificar** sus adquisiciones cuando superan los umbrales.
- **Como herramienta**: puede **denunciar** a competidores que abusan o cartelizan, y puede usar el **programa de inmunidad** si participó en un cártel y decide colaborar.

En M&A, la competencia es una **variable de diseño**: define el calendario, exige cláusulas específicas en el contrato (condición de cierre, *covenants* de cooperación, asignación del riesgo regulatorio) y a veces obliga a **rediseñar** la operación (vender un activo para obtener la autorización). El abogado corporativo que la entiende protege el deal desde el inicio.

10. Definiciones doctrinales

(Parafraseado; ⚠ atribuciones a autores concretos, verificar.)

- **Competencia económica**: el proceso de rivalidad entre agentes que ofrecen bienes o servicios, que los disciplina a mejorar precio, calidad e innovación para ganar al consumidor. El derecho la protege como **proceso**, no como resultado.
- **Poder de mercado (poder sustancial)**: la capacidad de una empresa para fijar precios o restringir la oferta **de forma rentable e independiente** de sus competidores y clientes. Tener poder de mercado no es ilegal; **abusar** de él, sí.
- **Mercado relevante**: el "campo de juego" donde se mide el poder y el daño; se define por el **producto** (qué bienes son sustituibles entre sí) y la **geografía** (dónde compiten). Definirlo es el primer paso —y el más disputado— de todo análisis de competencia.
- **Concentración**: cualquier operación que **une el control** de empresas antes independientes (fusión, adquisición de ac-

ciones o activos, creación de una JV con control). Es el objeto del control de concentraciones.

- **Prácticas monopólicas:** conductas prohibidas; **absolutas** (entre competidores, *per se* ilegales) y **relativas** (de quien tiene poder, ilegales solo si dañan la competencia).

11. Definiciones legales

⚠ **Verificar artículos, umbrales y plazos contra la LFCE vigente.** Lo que sigue describe **dónde** vive cada concepto, no su numeración exacta.

- La **Ley Federal de Competencia Económica (LFCE)** es la norma central: define las prácticas monopólicas absolutas y relativas, el régimen de **concentraciones** (qué se notifica, umbrales, procedimiento), las facultades de la autoridad, las sanciones y el programa de inmunidad. ⚠ *Artículos y umbrales: verificar.*
- La **Constitución** prohíbe los **monopolios** y las prácticas que los generan, y da fundamento a la autoridad autónoma. ⚠ *Artículo: verificar (tradicionalmente, el 28).*
- Las autoridades: la **COFECE** (Comisión Federal de Competencia Económica), órgano constitucional autónomo para la economía en general; y el **IFT** (Instituto Federal de Telecomunicaciones), que aplica la competencia en **telecomunicaciones y radiodifusión**. ⚠ *Verificar denominaciones y competencias vigentes.*

Idea para fijar: competencia general → **COFECE**; telecom y radiodifusión → **IFT**. Y la norma base es la **LFCE**. Con ese mapa sabes a quién acudir y dónde buscar.

12. Definición sencilla

Para explicárselo a alguien sin formación:

El derecho de la competencia es el "árbitro" del mercado. Se asegura de que las empresas compitan en serio y no hagan trampa. Tres trampas principales: 1. **Ponerse de acuerdo con tus rivales** para subir precios o repartirse el mercado (un *cártel*) — prohibidísimo. 2. **Abusar** de ser el más grande para aplastar a los demás injustamente. 3. **Fusionarse o comprar** competidores hasta quedar casi sin rivales — por eso las operaciones grandes necesitan **permiso** antes de hacerse.

El árbitro (en México, la **COFECE**) vigila las tres y puede multar, bloquear operaciones o ponerles condiciones.

13. Conceptos fundamentales

CONCEPTO	QUÉ ES
Mercado relevante	El producto + la geografía donde se mide la competencia y el daño.
Poder sustancial de mercado	Capacidad de fijar precios/restringir oferta independientemente.
Práctica monopólica absoluta	Acuerdo entre competidores (cártel): fijar precios, restringir oferta, repartir mercado, concertar posturas en licitaciones. ilegal per se .
Práctica monopólica relativa	Conducta de quien tiene poder de mercado que desplaza indebidamente a rivales o impide su acceso (ventas atadas, exclusividades abusivas, precios predatorios, etc.). Ilegal solo si daña (regla de la razón).
Concentración	Unión de control de agentes antes independientes (fusión, adquisición, JV con control).
Umbral de notificación	El tamaño (en valor de la operación, activos o ventas) a partir del cual una concentración debe notificarse antes de cerrar. $\triangle$ <i>Cifras: verificar</i> .
Notificación previa / standstill	Obligación de avisar y esperar la resolución antes de consumir la operación.
Gun-jumping	Consumar (o empezar a integrar/coordinar) antes de la autorización. Grave: multas y nulidad.
Remedios / condiciones	Compromisos que la autoridad impone para autorizar (p. ej., desinvertir un activo, dar acceso a una red).
Índice HHI	Medida de concentración de un mercado; ayuda a evaluar el efecto de una fusión.
Barreras de entrada	Obstáculos que impiden a nuevos competidores entrar; clave para evaluar poder y daño.
Programa de inmunidad (delación)	Beneficio (reducción o exención de sanción) para quien confiesa y coopera para destapar un cártel.
Eficiencias	Ahorros o mejoras que una concentración puede generar y que pueden compensar el daño a la competencia en el análisis.

14. Desarrollo absoluto

El núcleo. Construimos la forma de pensar la competencia, con foco final en el **control de concentraciones** (la pieza que toca tu M&A).

14.A · EL INSTRUMENTAL DE ANÁLISIS: MERCADO RELEVANTE Y PODER DE MERCADO

Antes de juzgar cualquier conducta o fusión, la autoridad hace **dos preguntas** que son la base de todo:

1. **¿Cuál es el mercado relevante?** Es delimitar el "campo de juego". Tiene dos dimensiones: - **Producto**: ¿qué bienes/servicios compiten realmente entre sí? La prueba clásica es la **sustituibilidad**: si sube el precio de A, ¿los clientes se van a B? Si sí, A y B están en el mismo mercado. (El célebre test del "monopolista hipotético": ¿podría subir precios de forma rentable?)
- **Geografía**: ¿dónde compiten? (una ciudad, el país, el mundo). El cemento compite localmente (pesa y es caro de transportar); el software, globalmente.
2. **¿Hay poder de mercado?** Una vez definido el mercado, se mide qué tanto poder tiene la empresa: su **participación**, las **barreras de entrada** (¿pueden entrar rivales fácilmente?), el poder de los clientes, etc.

Por qué importa tanto definir el mercado: es el paso que **decide el caso**. Un mercado definido *estrecho* hace ver a la empresa como dominante; uno *amplio*, como un competidor más. Por eso la batalla de los abogados y economistas se libra, casi siempre, en **cómo se define el mercado relevante**. Es el aje-drez técnico de la competencia.

14.B · PILAR 1 Y 2: LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS

Prácticas monopólicas ABSOLUTAS (los cárteles) — *per se* ilegales. Son acuerdos **entre competidores** para no competir. La ley las prohíbe de forma **tajante**: no admiten justificación, no importa si "funcionaron" o no. Las cuatro clásicas:

- **Fijación de precios**: acordar el precio que cobrarán.
- **Restricción de la oferta**: acordar cuánto producir o vender.
- **Reparto de mercado**: dividirse clientes, zonas o segmentos.
- **Concertación en licitaciones (*bid rigging*)**: ponerse de acuerdo en posturas para "turnarse" los contratos (típico en obra pública y compras de gobierno).

Por qué son tan graves: un cártel roba directamente al consumidor (y al Estado, en licitaciones) subiendo precios sin dar nada a cambio. Por eso se castigan con las **multas más altas** y, en muchos sistemas, con **responsabilidad penal** para los individuos. ⚠ *Sanciones concretas: verificar.* Y por eso existe el **programa de inmunidad**: el primero de los conspiradores que confiesa y coopera obtiene un beneficio enorme — una herramienta que **rompe los cárteles desde dentro** sembrando desconfianza entre ellos (teoría de juegos pura: el dilema del prisionero aplicado).

Prácticas monopólicas RELATIVAS (abuso de poder) — regla de la razón. Son conductas de una empresa **con poder de mercado** que **desplazan indebidamente** a competidores o les cierran el acceso. A diferencia de los cárteles, **no son ilegales en sí mismas**: lo son solo si (i) quien las hace tiene poder sustancial y (ii) **dañan** la competencia sin una eficiencia que lo justifique. Ejemplos: **ventas atadas** (te vendo A solo si compras B), **exclusividades** abusivas, **precios predatorios** (vender bajo costo para quebrar al rival y luego subir), **negativa de trato** o **discriminación** para excluir. El análisis es **caso por caso** (regla de la razón): se pesa el daño contra la eficiencia.

La distinción que debes dominar: *cárteles = entre competidores = ilegales siempre (per se); abuso = de un dominante = ilegal solo si daña (regla de la razón).* Confundirlas es el error conceptual #1 en esta materia.

14.C · PILAR 3: EL CONTROL DE CONCENTRACIONES (LA PIEZA DE TU M&A)

Aquí es donde la competencia y tu especialidad se tocan directamente. Una **concentración** es una operación que une el control de empresas antes independientes —exactamente lo que hace una M&A—. El Estado no las prohíbe (la mayoría son benéficas), pero **vigila las grandes** para que no creen o refuercen un poder de mercado dañino. La mecánica, paso a paso:

1. ¿Hay que notificar? (los umbrales). No toda compra se notifica: solo las que **superan ciertos umbrales** de tamaño (medidos en el valor de la operación, en los activos/ventas de las partes, o en porcentajes de participación accionaria). Si la

operación los rebasa, la notificación es **obligatoria y previa al cierre**. $\triangle$ *Los umbrales exactos (expresados en UMA) cambian: verificar los vigentes — este es el dato que más se actualiza.*

2. La regla de oro: notificar y ESPERAR (standstill). *Si la operación se debe notificar, las partes no pueden consumarla hasta obtener la resolución favorable. Pueden firmar el contrato, pero el cierre queda condicionado* a la autorización. Cerrar antes es gun-jumping***.*

3. El análisis de la autoridad. Recibida la notificación, la autoridad (COFECE o IFT) analiza si la operación **dañaría la competencia**: define el mercado relevante, mide la concentración resultante (participaciones, HHI), evalúa barreras de entrada, el poder de los clientes y las posibles **eficiencias** que la operación genere. La pregunta central: *¿esta unión creará o reforzará un poder de mercado capaz de dañar el proceso competitivo y al consumidor?*

4. Los tres desenlaces posibles.

- **Autorización lisa y llana:** la mayoría; la operación no preocupa.
- **Autorización condicionada (con remedios):** se autoriza si las partes cumplen condiciones —las más típicas, **desinvertir** (vender) un activo, una marca o una línea de negocio para preservar la competencia; o remedios de conducta (dar acceso a una red, no discriminar)—.
- **Bloqueo (objeción):** se niega la autorización porque el daño es grave e irremediable. Mata el deal.

5. Los plazos. El análisis tiene plazos legales que pueden ir de semanas a **varios meses** según la complejidad (hay un procedimiento simplificado para casos claros y uno ordinario para los complejos). $\triangle$ *Plazos concretos: verificar.* Esto es crítico para el **calendario** del deal.

Errores que cuestan millones — *gun-jumping*: consumir la operación (o empezar a integrar las empresas, intercambiar información sensible o coordinar precios) **antes** de la autorización. Las consecuencias: **multas severas, nulidad de la operación** y, a veces, tener que **deshacer** todo (*divestiture*). El abogado de M&A debe blindar el *gun-jumping*: hasta el cierre autorizado, las empresas **siguen siendo independientes y compiten** — nada de "ya somos uno".

14.D · CÓMO SE INTEGRA LA COMPETENCIA EN EL DISEÑO DEL DEAL

Para el abogado corporativo, la competencia se traduce en cláusulas y decisiones concretas (conecta con el Libro 4 y el Laboratorio):

- **Condición de cierre (*condition precedent*):** "el cierre está sujeto a obtener la autorización de competencia". Es la forma de respetar el *standstill*.
- **Reparto del riesgo regulatorio:** ¿qué pasa si la autoridad **condiciona** o **bloquea**? Se negocia: cláusulas de "**esfuerzos**" (*best efforts* o *hell-or-high-water*, donde el comprador se obliga a desinvertir lo que sea para lograr la autorización?), *break-up fee* regulatorio (quién paga si se cae por competencia), y plazos máximos (*long-stop date*) para obtenerla.
- **Covenants de cooperación:** ambas partes se obligan a presentar la notificación, aportar información y cooperar para obtener la autorización.
- **Covenants anti-gun-jumping:** hasta el cierre, prohibición de integrar, compartir información competitivamente sensible o coordinar conductas.
- **Calendario realista:** el *deal* debe contemplar los **meses** que puede tardar la autorización.

Cómo piensa un socio de M&A: la pregunta de competencia se hace **el día uno**: "*¿esto se notifica? ¿hay riesgo de condiciones o bloqueo? ¿quién carga ese riesgo?*". De la respuesta dependen el calendario, el precio y hasta si vale la pena intentar el deal. Un comprador que necesita certeza exigirá que el vendedor cargue el riesgo regulatorio; un vendedor fuerte lo trasladará al comprador. Esa negociación —invisible para el novato— puede valer tanto como el precio.

15. Explicación intuitiva (el modelo mental)

Piensa en la competencia como **un partido con árbitro**. El objetivo del árbitro no es que gane tal o cual equipo, sino que **el partido sea limpio**: que nadie amañe el marcador. Tres intuiciones:

1. **Amañar el partido entre rivales (cártel) es la falta más grave.** Si los dos equipos acuerdan el resultado, el público (consumidor) paga la entrada por un espectáculo falso. Tarjeta roja directa, sin discusión (*per se*).
2. **Ser el mejor no es falta; hacer trampa siendo el mejor, sí (abuso).** Que un equipo domine porque juega mejor está bien. Lo que no se vale es usar su fuerza para **lesionar** al rival o impedirle jugar. Aquí el árbitro **sí evalúa la jugada** (regla de la razón).
3. **Fusionar dos equipos requiere permiso (concentraciones).** Si los dos mejores equipos se unen, quizá ya no haya partido. Por eso, antes de fusionarse, deben pedir permiso al árbitro, que decide si la liga sigue siendo competitiva, si pone condiciones, o si lo prohíbe.

La intuición que ordena el M&A: *firmar puedes; consumir (integrarte) no, hasta que el árbitro autorice.* Adelantarte (gun-jumping) es entrar a la cancha antes del silbatazo: falta grave.

16. Ejemplos simples

- **Cártel:** dos panaderías de un pueblo acuerdan no vender el pan a menos de cierto precio. Aunque sea un "acuerdo de caballeros", es una **práctica monopólica absoluta**: ilegal *per se*.
- **Abuso:** la única cementera de una región vende cemento bajo costo solo en la zona donde entró un competidor nuevo, para quebrarlo, y mantiene precios altos en el resto. Posible **precio predatorio** (práctica relativa): ilegal **si** tiene poder y daña.
- **Concentración:** las dos mayores cadenas de farmacias del país quieren fusionarse. Como superan los umbrales, **deben**

notificar y esperar; la autoridad evaluará si juntas tendrían un poder dañino.

17. Ejemplos complejos (multi-variable)

Fusión con remedio (desinversión). Dos empresas de bebidas se fusionan. En el país en general no hay problema, pero en **una región** y en **un tipo de bebida** (un mercado relevante estrecho) juntas tendrían el 75 %. La autoridad **autoriza condicionado** a que **vendan** una de sus marcas en esa región a un tercero, restaurando la competencia. El abogado de M&A debió **anticipar** este remedio y negociar en el SPA quién carga el costo de la desinversión.

Gun-jumping accidental. Entre la firma y la autorización (tres meses), el comprador empieza a "ayudar" a operar el target, fija conjuntamente precios y comparte listas de clientes. Aunque la operación luego se autorice, **ya hubo gun-jumping**: las dos empresas, que debían seguir compitiendo, se coordinaron. Resultado: multa. *Lección:* hasta el cierre autorizado, **se vive como independientes**.

Mercado relevante decide el caso. En una adquisición tecnológica, todo depende de si el mercado se define como "una app específica" (las partes serían dominantes) o como "todas las formas de hacer esa tarea" (serían un jugador más). La batalla técnica está en esa definición.

18. Casos reales (estilizados)

⚠ *No se citan expedientes ni nombres por no estar verificados (Principio Supremo). Patrones reconocibles; verificar resoluciones concretas de COFECE/IFT y tribunales.*

- **Cárteles en licitaciones públicas:** patrón clásico —empresas que se "turnan" contratos de gobierno concertando posturas—, de los más perseguidos y sancionados.
- **Concentraciones condicionadas con desinversión:** patrón frecuente en sectores concentrados (bebidas, telecom, farmacéutico, aerolíneas), donde la autoridad autoriza a cambio de vender activos.

- **Abuso en sectores en red** (telecom, energía): el incumbente dificulta el acceso de competidores a una infraestructura esencial. ⚠ *Verificar casos vigentes.*

Tres operaciones que enseñan cómo opera de verdad esta materia.

US v. Microsoft (2001) fijó el marco del **abuso de posición dominante en tecnología**: el problema no era el tamaño, sino la conducta de aprovechar el dominio en un mercado para cerrar otro. Es el antecedente conceptual de todos los casos digitales posteriores.

Microsoft–Activision (2023) mostró quién es hoy el verdadero *gatekeeper* de las megafusiones: la autoridad de competencia, y no una sola —el proceso incluyó un bloqueo inicial de la **CMA británica** antes de resolverse con compromisos ⚠—. Para un abogado mexicano la lección es de calendario: en una operación multijurisdiccional, **el cronograma lo dicta la autoridad más lenta y más exigente**, no la propia.

Grupo Modelo–AB InBev exigió la **desinversión del negocio de Corona en Estados Unidos** como condición. Es el mismo caso que aparece en el Libro 3 y por la misma razón: **la autoridad de competencia puede rediseñar la estructura de la operación.**

Cómo se traduce esto a tu trabajo, en tres reglas.

1 • El análisis antimonopolio va antes de firmar, no después. Si el riesgo aparece cuando el precio ya se acordó, el vendedor no va a querer absorber el costo de los *remedies*.

2 • Se llega a la mesa con los *remedies* ya decididos: qué se está dispuesto a desinvertir y qué no. Negociar eso improvisando frente a la autoridad es negociar desde la debilidad.

3 • Y no se toca la empresa objetivo antes de la autorización. Coordinar precios, integrar equipos comerciales o compartir información sensible antes de la luz verde es ***gun jumping***, se sanciona, y es uno de los errores más caros y más evitables de esta práctica. El closing checklist existe, en parte, para prevenirlo.

19. Casos empresariales (en la vida de una compañía)

- **Programa de *compliance* de competencia:** una empresa capacita a su personal para **no** caer en acuerdos prohibidos (ni siquiera informales con competidores en una cámara industrial) y para manejar reuniones de asociación con cuidado. Conecta con el Libro 8 (Compliance).
- **Decisión de notificar:** ante una adquisición, la empresa evalúa con sus abogados si supera umbrales; un error de cálculo aquí (no notificar lo que debía) es gun-jumping.
- **Uso ofensivo:** denunciar ante la COFECE a un competidor que abusa o a un proveedor que cartcliza, como estrategia legítima de negocio.

20. Casos corporativos (en transacciones)

- **El *antitrust* en el SPA:** condición de cierre de autorización, *covenants* de cooperación y anti-gun-jumping, asignación del riesgo regulatorio (*efforts* clauses, break-up fee, long-stop date). Es donde este libro y el Libro 4 se encuentran.
- **Estructurar para evitar/facilitar la notificación:** a veces la estructura o el calendario se ajustan a la realidad regulatoria (sin caer en simulaciones para evadir el control, lo cual es sancionable).
- **Due diligence de competencia:** revisar si el target tiene riesgos de competencia (¿participó en algún cártel? ¿tiene prácticas dudosas?) que el comprador heredaría. Conecta con el Libro 2 y el Laboratorio (DD).

21. Casos internacionales (*cross-border*)

- **Notificación multi-jurisdiccional:** una fusión global puede requerir autorización en **México, EE. UU., la UE y más** a la vez. Cada autoridad analiza su mercado; el deal no cierra hasta tener **todas** las autorizaciones necesarias. Coordinar esto es un arte (y un costo) del M&A internacional.
- **Decisiones divergentes:** distintas autoridades pueden llegar a conclusiones distintas o imponer remedios diferentes sobre la misma operación.

- **Cooperación entre agencias:** las autoridades intercambian información y, en cárteles globales, coordinan investigaciones. El programa de inmunidad en una jurisdicción interactúa con las demás.

22. Derecho comparado

⚠ *Cada régimen concreto debe verificarse en la legislación vigente del país.*

JURISDICCIÓN	RASGOS DISTINTIVOS
México	LFCE; autoridades autónomas COFECE (general) e IFT (telecom/radiodifusión); control de concentraciones por umbrales; prácticas absolutas (per se) y relativas (regla de la razón); programa de inmunidad.
EE. UU.	Cuna del <i>antitrust</i> : Sherman Act , Clayton Act , FTC Act ; aplicación por el DOJ y la FTC ; notificación de fusiones Hart-Scott-Rodino (HSR) ; fuerte componente penal en cárteles.
Unión Europea	De los regímenes más robustos: arts. 101 (acuerdos) y 102 (abuso) del TFUE; control de concentraciones por la Comisión Europea ; multas que llegan a % de la facturación mundial.
España	CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia); régimen alineado con la UE.
Delaware	No aplica aquí: la competencia es federal en EE. UU.; Delaware es derecho societario, no antitrust. (Evita confundir.)
Common law vs. Civil law	Convergen en el método económico (mercado relevante, poder de mercado) y en la distinción cártel/abuso/concentración; las diferencias son de procedimiento y de intensidad sancionatoria.

Lección para el M&A cross-border: los conceptos son universales, pero **cada jurisdicción tiene su propio umbral y su propia autoridad**. Una operación global se notifica donde toque, y no cierra hasta tener todas las autorizaciones.

23. Derecho mexicano (régimen positivo)

⚠ **Mapa conceptual; verificar artículos, umbrales y plazos vigentes.**

- **Constitución:** prohíbe los **monopolios** y las prácticas monopolísticas; manda proteger la competencia y da base a la

autoridad autónoma. ⚠ *Artículo (tradicionalmente 28): verificar.*

- **Ley Federal de Competencia Económica (LFCE):** define prácticas absolutas y relativas; regula las **concentraciones** (umbrales, notificación previa, procedimiento, plazos); las facultades de investigación y sanción; el **programa de inmunidad**; los recursos. ⚠ *Artículos/umbrales: verificar.*
- **Autoridades:** COFECE (economía en general) e IFT (telecom y radiodifusión), ambos órganos constitucionales autónomos. Sus resoluciones se impugnan ante **juzgados y tribunales especializados en competencia** (vía amparo indirecto, con reglas especiales). ⚠ *Verificar.*
- **Disposiciones regulatorias** de la propia COFECE/IFT (criterios técnicos, guías de concentraciones): el detalle operativo. ⚠ *Verificar las vigentes.*

24. Jurisprudencia relevante

⚠ *No se citan rubros ni números por no estar verificados (Principio Supremo). Localizar en el SJF y en las resoluciones de COFECE/IFT.*

Líneas que el estudiante debe saber que existen (y verificar):

- Criterios sobre la **definición del mercado relevante** y la medición del **poder sustancial**.
- Criterios sobre la **naturaleza per se** de las prácticas absolutas (no admiten justificación).
- Criterios sobre el **debido proceso** en las investigaciones de competencia y el alcance del amparo.
- Criterios sobre **concentraciones** y los requisitos de las condiciones/remedios.

25. Criterios de la Suprema Corte

La SCJN y los tribunales especializados han delineado el marco constitucional de la competencia: el alcance de la prohibición de monopolios, las garantías de **debido proceso** frente a las amplias facultades de la autoridad, y el equilibrio entre la **autonomía técnica** de la COFECE/IFT y el control

judicial. *△ Tesis concretas: verificar en el SJF.* Para el abogado, lo relevante: las resoluciones de competencia **se pueden impugnar**, y el cómo (amparo especializado) es en sí una subespecialidad.

26. Doctrina nacional

México ha desarrollado doctrina de competencia sobre todo a partir de la creación de la autoridad moderna; dialoga estrechamente con la doctrina económica y comparada. *△ Autores y obras concretas: verificar antes de citar.* Lo esencial: la doctrina mexicana ha asimilado el **método económico** (mercado relevante, poder de mercado, análisis de efectos) propio de esta rama.

27. Doctrina internacional

La doctrina dominante es de raíz **estadounidense y europea**, profundamente **económica**: las escuelas de pensamiento (Harvard, Chicago, post-Chicago) debaten cuánta intervención es óptima; la UE aporta una tradición de fuerte aplicación, sobre todo en abuso de dominancia y concentraciones. Hoy el debate global se concentra en los **mercados digitales** (plataformas, datos, efectos de red) y en si las herramientas clásicas bastan para ellos. *△ Autores y documentos concretos: verificar.*

28. Opiniones críticas (postura del Consejo)

- **La competencia es una variable de diseño del deal, no un trámite final.** Pensarla desde el día uno separa al abogado de M&A completo del que solo redacta.
- **El *gun-jumping* es un riesgo subestimado.** La presión por "avanzar" entre firma y cierre lleva a integraciones prematuras que cuestan multas y credibilidad. Disciplina: hasta el cierre autorizado, **independientes**.
- **El futuro es digital y el derecho va detrás.** Los mercados de plataformas y datos retan al análisis clásico; quien domine esa frontera tendrá una ventaja enorme en la próxima década.

29. Debate doctrinal (controversias vivas)

- **¿Bienestar del consumidor vs. estructura del mercado?** ¿La competencia debe proteger solo precios bajos al consumidor, o también la estructura competitiva (evitar concentración excesiva aunque baje precios a corto plazo)? Debate central y reabierto por las grandes tecnológicas.
- **¿Cuánta intervención en concentraciones?** El equilibrio entre permitir fusiones eficientes y evitar poder dañino; el peso que se da a las **eficiencias** alegadas.
- **Mercados digitales:** ¿bastan las herramientas clásicas para plataformas con efectos de red y poder basado en datos, o hacen falta reglas nuevas? ⚠ *Estado vigente: verificar.*

EL DEBATE MÁS VIVO DEL DERECHO CORPORATIVO ACTUAL, CON SUS DOS ESCUELAS

Esta materia tiene la peculiaridad de que su **pregunta fundacional está abierta hoy**, y no en un seminario: en las decisiones que se toman sobre las mayores empresas del mundo. Conviene poder nombrar a las dos escuelas, porque tu forma de argumentar un caso depende de cuál te resulte más persuasiva.

La Escuela de Chicago (Robert Bork, *The Antitrust Paradox*, 1978). Su tesis: el **único** fin legítimo del derecho de competencia es el **bienestar del consumidor**, y se mide fundamentalmente en **precios**. De ahí se sigue que la mayoría de las concentraciones son eficientes, que el gran tamaño no es por sí mismo un problema, y que **intervenir de más daña más que intervenir de menos**. Esta escuela ganó y reorganizó el antitrust mundial durante cuatro décadas —incluido el mexicano—.

La corriente neo-brandeisiana (Lina Khan, *Amazon's Antitrust Paradox*, 2017). Su objeción es específica y potente: el criterio de precios es **ciego frente a las plataformas digitales**, porque estas suelen **bajar** los precios al consumidor mientras acumulan control estructural sobre mercados, datos y canales adyacentes. Si el termómetro es el precio, el termómetro

no detecta el poder. Propone volver a mirar **estructura y poder**, no solo resultado en precio.

Las críticas cruzadas, que son igual de instructivas:

- A Chicago se le reprocha haber sido capturada por una ideología pro-fusión que permitió una ola de concentración. **Thomas Philippon**, en *The Great Reversal*, documenta que Estados Unidos dejó de ser el mercado más competitivo del mundo $\triangle$ — un argumento empírico incómodo para la escuela dominante.
- A los neo-brandeisianos se les reprocha **inseguridad jurídica**: si el criterio deja de ser el precio, ¿cuál es? Sin un estándar medible, el análisis se vuelve discrecional y el resultado, imprevisible.

La postura del Consejo, y es de método más que de ideología. Lo que un abogado necesita no es afiliarse: es saber **con qué vara lo van a medir en su jurisdicción y en su caso**. México sigue el modelo del bienestar del consumidor (LFCE ☺); la Unión Europea, más atenta a la estructura, va por delante en mercados digitales. Un abogado que solo conoce una escuela argumenta la mitad de los casos.

Y hay una razón histórica para no despachar la discusión como técnica: la **Sherman Act** (1890) nació contra los *trusts* de **Rockefeller** y **Carnegie** por motivos económicos y políticos —la idea de que el poder económico concentrado amenaza a la democracia—. Esa dimensión política, que Chicago dejó fuera por razones de rigor analítico, es exactamente la que los neo-brandeisianos volvieron a poner sobre la mesa. El péndulo no es una moda: es un debate de un siglo que vuelve a estar abierto.

30. Errores comunes

ERROR	POR QUÉ ES UN ERROR
No analizar competencia hasta el final del deal	Puedes diseñar una operación que nunca se podrá cerrar
Calcular mal los umbrales y no notificar lo que debía	Gun-jumping: multas y nulidad
Consumar o integrar antes de la autorización	Gun-jumping aunque la operación sea benéfica
Compartir información sensible entre las partes antes del cierre	Coordinación prohibida; riesgo de cártel y gun-jumping
Confundir cártel (per se) con abuso (regla de la razón)	Error conceptual base; cambia todo el análisis
Creer que "ser dominante" es ilegal	No lo es; solo lo es abusar del poder
Definir el mercado relevante a la ligera	Es el paso que decide el caso
Ignorar el riesgo regulatorio en el SPA	Nadie sabe quién paga si la autoridad bloquea/condiciona

31. Mitos frecuentes

- **"Si es mi empresa, vendo y compro a quien quiera sin pedir permiso."** Falso: las operaciones grandes requieren **autorización previa** de competencia.
- **"Ser el más grande es ilegal."** Falso: es legal; lo ilegal es **abusar** de esa posición.
- **"Un acuerdo de palabra con un competidor no cuenta."** Falso: un cártel **no necesita estar por escrito**; un acuerdo informal o tácito puede sancionarse.
- **"Si la fusión es buena para nosotros, la autoridad la aprobará rápido."** Falso: el análisis mira el **mercado y al consumidor**, no la conveniencia de las partes, y puede tardar meses.
- **"La competencia es solo teoría económica."** Falso: es derecho aplicado con consecuencias muy concretas (multas, nulidad, cárcel en cárteles).

32. Preguntas difíciles (para pensar como experto)

1. ¿Cómo defines el mercado relevante de un producto digital "gratis" (sin precio)? ¿Compite por dinero, por atención, por datos?
2. ¿Cuándo una eficiencia alegada es suficiente para autorizar una concentración que, de otro modo, dañaría la competencia?
3. ¿Dónde termina la cooperación legítima de planeación del cierre y empieza el gun-jumping?
4. ¿Quién debe cargar el riesgo regulatorio en un SPA: comprador o vendedor? ¿Cómo se negocia?
5. ¿Bastan las herramientas clásicas para las grandes plataformas, o se necesita un nuevo enfoque?

33. Casos de examen (con respuesta modelo)

Caso A. *Dos competidores acuerdan en una cámara industrial "no bajar precios". ¿Qué es?*

Respuesta modelo: una **práctica monopólica absoluta** (fijación de precios entre competidores), **ilegal per se** — no importa que sea informal ni que se justifique. Sancionable con las multas más altas y posible responsabilidad penal individual. ⚠️
Sanciones: verificar.

Caso B. *Una empresa firma la compra de un competidor que supera los umbrales y empieza a operarlo de inmediato, antes de notificar. Analiza.*

Respuesta modelo: gun-jumping: debió notificar y **esperar** la autorización (standstill). Consecuencias: multa y posible nulidad. Debió poner la autorización como **condición de cierre** y mantener las empresas independientes hasta entonces.

Caso C. *La COFECE autoriza una fusión "condicionada a desinvertir una marca". ¿Por qué?*

Respuesta modelo: porque en un **mercado relevante** específico la unión crearía poder dañino; el **remedio de desinversión** restaura la competencia y permite autorizar sin bloquear todo el deal.

34. Simulador (ejercicio tipo despacho)

Rol: asociado de M&A. **Ciente:** "Compradora" quiere adquirir a un competidor relevante en su sector. La socia te pide un **memo preliminar de competencia**.

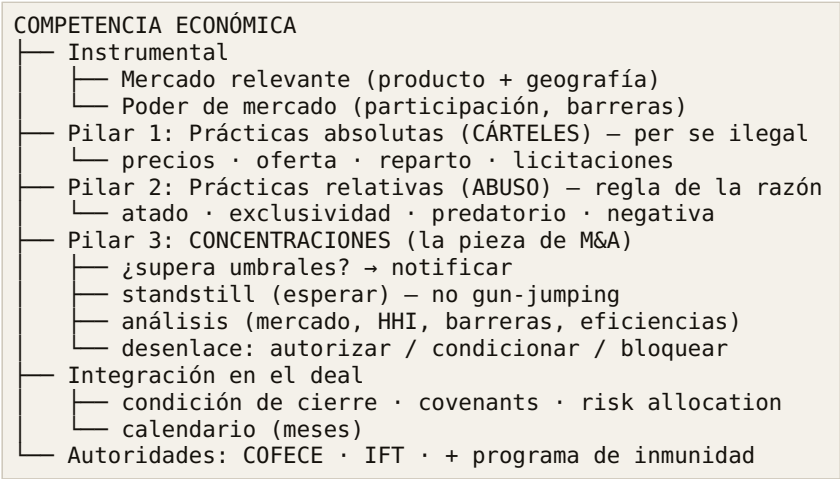
Tu tarea: (1) ¿la operación **supera umbrales** y debe notificarse? (marca que debes verificar los umbrales vigentes); (2) ¿hay **riesgo** de condiciones o bloqueo? (esboza el análisis de mercado relevante y participaciones); (3) propón las **cláusulas del SPA**: condición de cierre de autorización, covenants de cooperación y anti-gun-jumping, asignación del riesgo regulatorio (*¿best efforts o hell-or-high-water?*, break-up fee, long-stop date); (4) advierte del **gun-jumping** y el calendario realista. Usa el formato de memo del Laboratorio (Ej. 01).

Se evalúa que identifiques el riesgo regulatorio, lo traduzcas en cláusulas y marques lo que debes verificar.

35. Flashcards (recuperación activa)

- ¿Qué protege la competencia? → El **proceso competitivo** (no a los competidores).
- ¿Cártel vs. abuso? → Cártel = entre competidores, **per se** ilegal; abuso = de un dominante, ilegal **solo si daña**.
- ¿Las 4 prácticas absolutas? → Fijar precios, restringir oferta, repartir mercado, concertar licitaciones.
- ¿Qué es una concentración? → Unión de **control** de empresas antes independientes.
- ¿Regla de oro de las concentraciones? → **Notificar y esperar** (standstill) si superan umbrales.
- ¿Gun-jumping? → Consumar/integrar **antes** de la autorización. Grave.
- ¿Los 3 desenlaces de una concentración? → Autorizar, **condicionar** (remedios/desinversión), **bloquear**.
- ¿Autoridades en México? → **COFECE** (general) e **IFT** (telecom/radiodifusión).
- ¿Programa de inmunidad? → Beneficio para quien **delata** y coopera en un cártel.
- ¿Primer paso de todo análisis? → Definir el **mercado relevante**.

36. Mapa mental (estructura jerárquica)



37. Cuadros comparativos

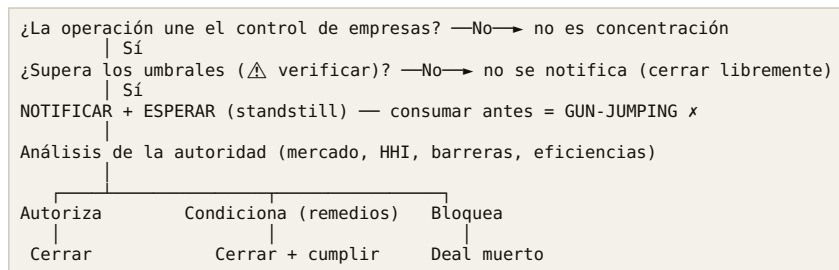
Absolutas vs. relativas:

	PRÁCTICAS ABSOLUTAS (CÁRTEL)	PRÁCTICAS RELATIVAS (ABUSO)
Entre quién	Competidores	Empresa con poder de merca- do
Legalidad	Per se ilegal	Ilegal solo si daña (regla de la razón)
Justifica- ción	No admite	Admite (eficiencias)
Sanción	La más alta + posible penal	Alta

Los 3 desenlaces de una concentración:

DESENLACE	CUÁNDO	EFFECTO EN EL DEAL
Autorización	No hay daño	Sigue adelante
Condiciona- da	Daño remediable	Sigue, con desinversión/conduc- tas
Bloqueo	Daño grave irremedia- ble	Mata el deal

38. Diagramas (flujo de una concentración)



39. Mnemotecnias

- **"FROL": las 4 prácticas absolutas** — Fijar precios, Restringir oferta, Organizar (repartir) mercado, Licitaciones concertadas.
- **"Notifica y Espera"** — la regla de oro de las concentraciones (lo contrario es gun-jumping).
- **"Per se el cártel; razón el abuso"** — para no confundir los dos pilares.
- **"COFECE todo; IFT telecom"** — quién es la autoridad.
- **"Hasta el silbatazo, rivales"** — no integrarse antes de la autorización.

40. Resumen ejecutivo

- El derecho de la competencia protege el **proceso competitivo** (no a los competidores) como bien público, porque la competencia disciplina precios y estimula innovación en beneficio del consumidor.
- Tiene **tres pilares**: prácticas monopólicas **absolutas** (cárteles entre competidores — *per se* ilegales), **relativas** (abuso de poder de mercado — ilegales solo si dañan) y **concentraciones** (control de fusiones y adquisiciones).
- El **control de concentraciones** es la pieza que toca el M&A: las operaciones que **superan umbrales** deben **notificarse y esperar** la autorización (standstill); consumir antes es **gun-jumping** (multas, nulidad). La autoridad puede **autorizar, condicionar (desinversión) o bloquear**.

- En el *deal*, la competencia se traduce en **condición de cierre**, *covenants* de cooperación y anti-gun-jumping, **asignación del riesgo regulatorio** y un **calendario** que contempla meses.
- Autoridades en México: **COFECE** (general) e **IFT** (telecom/radiodifusión); base normativa: la **LFCE**; herramienta clave contra cárteles: el **programa de inmunidad**.
- Todo análisis empieza por **definir el mercado relevante**; los umbrales, plazos y multas **cambian** y deben **verificarse**.

41. Checklist (operativo del profesional)

Ante una operación con dimensión de competencia:

- [] ¿La operación une **control** (es una concentración)?
- [] ¿**Supera los umbrales** vigentes? ($\triangle$ verificar las cifras actuales)
- [] Si sí: ¿puse la **autorización como condición de cierre** y aseguré el **standstill**?
- [] ¿Identifiqué el **mercado relevante** y el **riesgo** de condiciones/bloqueo?
- [] ¿Negocié la **asignación del riesgo regulatorio** (efforts, break-up fee, long-stop date)?
- [] ¿Incluí *covenants* de **cooperación** y **anti-gun-jumping**?
- [] ¿El **calendario** del deal contempla los meses del análisis?
- [] ¿Hice **due diligence de competencia** del target (cárteles, prácticas)?
- [] Si es *cross-border*: ¿en **qué jurisdicciones** hay que notificar?
- [] ¿**Verifiqué** umbrales, plazos y multas con un especialista y la ley vigente?

42. Bibliografía comentada

$\triangle$ *Tipos de fuente (no títulos concretos, por no estar verificados — Principio Supremo).*

- **El texto vigente de la LFCE** y las **disposiciones regulatorias / guías de concentraciones** de la COFECE/IFT — la fuente primaria; los **umbrales vigentes** viven aquí.

- **Resoluciones de la COFECE y el IFT** — para ver cómo se aplica en la práctica (cómo definen mercado, qué remedios imponen).
- **Doctrina y guías internacionales** (EE. UU. — DOJ/FTC *Merger Guidelines*; UE — Comisión Europea) — para el método económico y comparado.
- **Manuales de derecho de la competencia** (mexicanos y comparados) — para la dogmática. *Verificar ediciones actualizadas*.
- **Guías de M&A antitrust de despachos** — para el "cómo se maneja en el deal" (con cautela: verificar vigencia).
- **Los dos textos del debate, y hay que leer los dos:** Robert Bork, *The Antitrust Paradox* (1978), y Lina Khan, *Amazon's Antitrust Paradox* (*Yale Law Journal*, 2017). El segundo se lee en una sesión y es probablemente el artículo jurídico más influyente de la última década.
- **Thomas Philippon, *The Great Reversal* (2019).** La evidencia empírica sobre la concentración de los mercados estadounidenses. Es el contrapeso de datos al argumento teórico de Chicago.
- **Whish & Bailey, *Competition Law*.** El manual de referencia en inglés, con el aparato europeo completo (arts. 101 y 102 TFUE, Reglamento de Concentraciones). Si vas a hacer operaciones con dimensión europea, es la obra.
- **Jurisprudencia y decisiones:** *US v. Microsoft* (2001) para abuso de dominancia en tecnología, y los expedientes públicos de Microsoft–Activision y Grupo Modelo–AB InBev para ver cómo se negocian los *remedies* con la autoridad.

43. Ruta hacia el siguiente libro

Con este libro cierras el panorama regulatorio del M&A: ya sabes **estructurar** (Libros 1-4), **financiar** (5), **colaborar** (6), **invertir como fondo** (7), **gobernar y cumplir** (8), **estructurar fiscalmente** (9) y ahora **pasar el filtro de competencia** (10). El Nivel IV te da el ciclo completo de la operación corporativa,

desde su lógica hasta sus dos grandes filtros regulatorios —el fiscal y el de competencia—.

El **Nivel V • Maestría** te llevará al plano del estratega: **Negociación de alto nivel** (clave para negociar el riesgo regulatorio y los remedios), **Finanzas y contabilidad**, **Valuación** (cómo el riesgo de competencia afecta el precio) y **Estrategia corporativa y Game Theory** (el programa de inmunidad es teoría de juegos pura; las defensas y los movimientos de concentración, ajedrez empresarial). Lo aprendido aquí es la antesala perfecta de ese pensamiento estratégico.

◆ ¿Por qué esto importa para un abogado corporativo?

Porque **la autorización de competencia puede decidir si un deal vive o muere** — y su análisis define el calendario, el precio y la estructura. El abogado de M&A que piensa la competencia desde el primer día protege la operación; el que la ignora puede diseñar algo que **nunca se cerrará** o exponer a su cliente a un gun-jumping millonario. Es, junto con el fiscal, uno de los dos grandes filtros regulatorios que todo arquitecto de operaciones debe dominar.

◆ Cómo piensa un socio de un despacho internacional

Un socio de M&A trata la competencia como un **flujo de trabajo paralelo y crítico** desde el inicio: arma equipo con los especialistas de competencia (y economistas), evalúa **el día uno** si la operación se notifica y en qué jurisdicciones, modela el riesgo de remedios, y **negocia en el SPA quién carga ese riesgo** (un comprador que quiere certeza exigirá cláusulas *hell-or-high-water*; uno cauto, lo contrario). Vigila como halcón el **gun-jumping** —sabe que la presión por "avanzar" entre firma y cierre es el mayor riesgo— y construye el calendario alrededor de los plazos de la autoridad. Para él, la competencia no es un obstáculo: es una variable que se gestiona con estrategia.

◆ Errores que cuestan millones

- **No notificar una concentración que debía notificarse:** gun-jumping, multas y nulidad.

- **Integrar las empresas antes de la autorización** (operar, compartir información, coordinar precios): gun-jumping aunque el deal sea benéfico.
- **No anticipar un remedio de desinversión:** descubrir tarde que para cerrar hay que vender un activo valioso, sin haber negociado quién carga ese costo.
- **Calendario irreal:** prometer un cierre en semanas cuando la autorización tarda meses.
- **Un cártel "informal":** acordar precios con un competidor en una cámara — multas máximas y posible cárcel.

◆ Nivel de importancia profesional

Litigio	★★★☆☆
Corporate	★★★★☆
M&A	★★★★★
Mercado de Valores	★★★★☆
Venture Capital	★★☆☆☆
Private Equity	★★★★☆
Gobierno Corporativo	★★★★☆
Compliance	★★★★★
Derecho Bancario	★★★☆☆
Empresa Familiar	★★☆☆☆

Indispensable para tu especialidad: con el fiscal (Libro 9), es uno de los dos filtros regulatorios sin los cuales ninguna operación grande se diseña ni se cierra.

Nota final de método (Principio Supremo). Este libro enseña la **lógica** de la competencia, que perdura; **no** sustituye la consulta de la LFCE vigente, las guías de COFECE/IFT ni la asesoría de un especialista. **Umbrales, plazos y multas cambian: verificalos siempre** antes de decidir si una operación se notifica o cómo se maneja.

Nivel IV · Libro 10 · Competencia Económica y Control de Concentraciones. Estándar V3. Subordinado al Documento Fundacional AJE y al Protocolo de Verificación.

Voz consolidada (Edición Final).* Este capítulo no lleva apéndices al cierre: la doctrina, el análisis económico, el derecho comparado, la jurisprudencia y la mirada del

socio internacional viven dentro del razonamiento, en las secciones donde hacen falta. Ver el vacío C-1* y el método en la Auditoría de la Edición Final.



FIN DE LA OBRA

*«No naciste para quedarte en el estanque.
Trabaja en silencio; deja que el resultado haga el ruido.»*

Elias Alejo
Biblioteca Jurídica AJE — Manual para Ejercer el Derecho
Corporativo
Agosto de 2026

Universidad Nacional Autónoma de México · Facultad de Estudios
Superiores Aragón